

제1강 물권법 일반론 및 물권의 본질과 종류

♣ 학습목표

1. 물권법의 의의를 정리할 수 있다.
2. 물권의 본질과 그 객체를 정리할 수 있다.
3. 물권법정주의를 살펴보고 물권의 종류를 정리할 수 있다.

♣ 학습내용

- 물권법의 개념·법원·특질
- 물권과 채권의 비교
- 물권의 객체
- 물권법정주의
- 물권의 종류

♣ 사전 테스트

1. 물권법은 대체로 임의규정으로 이루어져 있다.
⇒ × : 물권법은 물건에 대한 배타적 지배관계를 규율하므로 대개 강행규정으로 구성되어 있는 반면, 채권법은 사적자치의 원칙이 강조되어 대부분 임의규정으로 구성된다.
2. 물권은 청구권이다.
⇒ × : 물권은 물건을 직접·배타적으로 지배하는 권리로서, 권리의 작용에 따른 분류상 지배권에 속한다.
3. 민법 제1조의 “법률”은 성문법 전체를 의미하지만, 제185조에서의 “법률”은 형식적 의미의 법률만을 의미한다.
⇒ ○ : 물권은 사유재산제의 근간이 되는 것이므로 행정부의 명령·규칙으로 그 내용을 정하는 것은 허용될 수 없다고 이해된다. 따라서 제185조에서의 “법률”은 민법이나 가등기담보법 등 국회가 제정한 형식적 의미의 법률만을 의미하는 것으로 본다.

※ 제1조 (법원) 민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고, 관습법이 없으면 조리에 의한다. → 민법 제1조는 민사에 관하여 민법의 법원으로 인정되는 범위와 그들 간의 적용 순위를 정하고 있다.

제185조 (물권의 종류) 물권은 법률 또는 관습법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다.

♣ 강의교안

I. 물권법의 의의

1. 개념

특정한 물건 기타 객체를 직접·배타적으로 지배할 수 있는 권리가 물권.

- 형식적 의미의 물권법 : 제2편 「물권법」(제185조- 제372조)
- 실질적 의미의 물권법 : 민법전의 물권편뿐만 아니라 물권에 대한 특별법 등을 포함하여, 사람이 물건 기타 객체(예를 들어 저당권의 객체인 지상권이나 전세권)를 직접 지배·이용하는 재산관계를 규율하는 사법 전체

※ 배타적 지배의 인정 이유 : 사유재산제를 정착시키고 물적 질서 확립하여 법적 안정성 도모

2. 물권법의 법원(제185조)

- 법률 : 민법 제2편(물권) 및 기타 특별법
- 관습법 : 보충적 효력설 / 대등적 효력설
- '물권을 임의로 창설하지 못한다'는 말은 두 가지 의미

하나는 종류강제다. 법률 또는 관습법이 인정하지 않는 새로운 물권의 종류를 약정으로 만들지 못한다.

- 우리 민법은 소유권, 점유권, 지상권, 지역권, 전세권, 유치권, 질권, 저당권 이렇게 8가지 종류의 물권만을 인정하고 있다. 그런데 만약 담보지상권이라는 새로운 종류의 물권을 당사자 간의 약정으로 만든다면, 이는 물권법정주의의 종류 강제에 반한다.

- 다른 하나는 내용강제다. 법률 또는 관습법이 인정하는 물권도, 그 물권의 내용을 법이 정한 내용과 다른 내용으로 정하지 못한다.

가령 우리 민법의 물권 중 저당권에 대해서는 저당권자의 점유적 효력이 인정되지 않는다. 저당권자는 저당물을 점유할 수 없고, 저당권설정자가 점유해야 한다는 것이다. 그런데 당사자들끼리 저당권의 내용을 바꾸어 저당권자가 저당물을 점유할 수 있는 저당권을 창설한다면 이는 내용 강제에 반한다고 할 것이다.

3. 물권법의 특징

- 강행규정성(물권법정주의)
- 고유법성(∴ 전세권)

II. 물권의 의의

1. 물권의 본질

(1) 재산권(당연 양도성) : 물건 기타 객체를 지배하여 이익을 얻는 권리

[당연 양도성 예외]

㉠ 제292조(부종성) ㉡지역권은 요역지와 분리하여 양도하거나 다른 권리의 목적으로 하지 못한다.

㉢ 제361조(저당권의 처분제한) 저당권은 그 담보한 채권과 분리하여 타인에게 양도하거나 다른 채권의 담보로 하지 못한다.

(2) 절대권 : 특정의 상대방이 아니라 모든 사람들에게 주장 → 追及力(물권적청구권)

추급력 : 저당물의 소유자가 바뀌어도 계속 저당권을 실행할 수 있다는 의미(저당권과 같은 담보물권의 경우 물건 있는 곳에 끝까지 따라가 효력을 발휘)

(3) 지배권 : 물권은 대내적으로 물건을 직접 지배하는 권리이고, 대외적으로는 배타적인 권리.

1) 직접적 지배 : 타인의 협력을 매개하지 않고 스스로 물건으로부터 이익을 얻는다.

2) 배타적 지배 : 타인의 간섭을 배제하고 독점적으로 이익을 누린다. → 물권적 청구권

즉 외부의 모든 자에 대한 불가침의무(그 결과 제3자의 물권침해는 원칙적으로 위법하여 불법행위가 성립한다) → 따라서 권리자, 권리의 내용, 물권의 대상(물건)의 특징이 확정되어야 함. 결국 물권의 존재를 외부에 알리는 공시제도가 중요한 의미가 있음.

※ 물권과 채권의 비교

물권	人-物	물건	대물권	직접·배타	지배권	절대권	대부분 강행규정 : 물권법정주의 → 공시 중요
채권	人-人	급부 : 채무자의 행위	대인권	간접·병존	청구권	상대권	대부분 임의규정(사적자치 강조) : 비전형·무명계약도 유효

2. 물권의 객체

: '특정의 독립한 물건'을 객체로 함

(1) 물건일 것(물건성)

- 광업권, 조광권, 어업권도 물건을 전속적 취득할 수 있는 권리이므로 물권에 준하며 지식재산권도 마찬가지임)

※ 광업권(탐사권+채굴권)이란 광물을 탐사하고 채굴할 수 있는 배타적인 권리로, 물건을 직접 지배하지는 않지만 물건을 배타적으로 취득할 수 있는 준물권적 권리

※ 조광권은 광업권자의 광구를 제3자가 대신 개발할 수 있는 권리로 채굴권만 대상이 된다.

※ 知識財産權 / Intellectual Property Rights (IP; IPR) ; 지식재산권이란 기존의 유형적인 재산을 보호하고 권리를 부여하는 고전적인 재산권에서 벗어나, 무형의 지식, 즉 교육, 연구, 문화, 예술, 기술 등등 인간이 창조한 모든 것에 대한 재산권을 보호하고 권리를 부여한다. 인간이 적극적으로 창작을 할 수 있도록 보호해주는 장치라고 할 수 있다. 과거에는 지적재산권(知的財産權)이라고 불렀다가 현재 한국특허청(KIPO)에서는 지식재산권이라는 용어를 사용하며, 줄여서 지재권으로 부르기도 한다. 현재 '지식재산권'이 정식 용어이기는 하지만, 아직도 다수의 법령에서 '지적재산권'이나 '무체재산권'이라는 용어가 혼용되고 있다.

대한민국에서 보호하는 지재권은 크게 3가지 카테고리로 분류된다.

- 1) 산업분야의 산업재산권(특허법, 실용신안법, 상표법, 디자인보호법 등)
- 2) 문화예술분야의 저작권법
- 3) 반도체 배치설계법을 비롯한 사회/기술의 변화에 따른 새로운 형태의 신지식재산권

- 물건 이외 : 재산권을 객체로 하는 경우(권리질권(제345조 : 채권질권, 주식질권, 지식재산권질권), 재산권의 준점유(제210조), 재산권의 준공동소유(제278조), 유가증권에 대한 유치권(제320조), 지상권 또는 전세권을 목적으로 하는 저당권(제371조))

제98조(물건의 정의)

본법에서 물건이라 함은 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력을 말한다.

→ 물건 : 유체물 + 무체물, 권리주체 외의 물질

▶ 돌발 퀴즈

시체는 물건인가? : ○

(재산권 V. 인격권)

- 물건성

· 긍정설 : 다수설·판례(대판(전합) 2008.11.20., 2007다27670)

· 부정설 : 미이라나 학술용 골격과 같이 인간의 존엄과 가치를 자극하지 않는 경우 이외에는 부정, 사자인격권의 인정 필요, 가족의 사자공양권설 내지 방어권을 인정하자는 견해

- 성질 : “매장·제사·공양 등을 할 수 있는 권능과 의무를 내용으로 하는 특수한” 소유권설(다수설·판례), 관습법상 관리권설, 사자공양권설

- 소유자 : 제사용 재산의 승계권자 --> 1차(협의) / 2차 (협의 X --> 장남(장손자))

(2) 독립성

- 토지(지번으로 등록)/ 건물(건축정도, 건축자의 의도, 용도)

- 물건의 일부나 그 구성부분?

· 원칙 : 물권의 객체 X (공시곤란하기 때문)

· 예외 : 용익물권(공시 필요 : 부동산법 제69조·제70조·제72조), 구분지상권

(3) 특정성

→ 물권의 객체가 「불특정」하거나 「현존」하지 않는 물건에는 물권이 성립하지 않는 것이 원칙이다. 사과 한 상자 등과 같은 종류물(불특정물) 위에는 채권은 성립할 수 있어도 구체적으로 어느 사과 한 상자인지를 알 수 없어서 배타적 지배를 인정할 수 없기 때문.

- 집합물은 특정성이 없어 일물일권주의에 반하는가?

→ 원칙 : 수개의 물건 / 예외 : 1개의 물건(①사회적 요청 + ②공시(특정))

공장 및 광업재단저당법(제10조·제52조) 일정한 재산이나 권리를 재단으로 하여 하나의 물건으로 보아 그 전체에 하나의 저당권 설정

- 명문의 규정이 없는 경우 “집합물” 개념 인정할 수 있는가?

· 부정설 : 일물일권주의에 반함

· 긍정설(다수설·판례) : 단일한 경제적 가치를 가지고 거래상 일체로서 다루어질 수 있고, 특정의 방법을 갖추면 통상의 양도담보와 마찬가지로 점유개정의 방법으로 공시할 수 있다. 따라서 수시로 그 내용이 변동하는 집합물(즉 유동집합물)에 관하여도 양도담보를 인정하고 있다(대판 1988. 10. 25, 85누941 : 대판 1990. 12. 26, 88다카20224 : 대판 1996. 9. 10, 96다25463 : 대판 2003. 3. 14, 2002다72385 : 대판 2004. 11. 12, 2004다22858).

(4) 일물일권주의

1) 의의

하나의 물건에 대하여 하나의 물권을 인정하는 원칙이 一物一權主義이다. 물건의 일부나 구성부분에 관하여는 물권이 성립되지 않으며, 수개의 물건 위에 1개의 물권의 성립이 인정되지 않고, 동일한 물건 위에 서로 양립하지 않는 내용의 물권이 성립할 수 없다. 그러나 소유권과 제한물권과 같이 서로 양립할 수 있는 물권의 경우에는 동일물 위에 동시에 성립할 수 있다.

(인정근거 : 공시 곤란 → 거래의 안전 보호에 미흡)

2) 독립한 물건의 판단기준

하나의 獨立한 物件이나의 여부를 정하는 표준은 물리적 관념 또는 사회 일반의 거래관념에 의하여 결정된다. 동산은 물리적으로 분리되어 있고 독립성의 인정이 용이하게 결정되지만, 특히 문제가 되는 것은 토지와 건물

가) 토지

① 원칙 (지적공부 기준; 대판 2007. 1. 11, 2004다23523)

[판례]

토지의 사정 당시 소유자를 달리하던 토지들이 분필 또는 합필되지 않은 채 사정 당시 등록된 그대로인 경우, 사정이 당연히 무효라는 등 특별한 사정이 없는 이상 각 토지의 경계는 사정 당시 등록된 지적공부인 지적도상의 경계에 따라야 한다(대판 2007. 1. 11, 2004다23523).

② 예외 (실제 경계기준; 대판 1996. 4. 23, 95다54761 등)

[판례]

지적도를 작성함에 있어 기점을 잘못 선택하는 등의 기술적인 착오로 말미암아 지적도상의 경계가 진실한 경계선과 다르게 잘못 작성되었다는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 그 토지의 경계는 지적도에 의하지 않고 실제의 경계에 의하여 확정하여야 한다고 판시하고 있다(대판 1996. 4. 23, 95다54761 : 1986. 10. 14, 84다카490 : 1993. 10. 8, 92다44503 : 1995. 4. 14 : 94다57879 : 대판 1998. 6. 26, 97다42823 등 참조).

나) 건물(사회통념) : 기동 지붕, 둘레 벽이 있는 경우

[판례]

건물이 증축된 경우에 증축 부분이 기존건물에 부합된 것으로 볼 것인가 아닌가 하는 점은 증축 부분이 기존건물에 부착된 물리적 구조뿐만 아니라, 그 용도와 기능의 면에서 기존건물과 독립한 경제적 효용을 가지고 거래상 별개의 소유권 객체가 될 수 있는지의 여부 및 증축하여 이를 소유하는 자의 의사 등을 종합하여 판단하고 있다(대판 2002. 10. 25, 2000다63110).

3) 일물일권주의 위반의 효과

물권적 합의는 원칙적으로 무효/ 다만 토지의 일부에 대한 매매계약과 같이 일물일권주의를 위반한 채권행위는 특별한 사정(예를 들어 토지의 분할이 허용되지 않는 사정)이 없는 한 유효이다.

4) 일물일권주의의 예외 : 용익물권(공시 필요 : 부동산 제69조·제70조·제72조), 구분지상권, 수목(권원에 의하여 식자한 자 소유), 입목, 명인방법을 갖춘 수목의 집단, 명인방법을 갖춘 미분리 과실, 농작물, 집합물(공장 및 광업재단 저당법 등)

3. 물권법정주의

제185조(물권의 종류)

물권은 법률 또는 관습법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다.

(1) 의의

물권의 종류와 내용은 법률이 정하는 것에 한하여 인정되며, 당사자가 그 밖의 물권을 자유로이 창설하는 것을 금한다.

∴ 배타적 지배권이기 때문에 공시의 원칙 관철 필요(강행규정)

(2) 위반 효력

강행규정인 물권법정주의에 위반하는 새로운 물권을 창설하거나 법정의 내용과 다른 내용의 물권을 약정하는 경우에는 물권적 효력은 무효가 된다(종류강제·내용강제). 다만 당사자 사이에서 채권적 효력은 있다(다수설).

※ 참고 : 연혁

구민법(일본민법)시대의 제175조는 「물권은 본법 기타의 법률에 정한 것 외에는 이를 창설할 수 없다」고 규정하고 있고, 일본의 통설은 동조의 법률에 관습법을 포함한다고 해석하였다. 또한 조선민사령 제12조는 「부동산에 관한 물권의 종류 및 효력에 대하여는 제1조의 법률(구민법)에 정하는 물권을 제외하고 관습에 의한다」고 규정함으로써 구민법시대하에서는 관습법상 물권의 창설을 인정하였다. 물론 이러한 주된 이유는 조선민사령 시행당시에 한국의 관습의 조사가 불충분하였기 때문에 여유를 남겨 두고자 한 것이었다. 그런데 민법제정 당시 민법초안의 제176조는 구민법 제175조와 마찬가지로 「법률」에 정하는 것으로 한정하려고 하였으나, 법률에 관습법을 포함한다는 것은 무리한 해석이고 반면에 포함하지 않는 해석을 하게 되면 민법제정 전부터 존재한 관습상의 물권적 권리를 인정할 수 없게 되는 문제점 등을 들어 결국에는 입법태도를 변경하여 관습법에 의한 물권의 창설을 인정하게 되었다(민법안의견서, 66면). 이처럼 법률 이외의 법원 특히 관습법에 의하여서도 물권의 종류와 내용을 정할 수 있다고 규정하는 민법전은 우리 민법이외에는 찾아볼 수 없다.

(3) 물권법정주의의 한계 : 엄격적용시 사회변화에 따라 탄력적 대처 곤란

→ 관습법

→ 특별법 제정(동산·채권 담보 등에 관한 법률)

(4) 내용

1) 법률(국회가 제정하는 형식적 의미의 법률을 의미, 명령·규칙은 제외)

2) 법률과 관습법과의 관계 : 대등적·변경적 효력설 / 보충적 효력설

3) “창설하지 못한다”의 의미 : ① 법률 또는 관습법이 인정하지 않는 새로운 종류의 물권을 만들지 못한다는 것(종류강제), ② 법률 또는 관습법이 인정하는 물권이더라도 법률 또는 관습법이 정하는 것과 다른 내용을 부여하지 못한다는 것(내용강제)을 의미

4. 물권의 종류

(1) 민법상의 물권

1) 소유권 : 사용·수익·처분의 권능을 포함하는 전면적·포괄적 지배권

2) 제한물권 : 소유권의 권능 중 일부를 제한하는 부분적 지배권

· 용익물권 : 용익(사용·수익가치)권능의 제한 - 지상권, 지역권, 전세권

· 담보물권 : 처분(환가가치)권능의 제한 - 유치권, 질권, 저당권

3) 점유권 : 본권과 대비되는 물건에 대한 사실적 지배

(2) 민법 외의 법률에서 정하는 물건

1) 상법 : 상사유치권, 상사질권, 각종의 우선특권

2) 특별법 : 공장·광업재단저당권, 입목저당권, 동산담보권, 자동차·항공기·건설기계·소형선박저당권, 광업권·조광권, 어업권, 가등기담보권, 선박저당권

(3) 관습법상 물건 : 분묘기지권, 관습법상의 법정지상권, 양도담보권 중 일부 등

- 온천권, 근린공원이용권, 사도통행권 등에 대해서는 관습법상 물건성을 부정(판례)

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 재산권으로서 그 성질상 당연히 양도성을 가진다.
- ② 절대권으로서 누구에게나 주장할 수 있다.
- ③ 물건에는 추급력이 인정되지 않는다.
- ④ 타인의 행위를 매개하지 않고 물건을 직접 지배하는 권리이다.
- ⑤ 하나의 물건 위에는 내용이 상충되는 수개의 물권이 존재할 수 없다.

③. 물건은 절대적으로서 목적물이 제3자에게 인도되더라도 물건자는 원칙적으로 점유자에 대하여 권리내용의 실현을 청구할 수 있는 추급력을 가진다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 물권의 객체는 원칙적으로 물건이지만, 권리를 대상으로 하는 경우도 있다.
- ② 일물일권주의 원칙상 집합물 위에는 하나의 물권이 성립할 수 없다.
- ③ 용익물권은 토지나 건물의 일부에도 설정될 수 있다.
- ④ 지상공간의 일부나 지하의 일부만을 대상으로 하는 구분지상권도 설정 가능하다.
- ⑤ 지중의 일정한 광물은 채굴되지 않았더라도 독립된 물건으로서 광업권의 객체가 된다.

②. 판례는 양식장의 뱀장어, 돈사의 돼지 등 특정성을 조건으로 유동집합물의 개념을 긍정하고, 이를 하나의 물건으로 취급하여 하나의 물권의 성립을 인정하고 있다(대판 1988. 10. 25, 85누941; 대판 2003. 3. 14, 2002다72385; 대판 2004. 11. 12, 2004다22858).

3. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 물권의 종류와 내용은 법률과 관습법이 정하는 것에 한정된다.
- ② 가등기담보권은 물건법정주의에 위반된다.
- ③ 관습상의 사도통행권은 관습법상의 물건이다.
- ④ 물건법에서는 유형선택의 자유 대신 내용형성의 자유가 인정된다.
- ⑤ 부동산에 대하여 질권을 설정할 수 있다.

①. 가등기담보권은 가등기담보법에서 규율되는 특별법상의 물건이다. 사도통행권은 관습법상의 물건으로 인정되지 않았다. 물건법정주의에 따라 유형선택의 자유만이 인정된다고 볼 수 있다. 질권은 동산과 권리를 대상으로 한다.

♣ 학습정리

1. 물권은 특정한 물건을 직접·배타적으로 지배할 수 있는 권리이다.
2. 일물일권주의의 원칙상 1개의 물권의 객체는 1개의 독립한 물건이어야 한다. 그러나 사회적 필요성이 있는 경우에는 일정한 예외를 인정할 수 있는데, 용익물권, 구분지상권, 미분리의 과실, 유동집합물 등이 그것이다.
3. 물권은 법률 및 관습법이 정하는 것 외에는 임의로 창설하지 못하므로, 물권의 종류와 내용에 관하여 당사자가 이와 다른 약정을 하는 것은 금지된다.

제2강 물권의 효력

♣ 학습목표

1. 물권의 우선적 효력에 대하여 설명할 수 있다.
2. 물권적 청구권을 정리할 수 있다.

♣ 학습내용

- 물권 상호간의 우선적 효력
- 채권에 우선하는 효력
- 물권적 청구권의 성립요건 및 내용
- 비용부담의 문제
- 다른 청구권과의 관계

♣ 사전 테스트

1. 일물일권주의에 따라 하나의 부동산에는 수개의 지당권이 설정될 수 없다.
⇒ × : 지당권은 부동산의 점유를 수반하지 않고 교환가치만에 대한 것이므로, 부동산의 가액에서 선순위 지당권의 피담보채권액을 제외한 나머지에 대하여는 후순위 지당권을 설정할 수 있다.
2. 유치권자는 점유권에 기하여 점유보호청구권을 행사할 수 있는 것은 물론이고 본권에 기한 물권적 청구권도 행사할 수 있다.
⇒ × : 유치권은 배타성을 전제로 하지 않는바 본권에 기한 물권적 청구권이 인정될 수 없다.
3. 소유권에 기한 물권적 청구권은 소멸시효에 걸리지 않는다.
⇒ ○ : 판례는 매매계약의 합의해제에 따른 매도인의 원상회복청구권을 소유권에 기한 물권적 청구권으로 보고 소멸시효의 대상이 되지 않는다고 하였다.

♣ 강의교안

I. 서설

1. 직접성(대내적) → 타인의 행위를 매개하지 않고 스스로 물건을 지배하여 그로부터 수익을 얻는다는 것
2. 배타성(대외적) → 누구에 대해서도 주장할 수 있고 어떠한 침해로부터도 보호된다는 것 → 우선적 효력 / 물권적 청구권

II. 우선적 효력

- 하나의 물건 위에 수개의 권리가 경합하는 경우 다른 권리에 우선하는 효력

1. 물권 상호간의 우선적 효력

- 일물일권주의에 따라서 하나의 물건 위에 성립한 양립할 수 없는 수개의 물권 상호간에는 시간적으로 우선 성립한 물권이 우선한다. 순위의 원칙(성립의 선후, 등기의 선후)
다만 배타성 없는 점유권은 우선적 효력을 갖지 않는다.

▶ 돌발 퀴즈

소유권과 제한물권이 경합하는 경우 일반적으로 소유권이 우선한다.

⇒ × : 제한물권은 용익물권과 담보물권으로 나뉘는데, 용익물권은 소유권의 권능 중 사용·수익가치를 제한하고 담보물권은 소유권의 권능 중 처분가치를 제한한다. 이처럼 제한물권은 소유권의 권능을 제한하는 것이므로 당해 권능과 관련하여서는 제한물권이 우선한다.

- 소유권과 제한물권(소유권 < 제한물권)
- 제한물권 상호간(상호간 우선순위, 등기순위), 저당권 상호간
- 점유권은 배타성이 없으므로 다른 물권과 달리 우선적 효력 없음

2. 채권에 우선하는 효력

- 시간적 선후에 관계없이 물권은 채권에 우선 : 물권은 물건에 대한 직접적 지배권인 반면, 채권은 채무자의 행위를 통하여 간접적으로 물건에 대한 지배를 미치는 권리
 - 소유자의 환취권, 제3자 이의의 소
 - 담보권자의 별제권, 회생담보권
- 예외
 - 임금 등 채권의 우선특권,
 - 주택·상가임대차에서의 소액보증금에 대한 우선특권
 - 조세우선특권
 - 가등기된 부동산물권변동에 관한 청구권
 - 등기된 부동산임차권
 - 대항력을 갖춘 주택·상가임차권

※ 추급효

물권의 일반적 효력으로 추급효를 드는 견해도 있으나 이는 우선적 효력이나 물권적 청구권의 행사에 의해 실현되는 것으로 통설은 추급효를 별개의 독립한 물권의 일반적 효력으로 다루지 않는다.

III. 물권적 청구권

1. 서설

- 지배권인 물권의 내용의 실현을 보장하기 위한 실체법상 권리

[참고]

금전은 특수한 물건으로 보아 가치의 표상이므로 물권적 청구권이 인정되지 않고 부당이득반환청구권이 문제될 뿐이다.(단 금전이 물성 자체를 중시하는 경우(예 : 기념주화)는 물건으로 취급)

2. 종류

- 반환청구권, 방해제거청구권, 방해예방청구권

(1) 소유권에 기한 물권적 청구권(제213조·제214조)

- 기타 물권 준용(질권은 준용규정 없으나 학설 판례는 인정)
- 대항력 갖춘 부동산 임차권에 소유권에 기한 물권적 청구권 유추적용(다수설, 판례)
- 대항력 없는 부동산 임차권은 소유자의 소유권에 기한 물권적 청구권 대위행사

(2) 점유보호청구권(제204조 내지 제206조)

- 유치권은 명문규정 없으나 점유보호청구권에 의해 보호
- 대항력 없는 부동산 임차권은 점유보호청구권에 의해 보호

3. 물권적 청구권의 일반적 성립요건

- 주체 : 현재의 물권자(재판상 청구시에는 사실심 변론 종결시)
 - 물권적 청구권은 물권과 분리하여 처분하지 못한다.
- 상대방 : 현재 물권의 실현을 방해하고 있는 자(예를 들어 창고 보관자)
- 상대방의 귀책사유는 요구되지 않는다
- 침해를 정당화하는 사유가 있는 경우 물권적 청구가 허용되지 않는다.

4. 물권적 청구권의 내용

(1) 법적 성질

- 물권에 부종하는 특수한 청구권(다수설) : 물권에 의존한다는 점에서 물권적 성질, 특정인에 대한 청구권이라는 점에서 채권적 성질

(2) 소멸시효의 대상적격

: 물권이 존재하는 한 독자적으로 소멸시효에 걸리지 않는가?

① 부정설(다수설) : 침해는 나날이 발생, 물권의 실효성 보장

- 판례는 소유권에 기한 물권적 청구권은 소멸시효에 걸리지 않는다고 한다.

② 긍정설 : 재산권이므로 20년 시효소멸 긍정

③ 제한적 긍정설 : 소유권 X, 제한물권 O

(3) 비용부담의 문제

- 청구권과 비용부담의 문제를 별개의 문제로 보는 견해
- 청구권의 내용 내지 본질이 비용부담의 문제라고 보는 견해
- 행위청구권설(판례) : 상대방의 귀책사유를 불문하고 상대방의 비용·노력으로 하여야 한다는 견해
- 소유자책임설 : 원칙적으로 행위청구권이지만 반환청구의 경우에는 예외 인정, 상대방의 점유설정의사가 없는 경우 수거허용청구권을 인정
- 책임설 : 방해상태가 상대방의 귀책사유로 인한 것이라면 행위·비용을 청구할 수 있으나, 천재지변 또는 제3자 행위에 의한 경우와 같이 상대방이 무책임 경우 상대방에 대하여 인용하도록 함에 그치고 물권자가 비용부담
- 인용청구권설 : 상대방에 대하여 인용을 청구하는 것에 그치고 비용부담의 문제는 불법행위나 계약법 등의 책임원리로써 결정

- Q : A(소유자)의 반환청구권 V. B(점유자?)의 방해배제청구권

- ① 점유설정의사 없는 경우 : 반환청구권 발생 하지 않음. 다만 A의 수거를 B가 방해하면 B의 소유권 남용 내지 방해시부터의 (불법)점유가 될 수 있어 반환청구권이 발생할 수 있음
- ② 점유설정의사 있는 경우
 - 점유자가 자신을 위해 점유하는 경우 → 전형적인 불법점유로 반환청구권 발생
 - 점유자가 소유자를 위해 점유하는 경우 → 사무관리에 따라 제734조 이하 규율
- ③ 결론 : 반환청구권과 방해배제청구권이 경합하는 경우는 실제로 없다.

5. 다른 청구권과의 관계

(1) 계약상의 청구권과 경합 가능

- 계약에 의한 용익관계가 종료된 경우 물권적 청구권 외에 계약에 따른 반환청구권도 발생하고 양자는 경합
- 피담보채무의 소멸로 저당권이 소멸된 경우 종전 소유자는 물권적 청구권은 행사할 수 없지만 근저당권설정계약상의 당사자로서 계약상 권리에 기하여 등기말소청구권을 행사 가능

(2) 불법행위로 인한 손해배상청구와 병존 가능

- 불법행위에 기한 손해배상청구권 : 귀책성, 위법성 → 요건의 엄격성// 금전배상 → 효과의 확실성
 - 물권적 청구권 : 귀책성 불요, 정당화 없을 것 → 요건의 단순성// 행위(작위, 부작위)청구 → 효과의 유연성
- (인격권 침해시 불법행위 손해배상 외에 명예회복에 적당한 처분청구권)

(3) 부당이득반환청구권 :

- 타인의 물건을 무단 점유하여 사용한 경우
- 소유권에 기한 반환청구 및 그 사용이익에 대한 부당이득반환청구인정 (부당이득 반환 범위 제201조 이하 적용)

Q : 매매계약이 무효·취소된 경우?

- : 점유부당이득 인정 그리고 소유권에 기한 물권적 청구권도 인정 → 경합가능(통설·판례)

(다만 소수설은 급부부당이득의 경우, 물권행위의 무인성을 인정하면서 무인성에 의해 물권적 청구권은 발생하지 않고 경합도 발생하지 않는다고 한다)

Q : 위의 경우 부당이득 반환 범위는?(단, 해제의 경우는 원상회복청구로 다루어 반환범위는 제548조 적용)

→ 다수설·판례 : 부당이득 반환 범위 제201조 이하 적용(제201조는 특별규정이므로)

→ 소수설 : 부당이득 반환 범위 제748조 이하 적용(급부부당이득의 유형이며 채권법적용영역임)

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 수개의 소유권이 경합하는 경우, 먼저 성립한 소유권이 우선한다.
- ② 소유권과 제한물권이 경합하는 경우, 제한물권이 우선한다.
- ③ 수개의 저당권이 동시에 설정될 수 있다.
- ④ 원칙적으로 물권은 그보다 먼저 성립한 채권에 대해서도 우선적 효력을 갖는다.
- ⑤ 등기된 부동산임차권이나 대항력 있는 주택임차권은 채권이므로 물권에 우선할 수 없다.

⑤. 이 경우 물권과 유사한 효력이 인정되어 그보다 나중에 성립한 물권에 우선한다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 일반적으로 금전의 점유가 침탈된 경우 물권적 청구권이 인정되지 않으나, 기념주화와 같은 경우 물권적 청구가 가능하다.
- ② 점유권에 기한 물권적 청구권과 본권에 기한 물권적 청구권은 경합할 수 있다.
- ③ 물권적 청구권을 소유권과 분리하여 소유권 없는 전 소유자에게 유보하여 행사하게 하는 것은 허용될 수 없다.
- ④ 임차인은 소유자인 임대인의 물권적 청구권을 대위행사할 수 있다.
- ⑤ 물권적 청구권은 물권을 기초로 하므로 채권적 청구권에 우선한다.

②. 점유를 수반하는 본권이 침해된 경우에는 본권에 기한 물권적 청구권과 점유보호청구권이 모두 발생할 수 있다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 소유자가 실체관계에 부합하지 않는 등기의 명의인을 상대로 등기말소청구를 한 이후 소유권을 상실한 경우, 물권적 청구권을 물론이고 이행불능을 이유로 전보배상청구를 할 수 없다.
- ② 소유권에 기한 물권적 청구권은 소멸시효에 걸리지 않는다.
- ③ 물권적 청구권에서의 비용부담 문제와 관련하여 판례는 기본적으로 상대방이 비용을 부담한다는 입장을 취한다.
- ④ 피담보채무의 변제로 저당권도 소멸되었다면 종전의 소유자는 물권적 청구권을 행사할 수 없는바 저당권등기의 말소를 청구할 수 없다.
- ⑤ 물권적 청구권의 행사가 가능한 경우에는 부당이득반환청구권이 인정될 여지가 없다.

- ⑤. 점유의 반환이라고 하는 소유권의 관철 측면에서는 물권적 청구권이 적용되고, 급부청산의 측면에서는 부당이득반환청구권이 적용되므로 양자는 경합한다.

♣ 학습정리

1. 물권의 대외적·배타적 지배력으로부터 물권의 우선적 효력과 물권적 청구권이 도출된다.
2. 원칙적으로 물권 상호간에는 먼저 성립한 물권이 우선하고, 물권과 채권 간에는 물권이 우선한다.
3. 물권적 청구권은 일정한 경우 반환·방해제거·방해예방의 청구를 할 수 있는 권리이다.
4. 소유권의 실현이 방해받는 상태가 존재하는 한 물권적 청구권은 끊임없이 발생하므로 소유권에 기한 물권적 청구권은 소멸시효의 대상이 아니다.
5. 우리 판례는 물권적 청구권이 행위청구권임을 밝히고 있으므로, 판례의 입장에 따를 경우 상대방이 그 비용을 부담해야 한다.
6. 물권적 청구권은 계약상의 청구권, 불법행위로 인한 손해배상청구권, 부당이득반환청구권 등과 경합할 수 있다.

제3강 물권변동 일반론 및 공시제도

♣ 학습목표

1. 물권변동의 유형을 정리할 수 있다.
2. 공시의 원칙과 공신의 원칙을 설명할 수 있다.
3. 물권변동과 공시방법의 관계에 관한 의사주의와 형식주의를 정리할 수 있다.
4. 물권행위의 독자성 및 무인성 인정 여부에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 물권변동의 유형
- 공시의 원칙, 공신의 원칙
- 물권행위의 개념 및 적용법규
- 의사주의, 형식주의
- 물권행위의 독자성 인정 여부
- 물권행위의 무인성 인정 여부

♣ 사전 테스트

1. 등기, 점유(또는 인도) 외의 공시방법은 인정될 수 없다.
⇒ × : 부동산에 관한 등기, 동산에 관한 점유 또는 인도, 입목법상 입목등기, 수목의 집단 및 미분리과실에 관한 명인방법, 특별법상의 일정한 동산에 대한 등기·등록도 공시방법으로서 인정되고 있다.
2. 우리 민법은 부동산에 관하여는 공신의 원칙을 인정하고 있으나, 동산의 경우에는 그렇지 아니다.
⇒ × : 부동산의 등기에 관하여는 공신의 원칙을 인정하지 않고, 동산의 점유(인도)에 대하여는 선의취득을 허용하여 공신의 원칙을 인정하고 있다.
3. 우리 민법은 물권변동과 공시방법 간의 관계에 있어서 의사주의를 채택하고 있다.
⇒ × : 형식주의를 채택하여 물권적 의사표시 이외에 등기 내지 인도라는 공시방법을 갖추어야 물권변동이 일어나는 것으로 하고 있다.

♣ 강의교안

I. 물권변동 서설

1. 물권변동의 의의 : 물권의 발생·변경·소멸

- 권리주체의 입장에서 물권의 취득·변경·상실을 의미

2. 물권변동의 유형

(1) 법률행위에 의한 물권변동 / 법률행위에 의하지 않은 물권변동

1) 법률행위에 의한 물권변동

- 부동산 : 제186조
- 동산 : 제188조 내지 제190조

2) 법률행위에 의하지 않은 물권변동(* 법률의 규정에 의한 물권변동이라고도 하지만 건물 신축·멸실에 의한 소유권 취득·소멸과 같이 법률의 규정이 없는 경우도 일반적으로 포함하여 통칭)

: 상속, 공용징수, 판결, 경매, 취득시효, 무주물 선점, 유실물, 습득, 매장물 발견, 침부/ 소멸시효, 혼동, 몰수 등

- 부동산 : 187조, 191조, 305조, 366조, 482조, 649조, 1005조 등
- 동산 : 246조, 249조, 252조, 253조, 254조, 257조, 1005조 등

(2) 부동산물권변동(제186조 - 제187조) / '양도'에 의한 동산물권변동(제188조 - 제190조)

(3) 소유권의 변동 / 제한물권의 변동

※ 물권의 발생 · 변경 · 소멸

물권의 발생	절대적 발생(원시취득)		
	상대적 발생(승계취득)	포괄승계	
		특정승계	이전적 승계 설정적 승계
물권의 변경	주체의 변경		
	작용의 변경		
	내용의 변경	질적 변경	양적 변경
물권의 소멸	절대적 소멸		
	상대적 소멸		

- 원시취득 - 건물 신축, 취득시효, 선의취득, 선점, 습득, 발견, 침부
- 포괄승계 - 상속, 포괄유증, 합병
- 이전적 승계 - 매매, 상속
- 설정적 승계 - 제한물권의 설정
- 주체의 변경 - 이전적 승계에 해당
- 작용의 변경 - 선순위 저당권 소멸로 후순위 저당권 순위 승진
- 질적 변경 - 물상대위
- 양적 변경 - 침부에 의한 대상 물건의 증감
- 절대적 소멸 - 목적물 멸실
- 상대적 소멸 - 이전적 승계에 해당(기존 물권자의 입장에서)

II. 물건변동과 공시

배타성에 따라 우선적 효력을 갖는 물권의 존재와 변동은 외부에서 알 수 있도록 공시하여야 물권을 거래하는 자를 보호할 수 있다. 이를 위해서는 「공시의 원칙」과 「공신의 원칙」의 양자나 또는 어느 하나를 인정하여야만 한다. 우리 민법은 부동산에는 공시의 원칙(제186조)만을, 동산에는 두 원칙(제188조 내지 제190조, 제249조)을 모두 인정

- 독일민법 : 부동산·동산에 두 원칙을 모두 인정
- 프랑스민법 : 부동산에는 공시의 원칙만을 동산에는 공신의 원칙만을 인정

1. 공시의 원칙

(1) 의의 : 물권의 존재 및 변동은 언제나 외부에서 인식할 수 있는 표상, 즉 공시방법을 갖추어야 한다는 원칙

(2) 공시의 원칙을 관철하는 방법

- ① 성립요건주의 또는 형식주의 : 공시방법이 없으면 제3자에 대하여는 물론 당사자 사이에도 물건변동을 인정하지 않는다(우리 현행민법, 독일민법, 스위스민법).
- ② 대항요건주의 또는 의사주의 : 당사자 사이에는 물건변동이 일어나지만 공시방법을 갖추지 않으면 제3자에 대항하지 못하는 것으로 한다(프랑스민법, 일본민법, 우리 구민법(의용민법))

(3) 현행법상 공시방법

① 부동산 - 등기

② 동산 - 인도(또는 점유)

* 예외

- 동산·채권 담보 등에 관한 법률상 동산·채권·지식재산권 - 담보등기, 등록
- 자동차 등 특정동산 저당법상 건설기계·선박(20톤 미만 기선 등)·자동차·항공기 - 등록
- 선박등기법상 선박(20톤 이상 기선 등) - 등기(대항요건)

③ 수목의 집단, 미분리의 과실, 농작물 - 명인방법

(4) 공시의 효과

- ① 권리변동의 효력은 성립요건주의(형식주의) 하에서 공시의 기본적인 효과이다. 즉 부동산물권의 변동은 등기하여야 그 효력이 생기고(186조), 동산에 관한 물권의 양도는 그 동산을 인도하여야 효력이 생긴다(188조 제1항).
- ② 공신력 : 동산만 인정(선의취득)
- ③ 추정력 : 동산물권(점유의 추정력(200조)) / 부동산물권(등기의 추정력 인정 : 학설·판례)

2. 공신의 원칙

(1) 의의 : 일정한 공시방법을 신뢰하고 거래한 경우 그 공시방법이 진정한 권리관계와 일치하지 않더라도 공시된 대로의 권리관계가 존재하는 것처럼 다루어야 한다는 원칙

(2) 현행법상 공신의 원칙

- 부동산물권변동 : 공신의 원칙 인정× (진정한 권리자 보호를 중시)
- 동산물권변동 : 공신의 원칙 인정○ (거래안전 보호를 중시) '동산의 선의취득'
- 등기에 공신력을 인정할 것인가는 입법정책적인 문제(등기제도의 완비유무 등 고려)

(3) 유사제도 : '외관법리'에 기초

- 표현대리
- 채권의 준점유자에 대한 변제
- 영수증소지자에 대한 변제
- 지시채권의 소지인에 대한 변제

III. 물권행위

1. 물권행위의 개념

- 직접 물권의 변동을 목적으로 하는 처분행위
- 물권적 의사표시(의사적 요소)+공시방법(사실적 요소)
- 불요식행위 : 등기·인도 등의 공시방법은 별개의 요소로 보아야 하고, 검인계약서는 등기신청서 제출할 서면의 하나로 요구되는 것에 불과하다.
- 물권적 합의(물권계약)
- 단독행위(물권포기, 승역지 소유자의 위기)
- 합동행위(수인의 공유자가 소유권을 포기 : 단독행위의 경합으로 보는 견해도 있음)

2. 적용법규

법률행위(물권에 관한 법률행위)이므로 민법총칙의 관련규정(법률행위의 요건, 대리, 조건, 추인 등)을 적용한다.

다만 부동산의 경우 해제조건이나 종기는 등기할 수 있으나 정지조건과 시기는 등기할 수 없다.

3. 물권행위와 공시방법의 관계

(1) 의사주의(대항요건주의) : 당사자의 합의만으로 소유권이 이전되고, 등기(일본민법은 인도까지)는 대항요건에 불과하다. 따라서 공시방법을 갖추지 않아도 물권변동의 당사자 간에는 소유권이 이전되지만 공시방법을 갖추지 않는 한 제3자에게 대항할 수 없다(의용민법).
→ 소유권의 상대적 귀속(물권 귀속의 대·내외관계 분리)

(2) 형식주의(성립요건주의) : 당사자 간의 합의 외에도 성립요건으로서의 공시방법을 갖추어야 물권변동이 일어난다. 따라서 공시방법을 갖추지 않는 한 당사자 간에는 물론이고 제3자에 대한 관계에서도 물권변동은 일어나지 않는다(현행민법).

* 의사주의와 형식주의의 문제는 당사자 간의 의사에 기한 물권변동, 즉 법률행위에 의한 물권변동(제186조 및 제188조 제1항)에 한하여 문제되는 것이다.

[참고]

의용민법의 의사주의에서 현행민법의 형식주의로 변경됨에 따른 경과조치로 부칙 제10조 제1항에서는 “6년 내에 등기”하도록 하였다.

의용민법 하에서는 의사주의에 따라 등기 없이도 소유권이 이전된 것으로 보았으므로 매수인의 등기청구권은 물권적 청구권으로서 소멸시효의 대상이 아니었으나, 현행민법상 등기청구권은 채권적 청구권에 불과하다(통설·판례). 통설·판례에 의하면 매매에 의한 소유권 이전등기청구권은 10년 내에 행사하여야 한다.

① 1960. 1. 1.부터 1966. 12. 31까지 기존 미등기 소유자들은 등기하여야 함.

② 1967. 1. 1.부터 등기청구권은 소멸시효 진행하여 1975. 12. 31.에 시효만료

③ 1976. 1. 1.이후에는 등기청구권의 시효소멸로 등기 불가능

→ 소유권은 있으나(특히 매수하여 소유하면서 점유·사용하면서도) 등기청구권은 없는 문제 발생.

따라서 대판(전합) 1976. 11. 6, 76다148에서는, 매매에 의하여 부동산이 인도되면 등기청구권이 시효소멸하지 않는다는 판시를 하였던 것이다(다수의견 : 사용·수익하고 있으므로 권리 위에 잠자고 있는 것이 아니고, 매도인보다 사용수익하고 있는 매수인을 더 보호해야 한다는 것을 근거로 한다).

(3) 물권행위의 구성요소

물권적 의사표시 외에 등기나 인도와 같은 공시방법도 물권행위의 구성요소로 볼 것인가 아니면 물권행위와는 별도의 요소로 볼 것인가?

1) 물권행위 성립요건설 : 물권적 의사표시와 공시방법을 합한 것이 물권행위라는 견해

· 근거 : 등기·인도를 해야만 처분행위로서 이행의 문제없이 물권변동이 이루어진다.

2) 물권행위 효력요건설 : 물권적 의사표시만이 물권행위이고 등기·인도는 물권변동의 효력요건

· 논거 : 제186조의 “등기하여야 효력이 생긴다”, 제188조의 “물권의 양도는 ... 효력이 생긴다”

제186조(부동산물권변동의 효력) 부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다.

제188조(동산물권양도의 효력, 간이인도) ① 동산에 관한 물권의 양도는 그 동산을 인도하여야 효력이 생긴다.

3) 물권변동의 별도의 요건설 : 물권적 의사표시만이 물권행위이고 등기·인도는 물권변동의 별개의 요건

· 논거 : 등기·인도는 물권행위의 효력요건이 아니라 물권변동의 또 다른 요건이고, 물권행위와 등기·인도는 물권변동을 일으키는 동등한 위치에 있는 것으로서 상호 독립적인 것이다.

4) 판례 : 명백하지 않으나, 아래 판례를 이유로 물권행위의 성립요건으로 보는 견해도 있다.

민법 제249조가 규정하는 선의 무과실의 기준시점은 물권행위가 완성되는 때인 것이므로 물권적 합의가 동산의 인도보다 먼저 행하여지면 인도된 때를, 인도가 물권적 합의보다 먼저 행하여지면 물권적 합의가 이루어진 때를 기준으로 해야 한다(대판 1991. 3. 22, 91다70).

▶ 돌발 퀴즈

우리 판례는 물권행위의 독자성을 인정하고 나아가 무인성도 인정한다.

⇒ × : 판례는 물권행위의 독자성을 부정함은 물론이고 무인성 또한 부정하고 있다(물권에 관한 계약해제의 효과에 관하여는 채권적 효과설과 물권적 효과설이 대립되어 있으나, 우리의 법제가 물권행위의 독자성과 무인성을 인정하고 있지 않은 점과 제548조 제1항 단서가 거래안정을 위한 특별규정이란 점을 생각할 때 계약이 해제되면 그 계약의 이행으로 변동이 생겼던 물권은 당연히 그 계약이 없었던 원상태로 복귀한다(대판 1977.5.24, 75다1394)).

4. 물권행위의 독자성

(1) 독자성의 2가지 의미

1) 물권행위는 채권행위와 개념적으로 별개다(개념적 독립성 또는 존재상 독자성)

2) 물권행위는 채권행위와 시기적으로 별개로 행하여지는가?(시기적 독자성이 있는가?)

→ 시기적 독자성은 물권행위의 시기가 불분명한 때에 문제되는데(예를 들어 “토지를 매매한다”), 이러한 독자성을 인정하는 주된 이유는 독자성을 인정하여야만 채권행위와 유인관계에 있는지 또는 무인관계에 있는지를 논할 수 있다.

→ 시기적 독자성을 부정한다고 하더라도 채권행위와 시기적으로 별도로 할 수 있음을 부정하는 것은 아니다.

(2) 학설 및 판례의 태도

1) 독자성 인정설(다수설)

- 통상 채권행위와 등기서류 교부시 간에는 시간적 간격이 존재
- 제186조 “법률행위”, 제188조 “양도”는 물권행위를 의미
- 무인성을 인정하기 위한 전제로서 독자성을 인정할 필요
- 시간적으로 동일하다면 채권행위와 동시에 이행행위가 완성되어 채권행위의 성질에 반함

2) 독자성 부정설(판례)

- 유인론을 취하고 있는 이상 독자성을 인정할 실익이 없다.
- 채권행위를 등기원인으로 기재하는 등기현실
- 거래당사자는 물권행위와 채권행위를 구분한다는 의식이 없음

5. 물권행위의 무인성

(1) 의의

물권행위가 그 원인행위인 채권행위와 별개로 독립하여 행하여진 때에 그 원인행위인 채권행위가 존재하지 않거나 무효·취소 또는 해제된 경우에 그 물권행위의 효력은 그 원인행위인 채권행위에 의하여 아무런 영향을 받지 않는 것을 물권행위의 무인성(채권행위의 부존재·무효·취소·해제→물권행위 유효)이라고 한다. 이에 반하여 그러한 경우에는 물권행위도 당연히 영향을 받는다는 것이 물권행위의 유인성(채권행위의 부존재·무효·취소·해제→물권행위 유효)이다.

물권행위의 유인성·무인성의 문제는 물권행위의 독자성을 인정하는 경우에 비로소 일어나는 문제이다.

* 무인성 인정 여부는 등기청구권, 계약해제, 부당이득반환청구권 등의 해석에서 차이를 보인다.

(2) 논의의 실익

1) 물권행위가 채권행위와 따로 독립하여 행하여질 때에만 문제된다. 따라서 채권행위가 불성립 하였으나 물권행위를 한 경우, 법정추인이 인정되지 않는 무효행위를 이행한 경우, 계약해제의 경우 등에 무인성 여부에 대한 실익이 있다.

* 채권행위와 물권행위가 하나의 행위로 합체된 경우, 법정추인이 되는 경우(채권행위취소사유 후 물권행위를 한 경우), 물권행위에도 실효원인이 존재하는 경우(제103조)에는 무인성 여부를 논할 실익이 없다.

2) 채권행위가 실효된 경우에 이미 이행된 물건의 반환을 구하는 근거가 물권적 청구권이나 아니면 채권적 부당이득반환청구권이나의 차이가 있다.

또한 무인설에 의하면 제3취득자는 선의·악의를 불문하고 보호를 받지만, 유인설에 의하면 제3취득자는 선의라도 보호를 받지 못하고 다만 제3자 보호규정이 있는 경우(무효·취소에 관한 제107조 내지 제110조, 해제에 관한 제548조, 선의취득에 관한 제249조 등)에 한하여 그 규정에 의한 보호를 받을 수 있다.

(3) 학설 및 판례의 태도

1) 무인론

- 채권행위와 물권행위는 별개의 행위이므로(독자성) 그 유효성도 별도로 판단해야 한다.

2) 상대적 무인론

- 아래의 경우에는 예외적으로 유인이라고 하는 견해
- 채권행위의 유효를 물권행위의 조건으로 한 경우
- 채권행위의 하자가 물권행위에도 공통된 경우
- 채권행위와 물권행위가 외형상 1개의 행위로 합체되어 행하여지는 경우

3) 유인론(판례·다수설)

- 채권행위가 실효된 경우 물권행위도 실효되어 물건의 반환에 있어서 부당이득반환청구는 물론이고 물권도 당연 복귀되어 물권에 기한 반환청구가 가능하다.

- 채권행위실효의 경우 물권행위의 효력도 상실한다는 것이 당사자의 의사에 부합
- 무인성설에 의하면 악의의 3자도 보호받게 되는 불합리
- 유인성설에 의하더라도 제3자 보호규정으로 보호받는 경우가 있다.

<사례1> A 소유의 X 부동산을 매수한 B가 자신 명의의 소유권이전등기를 경료하였으나 이후에 A가 매매계약을 취소한 경우

: A가 소유권을 회복할 수 있다는 결과에는 차이가 없고 이론구성의 차이에 불과

- 무인성 인정 : 매매계약을 취소하더라도 물권행위는 유효하므로 B의 소유권 취득에는 영향을 미치지 않고 A는 부당이득반환청구권을 행사할 수 있을 뿐이다. 이 경우 B가 X의 소유권을 보유하고 있어서 원물반환이 가능하므로 소유권을 회복할 수 있다.

- 무인성 부정 : 매매계약을 취소하면 물권행위도 소급하여 실효되고 X의 소유권은 당연히 A에게 복귀된다. 따라서 소유자인 A는 물권적 청구권을 행사하여 등기말소청구 및 점유회복을 청구할 수 있다.

<사례2> 나아가 A의 취소가 있기 전에 B가 X를 C에게 전매하여 C 명의의 소유권이전등기를 경료한 경우

: 악의의 제3취득자 C가 보호될 것인가에서 실제적 차이

- 무인성 인정 : B가 소유권자이므로 그의 유효한 처분행위에 의하여 C(선악불문)에게 소유권이 이전된다. 역시 A는 B에게 부당이득반환청구권(가액반환)을 행사할 수 있을 뿐이다.

- 무인성 부정 : 소유권은 A에게 복귀하므로 B의 C에 대한 전매는 무권리자의 행위로서 A가 추인하지 않는 한 C는 유효하게 소유권을 취득하지 못한다. 다만 제109조 제2항 및 제110조 제3항에서 취소는 선의의 제3자에게 대항할 수 없다고 하므로, C가 선의라면 유효하게 소유권을 취득할 수 있다.

♣ 확인학습문제

1. 공시의 원칙과 공신의 원칙에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 공시방법을 갖추지 않은 경우 물권변동의 효력을 부분적으로 부정하는 법제를 의사주의라고 하고 전면적으로 부정하는 법제를 형식주의라고 한다.
- ② 공시의 효과로는 권리변동의 효력, 공신력, 추정력을 들 수 있고, 이러한 효과는 부동산과 동산 모두에 인정된다.
- ③ 공신의 원칙은 공시의 원칙의 논리적 귀결이 아니라 물권거래의 안전과 신속을 도모하기 위한 별개의 제도이다.
- ④ 공신의 원칙을 인정하면 동적 안전을 강조하고 정적 안전은 소홀히 하게 된다.
- ⑤ 공신의 원칙과 유사한 제도로는 표현대리, 채권의 준점유자에 대한 변제 등을 들 수 있다.

②. 공신력은 동산에 관하여만 인정되고(동산의 선의취득), 부동산에 관하여는 인정되지 않는다.

2. 물권행위의 독자성에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 매매계약을 체결하면서 별도로 물권변동을 목적으로 하는 어떤 행위를 나중에 따로 하기로 합의하지 않은 경우에 부동산이라면 등기에 필요한 서류의 교부시, 동산이라면 인도시에 물권행위가 있는 것으로 본다.
- ② 물권행위의 독자성 인정 여부는 물권변동과 공시방법의 관계에 관한 입법주의와 논리필연적 관계에 있다.
- ③ 물권행위의 독자성을 인정한다고 하여 동산의 현실매매와 같이 채권행위와 물권행위가 하나의 행위로 합체되어 행하여질 수 있음을 부정하는 것은 아니다.
- ④ 물권행위의 독자성을 부정한다고 하여 매매대금이 전부 지급되기 전에 어느 특정시점에 소유권이전등기를 하여주기로 하는 등 물권행위의 시점이 명확한 경우에서까지 독자성을 부정하는 것은 아니다.
- ⑤ 우리 판례는 독자성을 부정한다.

②. 물권행위의 독자성 인정 여부와 물권변동과 공시방법의 관계에 관한 입법주의는 논리필연적인 관계에 있지 않다. 따라서 대항요건주의 하에서도 독자성이 문제될 수 있고(예 : 일본민법), 성립요건주의 하에서 독자성이 부정될 수도 있다(예 : 오스트리아민법).

3. 물권행위의 무인성에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 물권행위의 개념 자체를 부인한다면 물권행위의 무인성을 따질 여지가 없다.

- ② 무인성 인정 여부는 독자성을 인정하는 경우에 비로소 문제된다.
 - ③ 독자성을 인정할 경우에는 그 논리적 귀결로 무인성 역시 반드시 인정된다.
 - ④ 물권행위가 원칙적으로 채권행위시에 행하여진다는 입장에 의하면 물권행위는 원칙적으로 유인이다.
 - ⑤ 물권행위가 채권행위와 명확하게 다른 시기에 행하여진 경우에는 무인성이 문제될 수 있으나, 물권행위가 원칙적으로 채권행위와 다른 시기에 행하여진다고 하여 논리필연적으로 무인성을 인정해야 하는 것은 아니다.
- ③. 독자성을 인정한다고 하여 반드시 무인성을 인정해야 하는 것은 아니다. 독자성은 물권행위의 개념상 독립성 및 시기적 독자성을 인정할 것인가의 문제이고, 무인성은 채권행위의 부존재·무효·취소·해제로 물권행위도 실효되는가의 문제로서 국면을 달리 하는 것이다.

♣ 학습정리

1. 물권변동은 법률행위에 의한 것과 법률행위에 의하지 않은 것으로 나뉜다. 부동산의 경우 전자는 제186조에 의하여 규율되는 반면, 후자는 제187조에 의하여 규율된다.
2. 공시의 원칙은 물권 있는 곳에 공시방법이 갖추어져야 한다는 원칙인 반면, 공신의 원칙은 공시방법 있는 곳에 물권이 존재한다는 신뢰를 보호하는 원칙이다.
3. 공시방법을 갖추지 않은 물권변동의 효력을 제3자에 관한 관계에서만 부정하는 법제를 의사주의라고 하고, 당사자 사이에서도 부정하는 법제를 형식주의라고 한다.
4. 물권행위의 독자성은 물권행위의 개념상 독립성 및 시기적 독자성을 인정할 것인가의 문제로서 다수설은 이를 인정하나 판례는 이를 인정하지 않는다.
5. 물권행위의 무인성은 매매계약 등 채권행위의 부존재·무효·취소·해제로 물권행위도 실효되는가의 문제이며, 다수설과 판례는 유인론을 취한다.

제4강 법률행위에 의한 부동산물권변동

♣ 학습목표

1. 법률행위에 의한 물권변동의 범위에 대하여 정리할 수 있다.
2. 등기의 형식적 유효요건에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 제186조가 적용되는 물권변동(등기를 요하는 물권변동)
- 등기의 형식적 유효요건
- 중복등기
- 실체관계와 부합하는 등기

♣ 사전 테스트

1. 법률의 규정에 의한 물권변동은 등기를 해야 한다.
⇒ × : 법률의 규정에 의한 물권변동은 제187조에 따라 등기를 요하지 않는다. 다만 이를 처분하기 위하여는 등기해야 한다.
2. 판례에 의하면, 등기는 물권변동의 효력발생요건이자 효력존속요건이다.
⇒ × : 등기는 물권변동의 효력발생요건일 뿐 효력존속요건이 아니라는 것이 판례의 태도인바, 등기가 불법말소된 경우 말소등기 자체가 무효이므로 말소회복등기를 하면 종전의 순위를 보유하게 된다.
3. 동일부동산에 관하여 중복된 소유권보존등기에 더 잡아 등기명의인을 달리하는 각 소유권이전등기가 경료된 경우, 등기의 효력은 소유권이전등기의 선후에 의한다.
⇒ × : 이 경우 등기의 효력은 소유권이전등기의 선후에 의하는 것이 아니라 각 소유권이전등기의 바탕이 된 소유권보존등기의 선후를 기준으로 판단한다.

♣ 강의교안

제2절 부동산물권의 변동

제1관 법률행위에 의한 부동산물권의 변동

I. 총설

- 부동산물권변동 : 물권행위 + 등기
- 제186조 “법률행위” → 물권행위(다수설) / 채권행위(소수설)
: 채권행위를 전제로 하지 않는 물권행위도 있고, 물권행위가 채권행위와 명확하게 다른 시기에 행하여질 수 있으므로 물권행위로 보는 것이 타당

II. 등기

1. 등기를 요하는 물권변동의 범위

(1) 법률행위에 의한 물권의 취득

1) 물권의 양수, 제한물권의 취득

2) 재단법인 설립에서 출연부동산의 귀속

제48조(출연재산의 귀속시기) ① 생전처분으로 재단법인을 설립하는 때에는 출연재산은 법인이 성립된 때로부터 법인의 재산이 된다. ② 유언으로 재단법인을 설립하는 때에는 출연재산은 유언의 효력이 발생한 때로부터 법인에 귀속한 것으로 본다.

- 다수설 : 제48조를 제187조의 기타의 ‘법률’로 이해, 제48조에 따라 법인성립시, 유언효력 발생시(출연자 사망시)
- 소수설 : 설립행위는 법률행위이므로 제186조가 적용되어 등기시
- 판례 : 내부관계(출연자- 재단법인)에서는 등기가 없더라도 법인 설립시에 출연부동산의 소유권이 법인에 귀속되나, 외부관계(재단법인- 제3자)에서 제3자에게 대항하기 위해서는 등기가 필요

3) 원인행위의 실효에 의한 물권의 복귀

원인행위인 채권행위가 무효·취소·해제되어 소급적으로 실효된 경우 원상회복을 위한 이전 등기 내지 말소등기가 필요한가

가. 유인설

- 물권행위도 무효, 처음부터 물권변동 없는 것이므로 물권은 당연히 복귀
- 이전등기 불필요(소유권에 기한 반환청구권 행사 가능 : 말소등기청구)
- 제3자 보호 : 말소등기시의 선의의 제3자까지 확대하여 보호

나. 무인설

- 물권행위는 유효, 부당이득 관계가 발생할 뿐

- 이전등기 필요(부당이득반환청구권 행사 가능 : 소유권이전등기청구)
- 제3자 보호 : 원칙적으로 제3자 보호의 문제가 발생하지 않는다.

4) 조건부·기한부 법률행위

- 해제조건부·종기부 법률행위는 등기 가능
- 정지조건부·시기부 법률행위는 등기 불가

(2) 법률행위에 의한 물권의 소멸

1) 물권의 포기

- 제1설 : 물권적 단독행위이므로 제186조에 따라 등기 필요 (다수설)
- 제2설 : 형성권이므로 등기 불필요

2) 지상권·전세권의 소멸청구

- 제1설 : 형성권이므로 등기 불필요 (다수설)
- 제2설 : 형성권이지만 물권적 단독행위이므로 등기 필요
- 제3설 : 채권적 청구권이므로 등기 필요

3) 전세권의 소멸통고

- 제1설 : 형성권이므로 등기 불필요 (다수설) ∵ 제313조 : “소멸한다”
- 제2설 : 형성권이지만 물권적 단독행위이므로 등기 필요

3) 취득시효

- 시효취득은 법률의 규정에 의한 물권변동이지만, 점유취득시효에 관한 제245조 제1항은 등기를 요구하여 제187조의 적용을 배제

4) 소멸시효

소멸시효가 완성되면 등기가 없더라도 물권(지상권·지역권·전세권)이 소멸하는가

- 제1설 : 절대적 소멸설 → 등기 불필요
- 제2설 : 상대적 소멸설 → 등기 필요
- 제3설 : 법률의 규정에 의한 물권변동이므로 제187조에 의하여 등기 불필요
- 제4설 : 상대적 소멸설에 의하더라도 시효를 원용하면 소멸하므로 등기 불필요

2. 형식적(절차적) 유효요건

- 부동산등기법상의 절차에 따른 적법한 등기 : 등기의 존재 + 형식적 하자의 부존재

(1) 등기의 존재 : 등기부에 기재될 것(신청만으로는 안됨)

- 등기가 불법말소된 경우의 처리

· 통설·판례 : 등기는 물권변동의 효력발생요건일뿐 효력존속요건은 아니므로 말소등기 자체가 무효. 만약 말소등기 자체에 효력을 인정한다면 말소등기에 공신력을 인정하는 부당한 결과 발생

- 소수설 : 효력발생요건이자 효력존속요건이므로 불법말소된 경우 물건도 소멸

(2) 형식적 하자의 부존재

- 1) 부동산법 제29조 제1호, 제2호 : 등기관이 신청각하, 등기실행된 경우 직권말소
 - * 직권말소를 제1호, 제2호로 제한하는 이유 : 형식적 심사권
- 2) 부동산법 제29조 나머지 호 : 등기실행된 경우 원칙적으로 무효이지만 실체관계와 부합한다면 유효 (무효인 경우는 피해자가 말소등기청구하여야)

부동산등기법

제29조(신청의 각하) 등기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 이유를 적은 결정으로 신청을 각하(却下)하여야 한다. 다만, 신청의 잘못된 부분이 보정(補正)될 수 있는 경우로서 신청인이 등기관이 보정을 명한 날의 다음 날까지 그 잘못된 부분을 보정하였을 때에는 그러하지 아니하다.

1. 사건이 그 등기소의 관할이 아닌 경우
2. 사건이 등기할 것이 아닌 경우
3. 신청할 권한이 없는 자가 신청한 경우
4. 제24조제1항제1호에 따라 등기를 신청할 때에 당사자나 그 대리인이 출석하지 아니한 경우
5. 신청정보의 제공이 대법원규칙으로 정한 방식에 맞지 아니한 경우
6. 신청정보의 부동산 또는 등기의 목적인 권리의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우
7. 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우. 다만, 제27조에 따라 포괄승계인이 등기신청을 하는 경우는 제외한다.
8. 신청정보와 등기원인을 증명하는 정보가 일치하지 아니한 경우
9. 등기에 필요한 첨부정보를 제공하지 아니한 경우
10. 취득세(「지방세법」 제20조의2에 따라 분할납부하는 경우에는 등기하기 이전에 분할납부하여야 할 금액을 말한다), 등록면허세(등록에 대한 등록면허세만 해당한다) 또는 수수료를 내지 아니하거나 등기신청과 관련하여 다른 법률에 따라 부과된 의무를 이행하지 아니한 경우
11. 신청정보 또는 등기기록의 부동산의 표시가 토지대장·임야대장 또는 건축물대장과 일치하지 아니한 경우

제58조(직권에 의한 등기의 말소) ① 등기관이 등기를 마친 후 그 등기가 제29조제1호 또는 제2호에 해당된 것임을 발견하였을 때에는 등기관리자, 등기의무자와 등기상 이해관계 있는 제3자에게 1개월 이내의 기간을 정하여 그 기간에 이의를 진술하지 아니하면 등기를 말소한다는 뜻을 통지하여야 한다.

(3) 표제부의 하자 : 원칙적으로 그 등기 전부가 무효

- 이를 기반으로 하는 소유권보존등기, 소유권이전등기, 저당권설정등기 모두 무효
- 하자의 정도는 동일성으로 판단, 동일성이 인정되는 경우에는 경정등기 가능

▶ 돌발 퀴즈

판례에 의하면, 하나의 부동산에 관하여 보존등기가 이중으로 경료된 경우 언제나 나중의 보존등기가 무효가 되는 것으로 본다.

⇒ × : 동일인 명의로 보존등기가 중복된 경우에는 그러하나, 동일인이 아닌 경우에는 선등기기록이 원인무효로 되지 않는 한 후등기기록이 무효라고 한다.

(4) 중복등기 (이중등기) : 주로 보존등기에서 발생

- 절차상의 과오로 1부동산에 대하여 2이상의 보존등기가 개설되어 있는 경우 선행등기와 후행등기 중 어느 것을 유효하다고 볼 것인가의 문제(1부동산 1등기기록주의)

· 등기기록이 이중으로 개설되었더라도 어느 하나가 현저히 잘못된 지번표시 등 표제부의 하자로 인하여 무효라면 중복등기기록의 문제가 발생하지 않는다(대판 1978.6.27, 77다405).

· 동일한 부동산에 관하여 등기한 권리의 순위는 법률에 다른 규정이 없는 때에는 등기의 전후에 의하고, 등기의 전후는 등기용지의 동구에서 한 등기에 대하여는 순위번호에 의하므로, 동일한 부동산이나 동일한 지분에 관하여 이중으로 소유권 또는 지분이전등기가 경료된 경우, 선순위 등기가 원인무효이거나 직권말소될 경우에 해당하지 아니하는 한, 후순위등기는 실제적 권리관계에 부합하는지에 관계없이 무효이다(대판 1998.09.22, 98다23393).

· 동일부동산에 관하여 중복된 소유권보존등기에 더 잡아 등기명의인을 달리하는 각 소유권이전등기가 경료된 경우 등기의 효력은 소유권이전등기의 선후에 의하여 판단할 것이 아니고 각 소유권이전등기의 선후를 기준으로 판단하여야 한다(대판 2001.2.15, 99다66915).

<이중보존등기 발생원인>

- ① 철거한 건물의 보존등기를 그대로 둔 채 신축건물의 보존등기를 한 경우
- ② 토지의 분필·합필, 건물의 증개축 등으로 인한 부동산의 현상변경을 등기부에 반영하는 과정에서 착오가 생겨 이중으로 보존등기를 한 경우
- ③ 과거에 특히 농지상환완료·귀속재산불하·가압류·가처분·경매개시결정 등을 원인으로 하여 등기를 촉탁 받은 등기관이 그 과정에서 보존등기가 있음을 모른 채 보존등기를 한 경우
- ④ 등기의 정비과정에서 착오가 생긴 경우, 즉 등기소가 멸실회복등기, 임야대장에서 토지대장으로의 등록전환, 각종 특별조치법에 의한 등기 등을 하면서 기존의 등기가 존재하는지 여부를 제대로 조사하지 아니하고 다시 등기를 한 경우 : 등기과정에 있어서 정확한 검색방법의 미비

1) 동일인 명의로 보존등기가 중복된 경우

- 언제나 후등기기록이 무효(절차법설)

2) 등기명의인이 동일인이 아닌 경우

- 절차법설 : 등기가 경료된 시점의 선후에 의하여 형식적으로 유효등기를 판단하는 견해
- 후등기를 일단 무효로 취급하고, 소송을 하지 않고도 법률관계가 명확하게 되는 장점
- 실체법설 : 선등기와 후등기 양자의 실체법적 법률관계를 파악하여 진정한 소유권에 바탕을 둔 등기를 유효로 한다는 견해
- 1부동산 1등기기록의 원칙을 관철하지 못하고, 소송이 불가피하다는 단점

- 절차법적 절충설(판례) : 선등기기록의 추정력을 인정하여 선등기기록이 원인무효로 되지 않는 한 후등기기록이 무효
- 중복등기의 유·무효는 중복된 소유권보존등기의 유·무효에 의하여 판단, 이후에 경료된 소유권이전등기가 실체관계에 부합하는지 여부는 불문
- 중복된 소유권보존등기 중 원칙적으로 후등기기록이 무효이지만, 선등기기록이 원인무효라면 후등기기록이 유효
- 후등기기록이 매수인이나 원시취득자에 의하여 경료되어 실체관계와 부합하는 등기이더라도 선등기기록이 무효가 아닌 한 후등기기록이 무효

[판례]

- 표제부의 표시란의 이중등기

- 판례는 실체법설에 따라 동일부동산에 관한 이중보존등기가 있는 경우, 등기의 선후와 무관하게 실체적 권리관계와 일치하는 보존등기만이 효력이 있다고 한다(대판 1968. 11. 19, 66다1473).

- 사항란의 이중등기

- 판례는 보존등기의 명의인이 동일인인 경우에는 먼저 행하여진 것이 유효하고 뒤에 행하여진 등기는 그에 터잡아 이해관계인이 있는 경우에도 무효라고 판시하여 절차법설의 태도를 취하고 있다(대판 1993. 2. 23, 92다36387).
- 보존등기명의인이 동일인이 아닌 경우에는 당초에는 절차법설의 입장이었다가 1978년 전원합의체판결로 실체법설을 정면으로 수용하는 듯한 입장을 취하였고, 그 후에는 절차법설에 따른 판례(대판 1981. 11. 18, 81다1340)와 실체법설에 따른 판례(대판 1987. 3. 10, 84다카2132)로 나누어져 있었다. 그러나 1990년 전원합의체판결에서 선등기가 원인무효가 아닌 한 후등기는 비록 그 부동산 매수인에 의하여 이루어진 경우에도 일부동산 일등기용지를 채택하고 있는 부동산등기법 아래에서는 원칙적으로 무효이지만, 예외적으로 선등기가 무효이고 후등기가 실체관계에 부합하는 경우에는 후등기가 유효하다고 함으로써, 절충설(절차법적 절충설)을 명백히 하고 있다(대판[전합] 1990. 11. 27, 87다카2961 : 대판 2002. 7. 12, 2001다16913 등). 그리고 이러한 법리는 뒤에 된 소유권보존등기의 명의인이 당해 부동산의 소유권을 원시취득(점유시효취득, 등기부시효취득)한 경우에도 그대로 적용된다(대판 1997. 11. 28, 97다37494 : 대판 1996. 9. 20, 93다20177·20184 : 대판[전합] 1996. 10. 17, 96다12511. 점유취득시효의 경우에서도 절차법적 절충설을 유지하고 있다).

· 중복된 소유권보존등기에서 앞의 등기가 원인무효가 아닌 경우 뒤의 등기의 효력

동일부동산에 관하여 등기명의인을 달리하여 중복된 소유권보존등기가 경료된 경우에는 먼저 이루어진 소유권보존등기가 원인무효가 아닌 한, 뒤에 경료된 소유권보존등기는 비록 그 부동산의 매수인에 의하여 이루어진 경우에도(즉 실체적 권리관계에 부합하더라도) 일부동산 일등기용지주의의 원칙을 채택하고 있는 부동산등기법 아래에서는 무효로 해석함이 상당하다(대판[전합] 1990. 11. 27, 87다카2961).

· 중복소유권보존등기시 뒤의 등기명의인이 점유취득시효를 완성하더라도 앞의 등기가 원인무효가 아닌 한 후의 등기는 무효

동일부동산에 대하여 이미 소유권이전등기가 경료되어 있음에도 그 후 중복하여 소유권보존등기를 경료한 자가 그 부동산을 20년간 소유의 의사로 평온·공연하게 점유하여 점유

취득시효가 완성되었더라도, 선등기인 소유권이전등기의 토대가 된 소유권보존등기가 원인 무효라고 볼 아무런 주장·증명이 없는 이상, 뒤에 경료된 소유권보존등기는 실체적 권리관계에 부합하는지의 여부에 관계없이 무효이다(대판 1996. 9. 20, 93다20177·20184 : 대판 1997. 11. 28, 97다37494 : 대판 2008.2.14., 2007다63690).

· 무효인 이중보존등기에 기한 등기부취득시효의 허용여부

등기부취득시효(제245조 제2항)를 하기 위해서는 10년간 소유의 의사로 등기되어 있을 것이 요구되는데, 적법 유효한 등기를 마친 자일 필요는 없고 무효의 등기를 마친 자라도 상관없다는 것이 통설·판례(대판 1994. 2. 8, 93다23367)이다. 여기서 이중보존등기이기 때문에 무효로 되는 보존등기를 기초로 하여서도 등기부취득시효가 가능한지가 문제

→ 통설·판례는 부정설을 취하여 제245조 제2항에서의 등기는 이중등기로서 무효인 등기는 제외한다고 하는데, 중복등기로서 무효인 경우에는 별도의 합법적인 선행등기가 있기 때문에 권리추정력이 없거나 극히 적다고 보아야 하고 등기부취득시효를 인정하게 되면 여전히 중복보존등기가 행하여질 위험성이 있다는 것을 근거로 한다(대판[전합] 1996. 10. 17, 96다12511). 이와 달리 긍정설은 통상의 무효등기(원인행위가 무효·취소된 경우)와 중복보존등기로서 무효인 등기를 구별할 합리적인 이유가 없다는 것을 이유로, 이중등기로서 무효의 등기라고 하여도 민법 제245조 제2항에서 말하는 등기에 해당하는 것으로 본다.

※ 중복등기의 정리 : 이상의 판례의 논의와는 다르게 부동산등기법 및 부동산등기규칙에 의한 중복등기의 정리는 잠정적인 것에 불과

(5) 실체관계에 부합하는 등기

- 등기절차에 하자가 있더라도 유효한 원인행위 또는 법률의 규정에 의한 등기청구권과 부합하는 등기가 경료되고 종전의 진정한 권리자(등기의무자)가 등기명의자(등기권리자)의 등기청구권 행사를 저지할 만한 실체법상의 항변사유가 없거나 사후적으로 없어져서 진실한 권리관계와 합치되는 경우 그 등기를 유효하게 다룬다.

- 부동산소유권을 이전하는 계약에 기해 양도인이 사실상 그 목적 부동산에 대한 전면적인 지배를 양수인에게 취득케 하여 소유권의 모든 권능을 취득하였다고 할 수 있는 상태에 이르렀다면, 이러한 당사자간의 그 실질관계에 부합되는 등기는 등기의무자의 등기의사를 바탕으로 하였다고 할 수 있으므로 양수인 명의의 등기는 그것이 설사 등기의무자의 신청에 의하지 아니한 하자가 있다고 해도 실체관계에 부합되는 등기로서 유효하다(대판 1978.08.22, 76다343).

- 실체관계와 부합하는 등기

- 중간생략등기
- 미등기부동산의 양수인 등에 대한 소유권보존등기
- 실제의 등기원인과 다른 원인에 기한 등기
- 무효등기의 유효

- 실체관계와 부합하지 않는 등기

· 매매대금 전액이 지급되었거나 또는 매매대금 완불 이전이라 하더라도 그 소유권이전등기를 하기로 하는 약정이 있었다고 할 수 없다면, 소유서류 위조 등의 방법으로 한 매수인 명의의 소유권이전등기는 매도인의 의사에 반하는 것이임이 분명하므로 실체적 권리관계에 부합한다고 할 이유나 근거가 없다(대판 1985.4.9, 84다카130·131).

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 채권행위와 물권행위의 관계에 관하여 무인설을 취하는 견해는 채권행위가 소급적으로 실효된 경우 물권은 당연히 복귀하므로 이전등기 내지 말소등기가 필요하지 않다고 한다.
- ② 정지조건부·시기부 법률행위는 조건의 성취 내지 기한의 도래시까지 등기할 수 없다.
- ③ 등기가 물권변동의 효력발생요건일 뿐 효력존속요건은 아니다.
- ④ 동일인 명의로 보존등기가 중복된 경우에 언제나 후등기기록이 무효이다.
- ⑤ 중복된 보존등기의 등기명의인이 동일인이 아닌 경우에 있어서 선등기기록이 원인무효로 되지 않는 한 후등기기록이 무효이다.

⇒ ①. 유인설의 입장에서는 처음부터 물권변동이 없었던 것으로 되어 물권이 당연히 복귀하므로 등기를 필요로 하지 않게 된다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 실체관계에 부합하는 등기는 유효한 등기로 다루어질 수 있다.
- ② 실체관계와 부합하는 등기의 예로는 중간생략등기, 미등기부동산의 양수인 등에 대한 소유권 보존등기, 실제의 등기원인과 다른 원인에 기한 등기, 무효등기의 유용 등을 들 수 있다.
- ③ 무효인 이중보존등기에 기한 등기부취득시효의 완성도 가능하다.
- ④ 부동산 매매계약 이후에 양도인이 양수인으로 하여금 사실상 그 목적부동산에 대한 전면적인 지배를 취득케 하여 소유권의 모든 권능을 취득하였다고 할 수 있는 상태에 이르렀다면 등기에 등기의무자의 신청에 의하지 아니한 하자가 있다고 하더라도 등기가 실체관계에 부합하여 유효하다.
- ⑤ 등기가 양 당사자의 실질적인 관계에 부응하는 것이라면 그 등기는 일반적으로 등기의무자의 의사에 터 잡고 있는 것으로 볼 수 있다.

⇒ ③ 통설·판례는 제245조 제2항에서의 등기는 이중등기로서 무효인 등기는 제외한다고 하는데, 중복등기로서 무효인 경우에는 별도의 합법적인 선행등기가 있기 때문에 권리추정력이 없거나 극히 적다고 보아야 하고 등기부취득시효를 인정하게 되면 여전히 중복보존등기가 행하여질 위험성이 있다는 것을 근거로 하여 부정설의 입장을 취하고 있다(대판[전합] 1996. 10. 17, 96다12511).

3. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 원인행위의 실효에 의한 소유권의 복귀에 있어서 무인설은 양도인이 소유권에 기한 반환청구권은 행사할 수 없지만 부당이득반환청구권을 행사할 수 있다고 한다.
- ② 제245조 제1항의 점유취득시효의 완성에 의한 소유권 취득은 법률의 규정에 의한 물권변동이나 등기를 요한다.
- ③ 등기관은 신청된 등기사항에 관하여 실질적 심사권을 갖는다.
- ④ 등기부상 표제부에 하자가 존재하는 경우 원칙적으로 그 등기 전부가 무효이나, 동일성이 인정되는 경우에는 경정등기가 가능하다.
- ⑤ 등기기록이 이중으로 개설되었더라도 어느 하나가 현저히 잘못된 지번표시 등 표제부의 하자로 무효라면 중복등기기록의 문제가 발생하지 않는다.

⇒ ③ 등기관은 형식적 심사권을 가질 뿐이다.

♣ 학습정리

1. 법률행위에 의한 부동산물권변동은 제186조에 따라 등기를 해야 한다.
2. 등기의 형식적 유효요건으로는 등기의 존재와 형식적 하자의 부존재이다.
3. 소유권보존등기가 중복된 경우, 명의인이 동일인이라면 언제나 후등기기록이 무효로 되지만, 동일인이 아니라면 선등기기록이 원인무효가 아닌 한 후등기기록을 무효로 하는 것이 판례의 입장이다.
4. 판례는 무효인 이중보존등기에 의한 등기부취득시효의 완성을 인정하지 않는다.
5. 판례에 의하면 실체관계에 부합되는 등기는 등기의무자의 신청에 의하지 아니한 하자가 있더라도 유효하게 다루어질 수 있다고 한다.

제5강 등기의 실체적 유효요건

♣ 학습목표

1. 등기의 실체적 유효요건인 존재상·내용상 합치에 대하여 설명할 수 있다.
2. 관련문제로서 미등기매수인의 지위, 중간생략등기, 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구권, 명의신탁등기, 무효등기의 유효 등에 관하여 정리할 수 있다.

♣ 학습내용

1. 등기의 실체적 유효요건으로서의 존재상·내용상 합치
2. 존재상 불합치 - 등기를 갖추지 않은 부동산매수인의 지위
3. 내용상 불합치 - 질적 불합치 / 양적 불합치 / 등기와 물권변동 과정의 불합치
4. 등기와 물권변동 과정의 불합치 - 중간생략등기, 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구권, 명의신탁등기, 무효등기의 유효

♣ 사전 테스트

1. 언제나 법률행위가 있는 이후에만 등기가 이루어질 수 있다.
⇒ × : 유효한 법률행위 없이 등기만 있는 경우 무효이지만, 그에 합치되는 법률행위가 있으면 그때부터 유효로 된다.
2. 등기가 물권적 합의보다 큰 경우 그 등기는 무효이다.
⇒ × : 물권적 합의의 한도 내에서는 효력이 있다.
3. 판례에 의하면 중간자의 동의나 전원의 합의가 있으면 중간생략등기청구가 가능하다.
⇒ × : 이미 경료된 중간생략등기는 전원의 합의는 물론이고 중간자의 동의가 있는 경우에도 유효한 것으로 인정되지만, 중간생략등기청구권은 전원의 의사합치가 있는 경우에만 인정된다.

♣ 강의교안

3. 실체적 유효요건

- 당사자가 법률행위에 의하여 달성하고자 하는 물건변동에 부합하여야 할 것
- 법률행위와 등기의 일치 : 법률행위와 등기는 서로 부합해야 하고 그러하지 아니한 때에는 물건변동이 일어나지 않는다(대판 1964.11.24, 64다851·852).

(1) 존재상 불합치

- 물건변동이 일어나기 위해서는 법률행위와 등기 2가지 모두 존재해야 하므로, 법률행위가 없거나 무효인 경우에는 등기가 있더라도 등기는 무효이고 물건변동 불발생
- 등기를 갖추지 않은 부동산매수인의 지위
 - 인정 : 점유권, 점유보호청구권, 등기청구권, 과실수취권, (물권적 기대권)
 - * 매수인은 제213조 단서의 점유할 권리를 가지는 자에 해당되어 매도인의 물권적 청구권에 대항할 수 있고(∴ 매각되어 인도된 물건의 항변(*exceptio rei venditae et traditae*), 권리남용, 급부보유력), 매매계약이 제741조의 법률상 원인에 해당되므로 매도인은 부당이득반환청구 불가
 - 불인정 : 소유권, 소유권에 기한 물권적 청구권, 제3자이익의 소, 환취권
 - * 다만 소유권에 근접하는 효과 부여 : '법률상 또는 사실상 처분을 할 수 있는 지위', '사실상 소유 또는 실질적 소유'

(2) 내용상 불합치

1) 질적 불합치

- 원칙적으로 물건변동 없고, 등기는 무효
- 예를 들어 A토지 매매계약인데 B토지에 관하여 등기경료 → A 토지 소유권이전 없음, B 토지 소유권이전등기 무효(즉 B 토지 물건변동도 없음)
- 다만 경정등기를 하는 경우, 등기가 실체관계와 부합하는 등기로 되는 경우, 무효인 등기를 말소하고 법률행위와 부합하는 새로운 등기를 한 경우 물건변동 발생

2) 양적 불합치

① 등기가 합의보다 큰 경우

- 통설·판례 : 등기가 물권적 합의보다 양적으로 큰 경우에 등기는 물권적 합의의 한도 내에서 효력이 있다. 예컨대 저당권의 피담보채권액이 200만원으로 합의되었는데 300만원으로 등기된 경우에는 물권적으로 합의한 200만원의 범위 내에서 유효하다.
- 지분등기에 관한 판례로서 공유자 중 1인이 다른 공유자의 동의 없이 공유토지 전부를 매도하여 타인 명의로 소유권이전등기가 마쳐진 경우, 그 등기의 효력은 처분공유자의 공유지분 범위 내에서 유효하다(대판 2008. 4. 24, 2008다5073).

② 등기가 합의보다 작은 경우

- 제1설 : 등기가 물권적 합의보다 작은 경우에는 등기의 범위 내에서만 물권적 합의가 유효
- 제2설 : 일부무효의 법리에 따라 판단

3) 등기와 물건변동 원인·과정의 불합치(질적 불합치이지만 등기의 유효성이 인정되는 경우)

등기부에는 물건변동과 등기원인이 그대로 공시되는 것이 원칙이다. 그러나 실제로는 세금 관계 등의 이유로 위와 같은 원칙과 달리 등기가 이루어지는 경우가 있다. 이러한 것으로 문제가 되는 것에는 ㉠ 중간생략등기, ㉡ 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구와 같은 실제와 다른 등기원인에 의한 등기, ㉢ 명의신탁등기, ㉣ 무효등기의 유효 등이 있다.

▶ 돌발 퀴즈

중간등기 생략의 합의가 있었다면, 최초의 양도인은 최후의 양수인에 대하여 매매대금청구권에 관한 동시이행의 항변권을 행사할 수 없다.

→ × : 판례는 중간등기 생략 합의가 있었다라도 최초 양도인이 중간취득자에게 가지는 매매대금청구권의 행사가 제한되지도 않고 최후의 양수인에 대해서도 대금청구권의 동시이행을 항변할 수 있다고 한다.

<중간생략등기>

1. 의의

부동산물권이 최초 양도인으로부터 중간취득자에게, 다시 중간취득자로부터 최종취득자에게 전전이전하는 경우에, 중간취득자의 등기를 생략한 채 최초의 양도인에게 최종양수인에게 직접 이전등기를 하는 것(예컨대 乙이 甲으로부터 부동산을 매수하고, 이를 다시 乙이 丙에게 전매한 경우에 乙자신에게로의 등기를 생략하고, 甲으로부터 직접 丙에게 행하는 등기.)

→ 물건변동과정을 정확히 공시하지 않음(탈세/ 등기비용 절약 목적)

2. 파생유형

- ① 미등기부동산의 양수인이 보존등기를 하는 경우(대판 1995. 12. 26, 94다44675),
- ② 상속재산을 양도하였으나 상속인에의 이전등기를 거치지 않고 바로 피상속인으로부터 양수인에게 이전등기하는 경우(대판 1967. 5. 2, 66다2642; 이는 상속인에 의한 등기로서 부동산등기법 제47조가 이를 허용하고 있다),
- ③ 甲에게서 乙, 乙에게서 丙으로 매매된 부동산을 甲이 제한능력을 이유로 매매계약을 취소하면서 甲·乙 사이의 등기, 乙·丙 사이의 등기를 말소하는 대신에 丙이 직접 甲에게 이전등기하는 경우(진정명의회복을 위한 소유권이전등기)

3. 중간생략등기에 관한 규제법률

- ① 부동산등기특별조치법 : 다수설·판례는 동법의 처벌규정에도 불구하고 단속규정으로 보아 사법상 효력은 유효하다고 보고 있다(대판 1993. 1. 26, 92다39112).
- ② 부동산실명법 : 등기명의신탁형(중간생략형 명의신탁)의 명의신탁약정 무효(제4조 제1항), 물건변동 무효(제4조 제2항)

4. 이미 경료된 중간생략등기의 유효성

- 1) 절대적 무효설 중간생략등기는 성립요건주의에 반하고, 탈세와 탈법 및 부동산투기의 방법으로 이용되고 있는 현실에 비추어 이를 금지할 필요성이 있으며, 부동산등기특별조치법이 형사처벌하는 점을 고려해 볼 때(동법 제2조·제8조) 중간생략등기신청 금지규정을 효력규정으로 이해하여야 하고 따라서 중간생략등기는 효력규정 위반으로 무효인 등기로 보아야 한다는 견해.

- 2) 조건부 유효설 이 견해는 중간자의 동의나 3자(甲·乙·丙)사이의 합의가 있으면 중간생략등기도 유효하다고 하는 것으로 다수설과 판례의 입장이다. 그 근거로는 중간자의 동의 또는 3자 사이의 합의는 갑·병간의 물권이전에 대한 것이 포함되고 물권행위의 무인성을 인정하는 한 유효하다는 것을 들고 있다.
- 3) 독일민법 제185조 1항의 유추적용설 그리고 비권리자의 처분은 그것이 권리자의 동의를 얻어서 행한 것인 때에는 유효하다는 독일민법의 법리를 원용하여 최초의 양도인 甲과 중간취득자 乙 사이의 물권행위는 비권리자인 乙이 甲의 부동산을 처분하는 데 대한 동의로서의 의미를 가지는 것으로 해석할 수 있으므로 甲으로부터 최종 취득자 丙에게로의 이전등기는 유효하다고 한다.
- 4) 물권적 기대권설 甲·乙 사이의 물권행위로 乙은 목적물에 대한 물권유사의 물권적 기대권을 취득하고 乙은 이 권리를 다시 丙에게 양도한 것으로서 이것의 양도는 채권양도가 아니라 물권적 권리의 양도이므로 물권적 합의에 의하여야 하고 채권양도와 같은 대항요건은 필요로 하지 아니하며 중간자의 협력도 필요하지 않다고 하면서 이미 행하여진 중간생략등기는 중간자(乙)의 동의 없이 유효하다고 한다.
- 5) 채권양도설 민법이 물권변동에 관하여 형식주의를 취하므로 매수인은 등기가 있기 전까지는 채권을 가질 뿐이므로 채권양도의 법리에 의하여 매수인은 자신의 채권을 최종양수인에게 양도할 수 있고, 이에 의하여 최종매수인은 매도인에게 직접 등기청구권을 행사할 수 있다는 견해이다. 다만 이 견해는 대판 1995. 8. 22, 95다15575에 의해 부인되었는데 그 이유로 소유권이전등기청구권은 그 이행과정에 신뢰관계가 따르므로 특별한 사정이 없는 한 그 권리의 양도에 채무자인 매도인의 승낙이나 동의를 요한다는 점을 들고 있다.
- 6) 이원설 중간생략등기는 실질적 소유관념에 부합하고 절차상의 편의를 위해 필요하며 거래의 안전을 위한다는 점을 근거로 이미 경료된 중간생략등기는 유효하지만, 중간생략등기가 경료되기 전에는 중간생략등기 청구권은 특별법의 취지에 반하므로 인정될 수 없다고 한다.
- 7) 판례 판례는 중간생략등기가 이미 이루어진 경우 중간취득자의 동의, 3자간 합의가 있을 때에는 그 유효성을 인정하며(대판 1971. 2. 23, 70다2996) 다만 적법한 등기원인에 의하여 이미 경료된 경우 그러한 합의가 없더라도 그 등기가 실체관계에 부합하는 경우에는 합의 없음을 이유로 무효를 주장할 수 없다고 한다(대판 1980. 2. 12, 79다2104). 그러나 판례는 중간생략등기의 합의란 각 매매계약이 유효하게 성립함을 전제로 하는 것이므로 토지거래허가구역내의 토지의 최종매수인이 최초매도인을 매매당사자로 하는 토지거래허가를 받아 중간생략등기를 경료하더라도 그러한 등기는 무효라고 한다(대판 1996. 6. 28, 96다3982).

5. 중간생략등기청구권의 인정여부

중간생략등기가 이루어져 있지 않은 경우에 최종양수인이 중간자를 거치지 않고 최초양도인으로부터 직접 소유권이전등기를 청구할 수 있는지가 문제된다. 이에 관하여 학설은 (i) 중간생략등기의 청구권행사에 관해서는 무효설의 입장에서 병은 갑에게 등기를 청구할 수 없다는 견해, (ii) 무조건유효설의 입장에서 중간자의 동의를 불문하고 등기를 청구할 수 있다는 견해, (iii) 조건부유효설의 입장에서 중간자의 동의하에 丙이 甲에게 직접 등기를 청구할 수 있으며, 동의가 없을 때에만 채권자대위권의 이론에 따라 등기청구권의 대위행사만이 가능하다는 견해로 나뉘고 있다.

판례는 중간생략등기에 관한 최초양도인·중간자·최종양수인 전원의 합의가 없는 한 이를 인정하지 않는다(대판 1991. 4. 23, 91다57610; 대판 1995. 8. 22, 95다15575). 다만 최

중양수인은 채권자대위권의 이론에 따라 최초양도인에 대하여 중간자를 대위하여 중간자에게 중간자명의의 소유권이전등기를 할 것을 청구할 수 있을 뿐이라고 한다(대판 1983. 12. 13, 83다카881). 이러한 채권자대위권의 행사에 의한 경우는 중간자에게 이전등기를 할 것을 최초양도인에게 청구하는 것이므로 중간생략등기는 아니다. 그리고 토지거래허가구역내의 토지인 경우에는 중간생략등기의 합의가 있었다 하더라도 최종매수인이 최초의 매도인에 대하여 직접 그 토지에 관한 토지거래허가 신청절차의 협력을 청구할 수 없다고 한다(대판 1996. 6. 28, 96다3982).

[판례] 중간생략등기의 합의가 있으면 최초의 매도인이 중간 매수인에 대하여 갖고 있는 매매대금청구권의 행사가 제한되는지 여부

중간생략등기의 합의란 부동산이 전전 매도된 경우 각 매매계약이 유효하게 성립함을 전제로 그 이행의 편의상 최초의 매도인으로부터 최종의 매수인 앞으로 소유권이전등기를 경료하기로 한다는 당사자 사이의 합의에 불과할 뿐이므로, 이러한 합의가 있다고 하여 최초의 매도인이 자신이 당사자가 된 매매계약상의 매수인인 중간자에 대하여 갖고 있는 매매대금청구권의 행사가 제한되는 것은 아니고 동시이행의 항변권을 행사할 수 있다. 최초 매도인과 중간 매수인, 중간 매수인과 최종 매수인 사이에 순차로 매매계약이 체결되고 이들 간에 중간생략등기의 합의가 있는 후에 최초 매도인과 중간 매수인 간에 매매대금을 인상하는 약정이 체결된 경우, 최초 매도인은 인상된 매매대금이 지급되지 않았음을 이유로 최종 매수인 명의로의 소유권이전등기의무의 이행을 거절할 수 있다(대판 2005. 4. 29, 2003다66431).

<실제와 다른 등기원인에 의한 등기>

등기부에는 반드시 등기원인을 기재하도록 되어 있다(부동산등기법 제57조 제2항). 그런데 거래계에서는 세금관계 또는 등기절차의 번거로움 등으로 실제의 등기원인과 다르게 표시하여 등기를 신청하는 경우가 있다.

㉠ 증여에 의한 소유권 이전등기를 매매에 의한 이전등기로 신청(대판 1980. 9. 22, 80다791)

㉡ 대물변제로 인한 소유권이전등기를 함에 있어서 매매를 등기원인으로 기재(대판 1955. 4. 27, 4287민상336)

㉢ 원인무효에 의한 말소등기를 진정한 등기명의의 회복을 원인으로 소유권이전등기(대판 [전합] 1990. 11. 27, 89다카12398)

㉣ 법률행위의 취소·해제에 의한 말소등기를 이전등기로 하는 것

→ 물권적 합의는 물권의 득실변경을 직접 목적으로 하는 법률행위이므로 등기는 현재의 진실한 권리관계를 공시하면 되고 그에 이른 과정이나 태양까지 그대로 반영하지 아니하여도 법적 안정성을 꾀할 수 있다는 것을 이유로, 판례는 그 유효성을 인정하고 있다(대판 1970. 7. 24, 70다1005).

<진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구권>

1. 의의 진정명의회복을 원인으로 하는 소유권이전등기청구권이란 실체관계에 부합하지 않은 무효의 등기가 경료된 경우에 이를 진실한 권리관계에 합치하는 방법으로 말소등기 대신에 진정한 권리자명의로 이전등기를 청구할 수 있는 권리이다.
2. 법적성질 소유권을 갖는 자가 청구하는 것이므로 민법 제214조의 소유권에 기한 방해배제청구권의 성질을 갖는다(대판 2009. 4. 9, 2006다30921). 따라서 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구권은 소멸시효에 걸리지 않는다(대판 1993. 8. 24, 92다43975).
3. 인정여부
 - 1) 부정설 부정설의 논거는 다음과 같다. (i) 변동공시설의 입장에서 등기는 현재의 권리관계 뿐만 아니라 물건변동의 과정과 태양까지 반영하는 것이므로 물건변동과정과 다른 등기를 권리로서 당연히 청구할 수는 없다. (ii) 그리고 권리변동과정과 다른 등기가 이미 이루어진 경우 이를 유효로 하는 것은 공시수단으로서의 거래안전을 고려한 것인데, 이를 이유로 명의자에게 직접 등기를 청구할 수 있는 권리로서의 청구권을 인정한다는 것은 아니다. (iii) 등기가 甲에서 乙, 乙에서 또다시 丙으로 경료되어, 2단계 이상 걸치는 경우 말소등기에 의하지 않고 진정명의회복의 직접적인 이전등기가 허용된다면 중간생략등기의 문제와 같게 되고, 이와 같은 등기는 부실등기이며 이는 부동산물권변동에 관한 성립요건주의의 원칙에 반하는 것이다. (iv) 진정명의회복을 청구하는 자가 청구를 받는 자에 대한 직접 이전등기청구를 할 수 있는 실체법상의 원인이 존재하지 않는다.
 - 2) 긍정설 통설·판례의 입장인 긍정설의 논거는 다음과 같다. (i) 현상공시설의 입장에서 등기는 현재의 권리상태를 공시하면 족하다는 점에서 이전등기의 방식을 취하더라도 그 실질에 부합하는 이상 허용된다. (ii) 진정명의회복을 구하는 등기청구권은 물권적 청구권의 성질을 가지므로 그 대세적 효력에 기하여 말소등기뿐만 아니라 이전등기도 허용된다. (iii) 그리고 현재의 판례가 일관되게 중간생략등기의 유효성을 인정하는 것과 비교할 때 진정명의회복을 말소등기에 국한할 필요는 없다.
 - 3) 판례 판례는 처음에는 등기말소를 청구하여야 하고 소유권회복을 원인으로 한 이전등기청구는 할 수 없다고 하였다(대판 1972. 12. 26, 72다1846). 그러나 그 후의 전원합의체 판결에서 태도를 바꾸어, 이미 자기 앞으로 소유권을 표상하는 등기가 되어 있었거나 법률에 의하여 소유권을 취득한 자가 진정한 등기명의를 회복하기 위한 방법으로는 현재의 등기명의를인으로 상대로 그 등기의 말소를 구하는 외에 “진정한 등기명의를회복”을 원인으로 한 소유권이전등기절차의 이행을 직접 구하는 것도 허용되어야 한다고 판시하였다(대판[전합] 1990. 11. 27, 89다카12398).
4. 당사자
 - (1) 청구권자는 소유자이다. 즉 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구권은 그 성격이 소유권에 기한 방해배제청구권이므로 현재의 소유자가 물권의 방해자를 상대로 청구해야 한다. 판례도 이미 자기 앞으로 소유권을 표상하는 등기가 되어 있었거나 법률에 의하여 소유권을 취득한 자만이 진정명의회복을 원인으로 하는 소유권이전등기청구권을 가

진다고 판시하고 있다(대판[전합] 1990. 11. 27, 89다카12398 : 대판 1993. 2. 23, 92다48970 등).

[판례] 소유자로 부정한 사례

- 1) 명의신탁자는 대외적으로는 소유자라고 할 수 없으므로 제3자에 대하여 진정한 등기명의의 회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구를 할 수 있는 진정한 소유자의 지위에 있다고 볼 수 없다(대판 2001. 8. 21, 2000다36484 : 이 경우에 명의신탁자가 위 부동산에 관하여 자기 명의로 소유권이전등기를 마치기 위해서는, 명의수탁자를 대위하여 제3자에게 부동산에 관한 소유권이전등기의 말소등기를 청구하고, 명의수탁자에게 부동산에 관한 명의신탁해지를 원인으로 한 소유권이전등기 또는 소유권이전등기의 말소등기를 청구하여야 한다).
- 2) 포괄적 유증을 받은 자는 민법 제187조에 의하여 법률상 당연히 유증받은 부동산의 소유권을 취득하게 되나, 특정유증을 받은 자는 유증의무자에게 유증을 이행할 것을 청구할 수 있는 채권을 취득할 뿐이므로, 특정유증을 받은 자는 유증받은 부동산의 소유권자가 아니어서 직접 진정한 등기명의의 회복을 원인으로 한 소유권이전등기를 구할 수 없다(대판 2003. 5. 27, 2000다73445).
- 3) '진정한 등기명의의 회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구'는 당해 부동산에 관하여 이미 자기의 명의로 소유권을 표상하는 등기가 되어 있었거나 법률에 의하여 소유권을 취득한 그 부동산의 진정한 소유자가 그의 등기명의를 회복하기 위한 방법으로 현재의 등기부상의 소유명의인을 상대로 소유권이전등기절차의 이행을 직접 청구하는 경우에 인정되는 것인바, 가등기담보등에관한법률이 시행되기 전에 경료된 채권자 명의의 가등기에 기하여 소유권이전의 본등기가 경료된 경우 위 소유권이전등기가 비록 채권담보의 목적으로 경료된 것이라고 하더라도, 대외적인 관계에서는 그 소유권이 완전히 이전되는 것으로 볼 수밖에 없고, 따라서 위 가등기에 기한 소유권이전의 본등기가 경료됨으로써 그 가등기가 경료된 다음에 경료된 제3취득자 명의의 소유권이전등기가 말소됨으로 말미암아 제3취득자는 그 소유권을 상실하게 되었다고 보아야 할 것이므로, 그 후 채권자 명의의 위 가등기와 본등기의 원인이 그 피담보채무의 변제로 인하여 소멸하게 된다고 하더라도, 제3취득자로서는 채권자에게 진정한 등기명의의 회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구를 할 수 있는 진정한 소유자의 지위에 있다고 볼 수 없다(대판 1992. 1. 21, 91다35175).
- 4) 구민법 시행 당시 피상속인이 매수한 부동산임을 이유로 상속인들이 등기명의인을 상대로 진정한 등기명의의 회복을 위한 소유권이전등기청구를 한 사안에서, 그 부동산에 관하여 피상속인 명의의 등기가 있었음을 인정할 수 없고, 설령 민법 시행 전에 피상속인이 그 부동산을 매수하였다 하더라도 민법 시행 후 6년 내에 등기를 하지 않아 민법 부칙 제10조 제1항에 의하여 소유권을 상실하였으므로, 상속인들은 등기명의인을 상대로 진정한 등기명의의 회복을 위한 소유권이전등기청구를 할 수 없다(대판 2009. 4. 9, 2006다30921 : 대판 2005. 7. 29, 2003다46130 : 대판 1967. 11. 28, 67다1879).
- 5) 갑 명의의 소유권이전등기가 경료된 토지에 관하여 제3자 명의로 소유권보존등기가 이중으로 경료되고, 이에 터잡아 순차로 소유권이전등기가 경료된 사안에서, 위 소유권보존등기에 터 잡은 위 소유권이전등기의 최종 등기명의인인 을이 진정한 등기명의의 회복을 위한 소유권이전등기를 청구할 수 없다(대판 2007. 7. 12, 2007다14940).

[판례] 소유자로 인정한 사례

- 1) 부동산실명법 시행 전에 명의신탁약정에 의하여 부동산에 관한 물권을 명의수탁자의 명의로 등기하거나 하도록 한 명의신탁자는 법 시행일로부터 1년의 기간 이내에 실명등기를 하여야 하고, 그 기간 이내에 실명등기 또는 매각처분 등을 하지 아니하면 그 이후에는 명의신탁약정은 무효가 되고, 명의신탁약정에 따라 행하여진 등기에 의한 부동산의 물권변동도 무효가 된다고 규정하고 있으므로, 원칙적으로 일반 명의신탁의 명의신탁자는 명의수탁자를 상대로 원인무효를 이유로 그 등기의 말소를 구하여야 하는 것이기는 하나, 자기 명의로 소유권을 표상하는 등기가 되어 있었거나 법률에 의하여 소유권을 취득한 진정한 소유자는 그 등기명의를 회복하기 위한 방법으로 그 소유권에 기하여 현재의 원인무효인 등기명의를 상대로 진정한 등기명의를 회복을 원인으로 한 소유권이전등기절차의 이행을 구할 수도 있으므로, 명의신탁대상 부동산에 관하여 자기 명의로 소유권이전등기를 경료한 적이 있었던 명의신탁자로서는 명의수탁자를 상대로 진정한 명의회복을 원인으로 한 이전등기를 구할 수도 있다(대판 2002. 9. 6, 2002다 35157).
 - 2) 부동산의 공유자 중 한 사람은 공유물에 대한 보존행위로서 그 공유물에 관한 원인무효의 등기 전부의 말소를 구할 수 있고, 진정한 명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구권과 무효등기의 말소청구권은 어느 것이나 진정한 소유자의 등기명의를 회복하기 위한 것으로서 실질적으로 그 목적이 동일하고 두 청구권 모두 소유권에 기한 방해배제청구권으로서 그 법적 근거와 성질이 동일하므로, 공유자 중 한 사람은 공유물에 경료된 원인무효의 등기에 관하여 각 공유자에게 해당 지분별로 진정한 명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기를 이행할 것을 단독으로 청구할 수 있다(대판 2005. 9. 29, 2003다 40651).
 - 3) 법률에 의하여 소유권을 취득한 자가 그 등기명의를 회복하기 위한 방법으로 현재의 등기명의를 상대로 그 등기의 말소를 구하는 대신 진정한 등기명의를 회복을 원인으로 하는 소유권이전등기절차의 이행을 구하는 것은 그 필요성이 인정되는 한 법률상 허용되고, 이러한 법리는 분배농지의 상황을 완료한 수분배자나 그 상속인이 분배농지에 관하여 원인무효의 등기를 경료한 현재의 등기명의로에 대하여 진정한 명의회복을 위한 이전등기절차의 이행을 구하는 경우에도 마찬가지로 적용된다(대판 2009. 7. 9, 2008다 56019·56026)
- (2) 청구의 상대방은 진정한 명의로부터 직접 소유권이전등기를 경료받은 무권리자가 아니라 현재의 등기부상 소유명의로인이다(대판[전합] 1990. 11. 27, 89다카12398).

<명의신탁등기>

종래 명의신탁 : 다수설·판례에서 유효성 인정 ↔ 소수설 : 통정허위표시로서 무효.

부동산실권리자명의등기에 관한 법률

제3조(실권리자명의 등기의무 등)

- ① 누구든지 부동산에 관한 물권을 명의신탁약정에 따라 명의수탁자의 명의로 등기하여서는 아니 된다.

제4조(명의신탁약정의 효력)

- ① 명의신탁약정은 무효로 한다.
② 명의신탁약정에 따른 등기로 이루어진 부동산에 관한 물건변동은 무효로 한다. 다만, 부동산에 관한 물권을 취득하기 위한 계약에서 명의수탁자가 어느 한쪽 당사자가 되고 상대방 당사자는 명의신탁약정이 있다는 사실을 알지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.
③ 제1항 및 제2항의 무효는 제3자에게 대항하지 못한다.

<무효등기의 유용>

1. 의의 : 어떤 등기가 행하여졌으나 그것이 실체관계에 부합되지 않아서 무효이거나 사후적으로 무효로 된 후 그와 부합하는 실체관계가 생긴 경우에, 기존의 무효등기를 새로운 실체관계를 공시하는 등기로 그대로 이용하는 것을 무효등기의 유용이라고 한다.

2. 유형 :

- 1) 저당권등기의 유용(유효한 등기였다가 나중에 실체관계가 없어져 무효로 되었지만 그 후 권리관계의 내용에 있어서 처음의 것과 동일한 실체관계를 구비하게 된 경우)

→ 무효인 저당권설정등기의 유용에 관하여는 종래 무제한 긍정설·제한적 긍정설·부정설이 대립되었으나, 현재는 이해관계인의 부존재를 요건으로 하는 제한적 긍정설로 통일되었다. 판례도 저당권설정등기의 유용에 관하여는 그 유용합의 이전에 등기상의 이해관계 있는 제3자가 없는 경우에 한하여 유효하다고 하여 제한적 긍정설을 취하고 있다(대판 1994. 1. 28, 93다31702). 등기의 유효요건을 엄격히 할 경우에는 무효등기가 빈번히 생길 것이라는 점

- 2) 가장매매를 원인으로 한 등기(등기원인의 하자로 인하여 등기가 원시적으로 무효인 경우)

→ 나중에 등기와 부합하는 실체관계가 있으면 그때부터 등기가 유효

- 3) 표제부 유용(멸실된 건물의 보존등기를 신축한 건물의 보존등기로 유용하는 경우)

→ 신축건물과 멸실된 건물이 동일하다고 볼 수 없기 때문에 불허(대판 1976. 10. 26, 75다2211)

3. 요건

- ① 등기가 절차법상 유효한 등기로서의 요건을 갖추고 있어야 한다.
- ② 당사자 사이에 등기유용에 대한 합의가 있어야 한다. 등기유용의 합의는 법률행위에 상응하는 새로운 등기의 신청을 하는 대신 기존의 무효등기를 이용하기로 하는 등기신청에 준하는 절차법상의 합의이다. 합의는 묵시적으로도 할 수 있으며, 합의의 당사자는 원래의 등기의 당사자와 반드시 동일할 필요는 없다(대판 2007. 1. 11, 2006다50055).
- ③ 등기명의인 사이에 그 등기에 나타난 권리변동에 상응하는 법률행위가 있어야 한다. 즉 구실체관계가 소멸하고 이를 공시하던 등기가 말소되지 않고 있던 중 구실체관계와 동일한 새로운 실체관계가 발생하여야 한다(대법원 1969.3.4. 선고 67다2910).
- ④ 유용합의 이전에 이해관계를 맺게 된 제3자가 존재하지 않아야 한다. 즉 실질관계의 소멸로 무효로 된 등기의 유용은 그 등기를 유용하기로 하는 합의가 이루어지기 전에 등기상 이해관계가 있는 제3자가 생기지 않은 경우에 한하여 허용된다(대판 1989. 10. 27, 87다카425) (제3자 : 물권자로서 등기된 자/ 대항력 갖춘 임차권자, 처분금지가처분 등기한 자 O // 그러나 단순 채권자는 아님)

4. 효과

실체관계가 발생하고 등기유용 합의가 모두 갖추어진 때 효력 발생

(3) 법률행위 후 등기 전의 사정변경

- 1) 매매계약 후 부동산이 다른 사람에게 양도된 경우 그에 대하여 등기청구를 할 수 없고, 새 소유자와의 사이에 새로운 법률행위를 한 후에 그에 부합하는 등기를 하여야 한다.
- 2) 법률행위 후 매도인이 사망한 경우 제111조 제2항에 따라 법률행위는 영향받지 않는다. 실체법(민법)상 매도인의 상속인이 상속에 의한 등기를 하고(처분하기 위하여) 이후 매수인에게 이전등기를 해야 할 것이나, 절차법(부동산등기법)상 상속인으로부터 매수인에 대한 이전 등기에 관하여 규정하고 있다.

부동산등기법

제27조(포괄승계인에 의한 등기신청) 등기원인이 발생한 후에 등기관리자 또는 등기의무자에 대하여 상속이나 그 밖의 포괄승계가 있는 경우에는 상속인이나 그 밖의 포괄승계인이 그 등기를 신청할 수 있다.

- 3) 법률행위 후 행위능력을 상실한 경우에도 제111조 제1항에 따라 법률행위의 효력에 영향이 없고, 등기신청은 공법행위이지만 제한행위능력제도를 유추하여 법정대리인이 신청하거나 또는 사전 동의를 할 수 있다.
- 4) 법률행위 후 처분권이 제한된 경우 등기 불가

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 등기를 갖추지 않은 부동산매수인이더라도 목적부동산을 인도받은 이후에는 소유권에 기한 물권적 청구권을 행사할 수 있다.

- ② 이와 같은 미등기매수인의 경우에도 과실취득권은 갖는다.
- ③ 법률행위와 등기가 질적으로 불합치하는 경우 등기는 원칙적으로 무효이나 경정등기를 하거나 그 등기가 실체관계와 부합하는 등기로 되는 경우에는 물권변동이 일어난다.
- ④ 중간취득자의 동의나 전원의 합의가 있다면 이미 경료된 중간생략등기가 유효하다는 것이 판례의 입장이다.
- ⑤ 중간생략등기에 있어서 관계자 전원의 의사합치가 있어야 최후의 양수인이 최초의 양도인에 대하여 등기청구를 할 수 있다.

⇒ ①. 등기를 갖추지 못한 이상 물권변동이 일어나지 않으므로 소유권을 취득할 수 없고 소유권에 기한 물권적 청구권도 행사할 수 없다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 증여를 매매로 가장하여 등기하더라도 그 등기의 효력에는 하자가 없다.
- ② 이미 자기 앞으로 소유권을 표상하는 등기가 되어 있었거나 법률에 의하여 소유권을 취득한 자가 진정한 등기명의를 회복하기 위한 방법으로는 말소등기만이 가능하고 이전등기의 형식으로는 불가능하다.
- ③ 무효등기의 유용은 유용의 합의 이전에 등기부상 이해관계를 가지게 된 새로운 제3자가 없어야 가능하다.
- ④ 멸실된 건물의 보존등기를 신축한 건물의 보존등기로 유용하는 것은 허용되지 않는다.
- ⑤ 무효등기의 유용에 의하여 물권변동의 효력이 생기는바, 그 시점은 합의시이고 등기시로 소급하지는 않는다.

⇒ ②. 이 경우 현재의 등기명의인을 상대로 등기의 말소를 구하는 외에 진정한 명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기절차의 이행을 구하는 것도 허용된다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 진정명의 회복을 위한 소유권이전등기청구권은 소유권에 기한 방해배제청구권의 성격을 갖는 것으로서 말소등기청구권과 실질적으로 동일한 것이다.
- ② 따라서 양자의 소송물은 실질적으로 동일한 것으로 보아야 하므로 말소등기청구소송의 기판력은 진정명의 회복을 위한 소유권이전등기청구권에도 미친다.
- ③ 진정명의 회복을 위한 소유권이전등기를 청구할 수 있는 자는 물권자에 한하므로 명의신탁자, 특정수유자에게는 인정되지 않는다.
- ④ 진정명의 회복을 위한 소유권이전등기청구의 상대방은 현재 등기부상 소유명의인이다.
- ⑤ 부동산매매계약이 체결된 이후 매도인이 사망한 경우 반드시 상속에 의한 등기가 경료된 이후라야 상속인이 매수인에게 등기를 이전시킬 수 있다.

⇒ ⑤. 부동산등기법 제27조에서는 포괄승계인에 의한 등기신청을 규정하여 상속인이 등기를 신청할 수 있도록 하고 있다.

♣ 학습정리

1. 등기의 실체적 유효요건으로서 존재상 합치 및 내용상 합치를 요구한다.
2. 등기를 갖추지 않은 부동산매수인에게도 점유권, 점유보호청구권, 등기청구권, 과실수취권은 인정된다.
3. 이미 경료된 중간생략등기는 전원의 합의 외에 중간자의 동의로도 유효성이 인정되나, 중간 생략등기청구는 전원의 의사합치가 있는 경우에만 가능하다.
4. 실제와 다른 등기원인에 의한 등기이더라도 현재의 진실한 권리관계를 공시한다면 유효성이 긍정될 수 있다.
5. 실체관계에 부합하지 않는 무효의 등기가 경료된 경우 말소등기 대신 진정명의회복을 위한 소유권이전등기를 하는 것도 가능하다.
6. 무효인 등기이더라도 절차법상 유효하고 당사자 간 합의가 있으며 이해관계인이 존재하지 않는다면 그 등기를 유용하는 것도 가능하다.

제6강 법률행위에 의하지 않은 물권변동, 등기의 의의 및 종류

♣ 학습목표

1. 제187조에서 규정하는 법률행위에 의하지 않은 물권변동에 대하여 설명할 수 있다.
2. 등기의 종류를 정리할 수 있다.
3. 가등기에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

1. 제187조의 적용범위 : 법률행위에 의하지 않은 물권변동의 유형
2. 등기의 종류 - 사실/권리, 보존/권리변동, 기입/경정/변경/말소/멸실/회복, 주/부기, 종국/예비
3. 가등기의 종류 - 보전가등기, 담보가등기
4. 가등기상의 권리 이전 - 가등기의 부기등기, 가등기의 가등기

♣ 사전 테스트

1. 법률의 규정에 의한 물권변동은 등기를 필요로 하지 않는다.
⇒ ○ : 제187조에 의하여 등기가 요구되지 않는다.
2. 사실의 등기는 등기부상 갑구 및 을구에 기재된다.
⇒ × : 갑구 및 을구에 이루어지는 등기는 권리의 등기이다.
3. 가등기의 가등기도 불가능하다.
⇒ × : 판례는 가등기의 가등기, 가등기의 부기등기 모두 가능하다고 한다.

♣ 강의교안

제2관 법률행위에 의하지 않은 물건변동

1. 서설

- 등기를 요하지 않는 물건변동이란 법률의 규정에 의한 물건변동뿐 아니라 그밖에 당사자의 의사(법률행위)에 기하지 않은 물건변동을 총칭
- 시간 경과, 사망, 국가행위 등에 의하여 특정시점에 물건변동이 있었던 것으로 보아야 할 경우나 등기까지의 시간적 공백 문제 제거, 성질상 등기가 불가능하거나 법정책적 이유로 등기가 없더라도 물건변동 여부·시점이 명료
- 처분하기 위해서는 등기가 필요하다고 규정한 제187조 단서에 따라 등기 없는 처분은 무효이지만, 등기 없이 처분하더라도 채권적 효력은 인정

2. 적용범위

- 1) 포괄승계 : 상속, 포괄유증, 합병
- 2) 국가의 권력행위 : 공용징수, 판결(형성판결만 해당), 경매(공경매만 해당), 귀속재산의 귀속, 몰수, 농지분배 등
- 3) 기타 : 권리의 성질상 등기를 할 수 없는 경우(점유권, 유치권), 물건의 생멸·증감(신축건물의 소유권 취득), 소유자 부존재·불명(매장물 발견), 첨부, 혼동, 피담보채무 소멸로 인한 담보물권 소멸, 제한물권의 존속기간 만료, 법정책적 이유에 의한 물건변동(법정지상권, 관습법상 법정지상권, 법정저당권, 대위로 인한 저당권 이전)

제3관 부동산등기

I. 등기의 의의

- 등기공무원이 등기부라는 공적 정보저장매체에 부동산에 관한 일정한 권리관계를 기재하는 행위 또는 기재 그 자체

II. 등기의 종류

1. 사실의 등기 / 권리의 등기

- 1) 사실의 등기 : 위치, 사용목적, 면적 등 표제부에 하는 부동산 표시의 등기
- 2) 권리의 등기 : 부동산의 권리관계에 관하여 甲구(소유권), 乙구(소유권 이외)에 하는 등기

등기사항전부증명서(말소사실 포함)
- 집합건물 -

【표제부】 (건물의 현황 표시)

표제번호	등기	소재지(면적·건물면적 등)	건물 내역	등기사항 및 기타사항
1	2018년 12월 27일	서울특별시 강남구 테헤란로 12길 10, 11층 (전면적 1,100.00㎡, 건물면적 1,100.00㎡)	상업용 건물 (11층)	소유권(전부) 100% (소유권인도)

【대지권부】 (대지권부 현황 표시)

표제번호	소재지	면적	건물	등기사항 및 기타사항
1	서울특별시 강남구 테헤란로 12길 10	1,100.00㎡	11층	소유권(전부) 100% (소유권인도)

【권리부】 (권리부 현황 표시)

표제번호	등기	소재지	건물 내역	등기사항 및 기타사항
1	2018년 12월 27일	서울특별시 강남구 테헤란로 12길 10, 11층 (전면적 1,100.00㎡, 건물면적 1,100.00㎡)	상업용 건물 (11층)	소유권(전부) 100% (소유권인도)

등기부 등본 (권리 부속사항) - 토지

표제번호	등기	소재지	면적	건물	등기사항 및 기타사항
1	2018년 12월 27일	서울특별시 강남구 테헤란로 12길 10	1,100.00㎡	11층	소유권(전부) 100% (소유권인도)

등기부 등본 (권리 부속사항) - 건물

표제번호	등기	소재지	면적	건물	등기사항 및 기타사항
1	2018년 12월 27일	서울특별시 강남구 테헤란로 12길 10	1,100.00㎡	11층	소유권(전부) 100% (소유권인도)

2. 보존등기 / 권리변동의 등기

- 1) 보존등기 : 미등기 부동산에 관하여 최초로 행해지는 소유권의 등기
- 2) 권리변동의 등기 : 소유권보존등기를 기초로 이후에 행해지는 권리변동에 관한 등기

[illegible]

[결 구]		(소유권에 관한 사항)		
순위 번호	특 기 특 격	접 수	접 기 원 인	관 리 자 및 기 타 사 항
4	소유권이전	2012년 2월 8일 제2087호	2012년 2월 6일 매각	소유자 여가계 750614-1035853 서울특별시 중구구 청리공설 105 (원서증)
5	6번소유권자인 등기유언의배우 자최희봉최신애 관한부분에 대한 부분	2012년 4월 17일 제4639호	2012년 4월 1일 관봉	
6	5번등기유언의 부인등기앞소	2012년 5월 20일 제5678호	2012년 5월 14일 최광돌자거시결정 최소	

3. 등기내용에 따른 분류

- 1) 기입등기 : 새로운 등기원인에 기해 새로이 기입하는 등기(보통의 등기 : 소유권보존등기, 소유권이전등기, 저당권설정등기 등)
- 2) 경정등기 : 절차상 착오 등으로 인한 실체관계와 등기의 원시적 불일치를 시정하기 위한 등기(실수로 잘못 기재된 주소지 정정 등)
 - * 실질관계와 동일성이 인정되지 않는 등기는 무효로서 경정등기가 불가능(대판 2007.7.26, 2007다19006·19013)
- 3) 변경등기 : 등기사항의 변경으로 인한 실체관계와 등기의 후발적 불일치를 시정하기 위한 등기(소유자의 주소나 저당권의 이율 변경 등)
- 4) 말소등기 : 등기에 상응하는 실체관계가 부존재하거나(무효인 등기) 소멸한(채무변제로 인한 저당권 소멸) 경우 기존 등기 전부를 말소하는 등기
 - * 말소에 대하여 등기상 이해관계 있는 제3자(말소등기으로써 손해의 우려가 있는 등기상의 권리자)가 있는 경우 그의 승낙이 있어야 하는데, 그 제3자가 승낙의무를 부담하는지 여부는 승낙을 할 실체법상 의무가 있는지 여부에 의하여 결정
- 5) 멸실등기 : 대상 부동산이 멸실된 경우에 하는 등기
- 6) 회복등기 : 기존 등기가 부당하게 소멸한 경우 이를 복구하는 등기

4. 형식에 따른 분류

- 1) 주등기(독립등기) : 독립된 번호를 갖는 등기(원칙적인 형식)
- 2) 부기등기 : 주등기에 종속되어 독립된 번호 없이 주등기의 번호에 부가적인 호수를 기재하여 이루어지는 등기(기존 사항에 대한 추가적 기재),

5. 효력에 따른 분류

- 1) 종국등기(본등기) : 물건변동의 효력을 발생시키는 등기
- 2) 예비등기 : 장래 발생할 물건변동에 대비하는 등기(가등기와 예고등기가 이에 속하는데, 예고등기는 부동산등기법 개정으로 폐지)

예고등기제도 폐지(2011년 10월 13일)

舊부동산등기법 제4조(예고등기) 예고등기는 등기원인의무효나 취소로 인한 등기의 말소 또는 회복의 소가 제기된 경우에 한다. 그러나 그 무효나 취소로서 선의의 제3자에게 대항할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 공신의 원칙없는 점을 보완하기 위해서 소송제기 사실을 외부에 알리기 위함
- 지당권실행의 집행방해 등 강제집행절차를 방해할 목적으로 남용 현실(예를 들어 부동산 경매의 위험에 있는 자가 다른 사람과 공모하여 자신을 상대로 소유권이전등기 말소청구소송 등 허위채권 소송을 제기토록 하여 일반인의 입찰기회를 줄이거나 수차례 유찰시켜 저가로 낙찰받아 채권자를 해하여 왔음)

3) 가등기

▶ 돌발 퀴즈

정지조건부·시기부 법률행위는 조건성취·기한도래시까지 등기할 수 없으므로 이에 관한 가등기도 불가능하다.

⇒ × : 가등기는 장래 행하여질 본등기의 순위를 보전해주는 효력을 갖는 등기로서 장래 확정되는 정지조건부·시기부 청구권의 보전을 위하여 가등기가 이루어질 수 있다.

1) 의의

- 장차 행해질 본등기의 순위를 보전하는 등기
- 시기부·정지조건부 청구권, 예약완결권 등의 청구권 보전 : 물건변동은 본등기가 있어야 일어나지만 그 순위는 가등기의 순위에 따른다.

순번	등기 목적	등기 순위	등기 원 인
1	소유권이전등기	1	갑
2	소유권이전등기	2	을
3	소유권이전등기	3	병
4	소유권이전등기	4	정
5	소유권이전등기	5	미
6	소유권이전등기	6	바
7	소유권이전등기	7	사
8	소유권이전등기	8	아
9	소유권이전등기	9	자
10	소유권이전등기	10	차
11	소유권이전등기	11	니
12	소유권이전등기	12	하
13	소유권이전등기	13	마
14	소유권이전등기	14	루
15	소유권이전등기	15	리
16	소유권이전등기	16	로
17	소유권이전등기	17	조
18	소유권이전등기	18	구
19	소유권이전등기	19	김
20	소유권이전등기	20	박
21	소유권이전등기	21	최
22	소유권이전등기	22	한
23	소유권이전등기	23	정
24	소유권이전등기	24	전
25	소유권이전등기	25	남
26	소유권이전등기	26	이
27	소유권이전등기	27	윤
28	소유권이전등기	28	조
29	소유권이전등기	29	구
30	소유권이전등기	30	김
31	소유권이전등기	31	박
32	소유권이전등기	32	최
33	소유권이전등기	33	한
34	소유권이전등기	34	정
35	소유권이전등기	35	전
36	소유권이전등기	36	남
37	소유권이전등기	37	이
38	소유권이전등기	38	윤
39	소유권이전등기	39	조
40	소유권이전등기	40	구
41	소유권이전등기	41	김
42	소유권이전등기	42	박
43	소유권이전등기	43	최
44	소유권이전등기	44	한
45	소유권이전등기	45	정
46	소유권이전등기	46	전
47	소유권이전등기	47	남
48	소유권이전등기	48	이
49	소유권이전등기	49	윤
50	소유권이전등기	50	조
51	소유권이전등기	51	구
52	소유권이전등기	52	김
53	소유권이전등기	53	박
54	소유권이전등기	54	최
55	소유권이전등기	55	한
56	소유권이전등기	56	정
57	소유권이전등기	57	전
58	소유권이전등기	58	남
59	소유권이전등기	59	이
60	소유권이전등기	60	윤
61	소유권이전등기	61	조
62	소유권이전등기	62	구
63	소유권이전등기	63	김
64	소유권이전등기	64	박
65	소유권이전등기	65	최
66	소유권이전등기	66	한
67	소유권이전등기	67	정
68	소유권이전등기	68	전
69	소유권이전등기	69	남
70	소유권이전등기	70	이
71	소유권이전등기	71	윤
72	소유권이전등기	72	조
73	소유권이전등기	73	구
74	소유권이전등기	74	김
75	소유권이전등기	75	박
76	소유권이전등기	76	최
77	소유권이전등기	77	한
78	소유권이전등기	78	정
79	소유권이전등기	79	전
80	소유권이전등기	80	남
81	소유권이전등기	81	이
82	소유권이전등기	82	윤
83	소유권이전등기	83	조
84	소유권이전등기	84	구
85	소유권이전등기	85	김
86	소유권이전등기	86	박
87	소유권이전등기	87	최
88	소유권이전등기	88	한
89	소유권이전등기	89	정
90	소유권이전등기	90	전
91	소유권이전등기	91	남
92	소유권이전등기	92	이
93	소유권이전등기	93	윤
94	소유권이전등기	94	조
95	소유권이전등기	95	구
96	소유권이전등기	96	김
97	소유권이전등기	97	박
98	소유권이전등기	98	최
99	소유권이전등기	99	한
100	소유권이전등기	100	정

2) 종류① 보전가등기 : 부동산물권(소유권·지상권·지역권·전세권·저당권) 및 부동산에 관한 권리(권리질권·임차권), 채권담보권의 설정·이전·변경 또는 소멸의 청구권의 순위 보전을 그 본래의 기능(매매예약)

② 담보가등기 : 변태적으로 소비대차, 대물변제의 예약을 하는 경우에는 일반적으로 담보의 목적(대물변제예약)

③ 구별기준 : 실제의 목적을 기준

가등기가 순위보전가등기인지 담보가등기인지 여부는 당해 가등기가 실제상 채권담보를 목적으로 한 것인지 여부에 의하여 결정되는 것이지 당해 가등기의 등기부상 원인이 매매예약으로 기재되어 있는지 아니면 대물변제예약으로 기재되어 있는가 하는 형식적 기재에 의하여 결정되는 것이 아니다(대판 1998. 10. 7, 98마1333). 가등기가 담보가등기인지 여부는 그 등기부상 표시나 등기시에 주고 받은 서류의 종류에 의하여 형식적으로 결정될 것이 아니고 거래의 실질과 당사자의 의사해석에 따라 결정될 문제라고 할 것이다(대판 1992. 2. 11, 91다36932).

④ 효력상의 차이

일반적으로 가등기는 순위보전의 효력만 가지지만(통설·판례) 담보가등기는 그 밖에 실체적 효력이 인정된다. 즉, 가등기담보의 목적물이 다른 채권자에 의해 경매에 붙여진 경우, 가등기담보권자는 가등기인 채로 그 가등기의 순위를 가지고 우선변제권을 행사할 수 있다. 가등기가 된 부동산이 경매가 된 때에는 순위보전의 가등기인 경우에는 그것이 최선순위의 가등기인 경우에는 경매가 되어도 존속하지만(대결 2003. 10. 6, 2003마1438 참조), 담보가등기인 때에는 최선순위라도 경매에 의하여 소멸하고 다만 순서에 따른 우선변제를 받을 뿐이다. 가등기에 기한 본등기가 된 경우 후순위등기(중간처분등기)의 운명은 청구권의 순위를 보전하기 위한 가등기의 경우라면 후순위등기(중간처분등기)가 직권말소되지만(대결[전함] 1962. 12. 24, 4294민재항675), 담보가등기라면 본등기가 되더라도 그것이 담보권실행이 아닌 한 그 후순위등기(중간처분등기)는 직권말소되지 않는다(대결 1998. 10. 7, 98마1333).

3) 가등기의 절차

① 가등기의 신청 : 공동신청(가등기의무자의 승낙이 있으면 신청서에 승낙서를 첨부하여 가등기권리자가 단독으로 신청/ 판결/ 가처분명령에 의한 촉탁).

② 가등기를 본등기로 하는 절차 : 공동신청

4) 중간처분등기가 있는 경우 가등기권리자는 어떻게 본등기를 하는가?

청구권보전의 가등기가 있는 후 소유자가 제3자에게 소유권이전등기를 해준 경우(즉 중간처분등기가 있는 경우)에 가등기권리자는 어떤 절차를 거쳐서 본등기를 하여야 하는지가 문제된다. 즉 소유자로부터 하여야 하는가, 아니면 제3자로부터 하여야 하는지가 문제된다. (예를 들어 A가 그 소유부동산에 대해 B와 매매계약을 체결하고, B는 소유권이전청구권을 보전하기 위해 가등기를 한 후 A가 그 부동산을 C에게 양도한 경우, B가 가등기에 기해 본등기를 하고자 할 때 그 등기의무자는 누구이며, 또 C의 등기는 어떻게 처리되는가?)

→ 견해의 대립이 있었으나 종전의 판례(가등기권리자가 가등기의무자를 상대로 본등기를 하여야 하며, 그 본등기가 있게 되면 그와 저촉되는 제3자의 등기는 등기공무원이 직권으로 말소할 수 있다(대결[전함] 1962. 12. 24, 4294민재항675))에 따라 부동산 제92조를 신설하여 입법적으로 해결하였다.(그리고 지체 없이 그 사실을 말소된 권리의 등기명의자에게 통지하여야 한다)

5) 가등기상의 권리 이전

Q : : 가등기의 부가등기

예를 들어, B가 A로부터 부동산을 매수하면서 소유권이전등기청구권 보전을 위하여 가등기를 경료한 상태에서 그 소유권이전등기청구권을 C에게 양도한 경우와 같이 가등기에 의하여 보전된 청구권이 양도된 경우에 그 양도의 가등기가 가능한가?

→ 가등기에 대한 부가등기의 형식으로 할 수 있다(대판(전합) 1998. 11. 19, 98다24105).

Q : 가등기의 가등기

B가 부동산소유권을 취득하면 저당권을 설정하여 주기로 하고 D와 금전소비대차계약을 체결한 경우 D의 저당권설정등기청구권을 보전하기 위한 가등기가 가능한가?

→ 가등기의 가등기 역시 인정(동일 판례)

Q : 가등기상의 권리처분금지가처분

가등기상의 권리가 양도할 수 있는 권리라면 이를 타에 처분(양도·이전)하는 것을 금지하는 가처분도 허용됨은 당연하다. → 등기 가능

▶ 돌발 퀴즈

자신이 거주하고 있는 부동산의 등기부, 건축물대장을 확인하고, 권리관계를 확인하세요.

1. 정부 24 <https://www.gov.kr/portal/main>
2. 법원 인터넷 등기소 <http://www.iros.go.kr/PMMainJ.jsp>

⇒ 법원 인터넷 등기소에서는 각종 등기열람이, 정부24에서는 주민등록등본, 건축물대장, 토지대장, 지적도 등을 확인할 수 있다.

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 제187조가 적용되는 법률의 규정에 의한 물권변동은 등기를 요하지 않으므로 그 처분에 있어서도 등기를 필요로 하지 않는다.
- ② 제187조에서의 ‘판결’은 실체법상의 형성판결만을 의미하고 이행판결은 포함되지 않는다.
- ③ 제187조에서의 ‘경매’는 국가기관이 하는 공경매를 의미한다.
- ④ 자기의 비용과 노력으로 건물을 신축한 자는 건축허가가 타인의 명의이더라도 건물의 소유권을 원시취득한다.
- ⑤ 피담보채무의 소멸로 인하여 담보물권이 소멸된 경우에도 등기를 필요로 하지 않는다.

⇒ ① 제187조 단서에서는 처분하려면 등기가 있어야 한다고 규정한다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 사실의 등기는 표제부에, 권리의 등기는 갑구 내지 을구에 각각 기재된다.
- ② 등기와 실체관계의 원시적 불일치가 있으면 경정등기, 후발적 불일치가 있으면 변경등기가 이루어질 수 있다.

- ③ 경정등기는 동일성이 유지되는 범위 내에서 이루어질 수 있고, 실질관계와 동일성이나 유사성을 인정할 수 없다면 경정등기가 허용되지 않고 그 등기는 무효이다.
- ④ 말소등기에 있어서는 등기부상 이해관계 있는 제3자의 승낙을 얻어야 한다.
- ⑤ 부기등기는 주등기에 종속되는 것이지만, 주등기가 말소되는 경우에도 부기등기가 존치될 수 있다.

⇒ ⑤. 부기등기는 주등기와 일체를 이루는 것이므로 주등기가 말소되면 부기등기도 직권말소될 성질의 것이므로 부기등기만의 말소청구는 권리보호의 이익이 없는 부적법한 청구이다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 청구권의 순위를 보전하기 위한 것이 아닌 물권적 청구권을 보전하기 위한 가등기는 허용되지 않는다.
- ② 가등기에는 청구권의 순위를 보전하기 위한 보전가등기 이외에도 담보의 목적으로 이루어지는 담보가등기도 있다.
- ③ 보전가등기의 경우에는 순위보전의 효력만을 갖지만, 담보가등기의 경우에는 가등기인 채로 그 순위를 가지고 우선변제권을 행사할 수 있다.
- ④ 보전가등기의 경우에는 부동산이 경매가 된 때에도 최선순위이더라도 소멸하지만, 담보가등기의 경우 최선순위인 경우 여전히 존속한다.
- ⑤ 가등기의 가등기는 가능하지만, 가등기의 부기등기는 불가능하다.

⇒ ⑤. 판례는 양자 모두 긍정한다.

♣ 학습정리

- 1. 법률행위에 의하지 않은 물건변동은 제187조에 따라 등기를 요하지 않는다.
- 2. 실질관계와 동일성이 인정되지 않는 등기는 무효로서 경정등기가 불가능하다.
- 3. 말소등기에 관하여 등기상 이해관계 있는 제3자(말소등기으로써 손해의 우려가 있는 등기상의 권리자)가 있는 경우 그의 승낙이 있어야 한다.
- 4. 보전가등기는 순위보전의 효력만 갖지만, 담보가등기는 우선변제권 행사가 가능하다.
- 5. 판례는 가등기에 대한 가등기 형식은 물론이고 가등기의 부기등기 형식도 인정한다.

제7강 등기의 절차, 등기청구권, 등기의 효력 (1)

♣ 학습목표

1. 등기기관, 등기공부, 등기절차 관련사항을 정리할 수 있다.
2. 등기청구권의 발생원인·법적 성질 그리고 소멸시효, 대상적격에 관한 학설·판례의 법리를 설명할 수 있다.
3. 본등기의 효력으로서 권리변동적 효력, 순위확정력, 대항적 효력, 추정적 효력, 공신력 등을 정리할 수 있다.

♣ 학습내용

1. 등기기관, 등기공부, 등기절차
2. 등기청구권의 발생원인 및 법적 성질
3. 등기청구권의 소멸시효 대상적격
4. 본등기의 효력 - 권리변동적 효력, 순위확정력, 대항적 효력, 추정적 효력, 공신력
5. 등기의 추정력 - 추정의 본질·범위·효과

♣ 사전 테스트

1. 등기는 단독신청을 원칙으로 한다.
⇒ × : 공동신청이 원칙이지만, 공동신청에 의하지 않더라도 등기의 진정을 담보할 수 있는 경우 또는 성질상 등기의무자가 없는 경우에는 단독신청이 인정된다.
2. 등기청구권은 등기권리자가 등기의무자를 상대로 하는 경우만 인정된다.
⇒ × : 등기권리자가 등기의무자를 상대로 하는 것이 일반적인 형태이지만, 소유자로서의 민사책임이나 세금 등의 부담을 피하기 위하여 등기의무자가 등기권리자를 상대로 등기청구권을 행사할 수도 있다(등기인수청구권).
3. 등기의 추정력의 물적 범위에는 대리권존재의 추정도 포함된다.
⇒ ○ : 매매를 원인으로 하는 소유권이전등기의 명의인은 본인이 직접 또는 대리인에 의하여 적법하게 매수한 것으로 추정한다.

♣ 강의교안

III. 등기기관, 등기공부, 등기절차

1. 등기기관

- 등기소 : 부동산 소재지의 지방법원, 지원, 등기소
- 등기관

2. 등기공부 : 등기부, 대장

- 부동산의 물적 상황 내지 동일성 : 대장의 기재가 기준
- 권리의 변동 : 등기부의 기재가 기준

3. 등기절차

(1) 실체법상 등기사항 / 절차법상 등기사항

1) 실체법상 등기사항 : 등기하지 않으면 실체법상 효력이 발생하지 않는 사항

→ 제186조, 제187조에 의하여 정해지는 문제

2) 절차법상 등기사항 : 당사자의 등기신청 및 등기공무원의 직무·권한이 인정되는 사항

→ 부동산등기법상 등기가 허용되는 사항(등기능력)

(2) 등기의 신청

1) 원칙 : 공동신청

2) 예외 : 단독신청, 대위신청, 대리인에 의한 신청

(3) 등기의 심사 : 등기관은 등기절차상의 적법성 여부만을 심사(실질적 심사권 없음)

IV. 등기청구권

1. 의의

등기의 진정을 담보하기 위하여 부동산등기법 제23조 제1항은 등기관리자와 등기의무자의 공동신청주의를 취하고 있다. 그런데 당사자 일방(등기의무자)이 등기 신청에 협력하지 않으면 다른 당사자(등기관리자)가 단독으로 등기를 신청할 수 없게 된다.

여기서 등기관리자가 등기의무자에게 등기 신청에 협력할 것을 청구할 수 있는 권리를 인정할 필요가 있다. 즉 등기관리자가 등기의무자에 대하여 등기에 협력하여 줄 것을 청구할 수 있는 권리가 등기청구권이다.

* 등기신청권과 구별 : 등기를 신청할 수 있는 절차법상의 권리

* 등기인수청구권과 구별 : 등기의무자가 등기관리자를 상대로 등기청구권을 행사할 수 있는 바(대판 2001. 2. 9, 2000다60708), 이를 등기인수청구권이라고 한다(소유자로서의 민사책임(예를 들어 제758조) 또는 세금 등 공과의 부담을 피하기 위함).

2. 발생원인과 법적 성질

(1) 법률행위에 의한 물건변동에서의 등기청구권 → 채권적 청구권설(통설·판례)

물권변동을 목적으로 하는 채권행위가 있으면 그 채권행위에서 등기청구권이 당연히 발생하므로 그 성질은 채권적 청구권이라고 한다.

① 매매계약 -- → ② 물권적 합의 -- → ③ 등기

1. 채권적 청구권설 (다수설·판례)

- 1) ①(매매계약 : 채권행위)에서 발생한다는 견해 : 물권행위와 채권행위는 합체하여 이루어진다는 독자성 부인론의 입장에서, 또는 독자성을 인정하면서도 ①에서 발생
- 2) ②(물권적 합의)에서 발생하지만 등기가 없어서 아직 물권행위로 완성되지 않았으므로 여전히 등기청구권은 채권적 청구권
→ 이 견해에 의하면 등기청구권은 10년의 시효소멸에 걸리고, 채권양도방법(대항요건 : 통지·승낙)에 따라 양도가능. ↔ 다만 판례는 동의·승낙을 요구한다(매도인과 매수인의 신뢰관계를 이유로 소유권이전등기청구권의 양도성 제한).

2. 물권적 청구권설

- 1) 물권적 합의에서 발생한다는 견해
- 2) 물권적 기대권의 효력으로부터 도출된다는 견해
→ 시효소멸하지 않고, 자유롭게 양도가능

3. 판례(채권행위로부터 발생하는 채권적 청구권)

판례는 등기청구권을 채권행위로부터 발생하는 채권적 청구권으로 본다(대판 1997. 9. 22, 95다17298). 다만 부동산매수인이 매도인에 대하여 가지는 등기청구권은 채권적 청구권이지만, 매수인이 목적물을 인도받아 점유하고 있다면 그 등기청구권은 소멸시효에 걸리지 않는다고 한다(대판[전합] 1976. 11. 6, 76다148; 대판 1991. 12. 27, 91다35410; 대판 1996. 9. 20, 96다68).

나아가 판례는 최근에 부동산의 매수인이 그 부동산을 인도받은 이상 이를 사용·수익하다가 그 부동산에 대한 보다 적극적인 권리행사의 일환으로 다른 사람에게 그 부동산을 처분하고 그 점유를 승계하여 준 경우에도, 그 이전등기청구권의 행사 여부에 관하여 그가 그 부동산을 스스로 계속 사용·수익만 하고 있는 경우와 특별히 다를 바 없으므로, 위 두 어느 경우에도나 이전등기청구권의 소멸시효는 마찬가지로 진행되지 않는다(대판[전합] 1999. 3. 18, 98다32175)고 하여 그 적용범위를 더욱 확장하고 있다.

4. 검토

물권행위는 이행의 문제를 남기지 않는 행위임에도 물권행위로부터 발생한다는 것은 논리적 모순. 등기는 채권행위의 결과인 급부의무의 실현단계로서 등기청구권의 내용은 일반적으로 물권행위로 파악되는 '등기에 필요한 서류의 인도'를 요구하는 것이므로 채권행위로부터 발생하는 채권적 청구권이라는 견해가 타당

(2) 실체관계와 등기가 일치하지 않는 경우 → 물권적 청구권

등기와 실체적 권리관계가 일치하지 않는 경우에는 진정한 물권자는 물권의 완전한 실현을 방해당하고 있다고 할 것이므로 그 방해를 제거하기 위하여 등기청구권이 생긴다고 보아야 하고, 이 경우의 등기청구권은 물권의 효력으로서 파생하는 일종의 물권적 청구권이라는 것이 학설·판례(대판 1964. 11. 24, 64다851·852)의 일치된 견해이다.

가등기에 기한 소유권이전등기청구권이 시효의 완성으로 소멸되었다면, 그 가등기 이후에 그 부동산을 취득한 제3자는 그 소유권에 기한 방해배제청구로서 그 가등기권자에 대하여 본등기청구권의 시효소멸을 주장하여 그 등기의 말소를 구할 수 있다(대판 1991. 3. 12, 90다카27570).

(3) 시효에 의한 물권의 득실

1) 취득시효에 의한 물권의 득실 → 채권적 청구권(통설·판례)

→ 점유취득시효에서만 문제됨(등기부취득시효에서는 이미 등기되어 있으므로 등기청구권은 발생하지 않음)

- 채권적 청구권설(통설·판례) : 제245조 제1항의 “등기함으로써 그 소유권을 취득한다” 문언
- 물권적 청구권설 : 취득시효가 완성함으로써 물권적 기대권이라거나 취득시효 요건을 갖춘 점유자는 사실상 소유권이 있다는 견해

2) 소멸시효에 의한 물권의 득실 → 물권적 청구권(실체관계와 등기가 일치하지 않는 경우와 동일)

- 절대적 소멸설 → 실체관계와 등기가 일치하지 않은 경우와 동일
- 상대적 소멸설 → 시효완성에 의하여 시효원용권이 발생하고 이 권리의 행사로 시효대상인 권리가 소멸하므로 실체관계와 등기가 일치하지 않게 됨(시효원용권을 행사하지 않으면 등기청구권이 문제되지 않음)

(4) 부동산임차권 → 채권적 청구권

(5) 부동산환매권 → 채권적 청구권

3. 등기청구권의 행사

- 등기권리자(등기의무자도 행사 가능 : 등기인수청구권)
- 채권자대위권의 객체 가능(판례). 이 때 채무자의 무자력을 요구하지 않음
- 중간생략등기의 경우 최종매수인은 최초 매도인에게 직접 이전등기청구 가능(합의 필요)

4. 등기청구권의 소멸시효 대상적격

- 실체관계와 등기가 일치하지 않는 경우 물권적 청구권이므로 본권과 별도로 소멸시효에 걸리지 않는다.
- 그 밖에 채권적 청구권으로 인정되는 경우 10년의 소멸시효에 걸린다.

V. 등기의 효력

1. 본등기의 효력

1) 권리변동적 효력(창설적 효력)

부동산등기법

제6조(등기신청의 접수시기 및 등기의 효력발생시기)

- ① 등기신청은 대법원규칙으로 정하는 등기신청정보가 전산정보처리조직에 저장된 때 접수된 것으로 본다.
- ② 제11조제1항에 따른 등기관이 등기를 마친 경우 그 등기는 접수한 때부터 효력을 발생한다.

→ 종래 등기의 효력이 발생하는 시기에 관하여 견해의 대립을 입법적으로 해결

2) 순위확정력 (↔ 순위승진의 원칙)

- ㉠ 같은 구의 등기들의 선후 → 순위번호
- ㉡ 다른 구의 등기들의 선후 → 접수번호
- ㉢ 부기등기의 순위 → 주등기의 순위

→ 이 효력의 내용으로 이미 등기가 행하여졌다면 이와 양립할 수 없는 등기를 할 수 없다.

3) 대항적 효력

㉠ 부동산환매권등기와 부동산임차권등기는 권리변동적 효력은 발생하지 않고 제3자에 대한 대항적 효력만이 발생한다(제592조·제621조 제2항).

㉡ 지상권·지역권·전세권·저당권·저당권에 대한 권리질권 등 부동산제한물권이나, 환매권·부동산임차권과 같은 부동산채권에 관하여는 권리변동 외에 존속기간·지료·이자·지급시기 등 일정한 사항을 등기할 수 있다(부동산등기법 제53조·제69조·제72조·제74조·제75조).

→ 이 사항들을 등기하지 않으면 당사자 사이에 채권적 효력만 있으나, 등기한 때에는 제3자에 대하여도 대항할 수 있다.

4) 추정적 효력 (등기의 추정력)

① 의의

부동산물권변동을 공시하는 등기가 있으면, 그에 대응하는 실체적 권리관계가 등기명의인에게 존재하는 것으로 추정되는 것을 등기의 추정적 효력(또는 推定力)이라고 한다. 따라서 어떤 부동산이 甲의 소유로 보존등기가 되어 있으면, 그 부동산은 甲의 소유인 것으로 추정되고, 甲으로부터 乙에게 소유권이전등기가 되어 있는 부동산은 그의 소유에 속하는 것으로 추정된다.

→ 따라서 등기사실의 진실성을 부인하려는 자가 그에 대한 (주장 및) 증명책임을 진다.

Q : 민법 제200조는 점유자가 점유물에 대하여 행사하는 권리는 적법하게 보유한 것으로 추정한다고 규정하고 있는데, 동 조항이 동산뿐만 아니라 부동산에도 적용되는지가 문제된다.

1) 등기된 부동산

등기된 부동산의 경우에는 등기가 되어 있으므로 등기의 추정력이 점유의 추정력보다 더 강하므로 등기의 추정력만 적용되고, 제200조는 적용되지 않는다는 것이 통설과 판례(대판 1982. 4. 13, 81다780)이다.

2) 미등기의 부동산

미등기의 부동산의 경우에 제200조의 점유의 추정력을 적용할 것인가에 대하여 다툼이 있다.

i) 긍정설은 미등기 부동산의 경우에는 등기에 의존할 수가 없으므로 점유로 권리를 추정하여야 한다는 것을 근거로 한다.

ii) 부정설은 불완전한 공시방법인 점유에 부동산물권의 존재를 추정하는 것은 아무리 부동산에 관하여 등기가 없는 경우에 국한한다 하더라도 부동산의 성질 및 그 중요성에 비추어 타당하지 않다고 한다. 판례는 민법 제200조는 동산에 관한 규정이므로 등기 여부를 불문하고 부동산에는 적용이 없다고 한다(대판 1982. 4. 13, 81다780). 미등기토지에 점유자가 있는 경우에도 토지대장등본에 토지소유자로 등재된 자가 소유권자로 추정을 받는다(대판 1976. 9. 28, 76다1431)고 판시하여 미등기부동산의 경우에 점유의 추정력을 배제한다.

② 추정의 본질

- 다수설·판례 : 법률상 권리추정

㉠ 실체관계와 부합할 개연성 : 사실상 추정일 때 사용하는 논거라는 비판

㉡ 동산의 점유에 관하여 제200조가 권리추정을 인정하고 있으므로, 그보다 실체관계와 부합할 가능성이 훨씬 큰 공시방법인 등기에 관해서도 인정

참고

① 법률상 추정 : 법률이 있으면 그 법률이 권리나 사실을 추정한다(법률상 권리추정/법률상 사실추정)

② 사실상 추정 : A 사실이 있으면 B라는 권리나 사실을 추정한다(사실상 권리추정/사실상 사실추정)

③ 추정의 범위

㉠ 물적 범위

- 전제조건인 충족 추정

등기가 적법한 절차에 의하여 종료되었고 그 전제조건이 있을 경우에는 그것이 적법하게 충족되었을 것이라고 추정된다.

- 등기절차의 적법 추정

전 등기명의인이 미성년자이고 당해 부동산을 친권자에게 증여한 행위가 이해상반행위이더라도, 일단 친권자에게 이전등기가 경료되었다면, 특별한 사정이 없는 한 그 이전등기에 관하여 필요한 절차를 적법하게 거친 것으로 추정된다(대판 2002.2.5, 2001다72029).

- 기재사항의 적법 추정

담보물권의 등기는 그 담보물권의 존재 자체뿐만 아니라 이에 상응하는 피담보채권도 존재한다고 추정된다(대판 1969. 2. 18, 68다2329).

- 등기원인 추정

- 긍정설(다수설·판례) : 등기는 등기원인으로부터 연유한 것이므로 등기원인의 추정은 당연
- 부정설(소수설) : 등기관이 실질심사권이 없어 실제와 다른 등기원인의 실례가 많음

- 대리권존재의 추정

· 매매를 원인으로 하는 소유권이전등기의 명의인은 본인이 직접 또는 대리인에 의해 적법하게 매수한 것으로 추정한다(대판 1999. 2. 26, 98다56072).

㉞ 인적 범위

- 등기의 추정력은 등기명의인의 이익을 위해서만 인정되는 것이 아니고, 제3자도 추정의 효과를 원용할 수 있음

▶ 돌발 퀴즈

소유권이전등기의 추정력은 제3자에게만 미치고 권리변동의 당사자 간에는 미치지 않는다.

⇒ × : 판례는 소유권이전등기가 경료되어 있는 경우 그 등기명의자는 제3자에 대해서뿐만 아니라 그 전 소유자에 대해서도 적법한 등기원인에 의하여 소유권을 취득한 것으로 추정한다.

- 소유권이전등기의 추정력이 권리변동의 당사자에도 미치는가?

A(전등기명의인)이 B(현등기명의인)에 대하여 등기원인의 무효 내지 부존재를 이유로 A로부터 B에게의 이전등기의 말소를 청구하는 경우에 B는 그 등기의 추정력을 원용하여 자기가 진정한 소유자라고 주장할 수 있는가

· 부정설

등기의 효력은 그 실체관계의 존부에 의하여 좌우되는데 등기가 있다는 것만으로 그 등기원인으로 기재된 매매·증여 등의 법률관계가 있다는 추정은 이루어지지 않으므로 현 등기명의인이 등기원인의 존재를 주장하고 증명하여야 한다.

· 긍정설

부정설에 의하면 소유권이전등기를 받았음에도 불구하고 전등기명의인이 소유권이전등기의 말소등기를 청구할 것에 대비하여 등기부 취득시효가 완성될 때까지 매매계약서 및 영수증을 보관하여야 한다는 불합리한 결과에 도달하며, 또한 당사자 간에 등기의 추정력을 부정할 이론적 근거가 없다. 따라서 전 등기명의인이 등기원인의 부존재 등을 주장·증명하여야 한다.

· 판례

소유권이전등기가 경료되어 있는 경우에는 그 등기명의자는 제3자에 대해서 뿐만 아니라 그 전 소유자에 대해서도 적법한 등기원인에 의하여 소유권을 취득한 것으로 추정된다(대판 1982. 6. 22, 81다791; 대판 2000. 3. 10, 99다65462).

※ 소유권보존등기의 경우

보존등기는 단독신청에 의하므로 진실성이 보다 약하다고 할 것이므로 보존등기 명의자에 대하여는 소유권이 보존되어 있다는 사실만 추정되고 권리변동이 진실하다는 점까지 추정되지 않는다(통설·판례).

· 소유권보존등기의 경우에는 그 명의자가 전소유자로부터 소유권을 양도받은 것이라는 주장을 하더라도 전소유자가 양도사실을 부인하면 그 명의자는 소유자로 추정되지 않는다(대판 1982. 9. 14, 82다카707).

· 신축된 건물의 소유권은 이를 건축한 사람이 원시취득하는 것이므로, 건물 소유권보존등기의 명의자가 이를 신축한 것이 아니라면 그 등기의 권리추정력은 깨어지고, 등기명의자가 스스로 적법하게 그 소유권을 취득한 사실을 증명하여야 한다(대판 1996. 7. 30, 95다30734).

③ 추정의 효과

- 기본적 효과 : 등기의 추정력에 의하여 등기가 된 권리가 존재하는 것으로 추정, 양립할 수 없는 사실을 주장하는 자가 그 사실에 대한 반대증거(본증)를 제출해야 함

- 부수적 효과 : 등기내용에 관한 악의추정과 그 내용을 신뢰한 자의 무과실추정, 등기부를 조사하지 않아서 등기되어 있는 사실을 알지 못한 경우에 선의이지만 과실이 있는 것으로 추정(대판 1994. 6. 28, 94다94다7829)

④ 추정의 복멸

추정력이 반복되는 경우(10가지) 로는

(i) 사망자가 등기의무자로서 등기 신청된 경우, 즉 등기명의자가 사망한 후에 그자로부터 이전등기를 받은 경우(대판 1983. 8. 23, 83다카597 : 대판 2004. 9. 3, 2003다3157 참조),

(ii) 전 소유명의자가 虛無人인 경우, 즉 실재하지 않는 허무인으로부터 이전받은 등기의 경우(대판 1985. 11. 12, 84다카2494),

(iii) 등기명의자 이외의 제3자가 매수인으로서 매매계약을 체결한 경우(대판 1968. 8. 12, 68다1962),

(iv) 등기절차에 이상 있음이 판명된 경우(대판 2003. 2. 28, 2002다46256),

(v) 소유권이전등기의 원인으로 주장된 계약서가 진정하지 않은 것으로 증명된 경우(대판 1998. 9. 22, 98다29668),

(vi) 구 부동산소유권이전등기등에관한특별조치법(또한 구임야소유권이전등기등에관한특별조치법도 마찬가지이다)의 적용을 받을 수 없는 시점의 취득원인 일자를 내세우는 경우와 같이 그 주장 자체에서 위 특별조치법에 따른 등기를 마칠 수 없음이 명백하거나 그 주장하는 내용이 구체성이 전혀 없다든지 그 자체로서 허구임이 명백한 경우 등 특별한 사정이 있는 경우(대판 [전합] 2001. 11. 22, 2000다71388·71395 : 대판 2006. 2. 23, 2004다29835 : 대판 2010. 2. 25, 2009다98386 등 참조),

(vii) 소유권보존등기 명의인 이외의 자가 당해 토지를 사정받은 것으로 밝혀지는 경우(대판 2008. 12. 24, 2007다79718 : 대판 1997. 5. 23, 95다46654·46661 : 대판 1998. 9. 8, 98다13686 등 참조),

(viii) 등기의 일괄신청을 허용하지 않던 구 부동산등기법을 위반하여 등기의무자가 갑부동산과 동일한 등기원인, 접수일, 접수번호로 을부동산에 관한 소유권이전등기를 마친 경우(대판 2008. 3. 27, 2007다91756 : 대판 1957. 10. 21, 4290민상251·252 : 대판 2002. 2. 5, 2001다7202 9 : 대판 2003. 2. 28, 2002다46256 등)

(ix) 등기 기재 자체에 의하여 부실등기임이 명백한 경우(대판 1982. 9. 14, 82다카707)

(x) 대습상속인이 탈루된 경우(대판 1978. 1. 17, 77다1977) 등이 있다.

5) 공신력

- 동산에 관하여는 선의취득을 인정하여 점유의 공신력을 인정하지만, 부동산의 등기에 관하여는 공신력을 인정하는 규정 부존재
- 부동산거래에 관하여 정적 안전을 동적 안전보다 우선시한 입법자의 결단
 - * 취소 등의 경우에 있어서 선의의 제3자 보호는 별개의 문제

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 부동산의 물적 상황 내지 동일성에 관하여는 대장의 기재가 기준이 되지만, 권리의 변동에 관하여는 등기부의 기재가 기준이 된다.
- ② 등기청구권을 등기의무자가 행사하는 경우도 있다.
- ③ 법률행위에 의한 물권변동에 있어서의 등기청구권은 채권적 청구권이다.
- ④ 이 경우 채권적 청구권이므로 부동산을 인도받은 이후로부터 10년의 소멸시효에 걸린다.
- ⑤ 부동산의 매수인이 목적물을 사용,수익하다가 다른 사람에게 그 부동산을 처분하고 점유를 승계해준 경우에도 마찬가지로 10년의 소멸시효에 걸린다.

⇒ ⑤. 부동산매매에 기하여 매수인이 매도인에 대하여 가지는 등기청구권의 성질을 채권적 청구권으로 보는 것이 통설·판례의 태도이다. 따라서 원칙적으로 10년의 소멸시효에 걸리는 것이 원칙이지만, 매수인이 목적물을 인도받아 점유하고 있거나 나아가 보다 적극적인 권리행사의 일환으로 그 부동산을 처분하고 점유를 승계해준 경우에는 소멸시효에 걸리지 않는다고 하는 것이 것이 판례의 입장이다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 등기와 실체적 권리관계가 일치하지 않는 경우의 등기청구권은 물권의 효력으로서 파생하는 물권적 청구권이다.
- ② 취득시효의 완성으로 인한 등기청구권은 물권적 청구권이다.
- ③ 등기청구권을 물권적 청구권으로 볼 경우 소멸시효의 대상적격이 부인된다.
- ④ 등기의 추정력이 인정되면 당해 등기사실의 진실성을 부인하는 자가 그에 대한 주장 및 증명책임을 진다.
- ⑤ 등기의 추정력에 있어서 추정의 본질을 법률상 권리추정으로 보는 것이 판례의 태도이다.

⇒ ②. 채권적 청구권으로 보는 것이 통설·판례이다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 등기가 적법한 절차에 의하여 종료되었고 그 전제조건이 있을 경우에는 그것이 적법하게 충족되었을 것이라고 추정된다.
- ② 전 등기명의인이 미성년자이고 당해 부동산을 친권자에게 증여한 행위가 이해상반행위인 경우, 그 이전등기는 적법한 것으로 추정되지 않는다.
- ③ 부동산의 경우 제200조의 적법 추정이 적용되지 않는다.
- ④ 사망자를 등기의무자로서 등기신청한 경우나 전 소유명의자가 허무인인 경우에는 추정이 복멸된다.

- ⑤ 동산에 관하여는 점유의 공신력이 인정되지만, 부동산에 관하여는 등기의 공신력이 인정되지 않는다.

⇒ ② 이해상반행위이더라도 일단 친권자에게 이전등기가 경료되었다면 특별한 사정이 없는 한 필요한 절차를 적법하게 거친 것으로 추정한다.

♣ 학습정리

1. 등기는 공동신청이 원칙이다.
2. 법률행위에 의한 물권변동에 있어서의 등기청구권은 채권적 청구권이다. 그러나 점유하고 있거나 나아가 다른 사람에게 처분하여 점유를 승계해준 경우 그 등기청구권은 소멸시효에 걸리지 않는다.
3. 실체관계와 등기가 일치하지 않는 경우의 등기청구권은 물권적 청구권이다.
4. 등기의 추정력은 물적 범위의 측면에서 전제조건의 충족, 등기절차·기재사항의 적법, 등기원인, 대리권의 존재에도 미친다. 인적 범위의 측면에서는 등기명의인뿐만 아니라 제3자도 이를 원용할 수 있고, 소유권이전등기의 추정력은 권리변동의 당사자 간에도 미친다는 것이 판례의 입장이다.
5. 등기의 공신력은 인정되지 않는다.

제8강 등기의 효력 (2), 동산물권변동

♣ 학습목표

1. 보전가등기의 효력을 설명할 수 있다.
2. 동산물권변동 중 법률행위에 의한 경우에 대하여 정리할 수 있다.
3. 동산물권변동의 공시방법으로서의 인도의 4가지 종류를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

1. 보전가등기의 효력 - 본등기 후 / 전
2. 법률행위에 의한 동산물권변동 / 법률행위에 의하지 않은 동산물권변동
3. 인도의 종류 - 현실의 인도 / 간이인도 / 점유개정 / 목적물반환청구권의 양도
4. 점유개정에 의한 동산의 이중양도·이중양도담보

♣ 사전 테스트

1. 가등기는 순위보전의 효력이 있으므로 본등기에 의한 물권변동의 효력은 가등기한 때로 소급하여 발생한다.
⇒ × : 가등기에 기한 본등기가 경료되면 본등기의 순위만 가등기한 때로 소급함으로써 가등기 이후 본등기 이전에 이루어진 중간처분이 본등기보다 후순위로 되어 실효될 뿐이다.
2. 양수인이 이미 그 동산을 점유한 때에는 당사자의 의사표시만으로 그 효력이 생기는데, 이를 점유개정이라고 한다.
⇒ × : 간이인도이다. 점유개정은 당사자의 계약으로 양도인이 점유를 계속하는 경우이다.
3. 점유개정에 의한 동산의 이중양도가 있는 경우 먼저 점유개정으로 양수한 자가 소유권을 취득한다.
⇒ × : 판례는 먼저 현실의 인도를 받은 자가 소유권을 취득하는 것으로 본다.

♣ 강의교안

2. (청구권 보전) 가등기의 효력

* 채권담보의 목적으로 경료되는 담보가등기는 가등기담보 등에 관한 법률에 의하여 규율

(1) 본등기 후의 효력(본등기 순위보전의 효력)

- 가등기에 기하여 본등기가 행하여지면 그 본등기의 순위는 가등기의 순위에 의한다(부동산등기법 제6조). 이를 가등기의 본등기순위보전의 효력이라고 한다.
- 물권변동의 시기 : 가등기를 한 시점으로 소급하는 것은 아니고 본등기를 한 시점

2. 본등기 전의 효력(가등기인 채로의 효력 또는 청구권보전의 효력)

1) 실체법상의 효력 인정여부

담보가등기와는 달리 보전가등기에는 청구권이 존재한다는 것을 추정시키는 등기의 추정력이 인정되지 않는다. 그런데 보전가등기의 실체법적 효력 즉 가등기된 부동산의 처분행위를 한 경우 가등기된 권리를 침해하는 한도에서 효력이 없는지가 문제된다.

- ① 부정설(다수설·판례) : 가등기가 본등기의 요건을 구비하고 있어도 본등기가 없는 한 가등기 설정자의 처분행위를 저지할 수 없고, 이에 의한 제3취득자에 대하여 대항할 수 없다.
- ② 긍정설 : 가등기에 기하여 본등기를 청구할 수 있다고 하려면 가등기는 가등기인 채로 어떠한 실체법적 효력이 있는 것이고, 그 효력이 바로 청구권보전의 효력이다.

2) 불법말소된 가등기의 효력

가등기에 기한 본등기가 행하여질 수 있다는 공시적 효력이 있으므로 가등기가 불법으로 말소된 때에는 가등기명의인은 그 회복을 청구할 수 있다. 그리고 이 경우에 등기상 이해관계 있는 제3자가 선의라고 하더라도 위 회복등기절차에 대하여 승낙할 의무를 부담한다.

제3절 동산물권의 변동

1. 총설

① 동산물권의 변동

- 법률행위에 의한 경우 : 물권법총칙(제188조)
- 법률행위에 의하지 않은 경우 : 주로 소유권의 취득(동산의 취득시효(제246조)·무주물선점(제252조)·유실물습득(제253조)·매장물발견(제254조)·동산의 부합(제257조)·혼화(제258조)·가공(제259조))

제245조(점유로 인한 부동산소유권의 취득기간) ①20년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 부동산을 점유하는 자는 등기함으로써 그 소유권을 취득한다.

②부동산의 소유자로 등기한 자가 10년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 선의이며 과실없이 그 부동산을 점유한 때에는 소유권을 취득한다.

제246조(점유로 인한 동산소유권의 취득기간) ①10년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 동산을 점유한 자는 그 소유권을 취득한다.

②전항의 점유가 선의이며 과실없이 개시된 경우에는 5년을 경과함으로써 그 소유권을 취득한다.

제247조(소유권취득의 소급효, 중단사유) ①전2조의 규정에 의한 소유권취득의 효력은 점유를 개시한 때에 소급한다.

②소멸시효의 중단에 관한 규정은 전2조의 소유권취득기간에 준용한다.

제248조(소유권 이외의 재산권의 취득시효) 전3조의 규정은 소유권 이외의 재산권의 취득에 준용한다.

제249조(선의취득) 평온, 공연하게 동산을 양수한 자가 선의이며 과실없이 그 동산을 점유한 경우에는 양도인이 정당한 소유자가 아닌 때에도 즉시 그 동산의 소유권을 취득한다.

제250조(도품, 유실물에 대한 특례) 전조의 경우에 그 동산이 도품이나 유실물인 때에는 피해자 또는 유실자는 도난 또는 유실한 날로부터 2년내에 그 물건의 반환을 청구할 수 있다. 그러나 도품이나 유실물이 금전인 때에는 그러하지 아니하다.

제251조(도품, 유실물에 대한 특례) 양수인이 도품 또는 유실물을 경매나 공개시장에서 또는 동종류의 물건을 판매하는 상인에게서 선의로 매수한 때에는 피해자 또는 유실자는 양수인이 지급한 대가를 변상하고 그 물건의 반환을 청구할 수 있다.

제252조(무주물의 귀속) ①무주의 동산을 소유의 의사로 점유한 자는 그 소유권을 취득한다.

②무주의 부동산은 국유로 한다.

③야생하는 동물은 무주물로 하고 사양하는 야생동물도 다시 야생상태로 돌아가면 무주물로 한다.

제253조(유실물의 소유권취득) 유실물은 법률에 정한 바에 의하여 공고한 후 6개월 내에 그 소유자가 권리를 주장하지 아니하면 습득자가 그 소유권을 취득한다. <개정 2013. 4. 5.>

제254조(매장물의 소유권취득) 매장물은 법률에 정한 바에 의하여 공고한 후 1년내에 그 소유자가 권리를 주장하지 아니하면 발견자가 그 소유권을 취득한다. 그러나 타인의 토지 기타 물건으로부터 발견한 매장물은 그 토지 기타 물건의 소유자와 발견자가 절반하여 취득한다.

제255조(문화재의 국유) ①학술, 기예 또는 고고의 중요한 재료가 되는 물건에 대하여는 제252조제1항 및 전2조의 규정에 의하지 아니하고 국유로 한다.

②전항의 경우에 습득자, 발견자 및 매장물이 발견된 토지 기타 물건의 소유자는 국가에 대하여 적당한 보상을 청구할 수 있다.

제256조(부동산에의 부합) 부동산의 소유자는 그 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득한다. 그러나 타인의 권원에 의하여 부속된 것은 그러하지 아니하다.

제257조(동산간의 부합) 동산과 동산이 부합하여 훼손하지 아니하면 분리할 수 없거나 그 분리에 과도한 비용을 요할 경우에는 그 합성물의 소유권은 주된 동산의 소유자에게 속한다. 부합한 동산의 주종을 구별할 수 없는 때에는 동산의 소유자는 부합당시의 가액의 비율로 합성물을 공유한다.

제258조(혼화) 전조의 규정은 동산과 동산이 혼화하여 식별할 수 없는 경우에 준용한다.

제259조(가공) ①타인의 동산에 가공한 때에는 그 물건의 소유권은 원재료의 소유자에게 속한다. 그러나 가공으로 인한 가액의 증가가 원재료의 가액보다 현저히 다액인 때에는 가공자의 소유로 한다.

②가공자가 재료의 일부를 제공하였을 때에는 그 가액은 전항의 증가액에 가산한다.

제260조(첨부의 효과) ①전4조의 규정에 의하여 동산의 소유권이 소멸한 때에는 그 동산을 목적으로 한 다른 권리도 소멸한다.

②동산의 소유자가 합성물, 혼화물 또는 가공물의 단독소유자가 된 때에는 전항의 권리는 합성물, 혼화물 또는 가공물에 존속하고 그 공유자가 된 때에는 그 지분에 존속한다.

제261조(첨부로 인한 구상권) 전5조의 경우에 손해를 받은 자는 부당이득에 관한 규정에 의하여 보상을 청구할 수 있다.

② 권리자로부터 취득 / 무권리자로부터 취득(선의취득 : 점유의 공신력 인정)

II. 권리자로부터의 취득(법률행위 + 인도)

1. 서설

① 제188조 제1항

제188조(동산물권양도의 효력, 간이인도)

① 동산에 관한 물권의 양도는 그 동산을 인도하여야 효력이 생긴다.

→ 물권행위 공시방법으로서의 인도를 동산물권변동의 요건으로 하고 있다.

② 원칙의 적용범위 : 소유권의 양도에 한하여 적용

- 점유권, 유치권, 질권 : 점유가 그 권리의 발생 및 존속 요건이므로 다시 인도를 필요로 하지 않음
- 지상권, 지역권, 전세권 : 부동산을 대상으로 함

2. 법률행위

- 다수설 : 물권행위
- 소수설 : 채권행위

→ 동산물권변동은 현실매매가 대부분으로 통상 채권행위와 물권행위가 동시에 이루어지지만, 소유권유보부 매매, 종류채권을 발생시키는 경우, 타인의 물건의 매매의 경우 채권행위와 물권행위가 별개로 행하여짐.

3. 인도

1) 인도의 의미

- 인도 = 점유의 이전을 의미, 즉 사실적 지배의 이전.

2) 인도의 종류

- 현실의 인도가 인도의 원칙적인 모습이고 나머지는 의사표시로서 이루어지는 인도
- 현실의 인도(공시방법으로서 불완전) / 나머지 인도방법(실제로 사실적 지배가 이전되지 않는 관념적인 방법) → 동산물권변동에 관하여 공신력을 인정하여 거래안전 도모

인도방법	형식과 공시방법의 일치 여부	형식(인도)		공시방법(점유)	
		물권의 이전	점유의 이전	직접점유자	양수인의 점유
현실의 인도	인도=점유 (인도에 의해 물권과 점유가 동시에 이전)	양도인→ 양수인	양도인→양수인	양도인→양수 인	직접점유

간이인도	인도≠점유 (인도후에도 외형상 변화가 없다. 즉 직접점유자가 바뀌지 않는다.)	양수인→양수인	양수인 (타주점유→자 주점유)	직접점유
점유개정		양도인→양도인	양도인 (자주점유→타 주점유)	간접점유
목적물반 환 청구권의 양도		제3자→제3자	제3자	간접점유

* 부동산물권변동에서 등기는 형식주의 차원에서의 형식임과 동시에 성립요건주의 차원에서의 공시방법이나, 이와 달리 동산물권변동에서는 반드시 형식으로서의 인도에 의하여 공시방법으로서의 점유를 갖추게 된다고는 할 수 없다.

① 현실의 인도

- 물건에 대한 사실상 지배를 실제로 이전하는 것 : 인도의 원칙적인 모습.
→ 현실의 인도는 사실상 지배의 이전과 인도인과 인수인 사이의 점유이전의 합의에 의하여 이루어진다.
- 현실적 이전의 여부 : 양도인의 물건에 대한 사실상의 지배가 동일성을 유지한 채 양수인에게 완전히 이전되어 양수인은 목적물에 대한 지배를 계속적으로 확고하게 취득하여야 하고, 양도인은 물건에 대한 점유를 완전히 종결하여야 한다(대판 2003. 2. 11, 2000다66454).
(예 : 물건을 본인 또는 사용인에게 교부하거나, 물건이 집에 배달된 경우, 물건을 보관한 창고의 열쇠를 교부하는 경우)
- 현실의 인도의 법적 성질
 - 효과의사설(법률행위설) : 점유이전의 의사는 점유권 이전의 합의(물권행위)다. 즉 점유이전의 합의는 점유권을 양도하는 것이다(근거 : 제196조)

제196조(점유권의 양도) ① 점유권의 양도는 점유물의 인도로 그 효력이 생긴다.

- 자연적 의사설(사실행위설)(다수설) : 양도인의 점유이전의사 및 양수인의 점유취득의사는 자연적 의사일 뿐 효과의사는 아니다. 점유권은 점유의 이전이 있으면 항상 인정되는 권리이고 제196조의 점유권의 양도 규정은 허구일 뿐이다.

② 간이인도(제188조 제2항)

제188조(동산물권양도의 효력, 간이인도)

② 양수인이 이미 그 동산을 점유한 때에는 당사자의 의사표시만으로 그 효력이 생긴다.

- 양수인이 이미 목적물을 점유하고 있는 경우에는 현실의 인도 없이 당사자 사이의 소유권 이전에 관한 의사표시(물권적 합의)만으로 소유권이 이전된다(제188조 제2항).
- 예를 들어 임차인 A가 목적물을 점유하고 있다가 임대인 B로부터 이를 매수하는 경우에는 A·B사이의 소유권이전에 관한 합의만 있으면 목적물의 소유권이 A에게 이전된다. 즉 간이인도는 추상적 인도개념으로서, 이에 의해 양수인의 점유는 타주점유에서 자주점유로 바뀐다.
- 점유이전 반복이라는 번거로운 절차 생략.

- 간이인도의 법적 성질 : 계약

※ 간이인도에 관한 제188조 제2항의 「의사표시」가 무엇을 의미하는가?

· 소유권이전의 합의로 보는 견해

양수인이 점유를 하고 있는 때에는 현실의 인도를 통하여 점유를 이전할 필요가 없기 때문에 점유이전의사를 의미하는 것이 아니라 소유권이전의 합이라고 보는 견해

· 점유의 승계에 관한 합의로 보는 견해

민법은 점유권의 양도의 방법으로서 간이인도에 관한 규정을 준용하고 있고(제196조 제2항·제188조 제2항), 또한 간이인도는 부동산에 관하여도 있을 수 있으므로 점유의 승계에 관한 합의를 소유권이전의 합의와 구별할 수 있다. 따라서 여기서의 의사표시는 점유의 승계에 관한 합의라는 견해

· 검토

간이인도의 경우에는 양수인이 이미 물건을 점유하고 있으므로 점유의 이전을 필요로 하지 않으므로 점유의 이전 내지 승계에 관한 합의도 당연히 필요하지 않다. 따라서 제188조 제2항은 소유권이전에 관한 규정으로서 소유권이전의 합의만 있으면 동산의 소유권이 곧바로 양수인에게 이전된다는 취지를 규정한 것이라고 보아야 할 것이다.

→ 어느 견해에 의하더라도 간이인도는 의사표시(합의)에 의한 것이므로 행위능력, 의사표시 흠결 규정이 적용된다.

③ 점유개정(제189조)

제189조(점유개정)

동산에 관한 물권을 양도하는 경우에 당사자의 계약으로 양도인이 그 동산의 점유를 계속하는 때에는 양수인이 인도받은 것으로 본다.

- 동산물권을 양도하면서 양도인이 양수인과 점유매개관계를 설정하여, 양수인에게 간접점유를 취득시키고 스스로는 양수인의 점유매개자로서 점유를 계속하는 것을 말한다(제189조). 예를 들어 A가 자기의 물건을 B에게 양도하면서 A 자신이 임차인으로서 계속 사용하기 위해서 점유하는 경우이다.

- 기능 : 다시 인도받는 번잡한 절차를 생략/ 동산의 양도담보의 제도를 가능

- 성립요건

· 점유개정에 의하여 양도인의 점유가 자주점유에서 타주점유로 변경되므로 양도인이 먼저 물건을 자주점유하고 있어야 한다.

· 소유권이전에 관한 합의 + 간접점유를 발생시키는 계약(즉 점유매개관계)

이 두 합의는 하나의 행위로 합체되어서 행하여지는 것이 보통이다. 소유권이전에 관한 합의는 법률행위이므로, 행위능력, 의사의 흠결, 조건·기한, 대리 가능 장래 취득할 물건을 위하여 점유개정을 하는 것도 유효하다. 점유매개관계란 위 예에서 A(매도인)가 직접점유, B(매수인)가 간접점유를 갖는 관계로서, 제189조의 법문상 계약(예 : 임대차 계약 등)에 의하여 설정된다.

※ 점유개정에 의한 동산의 이중양도

1. 문제

동산의 양도인이 점유개정으로 계속 물건을 점유하면서 다시 제3자에게 점유개정에 의하여 이중으로 양도한 경우에 누가 소유권을 취득하는가? 예컨대 A가 B에게 동산을 양도하면서 소유권이전의 합의를 하고 A가 B로부터 그 목적물을 임차하여 계속 사용하기로 하고 다시 A가 C에게 양도하면서 같은 방법으로 점유개정에 의한 인도를 하고 A가 계속 사용하는 경우 B와 C 가운데 누가 소유권을 취득하느냐?)

2. 학설

① 먼저 현실의 인도를 받은 자

현실의 인도가 인도의 기본형이기 때문에 먼저 현실의 인도를 받은 자(선의·악의 구별없이)가 소유권을 취득한다는 견해(판례)

② 선의취득의 문제로 해결(C의 선의·무과실)

선의 취득의 문제로 돌아가 선의에 의하여 현실의 인도를 받아야 소유권을 취득한다는 견해, 즉 C의 권리취득은 이미 소유권을 B에게 양도하여 무권리자가 된 A로부터의 취득이므로 선의취득의 문제로 되나, 점유개정에 의한 인도로는 선의취득이 되지 않으므로 제2양수인 C가 현실로 인도를 받은 경우 비로소 선의취득을 한다고 한다.

3. 판례(먼저 현실의 인도 또는 양도인 상대 처분금지가처분)

양수인들 사이에 있어서는 먼저 현실의 인도를 받아 점유를 한 자가 소유권을 취득하는 것으로 해석한다(대판 1989. 10. 24, 88다카26802 대판 1975. 1. 28, 74다1564). 그리고 점유개정에 의하여는 선의취득을 할 수 없다고 한다(대판 1964. 5. 5, 63다775). 다만 양수인 중 한사람이 처분금지 가처분집행을 하고 그 동산의 인도를 명하는 판결을 받은 경우에는, 다른 양수인이 위 가처분집행 후에 양도인으로부터 그 동산을 현실로 인도받아 점유를 승계하였더라도, 그 동산을 선의취득한 것이 아닌 한 이와 같은 양수인은 가처분채권자가 본안소송에서의 승소판결에 따른 채무명의에 터잡아 강제집행을 하는 경우 이를 수인하여야 하는 지위에 있으므로 가처분채권자와의 사이에서는 그 동산의 소유권을 취득하였다고 주장할 수 없다고 한다(대판 1989. 10. 24, 88다카26802).

점유개정에 의한 동산의 이중양도 및 양수인 중 1인이 처분금지가처분을 한 경우 동산의 소유자가 이를 이중으로 양도하고 각 점유개정의 방법으로 양도인 이 점유를 계속하는 경우 양수인들 사이에 있어서는 먼저 현실의 인도를 받아 점유를 해온 자가 소유권을 취득한다고 볼 것이나, 양수인 중 한 사람이 처분금지가처분집행을 하고 그 동산의 인도를 명하는 판결을 받은 경우에는 다른 양수인이 위 가처분집행후에 양도인으로부터 그 동산을 현실로 인도받아 점유를 승계하였더라도 그 동산을 선의 취득한 것이 아니한 이와 같은 양수인은 가처분채권자가 본안소송에서의 승소판결에 따른 채무명의를 터잡아 강제집행을 하는 경우 이를 수인하여야 하는 지위에 있으므로 가처분채권자와의 사이에서는 그 동산의 소유권을 취득하였다고 주장할 수 없다.(대판 1989. 10. 24, 88다카26802).

▶ 돌발 퀴즈

판례는 점유개정에 의한 동산의 이중양도에 있어서 현실의 인도를 기준으로 삼았고, 점유개정에 의한 동산의 이중양도담보에 있어서도 마찬가지로 현실의 인도를 기준으로 양수인들 간의 우열을 가리는 입장이다.

⇒ × : 점유개정에 의한 이중양도담보에 있어서는 제1양도담보권자가 소유권을 확정적으로 취득한다.

※ 점유개정에 의한 동산의 이중양도담보

1. 문제점

양도담보는 점유개정에 의해서도 가능하다. 다만 점유개정으로 이중의 양도담보를 설정한 경우의 이중의 양도담보권자 상호간의 관계가 문제된다.

예를 들어 A가 B에게 돈을 빌리면서 A 자기소유물을 채권자 B에게 담보로 제공하면서 그 물건의 소유권이전의 합의를 해 주고, 다만 그 물건의 사용·수익은 채무자 A가 계속하는하기로 하는 한편, 그 후에 또 다시 채무자 A가 제3자 C에게 위와 같은 방법으로 점유개정에 의한 양도담보계약을 체결하는 경우에 乙과 丙의 관계가 문제된다.

→ 동산양도담보의 법적 성질에 따라 해결

2. 학설·판례

① 신탁적 소유권이전설(판례)

- 제1의 양도담보권자가 소유권을 확정적으로 취득(B가 확정적 소유권취득)
- 제2의 양도담보설정계약을 체결한 자(후순위 채권자)는 무권리자로부터 계약체결한 것이고, 점유개정에 의한 선의취득도 인정되지 않으므로 결국 양도담보권을 취득 못함

② 담보물권설 : B는 제1의 양도담보권자(선순위담보물권자)가 되고, C는 제2의 양도담보권자(후순위담보물권자)가 됨

3. 판례

금전채무를 담보하기 위하여 채무자가 그 소유의 동산을 채권자에게 양도하되 점유개정의 방법으로 인도하고 채무자가 이를 계속 점유하기로 약정한 경우 특별한 사정이 없는 한 그 동산의 소유권은 신탁적으로 이전되는 것에 불과하여, 채권자와 채무자 사이의 대내적 관계에서는 채무자가 소유권을 보유하나 대외적인 관계에서의 채무자는 동산의 소유권을 이미 채권자에게 양도한 무권리자가 되는 것이어서 다시 다른 채권자와 사이에 양도담보설정계약을 체결하고 점유개정의 방법으로 인도하더라도 선의취득이 인정되지 않는 한 나중에 설정계약을 체결한 채권자로서는 양도담보권을 취득할 수 없는데, 현실의 인도가 아닌 점유개정의 방법으로는 선의취득이 인정되지 아니하므로 결국 뒤의 채권자는 적법하게 양도담보권을 취득할 수 없다(대판 2005. 2. 18, 2004다37430 : 대판 2004. 12. 24, 2004다45943 : 대판 2004. 10. 28, 2003다30463 : 대판 2004. 6. 25, 2004도1751 : 대판 1994. 8. 26, 93다44739).

동산에 대하여 점유개정의 방법으로 이중양도담보를 설정한 경우 원래의 양도담보권자는 뒤의 양도담보권자에 대하여 배타적으로 자기의 담보권을 주장할 수 있다(대판 2000. 6. 23, 99다65066)

⇒ 또한 담보권설의 입장에서, 일반채권자와는 구분되는 양도담보권자의 지위를 예상한 후속채약자의 기대를 보호하고, 또한 채무자의 입장에서는 점유개정을 기준으로 하여 담보액 범위에서 각가 우선변제권을 인정하여 담보목적물의 가치를 활용할 실제상의 필요가 있음을 고려한다면 점유개정을 기준으로 할 필요성도 인정할 수 있을 것이다.

※ 질권의 점유개정금지(제332조) : 질권의 유치적 효력 확보목적

제332조(설정자에 의한 대리점유의 금지)

질권자는 설정자로 하여금 질물의 점유를 하게 하지 못한다.

→ 점유개정에 의한 동산담보를 인정하고 있어서 동조문은 무의미하다는 비판, 오히려 서민들의 동산사용을 못하게 하고 동산담보를 못하는 문제가 있어 폐지하자는 다수의 주장, 이에 동산·채권담보 등에 관한 법률 제정하여 중소기업자 자금유통의 수단 마련함(다만 설정자가 제한되어 있음)

④ 목적물반환청구권의 양도(제190조)

제190조(목적물반환청구권의 양도)

제삼자가 점유하고 있는 동산에 관한 물권을 양도하는 경우에는 양도인이 그 제삼자에 대한 반환청구권을 양수인에게 양도함으로써 동산을 인도한 것으로 본다.

- 양도인이 제3자의 점유를 매개하여 목적물을 간접점유하고 있는 경우, 양도인이 그 제3자에 대한 반환청구권을 양수인에게 양도함으로써 동산의 소유권이 양수인에게 이전된다.

예를 들어 A가 C에게 빌려준 자기 물건을 B에게 양도하면서 C에 대한 물건반환청구권을 B에게 양도하면 B는 인도를 받은 것으로 된다.

→ 이 경우에는 소유권이전을 위해서는 소유권이전의 합의와 반환청구권 양도의 합의가 필요하며 이 두 합의는 일반적으로 하나의 행위로 합체되어 행하여지게 된다.

- 반환청구권의 성질 : 목적물반환청구권은 임대차·임치·위임 등의 법률행위나 또는 법률의 규정(제738조·제684조 제1항·제747조 제1항)에 의하여 발생하는데, 이는 채권적 청구권이다(통설). 따라서 목적물반환청구권의 양도에는 채권양도에 관한 규정이 준용되어 점유자에 대한 통지나 점유자의 승낙이 필요하다고 본다(다수설·판례). 즉 양수인·양도인 사이에 합의로 효력이 생기지만 점유매개자에게 통지 또는 승낙이 있어야 대항할 수 있다.

* 운송증권(화물상환증, 선하증권 등)을 제3자에게 교부한 경우에는 그 교부가 물건의 인도에 갈음하기 때문에 제190조가 아니라 제188조 제1항이 적용된다.

※ 인도주의의 예외

(1) 등기·등록으로公示되는 동산

1) 선박에 대하여는 등기를 대항요건으로 하고 있다. 즉, 20톤 이상의 선박의 공시방법은 등기이며(상법 제745조), 그 물권변동은 등기하여야 제3자에 대항할 수 있다(상법 제743조). 그 미만의 선박은 민법 제188조 제1항에 따라 물권행위와 인도가 있어야 권리이전의 효력이 생긴다(대판 1966.12.20, 66다1554). 항진추진기가 없어서 선박등기의 대상이 되지 않는 부선도 마찬가지이다(대판 1999. 6. 22, 99다7602).

2) 그리고 자동차와 항공기의 소유권 및 저당권의 득실변경은 인도에 의하지 않고 등록하여야 그 효력이 생긴다(자동차 등 특정동산 저당법 제5조). 그 밖에 건설기계저당권의 득실변경도

역시 등록하여야 효력이 발생한다(자동차 등 특정동산 저당법 제5조). 건설기계는 소유자가 등록을 하여야 하나(건설기계관리법 제3조), 소유권이전은 일반원칙에 의하며, 단지 소유자의 변경을 신고하면 된다(건설기계관리법 제5조).

(2) 부동산등기에 의하여 공시되는 동산

부동산의 종물인 동산은 주물이 처분되면 그 효과를 받는 것이 원칙이다(제100조 제2항). 즉 주물인 부동산의 이전등기가 있으면 종물인 동산의 양도에 관하여 따로 인도가 필요하지 않다. 주물인 건물에 저당권이 설정되는 경우도 같다.

(3) 증권에 의하여 표상되는 동산

선하증권·화물상환증·창고증권 등이 발행된 경우에는 이러한 증권이 표상하는 상품의 인도는 증권의 인도에 의해서도 행하여질 수 있다(상법 제133조·제157조·제861조).

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 가등기도 추정력을 갖는다.
- ② 담보가등기와 달리 보전가등기는 실체법상의 효력이 인정되지 않는다.
- ③ 법률행위에 의한 동산물권변동에 있어서는 물권행위와 인도가 있어야 한다.
- ④ 제188조부터 제190조까지의 규정은 소유권의 양도에만 적용되고, 점유권, 유치권, 질권에는 그 적용이 없다.
- ⑤ 동산물권변동에는 부동산물권변동과는 달리 정지조건이나 시기를 붙일 수 있다.

⇒ ① 가등기에는 추정력이 인정되지 않는다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 간이인도가 있으면 양수인의 점유는 타주점유에서 자주점유로 바뀐다.
- ② 간이인도의 법적 성질은 계약이다.
- ③ 점유개정이 있으면 양수인의 점유는 자주점유에서 타주점유로 바뀐다.
- ④ 점유개정의 법적 성질은 계약이다.
- ⑤ 점유개정에 있어서는 점유매개관계의 성립이 요구된다.

⇒ ③. 점유개정이 있으면 양도인의 점유가 자주점유에서 타주점유로 변경된다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 동산물권변동의 공시방법은 인도이다.
- ② 인도의 원칙적인 모습은 현실의 인도이고, 가장 불완전한 인도방법은 간이인도이다.
- ③ 양수인이 이미 그 동산을 점유한 때에는 당사자의 의사표시만으로 그 효력이 생긴다.
- ④ 동산에 관한 물권을 양도하는 경우에 당사자의 계약으로 양도인이 그 동산의 점유를 계속하는 때에는 양수인이 인도받은 것으로 본다.
- ⑤ 제3자가 점유하고 있는 동산에 관한 물권을 양도하는 경우에는 양도인이 그 제3자에 대한 반환청구권을 양수인에게 양도함으로써 동산을 인도한 것으로 본다.

⇒ ②. 점유개정이 가장 불완전한 인도방법으로 평가된다.

♣ 학습정리

1. 보전가등기는 순위보전의 효력만 갖고, 등기의 추정력이나 실체법적 효력은 인정되지 않는다.
2. 동산물권변동의 공시방법은 인도이다.
3. 인도는 현실의 인도, 간이인도, 점유개정, 목적물반환청구권의 양도로 나뉘는데, 현실의 인도를 제외하고는 실제로 사실적 지배가 이전되는 않는 관념적인 것이다.
4. 판례는 점유개정에 의한 이중양도의 경우에는 먼저 현실의 인도를 받은 자가 소유권을 취득하는 것으로 보고 있고, 점유개정에 의한 이중양도담보의 경우에는 신탁적 소유권이전설에 입각하여 제1양도담보권자가 소유권을 취득하는 것으로 본다.

제9강 선의취득, 명인방법

♣ 학습목표

1. 선의취득에 대하여 설명할 수 있다.
2. 명인방법에 대하여 정리할 수 있다.

♣ 학습내용

1. 선의취득의 요건, 효과
2. 도품·유실물에 대한 특칙
3. 명인방법의 의의, 내용

♣ 사전 테스트

1. 선의취득은 유치권에 대해서도 이루어질 수 있다.
⇒ × : 선의취득은 소유권과 질권에 한정된다.
2. 선의취득은 승계취득이다.
⇒ × : 선의취득은 법률의 규정에 의한 원시취득이라는 것이 통설의 입장이다.
3. 명인방법으로 공시되는 물건변동은 소유권에만 국한된다.
⇒ × : 소유권 외에도 양도담보권이 있다.

▶ 돌발 퀴즈

토지의 주위에 울타리를 치고 그 안에 수목을 정원수로 심어 가꾸었다면 명인방법으로서 인정할 수 있다.

⇒ × : 판례는 수목을 지적만으로 표시한 때처럼 수목들이 특정되지 않은 경우에는 명인방법으로서의 효력을 부정한다.

♣ 강의교안

III. 무권리자로부터의 취득 : 선의취득

제249조(선의취득)

평온, 공연하게 동산을 양수한 자가 선의이며 과실없이 그 동산을 점유한 경우에는 양도인이 정당한 소유자가 아닌 때에도 즉시 그 동산의 소유권을 취득한다.

1. 의의

상대방의 점유를 신뢰하여 동산을 거래상 양수한 자는 설사 상대방이 무권리자라도 그 동산의 소유권 및 질권을 유효하게 취득하는 제도(동산의 점유에 공신력 인정)

- 소유권 : 제249조~제251조

- 질권 : 제343조
- 점유권 : × (점유 자체에 대한 권리)
- 유치권 : × (법률의 규정에 의한 성립)
- 지상권·지역권·전세권·저당권 : × (부동산)

* 인정이유 : 판례는 동산 선의취득제도의 취지를 동산을 점유하는 자의 권리외관을 중시하여 이를 신뢰한 자의 소유권 취득을 인정하고 진정한 소유자의 추급을 방지함으로써 거래의 안전을 확보하기 위하여 법이 마련한 제도라고 하고 있다(대판 1998. 6. 12, 98다6800).

2. 요건

(1) 객체에 관한 요건

선의취득의 객체는 동산에 한한다. 동산이란 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력(제98조) 가운데에서 토지 및 그 정착물이 아닌 물건을 가리킨다(제99조).

1) 금전 내지 화폐

- 금전이 가치의 표상으로 유통되는 경우에는 선의취득의 적용이 없고, 금전은 그 점유 있는 곳에 당연히 소유권이 있다고 보아, 부당이득반환청구권의 문제로 처리하여야 한다. → 그러나 封金의 임치, 진열을 목적으로 한 특정화폐의 급부 등 단순히 물건으로 거래되는 경우에는 보통의 동산과 같이, 선의취득에 관한 규정이 적용

- 따라서 제250조 단서는 단순한 물건으로서 거래되는 금전에만 적용된다고 보아야 한다. 예를 들어 코팅되어 물건으로 거래된 오만원권을 코팅을 찢어 사용한 경우 소유자는 2년내에 반환을 청구하지 못한다. 즉 선의취득을 한 금전을 보통의 금전으로서 사용해 버릴 수 있기 때문에 도품이나 유실물일지라도 반환 청구를 금지.

2) 등기·등록으로 공시되는 동산

- 등기·등록으로 공시되는 동산(선박·자동차·항공기·건설기계 등)은 선의취득의 목적물이 되지 못한다(성질상 동산이지만 법률상으로는 부동산과 같이 다루어지기 때문).

- 그러나 등기가 필요 없는 선박 등에 관하여는 선의취득이 인정된다.

3) 명인방법에 의하여 공시되는 지상물

명인방법에 의하여 공시되는 지상물(수목의 집단·立稻·미분리과실 등)은 본래 토지의 일부이거나 토지의 구성부분의 일부(미분리과실의 경우)이므로 동산이 아니며 특별한 공시방법이 있으므로 선의취득의 객체가 되지 않는다. 다만 그것이 지반으로부터 분리된 때에는 동산이 되므로 그에 대한 선의취득의 목적이 된다.

4) 증권적 채권 증권적 채권(지시채권·무기명채권)은 채권이지 동산이 아니며, 이에 관해서는 따로 특별규정(제514조·제524조)을 두고 있어 제249조 이하의 규정은 적용이 없다.

* 어음, 수표, 주식 등 : 무권리자 내지 무권한자로부터의 취득에 한하지 않고, 惡意·重大한 過失이 없을 것을 요건으로 하므로 경과실이 있더라도 선의취득이 가능하며, 도품·유실물에 관한 제한이 없다.

5) 증권화된 동산

화물상환증·창고증권·선하증권 등과 같이 증권에 의하여 표상된 동산은 증권의 배서·교부에 의하여 인도되지만 창고업자나 운송업자가 증권 없이 물건을 처분한 경우에는 상대방은 그 물건을 선의취득할 수 있다. 이와 병행하여 증권자체의 선의취득도 가능하며, 다만 양자가 경합되는 경우에는 전자가 우선한다고 해석할 것이다.

6) 양도가 금지된 물건

국유재산 등과 같이 양도가 금지되어 있는 물건은 사법상 거래의 객체가 될 수 없으므로, 거래안전을 보호하기 위한 선의취득의 대상이 될 수 없다. 따라서 국유문화재처럼 법률상 양도 및 私權設定이 금지된 경우나 아편, 아편흡식기구, 음란한 문서, 기타의 물건, 위조·변조한 통화와 그 유사물 등과 같이 소유 또는 소지가 금지되는 것은 선의취득의 대상이 될 수 없다.

(2) 양도인에 관한 요건

1) 양도인이 점유하고 있을 것

양도인의 점유는 직접점유·간접점유·자주점유·타주점유를 불문한다. 점유보조자를 권리자로 오신할 경우에도 선의취득의 보호를 받는다. 판례에서도 점유보조자의 횡령이 제250조의 도품이 아니라고 한다(대판 1991. 3. 22, 91다70).

[판례] 점유보조자의 횡령

민법 제250조, 제251조 소정의 도품, 유실물이란 원권리자로부터 점유를 수탁한 사람이 적극적으로 제3자에게 부정처분한 경우와 같은 위탁물횡령의 경우는 포함되지 아니하고 또한 점유보조자 내지 소지기관이 횡령처럼 형사상 절도죄가 되는 경우도 형사법과 민사법의 경우를 동일시 해야 하는 것은 아닐 뿐만 아니라 진정한 권리자의 선의의 거래 상대방간의 이익형량의 필요성에 있어서 위탁물횡령의 경우와 다를 바 없으므로 민법 제250조의 도품, 유실물에 해당되지 않는다(대판 1991. 3. 22, 91다70).

→ 즉 점유보조자의 형사상 절도는 민사상 횡령으로 보아 도품에 해당하지 않고 제249조의 선의취득이 적용되는 것으로 보아야 한다.

2) 양도인이 무권리자일 것

① 양도인이 처음부터 소유자가 아닌 경우(前主가 임차인, 수취인, 단순한 점유보조자)

② 양도인의 소유권 취득이 무효, 취소, 해제되어 소급하여 무권리자로 되는 경우

③ 타인의 동산을 자기의 이름으로 처분할 권한이 없는 자

: 위탁매매인·질권자·집행관 등이 그의 권한에 기하여 자기의 이름으로 처분하는 경우에 그 처분재산 속에 타인의 동산이 섞여 있어서 그 동산을 처분할 권한이 없는 때에, 이들에게 처분권이 있다고 오신하여 거래를 하면 선의취득은 성립한다.

④ 대리인이 본인 소유가 아닌 동산을 처분한 경우

→ 취득자가 본인의 소유물이라고 오신한 때에도 선의취득이 성립

→ 그러나 대리권이 있다고 오신하면 선의취득의 보호를 받지 못한다(통설). 단 표현대리 가능

(3) 선의취득자(양수인)에 관한 요건

1) 선의취득자가 前主와 동산물권취득에 관한 유효한 거래행위를 하였을 것

① 동산물권의 거래행위일 것

② 물권취득의 거래행위가 있을 것

선의취득에는 매매·증여·질권설정·대물변제·변제를 위한 급부·소비대차의 이행으로서 급부하는 것과 경매 등 특정승계에 의한 경우에만 인정된다. 선의취득은 개별적인 거래를 보호하는 것이기 때문이다.

· 포괄승계(예 : 상속·회사의 합병) : 법률상 당연히 취득효과가 생김 → 적용 ×

- 사실행위(예 : 타인의 임야를 자기 소유로 오인하여 목재를 채취하는 경우) : 거래행위를 매개하지 않음 → 적용 ×

③ 거래행위가 유효할 것

양도인이 무권리자라는 점을 제외하고는 위 거래행위는 유효하게 성립된 것이어야 한다. 물권취득의 거래행위가 제한능력·착오·사기·강박·대리권의 흠결 무권대리 등으로 실효된 때에는 선의취득은 부인

이 경우 양수인을 보호할 수 있는 방법은 제한능력자의 상대방보호(제15조·제16조), 무권대리인의 상대방 보호(제125조 이하 표현대리, 제131조 이하 최고·철회권), 착오의 경우는 신뢰이익 배상 인정의 여부 등이 있을 수 있다. 다만 사기·강박의 경우 양수인이 사기·강박한 경우는 보호할 필요가 없고, 제3자가 사기·강박한 경우에는 양수인이 이러한 사실에 대해 악의 또는 과실이 있는 경우만 취소를 인정하기 때문에 양수인의 보호문제가 달리 생기지 않는다.

2) 평온·공언·선의·무과실일 것

① 선의라 함은 前主가 무권리자라는 것을 알지 못하는 것

- 취소원인(예 : 제한능력·착오·사기·강박)을 알고 있는 자는 악의로 해석
- 무과실은 전주(양도인)가 무권리자라는 사실을 알지 못하는데 과실이 없음
- 거래는 평온·공언하게 행하여져야 한다.

② 선의·무과실의 기준시기는 물권행위가 완성되는 때이고(대판 1962. 3. 22, 4294민상1174), 즉 물권적 합의가 동산의 인도보다 먼저 행해지면 인도된 때를, 인도가 먼저 행해지면 물권적 합의를 기준으로 하여야 한다. 인도의 시기는 현실의 인도의 경우에는 문제가 없으나 반환청구권의 양도의 경우에는 그 양도의 통지를 받은 때이고, 간이인도의 경우에는 물권적 합의가 있는 때이다.

③ 현행 민법은 선의취득의 선의·무과실에 대한 증명책임을 규정하지 않는다. 따라서 점유자는 善意로 平穩·公然하게 점유하는 것으로 추정하는 제197조 제1항의 규정을 선의취득자에게 준용한다.

Q : 제197조에서 무과실의 추정에 관하여는 규정하고 있지 않는데 무과실도 추정될 수 있는가?

① 무과실 추정 부정설(판례)

무과실 추정하는 규정이 없으므로 선의취득자에게 무과실 증명책임

② 무과실 추정 긍정설(다수설)

제200조에 의하여 점유자에게 권리가 있는 것으로 추정되므로, 그와 거래한 자가 前主에게 권리가 있다고 믿었다 하더라도 과실이 있다고 할 수 없음을 근거로 무과실도 추정되는 것으로 해석

③ 검토

민법 제200조에 의해 점유자가 점유물에 대하여 행사하는 권리는 적법하게 보유한 것으로 추정된다고 하더라도 이는 점유자의 점유상태에 관한 법률상의 추정일 뿐이고, 양수인이 그 점유를 신뢰한데 과실이 있는지의 여부는 별개의 문제이다. 또한 진정한 권리자의 희생은 최소한으로 줄이면서 거래의 안전을 도모해야 하므로 명문의 규정이 없는 이상 무과실은 추정되지 않는 것으로 보아야 한다.

3) 선의취득자가 점유를 취득하였을 것

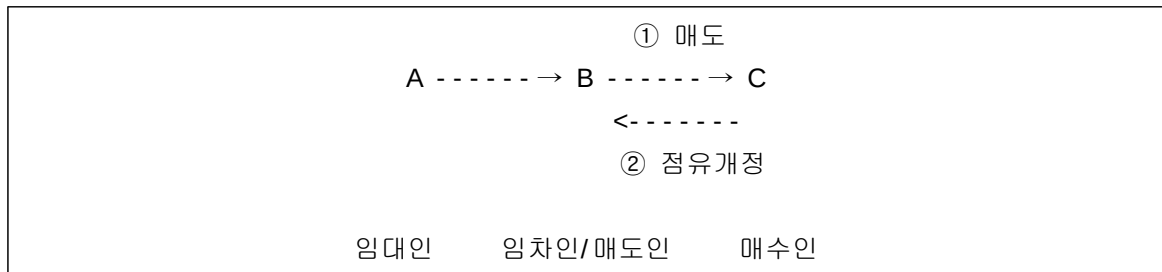
① 현실의 인도

② 간이인도(이설없음)

예컨대 동산에 관하여 임차인이 임대인의 소유자라고 믿고 그로부터 그 동산을 매수하는 경우에는 임대인이 소유자가 아니더라도 임차인은 그 동산의 소유권을 취득한다. 판례도 동산의 선의취득에 필요한 점유의 취득은 이미 현실적인 점유를 하고 있는 양수인에게는 간이인도에 의한 점유취득으로 그 요건은 충족된다고 한다(대판 1981. 8. 20, 80다2530).

③ 점유개정

양수인이 무권리자로부터 점유개정에 의해 동산을 양도받은 경우에도 선의취득이 성립할 수 있는지 문제된다. 이것은 점유개정이 공시방법으로써 불완전하여 거래안전을 해칠 우려가 있어서 어느 범위까지 점유개정을 유효한 공시방법으로 인정할 것인가와 관련된다. 이에 대하여 견해가 대립한다.



- 부정설(판례·통설)
 - 점유개정은 관념적 점유이전방법 중에서도 가장 불명확
 - 외부에서 거래행위의 존재를 전혀 인식할 수 없다는 점에서 진정한 권리자에게 너무 가혹
- 긍정설
 - 민법이 인도의 방법으로써 점유개정을 인정하고 있는 이상 그에 의한 선의취득을 부정할 이유가 없음
- 절충설
 - 선의취득의 요건으로 일응 점유개정으로 족하지만, 이에 의한 소유권취득은 확정적인 것은 아니고, 그 후 현실의 인도를 받아야 비로소 확정된다
 - 선의취득제도는 거래안전을 위하여 원권리자의 권리를 박탈하는 제도인바, 이는 최소한 상대방이 신뢰할 권리의 외관이 존재해야 할 것

④ 반환청구권의 양도(다수설·판례)

예를 들어 소유자 A로부터 목적물을 임차한 B가 다시 C에게 사용케 하면서 D에게 양도하고 B 자신의 C에 대한 반환청구권을 D에게 양도한 경우이다. 이러한 목적물반환청구권의 양도에 의한 점유취득을 선의취득의 점유로 인정할 것인가?

- 긍정설(판례·다수설) : 양도인은 점유를 잃고 양도인과 진정한 권리자 사이에 비록 점유의 매개관계가 있었다 하더라도 그것은 완전히 단절되기 때문.

3. 효과

(1) 물건(소유권 또는 질권)의 원시취득

1) 소유권 : 제249조 / 질권 : 제343조

- 무권리자가 양도한 경우 : 진정한 소유자의 소유권은 소멸
- 무권리자가 질권을 설정한 경우 : 진정한 소유자는 자기소유물에 대한 질권설정자(즉 물상보증인의 지위)가 됨

2) 선의취득하는 소유권 또는 질권은 법률의 규정에 의한 원시취득이다(통설).

→ 선의취득자는 그 물건 위에 존재하던 제한물권(유치권·질권)의 부담이 없는 완전한 소유권을 취득한다.(원시취득설 : 통설)

3) 선의취득의 효과는 종국적이다. 즉 양수인이 진정한 권리자에게 동산을 반환하여야 하거나, 양도인에 대하여 담보책임(타인의 권리매매에 따른 제570조)을 추궁하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 법률의 규정에 의하여 선의취득자는 권리를 취득하고, 종전 소유자는 소유권을 상실하게 되므로 선의취득자가 임의로 선의취득의 효과를 거부하고 종전 소유자에게 동산을 반환받아 갈 것을 요구할 수 없다(대판 1998. 6. 12, 98다6800).

(2) 원권리자와 선의취득자의 관계(부당이득의 문제)

선의취득자는 진정한 권리자에 대하여 부당이득반환의무를 부담하는가? 유상취득의 경우에는 선의취득자는 원권리자에 대하여 부당이득의 반환의무를 부담하지 않는다(통설).

※ 무상취득의 경우?

- ① 긍정설 : 당사자간의 이해를 공정하게 해결
- ② 부정설(다수설) : 독일민법(제816조 후단)처럼 무상취득의 경우에도 이득반환을 인정하는 규정이 없다. 긍정설을 취하면 무상거래의 경우 선의취득을 인정하지 아니하는 것과 마찬가지로의 결과가 초래

(3) 원권리자와 양도인과의 관계

양도인은 양수인과의 거래행위에 의하여 취득한 이익을 부당이득으로 원권리자에게 반환하여야 한다. 또한 양도인에게 귀책사유가 있는 경우에는 유상·무상을 불문하고 원권리자는 양도인에 대하여 채무불이행 또는 불법행위로 인한 손해배상을 청구할 수 있다. 다만 경매에 기한 선의취득에서는 동산의 소유자는 배당을 받은 채권자에 대하여 부당이득으로서 배당받은 금액의 반환을 청구할 수 있다(대판 1998. 3. 27, 97다32680).

4. 도품·유실물에 관한 특칙

제250조(도품, 유실물에 대한 특례)

전조의 경우에 그 동산이 도품이나 유실물인 때에는 피해자 또는 유실자는 도난 또는 유실한 날로부터 2년내에 그 물건의 반환을 청구할 수 있다. 그러나 도품이나 유실물이 금전인 때에는 그러하지 아니하다.

제251조(도품, 유실물에 대한 특례)

양수인이 도품 또는 유실물을 경매나 공개시장에서 또는 동종류의 물건을 판매하는 상인에게서 선의로 매수한 때에는 피해자 또는 유실자는 양수인이 지급한 대가를 변상하고 그 물건의 반환을 청구할 수 있다.

(1) 특칙의 적용범위

1) 도품과 유실물

- ① 도품 : 절도 또는 강도에 의하여 점유자의 의사에 반해서 그의 점유를 박탈당한 물건
- ② 유실물 : 점유자의 의사에 의하지 않고 그의 점유를 이탈한 물건으로 도품이 아닌 것
- ③ 사기·공갈·횡령물 : 점유자의 의사가 관여 → 적용제외

2) 간접점유

본인이 간접점유하고 있는 경우에는 점유이탈의 의사의 유무는 직접점유자의 의사를 기준, 점유보조자를 통해서 점유하는 경우에는 점유보조자를 표준으로 하여야 한다(통설, 대판 1991. 3. 22, 91다70).

→ 직접점유자·점유보조자가 처분한 물건은 도품·유실물이 아니다.

(2) 특칙의 내용

피해자 또는 유실자는 도난 또는 유실한 날로부터 2년 내에 그 물건의 반환을 청구할 수 있다. 이 반환청구는 일반적으로 무상이나, 제251조가 적용되는 경우에는 대가를 변상하여야 한다.

1) 반환청구권자

도난의 피해자 또는 유실자이다(제250조 본문 ; 소유자, 임차인 또는 수취인(통설)). 질권자가 질물을 도난 또는 유실한 경우에도 마찬가지이다(제343조 참조).

2) 반환청구기간

- ① 도난 또는 유실한 날로부터 2년간
- ② 기산점 : 절취행위가 성립한 때가 아니고 피해자가 점유를 상실한 때(통설)
 - 제척기간설(다수설) : 물권적 반환청구권이므로 2년의 기간에 있어서 중단이 인정되어서는 안된다.
 - 시효기간설(소수설.곽윤직·김상용) : 반환청구권은 형성권이 아닌 채권적 청구권이다.

3) 반환청구의 상대방

제249조의 요건을 구비하고 있는 도품·유실물은 현재 점유하고 있는 자로서 도품·유실물에 관하여 직접 선의취득한 자(도둑·습득자)와 그 특정승계인도 포함한다.

(예 : 소유자 A의 물건을 B가 절취하여 이를 C·D에게 순차로 양도한 경우, C·D가 선의취득자라 하더라도 A의 반환청구를 거절할 수 없다).

4) 소유권의 귀속

피해자 또는 유실자가 반환청구를 할 수 있는 2년 동안 그 소유권이 원소유자에게 속하느냐 또는 선의취득자에게 속하느냐?

- 선의취득자귀속설(통설)

제250조의 취지가 피해자나 유실자가 제249조에 의한 선의취득자로부터 목적물의 점유를 회수하여 도난이나 유실시의 본권관계를 회복하고자 하는 것이므로 선의취득의 성립과 동시에 소유권은 선의취득자에게 귀속한다. 따라서 선의취득에 의하여 취득자는 소유권을 확정적으로 취득하고 다만 2년 내에 그 반환을 청구당함으로써 소유권을 상실하는 수가 있다고 해석하는 것이 타당하다고 한다. 그 결과 위 반환청구권은 법률의 규정에 의해 인정되는 특별한 청구권으로 해석한다.

- 원소유자귀속설

선의취득자는 반환청구기간이 경과하여야 비로소 소유권을 취득한다는 견해로, 통설이 취하고 있는 “반환을 청구할 수 있다”는 규정에 본권관계를 부활시키는 기능을 가지는 법정의 특별한 원상회복청구권이 포함된다고 해석하는 것은 무리한 해석이고, 2년 동안은 선의취득을 보류하는 것이 이 제도가 기원한 게르만법의 취지에도 부합

5) 대가의 변상

반환청구는 원칙적으로 무상으로 할 수 있으나, 선의취득자가 그 물건을 경매·공개시장 또는 동종의 물건을 판매하는 상인으로부터 선의로 매수한 때에는 선의취득자가 지급한 대가를 변상하여야 한다(제251조).

- 대가 : 매매대금, 비용 ○ // 대금지급 이후의 이자 X
- 효과
 - 동시이행관계(상환급부판결) : 물건의 반환과 대가의 변상은 동시이행의 관계
 - 통설·판례 : 대가변상청구권은 인정되나 반환거절권은 인정되지 않음

제4절 명인방법

1. 총설

- 부동산물권 : 등기
- 동산물권 : 점유
- 입목에 관한 법률 : 「입목등기」
- 판례 : 관습법상의 「명인방법」(수목의 집단·미분리의 과실)
 - 수목의 집단은 인공적·자연적인 것을 불문
 - 미분리의 과실은 과수의 열매 외에 立稻·인삼·농작물 등

2. 명인방법의 의의

명인방법이란 지상물의 소유권에 관한 귀속을 명확하게 인식토록 하는 방법을 말한다. 입목 등기를 하지 않은 수목의 집단과 미분리의 과실·立稻·엽연초·인삼·농작물 등도 명인방법이라는 공시방법을 갖추으로써 그 지반이나 원물로부터 독립한 물권거래의 객체로 삼는 관행이 확립되어 있고, 또한 판례에 의하여 인정되고 있다.

등기를 공시방법으로 하는 토지나 건물, 입목법에 의한 입목에는 명인방법이 적용될 수 없다.

3. 명인방법의 내용

- 1) 명인방법이 갖추어지면 개개의 수목, 수목의 집단, 미분리 과실 등이 지반으로부터 분리양도가 가능하고 토지에 대한 저당권의 효력범위에서 제외된다.
 - 2) 명인방법으로 공시되는 물권변동은 소유권·양도담보권의 이전 및 유보에 한한다.
- 3) 소유권의 귀속을 대외적으로 표시하여야 한다.

- 긍정적인 예

- 임야의 여러 곳에 「입산금지 소유자 甲」이라는 팻말(대판 1967. 12. 18, 66다2382·2383)
- 경계에 따라 일정한 거리를 두고 樹皮를 깎아 소유자의 성명을 墨書한다거나, 논밭 주위에 새끼를 둘러 소유자의 성명을 묵서한 木札을 세우는 방법(대판 1976. 4. 27, 76다72).
- 입인상의 권리에 변동이 있음을 일반에게 알리는 문구를 기재한 팻말을 인삼포를 통과하는 사람이면 누구나 쉽게 볼 수 있게 설치한 경우(대판 1972. 2. 29, 71다2573)
- 집달관이 임야의 입구 부근에 그 지상임목이 무주의 소유에 속한다는 공시문을 붙인 팻말을 세운 경우(대판 1989. 10. 13, 89다카9064)

- 부정적인 예

- 법원의 검증당시 재판장의 수령 10년 이상된 수목을 흰 페인트칠로 표시하라는 명에 따라 측량감정인이 포푸라의 표피에 흰 페인트칠을 하고 편의상 그 위에 일련번호를 붙인 경우에는 제3자에 대하여 포푸라에 관한 소유권이 원고들에게 있음을 공시한 명인방법으로 볼 수 없다(대판 1990. 2. 13, 89다카23022).
- 토지의 주위에 울타리를 치고 그 안에 수목을 정원수로 심어 가꾸어 온 사실만으로는 명인방법을 갖추었다고 보기 어렵다(대판 1991. 4. 12, 90다20220).

- 특정성

특정이 되지 않은 임목에 대하여 명인방법을 취하였다 하더라도 그 효력이 생기지 않는다(대판 1972. 12. 12, 72다1351 : 대판 1973. 9. 25, 73다1229 : 대판 1975. 11. 25, 73다1323). 즉 어떤 범위의 지상물이 거래의 목적물인가를 알 수 있도록 특정하여야 한다. 따라서 수목을 지적(입방미터)만으로 표시한 때처럼 수목들이 특정되지 않은 경우에는 명인방법을 취하였다고 하더라도 그 효력이 생기지 않는다(대판 1975. 11. 25, 73다1323 : 대판 1972. 12. 12, 72다1351).

- 계속성

명인방법은 계속됨을 요한다. 명인방법 후 제3자가 권리취득 당시에 명인할 수 없는 상태였다면 명인방법으로서 효력이 없다. 절차상 흠이 있는 명인방법이라도 실체관계에 부합하면 유효한 것으로 된다(대판 1973. 9. 24, 73다1229).

4) 명인방법의 우열

지상물을 이종으로 양수한 자가 악의였다고 하더라도 먼저 명인방법을 갖추면 소유권을 취득하게 된다(대판 1967. 2. 28, 66다2442). 명인방법과 기타의 공시방법이 경합하는 경우, 예를 들어 임목을 명인방법과 등기로 이중양도한 경우에 관하여 판례는 어느 공시방법에 대하여도 같은 효력을 인정하여 먼저 공시방법을 갖춘 양수인이 우선하게 된다고 한다(대판 1972. 10. 25, 72다1389).

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 부동산에 대하여는 선의취득이 이루어질 수 없다.
- ② 가치의 표상으로서 유통되는 금전에 대해서는 선의취득이 불가능하다.
- ③ 등기·등록으로서 공시되는 동산에 대해서는 선의취득이 불가능하다.
- ④ 증권적 채권에 대해서는 선의취득이 있을 수 없다.
- ⑤ 국유재산 등과 같이 양도가 금지된 물건에 대해서는 선의취득이 있을 수 없다.

⇒ ④ 어음, 수표, 주식 등에 대해서도 선의취득이 가능하고 보다 완화된 요건을 요구한다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 점유보조자를 권리자로 오신한 경우에도 선의취득이 가능하다.
- ② 대리권이 있다고 오신한 경우에는 선의취득의 보호를 받지 못한다.
- ③ 포괄승계나 사실행위에 의해서는 선의취득이 불가능하다.
- ④ 판례는 양수인이 과실 없이 점유한 것으로 추정한다.
- ⑤ 점유개정에 의해서는 선의취득이 이루어질 수 없다.

⇒ ④. 제197조 제1항에서 무과실에 대한 규정이 없고, 판례도 선의취득자에게 무과실의 증명 책임을 지운다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 선의취득은 원시취득으로서 선의취득자는 그 물건 위에 존재하던 제한물권의 부담이 없는 완전한 소유권을 취득한다.
- ② 선의취득은 거래안전의 보호를 위한 것이므로 양수인이 임의로 선의취득의 효과를 거부하고 종전 소유자에게 동산을 반환받아 갈 것을 요구하는 것도 허용된다.
- ③ 점유이탈의 의사 유무는 직접점유자 내지 점유보조자를 표준으로 한다.
- ④ 입목법에 의한 입목은 명인방법이 적용될 수 없다.
- ⑤ 판례는 명인방법과 다른 공시방법이 경합하는 경우 대등한 효력을 인정하여 먼저 공시방법을 갖춘 양수인이 우선하는 것으로 본다.

⇒ ②. 선의취득의 효과는 종국적인 것으로 진정한 권리자에게 반환받아 갈 것을 요구하거나 양도인에게 담보책임을 추궁할 수 없다.

♣ 학습정리

- 1. 동산물권변동의 공시방법인 점유에는 공신력이 인정되는바, 무권리자로부터 동산을 양수하였더라도 평온·공연·선의·무과실로 그 동산을 점유한 경우에는 그 동산의 소유권을 취득한다.
- 2. 점유개정은 가장 불완전한 공시방법이므로 점유개정에 의해서는 선의취득이 이루어질 수 없다.
- 3. 선의취득은 법률의 규정에 의한 원시취득이고, 그 효과는 종국적인 것이다.
- 4. 도품이나 유실물에 대하여 선의취득이 있는 경우에는 피해자 또는 유실자는 2년 내에 그 물건의 반환을 청구할 수 있다.
- 5. 수목의 집단이나 미분리 과실에 대하여는 명인방법에 의한 공시가 가능하다.

제10강 물권의 소멸, 점유권 서설, 점유의 개념

♣ 학습목표

1. 물권의 소멸에 대하여 설명할 수 있다.
2. 점유제도의 기초이론을 정리할 수 있다.

♣ 학습내용

- 물권의 소멸(목적물멸실, 소멸시효, 물권의 포기, 혼동, 공용징수·몰수)
- 점유제도의 의의
- Possessio와 Gewere
- 점유의 개념
- 점유보조자

♣ 사전 테스트

1. 자동차는 선의취득의 목적물이 될 수 있다.
⇒ × : 등기·등록으로 공시되는 동산(선박·자동차·항공기·건설기계 등)은 선의취득의 목적물이 되지 못한다
2. 선의취득에서 동산의 인도가 먼저 행해진 후 물권적 합의가 이루어진 경우, 선의·무과실의 기준시기는 동산이 인도된 때이다.
⇒ × : 선의·무과실의 기준시기는 물권행위가 완성되는 때이고(대판 1962. 3. 22, 4294민상1174), 즉 물권적 합의가 동산의 인도보다 먼저 행해지면 인도된 때를, 인도가 먼저 행해지면 물권적 합의를 기준으로 하여야 한다.
3. 토지의 주위에 울타리를 치고 그 안에 수목을 정원수로 심어 가꾸어 온 사실이 있다면 명인방법을 갖추었다고 볼 수 있다.
⇒ × : 토지의 주위에 울타리를 치고 그 안에 수목을 정원수로 심어 가꾸어 온 사실만으로는 명인방법을 갖추었다고 보기 어렵다(대판 1991. 4. 12, 90다20220).

♣ 강의 교안

제6절 물권의 소멸

1. 목적물의 멸실

(1) 물건의 멸실

- ① 토지의 浦落, 물건의 燒失, 유실 등과 같이 물리적으로 완전히 소멸해 버리는 경우,
 - ② 무너진 건물의 벽돌 등과 같이 멸실물의 물질적 변형물이 남는 경우,
 - ③ 소실한 건물의 화재보험금 등과 같이 멸실물의 가치적 변형물이 남는 경우가 있다.
- 그러나 물권은 원칙적으로 목적물의 물질적 변형물에 미친다고 해석된다.

- (2) 물권 중 교환가치지배권인 담보물권에 있어서는 목적물의 가치변형물에도 미치는 것이 원칙이다. 이를 物上代位라고 한다(제342조·제370조). 그러나 그 가치변형물의 지급 또는 인도 전에 담보물권자가 압류하여야 그 가치변형물에 효력이 미친다.

제342조(물상대위)

질권은 질물의 **멸실, 훼손 또는 공용징수**로 인하여 질권설정자가 받을 금전 기타 물건에 대하여도 이를 행사할 수 있다. 이 경우에는 그 **지급 또는 인도전에 압류**하여야 한다.

- (3) 목적물의 멸실에 의하여 물권이 소멸하면, 그 후 동일한 물건이 재생되었다고 하더라도 소멸된 물권은 다시 발생하지 않는다.

포락한 토지가 다시 成土化 되었다 하더라도 포락한 토지에 대한 종전의 소유권은 영구히 소멸되고 그 성토화된 토지 소유권을 다시 취득하지 못한다고 한다(대판 1983. 12. 27, 83다카 1561 : 대판 1984. 11. 27, 84다카1072 등).

2. 소멸시효

제162조(채권, 재산권의 소멸시효)

- ① 채권은 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
- ② 채권 및 소유권 이외의 재산권은 20년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

- 소멸시효 대상인 물권

소유권 : X

점유권 : X (점유의 계속으로 점유권 존속하고 점유의 상실로 점유권 소멸 : 시효소멸 적용 없다)

지상권 : O

지역권 : O

전세권 : X (20년 시효소멸하기 전에 최장인 존속기간인 10년에 걸쳐 시효에 걸릴 여지없다)

유치권 : X (피담보채권과 독립하여 걸리지 않는다)
질권 : X (피담보채권과 독립하여 걸리지 않는다)
저당권 : X (피담보채권과 독립하여 걸리지 않는다)

3. 물권의 포기

(1) 성질

1) 물권의 포기는 물권을 소멸시키는 의사표시로 성립하는 물권적 단독행위이다.

소유권 및 점유권의 포기는 상대방 없는 단독행위이고, 제한물권의 포기는 상대방 있는 단독행위(통설)

(2) 제한 및 한계

물권의 포기는 자유이나, 이로 인하여 타인의 이익을 해하는 경우에는 그 타인의 동의가 있어야 한다. 지상권 또는 전세권이 저당권의 목적인 경우에는 그 지상권 또는 전세권의 포기는 저당권자의 동의가 있어야 한다(제371조).

또한 포기도 법률행위이므로 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반하는 때에는 무효이다(제103조).

(3) 효과 소유권을 포기하면 소유권은 소멸하고 무주물로 되어 동산인 때는 그 점유자가 소유권을 취득하고 부동산일 때에는 무주의 부동산으로서 국유가 된다. 한편 제한물권을 포기하면 소유권은 완전한 상태로 복귀한다.

4. 혼동

제191조(혼동으로 인한 물권의 소멸)

- ① 동일한 물건에 대한 소유권과 다른 물권이 동일한 사람에게 귀속한 때에는 다른 물권은 소멸한다. 그러나 그 물권이 **제삼자의 권리의 목적이 된 때에는** 소멸하지 아니한다.
- ② 전항의 규정은 소유권이외의 물권과 그를 목적으로 하는 다른 권리가 동일한 사람에게 귀속한 경우에 준용한다.
- ③ 점유권에 관하여는 전2항의 규정을 적용하지 아니한다.

(1) 의의

서로 대립되는 두 개의 법률상의 지위 또는 자격이 동일인에게 귀속하는 것을 混同이라 한다. 이러한 경우에 이들 두 개의 지위를 존속시키는 것은 무의미하므로 그 한쪽은 다른 쪽에 흡수되어서 소멸하는 것이 원칙이다. 혼동은 채권과 물권에 공통된 소멸원인이다.

우리 민법은 동산물권·부동산물권의 구별 없이 물권은 혼동으로 소멸하는 것으로 하고, 특별한 경우에 한하여 예외적으로 소멸하지 않는 것으로 하고 있다.

(2) 소유권과 제한물권과의 혼동

1) 원 칙

동일한 물건에 대한 소유권과 제한물권이 동일한 사람에게 귀속하면 제한물권은 소멸하는 것이 원칙이다(제191조 제1항 본문).

예를 들어 지당권자가 지당물의 소유권을 취득하거나 소유권자가 지상권자 또는 전세권자를 상속하게 되면 지당권 등은 소멸하는 것이다.

2) 예 외

혼동으로 소멸하는 제한물권이 제3자의 권리의 목적인 때에는 소멸하지 아니한다(제191조 제1항 단서).

→ ㉠ 지상권지당권에서 지상권자가 소유권취득

㉡ 전세권지당권에서 전세권자가 소유권취득

㉢ 제1저당권자가 소유권취득(소유자지당권) (제2번 지당권이 있는 경우)

여기서 「제3자의 권리의 목적인 때」의 의미를 넓게 「본인 또는 제3자」의 이익을 위하여 필요한 경우로 넓게 해석하고 있다(통설). 판례도 어떠한 물건에 대한 소유권과 다른 물권이 동일한 사람에게 귀속한 경우 그 제한물권은 혼동에 의하여 소멸하는 것이 원칙이지만, 본인 또는 제3자의 이익을 위하여 그 제한물권을 존속시킬 필요가 있다고 인정되는 경우에는 민법 제191조 제1항 단서의 해석에 의하여 혼동으로 소멸하지 않는다(대판 1998. 7. 10, 98다18643 : 대판 1962. 5. 3, 62다98)고 하여 본인의 이익을 위하여 필요한 경우까지 인정하여 넓게 해석하고 있다.

예) ㉠ 1번지당권이 있고 2번 지당권이 있는 경우 1번지당권자가 소유권을 취득하더라도 1번 지당권은 혼동으로 소멸하지 않는다.(아래참조 소유자지당권)

㉡ 위의 예에서 1번 지당권 대신 대항력 있는 임차권인 경우도 마찬가지이다(대판 2001. 5. 15, 2000다12693). 다만 후순위 지당권이 있더라도 선순위 대항력을 갖춘 임차인이 경매를 통해 소유권을 취득한 경우에는 경매에 의해 후순위 지당권도 소멸하므로 임차권을 존속할 필요가 없다. 따라서 이 경우에는 임차권은 혼동으로 소멸한다(대판 1998. 9. 25, 97다28650).

㉢ 가등기권자가 가등기에 기재자가 아니라 별도로 소유권이전등기를 받은 경우 가등기에 기한 본등기청구권은 혼동으로 소멸하지 않는다(대판 2007. 2. 22, 2004다59546 : 대판 1995. 12. 26, 95다29888).

(3) 혼동으로 소멸하지 않는 권리

1) 점유권 점유권은 물건의 사실상 지배의 사실을 보호하는 것이며, 점유권에는 소유권 기타 본권을 수반할 수도 있다. 따라서 이들의 물권은 본래 양립할 수 있는 것이기 때문에, 점유권은 혼동으로 소멸하지 않는다(제191조 제3항).

2) 광업권 광업권은 광물채취를 목적으로 하기 때문에 지표의 이용을 목적으로 하는 토지 소유권과는 별개의 독립한 권리이다. 따라서 양자는 양립할 수 있는 것이므로 혼동에 의하여 소멸되지 않는다.

(4) 혼동의 효과

- 1) 혼동에 의한 물건소멸의 효과는 절대적이다. 따라서 혼동 이전의 상태로 복귀하더라도 소멸한 권리는 부활하지 아니한다.

예를 들어 지상권자가 소유권을 취득함으로써 지상권이 소멸한 후에 그 소유권을 전 소유자가 다시 취득하게 되더라도 지상권은 부활하지 않는다.

- 2) 그러나 혼동을 생기게 한 원인이 존재하지 않거나 원인행위가 무효·취소·해제 등으로 인하여 효력을 잃은 때에는 혼동이 생기지 않았던 것으로 되고, 그 결과 소멸한 물건이 부활한다(통설·대판 1971. 8. 31, 71다1386).

정리

① 지당권자가 소유권을 취득(후순위 지당권 없는 경우) → 지당권 소멸

② 1번지당권자가 소유권을 취득(2번 지당권 있는 경우)

→ 지당권 존속(후순위 부담 유리방지/ 본인의 이익보호/소위 소유자지당권)

※ 주의 : 1번 지당권자가 상속으로 채무자 소유 부동산 소유권을 취득한 경우(2번 지당권 있는 경우)

→ 지당권은 소멸한다. 왜냐하면 상속으로 피담보채권도 혼동으로 소멸하고 부종성으로 지당권도 소멸하기 때문이다.

③ 지상권지당권에서 지상권자가 소유권취득 → 지당권 존속(제3자 이익 해함 방지)

④ 지상권지당권자가 지상권을 취득한 경우(후순위 지당권자가 없는 경우) → 지당권소멸

⑤ 지상권지당권자가 지상권을 취득한 경우(후순위 지당권자가 있는 경우) → 지당권존속

⑥ 지상권지당권을 질물로 설정한 경우 지당권자가 지상권을 취득한 경우 → 지당권존속

→ 채권채무의 혼동이 있는 경우 피담보채권의 운명을 먼저 검토하고 난 후 물권의 혼동을 검토한다.

5. 공용징수·몰수

공용징수라 함은 국가 또는 사업자가 특정한 공익사업을 위하여 소유권 기타 재산권을 강제로 취득하는 것이다. 이러한 공용징수에 의하여 공익사업의 주체는 원시적으로 권리를 취득하고, 반면에 피징수자의 권리와 그 목적물 위에 존재하였던 제3자의 권리는 모두 소멸한다. 몰수라 함은 재산권을 박탈하는 재산형이다(형법 제41조). 몰수에 의하여 국가는 원시적으로 권리를 취득하나, 피수익자의 물건은 소멸한다.

▶ 돌발 퀴즈

가등기권자가 가등기에 기해서가 아니라 별도로 소유권이전등기를 받은 경우 가등기에 기한 본등기청구권은 혼동으로 소멸한다.

⇒ × : 가등기권자가 가등기에 기해서가 아니라 별도로 소유권이전등기를 받은 경우 가등기에 기한 본등기청구권은 혼동으로 소멸하지 않는다(대판 2007. 2. 22, 2004다59546 : 대판 1995. 12. 26, 95다29888).

제3장 소유권과 점유권

제1절 점유권

I. 총 설

점유제도

1. 점유제도의 의의

제192조(점유권의 취득과 소멸)

① 물건을 **사실상 지배**하는 자는 **점유권**이 있다.

② 점유자가 물건에 대한 사실상의 지배를 상실한 때에는 점유권이 소멸한다. 그러나 제 204조의 규정에 의하여 점유를 회수한 때에는 그러하지 아니하다.

법률요건 -----> 법률효과

사실상의 지배상태(점유)

점유권

(점유권의 내용/ 점유권능)

- ① 점유보호청구권(제204조 이하)
- ② 자력구제(제209조)
- ③ 권리의 추정(제200조)
- ④ 선의점유자의 과실수취권(제201조)
- ⑤ 점유물의 멸실·훼손에 대한 책임 경감(제202조)
- ⑥ 점유물에 지출하는 비용상환청구권(제203조)
- ⑦ 동산물권변동의 성립·효력발생요건(제188조)
- ⑧ 선의취득(제249조)
- ⑨ 취득시효(제245조 이하)

: 법률요건으로서 점유 → 법률효과로서 점유권 → 그 내용으로서 법류효과

→ 예를 들어 A의 노트북을 B가 훔쳐가 사용하던 중 다시 C가 그 노트북을 훔쳐갔다면 B는 소유자가 아니지만 점유 자체에 기하여 그 반환을 청구할 수 있다(제204조)

제200조(권리의 적법의 추정)

점유자가 점유물에 대하여 행사하는 권리는 적법하게 보유한 것으로 추정한다.

제201조(점유자와 과실)

- ① 선의의 점유자는 점유물의 과실을 취득한다.
- ② 악의의 점유자는 수취한 과실을 반환하여야 하며 소비하였거나 과실로 인하여 훼손 또는 수취하지 못한 경우에는 그 과실의 대가를 보상하여야 한다.
- ③ 전항의 규정은 폭력 또는 은비에 의한 점유자에 준용한다.

제202조(점유자의 회복자에 대한 책임)

점유물이 점유자의 책임있는 사유로 인하여 멸실 또는 훼손한 때에는 악의의 점유자는 그 손해의 전부를 배상하여야 하며 선의의 점유자는 이익이 현존하는 한도에서 배상하여야 한다. 소유의 의사가 없는 점유자는 선의인 경우에도 손해의 전부를 배상하여야 한다.

제203조(점유자의 상환청구권)

- ① 점유자가 점유물을 반환할 때에는 회복자에 대하여 점유물을 보존하기 위하여 지출한 금액 기타 필요비의 상환을 청구할 수 있다. 그러나 점유자가 과실을 취득한 경우에는 통상의 필요비는 청구하지 못한다.
- ② 점유자가 점유물을 개량하기 위하여 지출한 금액 기타 유익비에 관하여는 그 가액의 증가가 현존한 경우에 한하여 회복자의 선택에 좇아 그 지출금액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다.
- ③ 전항의 경우에 법원은 회복자의 청구에 의하여 상당한 상환기간을 허여할 수 있다.

제204조(점유의 회수)

- ① 점유자가 점유의 침탈을 당한 때에는 그 물건의 반환 및 손해의 배상을 청구할 수 있다.
- ② 전항의 청구권은 침탈자의 특별승계인에 대하여는 행사하지 못한다. 그러나 승계인이 악의인 때에는 그러하지 아니하다.
- ③ 제1항의 청구권은 침탈을 당한 날로부터 1년내에 행사하여야 한다.

제205조(점유의 보유)

- ① 점유자가 점유의 방해를 받은 때에는 그 방해의 제거 및 손해의 배상을 청구할 수 있다.
- ② 전항의 청구권은 방해가 종료한 날로부터 1년내에 행사하여야 한다.
- ③ 공사로 인하여 점유의 방해를 받은 경우에는 공사착수후 1년을 경과하거나 그 공사가 완성한 때에는 방해의 제거를 청구하지 못한다.

제206조(점유의 보전)

- ① 점유자가 점유의 방해 받을 염려가 있는 때에는 그 방해의 예방 또는 손해배상의 담보를 청구할 수 있다.

②공사로 인하여 점유의 방해받을 염려가 있는 경우에는 전조제3항의 규정을 준용한다.

제209조(자력구제)

- ① 점유자는 그 점유를 부정히 침탈 또는 방해하는 행위에 대하여 자력으로써 이를 방위할 수 있다.
- ②점유물이 침탈되었을 경우에 부동산일 때에는 점유자는 침탈후 즉시 가해자를 배제하여 이를 탈환할 수 있고 동산일 때에는 점유자는 현장에서 또는 추적하여 가해자로부터 이를 탈환할 수 있다.

2. Possessio와 Gewere

근대법에서의 점유제도는 로마법계의 Possessio와 게르만법계의 Gewere와의 이론적·제도적 결합의 산물이다.

Possessio	Gewere
로마법에서는 물건에 대한 법률적 지배인 <u>소유권(dominium)</u> 과 물건에 대한 사실상 지배인 점유(<u>possessio</u>)로 분리하여 <u>후자를 본권의 유무와 관계없이 보호</u> 하였다.	게르만법은 본권과 점유의 분화를 몰랐고, 외형상 나타난 사실상 지배라는 현상형태를 통하여 본권을 파악 하고 있다. 따라서 Gewere의 어원은 「권리의 옷」으로서 그 효력은 ① 방어적 효력, ② 공격적 효력, ③ 이전적 효력 등이 있다.
Possessio의 요소 ① 점유보호청구권(占有訴權) ② 선의자의 과실취득권 ③ 비용상환청구권 ④ 소유권과 제한물권의 구별 ⑤ 공유 ⑥ 지역권 ⑦ 점유의 소와 본권의 소의 구별	Gewere의 요소 ① 점유의 권리추정력 ② 자력구제 ③ 선의취득 ④ 부동산등기제도 ⑤ 간접점유 ⑥ 공신의 원칙과 공시의 원칙 ⑦ 동산과 부동산의 구별

3. 점유보호의 근거

- ① 평화설(다수설) : 사회의 평화와 질서를 유지하기 위한 것
- ② 연속설 : 점유물을 그대로 보유(생활관계의 연속) 하려는 점유자 개인의 이익을 보호
- ③ 결합설 : 위의 모두이다

4. 점유권의 개념

(1) 물건이지만 본래의 물건이 아님

로마법에서는 점유권을 하나의 사실로 보았으나, 사비니(1779~1861) 이후 근대법 이론에서는 하나의 권리로 인정하게 되었다. 점유권은 현재 사실상 지배하고 있다는 데에서 생기고 사실상 지배를 상실하면 소멸하므로 객체를 지배할 수 있는 권리는 아니다. 따라서 점유권은 민법이 특히 물권의 일종으로 하고 있지만 본래의 물권과는 다른 것이다.

(2) 「점유할 수 있는 권리」 또는 「점유할 권리」와 구별

이들은 점유하는 것을 법률상 정당화하는 권리로서 본권이라고 한다. 소유권·전세권·지상권·임차권 등 물건의 사용가치의 지배를 목적으로 하는 권리는 모두 이 권리(본권)를 포함하고 있다. (예를 들어 盜人は 점유권은 있으나, 점유할 권리는 없고, 도난당한 피해자는 그 반대이다)

II. 점 유

1. 점유의 개념

- 사실적 지배(사실적 지배 + 점유설정의사)

제192조(점유권의 취득과 소멸)

- ① 물건을 **사실상 지배**하는 자는 **점유권**이 있다.
- ② 점유자가 물건에 대한 사실상의 지배를 상실한 때에는 점유권이 소멸한다. 그러나 제 204조의 규정에 의하여 점유를 회수한 때에는 그러하지 아니하다.

우리 민법 : 객관설(제192조)(주관적 의사는 요구하지 않음)

객관설 (①소지의사설(다수설)/ ②순객관설(소수설 : 점유설정의사도 불필요하다))

주관설(①소유자의사설, ②지배자의사설, ③자기를 위하여 소지하는 의사설)

일본민법 제180조 “점유권은 자기를 위하여 하는 의사를 가지고 물건을 소지함에 의하여 취득한다”

(1) 사실적 지배로서 점유

- 점유라고 함은 물건이 사회통념상 그 사람의 사실적 지배에 속한다고 보여지는 객관적 관계
- 구체적인 판단

① 물건과 사람과의 시간적, 공간적 관계와 본권관계, 타인지배의 배제가능성 등을 고려하여 사회관념에 따라 합목적적으로 판단하여야 한다(대판 2009. 9. 24, 2009다39530). 결국 점유를 인정함에 있어서 물건에 대해 언제나 사실적으로 드러나는 현상뿐만 아니라 관념적·규범적인 비사실적 요소를 포함하여 인정

② 사실상 지배를 판단함에 있어서 본권의 유무는 원칙적으로 문제되지 않으나 사실상 지배(점유)를 인정하기 위하여 본권관계를 고려하고 있다.

(2) 점유설정의사

① 점유설정의사 필요설(통설)

민법상 점유가 성립하기 위하여 일정한 점유의사를 필요로 하지 않으나, 적어도 사실적 지배관계를 가지려는 의사(점유설정의사)는 필요하다(통설). <- - 그러한 의사 없이는 어떤 지배라는 것을 생각할 수 없기 때문이다.

② 점유설정의사 불요설

㉠ 민법 제192조 제1항이 명문으로 「물건에 대한 사실상의 지배」만으로 점유가 성립한다고 규정하고 있으므로 순객관설이 타당하다.

㉡ 점유설정의사는 자연적의사인데 법인에게서는 이러한 의사를 인정하기 어렵게 된다는 것을 그 근거로 하고 있다.

예) 우편함에 투입된 서신은 점유자가 인식하지 못하였더라도 점유설정의사가 있다. 이는 그 투입이 예정되어 있기 때문이다.

그러나 잘못 배달된 편지, 지나가던 도둑이 우편함에 훔친 물건을 몰래 숨겨둔 경우, 남의 모자가 자기 집에 바람에 날려 들어온 경우에는 점유설정의사가 없다.

③ 제한능력자라도 사실상의 지배를 하려는 의사가 있는 한 점유 인정

④ 점유는 사실행위이기 때문에 대리에 관한 규정은 적용 없음

(3) 예외(점유의 관념화)

물건에 대한 사실상 지배 여부는 사회관념상 점유자에게 점유권을 주어 보호할 가치가 있는지를 중심으로 정할 가치판단의 문제이다.

→ ① 사실상 지배를 함에도 점유가 성립하지 않는 경우(제195조 점유보조자)

② 사실상 지배를 하지 않음에도 점유가 성립하는 경우(제193조 상속인의 점유, 제194조 간접 점유)

위 세 가지를 보통 占有의 觀念化라고 부른다.

2. 점유보조자

제195조(점유보조자)

가사상, 영업상 기타 유사한 관계에 의하여 타인의 지시를 받아 물건에 대한 사실상의 지배를 하는 때에는 그 타인만을 점유자로 한다.

(1) 의의

점유보조자의 점유를 인정하지 않은 이유 :

- ㉠ 그에게 점유권을 주어 보호할 만한 이익이 적음
- ㉡ 만약 점유권을 인정하면 점유주에 대하여도 점유권 행사가 가능하여 점유질서의 혼란 우려

(2) 요건

- ① 사실상의 지배
- ② 점유보조관계(또는 사회적 종속관계)

㉠ 점유보조자가 「타인의 지시를 받아」 사실상의 지배를 하여야 한다. 이러한 지시관계를 점유보조관계(명령·복종관계)라고 한다.

- ㉡ 가사상, 영업상 + 계약법·친족법·공법상 법률관계 등 / 계속적·일시적

Q : 자기물건에 대하여도 점유보조관계 인정

(예 : 부모가 의사능력이 없는 어린아이에게 물건을 준 때 그 어린아이)

[판례] 관리대행의 경우 점유보조관계 인정

고속국도법 제5조, 제6조 제1항, 제2항 및 같은법시행규칙 제2조 제1항, 제2항의 각 규정에 의하면 고속국도의 관리청인 건설부장관은 고속국도법과 도로법 기타 도로에 관한 법률에 규정된 고속국도에 관한 그의 권한의 일부를 미리 당해 고속국도의 노선명, 구간과 대행하게 하는 권한내용 및 그 기간을 정하여 한국도로공사로 하여금 대행하게 할 수 있고, 한국도로공사가 건설부장관의 권한을 대행하는 경우에 그 대행하는 범위 내에서 고속국도법과 도로법 기타 도로에 관한 법률의 적용에 있어서는 당해 고속국도의 관리청으로 본다고 규정하고 있는 점에 비추어 보면, 한국도로공사가 위 규정들에 따라 건설부장관을 대행하여 고속국도 부지인 부동산을 관리하여 온 이상 이는 위 법규에 따라 건설부장관이 정하는 범위 내에서 건설부장관을 대행하는 것에 불과하여 독립한 점유주체로 될 수 없고, 건설부장관을 기관으로 하는 대한민국의 점유보조자에 불과하다(대판 1995. 2. 14, 94다28994).

㉔ 그런데 법인의 점유에 관하여는 학설상 견해의 대립.

(판례 : 법인의 대표기관이 점유하는 경우에는 대표기관의 점유가 아니라 법인 자신의 점유로 본다. 대판 1996. 1. 26, 94다45562)

③ 사회적 종속관계를 외부에서 인식할 필요는 없다(다수설)

(3) 효과

① 점유권의 배제(제195조)

점유보호청구권의 주체 X // 그 상대방도 X (대판 1960. 3. 10, 4292민상257).

[판 례] 점유보조자의 소유물반환청구의 상대방(소극)

소유물반환청구의 상대방은 현재 그 물건을 점유하는 자이고 그 점유보조자에 불과한 자는 이에 해당하지 아니하므로, 주식회사의 직원으로서 회사의 사무실로 사용하고 있는 건물부분에 대한 점유보조자에 불과할 뿐 독립한 점유주체가 아닌 피고들은, 회사를 상대로 한 명도소송의 확정판결에 따른 집행력이 미치는 것은 별론으로 하고, 소유물반환청구의 성질을 가지는 퇴거청구의 독립한 상대방이 될 수는 없는 것이다(대판 2001. 4. 27, 2001다13983).

② 자력구제권(제209조)의 행사(이설없음)

③ 점유주의 점유 취득 및 상실에 대한 영향

예를 들어 가정부가 시장에서 물건을 사거나 또는 물건을 잃어버린 경우에는 점유주도 그에 따라 점유를 하거나 또는 점유를 잃게 된다.

④ 점유보조관계의 종료

점유보조자와 점유주는 종속관계가 종료하면 점유보조자의 지위도 종료한다. 그러나 점유보조관계를 끝낸다는 의사가 외부에 명시되지 않으면 아니된다. 점유보조관계가 종료하면 점유주는 점유보조자에 대하여 점유물반환청구를 할 수 있다.

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 포락한 토지가 다시 성토화 되었다면, 포락한 토지에 대한 종전의 소유권은 회복되고, 그 성토화된 토지 소유권을 다시 취득한다.
- ② 지상권이 저당권의 목적인 경우에 그 지상권의 포기는 저당권자의 동의가 있어야 한다.
- ③ 부동산의 소유권을 포기하면 무주의 부동산으로서 국유가 된다.
- ④ 제한물권을 포기하면 소유권은 완전한 상태로 복귀한다.

- ⑤ 동일한 물건에 대한 소유권과 다른 물건이 동일한 사람에게 귀속한 때에는 다른 물건은 소멸하지만, 그 물건이 제3자의 권리의 목적이 된 때에는 소멸하지 아니한다.

- ①. 포락한 토지가 다시 成土化 되었다 하더라도 포락한 토지에 대한 종전의 소유권은 영구히 소멸되고 그 성토화된 토지 소유권을 다시 취득하지 못한다고 한다(대판 1983. 12. 27, 83다카1561 : 대판 1984. 11. 27, 84다카1072 등)

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 우리 민법은 동산물권·부동산물권의 구별 없이 물권은 혼동으로 소멸하는 것으로 하고, 특별한 경우에 한하여 예외적으로 소멸하지 않는 것으로 하고 있다.
- ② 1번 저당권이 있고 2번 저당권이 있는 경우 1번 저당권자가 소유권을 취득하더라도 1번 저당권은 혼동으로 소멸하지 않는다.
- ③ 대항력을 갖춘 선순위 임차권과 후순위 저당권이 있는 부동산에 관하여 선순위 대항력을 갖춘 임차인이 경매를 통해 소유권을 취득한 경우에는 임차권은 혼동으로 소멸하지 않는다.
- ④ 혼동을 생기게 한 원인이 존재하지 않거나 원인행위가 무효·취소·해제 등으로 인하여 효력을 잃는 때에는 혼동이 생기지 않았던 것으로 되고, 그 결과 소멸한 물건이 부활한다.
- ⑤ 점유권과 소유권은 본래 양립할 수 있는 것이기 때문에, 점유권은 혼동으로 소멸하지 않는다.
- ③. 후순위 저당권이 있더라도 선순위 대항력을 갖춘 임차인이 경매를 통해 소유권을 취득한 경우에는 경매에 의해 후순위 저당권도 소멸하므로 임차권을 존속할 필요가 없다. 따라서 이 경우에는 임차권은 혼동으로 소멸한다(대판 1998. 9. 25, 97다28650).

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 가사상, 영업상 기타 유사한 관계에 의하여 타인의 지시를 받아 물건에 대한 사실상의 지배를 하는 때에는 그 타인만을 점유자로 한다.
- ② 도로의 유지·관리에 관한 상위 지방자치단체장의 행정권한이 행정권한위임조례에 의하여 하위 지방자치단체장에게 위임되었다면 사무귀속의 주체는 상위 지방자치단체장이라 하더라도 권한을 위임받은 하위 지방자치단체장이 도로의 관리청이 되고 위임관청은 사무처리의 권한을 잃는 것이므로, 권한을 위임받은 도로의 관리청이 속하는 지방자치단체가 그 도로의 관리·유지를 위하여 하는 점유가 점유보조자의 지위에서 하는 점유라고 할 수 없다
- ③ 법인의 대표기관이 점유하는 경우에는 법인 자신의 점유가 아니라 대표기관의 점유로 본다.
- ④ 주식회사의 직원으로서 회사의 사무실로 사용하고 있는 건물부분에 대한 점유보조자에 불과할 뿐 독립한 점유주체가 아닌 피고들은, 회사를 상대로 한 명도소송의 확정판결에 따른 집행력이 미치는 것은 별론으로 하고, 소유물반환청구의 성질을 가지는 퇴거청구의 독립한 상대방이 될 수는 없는 것이다
- ⑤ 자기물건에 대하여도 점유보조관계가 인정된다.
- ③. 법인의 대표기관이 점유하는 경우에는 대표기관의 점유가 아니라 법인 자신의 점유로 본다. 대판 1996. 1. 26, 94다45562

♣ 학습정리

1. 목적물의 멸실에 의하여 물권이 소멸하면, 그 후 동일한 물건이 재생되었다고 하더라도 소멸된 물권은 다시 발생하지 않는다.
2. 소유권은 소멸시효의 대상이 되지 않는다.
3. 물권이 포기는 자유이나, 이로 인하여 타인의 이익을 해하는 경우에는 그 타인의 동의를 있어야 한다.
4. 동일한 물건에 대한 소유권과 다른 물권이 동일한 사람에게 귀속한 때에는 다른 물권은 소멸한다. 그러나 그 물권이 제삼자의 권리의 목적이 된 때에는 소멸하지 아니한다.
5. 물건을 사실상 지배하는 자는 점유권이 있고, 점유자가 물건에 대한 사실상의 지배를 상실한 때에는 점유권이 소멸한다.
6. 가사상, 영업상 기타 유사한 관계에 의하여 타인의 지시를 받아 물건에 대한 사실상의 지배를 하는 때에는 그 타인만을 점유자로 한다.

제11강 간접점유, 점유의 모습, 점유권의 득실

♣ 학습목표

1. 간접점유 제도에 대하여 설명할 수 있다.
2. 점유의 종류를 정리할 수 있다.
3. 점유의 득실을 정리할 수 있다.

♣ 학습내용

- 간접점유
- 자주점유와 타주점유의 비교
- 하자 있는 점유와 하자 없는 점유의 비교
- 선의점유와 악의점유의 비교
- 과실 있는 점유와 과실 없는 점유의 비교
- 점유의 득실

♣ 사전 테스트

1. 동일한 물건에 대한 소유권과 다른 물권이 동일한 사람에게 귀속한 때에는 그 물권은 제3자의 권리의 목적이 되는지 여부와 관계없이 소멸한다.
⇒ × : 동일한 물건에 대한 소유권과 다른 물권이 동일한 사람에게 귀속한 때에는 다른 물권은 소멸하지만, 그 물권이 제3자의 권리의 목적이 된 때에는 소멸하지 아니한다.
2. 자기물건에 대하여는 점유보조관계가 인정되지 않는다.
⇒ × : 자기물건에 대하여도 점유보조관계가 인정된다.
3. 가사상, 영업상 기타 유사한 관계에 의하여 타인의 지시를 받아 물건에 대한 사실상의 지배를 하는 때에는 점유자가 된다.
⇒ × : 가사상, 영업상 기타 유사한 관계에 의하여 타인의 지시를 받아 물건에 대한 사실상의 지배를 하는 때에는 그 타인만을 점유자로 한다.

♣ 강의 교안

3. 간접점유

제194조(간접점유)

지상권, 전세권, 질권, 사용대차, 임대차, 임치 기타의 관계로 타인으로 하여금 물건을 점유하게 한 자는 간접으로 점유권이 있다.

(1) 의의

간접점유란 일정한 법률관계에 기하여 타인을 매개로 하여 간접적으로 점유하는 것을 말한다.
예를 들어 임대인(A)을 간접점유자, 임차인(B)을 점유매개자라고 부르며, A·B간의 법률관계인 임대차관계를 점유매개관계라고 한다.

따라서 간접점유는 점유매개관계에 기하여 직접점유를 하는 자(점유매개자)에 의하여 매개되는 점유이다.

지상권, 전세권, 질권, 사용대차, 임대차, 임치 기타의 관계 : 예시규정

→ 도급, 양도담보, 법률의 규정(위 도로관리위임 사례)

(2) 인정근거

간접점유자는 물건에 대하여 사실상의 지배를 하지 않지만 점유매개자의 점유권이 간접점유자의 권리에서 전래된 것이고, 그 내용이 제한적이며 간접점유자는 점유매개관계의 종료시 반환청구권을 가지고 있어 사회관념상 여전히 그 물건을 자기의 지배권 내에 두고 있다.

(3) 성립요건

① 특정인의 직접점유

점유매개자가 물건을 점유하고 있어야 한다(타주점유).

② 점유매개관계의 존재

(a) 특정인의 직접점유가 있어야 한다.

(b) 간접점유자와 점유매개자 사이에 점유매개관계가 있어야 한다(계약, 법률의규정).

(c) 점유매개관계는 반드시 유효한 것일 필요는 없다.

점유란 원래 점유할 수 있는 권리 즉 본권의 유무를 묻지 않고 사실상 지배에 의해서 인정되기 때문이다(김증한/김학동·김상용).

예컨대 임대차계약을 맺었는데 그것이 무효이거나 취소된 경우에도 임차인이 점유를 계속하는 한 간접점유는 그대로 존속한다(통설). 이 경우에는 부당이득반환청구에 의하여 점유매개관계가 성립한다.

(d) 점유매개자의 점유할 권리는 간접점유자의 권리로부터 전래한 것이고, 내용에 있어서 간접점유자의 권리보다 제한된 것이어야 한다.

(e) 점유매개관계는 중첩적으로 있을 수 있다. 예를 들어 소유자 A가 B에게 소유물을 임대한 후 B가 다시 C에게 전대하면 두개의 점유매개관계가 있게 된다.

③ 반환청구권의 존재

점유매개관계의 특징은 간접점유자가 직접점유자에 대하여 반환청구권을 가진다는 점이다. 이 반환청구권의 존재는 간접점유자가 물건에 대한 지배력이 미치고 있다는데 대한 절대적 요건이다.

(4) 효과(간접점유자의 지위)

① 점유권

간접점유자도 점유권을 가진다(제194조).

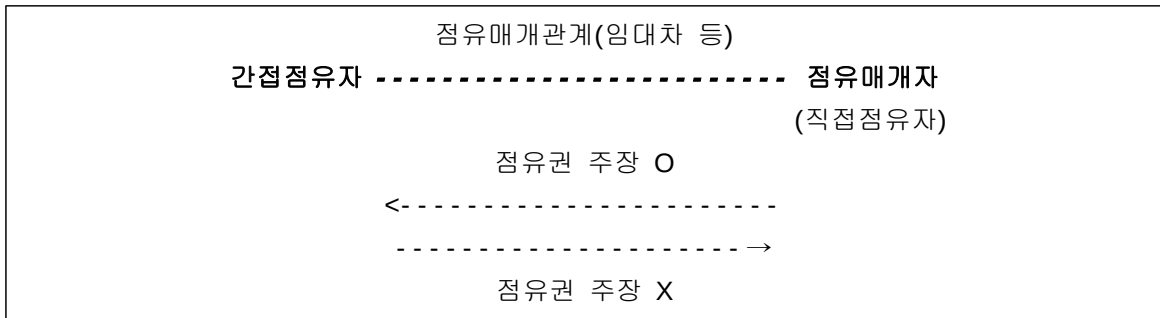
따라서 점유에 관한 규정은 그 성질상 또는 규정상 그 적용이 배제된다고 생각되는 것을 제외하고는 간접점유에도 적용된다.

또한 점유매개관계에 기하여 물건에 직접적으로 실력을 행사하는 자(직접점유자)도 점유권을 가진다.

② 대내관계(간접점유자와 직접점유자 사이)

간접점유자는 직접점유자에 대하여 점유보호청구권이나 자력구제권을 행사할 수 없다. 다만 간접점유자도 간접점유의 기초적 법률관계(점유매개관계)나 또는 본권에 기한 청구권만 행사할 수 있다.

그러나 직접점유자는 간접점유자에 대하여 점유매개관계에 기한 청구권 외에 점유보호청구권이나 자력구제권을 행사할 수 있다.

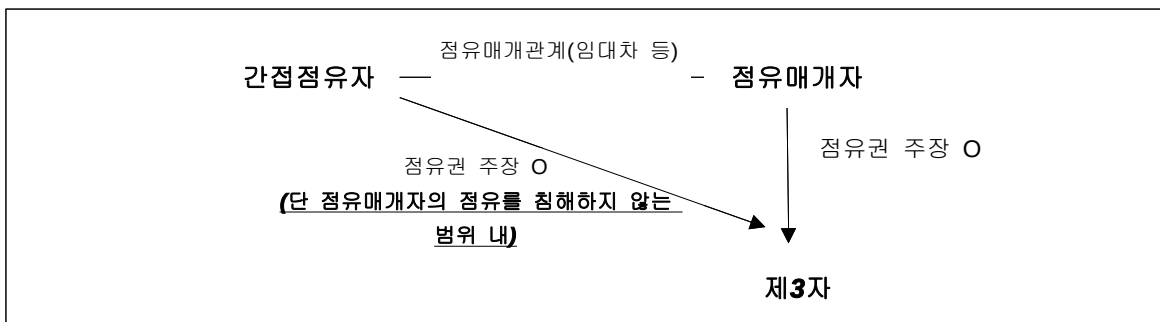


③ 대외관계(간접점유자와 제3자 사이)

(a) 직접점유자의 점유를 침탈당하거나 방해당하고 있는 경우에는 간접점유자도 제3자에 대하여 점유보호청구권을 가진다(제207조 제1항). 다만 간접점유자는 점유물을 침탈당한 경우에 침탈자에 대하여 직접 자기에게 반환할 것을 청구할 수 없고 직접점유자에게 반환할 것을 청구할 수 있을 뿐이다. 다만 직접점유자가 반환받을 수 없거나 반환을 원하지 않을 때에 한하여 자기에게 반환을 청구할 수 있다(제207조 제2항).

제207조(간접점유의 보호)

- ① 전3조의 청구권은 제194조의 규정에 의한 간접점유자도 이를 행사할 수 있다.
- ② 점유자가 점유의 침탈을 당한 경우에 간접점유자는 그 물건을 점유자에게 반환할 것을 청구할 수 있고 점유자가 그 물건의 반환을 받을 수 없거나 이를 원하지 아니하는 때에는 자기에게 반환할 것을 청구할 수 있다.



Q : 직접점유자가 점유물을 횡령하여 제3자에게 처분한 경우처럼 직접점유자에 의하여 간접점유가 침해된 때에는 간접점유자의 제3자에 대한 점유보호청구권이 인정되는가?
→ 부정설(판례·다수설)

판례(직접점유자의 횡령시 간접점유자의 제3자에 대한 점유보호청구권 부정)

직접점유자가 임의로 점유를 타에 양도한 경우에는 점유이전이 간접점유자의 의사에 반한다 하더라도 간접점유자의 점유가 침탈된 경우에 해당하지 않는다고 하여 이 경우에 간접점유자의 점유보호청구권을 인정하지 않고 있다(대판 1993. 3. 9, 92다5300).

검토 : 간접점유의 침탈을 민법 제204조 제1항의 침탈로 해석할 수 있는냐의 문제이다. 동조의 침탈은 “직접점유자를 기준”으로 하여야 한다. 왜냐하면 간접점유는 점유매개관계를 원인으로만 성립되므로 제3자의 행위에 의해서는 침해될 수 없기 때문이다. 따라서 직접점유자에 대한 침해가 법률상 허용되는 경우 또는 직접점유자가 이에 동의한 경우에는 간접점유자는 점유보호청구권을 행사할 수 없다. 다만 간접점유자가 소유권을 침해받은 경우 소유권에 기한 물권적 청구권을 행사하여 반환받을 수 있고, 이 경우라도 제3자는 동산이라면 선의취득을 주장할 수 있다.

(b) 직접점유자에 대한 침해가 있는 경우에 간접점유자는 제3자에 대하여 자력구제권이 있는가?

㉠ 긍정설

- 직접점유자가 자력구제권을 행사하지 않고 있을 경우 간접점유자도 그 권리를 행사할 수 있어야 점유자의 보호에 공평
- 민법 제209조가 간접점유자의 자력구제를 금지하는 규정을 두지 않았다

㉡ 부정설(다수설)

- 개인의 私力を 행사하는 자력구제는 가능한 한 제한적으로 허용되어야 한다.

④ 점유의 모습의 표준

선의·악의·강박·은닉 등의 간접점유자의 점유의 모습은 모두 직접점유자의 점유를 표준.

그러나 간접점유자가 악의인 때에는 직접점유자가 선의라도 간접점유자의 점유는 악의로 된다.

4. 상속인의 점유

점유권은 상속인에게 이전한다(제193조). 여기서 말하는 점유는 제192조에서 말하는 점유가 아니고 물건에 대한 사실상의 지배가 없는 점유이다. 피상속인은 사망시에 점유자이어야 한다. 직접점유이든 간접점유이든 이를 묻지 않는다.

상속인이 상속의 사실을 모르더라도, 또 물건을 사실상 지배하지 않더라도 당연히 피상속인의 점유권은 그 사망과 동시에 상속인에게 이전된다.

그리고 상속인이 상속에 의하여 당연히 승계하는 점유 및 점유권은 피상속인이 가지고 있었던 것과 동일한 것이다.

본조는 포괄승계가 일어나는 포괄적 유증(제1078조)·회사의 합병에도 준용된다.

점유의 종류

(자주점유 / 타주점유)

(하자 있는 점유 / 하자 없는 점유)

(선의점유 / 악의점유)

(과실 있는 점유/ 과실 없는 점유)

1. 자주점유·타주점유

(1) 개념

① 의의

자주점유 : 소유의 의사를 가지고 하는 점유

타주점유 : 그렇지 않은 점유(타인이 소유권을 가지고 있다는 것을 전제로 하는 점유)

소유의 의사 : 소유자가 할 수 있는 것과 같은 배타적 지배를 사실상 행사하려고 하는 의사(대판 1994. 11. 9, 94라36438), 그러한 소유권이 있거나 있다고 믿을 필요는 없다. 사실상 소유할 의사가 있는 것으로 충분하다.

→ 따라서 무효인 매매에 있어서 매수인이나 도둑도 자주점유자에 해당된다.

② 자주점유와 타주점유를 구별하는 실익

자주점유여부 구별실익 있는 경우	자주점유여부 구별실익 없는 경우
① <u>취득시효</u> (제245조 이하)	① 동산선의취득(평온·공연·선의·무과실이 문제될 뿐)
② <u>무주물선점</u> (제252조)	② 과실취득권(선의·악의가 문제될 뿐)
③ 점유자의 회복자에 대한 <u>책임감경</u> (제202조)	③ 비용상환청구권(점유의 성질을 문제 삼지 않음)

(2) 자주점유인가의 판단기준

[판례] 대판[전합] 1997. 8. 21, 95다28625

점유자의 점유가 소유의 의사 있는 자주점유인지 아니면 소유의 의사 없는 타주점유인가의 여부는 점유자의 내심의 의사에 의하여 결정되는 것이 아니라 점유취득의 원인이 된 ① 권원의 성질이나 ② 점유와 관계가 있는 모든 사정에 의하여 외형적·객관적으로 판단되어야 한다.

→ 즉 ① 1차로 권원의 성질 : 임차인·수치인 → 권원의 성질상 타주점유

② 2차로 점유와 관계 있는 모든 사정 : 점유자가 진정한 소유자라면 통상 취하지 않았을 태도를 보이거나 진정한 소유자라면 당연히 취했을 조치를 취하지 않은 등의 사정

1) 점유취득시를 기준으로 권원의 성질에 의하여 객관적으로 결정된다(통설·판례)

2) 권원의 성질상 자주점유인 경우

① 증여·매매·교환과 같이 소유권취득의 원인이 되는 계약(매매계약이 무효인 경우, 즉 실제로 매매계약이 있었던 이상, 그 계약이 무효라 하더라도 매수인은 원칙적으로 자주점유자이다 (대판 1980. 5. 27, 80다671; 대판 1992. 10. 27, 92다30375; 대판 1994. 12. 27, 94다25513, 다만 후술하는 매매 계약이 무효임을 알거나, 주무관청의 허가 없음을 알고 매매계약을 체결하는 경우는 자주점유의 추정이 반복된다).

② 타인의 권리를 매매한 경우, 즉 판례는 ‘매도인에게 처분권한이 없다는 것을 매수인이 알고서 매수하였다는 사정이 증명되지 않는 한’ 자주점유라고 하면서(대판[전합] 2000. 3. 16, 97다37661), 토지매수인이 매매계약에 의하여 목적 토지의 점유를 취득한 경우, 그 계약이 타인의 토지의 매매에 해당하여 곧바로 소유권을 취득할 수 없다는 사실만으로 자주점유의 추정이 반복되지는 않는다.

③ 매수인의 점유가 등기를 수반하지 아니한 점유임이 밝혀졌다고 하더라도 타주점유로 볼 수는 없다(대판[전합] 2000. 3. 16, 97다37661).

[판례] 등기를 수반하지 아니한 점유임이 밝혀진 경우 타주점유로 볼 것인지 여부(소극)

[다수의견] 현행 우리 민법은 법률행위로 인한 부동산 물권의 득실변경에 관하여 등기라는 공시방법을 갖추어야만 비로소 그 효력이 생긴다는 형식주의를 채택하고 있음에도 불구하고 ① 등기에 공신력이 인정되지 아니하고, 또 현행 민법의 시행 이후에도 법생활의 실태에 있어서는 상당기간 동안 의사주의를 채택한 ② 구 민법에 따른 부동산 거래의 관행이 잔존하고 있었던 점 등에 비추어 보면, 토지의 매수인이 매매계약에 의하여 목적 토지의 점유를 취득한 경우 설사 그것이 타인의 토지의 매매에 해당하여 그에 의하여 곧바로 소유권을 취득할 수 없다고 하더라도 그것만으로 매수인이 점유권원의 성질상 소유의 의사가 없는 것으로 보이는 권원에 바탕을 두고 점유를 취득한 사실이 증명되었다고 단정할 수 없을 뿐만 아니라, 매도인에게 처분권한이 없다는 것을 잘 알면서 이를 매수하였다는 등의 다른 특별한 사정이 증명되지 않는 한, 그 사실만으로 바로 그 매수인의 점유가 소유의 의사가 있는 점유라는 ③ 추정이 깨어지는 것이라고 할 수 없고, ④ 민법 제197조 제1항이 규정하고 있는 점유자에게 추정되는 소유의 의사는 사실상 소유할 의사가 있는 것으로 충분한 것이지 반드시 등기를 수반하여야 하는 것은 아니므로 등기를 수반하지 아니한 점유임이 밝혀졌다고 하여 이 사실만 가지고 바로 점유권원의 성질상 소유의 의사가 결여된 타주점유라고 할 수 없다.

④ 취득시효 완성후의 점유자의 점유는 특단의 사정이 없는 한 자주점유

판례는 취득시효완성 후 점유자가 권리자에 대해 매수를 시도한 사실이 있다 하더라도 그러한 사실만으로는 그 후부터는 물론 그전의 점유가 타주점유였다고 단정할 수는 없다고 한다(대판[전합] 1983. 7. 12, 82다708).

3) 권원의 성질상 타주점유인 경우

예 : 지상권자·전세권자·질권자·임차인·명의수탁자의 점유

- ① 공유자 1인이 공유토지 전부를 점유하는 경우 다른 공유자의 지분범위 내에서는 타주점유자이다(대판 2010. 2. 25, 2009다98386; 대판 1996. 7. 26, 95다51861).
- ② 공동상속인 중 1인이 상속 부동산 전부를 점유하고 있는 경우, 자신의 상속지분을 초과하는 부분에 대한 점유도 타주점유이다(대판 2008. 9. 25, 2008다31485).
- ③ 귀속농지를 포함한 귀속재산의 점유자는 국가에 대한 보관자의 지위에 있게 되므로 권원의 성질상 타주점유이다(대판 2006. 6. 9, 99다36778).
- ④ 국유지를 장차 불하받을 생각으로 그 점유·사용권만을 양도받아 점유한 자의 점유는 타주점유이다(대판 1997. 7. 11, 97다15562).
- ⑤ 타주점유를 상속으로 승계한 자의 점유도 타주점유이다(대판 1995. 12. 22, 95다30062).
- ⑥ 구 농지개혁법(1994. 12. 22. 법률 제4817호 농지법 부칙 제2조 제1호로 폐지)에 의하여 정부가 매수한 농지가 농민들에게 분배되지 않는 것으로 확정될 경우 그 소유권은 원소유자에게 복귀되는 것이므로 국가가 구 농지개혁법에 따라 농지를 매수한 것은 이를 자경하는 농민 등에게 분배하기 위한 것이고, 분배하지 아니하기로 확정되는 경우에는 원소유자에게 환원될 것이 매수 당시부터 예정되어 있는 것이므로 국가의 매수농지에 대한 점유는 진정한 소유자의 지배를 배제하려는 의사를 가지고 하는 자주점유라고 볼 수 없고, 권원의 성질상 타주점유로 보아야 한다(대판 2001. 12. 27, 2001다48187).
- ⑦ 매매대상 대지의 면적이 등기부상의 면적을 상당히 초과하는 경우에 특별한 사정이 없다면 계약 당사자들이 이러한 사실을 알고 있었다고 보는 것이 상당하며, 그러한 경우에는 매도인이 그 초과 부분에 대한 소유권을 취득하여 이전하여 주기로 약정하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 초과 부분은 단순한 점용권의 매매로 보아야 하고 따라서 그 점유는 권원의 성질상 타주점유에 해당한다(대판 2009. 12. 10, 2006다55784·55791; 대판 2001. 11. 27, 2001두6982; 대판 2000. 4. 25, 2000다348; 대판 1998. 11. 10, 98다32878; 대판 1999. 6. 25, 99다5866·5873 등). 매매가 아닌 증여도 실제 면적이 공부상 면적을 상당히 초과하는 경우, 그 초과 부분에 대하여서도 권원의 성질상 타주점유이다(대판 2004. 5. 14, 2003다61054). 자신 소유의 대지 위에 건축한 건물이 인접 토지를 침범하게 된 경우, 그 침범 면적이 통상 있을 수 있는 시공상의 착오 정도를 넘어 상당한 정도라면 당해 건물의 건축주는 건축 당시에 인접 토지를 침범하여 건축한다는 사실을 알고 있었다고 보는 것이 상당하므로 토지의 점유는 권원의 성질상 소유의 의사가 있는 점유라고 할 수 없다(대판 2001. 5. 29, 2001다5913).

4) 소유의 의사의 판단시점 : 점유개시시

- ① 소유의 의사는 점유의 개시시에 존재하면 족하다(통설).

판례도 점유의 시초에 자신의 토지에 인접한 타인 소유의 토지를 자신 소유의 토지의 일부로 알고서 이를 점유하게 된 자는 나중에 그 토지가 자신 소유의 토지가 아니라는 점을 알게 되었다고 하더라도 그러한 사정만으로 그 점유가 타주점유로 전환되는 것은 아니다(대판 2001. 5. 29, 2001다5913)고 하여 소유의 의사 유무는 점유개시시를 기준으로 판단하고 있다.

- ② 그러나 자주점유로 추정되던 자가 패소확정된 경우에는 판결이 확정된 후부터는 타주점유로 전환된다(대판 2000. 12. 8, 2000다14934).

[비교]

제197조(점유의 태양)

- ① 점유자는 소유의 의사로 선의, 평온 및 공연하게 점유한 것으로 추정한다.
② 선의의 점유자라도 본권에 관한 소에 패소한 때에는 그 소가 제기된 때로부터 악의의 점유자로 본다.

▶ 돌발 퀴즈

자주점유로 추정되던 자가 패소확정된 경우에는 그 소가 제기된 때로부터 타주점유로 전환된다.

⇒ × : 자주점유로 추정되던 자가 패소확정된 경우에는 판결이 확정된 후부터는 타주점유로 전환된다(대판 2000. 12. 8, 2000다14934)

(3) 자주점유의 추정과 번복

① 자주점유의 ‘추정’

- ㉠ 상대방이 타주점유임을 입증책임(대판[전합] 1983. 7. 12, 82다 708-709).

- ㉡ 그 증명을 어느 정도 하여야 자주점유의 추정을 깨뜨릴 수 있는 것인가?

점유자가 성질상 소유의 의사가 없는 것으로 보이는 권원에 바탕을 두고 점유를 취득한 사실이 증명되었거나, 점유자가 타인의 소유권을 배제하여 자기의 소유물처럼 배타적 지배를 행사하는 의사를 가지고 점유하는 것으로 볼 수 없는 객관적 사정, 즉 점유자가 진정한 소유자라면 통상 취하지 아니할 태도를 나타내거나 소유자라면 당연히 취했을 것으로 보이는 행동을 취하지 아니한 경우 등 외형적·객관적으로 보아 점유자가 타인의 소유권을 배척하고 점유할 의사를 갖고 있지 아니하였던 것이라고 볼 만한 사정이 증명된 경우에도 그 추정은 깨어진다(대판[전합] 2000. 3. 16, 97다37661; 대판 2002. 2. 26, 99다72743)

② 추정의 번복

㉠ 점유자가 점유 개시 당시에 소유권 취득의 원인이 될 수 있는 법률행위 기타 법률요건이 없이 그와 같은 법률요건이 없다는 사실을 잘 알면서 타인 소유의 부동산을 무단점유한 것임이 증명된 경우, 특별한 사정이 없는 한 점유자는 타인의 소유권을 배척하고 점유할 의사를 갖고 있지 않다고 보아야 하므로, 이로써 소유의 의사가 있는 점유라는 추정은 깨어진다(대판[전합] 1997. 8. 21, 95다28625 등).

㉔ 그 밖에 판례상 자주점유의 추정이 깨진다고 보는 경우(12)

(i) 주택 부지가 국유라는 사정을 알면서 그 주택을 매수한 경우, 매수인의 그 주택부지에 대한 점유(대판 1998. 3. 13, 97다50169),

(ii) 무허가 건물 부지가 타인의 소유라는 사정을 알면서 그 건물만을 매수한 경우, 그 부지에 대한 점유(대판 1998. 3. 13, 97다55447; 대판 1997. 10. 10, 96다29991),

(iii) 무허가 건물이 난립한 국·공유지 일대의 무허가 건물 부지 점유(대판 1998. 2. 10, 96다679),

(iv) 증여자의 증여행위가 처분권한 없는 자에 의한 처분행위임을 알고 수증을 받은 경우(대판 2005. 5. 12, 2004다63484),

(v) 지방자치단체나 국가가 자신의 부담이나 기부채납 등 지방재정법 또는 국유재산법 등에 정한 공공용 재산의 취득절차를 밟거나 그 소유자들의 사용승낙을 받는 등 토지를 점유할 수 있는 일정한 권원 없이 사유토지를 도로부지에 편입시킨 경우(대판 1998. 5. 29, 97다30349).

(vi) 지방자치단체나 국가가 권원 없이 사유토지를 도로부지에 편입시킨 경우(대판 2010. 2. 25, 2009다84530; 대판 2009. 9. 10, 2009다32553; 대판 2001. 3. 27, 2000다64472 등, 그러나 대판 2008. 3. 27, 2007다78258은 국가가 토지의 취득절차에 관련된 서류를 제출하지 못하고 있다고 하더라도 토지에 관한 지적공부 등이 전란으로 모두 소실된 사정과 국가의 점유용도 및 점유개시의 사정 등에 비추어 국가가 토지를 무단으로 점유하였다는 점이 증명되지 아니한 경우 대한민국의 토지에 대한 자주점유의 추정은 깨지지 않는다고 한다).

(vii) 토지 점유자가 점유기간 동안 여러 차례 부동산소유권이전등기등에관한특별조치법이 시행됨에 따라 등기의 기회가 있었음에도 불구하고 소유권이전등기를 하지 않았고 오히려 소유자가 같은 법에 의하여 소유권보존등기를 마친 후에도 별다른 이의를 하지 않은 경우(대판 2000. 3. 24, 99다56765),

(viii) 주무관청의 허가 없이는 처분할 수 없는 재산임을 알고 한 점유의 경우(대판 1998. 5. 8, 98다2945; 대판 1996. 11. 8, 96다29410; 대판 1995. 11. 24, 94다53341 등),

(ix) 점유자가 건물부지로 점유 중인 토지가 국가 소유임을 안 후 국가에 대하여 매수 요청을 하고, 나아가 스스로 미등기인 당해 토지에 대해 국가 명의로 등기되도록 협조까지 한 경우(대판 1997. 10. 24, 97다32901),

(x) 시효기간 진행 중에 점유하는 국유재산에 관하여 대부계약신청을 하여 관리청과의 사이에 대부계약을 체결한 경우(대판 1998. 6. 23, 98다11758),

(xi) 원고가 그 점유 토지를 자신의 명의로 사정받았다고 주장하였으나 토지조사부의 사정받은 자의 난에는 피고의 이름이 등재되어 있고 달리 원고가 그 점유 당시의 의사에 관하여 아무런 주장·증명도 하지 않은 경우, 그 토지에 대한 원고의 점유(대판 1999. 3. 12, 98다29834)에는 자주점유의 추정이 반복되고 타주점유가 된다. 또한

(xii) 점유자가 건물부지로 점유 중인 국가 소유의 여러 필지의 토지 중 일부 토지를 매입한 경우, 나머지 토지에 대한 점유는 점유 개시 당시부터 타주점유이었거나, 늦어도 일부 토지의 매수신청 당시부터는 타주점유로 봄이 상당하다는 이유로 자주점유의 추정이 반복되었다(대판 1998. 5. 8, 98다1232).

(4) 악의의 무단점유와 자주점유의 추정문제

악의의 무단점유, 즉 점유의 권원이 없으면서(무단), 그리고 권원이 없음을 알면서(악의) 점유한 경우에도 자주점유의 추정이 유지되느냐 아니면 추정이 깨어지느냐가 문제된다. 즉 무단점유에서의 점유를 정당화시키는 법률관계(법률행위 기타 법률요건)의 부존재(즉 객관적 요소의 부존재)에 대한 인식이라는 주관적 요소가 소유의 의사를 반복시킬 수 있는지의 문제이다(점유를 정당화 시키는 법률관계, 즉 권원이 부존재하더라도 소유의 의사가 반복되지 않는다).

1) 대법원 전원합의체 1997. 8. 21, 95다28625

[다수의견]

점유자가 점유 개시 당시에 소유권 취득의 원인이 될 수 있는 법률행위 기타 법률요건이 없이 그와 같은 법률요건이 없다는 사실을 잘 알면서 타인 소유의 부동산을 무단점유한 것임이 증명된 경우, 특별한 사정이 없는 한 점유자는 타인의 소유권을 배척하고 점유할 의사를 갖고 있지 않다고 보아야 할 것이므로 이로써 소유의 의사가 있는 점유라는 추정은 깨어졌다.

2) 학설

이 판결에 대하여 긍정적인 견해도 있으나, 결과에서는 찬성하지만 그 법리에서 부정적인 견해도 유력(타당)하다.

검토 : 법정책적인 측면에서 이 판결의 결론에 동의하지만, 그 법리에서 문제가 있다.

- ① 도둑의 점유가 전형적인 악의의 무단점유인데 이러한 경우도 자주점유로 보아야 할 것인 바, 따라서 악의의 무단점유도 자주점유로 보아야 할 것이다.
- ② 부동산소유권의 일반취득시효의 요건에 “선의”를 추가하는 것이 되어 민법 제245조 제1항에 규정에 반한다.
- ③ 우리 민법이 자주점유와 선의점유를 엄격하게 구별하고 있다는 점(제197조·제202조·제245조·제246조·제252조 제1항)에 비추어 해당 판결은 문제가 있다.

(5) 타주점유의 자주점유로의 전환

- 1) 타주점유가 자주점유로 전환되기 위해서는 타주점유자가 새로운 권원에 기하여 소유의 의사로서 점유를 시작하거나, 또는 타주점유자가 간접점유자에 대하여 소유의 의사가 있음을 표시하여야 한다(통설·대판 1993. 7. 16, 92다3787; 대판 1998. 3. 27, 97다53823). 예를 들어 건물임차인이 매매계약이라는 새로운 권원에 의하여 그 건물을 매수하면 그 때부터 자주점유자가 된다.

2) 상속

부정설(다수설·판례) : 상속에 의하여 피상속인의 지위가 상속인에게 포괄적으로 이전한다고 보아야 하므로 상속 자체는 새로운 권원이라고 볼 수 없다.

2. 하자 있는 점유와 하자 없는 점유

하자 있는 점유는 악의·과실·강박·은닉·不繼續 등 완전한 점유로서의 효력발생을 방해하는 사정이 있는 점유이며, 선의·무과실·평온·공연·계속 등의 사정이 있는 점유가 하자 없는 점유이다.

3. 선의점유와 악의점유

선의점유 : 「점유할 수 있는 권리」, 즉 본권이 없음에도 불구하고 있다고 誤信해서 하는 점유
악의점유 : 본권이 없음을 알거나, 또는 본권의 유무에 대하여 의심을 품으면서 하는 점유

→ 일반적으로 의심을 품는 경우는 선의가 되지만, 점유에 관하여는 본권 있음을 확신한 경우만 선의점유로 인정된다(통설). 의심을 가진 자도 악의로 해석하는 이유는 취득시효·선의취득·과실취득 등에 관하여 선의점유의 효과가 강력한 것이기 때문

→ 선의점유·악의점유의 구별은 본권 없이 점유하는 경우에만 인정되는 구별이다. 왜냐하면 본권을 가진 소유자·전세권자·임차인 등의 점유에 관해서는 선의·악의의 구별이 없다.

4. 과실 있는 점유와 과실 없는 점유

무과실만은 제197조와 같은 규정이 없기 때문에 추정되지 않는 것으로 본다. 따라서 주장자 자신이 무과실임을 증명하여야 한다(통설).

판례도 등기부상의 소유자로부터 부동산을 매수하고 이전등기를 경료한 자이더라도 자기의 점유가 과실이 없는 점유라는 것에 대한 증명책임이 있다고 한다(대판 1964. 11. 30, 64다 882).

5. 단독점유와 공동점유

하나의 물건을 한 사람이 직접점유하는 경우가 단독점유이고, 여러 명이 직접점유하는 경우가 공동점유이다. 그런데 공동점유에서 점유자 각자는 점유보호청구권과 자력구제권을 가진다.

III. 점유권의 득실

1. 원시취득 / 승계취득(특정승계(현실인도·간이인도)·포괄승계(상속))

제193조(상속으로 인한 점유권의 이전) 점유권은 상속인에 이전한다.

Q : 점유권의 상속에도 민법 제199조가 적용되는가? 즉 상속인이 상속재산을 현실적으로 점유하게 된 경우에 그는 피상속인의 점유와 자신의 점유의 병합과 분리를 주장할 수 있는지 문제된다.

- ① 긍정설(다수설) : 상속인이 사실상의 지배를 취득한 때로부터 피상속인의 점유가 하자있는 점유라도 상속인은 하자 없는 점유를 취득한다
- ② 부정설(판례) : 자신만의 고유한 점유를 주장하기 위해서는 별도의 새로운 권원이 존재하여야 한다.

2. 승계취득의 효과

제199조(점유의 승계의 주장과 그 효과)

- ① 점유자의 승계인은 자기의 점유만을 주장하거나 자기의 점유와 전점유자의 점유를 아울러 주장할 수 있다.
- ② 전점유자의 점유를 아울러 주장하는 경우에는 그 하자도 계승한다.

- ① 예를 들어 A가 악의로 6년간, B가 악의로 5년간 점유를 계속한 후에, C가 그 점유를 승계하여 선의로 10년간 점유하였다면 C는 A·B의 악의의 11년간의 점유와 자신의 선의의 10년간의 점유 합계 악의의 21년간의 점유를 주장할 수도 있고, 또는 자신의 선의의 10년간의 점유와 B의 악의의 5년간의 점유 합계 악의의 15년간의 점유를 주장할 수도 있고, 또는 자신의 선의의 10년간의 점유만을 주장할 수도 있다(취득시효에서 점유의 승계는 중요한 의미가 있다).
- ② 그런데 대판 전원합의체 1995. 3. 28, 93다47745는 전 점유자의 점유를 승계한 자는 그 점유 자체와 하자만을 승계하는 것이지 그 점유로 인한 법률효과(가령 시효완성에 따른 등기청구권)까지 승계하는 것은 아니라고 한다.

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 점유매개자의 점유할 권리는 간접점유자의 권리로부터 전래한 것이고, 내용에 있어서 간접점유자의 권리보다 제한된 것이어야 한다.
 - ② 점유매개관계는 중첩적으로 있을 수 있다. 예를 들어 소유자 A가 B에게 소유물을 임대한 후 B가 다시 C에게 전대하면 두개의 점유매개관계가 있게 된다.
 - ③ 간접점유자는 직접점유자에 대하여 점유보호청구권이나 자력구제권을 행사할 수 없다.
 - ④ 직접점유자가 간접점유자의 의사에 반하여 임의로 점유를 타에 양도한 경우에는 간접점유자의 점유가 침탈된 경우에 해당하므로 간접점유자의 점유보호청구권이 인정된다.
 - ⑤ 점유매개관계는 반드시 유효한 것일 필요는 없으므로, 임대차계약이 무효이거나 취소된 경우에도 임차인이 점유를 계속하는 한 간접점유는 그대로 존속한다.
- ④. 판례는 직접점유자가 임의로 점유를 타에 양도한 경우에는 점유이전이 간접점유자의 의사에 반한다 하더라도 간접점유자의 점유가 침탈된 경우에 해당하지 않는다고 하여 이 경우에 간접점유자의 점유보호청구권을 인정하지 않고 있다(대판 1993. 3. 9, 92다5300).

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 소유권취득의 원인이 되는 매매계약이 무효라 하더라도, 실제로 매매계약이 있었던 이상, 매수인은 원칙적으로 자주점유자이다.
- ② 매수인의 점유가 등기를 수반하지 아니한 점유임이 밝혀졌다고 하더라도 타주점유로 볼 수는 없다.
- ③ 취득시효완성 후 점유자가 권리자에 대해 매수를 시도한 사실이 있다면 그러한 사실만으로도 그 후부터는 물론 그전의 점유가 타주점유였다고 볼 수 있다.
- ④ 공유자 1인이 공유토지 전부를 점유하는 경우 다른 공유자의 지분범위 내에서는 타주점유자이다.
- ⑤ 국유지를 장차 불하받을 생각으로 그 점유·사용권만을 양도받아 점유한 자의 점유는 타주점유이다.

- ③. 취득시효완성 후 점유자가 권리자에 대해 매수를 시도한 사실이 있다 하더라도 그러한 사실만으로는 그 후부터는 물론 그전의 점유가 타주점유였다고 단정할 수는 없다(대판[전합] 1983. 7. 12, 82다708).

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 타주점유를 상속으로 승계한 자의 점유도 타주점유이다
 - ② 점유의 시초에 자신의 토지에 인접한 타인 소유의 토지를 자신 소유의 토지의 일부로 알고서 이를 점유하게 된 자는 나중에 그 토지가 자신 소유의 토지가 아니라는 점을 알게 되었다고 하더라도 그러한 사정만으로 그 점유가 타주점유로 전환되는 것은 아니다.
 - ③ 점유자가 점유 개시 당시에 소유권 취득의 원인이 될 수 있는 법률행위 기타 법률요건이 없이 그와 같은 법률요건이 없다는 사실을 잘 알면서 타인 소유의 부동산을 무단점유한 것임이 증명된 경우, 특별한 사정이 없는 한 점유자는 타인의 소유권을 배척하고 점유할 의사를 갖고 있지 않다고 보아야 하므로, 이로써 소유의 의사가 있는 점유라는 추정은 깨어진다.
 - ④ 타주점유가 자주점유로 전환되기 위해서는 타주점유자가 새로운 권원에 기하여 소유의 의사로서 점유를 시작하거나, 또는 타주점유자가 간접점유자에 대하여 소유의 의사가 있음을 표시하여야 한다
 - ⑤ 등기부상의 소유자로부터 부동산을 매수하고 이전등기를 경료한 자는 자기의 점유가 과실이 없는 점유라는 것이 추정되므로, 스스로 과실 없음을 증명할 필요가 없다.
- ⑤. 등기부상의 소유자로부터 부동산을 매수하고 이전등기를 경료한 자이더라도 자기의 점유가 과실이 없는 점유라는 것에 대한 증명책임이 있다(대판 1964. 11. 30, 64다882).

♣ 학습정리

- 1. 간접점유란 일정한 법률관계에 기하여 타인을 매개로 하여 간접적으로 점유하는 것을 말한다.
- 2. 점유자가 점유의 침탈을 당한 경우에 간접점유자는 그 물건을 점유자에게 반환할 것을 청구할 수 있고 점유자가 그 물건의 반환을 받을 수 없거나 이를 원하지 아니하는 때에는 자기에게 반환할 것을 청구할 수 있다.
- 3. 점유자의 점유가 소유의 의사 있는 자주점유인지 아니면 소유의 의사 없는 타주점유인자의 여부는 점유자의 내심의 의사에 의하여 결정되는 것이 아니라 점유취득의 원인이 된 권원의 성질이나 점유와 관계가 있는 모든 사정에 의하여 외형적·객관적으로 판단되어야 한다.
- 4. 점유자가 점유 개시 당시에 소유권 취득의 원인이 될 수 있는 법률행위 기타 법률요건이 없이 그와 같은 법률요건이 없다는 사실을 잘 알면서 타인 소유의 부동산을 무단점유한 것임이 증명된 경우, 특별한 사정이 없는 한 점유자는 타인의 소유권을 배척하고 점유할 의사를 갖고 있지 않다고 보아야 하므로, 이로써 소유의 의사가 있는 점유라는 추정은 깨어진다
- 5. '선의점유'란 「점유할 수 있는 권리」, 즉 본권이 없음에도 불구하고 있다고 誤信해서 하는 점유를 말하고, '악의점유'란 본권이 없음을 알거나, 또는 본권의 유무에 대하여 의심을 품으면서 하는 점유를 말한다.
- 6. 점유자의 승계인은 자기의 점유만을 주장하거나 자기의 점유와 전점유자의 점유를 아울러 주장할 수 있다. 전점유자의 점유를 아울러 주장하는 경우에는 그 하자도 계승한다.

제12강 점유의 효력(1)

♣ 학습목표

1. 점유권의 효력에 대하여 정리할 수 있다.
2. 점유의 추정적 효력을 설명할 수 있다.
3. 점유자와 회복자와의 관계에 대하여 정리할 수 있다.

♣ 학습내용

- 점유의 권리추정적 효력
- 점유자와 회복자와의 관계
- 선의점유자의 과실취득권
- 점유물의 멸실·훼손에 대한 책임

♣ 사전 테스트

1. 간접점유자는 점유권을 가지지 않고, 직접점유자만 점유권을 가진다.
⇒ × : 간접점유자도 점유권을 가지고, 또한 점유매개관계에 기하여 물건에 직접적으로 실력을 행사하는 자(직접점유자)도 점유권을 가진다.
2. 점유자의 점유가 자주점유인지 아니면 타주점유인지의 여부는 점유자의 내심의 의사에 의하여 결정된다.
⇒ × : 점유자의 점유가 소유의 의사 있는 자주점유인지 아니면 소유의 의사 없는 타주점유인자의 여부는 점유자의 내심의 의사에 의하여 결정되는 것이 아니라 점유취득의 원인이 된 권원의 성질이나 점유와 관계가 있는 모든 사정에 의하여 외형적·객관적으로 판단되어야 한다.
3. 전 점유자의 점유를 승계한 자는 그 점유 자체와 하자 뿐만 아니라 그 점유로 인한 법률효과(가령 시효완성에 따른 등기청구권)까지 승계한다.
⇒ × : 대판 전원합의체 1995. 3. 28, 93다47745는 전 점유자의 점유를 승계한 자는 그 점유 자체와 하자만을 승계하는 것이지 그 점유로 인한 법률효과(가령 시효완성에 따른 등기청구권)까지 승계하는 것은 아니라고 한다.

♣ 교안

IV. 점유권의 효력

1. 점유의 추정적 효력(제197조~ 제198조·제200조)
2. 점유자와 회복자와의 관계(제201조- 제203조)
3. 점유보호청구권(제204조·제206조)
4. 자력구제(제209조)

그 밖의 효력으로 불법행위의 성립, 부당이득의 성립 등이 문제될 수 있다.

1. 점유의 권리추정적 효력

진실한 권리관계와 부합할 개연성이 크기 때문

제200조(권리의 적법의 추정)

점유자가 점유물에 대하여 행사하는 권리는 적법하게 보유한 것으로 추정한다.

→ 증명책임의 전환이 이루어짐

- ① 추정이 점유자에게 유리한 지 아니면 불리한지를 묻지 않으며, 제3자도 제200조를 원용가능
- ② 과거의 점유자는 점유기간 중에 적법하게 권리를 보유한 것으로 추정
- ③ 도품이나 유실물 등 점유이탈물의 경우에도 권리의 추정이 미친다(다수설)
- ④ “점유물에 대하여 행사하는 권리” 의미 :
→ 점유하는 것을 정당한 것으로 하는 모든 권리(소유권, 임차권, 수차인의 권리)

- ⑤ 점유추정력의 한계 : 점유권의 승계취득에서 전주에 대해서는 제200조를 원용할 수 없다(다수설·판례) → 증명책임의 일반적인 문제로 해결
(예를 들어 임대인 소유자와 임차인인 점유자 사이에 임차권의 존부에 관하여 다툼이 생긴 경우에, 제200조에 의하여 적법한 임차권의 존재가 추정되지 않으며, 임차인이 임차권의 취득사실을 주장하고 증명하여야 한다)

▶ 돌발 퀴즈

임대인인 소유자와 임차인인 점유자 사이에 임차권의 존부에 관하여 다툼이 생긴 경우에, 제200조에 의하여 적법한 임차권의 존재가 추정된다.

⇒ × : 점유권의 승계취득에서 전주에 대해서는 제200조를 원용할 수 없다(다수설·판례). 따라서 제200조에 의하여 적법한 임차권의 존재가 추정되지 않으며, 임차인이 임차권의 취득사실을 주장하고 증명하여야 한다

2. 점유자와 회복자의 관계

(1) 서설

1) 본권 없이 타인의 물건을 점유하는 자는 본권자가 물권적 청구권을 행사하면, 그에 응하여 점유물을 본권자에게 반환하여야 한다. 이 경우에 점유자와 회복자 사이에는 ① 점유자의 과실수취 여부, ② 점유물의 멸실·훼손에 대한 책임, ③ 비용상환청구 등이 문제된다. 민법은 이 문제를 점유권의 효력으로서 규정하지만 실제로는 소유물반환청구권을 행사하는 경우에 부수적으로 발생하는 법률문제이다(독일민법은 우리의 제201조 내지 제203조에 해당하는 규정들을 소유물반환청구권의 내용으로 규정하고 있다).

2) 점유자가 타인의 물건을 점유하게 된 원인이 임대차·임치 등의 계약관계인 때에는 점유자가 물건을 반환하는 경우에 생기는 위와 같은 법률문제는 그 계약관계의 내용에 의하여 정해진다.

3) 민법 제201조 내지 제203조는 그와 같은 계약관계 없이 타인의 물건을 점유한 경우에 생기는 반환시의 법률관계에 관한 규정으로 선의점유자의 보호를 위하여 둔 규정이다. 왜냐하면 소유권이 있다고 믿고 물건을 사용한 경우에, 그러한 점유자에게 그와 같은 의무나 책임을 지우는 것은 가혹하기 때문이다.

즉 위 규정들은 선의의 점유자에 대하여 과실반환의무를 면제하거나 배상범위를 경감해줌으로써 선의점유자를 보호하기 위한 부당이득에 대한 특칙이다.

4) 부당이득의 효과로서 수익자는 그 받은 이익을 반환하여야 한다(제741조). 그 반환방법에 관하여 민법 제741조 제1항은 수익자가 그 받은 목적물은 반환할 수 없는 때에는 그 가액을 반환하여야 한다고 규정한다. 따라서 원물반환이 원칙이고, 원물반환을 할 수 없는 때에는 예외적으로 그 가액을 반환하여야 한다.

이 때 수익자가 원물반환을 하는 경우는 수익자가 그 원물을 점유하고 있는 때인데, 수익자가 그 원물을 반환하는 관계는 제201조 내지 제203조에서 규정하는 「점유자와 회복자의 관계」와 매우 유사하다. 따라서 이에 관하여 통설은 (i) 민법이 부당이득에 있어서 원물반환에 관한 규정을 구체적으로 두고 있지 않은 점, (ii) 제201조 내지 제203조는 소유권 등 본권에 기한 청구권을 행사하는 것을 전제로 하고 있지만 그것은 실질적으로 부당이득반환청구의 성질을 가진다는 점을 이유로 부당이득을 이유로 선의의 점유자가 원물반환을 하는 경우에는 언제나 제201조 내지 제203조의 규정에 의하여 그 반환범위가 결정된다고 한다. 즉 법률관계의 부존재·무효·취소의 경우에 원물반환에 관하여는 제201조 내지 제203조가 적용된다.

다만 판례(대판 1997. 12. 9, 96다47586; 대판 1998. 12. 23, 98다43175; 대판 2000. 6. 9, 2000다9123)는 해제의 경우에 부당이득반환에 관한 특칙인 제548조를 근거로 제201조 제1항의 적용을 부정한다.

결론

계약관계가 있는 경우 그 계약상의 하자로 해제하는 경우 → 해제

계약관계가 없는 경우 : 소유자의 소유물반환청구에 대응하여

㉠ 선의점유자의 과실수취권(제748조의 특칙)

㉡ 선의점유자의 멸실·훼손에 대한 책임경감(제750조의 특칙)

㉢ 선의·악의점유자의 비용상환청구권

제201조(점유자와 과실)

① 선의의 점유자는 점유물의 과실을 취득한다.

② 악의의 점유자는 수취한 과실을 반환하여야 하며 소비하였거나 과실로 인하여 훼손 또는 수취하지 못한 경우에는 그 과실의 대가를 보상하여야 한다.

③ 전항의 규정은 폭력 또는 은비에 의한 점유자에 준용한다.

(2) 선의점유자의 과실취득권(제748조의 특칙)

1) 의의

① 인정이유 : 과실을 수취할 권리를 가지는 것으로 오신하여 점유하는 자는 과실을 수취하여 소비하는 것이 보통이므로 후에 원물의 반환을 청구당한 경우에 과실 전부를 반환케 하는 것은 가혹

② 과실 : 넓은 의미의 과실로서 천연과실·법정과실도 포함된다. 물건을 사용하여 얻은 이익 즉 사용이익도 과실에 준한다고 해석(통설·대판1987. 7. 9, 86다카1966 / 반대견해 : 천연과실만을 의미하고 법정과실과 사용이익은 제외)

→ 건물을 사용함으로써 얻는 이익은 그 건물의 과실에 준하는 것이므로 선의의 점유자는 비록 법률상 원인 없이 타인의 건물을 점유·사용하고 이로 말미암아 그에게 손해를 입혔다 하더라도 그 점유·사용으로 인한 이익을 반환할 의무를 지지 않는다(대판 1996. 1. 26, 95다44290).

③ 적극적 과실수취권설(다수설·판례 / 반대 : 소비한 과실에 대한 반환의무 면제에 불과)

2) 요건

① 선의점유자 : 과실수취할 본권이 없다는 것을 단순히 알지 못한 것으로는 부족하고 적극적으로 과실수취권이 있다고 오신하여야 한다.(무과실은 규정이 없으므로 요건으로 하지 않음 : 다수설)

(예를 들어 A의 농지를 B의 소유로 잘못 알고 B로부터 농지를 임차하여 점유한 C는 선의의 점유자이다)

② 과실수취할 본권(예 소유권·지상권·임차권) ↔ 지역권·수치인은 없음

③ 점유자가 선의인지 여부는 과실에 대하여 독립한 소유권이 성립하는 시기를 기준으로 판단

악의점유자의 과실반환의무

① 제201조 제2항

② [판례] (대법원 2003. 11. 14. 선고 2001다61869 판결)

타인 소유물을 권원 없이 점유함으로써 얻은 사용이익을 반환하는 경우 민법은 선의 점유자를 보호하기 위하여 제201조 제1항을 두어 선의 점유자에게 과실수취권을 인정함에 대하여, 이러한 보호의 필요성이 없는 악의 점유자에 관하여는 민법 제201조 제2항을 두어 과실수취권이 인정되지 않는다는 취지를 규정하는 것으로 해석되는바, 따라서 악의 수익자가 반환하여야 할 범위는 민법 제748조 제2항에 따라 정하여지는 결과 그는 받은 이익에 이자를 붙여 반환하여야 한다 .

즉, 악의 점유자는 과실을 반환하여야 한다고만 규정한 민법 제201조 제2항이, 민법 제748조 제2항에 의한 악의 수익자의 이자지급의무까지 배제하는 취지는 아니기 때문에, 악의 수익자의 부당이득금 반환범위에 있어서 민법 제201조 제2항이 민법 제748조 제2항의 특칙이라거나 우선적으로 적용되는 관계를 이루는 것은 아니다.

그리고 위 조문에서 규정하는 이자는 당해 침해행위가 없었더라면 원고가 위 임료로부터 통상 얻었을 법정이자상당액을 말하는 것이므로 악의 수익자는 위 이자의 이행지체로 인한 지연손해금도 지급하여야 할 것이다.

③ 선의의 점유자라도 본권에 관한 訴에 패소한 때에는 그 소가 제기된 때로부터 악의의 점유자로 본다(제197조)(구체적으로는 소장부분 송달시부터(즉 익일))

④ 불법행위에 기한 손해배상책임과 경합.

(3) 점유물의 멸실·훼손에 대한 책임(제202조)(선의이고 자주점유자에 대한 제750조의 특칙)

제202조(점유자의 회복자에 대한 책임)

점유물이 점유자의 책임있는 사유로 인하여 멸실 또는 훼손한 때에는 악의의 점유자는 그 손해의 전부를 배상하여야 하며 선의의 점유자는 이익이 현존하는 한도에서 배상하여야 한다. 소유의 의사가 없는 점유자는 선의인 경우에도 손해의 전부를 배상하여야 한다.

- 1) 점유물이 점유자의 책임 있는 사유(자기의 재산에 대한 주의를 게을리 한 것)로 멸실·훼손된 때에는 불법행위가 되어 손해배상책임이 인정된다(제750조).
 → 선의이고 자주점유자에게 가혹 : 현존이익 한도에서 배상
 → 선의이지만 타주점유인 경우, 악의인 경우 : 손해 전부 배상
 → 악의인 경우(자주·타주 불문) : 손해 전부 배상
- 2) 불법행위책임과 경합(다수설·판례)
- 3) 물리적 멸실뿐만 아니라 법률적 멸실(반환불능)도 포함

♣ 확인학습문제

1. 점유의 권리추정적 효력에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 점유자가 점유물에 대하여 행사하는 권리는 적법하게 보유한 것으로 추정한다.
 - ② 추정이 점유자에게 유리한지 아니면 불리한지를 묻지 않으며, 제3자도 제200조를 원용할 수 있다.
 - ③ 과거의 점유자는 점유기간 중에 적법하게 권리를 보유한 것으로 추정한다.
 - ④ 도품이나 유실물 등 점유이탈물의 경우에는 권리의 추정이 미치지 않는다.
 - ⑤ “점유물에 대하여 행사하는 권리”는 ‘점유하는 것을 정당한 것으로 하는 모든 권리(소유권, 임차권, 수차인의 권리)’를 의미한다.
- ④. 도품이나 유실물 등 점유이탈물의 경우에도 권리의 추정이 미친다(다수설).

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 본권 없이 타인의 물건을 점유하는 자는 본권자가 물권적 청구권을 행사하면, 그에 응하여 점유물을 본권자에게 반환하여야 한다.
 - ② 민법 제201조 내지 제203조는 임대차·임치 등의 계약관계 없이 타인의 물건을 점유한 경우에 생기는 반환시의 법률관계에 관한 규정으로 선의점유자의 보호를 위하여 둔 규정이다.
 - ③ 법률관계의 부존재·무효·취소의 경우에 원물반환에 관하여는 제201조 내지 제203조가 적용된다.
 - ④ 해제의 경우에도 제201조 제1항이 적용된다.
 - ⑤ 선의의 점유자는 점유물의 과실을 취득한다.
- ④. 판례(대판 1997. 12. 9, 96다47586; 대판 1998. 12. 23, 98다43175; 대판 2000. 6. 9, 2000다9123)는 해제의 경우에 부당이득반환에 관한 특칙인 제548조를 근거로 제201조 제1항의 적용을 부정한다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 악의의 점유자는 수취한 과실을 반환하여야 하며 소비하였거나 과실로 인하여 훼손 또는 수취하지 못한 경우에는 그 과실의 대가를 보상하여야 한다.
 - ② 선의점유자의 과실취득권에 있어서 과실수취할 본권이 없다는 것을 단순히 알지 못한 것으로는 부족하고 적극적으로 과실수취권이 있다고 오신하여야 한다.
 - ③ 악의 점유자는 과실을 반환하여야 한다고만 규정한 민법 제201조 제2항이, 민법 제748조 제2항에 의한 악의 수익자의 이자지급의무까지 배제하는 취지는 아니다.
 - ④ 점유물이 점유자의 책임있는 사유로 인하여 멸실 또는 훼손한 때에는 악의의 점유자는 그 손해의 전부를 배상하여야 하며 선의의 점유자는 이익이 현존하는 한도에서 배상하여야 한다.
 - ⑤ 점유자의 과실수취권에 있어서 과실은 천연과실을 의미하며, 법정과실이나 사용이익은 제외한다.
- ⑤. 넓은 의미의 과실로서 천연과실·법정과실도 포함된다. 물건을 사용하여 얻은 이익 즉 사용이익도 과실에 준한다(통설·대판1987. 7. 9, 86다카1966).

♣ 학습정리

- 1. 점유자가 점유물에 대하여 행사하는 권리는 적법하게 보유한 것으로 추정한다.
- 2. 선의의 점유자는 점유물의 과실을 취득한다.
- 3. 악의의 점유자는 수취한 과실을 반환하여야 하며 소비하였거나 과실로 인하여 훼손 또는 수취하지 못한 경우에는 그 과실의 대가를 보상하여야 한다.
- 4. 점유물이 점유자의 책임있는 사유로 인하여 멸실 또는 훼손한 때에는 악의의 점유자는 그 손해의 전부를 배상하여야 하며
- 5. 점유물이 점유자의 책임있는 사유로 인하여 멸실 또는 훼손한 때에는 선의의 점유자는 이익이 현존하는 한도에서 배상하여야 한다.
- 6. 점유물이 점유자의 책임있는 사유로 인하여 멸실 또는 훼손한 때에는 소유의 의사가 없는 점유자는 선의인 경우에도 손해의 전부를 배상하여야 한다.

제13강 점유의 효력 (2)

♣ 학습목표

1. 점유자의 비용상환청구권에 대하여 정리할 수 있다.
2. 점유보호청구권 및 자력구제권을 설명할 수 있다.
3. 준점유 제도에 대하여 정리할 수 있다.

♣ 학습내용

- 점유자의 비용상환청구권
- 점유보호청구권
- 자력구제권
- 준점유

♣ 사전 테스트

1. 선의점유자의 과실취득권에 있어서 적극적으로 과실수취권이 있다고 오신할 필요까지는 없고, 과실수취할 본권이 없다는 것을 단순히 알지 못한 것으로 족하다.
⇒ × : 선의점유자의 과실취득권에 있어서 과실수취할 본권이 없다는 것을 단순히 알지 못한 것으로는 부족하고 적극적으로 과실수취권이 있다고 오신하여야 한다.
2. 점유물이 점유자의 책임있는 사유로 인하여 멸실 또는 훼손한 때에는 소유의 의사가 없더라도 선의의 점유자는 이익이 현존하는 한도에서 배상하여야 한다.
⇒ × : 점유물이 점유자의 책임있는 사유로 인하여 멸실 또는 훼손한 때에는 소유의 의사가 없는 점유자는 선의인 경우에도 손해의 전부를 배상하여야 한다.
3. 점유권의 승계취득에서 전소유자에 대하여도 제200조(권리의 적법의 추정)를 원용할 수 있다.
⇒ × : 점유권의 승계취득에서 전소유자에 대하여는 제200조(권리의 적법의 추정)를 원용할 수 없다(다수설·판례).

♣ 강의교안

(4) 점유자의 비용상환청구권(제203조)

제203조(점유자의 상환청구권)

- ① 점유자가 점유물을 반환할 때에는 회복자에 대하여 점유물을 보존하기 위하여 지출한 금액 기타 필요비의 상환을 청구할 수 있다. 그러나 점유자가 과실을 취득한 경우에는 통상의 필요비는 청구하지 못한다.
- ② 점유자가 점유물을 개량하기 위하여 지출한 금액 기타 유익비에 관하여는 그 가액의 증가가 현존한 경우에 한하여 회복자의 선택에 좇아 그 지출금액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다.
- ③ 전항의 경우에 법원은 회복자의 청구에 의하여 상당한 상환기간을 허여할 수 있다.

1) 의의

- ① 점유자와 회복자 사이의 비용상환에 관한 문제는 그들 사이에 의사에 기한 법률관계(예컨대 전세권 제319조, 유치권 제325조, 사용대차 제617조, 임대차 제626조 등)가 존재한다면 그에 의한다(대판 2003. 7. 23, 2001다64752). 그러한 법률관계가 없다면 사무관리나 부당이득의 규정에 의하는 것이 원칙.
- ② 제203조가 점유자의 선의악의 또는 소유의 의사 유무를 구별하지 않고 특별한 부당이득 반환청구권을 규정

2) 요건

① 비용상환청구권자의 요건

㉠ 상환청구권자

현재의 점유자, 즉 소유물반환청구권이 행사될 당시의 점유자가 비용상환을 청구할 수 있다. 불법점유자라도 청구가 가능하다. 다만 불법점유자는 비용상환을 위한 유치권을 행사할 수는 없다.

전점유자가 비용을 지출한 이후 현점유자에게 점유가 승계된 경우에 누가 비용상환을 청구할 수 있는가?

- 전점유자라는 견해 : 비용상환청구권의 양수에 관한 규정이 존재하지 않으므로 현점유자는 전점유자의 비용상환청구권을 행사할 수 없다. 점유를 승계한 자는 점유 자체와 하자만을 승계하는 것이지 점유로 인한 법률효과까지 승계하는 것은 아니라는 판례(대판[전합] 1095.3.28., 93다47745)의 논리에 따른 경우에도 같다.

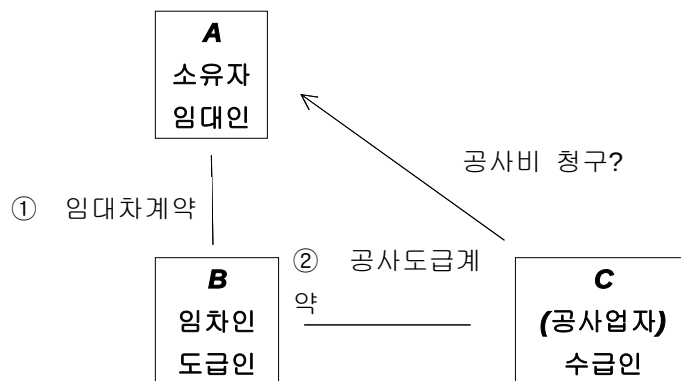
- 현점유자라는 견해 : 비용상환청구권은 물건에 부착되는 성질이 강하고, 전점유자는 자신이 지출한 비용도 고려하여 점유양도시에 대가를 받았을 것이므로 현점유자가 행사할 수 있다.

전용물소권(轉用物訴權, actio de in rem verso)의 문제

Q : 수급인 C가 도급인 B와의 도급계약을 기초로 공사한 것이므로 결과적으로 소유자 A에게도 이득이 되었다는 것을 이유로 A에 대하여 부당이득으로서 직접 공사비(유익비)를 청구할 수 있는가?

-- → 부정(전용물소권 부정; 통설·판례)

유효한 도급계약에 기하여 수급인이 도급인으로부터 제3자 소유 물건의 점유를 이전받아 이를 수리한 결과 그 물건의 가치가 증가한 경우에, 도급인이 그 물건을 간접점유하면서 궁극적으로 자신의 계산으로 비용지출과정을 관리한 것이므로, 도급인만이 소유자에 대한 관계에서 제203조에 의한 비용상환청구권을 행사할 수 있는 비용지출자이고, 수급인은 그러한 비용지출자에 해당하지 않는다(대판 2002. 8. 23, 99다66564·66571).



㉠ 상환청구의 상대방

점유자의 비용지출 후에 소유권이 양도되어 소유자가 교체되었다면 전소유자와 현재의 소유자 중 누가 상환의무를 부담하는지가 문제된다. 이 경우 지출당시의 소유자가 아닌 회복당시의 소유자, 즉 현재의 소유자가 상환청구의 상대방이 된다는 것이 판례의 입장이다(대판 2003. 7. 25, 2001다64752; 대판 1966. 6. 15, 65다598). 이로 인한 양수인인 현재의 소유자의 손해는 원인행위에 기한 채무불이행책임 또는 담보책임에 의하여 전보될 수 있다.

㉡ 비용상환청구권의 발생시기 : 점유물 반환을 청구받은 때

[판례] 대법원 2011.12.13. 선고 2009다5162 판결

점유자가 점유물을 보존하거나 개량하기 위하여 지출한 필요비나 유익비에 관하여 민법 제203조 제1항, 제2항은 '점유자가 점유물을 반환할 때'에 상환을 청구할 수 있도록 규정하고 있으므로, 그 상환청구권은 점유자가 회복자에게서 점유물 반환을 청구받은 때에 비로소 이를 행사할 수 있는 상태가 되고 이행기가 도래한다.

㉔ 비용상환의 범위

- 필요비(제203조 제1항) : 물건의 보존을 위하여 지출한 비용 등 물건 자체에 기여하기 위한 비용(보존비, 수선비, 사육비, 공조공과비 등)
 - 원칙 : 선의, 악의 등 점유의 태양 묻지 않고 반환청구 가능
 - 예외 : 통상의 필요비(통상의 이용상태 유지에 드는 비용)는 점유자가 과실을 취득하거나 물건을 이용한 경우에는 반환청구할 수 없음(제203조 제1항 단서)
- 유익비(제203조 제2항) : 점유물을 개량하기 위해서 지출한 금액 등 물건의 가치를 증대케 하는 비용
 - 요건 : 가액의 증가가 현존해야(지출한 비용의 결과가 부합한 경우에 한하여 문제된다)
 - 내용 : 지출금액과 현존하는 가치증가액 중 회복자가 선택 가능

㉕ 점유자의 유치권

필요비나 유익비의 상환청구권은 물건에 관하여 생긴 채권이기 때문에, 점유자의 유치권이 발생할 수 있다. 다만 제203조 제3항에 의하여 법원으로부터 상당한 상환기간을 허여받은 경우 유치권을 행사할 수 없다.

유치권은 그 점유가 “불법행위로 인한 경우”에는 그 유치권이 발생하지 않으므로, 점유할 권리가 없음을 알면서 또는 과실로 알지 못한 채 물건을 점유하기에 이른 자는 유치권을 취득하지 못한다.

3. 점유의 보호 (점유보호청구권 및 자력구제권)

(1) 점유보호청구권 서설

제204조(점유의 회수)

- ① 점유자가 점유의 침탈을 당한 때에는 그 물건의 반환 및 손해의 배상을 청구할 수 있다.
- ② 전항의 청구권은 침탈자의 특별승계인에 대하여는 행사하지 못한다. 그러나 승계인이 악의인 때에는 그러하지 아니하다.
- ③ 제1항의 청구권은 침탈을 당한 날로부터 1년 내에 행사하여야 한다.

제205조(점유의 보유)

- ① 점유자가 점유의 방해를 받은 때에는 그 방해의 제거 및 손해의 배상을 청구할 수 있다.
- ② 전항의 청구권은 방해가 종료한 날로부터 1년 내에 행사하여야 한다.
- ③ 공사로 인하여 점유의 방해를 받은 경우에는 공사착수 후 1년을 경과하거나 그 공사가 완성한 때에는 방해의 제거를 청구하지 못한다.

제206조(점유의 보전)

- ① 점유자가 점유의 방해 받을 염려가 있는 때에는 그 방해의 예방 또는 손해배상의 담보를 청구할 수 있다.
- ② 공사로 인하여 점유의 방해 받을 염려가 있는 경우에는 전조 제3항의 규정을 준용한다.

본권 유무와는 관계없이 사실적 지배를 보호하기 위한 일종의 물권적 청구권

① 청구권자 : 직접점유자 ○ / 간접점유자 ○ / 점유보조자 X

② 상대방 : 현재 점유를 침해하는 상태에 있는 자

(A(소유자) → B(침탈자) → C(선의 특별승계인) → D(악의 승계인))

: A는 D에게 점유회수청구권을 행사할 수 없다. 왜냐하면 C에 의하여 점유침탈의 교란상태는 종료되었다.)

다만 손해배상청구의 상대방은 스스로 손해를 발생케 한 자만이고 그의 특별승계인은 상대방으로 될 수 없다.(불법행위 손해배상책임의 성질)

③ 점유자의 자력구제와의 관계 : 점유침탈의 경우에 침탈자의 새로운 지배상태가 확립되지 않고 평화교란 상태가 “계속되는 동안”에는 점유보호청구권과 점유자의 자력구제권(제209조)이 모두 인정된다. 그러나 점유의 침탈로 인하여 사실상의 지배상태가 침탈자에게 “옮겨가게 되면” 침탈자의 점유가 성립되어 피해자는 점유보호청구권만 행사할 수 있다(대판 1993. 3. 26, 91다14116). 점유보호청구권과 자력구제는 상호 보완적으로 점유를 보호하고 있다.

(2) 점유회수청구권(점유물반환청구권)

① 침탈 : 점유자의 의사에 기하지 않은 채 점유 상실

위법한 강제집행에 의하여 점유를 빼앗은 것도 점유침탈에 해당된다.

그러나 사기에 의하여 점유를 이전한 것과 같이 의사에 의한 경우나 직접점유자가 임의로 점유를 타에 양도한 경우는 해당되지 않는다.

직접점유자가 임의로 점유를 타에 양도한 경우에는 점유이전이 간접점유자의 의사에 반한다 하더라도 간접점유자의 점유가 침탈된 경우에 해당하지 않는다(대판 1993. 3. 9, 92다5300).

점유침탈자의 고의·과실은 요건이 아니므로 정당하게 인도청구할 수 있는 자에 의한 점유침탈 이더라도 점유회수청구권을 행사할 수 있다.

※ 상호침탈의 문제

부정설(다수설) : B의 반환청구를 인정하더라도 A가 다시 반환청구할 수 있게 되어 소송상 불경제이기 때문

② 점유회수청구의 내용은 물건 자체의 인도(매각대금 자체 X)

손해배상은 물건을 계속 점유하면서 얻을 수 있는 이익(사용이익)을 기준으로 산정

- ③ 1년의 제척기간 (따라서 재판상 또는 재판외 가능) : 판례는 제척기간을 일반적으로 재판상 또는 재판외 권리행사기간으로 새기나 제204조의 경우 출소기간으로 본다.

- ④ 손해배상 : 고의·과실 요함

(3) 점유보유청구권(점유물방해제거청구권)

- ① 방해의 제거 및/또는 손해배상

- 점유에 대한 방해 : 물건 자체에 대한 사실상의 지배상태를 침탈 이외의 방법으로 점유를 방해하는 것이다(대판 1987. 6. 9, 86다카2942). 즉 침탈의 경우에는 점유를 상실하지만 방해의 경우에는 점유자가 점유를 상실하지 않는다.

- ② 손해배상 : 고의·과실 요함

- ③ 1년의 제척기간 : '방해가 종료한 날로부터'이므로 방해제거청구가 아닌 손해배상청구에만 관련된다. 공사로 인한 점유방해의 경우 공사착수후 1년이 경과하거나 공사가 완성된 때에는 방해제거청구를 할 수 없다.

(4) 점유보전청구권(점유물방해예방청구권)

- ① 방해의 예방(작위·부작위) 또는 손해배상의 담보

(방해를 일으킬 염려가 있는 공사의 중지 등)

- 구체적 사정 하에서 사회통념에 따라 객관적으로 판단된 방해의 염려가 있어야 한다(대판 1987.6.9., 86다카2942).

- ② 손해배상의 담보 : 방해의 염려가 있는 한 고의·과실 불요

단 그 담보로부터 실제로 손해배상을 받기 위해서는 상대방의 고의나 과실이 있어야 함.

(5) 점유의 소와 본권의 소

제208조(점유의 소와 본권의 소와의 관계)

- ① 점유권에 기한 소와 본권에 기한 소는 서로 영향을 미치지 아니한다.
② 점유권에 기한 소는 본권에 관한 이유로 재판하지 못한다.

- ① 점유보호청구권에 기한 소를 점유의 소라고 하며, 소유권·전세권·임차권 등의 점유할 수 있는 권리에 기한 소를 본권의 소라고 한다.

② 점유의 소와 본권의 소는 동일한 이익을 목적으로 하지만, 청구원인을 달리하므로, 즉 그 기초를 달리하고 별개의 목적을 가지므로 서로 영향을 미치지 않는다.

③ 점유를 침탈당한 본권자는 본권의 소와 점유의 소를 동시에 제기하거나 양소를 선택적으로 병합할 수 있으며, 어느 한 청구에 대하여 패소한 후에 다른 청구를 하여도 된다.

④ 점유의 소는 본권에 관한 이유로 재판하지 못하므로, 점유자의 점유를 침탈한 자가 소유자이더라도 점유의 소에서 본권에 기한 항변을 제출하지 못한다. 다만 점유의 소에 패소하더라도 소유물반환청구소송의 승소로써 있어야 할 상태로 회복할 수 있다.

소유자의 본권의 소와 점유자의 점유의 소가 각각 승소로 확정되었다면, 최종적으로 본권의 소에서 승소한 소유자가 보호받게 된다.

(6) 자력구제권

제209조(자력구제)

① 점유자는 그 점유를 부정히 침탈 또는 방해하는 행위에 대하여 자력으로써 이를 방위할 수 있다.

② 점유물이 침탈되었을 경우에 부동산일 때에는 점유자는 침탈후 즉시 가해자를 배제하여 이를 탈환할 수 있고 동산일 때에는 점유자는 현장에서 또는 추적하여 가해자로부터 이를 탈환할 수 있다.

【----- 점유평화상태교란상태-----】

자력방위권 -----> 자력탈환권 -----> 점유보호청구권

점유의 침탈 부동산 : 침탈 후 “즉시” 점유평화상태교란 종료

또는 방해행위 계속 동안 동 산 : “현장에서 또는 추적하여”

① 제209조 요건 충족된 경우 : 위법성 조각, 탈환시 점유권이 상실되지 않은 것으로 봄.

② 간점점유자에게는 자력구제권을 인정할 필요가 없을 것이나, 점유보조자는 자력구제권자로 인정할 수 있을 것이다.

[판례] 직시의 의미 및 자력탈환의 한계

민법 제209조 제1항에 규정된 점유자의 자력방위권은 점유의 침탈 또는 방해의 위험이 있는 때에 인정되는 것인 한편, 제2항에 규정된 점유자의 자력탈환권은 점유가 침탈되었을 때 시간적으로 좁게 제한된 범위 내에서 자력으로 점유를 회복할 수 있다는 것으로서, 위 규정에서 말하는 “즉시”란 “객관적으로 가능한 한 신속히” 또는 “사회관념상 가해자를 배제하여 점유를 회복하는 데 필요하다고 인정되는 범위 안에서 되도록 속히”라는 뜻으로 해석할 것이므로 점유자가 침탈사실을 알고 모르고와는 관계없이 침탈을 당한 후 상당한 시간이 흘렀다면 자력탈환권을 행사할 수 없다(대판 1993. 3. 26, 91다14116).

▶ 돌발 퀴즈

점유보조자에게는 자력구제권을 인정할 필요가 없을 것이나, 간점점유자는 자력구제권자로 인정할 수 있을 것이다.

→ × : 간점점유자에게는 자력구제권을 인정할 필요가 없을 것이나, 점유보조자는 자력구제권자로 인정할 수 있을 것이다.

V. 준점유

제210조(준점유) 본장의 규정은 재산권을 사실상 행사하는 경우에 준용한다.

1. 서설

물건이 아닌 「재산권」을 「사실상 행사」하는 경우

2. 준점유의 요건

(1) 준점유의 객체

점유를 수반하는 재산권에는 준점유가 성립할 여지가 없으므로 준점유의 객체가 되는 재산권은 점유를 수반하지 않는 재산권에 한한다.

따라서 소유권·지상권·전세권·유치권·질권·임치권 등은 점유에 의한 보호가 가능하므로 준점유의 대상이 아니고, 재산권에 한하므로 신분권은 준점유의 객체가 아니다.

→ 결국 준점유가 인정되는 재산권은 물권(저당권·지역권), 채권(채권증서를 소지하고 있는 경우·예금증서와 인장을 소지한 경우), 지식재산권(특허권·실용신안권·디자인권·상표권·저작권 등), 형성권(취소권·해제권), 물권에 준하는 권리(광업권·어업권·환매권)이다.

(2) 재산권의 사실상 행사

준점유는 재산권을 사실상 행사하여야 성립한다. 즉 점유를 수반하지 않는 재산권이 사실상 어떤 사람에게 귀속하는 것과 같은 외관을 가져야 한다. 따라서 채권증서를 소지하거나 은행의 예금증서와 인장을 소지하고 있으면 채권의 준점유가 인정되고, 표현상속인이 피상속인의 재산 일반에 관하여 외견상 상속한 것으로 보이고 상속재산에 채권이 포함된 경우와 같이 사회관념상 인정된 경우라면 준점유가 성립한다.

3. 준점유의 효과

준점유에 관하여는 점유에 관한 규정이 준용된다(제201조). 준점유를 기초로 하여 준점유권이 성립하고, 그 효과로서 권리의 추정·비용상환·점유보호청구권·과실수취권 등이 인정된다.

변제수령의 권한이 없는 자에게 변제한 것은 무효임이 원칙이나(제742조), 민법은 거래안전의 보호를 위하여 특칙으로 채무자가 선의·무과실로 채권의 준점유자에게 변제한 경우에는 그 변제의 효력을 인정하고 있다(제470조).

그러나 선의취득의 규정(제249조 이하)은 동산점유의 공신력 혹은 동산소유권의 취득에 관한 규정이므로 이것을 준점유에 준용할 수 없다. 예를 들어 무권리자로부터 정기에금증서를 양수하더라도 양수인은 보호되지 않는다.

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 점유자가 점유물을 반환할 때에는 회복자에 대하여 점유물을 보존하기 위하여 지출한 금액 기타 필요비의 상환을 청구할 수 있다. 그러나 점유자가 과실을 취득한 경우에는 통상의 필요비는 청구하지 못한다.
 - ② 점유자가 점유물을 개량하기 위하여 지출한 금액 기타 유익비에 관하여는 그 가액의 증가가 현존한 경우에 한하여 회복자의 선택에 좇아 그 지출금액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다.
 - ③ 위 ②의 경우에 법원은 회복자의 청구에 의하여 상당한 상환기간을 허여할 수 있다.
 - ④ 점유자의 비용지출 후에 소유권이 양도되어 소유자가 교체되었다면 회복당시의 소유자, 즉 현재의 소유자가 아닌 지출당시의 소유자가 상환청구의 상대방이 된다.
 - ⑤ 점유자가 점유물을 보존하거나 개량하기 위하여 지출한 필요비나 유익비에 관하여 민법 제 203조 제1항, 제2항은 ‘점유자가 점유물을 반환할 때’에 상환을 청구할 수 있도록 규정하고 있으므로, 그 상환청구권은 점유자가 회복자에게서 점유물 반환을 청구받은 때에 비로소 이를 행사할 수 있는 상태가 되고 이행기가 도래한다.
- ④. 점유자의 비용지출 후에 소유권이 양도되어 소유자가 교체되었다면 전소유자와 현재의 소유자 중 누가 상환의무를 부담하는지가 문제된다. 이 경우 지출당시의 소유자가 아닌 회복당시의 소유자, 즉 현재의 소유자가 상환청구의 상대방이 된다(대판 2003. 7. 25, 2001다64752; 대판 1966. 6. 15, 65다598).

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 점유자가 점유의 방해 받은 때에는 그 방해의 제거 및 손해의 배상을 청구할 수 있다.
 - ② 위 ①의 청구권은 방해가 종료한 날로부터 1년 내에 행사하여야 한다.
 - ③ 공사로 인하여 점유의 방해를 받은 경우에는 공사착수 후 1년을 경과하거나 그 공사가 완성한 때에는 방해의 제거를 청구하지 못한다.
 - ④ 위 ①의 “점유의 방해”란 물건 자체에 대한 사실상의 지배상태를 침탈하는 등의 방법으로 점유를 방해하는 것이다.
 - ⑤ 위 ①의 손해배상에는 고의·과실을 요한다.
- ④. 물건 자체에 대한 사실상의 지배상태를 침탈 이외의 방법으로 점유를 방해하는 것이다(대판 1987. 6. 9, 86다카2942). 즉 침탈의 경우에는 점유를 상실하지만 방해의 경우에는 점유자가 점유를 상실하지 않는다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 점유권에 기인한 소와 본권에 기인한 소는 서로 영향을 미치지 아니한다.
 - ② 점유권에 기인한 소는 본권에 관한 이유로 재판하지 못한다.
 - ③ 소유자의 본권의 소와 점유자의 점유의 소가 각각 승소로 확정되었다면, 최종적으로 본권의 소에서 승소한 소유자가 보호받게 된다.
 - ④ 점유의 소는 본권에 관한 이유로 재판하지 못하므로, 점유자의 점유를 침탈한 자가 소유자이더라도 점유의 소에서 본권에 기한 항변을 제출하지 못한다.
 - ⑤ 점유를 침탈당한 본권자는 본권의 소와 점유의 소를 동시에 제기하거나 양소를 선택적으로 병합할 수 있으나, 어느 한 청구에 대하여 패소한 후에 다른 청구를 할 수 없다.
- ⑤. 점유를 침탈당한 본권자는 본권의 소와 점유의 소를 동시에 제기하거나 양소를 선택적으로 병합할 수 있으며, 어느 한 청구에 대하여 패소한 후에 다른 청구를 하여도 된다.

♣ 학습정리

- 1. 점유자는 회복자에 대하여 필요비의 상환을 청구할 수 있고, 유익비에 관하여는 그 가액의 증가가 현존한 경우에 한하여 회복자의 선택에 좇아 그 지출금액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다.
- 2. 점유자는 점유물반환청구권, 점유물방해제거청구권, 점유물방해예방청구권을 가진다.
- 3. 점유권에 기인한 소와 본권에 기인한 소는 서로 영향을 미치지 아니하고, 점유권에 기인한 소는 본권에 관한 이유로 재판하지 못한다.
- 4. 점유자는 그 점유를 부정히 침탈 또는 방해하는 행위에 대하여 자력으로써 이를 방위할 수 있다.
- 5. 준점유의 객체가 되는 재산권은 점유를 수반하지 않는 재산권에 한한다.

제14강 소유권 서설, 부동산소유권의 범위

♣ 학습목표

1. 소유권의 내용과 법적 성질을 정리할 수 있다.
2. 토지소유권의 범위를 설명할 수 있다.
3. 민법상 상린관계를 정리할 수 있다.

♣ 학습내용

- 소유권의 내용과 법적 성질
- 토지소유권의 범위
- 민법상 상린관계 규정
- 생활방해의 금지
- 주위토지통행권

♣ 사전 테스트

1. 점유자가 과실을 취득한 경우에는 통상의 필요비만 청구할 수 있다.
⇒ × : 점유자가 과실을 취득한 경우에는 통상의 필요비는 청구하지 못한다(제203조 제1항 단서).
2. 점유물반환청구권은 침탈자의 특별승계인에 대하여는 그 승계인이 악의인 경우에도 행사하지 못한다.
⇒ × : 점유물반환청구권은 침탈자의 특별승계인에 대하여는 행사하지 못한다. 그러나 승계인이 악의인 때에는 그러하지 아니하다(제204조 제2항).
3. 공사로 인하여 점유의 방해를 받은 경우에는 공사착수 후 1년을 경과하거나 그 공사가 완성한 때에도 방해의 제거를 청구할 수 있다.
⇒ × : 공사로 인하여 점유의 방해를 받은 경우에는 공사착수 후 1년을 경과하거나 그 공사가 완성한 때에는 방해의 제거를 청구하지 못한다(제205조 제3항).

♣ 강의교안

제2절 소유권

I. 총설

소유권의 내용

제211조(소유권의 내용)

소유자는 법률의 범위내에서 그 소유물을 사용, 수익, 처분할 권리가 있다.

- ① 사용·수익 : 물건의 사용가치를 파악하는 것(물건의 이용, 과실의 수취)
- ② 처분 : 물건의 교환가치를 파악하는 것(법률적 처분(양도, 담보권 설정)/ 사실적 처분(소비, 개조))
 - 제211조는 단순히 소유권의 내용을 밝히는 선언적 규정에 그치는 것이 아니라, 소유권이 침해되는 경우 물권적 청구권, 손해배상청구권으로 보호된다는 것을 의미
 - 소유자가 처분권을 수여한 경우, 소유자에게는 처분권이 존재하지 않는다고 하면 처분권 없는 소유권이라는 물권을 창출하는 것이 된다. 따라서 처분수권이 이루어진 경우에도 제3자의 처분이 실제로 유효하게 행하여지지 않고 있는 동안에는 소유자가 가지는 처분권능에 제한을 받지 아니한다(대판 2014.3.13., 2009다105215).

2. 소유권의 법적 성질

- 사실적 지배로서의 점유권과는 달리, 사실적 지배와는 무관한 관념적 지배권
- 전면성·포괄성 : 사용가치, 교환가치 전부에 대하여 전면적으로 작용
- 혼일성 : 용익권능, 처분권능의 단순한 총화가 아니라 융화되어 그 근거가 됨
- 탄력성 : 제한물권이 소멸하면 본래의 전면적 지배로 복귀
- 항구성 : 존속기간의 정함이 없음

II. 토지소유권의 범위

“토지”에 관하여 규정하고 있음

제212조(토지소유권의 범위)

토지의 소유권은 정당한 이익 있는 범위 내에서 토지의 상하에 미친다.

1. 토지 상·하의 범위

- (1) 정당한 이익 : 토지소유권은 사람이 지배할 수 있는 한도 내에서 지표면은 물론이고 지상과 지하에도 미치는 것으로 볼 것이다(대판 1961. 10. 19, 4293민상204) → 지배가능성 → 물건의 범위 결정과 동일 → 구체적 거래관념에 따라 객관적으로 결정

[판례] 토지소유자가 전선소유자로부터 부당이득반환을 받을 수 있는 범위

[1] 토지의 상공에 고압전선이 통과함으로써 토지소유자가 그 토지 상공의 이용을 제한받는 경우, 그 토지소유자는 위 전선을 소유하는 자에게 이용이 제한되는 상공 부분에 대한 임료 상당액의 부당이득금 반환을 구할 수 있고, 이 때 고압전선이 통과하고 있는 상공 부분과 관계 법령에서 고압전선과 건조물 사이에 일정한 거리를 유지하도록 규정하고 있는 경우 그 거리 내의 상공 부분은 토지소유자의 이용이 제한되고 있다고 볼 수 있다.

[2] 고압전선의 경우 양쪽의 철탑으로부터 아래로 늘어져 있어 강풍 등이 부는 경우에 양쪽으로 움직이는 횡진현상이 발생할 수 있는데, 그 최대횡진거리 내의 상공 부분은 횡진현상이 발생할 가능성이 있는 것에 불과하므로 일반적으로는 토지소유자가 그 이용에 제한을 받고 있다고 볼 수 없으나, 최대횡진거리 내의 상공 부분이라도 토지소유자의 이용이 제한되고 있다고 볼 특별한 사정이 있는 경우에는 그 토지소유자는 고압전선의 소유자에게 그 부분에 대한 임료 상당액의 부당이득금 반환을 구할 수 있다(대판 2009. 1. 15, 2007다58544).

- (2) 토지 소유권의 범위와 관련된 것

지하수·온천수 : 토지의 구성부분(독립된 소유권의 객체(물건) 아님)

미채굴의 광물 : 국가소유권의 객체라는 견해

토지소유권의 객체지만 광업권, 조광권 등 국가의 배타적인 채굴취득허가권의 객체- 이영준

2. 토지소유권의 경계

- (1) 원칙 : 토지소유권의 범위는 현실의 경계와 관계없이 지적공부상의 경계에 의해 확정되는 것이 원칙이다(대판 1993. 4. 13, 92다52887).

[판례] 토지 경계

가. 지적도상의 경계표시가 분할측량의 잘못 등으로 사실상의 경계와 다르게 표시되었다 하여도 그 매매당사자가 지적공부에 의하여 소유권의 범위가 확정된 토지를 매매할 의사가 아니고 사실상의 경계대로의 토지를 매매할 의사를 가지고 매매한 사실이 인정되는 등 특별한 사정이 없는 한 사실상의 경계에 관계없이 지적공부에 기재된 지번, 지목, 지적 및 경계에 의하여 소유권의 범위가 확정된 토지를 매매한 것으로 보아야 할 것이다.

나. 매매당사자가 토지의 실제 경계가 지적공부상의 경계와 상이한 것을 모르는 상태에서 실제의 경계를 대지의 경계로 알고 매매하였다고 하여 매매당사자들이 지적공부상의 경계를 떠나 현실의 경계에 따라 매매목적물을 특정하여 매매한 것이라고 볼 수 없다.(대판 1993. 5. 11, 92다48918·48925)

- (2) 예외 : 지적도 작성상 기점을 잘못 선택하는 등의 기술적 착오가 있는 경우 -> 당사자 간에 사실상의 경계대로의 토지를 매매할 의사가 있다면 실제의 경계로 함(대판 1994. 4. 23, 95다54761).

III. 상린관계(제216조- 제244조)

1. 서설

(1) 적용범위

소유권에 관한 규정 → 인접하는 토지소유자 상호간의 “이용” 조절 규정 → 지상권(제290조), 전세권(제319조)에 준용 → 토지의 임대차 유추적용

토지의 불법점유자는 상린관계 주장 불가(대판 1976. 10. 26, 76다1694)

(2) 규정의 성격

임의규정이라는 견해

강행규정이라는 견해

판례 제242조와 제244조는 임의규정으로 보고 있음

2. 인지사용청구권(제216조 제1항·제2항)

제216조(인지사용청구권)

- ① 토지소유자는 경계나 그 근방에서 담 또는 건물을 축조하거나 수선하기 위하여 필요한 범위내에서 이웃 토지의 사용을 청구할 수 있다. 그러나 이웃 사람의 승낙이 없으면 그 주거에 들어가지 못한다.
- ② 전항의 경우에 이웃 사람이 손해를 받은 때에는 보상을 청구할 수 있다.

3. 생활방해의 금지(immission, nuisance, troubles devorsinage)

제217조(매연 등에 의한 인지에 대한 방해금지)

- ① 토지소유자는 매연, 열기체, 액체, 음향, 진동 기타 이에 유사한 것으로 이웃 토지의 사용을 방해하거나 이웃 거주자의 생활에 고통을 주지 아니하도록 적당한 조치를 할 의무가 있다.
- ② 이웃 거주자는 전항의 사태가 이웃 토지의 통상의 용도에 적당한 것인 때에는 이를 인용할 의무가 있다.

(1) 기타 이에 유사한 것 : 불가량적인 것이라는 견해도 있고 토지이용과 불가피하게 결합된 간섭이라는 견해도 있다. 예를 들어 가스, 악취, 먼지 등이 공기 또는 대지를 통하여(지표를 흐르는 것이나 땅속에 스며드는 것은 이에 해당하지 않는다 : 다수설) 자연적으로 전파방산되는 것. 광선을 벽으로 막는 것과 같은 소극적 방해, 영안실의 존재와 같이 정신적·관념적으로 영향을 주는 것은 생활방해가 아니다.

(2) 한계로서 수인한도(제2항) : 가해자가 수인한도 내의 것임을 증명

통상의 용도에 적당한 것인가의 여부는 토지의 주위상황(예컨대 공업지역·주택지 등)과 토지소유자의 주관적 사정이 아닌 객관적인 평균인을 표준으로 하여 사회통념에 의하여 판단하여야 한다.

인근 고속도로에서 유입되는 소음으로 인하여 입은 환경 등 생활이익의 침해를 이유로 일정 한도를 초과하는 소음이 유입되지 않도록 하라는 내용의 유지청구 소송에서 그 침해가 사회통념상 일반적으로 수인할 정도를 넘어서는지의 여부는 피해의 성질 및 정도, 피해이익의 공공성, 가해행위의 태양, 가해행위의 공공성, 가해자의 방지조치 또는 손해회피의 가능성, 인·허가 관계 등 공법상 기준에의 적합 여부, 지역성, 토지이용의 선후관계 등 모든 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대판 2007. 6. 15, 2004다37904·37911; 대판 1999. 7. 27, 98다47528 참조)

(3) 효과

① 적당한 조치 : 생활방해를 막는데 적당한 모든 조치로서 피해자는 소유권 기타의 물권에 의한 물권적 청구권인 방해제거청구권, 방해예방청구권을 행사할 수 있다.

[판례] 헌법 제35조의 환경권과의 관계 → 헌법상 기본권의 대사인적 효력

① 환경권은 명문의 법률규정이나 관계 법령의 규정 취지 및 조리에 비추어 권리의 주체, 대상, 내용, 행사 방법 등이 구체적으로 정립될 수 있어야만 인정되는 것이므로, 사법상의 권리로서의 환경권을 인정하는 명문의 규정이 없는데도 환경권에 기하여 직접 방해배제청구권을 인정할 수 없다(대판 1997. 7. 22, 96다56153; 대판 1995. 9. 15, 95다23378; 대결 1995. 5. 23, 94마2218).

② 환경권은 명문의 법률규정이나 관계 법령의 규정 취지 및 조리에 비추어 권리의 주체, 대상, 내용, 행사 방법 등이 구체적으로 정립될 수 있어야만 인정되는 것이므로(대법원 1995. 5. 23.자 94마2218 결정 참조), 사법상의 권리로서의 환경권을 인정하는 명문의 규정이 없는데도 환경권에 기하여 직접 방해배제청구권을 인정할 수는 없다 할 것이다.

그러나, 어느 토지나 건물의 소유자가 종전부터 향유하고 있던 경관이나 조망, 조용하고 쾌적한 종교적 환경 등이 그에게 하나의 생활이익으로서의 가치를 가지고 있다고 객관적으로 인정된다면 법적인 보호의 대상이 될 수 있는 것이므로, 인접 대지 위에 건물의 건축 등으로 그와 같은 생활이익이 침해되고 그 침해가 사회통념상 일반적으로 수인할 정도를 넘어서는다고 인정되는 경우에는 위 토지 등의 소유자는 그 소유권에 기하여 건물의 건축 금지 등 방해의 제거나

예방을 위하여 필요한 청구를 할 수 있다고 할 것이고(대법원 1995. 9. 15. 선고 95다23378 판결 참조), 위와 같은 청구를 하기 위한 요건으로서 반드시 위 건물이 문화재보호법이나 건축법 등의 관계 규정에 위반하여 건축되거나 또는 그 건축으로 인하여 그 토지 안에 있는 문화재 등에 대하여 직접적인 침해가 있거나 그 우려가 있을 것을 요하는 것은 아니라고 할 것이다.(대판 1999. 7. 27, 98다47528. 원고봉은사 v. 윤봉빌딩 16층부터 19층공사금지청구).

② 불법행위에 기한 손해배상청구권(위자료 포함)

- 일조권

건물의 신축으로 인하여 그 이웃 토지상의 거주자가 직사광선이 차단되는 불이익을 받은 경우에 그 신축 행위가 정당한 권리행사로서의 범위를 벗어나 사법상 위법한 가해행위로 평가되기 위해서는 그 일조방해의 정도가 사회통념상 일반적으로 인용하는 수인한도를 넘어야 하고, 일조방해행위가 사회통념상 수인한도를 넘었는지 여부는 피해의 정도, 피해이익의 성질 및 그에 대한 사회적 평가, 가해건물의 용도, 지역성, 토지이용의 선후관계, 가해 방지 및 피해 회피의 가능성, 공법적 규제의 위반 여부, 교섭 경과 등 모든 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 12. 10. 선고 2000다72213 판결, 2004. 10. 28. 선고 2002다63565 판결 등 참조).

일조이익을 향유할 수 있는 자는 토지소유자, 건물소유자, 지상권자, 전세군자 또는 임차인 등 거주자를 말하며, 당해 토지·건물을 일시적으로 이용하는 것에 불과한 자는 해당되지 않는다(대판 2008.12.24., 2008다41499 판결).

- 조망권 : 조망이익이 법적인 보호의 대상이 되기 위한 요건

어느 토지나 건물의 소유자가 종전부터 향유하고 있던 경관이나 조망이 그에게 하나의 생활 이익으로서의 가치를 가지고 있다고 객관적으로 인정된다면 법적인 보호의 대상이 될 수 있는 것인바, 이와 같은 조망이익은 원칙적으로 특정의 장소가 그 장소로부터 외부로 조망함에 있어 특별한 가치(필자 주 : ①객관적 조망가치)를 가지고 있고, 그와 같은 조망이익의 향유를 하나의 중요한 목적(필자 주 : ②주관적 조망목적)으로 하여 그 장소에 건물이 건축된 경우와 같이 당해 건물의 소유자나 점유자가 그 건물로부터 향유하는 조망이익이 사회통념상 독자의 이익으로 승인되어야 할 정도로 중요성(필자 주 : ③사회적 승인)을 갖는다고 인정되는 경우에 비로소 법적인 보호의 대상이 되는 것이고, 그와 같은 정도에 이르지 못하는 조망이익의 경우에는 특별한 사정이 없는 한 법적인 보호의 대상이 될 수 없다(대판 2007.6.28. 선고 2004다54282).

4. 수도 등의 시설권(제218조)

제218조(수도 등 시설권)

- ① 토지소유자는 타인의 토지를 통과하지 아니하면 필요한 수도, 소수관, 가스관, 전선 등을 시설할 수 없거나 과다한 비용을 요하는 경우에는 타인의 토지를 통과하여 이를 시설할 수 있다. 그러나 이로 인한 손해가 가장 적은 장소와 방법을 선택하여 이를 시설할 것이며 타토지의 소유자의 요청에 의하여 손해를 보상하여야 한다.
- ② 전항에 의한 시설을 한 후 사정의 변경이 있는 때에는 타토지의 소유자는 그 시설의 변경을 청구할 수 있다. 시설변경의 비용은 토지소유자가 부담한다.

5. 주위토지통행권(제219조·제220조)

제219조(주위토지통행권)

- ① 어느 토지와 공로사이에 그 토지의 용도에 필요한 통로가 없는 경우에 그 토지소유자는 주위의 토지를 통행 또는 통로로 하지 아니하면 공로에 출입할 수 없거나 과다한 비용을 요하는 때에는 그 주위의 토지를 통행할 수 있고 필요한 경우에는 통로를 개설할 수 있다. 그러나 이로 인한 손해가 가장 적은 장소와 방법을 선택하여야 한다.
- ② 전항의 통행권자는 통행지소유자의 손해를 보상하여야 한다.

제220조(분할, 일부양도와 주위통행권) → 무상통행권(무상주위토지통행권)

- ① 분할로 인하여 공로에 통하지 못하는 토지가 있는 때에는 그 토지소유자는 공로에 출입하기 위하여 다른 분할자의 토지를 통행할 수 있다. 이 경우에는 보상의 의무가 없다.
- ② 전항의 규정은 토지소유자가 그 토지의 일부를 양도한 경우에 준용한다.

(1) 의 의

1) 주위토지통행권이 인정되는 경우

- ① 어느 토지와 公路 사이에 그 토지의 용도에 필요한 통로가 없는 경우에, 그 토지소유자는 주위의 토지를 통행 또는 통로로 하지 아니하면 공로에 출입할 수 없거나,
- ② 과다한 비용을 요하는 때에는 그 주위의 토지를 통행할 수 있고, 필요한 경우에는 통로를 개설할 수 있다(제219조 제1항).

이미 그 소유 토지의 용도에 필요한 통로가 있는 경우에는 그 통로를 사용하는 것보다 더 편리하다는 이유만으로 다른 장소로 통행할 권리는 인정할 수 없지만(대판 1995. 6. 13, 95다1088·95다1095), 이미 기존의 통로가 있더라도 그것이 당해 토지의 이용에 부적합하여 실제로 통로로서의 충분한 기능을 하지 못하고 있는 경우에도 주위토지통행권을 인정하고 있다(대판 2003. 8. 19, 2002다53469; 대판 1994. 6. 24, 94다14193; 대판 1992. 3. 31, 92다1025).

그러나 토지소유자 자신이 그 토지와 공로 사이의 통로를 막는 건물을 축조한 경우에는 타인 소유의 주위토지를 통행할 권리가 생긴다고 할 수 없다(대판 2006. 6. 2, 2005다70144; 대판 1972 1. 31, 71다2113). 따라서 비록 주위토지통행권이 인정되고 있던 중 통행지 위에 연립주택이 건축된 경우, 공로로 통할 수 있는 다른 인접 토지가 있다면 별도의 통행로 개설 비용이 들더라도 연립주택 단지 내의 주거의 평온과 안전에 대한 침해를 최소화하여야 하므로 기존 통행로에 대한 주위토지통행권은 인정되지 않는다(대판 2009. 6. 11, 2008다75300·75317·75324).

- 2) 여기서 공로라 함은 일반인이 통행하고 있는 통로로서 私道를 포함한다. 통로가 없는 경우란 다른 토지에 둘러싸인 경우는 물론, 池沿·하천·해양 등을 이용하지 않고서는 외부에 나갈 수 없는 경우, 또는 험한 낭떠러지가 있어서 그 토지와 공로가 심하게 고저를 이루는 경우도 포함된다(구민법 제210조 제2항).

[판례] 제219조의 취지를 확장한 판결

토지소유자의 적법한 건축행위가 인접 민간지상파방송사업자의 방송을 위한 전파송신에 영향을 미친 경우 민간지상파방송사업자로서는 그 비용부담 하에 그 인접의 토지소유자 등의 손해가 가장 적은 장소와 방법을 선택하여 인접 토지상에 건축된 건축물에 방송 송신에 필요한 시설을 설치할 수 있고, 인접 토지소유자 등은 이를 용인할 의무가 있다(대판 2003. 11. 28, 2003다43322).

(2) 법적 성질

1) 법정의 물건적 청구권

주위토지통행권은 상린관계규정에 의해 발생하는 토지사용권으로 등기나 토지소유자의 승낙을 필요로 하지 않는 법정의 물건적 청구권이다. 즉 포위된 토지의 이용의 확보를 위하여 그 소유권에 기한 물건적 청구권의 확장이라고 할 수 있다. 따라서 주위토지통행권자가 통행지의 소유자 이외의 제3자를 상대로 통행권의 확인 및 방해금지 청구를 할 수 있다(대판 2005. 7. 14, 2003다18661).

약정통행권 → 채권적 청구권/ 통행지역권(등기필요)
법정통행권(주위토지 통행권)

2) 소극적 권리

주위토지통행권은 통행의 수인을 청구하는데 불과한 소극적 권리라고 할 수 있다. 따라서 통행지 소유자는 통로개설 등 적극적인 작위의무를 부담하지 않는다. 다만 통행에 방해가 되는 담장 등 축조물을 설치한 경우에는 주위토지통행권의 본래적 기능발휘를 위하여 철거의무를 부담하고, 그 담장이 비록 당초에는 적법하게 설치되었던 것이라 하더라도 그 철거의 의무에는 영향이 없다(대판 1990. 11. 13, 90다5238; 대판 2006. 10. 26. 2005다30993).

(3) 통행방법과 손해의 보상

1) 주위토지통행권을 주장할 수 있는 자의 범위

- ① 통행권은 토지소유자뿐만 아니라 지상권자·전세권자에게도 인정된다(제280조·제319조에 의한 제219조의 준용). 토지사용권을 가진 자에게 인정되는 권리이므로 명의신탁자에게는 인정되지 아니한다. 비록 명의신탁자가 토지에 관하여 개발행위허가를 받았거나 전소유자가 주위토지의 전소유자로부터 통행로에 해당하는 부분에 대한 사용승낙을 받은 적이 있다는 등의 사정으로는 현소유자에게 대항할 수 없다(대판 2008. 5. 8, 2007다22767).
- ② 토지의 불법점유자는 토지소유권의 상린관계로서 주위토지통행권의 주장이나 통행지역권의 시효취득 주장을 할 수 없다(대판 1976. 10. 29, 76다1694).
- ③ 일부양도의 경우 종전 소유자의 토지에만 인정된다. 즉 동일인 소유의 토지의 일부가 양도되어 공로에 통하지 못하는 토지가 생긴 경우에 포위된 토지를 위한 주위토지통행권은 일부양도 전의 양도인 소유의 종전 토지에 대하여만 생기고 다른 사람 소유의 토지에 대하여는 인정되지 아니한다(대판 2005. 3. 10, 2004다65589·65596).

2) 통행방법과 손해의 보상

- ① 다른 토지를 통행하거나, 또는 통로를 개설할 때 통행권자는 통행지 또는 통로개설지에 가장 손해가 적은 장소와 방법을 선택하여야 한다(제219조 제1항 단서). 모래를 깔거나, 돌계단을 조성하거나, 장애가 되는 나무를 제거하는 등의 방법으로 통로를 개설할 수 있으며 통행지 소유자의 이익을 해하지 않는다면 통로를 포장하는 것도 허용된다(대판 2003. 8. 19, 2002다53469).
- ② 통행권자는 통행지소유자의 손해를 보상하여야 한다(제219조 제2항). 보상금의 지급은 일시에 하든 정기적으로 하든 상관없다. 지급을 지체하여도 통행권은 소멸하는 것이 아니고 다만 채무불이행책임이 생길 뿐이다. 손해보상 의무는 통행권자에게 있는 것이므로 통행권자의 허락을 얻어 사실상 통행하고 있는 자는 보상의무가 없다(대판 1991. 9. 10, 91다19623).

3) 통로개설과 유지비용부담자

주위토지통행권자는 주위토지통행권이 인정되는 때에도 그 통로개설이나 유지비용을 부담하여야 한다(대판 2006. 10. 26, 2005다30993).

(4) 주위토지통행권의 범위

1) 주위토지통행권의 범위와 판단기준

사회통념에 비추어 쌍방토지의 지형과 위치 및 이용관계, 부근의 지리상황, 상린지이용자의 이해득실 기타 제반사정을 참작한 후 구체적 상황에 따라 판단한다. 따라서 자동차 등도 통과할 수 있는 통로의 개설도 허용되지만, 토지이용의 편의를 위해서 다소 필요한 상태라고 여겨지는 정도에 그치는 경우에는 자동차의 통행을 허용할 수 없다(대판 2006. 6. 2, 2005다70144).

2) 사정변경에 의하여 통행방법이 변경

사정변경에 의하여 통행방법이 변경될 수 있다. 즉 주위토지통행권은 통행을 위한 지역권과는 달리 그 통행로가 항상 특정한 장소로 고정되어 있는 것은 아니고 주위 토지 소유자가 그 용법에 따라 기존 통행로로 이용되던 토지 사용방법을 바꾸었을 때(예컨대, 그 지상에 건축물의 축조 등)에는 대지소유자는 그 주위 토지 소유자를 위하여 보다 손해가 적은 다른 장소로 옮겨 통행할 수밖에 없는 경우도 있을 것이다(대판 1989. 5. 23, 88다카10739-10746).

3) 기존통행로가 있더라도 주위토지통행권 발생 가능

이미 기존의 통로가 있더라도 그것이 당해 토지의 이용에 부적합하여 실제로 통로로서의 충분한 기능을 하지 못하고 있는 경우에는 인정된다(대판 2003. 8. 19, 2002다53469). 그러나 일단 주위토지통행권이 발생하였다고 하더라도 나중에 그 토지에 접하는 공로가 개설됨으로써 주위토지통행권을 인정할 필요성이 없어진 때에는 그 통행권은 소멸한다(대판 2009. 6. 11, 2008다75300-75317-75324; 대판 2005. 7. 14, 2003다18661; 대판 1998. 3. 10, 97다47118). 그리고 일단의 토지를 형성하고 있던 동일인 소유의 수필의 토지 중 일부가 양도된 경우, 일부 양도전의 양도인 소유의 종전 토지에 대하여 무상의 주위토지통행권이 인정되는 이상 제3자 소유의 토지에 대하여는 민법 제219조에 따른 주위토지통행권을 주장할 수 없다(대판 2005. 3. 10, 2004다65589-65596).

4) 배타적 점유 부정

통행권이 인정되더라도 통행권자는 통행지를 배타적으로 점유할 수는 없다. 따라서 통행권자가 배타적으로 점유하고 있다면 통행지 소유자는 그 인도를 청구할 수 있다(대판 1993. 8. 24, 93다25479; 대판 1980. 4. 8, 79다1460; 대판 1977. 4. 26, 76다2823). 반면에 통행권자가 배타적인 점유를 하고 있지 않다면 통행지 소유자 통로 부분의 인도를 구하거나 그 통로에 설치된 시설물의 철거를 구할 수 없다(대판 2003. 8. 19, 2002다53469).

5) 장래의 이용상황을 위한 주위토지통행권 부정

주위토지통행권은 현재의 토지의 용법에 따른 이용의 범위에서 인정되는 것이며, 장래의 이용상황을 미리 보장하는 것이 아니다(대판 1996. 11. 29, 96다33433). 따라서 위요지소유자에게 장래 그 토지에 건축을 할 것에 대비하여 건축허가에 필요한 폭의 통행로를 미리 보장하고 주위토지소유자로 하여금 이를 수인하도록 할 수는 없다(대판 1991. 5. 28, 91다9961-9978).

(5) 분할, 일부양도와 주위통행권(무상통행권)

1) 본래는 포위되지 않았던 토지가 분할 또는 일부양도로 인하여 공로에 통하지 못하는 토지로 된 때에는 그 토지 소유자는 다른 분할자 또는 양수인의 토지만을 통행할 수 있고 제3자의 토지를 통행하지는 못한다(제220조 제1항 제1문·제2항). 이 경우에는 보상의무가 없다(제220조 제1항2문·2항).

이러한 무상의 통행권이 인정되는 이유는 분할 또는 양도당사자가 분할 또는 일부양도로 인하여 자기의 토지가 통행될 것임을 예견할 수 있었기 때문이다. 여기에서의 토지의 일부양도에는 1필의 토지의 일부가 양도된 경우뿐만 아니라 일단으로 되어 있던 동일인 소유의 수필의 토지 중 일부가 양도된 경우도 포함된다(대판 2005. 3. 10, 2004다65589-65596; 대판 1995. 2. 10, 94다45869-45876). 따라서 일단의 토지를 형성하고 있던 동일인 소유의 수필의 토지 중 일부가 양도된 경우, 일부 양도 전의 양도인 소유의 종전 토지에 대하여 무상의 주위토지통행권이 인정되는 이상 제3자 소유의 토지에 대하여는 민법 제219조에 따른 주위토지통행권을 주장할 수 없다(대판 2005. 3. 10, 2004다65589-65596).

2) 무상통행권은 원칙적으로 직접 분할 당사자나 일부양도의 당사자 사이에서만 적용된다(통설·판례). 즉 피포위지의 특정승계인에 대하여는 무상통행권이 인정되지 않는다. 판례도 무상주위토지통행권에 관한 민법 제220조의 규정은 토지의 직접 분할자 또는 일부양도의 당사자 사이에만 적용되고 포위된 토지 또는 피통행지의 특정승계인에게는 적용되지 않는다(대판 1994. 12. 2, 93다45268 등), 이러한 법리는 분할자 또는 일부양도의 당사자가 무상주위토지통행권에 기하여 이미 통로를 개설해 놓은 다음 특정승계가 이루어진 경우라 하더라도 마찬가지라 할 것이라고 한다(대판 2002. 5. 31, 2002다9202). 따라서 포위된 토지 또는 피통행지의 특정승계인의 경우에는 주위토지통행권에 관한 일반원칙으로 돌아가 그 통행권의 범위를 따로 정하여야 한다(대판 1996. 11. 29, 96다33433-33440).

3) 무상토지통행권의 부담이 있음을 알면서 통행지를 매수한 자는 이를 수인할 의무를 진다. 즉 토지의 원소유자가 토지를 분할·매각함에 있어서 토지의 일부를 분할된 다른 토지의 통행로

로 제공하여 독점적·배타적인 사용수익권을 포기하고 그에 따라 다른 분할토지의 소유자들이 그 토지를 무상으로 통행하게 된 후에 그 통행로 부분에 사용·수익의 제한이라는 부담이 있다는 “사정을 알면서” 그 토지의 소유권을 승계취득한 자는, 다른 특별한 사정이 없는 한 원칙적으로 그 토지에 대한 독점적·배타적 사용수익을 주장할 만한 정당한 이익을 갖지 않는다는 것이어서 원소유자와 마찬가지로 분할토지의 소유자들의 무상통행을 수인하여야 할 의무를 진다(대판 1998. 3. 10, 97다47118).

그리고 토지소유자가 토지를 매수할 때 통로 부분은 주위의 토지 소유자들을 위해 무상으로 통행에 제공된 사실을 용인하고 그 상태에서 이를 매수한 것이라고 봄이 상당한 경우라면 통로 주위대지를 매수한 이래 줄곧 통로 부분을 무상으로 통행해 온 주위대지 소유자에 대하여 단지 통로의 소유자라는 이유만으로 통행료를 청구하는 것은 신의칙에 위배되어 허용될 수 없다(대판 1992. 2. 11, 91다40399).

[사례]

A는 1필의 토지를 2개로 분필하고 도로에 접한 甲지를 B에게 도로에 접하지 않은 乙지를 C에게 동시에 분양하였다. 그 후 甲지는 B로부터 D에게로, 乙지는 C로부터 E에게로 각각 전매되었다. 乙지에 건물을 신축하려는 E는 D에게 건축에 필요한 통로의 개설을 위하여 무상의 통행을 요구할 수 있는가?

I. 주위토지통행권의 일반론

II. 분할과 주위통행권

1. 토지가 분필되어 동시에 모두 양도된 경우에도 그 양수인 사이에 무상통행권 인정여부
2. 무상통행권의 부담은 해당 토지의 특정승계인에게도 승계되는지 여부

토지의 분할 등으로 공로의 출입이 막힌 경우에는, 다른 분할자의 토지나 양도당사자의 토지를 통행할 수 있고, 이 경우 보상의무는 없다(제220조). 왜냐하면 분할·양도당사자가 분할·일부양도로 인하여 자기의 토지가 통행될 것임을 예견할 수 있었기 때문이다.

그러나 토지가 분할되어 동시에 모두 양도된 경우에도 그 양수인 사이에는 무상통행권이 인정되는지가 문제되는데, 이에 관하여 판례는 제220조 제2항에 의하여 무상통행권이 공유토지의 직접분할자 상호간 또는 일부양도의 당사자, 즉 본래의 토지소유자와 일부양수인 사이에서만 인정되는 것으로 해석한다. 이에 반하여 학설은 1필의 토지가 분필되어 동시에 양도된 경우에도 본래는 1필의 토지였으므로 그 토지의 일부에 이미 통로가 확보되었을 것이라는 일방 양수인의 신뢰를 보호할 필요가 있고, 분필된 토지의 타방 양수인은 무상통행권의 부담을 고려하여 그 토지의 가격을 정함이 일반적이라고 한다. 또한 이 경우에 무상통행권의 부담은 해당 토지의 특정승계인에게도 승계되는지가 문제되는데, 이에 관하여 학설은 통행지의 특정승계인이 무상통행권의 부담을 알고 당해 토지의 가격을 정하였을 때에만 무상통행권의 부담을 승계한다고 한다. 그러나 판례는 해당 토지가 특정승계인에게 양도되면 무상통행권의 부담은 소멸하고 제219조의 일반원칙이 적용된다고 한다.

위 사례에서 판례의 태도를 따른다면 E는 D에게 공로의 통행에 대하여 무상제공을 요구할 수 없게 된다.

▶ 돌발 퀴즈

주위토지통행권자는 통행지의 소유자 이외의 제3자를 상대로 통행권의 확인 및 방해금지 청구를 할 수 없다.

⇒ × : 주위토지통행권자가 통행지의 소유자 이외의 제3자를 상대로 통행권의 확인 및 방해금지 청구를 할 수 있다(대판 2005. 7. 14, 2003다18661).

6. 물에 관한 상린관계

(1) 자연적 배수

물이 자연적으로 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르는 경우에 저지의 소유자는 이를 인용할 의무가 있다(제221조 제1항).

자연히 흘러내리는 물이 저지의 소유자에게 필요한 것인 경우에, 고지의 소유자는 자기의 정당한 사용범위를 넘어 흘러내리는 물을 막지 못한다(동조 제2항).

(2) 인공적 배수

물을 인공적인 시설에 의하여 타인의 토지에 버리는 것은 원칙적으로 금지되고, 처마물이 이웃 토지에 떨어지는 때에 직접 떨어지지 않도록 적당한 시설을 해야 한다(제225조).

그리고 토지소유자가 저수, 배수 또는 인수를 하기 위해서 설치한 공작물이 파손 또는 폐쇄로 인하여 다른 토지에 손해를 가하거나 가할 염려가 있는 경우에, 다른 토지의 소유자는 공작물설치자의 비용으로(다른 관습이 없는 한), 그 공작물을 보수, 폐쇄의 소통 또는 예방에 필요한 조치를 청구할 수 있다(제223조, 제224조).

다만 고지의 소유자는 침수지를 말리기 위해서 또는 가용이나 농,공업용의 여수를 소통하기 위해서 공로, 공류 또는 하수도에 이르기 까지 저지에 물을 통과시킬 수 있다(제226조). 그리고 토지소유자는 그 소유지의 물을 소통시키기 위해서 고지 또는 저지의 소유자가 설치한 공작물을 사용할 수 있다(제227조).

(3) 여수급여청구권

토지소유자는 과다한 비용이나 노력을 요하지 않고는 가용이나 토지이용에 필요한 물을 얻기 곤란한 경우에 이웃 토지의 소유자에게 여수의 급여를 청구할 수 있다. 다만 그 손해를 보상해야 한다(제228조).

(4) 유수의 이용권

(가) 수류지(하상)의 소유권이 사인에게 속하고 유수를 흐르는 채로 사용하는 경우

구거(도랑)의 기타 수류의 양쪽 언덕(양안)의 토지가 동일인에게 속하는 경우에, 토지소유자가 수로 및 수류의 폭을 변경할 수 있다. 그러나 하류에서는 자연의 수로와 일치하도록 하여야 한다(제229조 제2항). 반면 양안의 토지가 동일인에게 속하지 않는 때에는 한쪽 언덕의 소유자는 그 수로나 폭을 변경할 수 없다(동조 제1항).

수류지의 소유자가 독을 설치할 필요가 있는 때에는 그 독을 대안(수류의 맞은쪽 언덕)에 접촉하게 할 수 있다(제230조 제1항). 대안의 소유자는 수류지의 일부가 그 소유에 속하는 경우에 그 독을 사용할 수 있다. 그러나 그 이익을 받는 비율로 독의 설치 및 보존의 비용을 부담해야 한다(동조 제2항).

(나) 공유하천의 물을 수류지 외의 토지로 끌어다 사용하는 경우

공유하천의 연안에서 농, 공업을 영위하는 자는 이에 이용하기 위하여 타인의 용수를 방해하지 않는 범위 내에서 필요한 인수를 할 수 있다(제231조 제1항). 그러한 인수를 위해서 필요한 공작물(가령 보)을 설치할 수 있다(동조 제2항). 다만 인수 또는 공작물로 하류연안의 용수권을 방해하는 때에는 그 하류연안의 용수권자는 방해의 제거 및 손해의 배상을 청구할 수 있다(제232조).

공유하천용수권자가 수로 기타 공작물을 양도하면, 그 특별승계인은 전주의 용수에 관한 권리의무를 승계한다(제233조).

(5) 지하수용수권

상린자는 그 공용에 속하는 원천(예 : 공동으로 사용하는 우물)이나 수도를 각 수요의 정도에 따라 타인의 용수를 방해하지 않는 범위 내에서 각각 용수할 권리를 갖는다(제235조).

필요한 용도나 수익이 있는 원천 또는 수도가 타인의 건축 기타 공사로 인하여 단수나 감수 기타 용도에 장애가 생긴 때에는 용수권자는 손해배상을 청구할 수 있고, 특히 그 공사로 인하여 “음료수 기타 생활상 필요한 용수”에 장애가 발생되면 원상회복을 청구할 수 있다(제236조).

7. 경계에 관한 상린관계

(1) 경계표 및 담에 관한 법률관계

서로 인접하는 토지의 소유자는 다른 관습이 없는 한 공동비용으로 통상의 경계표나 담을 설치할 수 있다(제237조). 그러므로 어느 한쪽 토지의 소유자가 담의 설치에 협력할 것을 청구하면 다른 토지의 소유자는 이에 응하여야 한다.

한편 인지소유자는 자기의 비용으로 담의 재료를 통상의 것보다 양호한 것으로 하거나 높이를 높게 할 수 있고, 방화벽 기타 특수시설을 할 수 있다(제238조).

경계에 설치된 경계표, 담, 구거 등의 소유관계를 계약으로 정할 수 있으나, 민법은 상린자의 공유로 추정한다(제239조 본문). 그러나 그것이 어느 한쪽 토지의 소유자의 단독비용으로 설치되었다면 비용지출자의 소유로 되고, 담이 건물의 일부인 경우에 건물소유자의 소유에 속한다(동조 단서).

(2) 수목, 수근의 제거

인접지의 수목의 가지가 경계를 넘은 경우에 그 소유자에 대하여 가지의 제거를 청구할 수 있고, 상대방이 이에 응하지 않으면 청구자 자신이 제거할 수 있다(제240조 제1항, 제2항). 한편 인접지의 수목의 뿌리가 경계를 넘은 경우에는 상린자가 이를 임의로 제거할 수 있다(동조 제3항).

8. 공작물설치에 관한 상린관계

(1) 토지의 침굴금지

토지소유자는 이웃토지의 지반이 붕괴할 정도로 자기의 토지를 깊이 파서는 안된다. 다만 충분한 방어공사를 한다면 그렇지 아니하다(제241조).

(2) 경계선 부근의 건축

건물을 축조하는 경우 특별한 관습이 있는 경우를 제외하고 경계선으로부터 반 미터 이상의 거리를 두어야 한다(제242조 제1항). 이를 위반한 자에 대하여 건물의 변경이나 철거를 청구할 수 있지만, 건축 착수 후 1년을 경과하거나 건물이 완성된 후에는 손해배상만을 청구할 수 있다(제242조 제2항).

(3) 차면시설의무

경계로부터 2미터 이내의 거리에서 이웃 주택의 내부를 관망할 수 있는 창이나 마루를 설치하는 경우에는 적당한 차면시설을 하여야 한다(제243조).

(4) 지하시설 등에 대한 제한

우물을 파거나 용수, 하수 또는 오물 등을 저지할 지하시설을 하는 때에는 경계로부터 2미터 이상의 거리를 두어야 하며 저수지, 구거 또는 지하실 공사에는 경계로부터 그 깊이의 반 이상의 거리를 두어야 한다(제244조 제1항). 이러한 공사를 함에는토사가 붕괴하거나 하수 또는 오액이 이웃에 흐르지 아니하도록 적당한 조치를 하여야 한다(제244조 제2항).

※ 상린관계 규정 중에서 관습이 우선적으로 적용되도록 한 것

제222조의 소통공사권

제223조의 저수 등을 위한 공작물 공사청구권

제229조의 수류의 변경

제231조의 공유하천 용수권

제232조의 하류연안 용수권 보호

제233조의 용수권 승계

제237조의 경계표, 담의 설치권

제242조의 경계선 부근 건축

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 소유자가 제3자에게 처분권을 수여한 경우, 그 제3자의 처분이 실제로 유효하게 행하여지지 않고 있는 동안에도 소유자가 가지는 처분권능은 제한을 받는다.
- ② 소유권은 전면성, 포괄성, 혼일성, 탄력성, 항구성 등의 법적 성질을 가진다.
- ③ 토지소유권은 사람이 지배할 수 있는 한도 내에서 지표면은 물론이고 지상과 지하에도 미치는 것으로 볼 것이다.
- ④ 토지소유권의 범위는 현실의 경계와 관계없이 지적공부상의 경계에 의해 확정되는 것이 원칙이다.
- ⑤ 토지소유자는 경계나 그 근방에서 담 또는 건물을 축조하거나 수선하기 위하여 필요한 범위 내에서 이웃 토지의 사용을 청구할 수 있으나, 이웃 사람의 승낙이 없으면 그 주거에 들어가지 못한다.

- ①. 소유자가 처분권을 수여한 경우, 소유자에게는 처분권이 존재하지 않는다고 하면 처분권 없는 소유권이라는 물권을 창출하는 것이 된다. 따라서 처분수권이 이루어진 경우에도 제3자의 처분이 실제로 유효하게 행하여지지 않고 있는 동안에는 소유자가 가지는 처분권능에 제한을 받지 아니한다(대판 2014.3.13., 2009다105215).

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 어느 토지나 건물의 소유자가 종전부터 향유하고 있던 경관이나 조망, 조용하고 쾌적한 종교적 환경 등이 그에게 하나의 생활이익으로서의 가치를 가지고 있다고 객관적으로 인정된다면 법적인 보호의 대상이 될 수 있는 것이므로, 인접 대지 위에 건물의 건축 등으로 그와 같은 생활이익이 침해되고 그 침해가 사회통념상 일반적으로 수인할 정도를 넘어선다고 인정되는 경우에는 위 토지 등의 소유자는 그 소유권에 기하여 건물의 건축 금지 등 방해의 제거나 예방을 위하여 필요한 청구를 할 수 있다.
- ② 위 ①과 같은 청구를 하기 위한 요건으로서 반드시 위 건물이 문화재보호법이나 건축법 등의 관계 규정에 위반하여 건축되거나 또는 그 건축으로 인하여 그 토지 안에 있는 문화재 등에 대하여 직접적인 침해가 있거나 그 우려가 있을 것을 요한다고 할 것이다.
- ③ 건물의 신축으로 인하여 그 이웃 토지상의 거주자가 직사광선이 차단되는 불이익을 받은 경우에 그 신축 행위가 정당한 권리행사로서의 범위를 벗어나 사법상 위법한 가해행위로 평가되기 위해서는 그 일조방해의 정도가 사회통념상 일반적으로 인용하는 수인한도를 넘어야 하고, 일조방해행위가 사회통념상 수인한도를 넘었는지 여부는 피해의 정도, 피해이익의 성질 및 그에 대한 사회적 평가, 가해건물의 용도, 지역성, 토지이용의 선후관계, 가해 방지 및 피해 회피의 가능성, 공법적 규제의 위반 여부, 교섭 경과 등 모든 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.
- ④ 일조이익을 향유할 수 있는 자는 토지소유자, 건물소유자, 지상권자, 전세군자 또는 임차인 등 거주자를 말하며, 당해 토지·건물을 일시적으로 이용하는 것에 불과한 자는 해당되지 않는다.
- ⑤ 어느 토지나 건물의 소유자가 종전부터 향유하고 있던 경관이나 조망이 그에게 하나의 생활이익으로서의 가치를 가지고 있다고 객관적으로 인정된다면 법적인 보호의 대상이 될 수 있는 것인바, 이와 같은 조망이익은 원칙적으로 특정의 장소가 그 장소로부터 외부로 조망함에 있어 특별한 가치를 가지고 있고, 그와 같은 조망이익의 향유를 하나의 중요한 목적으로 하여 그 장소에 건물이 건축된 경우와 같이 당해 건물의 소유자나 점유자가 그 건물로부터 향유하는 조망이익이 사회통념상 독자의 이익으로 승인되어야 할 정도로 중요성을 갖는다고 인정되는 경우에 비로소 법적인 보호의 대상이 되는 것이고, 그와 같은 정도에 이르지 못하는 조망이익의 경우에는 특별한 사정이 없는 한 법적인 보호의 대상이 될 수 없다.
- ②. 반드시 건물이 문화재보호법이나 건축법 등의 관계 규정에 위반하여 건축되거나 또는 그 건축으로 인하여 그 토지 안에 있는 문화재 등에 대하여 직접적인 침해가 있거나 그 우려가 있을 것을 요하는 것은 아니라고 할 것이다.(대판 1999. 7. 27, 98다47528).

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 어느 토지와 공로사이에 그 토지의 용도에 필요한 통로가 없는 경우에 그 토지소유자는 주위의 토지를 통행 또는 통로로 하지 아니하면 공로에 출입할 수 없거나 과다한 비용을 요하는 때에는 그 주위의 토지를 통행할 수 있고 필요한 경우에는 통로를 개설할 수 있다.
- ② 위 ①의 경우 손해가 가장 적은 장소와 방법을 선택하여야 한다.

- ③ 위 ①의 통행권자는 통행지소유자의 손해를 보상하여야 한다.
 - ④ 분할로 인하여 공로에 통하지 못하는 토지가 있는 때에는 그 토지소유자는 공로에 출입하기 위하여 다른 분할자의 토지를 통행할 수 있다.
 - ⑤ 위 ④의 통행권자는 통행지소유자의 손해를 보상하여야 한다.
- ⑤. 분할로 인하여 공로에 통하지 못하는 토지가 있는 때에는 그 토지소유자는 공로에 출입하기 위하여 다른 분할자의 토지를 통행할 수 있다. 이 경우에는 보상의 의무가 없다(제220조 제1항).

♣ 학습정리

1. 토지소유권은 사람이 지배할 수 있는 한도 내에서 지표면은 물론이고 지상과 지하에도 미치는 것으로 볼 것이다
2. 토지소유자는 매연, 열기체, 액체, 음향, 진동 기타 이에 유사한 것으로 이웃 토지의 사용을 방해하거나 이웃 거주자의 생활에 고통을 주지 아니하도록 적당한 조치를 할 의무가 있고, 이웃 거주자는 이러한 사태가 이웃 토지의 통상의 용도에 적당한 것인 때에는 이를 인용할 의무가 있다.
3. 어느 토지와 공로사이에 그 토지의 용도에 필요한 통로가 없는 경우에 그 토지소유자는 주위의 토지를 통행 또는 통로로 하지 아니하면 공로에 출입할 수 없거나 과도한 비용을 요하는 때에는 그 주위의 토지를 통행할 수 있고 필요한 경우에는 통로를 개설할 수 있다.
4. 분할로 인하여 공로에 통하지 못하는 토지가 있는 때에는 그 토지소유자는 공로에 출입하기 위하여 다른 분할자의 토지를 통행할 수 있다.
5. 무상통행권은 원칙적으로 직접 분할 당사자나 일부양도의 당사자 사이에서만 적용된다.

제15강 건물의 구분소유 (1)

♣ 학습목표

1. 건물의 구분소유에 대하여 정리할 수 있다.
2. 구분소유의 법률관계를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 구분소유의 의의
- 구분소유의 성립
- 전유부분 및 공용부분
- 구분소유의 법률관계

♣ 사전 테스트

1. 주위토지통행권은 소유권자가 아닌 지상권자·전세권자에게는 인정되지 않는다.
⇒ × : 주위토지통행권은 토지소유자뿐만 아니라 지상권자·전세권자에게도 인정된다(제280조·제319조에 의한 제219조의 준용).
2. 토지의 불법점유자도 토지소유권의 상린관계로서 주위토지통행권의 주장이나 통행지역권의 시효취득 주장을 할 수 있다.
⇒ × : 토지의 불법점유자는 토지소유권의 상린관계로서 주위토지통행권의 주장이나 통행지역권의 시효취득 주장을 할 수 없다(대판 1976. 10. 29, 76다1694).
3. 주위토지통행권은 현재의 토지의 용법에 따른 이용의 범위에서 인정되는 것이 원칙이지만, 장래의 이용상황을 미리 보장하는 것도 가능하다.
⇒ × : 주위토지통행권은 현재의 토지의 용법에 따른 이용의 범위에서 인정되는 것이며, 장래의 이용상황을 미리 보장하는 것이 아니다(대판 1996. 11. 29, 96다33433).

♣ 강의교안

IV. 구분소유(제215조)

제215조(건물의 구분소유)

- ① 수인이 한 채의 건물을 구분하여 각각 그 일부분을 소유한 때에는 건물과 그 부속물중 공용하는 부분은 그의 공유로 추정한다.
- ② 공용부분의 보존에 관한 비용 기타의 부담은 각자의 소유부분의 가액에 비례하여 분담한다.

1. 의의

구분소유란 1동의 건물을 구분하여 그 구분된 부분을 별개의 건물로 소유하는 것을 말한다. 이에 대하여 민법 제215조가 규정하고 있으나, 이 조문으로는 공동주거에 따른 복잡한 법률관계를 규율하기 곤란하여 1984년 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률을 제정하여 시행 → 따라서 민법 제215조는 그 존재의의를 상당부분 상실

일물일권주의의 원칙상 원래 1동의 건물은 1개의 물건으로 다루어지나, 구분소유에 있어서는 여러 사람이 1동의 건물을 구분하여 소유할 수 있음을 전제로 하고 있다.

2. 구분소유권의 성립

(가) 구조상·이용상 독립성이 있을 것

“1동의 건물 중 구조상 구분된 수 개의 부분이 독립한 건물로서 사용될 수 있을 때”에 구분소유가 가능하다(집합건물법 제1조).

다시 말해 구분소유가 성립하기 위하여 1동의 건물 중 구분된 각 부분이 구조상의 독립성과 이용상의 독립성을 갖추어야 (대법원 1995.6.9. 선고 94다40239 판결) → 물적지배의 범위를 명확히 할 필요

아울러 상가건물의 구분점포도 집합건물법상의 구분소유권의 대상이 된다(동법 제1조의2).

(나) 구분행위

구분건물이 되기 위해서는 객관적, 물리적인 측면에서 구분건물이 구조상·이용상의 독립성 이외에, 그 건물을 구분소유권의 객체로 하려는 소유자의 의사표시, 즉 구분행위가 필요하다.

구분행위는 건물의 특정 부분을 구분하여 소유권의 객체로 하려는 법률행위로서 구분건물의 물리적 완성 전에도 구분행위의 존재를 인정할 수 있고, 건축허가신청이나 분양계약 등에서 이를 할 수 있는데 건축물대장에 등록을 하거나 소유권보존등기를 하는 것은 구분소유의 성립에 필요한 요건이 아니다(아래 2010다71578 판결). 기존건물에 증축한 경우, 1동의 건물로서 증축으로 인한 건물표시변경등기를 경료하지 않은 이상, 구조상·이용상 독립성과 더불어 구분행위가 있어야 비로소 구분소유권이 성립한다(대판 1999.7.27., 98다35020).

대판(전) 2013.1.17, 2010다71578

[다수의견] 1동의 건물에 대하여 구분소유가 성립하기 위해서는 객관적·물리적인 측면에서 1동의 건물이 존재하고, 구분된 건물부분이 구조상·이용상 독립성을 갖추어야 할 뿐 아니라, 1동의 건물 중 물리적으로 구획된 건물부분을 각각 구분소유권의 객체로 하려는 구분행위가 있어야 한다. 여기서 구분행위는 건물의 물리적 형질에 변경을 가함이 없이 법률관념상 건물의 특정부분을 구분하여 별개의 소유권의 객체로 하려는 일종의 법률행위로서, 그 시기나 방식에 특별한 제한이 있는 것은 아니고 처분권자의 구분의사가 객관적으로 외부에 표시되면 인정된다. 따라서 구분건물이 물리적으로 완성되기 전에도 건축허가신청이나 분양계약 등을 통하여 장래 신축되는 건물을 구분건물로 하겠다는 구분의사가 객관적으로 표시되면 구분행위의 존재를 인정할 수 있고, 이후 1동의 건물 및 그 구분행위에 상응하는 구분건물이 객관적·물리적으로 완성되면 아직 그 건물이 집합건축물대장에 등록되거나 구분건물로서 등기부에 등기되지 않았더라도 그 시점에서 구분소유가 성립한다.

(다) 분양자의 담보책임

- 분양자 및 시공자는 수분양자인 구분소유자에 대하여 건물의 건축상 하자에 대하여 담보책임을 부담하고, 이 경우 수급인에 관한 민법 제667조 및 제668조의 규정을 준용한다(집합건물법 제9조 제1항). 이는 분양자가 부담하는 책임의 내용이 민법상 수급인의 담보책임이라는 것이고, 분양자가 부담하는 책임이 분양계약에 기한 것이라거나 분양계약의 법률적 성격이 도급이라는 취지는 아니므로 민법 제668조 단서가 준용되지 않고 따라서 건물 완공 후에도 하자로 계약의 목적을 달성할 수 없는 때에는 해제할 수 있다(대판 2003.11.14., 2002다2485).

→ 건축업자 내지 분양자로 하여금 견고한 건물을 짓도록 유도하고 부실하게 건축된 집합건물의 소유자를 두텁게 보호하기 위함

- 담보책임의 존속기간 : 건물의 주요구조부 및 지반공사의 하자는 10년, 그 밖의 하자는 5년의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간이다(집합건물법 제9조의2 제1항). 그 기산점은 전유부분은 인도한 날, 공용부분은 사용검사일 또는 사용승인일이고, 하자로 인하여 건물이 멸실·훼손된 경우 멸실·훼손일로부터 1년 이내에 권리를 행사하여야 한다(동조 제2항).

- 편면적 강행규정 : 분양자 및 시공자의 담보책임은 특약에 의해서도 수분양자에게 불리하게 변경될 수 없다(동조 제3항).

▶ 돌발 퀴즈

구분건물이 물리적으로 완성되기 전에는 건축허가신청이나 분양계약 등을 통하여 장래 신축되는 건물을 구분건물로 하겠다는 구분의사가 객관적으로 표시되었더라도 구분행위의 존재를 인정할 수 없다.

⇒ × : 구분건물이 물리적으로 완성되기 전에도 건축허가신청이나 분양계약 등을 통하여 장래 신축되는 건물을 구분건물로 하겠다는 구분의사가 객관적으로 표시되면 구분행위의 존재를 인정할 수 있다(대판(전) 2013.1.17., 2010다71578).

3. 전유부분 및 공용부분

(가) 전유부분 : 구분소유권의 목적인 건물부분을 전유부분이라고 함 → 이 건물부분은 구조상 및 이용상의 독립성을 갖추어야 한다.

- 지하실 ×, 지하주차장(특약으로 공용부분에서 제외되고 구조상·이용상 독립성 갖춘 경우)
○, 상가건물 점포의 복도부분과 접해있던 유리벽체 ○

(나) 공용부분 : 공용부분이란 다수의 구분소유자가 공동으로 이용하는 부분으로, 건물 중 전유부분을 제외한 부분을 말한다.

· 그 성질 및 구조상 당연히 공용부분으로 되는 것(구조상 공용부분) : 전유부분 외의 건물부분(가령 지붕, 계단, 복도, 승강기실, 복도), 전유부분에 속하지 않는 건물의 부속물(가령 전기배선, 수도, 가스배관, 냉난방설비, 저수탱크 등) 등 → 등기를 요하지 않는다.

· 규약에 의한 공용부분(규약상 공용부분) : 관리사무실 또는 노인정 등 → 당사자들 사이의 규약이 필요하며 그 취지도 등기해야 한다(동법 제3조 제4항).

4. 구분소유의 법률관계

(1) 구분소유자의 전유부분에 대한 권리와 의무

전유부분은 구분소유자의 배타적 지배의 대상이나, 구분소유자는 건물의 보존에 해로운 행위 기타 건물의 관리 및 사용에 관하여 구분소유자의 공동의 이익에 반하는 행위를 하여서는 안 된다(동법 제5조 제1항). 집합건물인 상가건물의 구분소유자가 전유부분에 대하여 용도변경을 하는 것은 다른 구분소유자들과 함께 해야 할 필요가 없고 또한 그들의 동의를 얻어야 하는 것도 아니다(대판 2007.6.1, 2005두17201).

전유부분이 주거의 용도로 분양된 것인 때에는 구분소유자는 정당한 사유없이 그 부분을 주거 이외의 용도로 사용 또는 그 내부벽을 철거 또는 파손하여 증축, 개축하는 행위를 해서는 안 된다(동조 제2항).

구분소유자는 그 전유부분 또는 공용부분을 보존 또는 개량하기 위하여 필요한 범위 내에서 다른 구분소유자의 전유부분 또는 자기의 공유에 속하지 않는 공용부분의 사용을 청구할 수 있다(동조 제3항).

전유부분을 점유하는 자로서 구분소유자가 아닌 자도 동법 제5조 제1항부터 제3항까지의 규정이 준용된다.

재건축에 찬성하지 아니한 때에는 그 결의에 찬성하지 않는 구분소유자는 매도 청구에 응하여야 한다(동법 제48조 제4항).

(2) 위반의 효과

구분소유자나 점유자가 공동의 이익에 어긋나는 행위를 하거나 할 우려가 있는 경우에는 행위의 정지, 결과의 제거, 예방에 필요한 조치를 청구할 수 있다(동법 제43조).

공동의 이익에 어긋나는 행위로 공동생활상의 장애가 현저하고 정지·결과제거 등의 청구만으로는 장애를 제거하여 공용부분의 이용 확보나 구분소유자의 공동생활 유지를 도모함이 매우 곤란할 경우 전유부분의 사용금지를 청구할 수 있다(동법 제44조).

제5조제1항 및 제2항을 위반하거나 규약에서 정한 의무를 현저히 위반하여 공동생활을 유지하기 매우 곤란하게 된 경우 그 전유부분 및 대지사용권의 경매를 명할 것을 법원에 청구할 수 있다(동법 제45조 제1항). 이러한 경매청구권의 요건 충족 여부에 관하여는, 단지 당해 구분소유자의 권리행사 등 일정한 행위가 다수의 다른 구분소유자들의 의사와 계속적·반복적으로 배치된다거나 관리단 또는 다른 구분소유자들과의 사이에 갈등이나 반목이 발생하였다는 것만으로 쉽사리 이를 긍정해서는 아니 된다(대판 2009.12.24., 2009다41779).

제45조제1항에 따른 의무위반으로 공동생활을 유지하기 매우 곤란하게 된 경우 그 전유부분을 목적으로 하는 계약의 해제 및 그 전유부분의 인도를 청구할 수 있다(동법 제46조 제1항).

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 수인이 한 채의 건물을 구분하여 각각 그 일부분을 소유한 때에는 건물과 그 부속물중 공용하는 부분은 그의 공유로 추정한다.
 - ② 공용부분의 보존에 관한 비용 기타의 부담은 각자의 소유부분의 가액에 비례하여 부담한다.
 - ③ 구분소유가 성립하기 위하여 1동의 건물 중 구분된 각 부분이 구조상의 독립성과 이용상의 독립성을 갖추어야 한다.
 - ④ 구분건물이 되기 위해서는 그 건물을 구분소유권의 객체로 하려는 소유자의 의사표시, 즉 구분행위가 필요하다.
 - ⑤ 1동의 건물 및 그 구분행위에 상응하는 구분건물이 객관적·물리적으로 완성되었더라도 아직 그 건물이 집합건축물대장에 등록되거나 구분건물로서 등기부에 등기되지 않았으면 그 시점에서 구분소유가 성립하지 못한다.
- ⑤. 1동의 건물 및 그 구분행위에 상응하는 구분건물이 객관적·물리적으로 완성되면 아직 그 건물이 집합건축물대장에 등록되거나 구분건물로서 등기부에 등기되지 않았더라도 그 시점에서 구분소유가 성립한다(대판(전) 2013.1.17., 2010다71578).

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 구분소유권의 목적인 건물부분을 전유부분이라고 함 → 이 건물부분은 구조상 및 이용상의 독립성을 갖추어야 한다.
 - ② 공용부분이란 다수의 구분소유자가 공동으로 이용하는 부분으로, 건물 중 전유부분을 제외한 부분을 말한다.
 - ③ 성질 및 구조상 당연히 공용부분으로 되는 것은 등기를 요하지 않으나, 규약에 의한 공용부분은 그 취지를 등기해야 한다.
 - ④ 집합건물인 상가건물의 구분소유자가 전유부분에 대하여 용도변경을 하는 것은 다른 구분소유자들과 함께 해야 할 필요는 없으나 그들의 동의를 얻어야 한다.
 - ⑤ 전유부분이 주거의 용도로 분양된 것인 때에는 구분소유자는 정당한 사유없이 그 부분을 주거 이외의 용도로 사용 또는 그 내부벽을 철거 또는 파손하여 증축, 개축하는 행위를 해서는 안 된다.
- ④. 집합건물인 상가건물의 구분소유자가 전유부분에 대하여 용도변경을 하는 것은 다른 구분소유자들과 함께 해야 할 필요가 없고 또한 그들의 동의를 얻어야 하는 것도 아니다(대판 2007.6.1, 2005두17201).

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 구분소유자나 점유자가 공동의 이익에 어긋나는 행위를 하거나 할 우려가 있는 경우에는 행위의 정지, 결과의 제거, 예방에 필요한 조치를 청구할 수 있다.
 - ② 공동의 이익에 어긋나는 행위로 공동생활상의 장애가 현저하고 정지·결과제거 등의 청구만으로는 장애를 제거하여 공용부분의 이용 확보나 구분소유자의 공동생활 유지를 도모함이 매우 곤란할 경우 전유부분의 사용금지를 청구할 수 있다.
 - ③ 집합건물법 제5조제1항 및 제2항을 위반하거나 규약에서 정한 의무를 현저히 위반하여 공동생활을 유지하기 매우 곤란하게 된 경우 그 전유부분 및 대지사용권의 경매를 명할 것을 법원에 청구할 수 있다.
 - ④ 위 ③의 경매청구권의 요건 충족 여부에 관하여는, 당해 구분소유자의 권리행사 등 일정한 행위가 다수의 다른 구분소유자들의 의사와 계속적·반복적으로 배치된다거나 관리단 또는 다른 구분소유자들과의 사이에 갈등이나 반목이 발생하였다는 것만으로 족하다.
 - ⑤ 재건축에 찬성하지 아니한 때에는 그 결의에 찬성하지 않는 구분소유자는 매도 청구에 응하여야 한다.
- ④. 이러한 경매청구권의 요건 충족 여부에 관하여는, 단지 당해 구분소유자의 권리행사 등 일정한 행위가 다수의 다른 구분소유자들의 의사와 계속적·반복적으로 배치된다거나 관리단 또는 다른 구분소유자들과의 사이에 갈등이나 반목이 발생하였다는 것만으로 쉽사리 이를 긍정해서는 아니 된다(대판 2009.12.24., 2009다41779).

♣ 학습정리

- 1. 수인이 한 채의 건물을 구분하여 각각 그 일부분을 소유한 때에는 건물과 그 부속물중 공용하는 부분은 그의 공유로 추정한다.
- 2. 공용부분의 보존에 관한 비용 기타의 부담은 각자의 소유부분의 가액에 비례하여 부담한다.
- 3. 구분소유가 성립하기 위하여 1동의 건물 중 구분된 각 부분이 구조상의 독립성과 이용상의 독립성을 갖추어야 한다.
- 4. 구분건물이 되기 위해서는 그 건물을 구분소유권의 객체로 하려는 소유자의 의사표시, 즉 구분행위가 필요하다.
- 5. 1동의 건물 및 그 구분행위에 상응하는 구분건물이 객관적·물리적으로 완성되면 아직 그 건물이 집합건축물대장에 등록되거나 구분건물로서 등기부에 등기되지 않았더라도 그 시점에서 구분소유가 성립한다.

제16강 건물의 구분소유 (2)

♣ 학습목표

1. 건물의 구분소유를 정리할 수 있다.
2. 구분소유 중 공용부분의 법률관계에 대하여 설명할 수 있다.
3. 구분소유에 있어서의 대지사용권에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 공용부분의 법률관계
- 대지사용권
- 관리단과 규약
- 구분소유의 소멸

♣ 사전 테스트

1. 구분소유권의 목적인 건물부분을 전유부분이라고 하는데, 구조상 및 이용상의 독립성을 갖출 필요는 없다.
⇒ × : 구분소유권의 목적인 건물부분을 전유부분이라고 하고, 구조상 및 이용상의 독립성을 갖추어야 한다.
2. 구분건물이 되기 위해서 소유자가 그 건물을 구분소유권의 객체로 하려는 의사표시를 할 필요는 없다.
⇒ × : 구분건물이 되기 위해서는 그 건물을 구분소유권의 객체로 하려는 소유자의 의사표시, 즉 구분행위가 필요하다.
3. 1동의 건물 및 그 구분행위에 상응하는 구분건물이 객관적·물리적으로 완성되었더라도 그 건물이 집합건축물대장에 등록되거나 구분건물로서 등기부에 등기되어야 구분소유가 성립한다.
⇒ × : 1동의 건물 및 그 구분행위에 상응하는 구분건물이 객관적·물리적으로 완성되면 아직 그 건물이 집합건축물대장에 등록되거나 구분건물로서 등기부에 등기되지 않았더라도 그 시점에서 구분소유가 성립한다.

♣ 강의교안

(3) 공용부분의 법률관계

1) 공용부분의 공유 및 지분

공용부분은 원칙적으로 구분소유자의 전원의 공유에 속하고, 일부의 구분소유자만의 공유에 속하는 일부공용부분도 인정된다(집합건물법 제10조 제1항).

구분소유자는 공용부분을 그 용도에 따라서 사용할 수 있다(동법 제11조).

* 공용부분을 지분 비율로 사용하는 것은 아니다.

공용부분에 대한 지분은 그가 가지는 전유부분의 면적의 비율에 의하고(법 제12조 제1항), 일부 공용부분으로서 면적이 있는 것은 그 공용부분을 공용하는 구분소유자의 전유부분의 면적 비율에 따라 배분하여 그 면적을 각 구분소유자의 전유부분 면적에 포함한다(동조 제2항).

공용부분의 분할청구는 허용되지 않는다(민법 제268조 제3항).

전유부분과 공용부분에 대한 지분은 일체성을 가지므로, 공유자의 공용부분에 대한 지분은 그가 가지는 전유부분의 처분에 따르며(집합건물법 제13조 제1항), 전유부분과 분리하여 공용부분에 대한 지분을 처분할 수 없고(동조 제2항). 공용부분에 대한 물권의 득실변경은 등기를 요하지 않는다(동조 제3항).

2) 공용부분의 변경 및 관리

공용부분의 변경에 관한 사항은 관리단집회에서 구분소유자의 4분의 3 이상 및 의결권의 4분의 3 이상의 결의로써 결정하는데, 공용부분의 개량을 위한 것으로서 지나치게 많은 비용이 드는 것이 아닐 경우 등에는 통상의 집회결의로써 결정할 수 있고, 공용부분의 변경이 다른 구분소유자의 권리에 특별한 영향을 미칠 때에는 그 구분소유자의 승낙을 받아야 한다(동법 제15조).

공용부분의 관리에 관한 사항은 변경에 해당하는 경우를 제외하고는 통상의 집회결의로써 결정하고, 구분소유자의 승낙을 받아 전유부분을 점유하는 자는 이 집회에 참석하여 그 구분소유자의 의결권을 행사할 수 있는데, 규약으로 달리 정할 수 있다(동법 제16조).

일부공용부분의 관리에 관한 사항 중 구분소유자 전원에게 이해관계가 있는 사항과 규약으로 정한 사항은 구분소유자 전원의 집회결의로써 결정하고, 그 밖의 사항은 그것을 공용하는 구분소유자만의 집회결의로써 결정한다(동법 제14조).

공용부분의 보존행위는 각 구분소유자가 할 수 있으므로(동법 제16조 제1항 단서), 공용부분의 불법점유자를 상대로 물권적 청구나 부당이득반환청구 등을 할 수 있다.

* 공용부분은 전유부분으로 변경되지 않는 한 구분소유권의 목적이 될 수 없고 전유부분과 분리하여 처분할 수 없는바, 공용부분에 대하여 취득시효의 완성을 인정하여 소유권취득을 인정한다면 전유부분과 분리하여 공용부분의 처분을 허용하고 일정기간의 점유로 공용부분이 전유부분으로 변경되는 결과가 되어 집합건물법의 취지에 어긋나는 것이 되므로. 집합건물의 공용부분은 취득시효에 의한 소유권 취득의 대상이 될 수 없다(대판 2013.12.12., 2011다 78200·78217).

3) 공용부분의 부담 및 수익

공용부분의 부담 및 수익은 원칙적으로 지분의 비율에 의한다(동법 제17조). 관리비 징수에 관하여는 규약이 존재하지 않더라도 공용부분에 대한 관리비는 구분소유자에게 청구할 수 있다(대판 2009.7.9., 2009다22266). 공유자가 공용부분에 관하여 다른 공유자에 대하여 가지는 채권은 그 특별승계인에 대하여도 행사할 수 있으므로, 전 구분소유자의 특별승계인에게 전 구분소유자의 체납관리비를 승계하도록 한 관리규약 중 공용부분 관리비에 관한 부분은 유효하다(대판 2006.6.29, 2004다3598·3604)

집합건물의 설치 또는 보존의 하자로 타인에게 손해를 가한 경우 그 하자는 공용부분에 존재하는 것으로 추정하는데(동법 제6조), 민법 제758조 소정의 공작물 책임을 그 공용부분의 점유자나 구분소유자 전원이 부담하도록 함으로써 피해자 구제에 충실하기 위한 취지이다.

▶ 돌발 퀴즈

집합건물의 공용부분은 취득시효에 의한 소유권 취득의 대상이 될 수 있다.

⇒ × : 공용부분은 전유부분으로 변경되지 않는 한 구분소유권의 목적이 될 수 없고 전유부분과 분리하여 처분할 수 없는바, 공용부분에 대하여 취득시효의 완성을 인정하여 소유권취득을 인정한다면 전유부분과 분리하여 공용부분의 처분을 허용하고 일정기간의 점유로 공용부분이 전유부분으로 변경되는 결과가 되어 집합건물법의 취지에 어긋나는 것이 되므로. 집합건물의 공용부분은 취득시효에 의한 소유권 취득의 대상이 될 수 없다(대판 2013.12.12., 2011다78200·78217).

(4) 대지사용권

대지사용권은 전유부분을 소유하기 위하여 건물의 대지에 대하여 가지는 일체의 권리로서(집합건물법 제2조 제6호), 소유권은 물론이고 지상권이나 임차권과 같은 용익권도 대지사용권으로 될 수 있다.

전유부분과 함께 대지지분을 취득하기 위한 실질적 요건을 모두 갖추었지만 대지지분에 대한 등기를 아직 마치지 못한 경우이더라도, 매수인의 지위에서 가지는 대지에 대한 점유·사용권은 단순한 점유권과는 차원을 달리하는 본권으로서 동법 제2조 제6호의 대지사용권에 해당하고, 수분양자로부터 전유부분과 대지지분을 다시 매수하거나 증여 등의 방법으로 양수받거나 전전양수받은 자 역시 당초 수분양자가 가졌던 이러한 대지사용권을 취득한다(대판 2000.11.16., 98다45652·45659)

다른 규약이 없는 한 대지사용권은 전유부분의 처분에 따르므로(동법 제20조 제1항), 구분소유권과 대지사용권의 일체성이 보장된다.

따라서 전유부분에 대한 소유권보존 또는 이전등기만 경료되고 대지지분에 대한 등기가 경료되기 전에 전유부분에 대해서만 양도담보를 원인으로 한 소유권이전등기가 경료된 경우, 양도담보의 효력은 대지사용권의 분리처분이 가능하도록 규약으로 정하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 대지사용권에까지 미친다(대판 2008.11.27., 2008다60742).

부동산의 대지사용권인 공유지분에 관하여 대지권인 취지의 등기가 경료된 이상, 전유부분에 대하여 설정된 전세권은 대지권에 대해서도 미치고, 전세권설정등기가 건물부분만에 관한 것이라는 취지의 부기등기가 경료되었다고 하여 달리 볼 것도 아니므로, 부동산의 매각대금 중 대지권에 관한 부분에 대하여도 전세권자가 전세권설정등기 이후에 근저당권을 취득한 채권자보다 우선하여 변제받을 권리가 있다(대판 2009.1.30., 2008다67217).

다만 구분소유자가 애초부터 대지사용권을 보유하고 있지 아니하거나, 대지사용권 보유의 원인이 된 신탁계약 종료에 따라 대지사용권이 소멸한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 집합건물법 제20조가 정하는 전유부분과 대지사용권의 일체적 취급이 적용될 여지가 없다(대판 2011.9.8., 2011다23125).

구분소유자에게 대지사용권이 없는 경우에, 그 전유부분의 철거를 구할 권리를 가진 자는 그 구분소유자에 대하여 구분소유권을 시가로 매도할 것을 청구할 수 있고(동법 제7조), 대지 위에 구분소유권의 목적인 건물이 속하는 1동의 건물이 있을 경우 그 대지의 공유자는 그 건물의 사용에 필요한 범위 내의 대지에 대하여 분할을 청구하지 못한다(동법 제8조).

(5) 관리단과 규약

건물에 대하여 구분소유관계가 성립되면, 구분소유자 전원을 구성원으로 하는 건물 및 그 대지와 부속시설의 관리에 관한 사업의 시행을 목적으로 하는 관리단이 구성되는데(동법 제23조 제1항), 이러한 관리단은 특별한 조직행위가 없어도 당연히 성립하는 단체이다(대판 2002.12.27., 2002다45284).

관리단은 권리능력없는 사단으로서, 구분소유자가 10인 이상인 때에는 관리인을 선임해야 하고(동법 제24조 제1항), 관리인은 관리단을 대표한다(동법 제25조 제1항).

건물과 대지 또는 부속시설의 관리 또는 사용에 관한 구분소유자 상호간의 사항 중 집합건물법이 규정하지 않는 사항을 규약으로 정할 수 있다(동법 제28조 제1항). → 이 규약은 구분소유자의 승계인에 대하여도 효력을 가진다.

6. 구분소유의 소멸

구분소유는 구분소유부분의 합병등기에 의하여, 물리적 구분의 제거에 의하여 또는 건물의 전부 또는 일부 멸실에 의하여 소멸됨. 다만, 건물의 일부멸실의 경우에 복구권이 인정될 수 있음(동법 제50조)

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 공용부분은 원칙적으로 구분소유자의 전원의 공유에 속하고, 일부의 구분소유자만의 공유에 속하는 일부공용부분도 인정된다.
- ② 구분소유자는 공용부분을 지분 비율로 사용할 수 있다.
- ③ 공용부분에 대한 지분은 그가 가지는 전유부분의 면적의 비율에 의한다.
- ④ 공용부분의 분할청구는 허용되지 않는다.
- ⑤ 전유부분과 공용부분에 대한 지분은 일체성을 가지므로, 공유자의 공용부분에 대한 지분은 그가 가지는 전유부분의 처분에 따른다.

- ②. 구분소유자는 공용부분을 그 용도에 따라서 사용할 수 있다(집합건물법 제11조). 공용부분을 지분 비율로 사용하는 것은 아니다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 전유부분과 분리하여 공용부분에 대한 지분을 처분할 수 없다.
 - ② 공용부분의 부담 및 수익은 원칙적으로 지분의 비율에 의한다.
 - ③ 관리비 징수에 관하여는 규약이 존재하지 않더라도 공용부분에 대한 관리비는 구분소유자에게 청구할 수 있다.
 - ④ 전 구분소유자의 특별승계인에게 전 구분소유자의 체납관리비를 승계하도록 한 관리규약은 공용부분 관리비에 관한 부분도 무효이다.
 - ⑤ 집합건물의 설치 또는 보존의 하자로 타인에게 손해를 가한 경우 그 하자는 공용부분에 존재하는 것으로 추정한다.
- ④. 공유자가 공용부분에 관하여 다른 공유자에 대하여 가지는 채권은 그 특별승계인에 대하여도 행사할 수 있으므로, 전 구분소유자의 특별승계인에게 전 구분소유자의 체납관리비를 승계하도록 한 관리규약 중 공용부분 관리비에 관한 부분은 유효하다(대판 2006.6.29., 2004다3598·3604).

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 전유부분과 함께 대지지분을 취득하기 위한 실질적 요건을 모두 갖추었지만 대지지분에 대한 등기를 아직 마치지 못한 경우이더라도, 매수인의 지위에서 가지는 대지에 대한 점유·사용권은 단순한 점유권과는 차원을 달리하는 본권으로서 집합건물법 제2조 제6호의 대지사용권에 해당하고, 수분양자로부터 전유부분과 대지지분을 다시 매수하거나 증여 등의 방법으로 양수받거나 전전양수받은 자 역시 당초 수분양자가 가졌던 이러한 대지사용권을 취득한다
 - ② 전유부분에 대한 소유권보존 또는 이전등기만 경료되고 대지지분에 대한 등기가 경료되기 전에 전유부분에 대해서만 양도담보를 원인으로 한 소유권이전등기가 경료된 경우, 양도담보의 효력은 대지사용권의 분리처분이 가능하도록 규약으로 정하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 대지사용권에까지 미친다.
 - ③ 부동산의 대지사용권인 공유지분에 관하여 대지권인 취지의 등기가 경료된 이상, 전유부분에 대하여 설정된 전세권은 대지권에 대해서도 미치고, 전세권설정등기가 건물부분만에 관한 것이라는 취지의 부기등기가 경료되었다고 하여 달리 볼 것도 아니므로, 부동산의 매각대금 중 대지권에 관한 부분에 대하여도 전세권자가 전세권설정등기 이후에 근저당권을 취득한 채권자보다 우선하여 변제받을 권리가 있다.
 - ④ 구분소유자가 애초부터 대지사용권을 보유하고 있지 아니하거나, 대지사용권 보유의 원인이 된 신탁계약 종료에 따라 대지사용권이 소멸한 경우에도 특별한 사정이 없는 한 집합건물법 제20조가 정하는 전유부분과 대지사용권의 일체적 취급이 적용된다.
 - ⑤ 건물에 대하여 구분소유관계가 성립되면, 구분소유자 전원을 구성원으로 하는 건물 및 그 대지와 부속시설의 관리에 관한 사업의 시행을 목적으로 하는 관리단이 구성되는데, 이러한 관리단은 특별한 조직행위가 없어도 당연히 성립하는 단체이다.
- ④. 구분소유자가 애초부터 대지사용권을 보유하고 있지 아니하거나, 대지사용권 보유의 원인이 된 신탁계약 종료에 따라 대지사용권이 소멸한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 집합건물법

제20조가 정하는 전유부분과 대지사용권의 일체적 취급이 적용될 여지가 없다(대판 2011.9.8., 2011다23125).

♣ 학습정리

1. 공용부분에 대한 지분은 그가 가지는 전유부분의 면적의 비율에 의한다.
2. 전 구분소유자의 특별승계인에게 전 구분소유자의 체납관리비를 승계하도록 한 관리규약 중 공용부분 관리비에 관한 부분은 유효하다.
3. 공용부분은 전유부분으로 변경되지 않는 한 구분소유권의 목적이 될 수 없고 전유부분과 분리하여 처분할 수 없다.
4. 집합건물의 공용부분은 취득시효에 의한 소유권 취득의 대상이 될 수 없다.
5. 구분소유자 전원을 구성원으로 하는 관리단은 특별한 조직행위가 없어도 당연히 성립하는 단체이다.

제17강 취득시효 (1)

♣ 학습목표

1. 취득시효의 제도적 의의를 정리할 수 있다.
2. 점유취득시효의 요건에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 취득시효의 제도적 의의
- 점유취득시효의 요건
- 시효기간과 기산점

♣ 사전 테스트

1. 전유부분과 분리하여 공용부분에 대한 지분을 처분할 수 있다.
⇒ × : 전유부분과 분리하여 공용부분에 대한 지분을 처분할 수 없다.
2. 집합건물의 설치 또는 보존의 하자로 타인에게 손해를 가한 경우 그 하자는 전유부분에 존재하는 것으로 추정한다.
⇒ × : 집합건물의 설치 또는 보존의 하자로 타인에게 손해를 가한 경우 그 하자는 공용부분에 존재하는 것으로 추정한다.
3. 집합건물의 공용부분은 취득시효에 의한 소유권 취득의 대상이 될 수 있다.
⇒ × : 집합건물의 공용부분은 취득시효에 의한 소유권 취득의 대상이 될 수 없다.

♣ 강의교안

V. 취득시효

목적물	① 부동산 취득시효	제1항 (일반/점유) : 20년의 평온·공연·자주점유 제2항(단기/등기부) : 10년의 평온·공연·선의·무과실·자주점유
	② 동산 취득시효	제1항(장기) : 10년의 평온·공연·자주점유 제2항(단기) : 5년의 평온·공연·선의·무과실·자주점유
권리	① 소유권 → 자주점유 요건	
	② 기타 재산권 → 자주점유 요건 (X)	

1. 시효의 의의와 취득시효의 제도적 의의

- 일정한 사실상태가 오랫동안 계속되었을 때, 그 상태가 진실한 권리관계와 일치하는가의 여부를 묻지 않고, 그 사실 상태를 그대로 권리관계로 인정하는 제도
 - ⇒ 소멸시효(진정한 권리자의 권리 상실)와 취득시효(점유자 권리취득)
- 취득시효의 제도적 의의 ⇒ 사실상태대로 보호함으로써 법적 안정성을 기하고 입증의 어려움으로 인한 혼란 회피

※ 취득시효제도에 대한 비판적 견해

등기를 부동산물권변동의 공시방법으로 하고 성립요건주의를 취하고 있는 민법에 있어서 공식적인 권리의 추정을 받는 등기를 뒤엎고 단순한 점유자가 소유권을 취득하게 되는 취득시효 제도는 비정상적인 것이다.

또한 정당한 권원이 없는 점유자가 정당한 권리자의 소유권을 빼앗아 취득하는 것은 소유권의 항구성을 퇴색시키고, 또한 점유취득시효에 있어서는 법률의 규정에 의한 부동산물권변동에는 등기를 요구하지 않는 제187조의 원칙을 무시하고 별도의 등기를 요구하는 것도 극히 예외적인 것이라고 할 것이다.

이러한 점들을 이유로, 장차 등기부가 정비되면 점유취득시효는 삭제되거나 극히 제한적으로만 인정되어야 한다는 주장들이 제기되고 있다.

판례도 “무릇 점유취득시효제도는 권리 위에 잠자는 자를 배제하고 점유사용의 현실적 상황을 존중하자는 제도이기는 하지만 이는 극히 예외적인 상황하에서만 인정되어야 할 것이고, 이를 지나치게 넓게 인정하는 것은 타인의 재산권을 부당히 침해할 요소가 큰 것이므로, 법이 진정한 재산권을 보호하지 못하는 결과가 되어 온당치 않다고 보여지고, 따라서 그 취득요건은 극히 엄격히 해석해야 할 것”이라고 하였다(대판 1995.05.09, 94다22484).

- 목적이 되는 권리 : 소유권, 지상권, 지역권, 질권, 분묘기지권 등
 - 대상이 되는 물건
 - 국유재산은 시효취득의 대상이 되지 않는다는 국유재산법의 규정에 대하여 위헌결정이 있었
고, 현재는 행정재산만을 제외하고 보존재산과 잡종재산은 시효취득 가능하다.
 - 부동산의 일부
- 점유는 반드시 독립한 물건, 즉 1필의 토지 또는 1동의 건물에 관하여 하여야 하는지, 즉 부
동산의 일부에 대하여도 시효취득이 가능한지도 문제되는데, 판례는 토지에 대한 점유취득시효
에 관하여 이를 인정하였다(대판 1965.1.19, 64다1254).
- 일부에 대한 점유가 다른 부분과 구분되어 시효취득자에게 속한다는 것을 인식할 수 있는 총
분하고 객관적인 징표가 계속하여 존재해야 한다(대판 1989.4.25, 88다카9494).
- 등기를 하기 위해서는 우선 토지부분의 분필절차를 거친 후에 시효취득의 등기를 해야 한다.

※ 자기 소유의 물건

구민법에서는 타인의 물건으로 한정하였으나 현행민법은 이러한 제한을 두고 있지 않는데,
자기 소유의 물건에 대하여도 취득시효를 인정할 것인가?

- 긍정설(통설) : 시효취득은 원시취득이므로 타인의 소유권의 승계의 문제가 발생하지 않
고, 자기의 소유임을 증명하기 어려울 때에는 자기의 물건에 대한 취득시효를 주장할 필요
가 인정된다. 취득시효는 누구의 소유권인가를 묻지 않고 사실상태를 권리관계로 승화시키
는 제도 취득시효의 객체가 되는 물건은 반드시 타인의 물건일 필요는 없다
- 부정설 : 자기소유의 부동산이라는 것이 분명한데도 굳이 취득시효를 주장하는 것은 무의
미하다.
- 판례
- 긍정적인 것

취득시효는 당해 부동산을 오랫동안 계속하여 점유한다는 사실상태를 일정한 경우에 권리
관계로 높이려고 하는 데에 그 존재이유가 있는 점에 비추어 보면, 시효취득의 목적물은
타인의 부동산임을 요하지 않고 자기 소유의 부동산이라도 시효취득의 목적물이 될 수 있
다고 할 것이고, 취득시효를 규정한 민법 제245조가 '타인의 물건인 점'을 규정에서 빼놓은
것도 같은 취지에서라고 할 것이다(대판 2001.07.13, 2001다17572).

시효로 인한 부동산 소유권의 취득은 원시취득으로서 취득시효의 요건을 갖추면 곧 등기청
구권을 취득하는 것이고 또 타인의 소유권을 승계취득하는 것이 아니어서 시효취득의 대상
이 반드시 타인의 소유물이어야 하거나 그 타인이 특정되어 있어야만 하는 것은 아니므로
성명불상자의 소유물에 대하여 시효취득을 인정할 수 있다(대판 1992.02.25, 91다9312).

· 부정적인 것

취득시효의 기산점은 그 점유를 개시한 날이 되어야 하고 시효취득을 주장하는 자가 기산
일을 임의로 정할 수는 없다고 할 것이나 자기소유의 부동산을 점유하고 있는 상태에서 다
른 사람 명의로 소유권이전등기가 된 경우라면 그리고 그 점유가 자주점유인 것이라면 그
취득시효의 기산점은 소유권의 변동일(소유권이전등기일)이 되어야 할 것이다. 왜냐하면 자
기소유 부동산을 점유하는 것은 취득시효의 기초로서의 점유라고 할 수는 없는 것이고 그
소유권의 변동이 있는 경우 비로소 취득시효의 기초로서의 점유가 개시되는 것이라고 보아
야 할 것이기 때문이다(대판 1989.09.26, 88다카26574; 대판 1997. 3. 14, 96다55860; 대
판 2008.6.26, 2007다7898).

공유자들이 분할 전 토지의 전체면적 중 각 점유부분을 구분소유하게 된다고 믿고서 그 각
점유부분의 대략적인 면적에 해당하는 만큼의 지분에 관하여 소유권이전등기를 경료하는

경우에는 등기부상 공유자들이 분할 전 토지의 공유자로 되어 있다고 하더라도 그들은 각자 자기 소유의 토지를 점유하는 것일 뿐 자신과 타인이 공유하는 토지를 점유하는 것은 아니라고 할 것이므로, 이 사건에서와 같이 토지 소유자가 토지의 특정한 일부분을 타인에게 매도하면서 등기부상으로는 전체 토지의 일부 지분에 관한 소유권이전등기를 경료해 준 경우에 매도 대상에서 제외된 나머지 특정 부분을 계속 점유한다고 하더라도 이는 자기 소유의 토지를 점유하는 것이어서 취득시효의 기초가 되는 점유라고 할 수 없을 것이다(대판 2001.04.13, 99다62036). 토지의 특정한 일부분을 매수한 자가 등기부상으로는 전체 토지의 일부 지분에 관한 소유권이전등기를 경료받고 매수 대상인 그 특정 부분을 점유하는 경우에도 마찬가지일 것이다(대판 2009.10.15, 2007다83632).

토지구획정리사업의 시행으로 환지예정지지정이 있을 경우 종전 토지의 소유자는 환지예정지로 지정된 토지에 관하여 사용·수익권을 취득하게 되고, 이 사용·수익권은 종전 토지에 대한 소유권에 기한 것이므로, 종전 토지 소유자의 환지예정지에 대한 점유는 자기 소유의 종전 토지에 대한 점유와 그 성질이 같다 할 것이어서, 종전 토지 소유자가 종전 토지에 대한 환지예정지를 점유하는 것은 취득시효의 기초로서의 점유라고 볼 수 없다(대판 2002.09.04, 2002다22083).

2. 점유취득시효의 요건(제245조 제1항)

1) 소유의 의사(자주점유)

소유의 의사는 타인의 소유권을 배제하여 자기의 소유물처럼 배타적 지배를 행사하는 의사를 말함(대법원 1990.11.13. 선고 90다카21381, 21398 판결), 법률상 그러한 지배를 할 수 있는 권원 즉 소유권을 가지고 있거나 또는 소유권이 있다고 믿고서 하는 점유가 아님(대법원 1994.11.8. 선고 94다36438, 36445 판결)

⇒ 원칙적으로 자주점유는 추정됨(제197조 제1항)

2) 자주점유에 대한 판단기준

소유의 의사는 점유개시 당시 존재하는 것으로 족하고, 나중에 매도인에게 처분권이 없음을 알았더라도 자주점유의 성질이 바뀌지 않는다(대판 1996.5.28, 95다40328).

점유자의 내심의 의사가 아니라, 점유취득의 권원이 된 성질이나 점유와 관계가 있는 모든 사정에 의하여 외형적·객관적으로 판단해야 함

점유는 자주점유로 추정되는데, 이 경우 자주점유가 아니라고 주장하는 사람은 상대방의 점유가 타주점유임을 증명할 책임을 진다. 따라서 점유자가 스스로 매매 또는 증여와 같은 자주점유의 권원을 주장하였으나 이것이 인정되지 않는 경우에도 원래 위와 같은 자주점유의 권원에 관한 증명책임이 점유자에게 있지 아니한 이상 그 점유권원이 인정되지 않는다는 사유만으로 자주점유의 추정이 번복된다거나 또는 점유권원의 성질상 타주점유라고 볼 수는 없다(대판(전) 1983.7.12, 82다708·709, 82다카1792·1793)

그러나 처분권한 없는 자로부터 그 사실을 알면서 부동산을 취득하거나, 어떠한 법률행위가 무효임을 알면서 그 법률행위에 의하여 부동산을 취득하여 점유를 시작한 때에는 점유 시작 당시에 소유의 의사가 있다고 할 수 없다.

- 자주점유라고 본 경우

○ 매매가 무효인 경우라도 그것만으로는 매수인의 점유가 타주점유라고 할 수 없음

○ 점유자가 스스로 매매나 증여와 같은 자주점유의 권원을 주장하였으나 이것이 인정되지 않더라도 자주점유의 추정이 깨어지지 않는다고 함(대법원 1983.7.12. 선고 82다708,709, 82다카1792,1793 전원합의체 판결)

○ 타인의 토지의 매매에 해당하여 그에 의하여 곧바로 소유권을 취득할 수 없다고 하더라도 그것만으로 매수인이 점유권원의 성질상 소유의 의사가 없는 것으로 보이는 권원에 바탕을 두고 점유를 취득한 사실이 증명되었다고 단정할 수 없을 뿐만 아니라, 매도인에게 처분권한이 없다는 것을 잘 알면서 이를 매수하였다는 등의 다른 특별한 사정이 입증되지 않는 한, 그 사실만으로 바로 그 매수인의 점유가 소유의 의사가 있는 점유라는 추정이 깨어지는 것이라고 할 수 없다. 그리고 민법 제197조 제1항이 규정하고 있는 점유자에게 추정되는 소유의 의사는 사실상 소유할 의사가 있는 것으로 충분한 것이지 반드시 등기를 수반하여야 하는 것은 아니므로 등기를 수반하지 아니한 점유임이 밝혀졌다고 하여 이 사실만 가지고 바로 점유권원의 성질상 소유의 의사가 결여된 타주점유라고 할 수도 없을 것이다(대법원 2000.03.16. 선고 97다37661 전원합의체 판결)

- 자주점유의 추정이 깨진다고 본 경우

○ 점유자가 성질상 소유의 의사가 없는 것으로 보이는 권원에 바탕을 두고 점유를 취득한 사실이 증명된 경우 → 지상권, 전세권, 임차권과 같은 전형적인 타주점유의 권원에 의하여 점유함이 증명된 경우

○ 타인의 소유권을 배제하여 자기의 소유물처럼 배타적 지배를 행사하는 의사를 가지고 점유하는 것으로 볼 수 없는 객관적 사정이 인정된 경우(대법원 1990.11.13. 선고 90다카21381, 21398 판결), 토지 점유자가 점유기간 동안 여러 차례 부동산소유권이전등기등에관한특별조치법이 시행됨에 따라 등기의 기회가 있었음에도 불구하고 소유권이전등기를 하지 않았고 오히려 소유자가 같은 법에 의하여 소유권보존등기를 마친 후에도 별다른 이의를 하지 않은 경우, 자주점유의 추정이 번복될 수 있다(대법원 2000.03.24. 선고 99다56765 판결).

○ 악의의 무단점유에 해당하는 경우 → 점유자가 점유 개시 당시 소유권 취득의 원인이 될 수 있는 법률행위 기타 법률요건 없이 그와 같은 법률요건이 없다는 사실을 알면서 타인 소유의 부동산을 무단점유한 경우(대법원 1997.8.21. 선고 95다28625 전원합의체 판결)

→ 악의의 무단점유를 타주점유로 보는 것이 과연 이론적으로 정당하다고 할 것인가? 악의의 무단점유야말로 소유자를 배제하고 소유의 의사를 갖고 하는 점유, 즉 자주점유의 전형이라고 할 수 있지 않을까? : 95다28625 판결의 반대의견도 확인 요망

※ 시효기간과 기산점

(1) 문제점

① 점유자가 점유기간의 기산점을 임의로 선택할 수 있고, 따라서 현재로부터 거슬러 올라가 20년 이상 점유한 사실을 증명하면 그것으로 점유취득시효의 완성을 인정할 수 있는지(逆算說) 아니면 점유자가 임의로 기산점을 선택할 수 없고 현실적으로 점유를 개시한 시점에 확정하여 그때부터 20년의 기간을 기산하여야 하는지(固定時說)가 문제된다.

- ② 소유자 변동이 없는 경우(즉 이해관계 있는 제3자가 없는 경우)에는 점유자와 소유자 간의 관계만 문제되므로 점유자가 기산점을 임의로 선택하여도 불합리한 점은 발생하지 않는다(점유승계의 경우에도 마찬가지이다).

그러나 시효기간만료 후에 점유자가 아직 등기를 경료하지 않고 있는 동안에 부동산이 양도되어 그 등기를 마친 제3자가 있는 경우, 역산설에 의하여 그 기산점을 임의로 선택할 수 있게 한다면 제3자의 법적 지위를 불안하게 하여 부당한 결과가 발생한다(역산설에 의하면 점유자의 기산점 임의선택에 의하여 제3자는 시효기간 도중의 소유자가 될 수도 있고 시효기간 만료 후의 소유자가 될 수도 있다). 예를 들어 점유취득시효에서 A소유 토지를 점유자 B가 1960년 2월 1일(점유개시시)부터 1990년 12월 31일(사실심변론종결시)까지 점유하고 있고 A가 1982년 3월 1일에 위 부동산을 제3자인 C에게 양도한 경우에, 점유자 B가 점유개시시점을 1960년 2월 1일(또는 1961년 2월 1일)로 선택한다면 C는 시효기간만료 후에 양수한 것이 되지만, B가 1962년 4월 1일을 기산점으로 선택한다면(또는 현재로부터 거슬러 올라가 1970년 12월 31일을 선택한다면) C는 시효기간 도중에 소유권을 취득한 자가 되어 C의 지위가 B의 기산점 선택에 의해 좌우되어 부당하게 된다.

③ 정리

- 시효기간 완료 후 소유명의자의 변동 여부, 점유의 승계 여부, 취득시효의 재차 완성 여부에 따라 결론이 달라진다.

(i) 제1규칙(소유자 변동의 측면) - 소유자 변동이 없는 경우와 있는 경우(즉 이해관계 있는 제3자가 있는 경우)를 분리하여, 소유자 변동이 없는 경우에는 기산점을 임의로 선택하여도 불합리한 점이 없지만(역산설), 소유자 변동이 있는 경우에는 제3자의 지위의 불안정을 방지하기 위하여 기산점을 임의로 선택할 수 없다(고정시설).

(ii) 제2규칙(점유승계의 측면) - 점유승계가 있는 경우 전점유자의 점유까지 승계할 수 있으나 그 기산점은 전점유자의 점유기간 중간의 임의시점을 선택할 수는 없다(제한적 역산설).

(iii) 제3규칙 - 제1규칙과 제2규칙이 공존하는 경우 제1규칙이 우선적으로 적용된다. 왜냐하면 이해관계 있는 3자의 보호와 관련되기 때문이다. 예를 들어 소유자의 변동이 없고, 전점유자의 승계가 있는 경우 제1규칙이 우선적으로 적용되므로 전점유기간 중간의 임의시점을 선택할 수 있다.

(iv) 제4규칙 - 시효완성 후 등기 전에 소유자의 변동이 생기고 소유자 변동시점부터 다시 제2의 취득시효가 진행되는 경우, 위의 제1·2·3규칙이 동일하게 적용된다.

(2) 기본적인 입장(고정시설과 점유승계의 경우 역산설)

- ① 고정시설 취득시효의 기산점은 법률효과의 판단에 관하여 직접 필요한 주요사실이 아니고 간접사실에 불과하여 법원으로서에는 이에 관한 당사자의 주장에 구속되지 아니하고 소송자료에 의하여 진정한 점유의 시기를 인정하여야 하는 것이므로, 그러한 점유권원, 점유개시 시점과 그로 인한 취득시효완성일을 달리 주장한다고 하더라도, 그러한 주장의 차이를 가지고 별개의 소송물을 구성한다고 할 수 없다(대판 1994. 4. 15, 93다60120; 대판 1982. 6. 22, 80다2671)고 하여 원칙적으로 고정시설을 취하고 있다.

- ② 점유를 승계한 경우 역산가능((제한적) 역산설) 제한적 역산설의 입장에 따라 전점유자의 점유를 승계하여 병합하는 경우에도 그 점유기간 중의 임의의 시점을 선택할 수는 없다. 여기에서 기산점을 임의선택할 수 없다는 것은 전점유자 중 한 사람의 점유 도중의 시

기를 기산점으로 정할 수 없다는 뜻이고, 점유가 순차 이전되어 전점유자 및 전전점유자까지 존재하는 경우 점유의 분리·병합에 의해서 어느 특정 점유자의 점유개시 시점을 기산점으로 선택하는 것은 가능하다.

예를 들어 A가 5년, B가 6년, C가 7년, D가 8년을 점유한 경우 D는 8년의 점유를 주장할 수도 있고, C의 점유를 승계하여 15년, B의 점유까지 승계하여 21년의 점유를 주장하거나, A의 점유부터 승계하여 26년의 점유를 주장할 수도 있다. 이러한 점은 당해 부동산의 소유자(등기명의자)가 변동되어, 직전점유자의 점유만을 주장하는 경우에는 그 등기명의의 변경이 시효기간 만료 전으로 되지만, 그 이전 점유자의 점유까지 주장하는 경우에는 그 변경이 시효기간 만료 이후로 되는 경우에도 마찬가지이다(대판 1982. 1. 26, 81다826). 다만 이 경우에도 그 점유개시시점을 전점유자의 점유기간 도중의 임의시점을 택하여 주장할 수 없을 뿐이다(대판 1992. 12. 11, 92다9968-9975).

물론 취득시효기간 중 계속해서 등기명의자가 동일한 경우에는 그 기산점을 어디에 두든 기간에 취득시효의 완성을 주장할 수 있는 시점에서 보아 그 기간이 경과한 사실만 확정되면 충분하므로, 전 점유자의 점유를 승계하여 자신의 점유기간을 통산하여 20년이 경과한 경우라면 전 점유자가 점유를 개시한 이후의 임의의 시점을 그 기산점으로 삼을 수 있다(대판 1998. 5. 12, 97다8496-8502).

(3) 구체적 유형 1 - 소유자 변동이 없는 경우

① 소유자가 동일하고 점유승계도 없는 경우에도 기산점은 임의로 선택하여도(역산하여도) 무방하다. 즉 취득시효를 주장하는 자는 소유자의 변동이 없는 토지에 관하여는 취득시효의 기산점을 임의로 선택할 수 있고, 취득시효를 주장하는 날로부터 역산하여 20년 이상의 점유사실이 인정되고 그 점유가 자주점유가 아닌 것으로 밝혀지지 않는 한 취득시효를 인정할 수 있다(대판 1993. 11. 26, 93다30013).(역산설)

예 1) 점유자 B가 25년간 점유하고 있는 경우에 B는 임의의 기산점을 선택하여(점유개시시이든 역산하든 상관없이) 등기없이 소유자 A에 대하여 시효취득을 주장(소유권이전등기청구)할 수 있다. 즉 A는 취득시효완성당시의 당사자이다.

② 소유자가 동일하고 점유승계가 있는 경우에도 기산점은 임의로 선택하여도(역산하여도) 무방하다(대판 1998. 5. 12, 97다8496). 그리고 전점유자의 점유기간 중간의 임의시점을 기산점으로 선택할 수도 있다(대판 1998. 5. 12, 97다8496-8502).(역산설)

예 2) A소유 부동산을 B가 5년, C가 6년, D가 7년, E가 8년을 점유한 경우, E는 C·D·E의 점유를 합산하여 21년을 주장할 수 있고 C의 점유기간(6년) 중 1년이 지난 5년만을 합산하여 20년이 되는 시점을 기산점으로 할 수 있다.

③ 상속의 경우에는 소유자 변동이 없다고 할 것이다.

(4) 구체적 유형 2 - 소유자 변동이 있는 경우

- ① 소유자의 변동이 있고 점유자의 승계가 없는 경우에는, 기산점을 임의로 선택할 수 없다(대판 1976. 6. 22, 76다487·488)(고정시설).

예 3) 시효완성 전에 소유자 변동이 있는 경우

소유자 A의 부동산에 대하여 B의 시효취득이 진행되는 도중에 소유권이 C에게 이전되고 그 후 시효가 완성된 경우에는, 점유의 기산점은 점유를 처음 개시한 때로 확정되고(고정시설) 이로써 종래의 B의 점유상태의 계속이 파괴되었다고 할 수 없으므로 취득시효의 중단사유가 될 수 없다(대판 1997. 4. 25, 97다6186). 따라서 B는 C에 대하여 취득시효의 완성을 주장(C에 대하여 소유권이전등기청구)할 수 있다.

예 4-1) 시효완성 후에 소유자 변동이 있는 경우(부동산 이종양도와 같은 경우)

소유자 A의 부동산에 대하여 B가 점유시효를 완성 후, 등기 전에 A가 그 부동산을 C(악의여도 상관없다, 대판 1994. 4. 12, 93다50666·50673)에게 양도하여 등기까지 갖추어 준 경우에는, 점유의 기산점은 점유를 처음 개시한 때로 확정되고(고정시설), 이 경우는 부동산 이종양도가 행하여진 경우와 마찬가지로 C는 B에 대하여 제3자이고 따라서 B는 C에게 시효취득으로써 대항할 수 없다.

예 4-2) 시효완성 후에 소유자 변동이 있는 경우 다시 2차의 취득시효기간이 경과한 경우

취득시효완성 후 토지소유자에 변동이 있고, 소유자가 변동된 시점을 새로운 기산점으로 삼아도(그 시점을 고정으로 한다) 다시 취득시효기간이 완성되는 경우 취득시효의 완성을 주장할 수 있다(대판[전합] 1994. 3. 22, 93다46360).

예 4-3) 시효완성 후에 소유자 변동이 있고 다시 2차의 취득시효기간 도중에 소유자가 변동된 경우

시효완성 후에 소유자 변동이 있는 경우 그 소유자 변동 시점을 새로운 기산점으로 하여 2차의 취득시효기간이 시작되므로(고정시설), 2차 취득시효기간 완성 전에 소유자 변동이 있는 경우는 예3과 마찬가지로 2차 취득시효기간 이후에 소유자 변동이 있다는 사정만으로는 점유자의 종래의 사실상태의 계속을 파괴한 것이라고 볼 수 없다(대판[전합] 2009. 7. 16, 2007다15172·15189 다수의견). 따라서 새로운 소유명의자는 취득시효완성 당시 권리의무 변동의 당사자로서 취득시효완성으로 인한 불이익을 받게 된다.

▶ 돌발 퀴즈

소유자가 동일하고 점유승계가 있는 경우에도 기산점은 임의로 선택하여도 무방하나, 전점유자의 점유기간 중간의 임의시점을 기산점으로 선택할 수는 없다.

⇒ × : 소유자가 동일하고 점유승계가 있는 경우에도 기산점은 임의로 선택하여도 무방하다(대판 1998. 5. 12, 97다8496). 그리고 전점유자의 점유기간 중간의 임의시점을 기산점으로 선택할 수도 있다(대판 1998. 5. 12, 97다8496·8502).

- ② 소유자 변동이 있고 점유자의 점유승계가 있는 경우에는, 점유자의 승계인이 자기의 전 점유자의 점유를 아울러 주장할 때 그 직전의 점유만을 주장할 것인가, 그 전 점유자의 것을 아울러 주장할 것인가는 그 주장하는 사람의 임의에 속하나 그 점유시초를 전 점유자의 점유기간 중의 임의시점을 택하여 주장할 수 없다(대판 1981. 4. 14, 80다2614).(제한적 역산설)

예 5) 소유자 A의 부동산에 대하여 B가 7년, C가 8년, D가 9년, E가 13년을 점유하였고, 그 점유 도중에 A가 F에게 D가 점유를 시작한 지 1년이 지난 시점에 소유권을 이전한 경우에, E

는 자기의 점유기간인 13년과 D의 점유 중 1년이 지난 시점부터의 8년만을 합산하여 주장할 수 없다. 만약 F에게 이전한 시점이 B의 점유기간 도중이었다면 E는 C의 점유시점부터 또는 D의 점유시점부터 기산점을 임의로 선택할 수 있다.

[판례]

원래 취득시효제도는 일정한 기간 점유를 계속한 자를 보호하여 그에게 실체법상의 권리를 부여하는 제도이므로, 부동산을 20년 간 소유의 의사로 평온·공연하게 점유한 자는 민법 제245조 제1항에 의하여 점유부동산에 관하여 소유자에 대한 소유권이전등기청구권을 취득하게 되며, 점유자가 취득시효기간의 만료로 일단 소유권이전등기청구권을 취득한 이상, 그 후 점유를 상실하였다고 하더라도 이를 시효이익의 포기라 볼 수 있는 경우가 아닌 한, 이미 취득한 소유권이전등기청구권은 소멸되지 아니한다.

전 점유자의 점유를 승계한 자는 그 점유 자체와 하자만을 승계하는 것이지 그 점유로 인한 법률효과까지 승계하는 것은 아니므로 부동산을 취득시효기간 만료 당시의 점유자로부터 양수하여 점유를 승계한 현 점유자는 자신의 전 점유자에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 전 점유자의 소유자에 대한 소유권이전등기청구권을 대위행사할 수 있을 뿐, 전 점유자의 취득시효 완성의 효과를 주장하여 직접 자기에게 소유권이전등기를 청구할 권원은 없다(대판 [전합] 1995. 3. 28, 93다47745).

→ 예를 들어, A소유 부동산을 B가 1975년에 점유하다, 1985년에 C에게 인도하고, C는 1990년에 D에게, D는 2006년에 E에게 인도하여 2009년 현재 E가 점유하고 있고, 소유자 A가 F에게 2000년에 그 부동산을 양도하여 이전등기한 경우에, E는 자신의 점유가 3년 밖에 되지 않으므로 전점유자의 점유를 승계해야 하는데, B의 점유개시시인 1975년부터(즉 제한적 역산설에 의하여)의 점유를 승계하면 1995년에 시효가 완성되어 2000년 당시의 점유자인 C의 시효취득에 따른 등기청구권을 E가 대위행사해야 하지만 등기청구의 상대방인 1995년 당시의 소유자가 그 후 소유권을 F에게 이전하였으므로 A에 대한 등기청구권이 불능이 되어 E는 대위청구도 할 수 없다. 그러나 이 경우에는 E는 C의 점유개시시인 1985년부터(즉 제한적 역산설에 의하여) 점유승계를 하면 2005년에 시효가 완성되고 2005년 당시 점유자인 D의 당시 소유자인 F에 대한 등기청구권을 E가 대위행사하면 된다. 즉 E는 D의 등기청구권을 대위행사해야 하며 E가 직접 시효취득을 주장할 수 없다.

③ 자기소유의 부동산을 점유하고 있는 상태에서 다른 사람 명의로 소유권 이전등기가 경료된 경우 취득시효의 기산점은 소유권 변동일(소유권이전등기일)이다.

취득시효의 기산점은 그 점유를 개시한 날이 되어야 하고 시효취득을 주장하는 자가 임의로 정할 수는 없다고 할 것이나 자기소유의 부동산을 점유하고 있는 상태에서 다른 사람 명의로 소유권이전등기가 된 경우 자기소유 부동산을 점유하는 것은 취득시효의 기초로서의 점유라고 할 수 없고 그 소유권의 변동이 있는 경우에 비로소 취득시효의 기초로서의 점유가 개시되는 것이므로 그 점유가 자주점유라면 취득시효의 기산점은 소유권의 변동일(소유권이전등기일)이 되어야 할 것이다(대판 2008. 6. 26, 2007다7898; 대판 1997. 3. 14, 96다55860; 대판 1989. 9. 26, 88다카26574).

	점유 승계 無	점유 승계 有
시효기간 중 소유자 변동 無	임의	전 점유자 선택 可, 점유기간 중 임의시점도 선택 可

시효기간 중 소유자 변동 有	고정(점유개시시)	전 점유자 선택 可, 점유기간 중 임의시점 선택은 不可, 고정(선택된 전점유자의 점유개시시)
시효기간 중 소유자 변동 有, 소유자변동시부터 재차 취득시효 완성	고정(소유자변동시), 이후 소유자가 다시 변경된 경우도 마찬가지	전 점유자 선택 可, 점유기간 중 임의시점 선택은 不可, 고정(소유자변동시)

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 취득시효의 기산점은 법률효과의 판단에 관하여 직접 필요한 주요사실이 아니고 간접사실에 불과하여 법원으로서는 이에 관한 당사자의 주장에 구속되지 아니하고 소송자료에 의하여 진정한 점유의 시기를 인정하여야 하는 것이다.
- ② 취득시효기간 중 계속해서 등기명의자가 동일한 경우에는 그 기산점을 어디에 두든지 간에 취득시효의 완성을 주장할 수 있는 시점에서 보아 그 기간이 경과한 사실만 확정되면 충분하므로, 전 점유자의 점유를 승계하여 자신의 점유기간을 통산하여 20년이 경과한 경우라면 전 점유자가 점유를 개시한 이후의 임의의 시점을 그 기산점으로 삼을 수 있다.
- ③ 소유자의 변동이 있고 점유자의 승계가 없는 경우에는, 기산점을 임의로 선택할 수 없다
- ④ 취득시효완성 후 토지소유자에 변동이 있고, 소유자가 변동된 시점을 새로운 기산점으로 삼아도 다시 취득시효기간이 완성되는 경우 취득시효의 완성을 주장할 수 있다.
- ⑤ 시효완성 후에 소유자 변동이 있는 경우 그 소유자 변동 시점을 새로운 기산점으로 하여 2차의 취득시효기간이 시작되므로, 2차 취득시효기간 완성 전에 소유자 변동이 있는 경우는 점유자의 종래의 사실상태의 계속을 파괴한 것이라고 볼 수 있다.

- ⑤. 시효완성 후에 소유자 변동이 있는 경우 그 소유자 변동 시점을 새로운 기산점으로 하여 2차의 취득시효기간이 시작되므로, 2차 취득시효기간 완성 전에 소유자 변동이 있는 경우는 2차 취득시효기간 이후에 소유자 변동이 있다는 사정만으로는 점유자의 종래의 사실상태의 계속을 파괴한 것이라고 볼 수 없다(대판[전합] 2009. 7. 16, 2007다15172·15189 다수의견).

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 부동산을 20년 간 소유의 의사로 평온·공연하게 점유한 자는 민법 제245조 제1항에 의하여 점유부동산에 관하여 소유자에 대한 소유권이전등기청구권을 취득하게 되며, 점유자가 취득시효기간의 만료로 일단 소유권이전등기청구권을 취득한 이상, 그 후 점유를 상실하였다고 하더라도 이를 시효이익의 포기라 볼 수 있는 경우가 아닌 한, 이미 취득한 소유권이전등기청구권은 소멸되지 아니한다.

- ② 부동산을 취득시효기간 만료 당시의 점유자로부터 양수하여 점유를 승계한 현 점유자는 자신의 전 점유자에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 전 점유자의 소유자에 대한 소유권이전등기청구권을 대위행사할 수도 있고, 전 점유자의 취득시효 완성의 효과를 주장하여 직접 자기에게 소유권이전등기를 청구할 권원도 있다.
- ③ 자기소유의 부동산을 점유하고 있는 상태에서 다른 사람 명의로 소유권이전등기가 된 경우 자기소유 부동산을 점유하는 것은 취득시효의 기초로서의 점유라고 할 수 없고 그 소유권의 변동이 있는 경우에 비로소 취득시효의 기초로서의 점유가 개시되는 것이므로 그 점유가 자주점유라면 취득시효의 기산점은 소유권의 변동일(소유권이전등기일)이 되어야 할 것이다.
- ④ 국유재산 중 행정재산만을 제외하고 보존재산과 잡종재산은 시효취득이 가능하다.
- ⑤ 판례는 토지에 대한 점유취득시효에 관하여 부동산 일부에 대한 시효취득을 인정한 바 있다.

②. 전 점유자의 점유를 승계한 자는 그 점유 자체와 하자만을 승계하는 것이지 그 점유로 인한 법률효과까지 승계하는 것은 아니므로 부동산을 취득시효기간 만료 당시의 점유자로부터 양수하여 점유를 승계한 현 점유자는 자신의 전 점유자에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 전 점유자의 소유자에 대한 소유권이전등기청구권을 대위행사할 수 있을 뿐, 전 점유자의 취득시효 완성의 효과를 주장하여 직접 자기에게 소유권이전등기를 청구할 권원은 없다(대판[전합] 1995. 3. 28, 93다47745).

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 점유자가 스스로 매매나 증여와 같은 자주점유의 권원을 주장하였으나 이것이 인정되지 않더라도 자주점유의 추정이 깨어지지는 아니한다.
 - ② 등기를 수반하지 아니한 점유임이 밝혀졌다고 하여 이 사실만 가지고 바로 점유권원의 성질상 소유의 의사가 결여된 타주점유라고 할 수 없다.
 - ③ 토지 점유자가 점유기간 동안 여러 차례 부동산소유권이전등기등에관한특별조치법이 시행됨에 따라 등기의 기회가 있었음에도 불구하고 소유권이전등기를 하지 않았고 오히려 소유자가 같은 법에 의하여 소유권보존등기를 마친 후에도 별다른 이의를 하지 않은 경우, 자주점유의 추정이 반복될 수 있다.
 - ④ 성명불상자의 소유물에 대하여 시효취득을 인정할 수 있다.
 - ⑤ 자기 소유의 부동산이 시효취득의 목적물이 될 수 있는지에 대하여 판례는 일관되게 부정하고 있다.
- ⑤. 판례의 태도는 일관적이지 않다.(긍정한 예 : 시효취득의 목적물은 타인의 부동산임을 요하지 않고 자기 소유의 부동산이라도 시효취득의 목적물이 될 수 있다(대판 2001.07.13., 2001다17572)).

♣ 학습정리

1. 부동산 점유취득시효의 요건은 20년의 평온·공연·자주점유이다.
2. 시효 제도는 일정한 사실상태가 오랫동안 계속되었을 때, 그 상태가 진실한 권리관계와 일치하는가의 여부를 묻지 않고, 그 사실 상태를 그대로 권리관계로 인정하는 제도로, 취득시효 제도는 법적 안정성을 기하고 입증의 어려움으로 인한 혼란 회피라는 제도적 의의를 가진다.
3. 자기소유의 부동산을 점유하고 있는 상태에서 다른 사람 명의로 소유권이전등기가 된 경우라면 그리고 그 점유가 자주점유인 것이라면 그 취득시효의 기산점은 소유권의 변동일(소유권이전등기일)이 되어야 한다.
4. 소유자가 동일하고 점유승계도 없는 경우에도 기산점은 임의로 선택하여도(역산하여도) 무방하다. 즉 취득시효를 주장하는 자는 소유자의 변동이 없는 토지에 관하여는 취득시효의 기산점을 임의로 선택할 수 있고, 취득시효를 주장하는 날로부터 역산하여 20년 이상의 점유사실이 인정되고 그 점유가 자주점유가 아닌 것으로 밝혀지지 않는 한 취득시효를 인정할 수 있다.
5. 소유자의 변동이 있고 점유자의 승계가 없는 경우에는, 기산점을 임의로 선택할 수 없다.

제18강 취득시효 (2)

♣ 학습목표

- 등기부취득시효에 대하여 설명할 수 있다.
- 동산소유권, 기타 재산권의 시효취득에 대하여 정리할 수 있다.
- 취득시효 완성의 효과를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 등기부취득시효의 요건
- 동산소유권의 시효취득
- 기타 재산권의 시효취득
- 취득시효의 중단, 정지, 시효이익 포기
- 취득시효 완성의 효과

♣ 사전 테스트

1. 시효취득의 목적물은 타인의 부동산이어야 하고, 자기 소유의 부동산은 시효취득의 목적물이 될 수 없다.
⇒ × : 대법원은 '시효취득의 목적물은 타인의 부동산임을 요하지 않고 자기 소유의 부동산이라도 시효취득의 목적물이 될 수 있다'고 판시한 바 있다(대판 2001.07.13., 2001다17572).
2. 국유재산은 시효취득이 불가능하다.
⇒ × : 국유재산 중 행정재산만을 제외하고 보존재산과 잡종재산은 시효취득이 가능하다.
3. 취득시효완성 후 토지소유자에 변동이 있으면, 소유자가 변동된 시점을 새로운 기산점으로 삼아도 다시 취득시효기간이 완성되었더라도 취득시효의 완성을 주장할 수 없다.
⇒ × : 취득시효완성 후 토지소유자에 변동이 있고, 소유자가 변동된 시점을 새로운 기산점으로 삼아도 다시 취득시효기간이 완성되는 경우 취득시효의 완성을 주장할 수 있다.

♣ 강의교안

1. 등기부취득시효의 요건

(1) 점유

선의·무과실 : ㉠ 점유에 관한 것 / 등기에 관한 것 ×

㉡ 점유개시시만 / 전 시효기간을 통하여 ×

- 선의는 제197조 제1항에 의하여 추정
- 무과실의 추정 규정은 없으므로 시효취득을 주장하는 점유자가 증명책임 부담
- 특별한 사정이 없는 한 등기부상의 명의인을 소유자로 믿고 부동산을 매수하여 점유 : 무과실(∴ 등기의 추정력)
- 처분자 명의로 등기가 경료되어 있더라도 그 등기가 정당하지 않은 것으로 의심할 만한 상당한 이유가 있는 경우 : 과실
- 매도인에게 그 부동산을 처분한 권한이 있는지 여부를 조사하지 않은 경우 : 과실
- 본인의 대리인으로서 처분권한을 위임받았다고 칭하는 자로부터 부동산을 매수하는 자가 직접 본인에 대하여 대리권의 유무를 확인하지 않은 경우 : 과실

(2) 등기

적법·유효한 등기일 것을 요구하지 않고 무효등기도 무방하나(대판 1994. 2. 8, 93다23367), 중복등기기록 중 폐쇄되어야 하는 보존등기나 그에 터 잡은 이전등기를 근거로 한 등기부취득시효는 부정된다(대판 2011. 7. 14, 2010다107064).

상속인의 경우 등기 없이도 등기부취득시효를 완성시킬 수 있다(대판 1989.12.26, 89다카6140).

(3) 점유와 등기의 계속

등기기간과 점유기간은 각각 10년이어야 한다.

등기기간 - 10년(전 등기명의자의 등기의 승계 긍정(등기에 대해서도 제199조 유추적용) : 대판(전) 1989. 12. 26, 87다카2176)

점유기간 - 10년(전 점유자의 점유 승계)

2. 동산소유권의 시효취득

10년간 소유의 의사로 평온·공연하게 동산을 점유한 자는 그 소유권을 취득한다(제246조 제1항). 그리고 점유를 개시한 때에 선의·무과실이였다면 5년간 점유함으로써 동산의 소유권을 취득한다(제246조 제2항).

그런데 동산에 관하여 선의취득이 인정되므로 제246조의 적용은 선의취득이 인정되지 않는 경우에 한하여 의미를 가진다.

3. 기타 재산권의 시효취득

제248조(소유권 이외의 재산권의 취득시효)

전3조의 규정은 소유권 이외의 재산권의 취득에 준용한다.

점유(또는 준점유)를 수반하는 권리 (→ 부양청구권이나 점유가 없는 저당권은 불가)
소유권이 아니므로 “소유의 의사” 요건은 요구되지 않는다.

4. 취득시효의 중단, 정지, 시효이익 포기

소멸시효의 중단에 관한 규정은 취득시효에 준용되고(제247조 제2항), 정지에 관한 규정도 다수설은 유추적용을 긍정하고 있으며, 시효이익 포기에 관한 규정 역시 판례는 유추적용하여 취득시효가 완성된 후에 시효이익을 포기할 수 있다고 한다.

(1) 중단

제247조(소유권취득의 소급효, 중단사유)

②소멸시효의 중단에 관한 규정은 전2조의 소유권취득기간에 준용한다.

① 청구 : 소유자로서 점유자를 상대로 소유권에 기한 반환·방해배제청구, 부당이득반환청구. 재판상 청구는 물론이고 재판외 청구도 중단사유에 해당한다. 반면 점유자가 소유자를 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하면서 청구원인을 취득시효의 완성이 아니라 매매로 주장한 경우에는 취득시효가 중단되지 않는다(대판 1997.12.12, 97다30288).

② 가처분 : 소유자로서 점유이전금지가처분, 등기부취득시효의 경우 점유자를 상대로 처분금지가처분 신청

③ 승인 : 점유자가 소유자의 소유권을 승인하는 경우(단순한 매수제외는 승인 ×)

* 압류, 가압류는 금전채권 또는 금전으로 환산가능한 채권에 관한 것이므로 취득시효에 준용 불가

재판상 청구에 의하여 소멸시효가 중단된 경우 재판확정시부터 시효가 새로이 진행하지만, 소유자가 점유자를 상대로 한 소송에서 승소의 확정판결을 얻은 경우에는 타주점유로 전환되고 시효가 다시 진행할 여지가 없다.

(i) 교육법의 규정에 의하면 교육, 학예에 관한 사항은 지방자치단체의 관장사무가 아니고 지방자치단체의 교육위원회의 관장사무이므로 국민학교 보건장부지로 점유하는 토지에 대하여는 지방자치단체가 소유자의 소유권을 승인하더라도 취득시효가 중단되지 않는다(대판 1974. 10. 25, 74다630·631).

(ii) 소유자의 토지인도 또는 매수요구에 대하여 점유자가 그때마다 경제적 사정이 여의치 못하여 살 수 없으니 잘 보아 달라고 말한 것은 점유자의 취득시효진행에 대한 중단사유인 승인이라고 볼 수 있다(대판 1972. 7. 25, 72다987).

(2) 정지

다수설은 소멸시효의 정지에 관한 규정을 유추적용 (반대하는 견해 : 입법자의 의사)

(3) 포기

- 1) 취득시효이익은 미리 포기하지 못한다(제184조 제1항 유추해석) → 따라서 시효기간 완성 후에는 포기 가능(따라서 현실적으로 등기부 취득시효에는 포기가 불가능하여 적용 없게 됨)

2) 시효이익 포기 인정의 예

- ① 시효취득자가 매도한 것을 인정하고 상대방에게 점유를 이전하여 준 경우(대판 1973. 6. 22, 72다2170)
- ② 취득시효완성 후 상대방의 소유를 인정하여 상대방과 합의한 다음 訴를 취하한 경우(대판 1973. 9. 29, 73다762)
- ③ 시효이익의 포기각서를 작성한 경우(대판 1974. 11. 26, 74다1043)
- ④ 무단점유를 시인하면서 변상금 납부의 유예를 요청한 경우(대판 1995. 4. 14, 95다3756)
- ⑤ 국가소유의 토지를 점유하던 자가 관리청과 토지를 대부받기로 하는 내용의 계약을 체결하고 토지를 점유하여 왔다면, 위 대부계약이 체결된 이후부터의 점유는 타주점유로 볼 것이고 (대판 1994. 4. 12, 93다62287; 시효기간 만료 후 대부계약체결과 비교. 아래 판례 참조), 따라서 시효이익의 포기가 있다.

3) 시효이익 포기 부정의 예

- ① 점유로 인한 부동산소유권의 취득기간이 경과한 뒤에 점유자가 소유자에게 그 부동산을 매수하자고 제의한 일이 있었다는 것만으로는 점유자가 위 부동산이 그 소유자의 소유임을 승인하여 타주점유로 전환되었다거나 시효이익을 포기하였다고는 볼 수 없다(대판 1992. 9. 1, 92다26543).
- ② 또한 농지분배를 신청한 경우에 그러한 사실이 있더라도 타주점유로 전환하였다가 시효이익을 포기하였거나 볼 수 없다고 한다(대판 1992. 11. 24, 92다29825).
- ③ 20년간 소유의 의사로 평온 공연하게 군 소유의 임야를 점유한 자가 그 후 군과 사이에 임야에 관하여 대부계약을 체결하였다 하더라도 달리 적극적인 의사표시를 하지 않은 이상 취득시효완성의 이익을 포기한 것으로 보기 어렵다(대판 1992. 12. 22, 92다46097).
- ④ 점유자의 취득시효 완성 후 소유자가 토지에 대한 권리를 주장하는 소를 제기하여 승소판결을 받은 사실이 있다고 하더라도 그 판결에 의하여 시효중단의 효력이 발생할 여지는 없고, 점유자가 그 소송에서 그 토지에 대한 시효취득을 주장하지 않았다고 하여 시효이익을 포기한 것이라고도 볼 수 없으며 그 토지에 대한 점유자의 점유가 평온, 공연한 점유가 아니게 되는 것도 아니다(대판 1996. 10. 29, 96다23573-23580).

[판례] 포기를 인정한 사례

- (1) 국유재산을 점유하여 취득시효가 완성된 후 국가와 국유재산 대부계약을 체결하고 대부료를 납부한 사실만으로는 취득시효 완성의 이익을 포기하는 적극적인 의사표시를 한 것으로 보기는 어렵지만, 그러한 대부계약이 아무런 하자 없이 여러 차례에 걸쳐 체결되었다거나, 단순히 대부계약의 체결에 그치지 않고 그 계약 전에 밀린 점용료를 변상금이란 명목으로 납

부하는 데까지 나아갔다면 그러한 대부계약 체결이나 변상금 납부는 국가의 소유권을 인정하고 취득시효 완성의 이익을 포기한다는 적극적인 의사표시를 한 것으로 봄이 상당하다(대판 2007. 4. 13, 2006다62546; 대판 1994. 11. 22, 94다32511; 대판 1998. 3. 10, 97다53304 참조).

- (2) 취득시효기간 만료 후 국가에 대하여 무단점유 사실을 확인하면서 당해 토지에 관하여 어떠한 권리도 주장하지 아니한다는 내용의 각서를 작성·교부하였고, 국가와 사이에 당해 토지를 대부하되 대부기간이 만료되거나 계약이 해지될 경우 지정한 기간 내에 원상으로 회복하여 반환하고 당해 토지에 관한 연고권을 주장할 수 없다는 내용의 국유재산 대부계약을 체결하였으며, 당해 토지를 권원 없이 점용한 데 대한 변상금 및 대부계약에 따른 대부료를 납부한 경우, 점유자는 취득시효완성의 이익을 포기하는 적극적인 의사표시를 하였다(대판 1998. 5. 22, 96다24101).
- (3) 토지의 점유자가 그 소유자에게, 소유자가 점유자를 상대로 한 소송의 확정판결에서 점유자로 하여금 소유자에게 임료 상당의 부당이득으로 지급할 것을 명한 매월 금 107,300원보다 거의 배나 되는 매월 금 200,000원씩을 지급하기로 하고 그 금원을 4년여 동안이나 아무 이의 없이 지급하여 온 이상 점유자가 소유자에게 매월 금 200,000원씩을 지급하기로 합의한 것은 단순히 판결에 기한 강제집행을 모면하기 위한 일시적 방편이라고 하기보다는 이로써 점유자와 소유자 사이에 토지에 관한 임대차계약이 체결된 것으로 보아야 하고, 따라서 점유자는 그 토지에 관한 시효 완성의 사실을 알고 그 이익을 포기한 것으로 추정함이 상당하다(대판 1997. 10. 24, 97다14606).
- (4) 취득시효 완성 후 관할관청에 무단점유로 인한 변상금을 이의 없이 납부하고 국유재산 대부계약을 체결한 경우, 시효이익을 포기하였다(대판 1995. 9. 29, 94다60301).

▶ 돌발 퀴즈

20년간 소유의 의사로 평온 공연하게 군 소유의 임야를 점유한 자가 그 후 군과 사이에 임야에 관하여 대부계약을 체결하였다면 취득시효완성의 이익을 포기한 것으로 볼 수 있다.

⇒ × : 20년간 소유의 의사로 평온 공연하게 군 소유의 임야를 점유한 자가 그 후 군과 사이에 임야에 관하여 대부계약을 체결하였다 하더라도 달리 적극적인 의사표시를 하지 않은 이상 취득시효완성의 이익을 포기한 것으로 보기 어렵다(대판 1992. 12. 22, 92다46097).

5. 취득시효 완성의 효과

(1) 권리취득 : 원시취득

점유취득시효는 점유함으로써 소유권 및 기타 재산권을 취득한다. 원소유자에 대하여 부당이득반환의무를 부담하지 않는다(법률의 규정에 의한 이익취득이므로 법률상 원인 있다).

[판례] 대법원 2003. 11. 13. 선고 2002다57935 판결

건물 공유자 중 일부만이 당해 건물을 점유하고 있는 경우라도 그 건물의 부지는 건물 소유를 위하여 공유명의자 전원이 공동으로 이를 점유하고 있는 것으로 볼 것이며, 건물 공유자들이 건물부지의 공동점유로 인하여 건물부지에 대한 소유권을 시효취득하는 경우라면 그 취득시효

완성을 원인으로 한 소유권이전등기청구권은 당해 건물의 공유지분비율과 같은 비율로 건물 공유자들에게 귀속된다.

Q : 시효취득의 목적물 위에 존재했던 부담 또는 제한물권(용익물권·담보물권)은 소멸?

A : 원시취득설(통설·판례) → 시효취득의 목적물 위에 존재했던 제한물권은 원칙적으로 소멸.
단 학설·판례대립

- ① 원시취득설 : 모든 제한물권은 소멸한다는 견해
시효취득자의 “용인” 여부로 판단하는 견해
- ② 승계취득설 : 부담은 소멸하지 않고 당연히 승계한다
- ③ 판례 : 시효완성 “전에” 부담 또는 제한이 설정되었느냐 “후에” 제한물권이 설정되었느냐로 판단

원시취득설

- ① 원소유자의 권리 위에 존재하던 제한은 원칙적으로 소멸하고 특별한 사정이 없는 한 시효완성자는 원 소유자의 소유권에 가하여진 각종 제한에 의하여 영향을 받지 않는 완전한 내용의 소유권을 취득한다.
- ② 그러나 시효의 기초인 점유 자체가 이미 그 위에 존재하는 타인의 권리(가령 지역권)에 의한 제한을 용인하면서 행하여졌다면 그러한 제한 있는 소유권을 취득한다.

승계취득설

소급효를 갖는 특수한 승계취득이다. 취득시효등기 전에 담보물권(또는 담보가등기)이 설정되어 있는 경우에 그 담보물권은 시효취득등기에 관계없이 존속하여야 한다는 것을 근거(용익물권이 설정되어 있다면 20년간 행사하지 않은 경우는 용익물권 자체가 소멸시효에 걸릴 것이며, 용익물권자의 권리행사가 있었다면 시효취득이 불가능할 것이다))

판례 : 원시취득으로 보면서 시효완성 후 등기 전에 원소유자가 토지의 현상변경(원소유자가 그 대지 부분에 건물을 신축) 또는 제한물권을 설정한 경우(소유권이전등기청구권 가등기)에는 시효완성자는 그 부담을 안고 소유권을 취득하는 것으로 본다.

즉 판례는 원시취득이라고 하면서도(대판 2004. 9. 24, 2004다31463), 취득시효완성 후 그 등기 전에는 소유자의 처분이 가능하므로 시효완성 후 등기 전에 설정된 부담이나 제한은 소멸하지 않는다(대판 1999. 7. 9, 97다53632)고 판시하여, 시효완성 전에 제한이나 부담이 설정된 경우에 등기를 경로하여 시효취득을 하면 그 제한이나 부담은 소멸하고, 시효완성 후에 그 등기 전에 설정된 부담이나 제한은 소멸하지 않는다는 태도를 보이고 있다.

[판례] 취득시효 완성 후 등기 전에 설정된 부담이나 제한의 소멸여부

인접 대지의 경계를 침범하여 건물을 소유하고 있던 점유자가 그 대지 부분에 대한 취득시효가 완성되었으나 이를 자신의 소유로 알고 원소유자에 대하여 취득시효완성을 이유로 그

권리를 주장하거나 이전등기청구권을 행사하지 아니하다가 취득시효완성 사실을 모르고 있던 원소유자가 그 대지 부분에 건물을 신축한 후에 취득시효완성을 원인으로 소유권이전등기를 경료한 경우, 원소유자가 건물을 신축함으로써 점유자의 그 대지 부분에 대한 점유의 상태가 변경된 뒤에야 점유자가 그 대지 부분에 관한 소유권이전등기를 경료하였으므로, 점유자로서는 그 지상에 위 건물이 존재한 상태로 대지의 소유권을 취득하였다고 할 것이어서 원소유자에 대하여 위 건물의 철거를 구할 수 없다(대판 1999. 7. 9, 97다53632).

[판례]

부동산점유취득시효는 20년의 시효기간이 완성한 것만으로 점유자가 곧바로 소유권을 취득하는 것은 아니고 민법 제245조에 따라 점유자 명의로 등기를 함으로써 소유권을 취득하게 되며, 이는 원시취득에 해당하므로 특별한 사정이 없는 한 원소유자의 소유권에 가하여진 각종 제한에 의하여 영향을 받지 아니하는 완전한 내용의 소유권을 취득하게 되고, 이와 같은 소유권취득의 반사적 효과로서 그 부동산에 관하여 취득시효의 기간이 진행중에 체결되어 소유권이전등기청구권가등기에 의하여 보전된 매매예약상의 매수인의 지위는 소멸된다고 할 것이지만, 시효기간이 완성되었다고 하더라도 점유자 앞으로 등기를 마치지 아니한 이상 전 소유권에 붙어 있는 위와 같은 부담은 소멸되지 아니한다(대판 2004. 9. 24, 2004다31463).

(2) 소급효

제247조(소유권취득의 소급효, 중단사유)

① 전2조의 규정에 의한 소유권취득의 효력은 점유를 개시한 때에 소급한다.

- 시효제도는 계속된 사실상태를 보호하기 위한 것이므로 등기를 함으로써 점유개시시점으로 소급하여 소유권을 취득한다. 그 취지는 점유기간 중 무권리의 상태에서 점유함에 따라 소유자에 대하여 부담하는 손해배상책임 등이 소급하여 그 효력을 상실한다는 것이다. 또한 취득시효기간 중에 취득한 과실, 사용이익은 정당한 권원에 의한 것이 되어 소유자에게 반환할 필요가 없다.

- 취득시효기간 중에, 그리고 점유취득시효에서는 등기가 경료되기까지의 기간 중에 점유자가 한 임대나 기타의 처분은 소급효 때문에 유효한 것으로 되지만, 그렇다고 하여 그 기간 중에 원소유자가 한 처분이 무효로 되는 것은 아니다.

따라서 점유자가 원소유자에 대하여 점유로 인한 취득시효기간이 만료되었음을 이유로 취득시효완성을 원인으로 한 소유권이전등기청구를 하는 등 그 권리행사를 하거나 원소유자가 취득시효완성 사실을 알고 점유자의 권리취득을 방해하려고 하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 원소유자는 점유자 명의로 소유권이전등기가 경료되기까지는 소유자로서 그 토지에 관한 적법한 권리를 행사할 수 있다고 할 것이므로, 그 권리행사로 인하여 점유자의 토지에 대한 점유의 상태가 변경되었다면, 그 뒤 소유권이전등기를 경료한 점유자는 변경된 점유의 상태를 용인하여야 하는 것이다(대법원 1999.07.09. 선고 97다53632 판결).

- 원소유자가 취득시효의 완성 이후 그 등기가 있기 전에 그 토지를 제3자에게 처분하거나 제한물권의 설정, 토지의 현상 변경 등 소유자로서의 권리를 행사하였다 하여 시효취득자에 대한 관계에서 불법행위가 성립하는 것이 아님은 물론 위 처분행위를 통하여 그 토지의 소유권이 나 제한물권 등을 취득한 제3자에 대하여 취득시효의 완성 및 그 권리취득의 소급효를 들어 대

항할 수도 없다 할 것이니, 이 경우 시효취득자로서는 원소유자의 적법한 권리행사로 인한 현상의 변경이나 제한물권의 설정 등이 이루어진 그 토지의 사실상 혹은 법률상 현상 그대로의 상태에서 등기에 의하여 그 소유권을 취득하게 된다. 따라서 시효취득자가 원소유자에 의하여 그 토지에 설정된 근저당권의 피담보채무를 변제하는 것은 시효취득자가 용인하여야 할 그 토지상의 부담을 제거하여 완전한 소유권을 확보하기 위한 것으로서 그 자신의 이익을 위한 행위라 할 것이니, 위 변제액 상당에 대하여 원소유자에게 대위변제를 이유로 구상권을 행사하거나 부담이득을 이유로 그 반환청구권을 행사할 수는 없다 할 것이다(대법원 2006.05.12. 선고 2005다75910 판결).

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 등기부취득시효의 등기는 적법·유효한 등기일 것을 요구하지 않고 무효등기도 무방하다.
- ② 중복등기기록 중 폐쇄되어야 하는 보존등기나 그에 더 잡은 이전등기를 근거로 한 등기부취득시효도 인정된다.
- ③ 상속인의 경우 등기 없이도 등기부취득시효를 완성시킬 수 있다.
- ④ 10년간 소유의 의사로 평온·공연하게 동산을 점유한 자는 그 소유권을 취득한다.
- ⑤ 점유를 개시한 때에 선의·무과실이었다면 5년간 점유함으로써 동산의 소유권을 취득한다.

- ②. 중복등기기록 중 폐쇄되어야 하는 보존등기나 그에 더 잡은 이전등기를 근거로 한 등기부취득시효는 부정된다(대판 2011. 7. 14, 2010다107064).

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 점유자가 소유자를 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하면서 청구원인을 취득시효의 완성이 아니라 매매로 주장한 경우 취득시효가 중단되지 않는다.
- ② 소유자의 토지인도 또는 매수요구에 대하여 점유자가 그때마다 경제적 사정이 여의치 못하여 살 수 없으니 잘 보아 달라고 말한 것은 점유자의 취득시효진행에 대한 중단사유인 승인이라고 볼 수 있다.
- ③ 점유로 인한 부동산소유권의 취득기간이 경과한 뒤에 점유자가 소유자에게 그 부동산을 매수하자고 제의한 일이 있었다면 점유자가 위 부동산이 그 소유자의 소유임을 승인하여 타주 점유로 전환되었고 시효이익을 포기하였다고 볼 수 있다.
- ④ 20년간 소유의 의사로 평온 공연하게 군 소유의 임야를 점유한 자가 그 후 군과 사이에 임야에 관하여 대부계약을 체결하였다 하더라도 달리 적극적인 의사표시를 하지 않은 이상 취득시효완성의 이익을 포기한 것으로 보기 어렵다.
- ⑤ 점유자의 취득시효 완성 후 소유자가 토지에 대한 권리를 주장하는 소를 제기하여 승소판결을 받은 사실이 있다고 하더라도 그 판결에 의하여 시효중단의 효력이 발생할 여지는 없고, 점유자가 그 소송에서 그 토지에 대한 시효취득을 주장하지 않았다고 하여 시효이익을 포기한 것이라고도 볼 수 없으며 그 토지에 대한 점유자의 점유가 평온, 공연한 점유가 아니게 되는 것도 아니다.

- ③. 점유로 인한 부동산소유권의 취득기간이 경과한 뒤에 점유자가 소유자에게 그 부동산을 매수하자고 제의한 일이 있었다는 것만으로는 점유자가 위 부동산이 그 소유자의 소유임을 승인하여 타주점유로 전환되었다거나 시효이익을 포기하였다고는 볼 수 없다(대판 1992. 9. 1, 92다26543).

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 건물 공유자 중 일부만이 당해 건물을 점유하고 있는 경우라도 그 건물의 부지는 건물 소유를 위하여 공유명의자 전원이 공동으로 이를 점유하고 있는 것으로 볼 것이며, 건물 공유자들이 건물부지의 공동점유로 인하여 건물부지에 대한 소유권을 시효취득하는 경우라면 그 취득시효 완성을 원인으로 한 소유권이전등기청구권은 당해 건물의 공유지분비율과 같은 비율로 건물 공유자들에게 귀속된다.
 - ② 취득시효완성 후 그 등기 전에는 소유자의 처분이 가능하므로 시효완성 후 등기 전에 설정된 부담이나 제한은 소멸하지 않는다.
 - ③ 취득시효로 인한 소유권취득의 효력은 점유를 개시한 때에 소급한다.
 - ④ 취득시효로 인한 소유권취득은 원칙적으로 원시취득이다.
 - ⑤ 시효취득자가 원소유자에 의하여 그 토지에 설정된 근저당권의 피담보채무를 변제한 경우, 변제액 상당에 대하여 원소유자에게 대위변제를 이유로 구상권을 행사하거나 부당이득을 이유로 그 반환청구권을 행사할 수 있다.
- ⑤. 시효취득자가 원소유자에 의하여 그 토지에 설정된 근저당권의 피담보채무를 변제하는 것은 시효취득자가 용인하여야 할 그 토지상의 부담을 제거하여 완전한 소유권을 확보하기 위한 것으로서 그 자신의 이익을 위한 행위라 할 것이니, 위 변제액 상당에 대하여 원소유자에게 대위변제를 이유로 구상권을 행사하거나 부당이득을 이유로 그 반환청구권을 행사할 수는 없다 할 것이다(대법원 2006.05.12. 선고 2005다75910 판결).

♣ 학습정리

- 1. 등기부취득시효에서 등기는 적법·유효한 등기일 것을 요하지 않고 무효등기도 무방하다.
- 2. 점유자가 소유자를 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하면서 청구원인을 취득시효의 완성이 아니라 매매로 주장한 경우에는 취득시효가 중단되지 않는다.
- 3. 점유로 인한 부동산소유권의 취득기간이 경과한 뒤에 점유자가 소유자에게 그 부동산을 매수하자고 제의한 일이 있었다는 것만으로는 점유자가 위 부동산이 그 소유자의 소유임을 승인하여 타주점유로 전환되었다거나 시효이익을 포기하였다고는 볼 수 없다.
- 4. 취득시효완성 후 그 등기 전에는 소유자의 처분이 가능하므로 시효완성 후 등기 전에 설정된 부담이나 제한은 소멸하지 않는다.
- 5. 시효취득자가 원소유자에 의하여 그 토지에 설정된 근저당권의 피담보채무를 변제한 경우, 변제액 상당에 대하여 원소유자에게 대위변제를 이유로 구상권을 행사하거나 부당이득을 이유로 그 반환청구권을 행사할 수는 없다.

제19강 취득시효 (3), 선점·습득·발견

♣ 학습목표

점유취득시효 완성 후 등기 전의 법률관계를 정리할 수 있다.
무주물 선점, 유실물 습득, 매장물 발견에 대하여 정리할 수 있다.

♣ 학습내용

- 점유취득시효 완성 후 등기 전의 법률관계
- 무주물 선점
- 유실물 습득
- 매장물 발견

♣ 사전 테스트

1. 점유자가 소유자를 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하면서 청구원인을 취득시효의 완성이 아니라 매매로 주장한 경우에는 취득시효가 중단된다.
⇒ × : 점유자가 소유자를 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하면서 청구원인을 취득시효의 완성이 아니라 매매로 주장한 경우에는 취득시효가 중단되지 않는다.
2. 점유로 인한 부동산소유권의 취득기간이 경과한 뒤에 점유자가 소유자에게 그 부동산을 매수하자고 제의한 일이 있었다면 점유자가 위 부동산이 그 소유자의 소유임을 승인하여 타주점유로 전환되었고 시효이익을 포기하였다고 볼 수 있다.
⇒ × : 점유로 인한 부동산소유권의 취득기간이 경과한 뒤에 점유자가 소유자에게 그 부동산을 매수하자고 제의한 일이 있었다는 것만으로는 점유자가 위 부동산이 그 소유자의 소유임을 승인하여 타주점유로 전환되었다거나 시효이익을 포기하였다고는 볼 수 없다.
3. 시효취득자가 원소유자에 의하여 그 토지에 설정된 근저당권의 피담보채무를 변제한 경우, 변제액 상당에 대하여 원소유자에게 대위변제를 이유로 구상권을 행사하거나 부당이득을 이유로 그 반환청구권을 행사할 수 있다.
⇒ × : 시효취득자가 원소유자에 의하여 그 토지에 설정된 근저당권의 피담보채무를 변제한 경우, 변제액 상당에 대하여 원소유자에게 대위변제를 이유로 구상권을 행사하거나 부당이득을 이유로 그 반환청구권을 행사할 수는 없다.

♣ 강의교안

(3) 점유취득시효에서 시효 완성 후 등기 전의 법률관계

1) 시효권리자와 원소유자와의 관계

시효권리자(시효취득자)는 소유명의자에 대하여 “채권적인” 등기청구권을 갖는다(대판 1993. 9. 14, 93다10989)

→ 등기 전에는 아직 소유자가 아니지만, 시효가 완성됨에 따라 시효권리자에게 등기를 해 줄 의무를 지는 소유명의자는 시효권리자에 대하여 불법점유임을 이유로 건물의 철거 및/또는 대지의 인도를 청구할 수 없고(대판 1988. 5. 10, 87다카1979), 점유로 인한 부당이득의 반환청구도 할 수 없다(대판 1993. 5. 25, 92다51280). 나아가 소유권 확인을 구할 법률상 이익도 없다(대판 1996. 6. 9, 94다13480).

→ 다만 채권자의 지위에 있으므로 진정한 소유자를 대위하여 무효인 등기명의인에 대하여 원인무효인 소유권이전등기의 말소를 구할 수 있다(대판 1993. 9. 14, 93다10989).

2) 시효완성 후 그 등기 전에 제3자에게 소유권이 이전된 경우

① 시효완성 후 그 등기 전에 제3자가 먼저 이전등기를 경료한 경우에는 마치 이중매매에서의 법률관계와 유사하게 그 이전등기가 당연무효가 아닌 한 소유자의 이전등기의무는 이행불능으로 되어 완성자는 제3자에 대하여 시효취득을 주장할 수 없다(대판 1986. 8. 19, 85다카2306). 그러나 가등기는 본등기의 순위보전의 효력을 가지는 것에 불과하고 또한 그 소유권 이전등기 의무자의 처분권한이 상실되지도 아니하므로 그 가등기만으로는 소유권이전등기의무가 이행불능이 된다고 할 수 없다(대판 1991. 7. 26, 91다8104)

이와는 달리 부동산소유권이전등기 의무자가 그 부동산에 관하여 제3자 앞으로 비록 채무담보를 위하여 소유권이전등기를 경료하였다고 할지라도 그 의무자가 채무를 변제할 자력이 없는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 소유권이전등기의무는 이행불능이 된다(대판 1991. 7. 26, 91다8104).

② 소유자의 처분과 불법행위

(i) 부동산에 관한 취득시효가 완성된 후에 취득시효를 주장하거나 이로 인한 소유권이전등기를 청구하기 전에는 등기명의자인 부동산소유자로서는 특단의 사정이 없는 한 그 시효취득 사실을 알 수 없으므로 이를 제3자에게 처분하였다고 하더라도 점유자에 대하여 불법행위가 되지 않는다(대판 1974. 6. 11, 73다1276).

(ii) 그러나 부동산 소유자가 취득시효가 완성된 사실을 알고 그 부동산을 제3자에게 처분하여 소유권이전등기를 넘겨줌으로써 취득시효 완성을 원인으로 한 소유권이전등기의무가 이행불능에 빠지게 되어 시효취득을 주장하는 자가 손해를 입었다면 불법행위를 구성한다고 할 것이고, 부동산을 취득한 제3자가 부동산 소유자의 이와 같은 불법행위에 적극 가담하였다면 이는 사회질서에 반하는 행위로서 무효라고 할 것이다(대판 2002. 3. 15, 2001다77352·77369). 구체적으

로 시효취득을 주장하는 권리자가 취득시효를 주장하거나, 소유권이전등기청구소송을 제기하여 그에 관한 증명까지 마쳤다면 부동산소유자로서는 시효취득의 사실을 알 수 있다 할 것이다(대판 1994. 4. 12, 93다60779).

③ 소유자의 처분과 채무불이행책임

(i) 취득시효완성자는 자신에 대한 이전등기의무가 이행불능에 빠졌음을 이유로 제390조에 의하여 채무불이행으로 인한 손해배상을 청구할 수 있는지가 문제된다. 이에 관하여 판례는 부동산점유자에게 시효취득으로 인한 소유권이전등기청구권이 있다고 하더라도 이로 인하여 부동산소유자와 시효취득자 사이에 계약상의 채권채무관계가 성립하는 것은 아니므로 그 부동산을 처분한 소유자에게 채무불이행책임을 물을 수 없다고 한다(대판 1995. 7. 11, 94다4509).

이러한 판례의 입장과는 달리, 취득시효완성자의 등기청구권을 채권적 청구권으로 보는 이상 법정의 채권·채무관계는 존재하며, 따라서 등기의무자의 귀책사유로 이행불능이 되면 채무불이행책임(이행불능당시의 시가의 손해)을 인정하여야 한다는 견해도 있다.

(ii) 점유자가 원소유자에 대하여 점유로 인한 취득시효기간이 만료되었음을 이유로 취득시효완성을 원인으로 한 소유권이전등기청구를 하는 등 그 권리행사를 하거나 원소유자가 취득시효완성 사실을 알고 점유자의 권리취득을 방해하려고 하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 원소유자는 점유자 명의로 소유권이전등기가 경료되기까지는 소유자로서 그 토지에 관한 적법한 권리를 행사할 수 있고, 따라서 그 권리행사로 인하여 점유자의 토지에 대한 점유의 상태가 변경되었다면, 그 뒤 소유권이전등기를 경료한 점유자는 변경된 점유의 상태를 용인하여야 한다(대판 1999. 7. 9. 97다53632, 건물을 신축한 사안으로서 건물의 철거를 구할 수 없다고 판시).

[판례] 부동산의 점유취득시효가 완성된 후 소유명의자의 의무의 범위

부동산의 소유명의자는 그 부동산에 대해 점유취득시효가 완성된 자에게 소유권이전등기를 하여 줄 의무를 부담하지만 그 시효가 완성된 자가 시효완성 후에 어떤 사정에 의하여 그 점유를 잃었다고 해서 그 점유자로부터 점유를 회수하여 다시 이를 시효가 완성된 자에게 돌려줄 의무까지 부담한다고 할 수 없다(대판 1997. 3. 28, 96다10638).

④ 대상청구권

취득시효완성자는 소유자를 상대로 이행불능에 따른 효과로서 대상청구권을 행사할 수 있는지가 문제된다. 판례는 취득시효가 완성된 토지가 수용됨으로써 취득시효완성을 원인으로 하는 소유권이전등기의무가 이행불능으로 된 경우에는 그 소유권이전등기청구권자는 이행불능으로 인하여 입은 손해를 한도로 대상청구권을 행사하여 토지소유자가 그 대가로서 지급받은 수용보상금의 반환을 청구할 수 있다고 한다(대판 1994. 12. 9, 94다25025). 그리고 이러한 대상청구권을 행사하기 위해서는 그 이행불능 전에 등기명의자에 대하여 점유로 인한 부동산소유권의 취득기간이 만료되었음을 이유로 그 권리를 주장하거나 등기청구권을 행사할 것을 요구하고 있다(대판 1996. 12. 10, 94다43825).

3) 시효완성 후 점유자가 부동산을 양도한 경우

① 점유승계자의 원소유자에 대한 소유권이전등기청구 방법

부동산을 취득시효기간 만료 당시의 점유자로부터 양수하여 점유를 승계한 현점유자는 자신의 전점유자에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 전점유자의 소유자에 대한 소유권이전등기청구권을 대위행사할 수 있을 뿐, 전점유자의 취득시효완성의 효과를 주장하여 직접 자기에게 소유권이전등기를 청구할 수 없다(대판[전합] 1995. 3. 28, 93다47745).

(4) 시효완성 후 등기가 경료된 경우

→ 점유 개시시 소급하여 소유권취득(제247조 제1항) → 취득시효기간 중 취득한 과실(사용이익포함)은 정당한 권원에 기한 것으로 되어 소유자에게 반환할 필요 없음

→ 등기부취득시효는 별도로 등기할 필요 없음

▶ 돌발 퀴즈

부동산의 소유명의자는 그 부동산에 대해 점유취득시효가 완성된 자에게 소유권이전등기를 하여 줄 의무를 부담하므로 그 시효가 완성된 자가 시효완성 후에 어떤 사정에 의하여 그 점유를 잃었다면 그 점유자로부터 점유를 회수하여 다시 이를 시효가 완성된 자에게 돌려 줄 의무가 있다.

⇒ × : 부동산의 소유명의자는 그 부동산에 대해 점유취득시효가 완성된 자에게 소유권이전등기를 하여 줄 의무를 부담하지만 그 시효가 완성된 자가 시효완성 후에 어떤 사정에 의하여 그 점유를 잃었다고 해서 그 점유자로부터 점유를 회수하여 다시 이를 시효가 완성된 자에게 돌려줄 의무까지 부담한다고 할 수 없다(대판 1997. 3. 28, 96다10638).

V-2. 선점·습득·발견

제252조(무주물의 귀속)

① 무주의 동산을 소유의 의사로 점유한 자는 그 소유권을 취득한다.

② 무주의 부동산은 국유로 한다.

③ 야생하는 동물은 무주물로 하고 사육하는 야생동물도 다시 야생상태로 돌아가면 무주물로 한다.

제253조(유실물의 소유권취득) 유실물은 법률에 정한 바에 의하여 공고한 후 6개월 내에 그 소유자가 권리를 주장하지 아니하면 습득자가 그 소유권을 취득한다. <개정 2013.4.5>

제254조(매장물의 소유권취득) 매장물은 법률에 정한 바에 의하여 공고한 후 1년내에 그 소유자가 권리를 주장하지 아니하면 발견자가 그 소유권을 취득한다. 그러나 타인의 토지 기타 물건으로부터 발견한 매장물은 그 토지 기타 물건의 소유자와 발견자가 절반하여 취득한다.

제255조(문화재의 국유)

- ① 학술, 기예 또는 고고의 중요한 재료가 되는 물건에 대하여는 제252조제1항 및 전2조의 규정에 의하지 아니하고 국유로 한다.
- ② 전항의 경우에 습득자, 발견자 및 매장물이 발견된 토지 기타 물건의 소유자는 국가에 대하여 적당한 보상을 청구할 수 있다. (무주물 선점자는? → 유추적용)

1. 무주물 선점(원시취득)

- (1) 부동산은 국유이므로 대상이 아님 결국 동산만 무주물 선점, 동산인 경우에도 학술·기예·고고의 중요한 재료는 국유이므로 대상이 아니다(제255조).
- (2) 선점 : 준법률행위 중 사실행위
소유의 의사를 가지고 하는 점유(제1항)
완전한 점유(사냥꾼이 사슴 사살 위치 알아야 선점/ 오소리 굴속을 막는 것은 선점)
- (3) 수렵법 수산업법 위반이어도 사법상 소유권 취득(다수설)
- (4) 무주물이 학술 등의 재료가 되면 제255조 제2항 유추하여 국가에게 보상청구.

2. 유실물 습득

(음식점 점원이 손님이 놓고 간 핸드폰을 습득한 경우→ 공고 후 6월 지나도 주인이 나타나지 않으면 음식점 주인이 소유권 취득)

(1) 요건

- 1) 유실물이란 점유자의 의사에 기하지 않고 그 점유를 떠난 물건으로盜品이 아닌 것이다. 유실물법은 특히 범죄자가 놓고 간 것으로 인정되는 물건(유실물법 제11조), 착오로 인하여 점유한 물건, 타인이 놓고 간 물건, 逸失한 가축을 준유실물로 한다(유실물법 제12조). 표류물, 침몰품에 관하여는 수난구호법 제35조 제3항, 제37조에서 규정한다.
- 2) 습득이란 유실물의 점유를 취득하는 것이다. 단순한 발견은 습득이 아니다. 선점과는 달리 소유의 의사는 필요로 하지 않는다. 습득자가 유실물임을 알 필요도 없다. 즉 객관적으로 유실물이면 된다.
- 3) 법률(여기서는 유실물법을 의미)이 정하는 바에 따라 공고 후 6월 내에 그 소유자가 권리를 주장하지 않아야 한다(제253조).

(2) 효과

- 1) 습득자는 원시취득(그러나 습득일로부터 7일 이내에 경찰서에 제출하여야 하고, 소유권을 취득한 날로부터 3개월 이내에 물건을 수취해야 하며, 그렇지 않은 경우 소유권을 상실(국고))

2) 보상금청구권

물건을 유실한 소유자를 알게 되었을 때에는 유실물은 소유자에게 반환되어야 하고 유실물습득에 의한 소유권취득은 성립하지 않는다. 이 경우에 소유자와 습득자의 관계는 사무관리가 되어(제734조), 보수청구권이 인정되지 않는다. 그러나 유실물법 제4조는 특례를 인정하여 유실물의 가액의 5/100 ~ 20/100의 범위 내에서 보상금을 취득자에게 지급하여야 한다고 규정하고 있다. 이를 인정하는 것이 공평에 적합하기 때문이다. 유실물의 가액이라 함은 원칙적으로 반환받을 당시의 가격이다 그러나 선박, 차량, 건축물, 그 밖에 일반인의 통행을 금지한 구내에서 타인의 물건을 습득한 자는 그 물건을 관리자에게 인계하여야 하고, 이 경우 선박, 차량, 건축물 등의 점유자를 습득자로 하는데, 보상금은 점유자와 실제로 물건을 습득한 자가 반씩 나누어야 한다.(동법 제10조).

- 3) 학술 등의 재료 : 국유로 하고 보상금청구권이 인정된다.

4) 습득자의 보관비 등

습득자의 보관비·광고비 기타의 필요비는 물건의 반환을 받는 자나 물건의 소유권을 취득하여 이를 인도받는 자의 부담으로 하며 그 지급의 확보를 위하여 유치권의 규정이 적용된다(유실물법 제3조).

3. 매장물의 발견

(1) 의의

埋藏物은 법률에 정한 바에 의하여 공고한 후 1년 내에 그 소유자가 권리를 주장하지 아니하면 발견자가 그 소유권을 취득한다(제254조). 그러나 타인의 토지 기타 물건으로부터 매장물을 발견하는 경우에는 토지 기타 물건의 소유자와 발견자가 절반씩 그 소유권을 취득(제254조 단서).

(2) 법적 성질

매장물 발견에 의한 소유권 취득은 법률행위가 아니다. 발견자에 대하여는 그 노고에 보상한다는 사고에 기하여, 또한 포장물의 소유자에 대하여는 그 소유권에 부수하는 이익으로서 소유권을 취득시키는 것이다. 따라서 공평의 관념에 기한 편의상의 규정에 지나지 않는다.

(3) 요건

1) 매장물일 것

매장물이라 함은 토지 그 밖의 포장물 속에 매장되어, 그 소유권이 누구에게 속하는지를 판별할 수 없는 물건을 말한다. 매장물이 된 원인은 인위적·자연적인 것인지를 불문한다. 매장물은

과거 누구의 소유에 속하고 있었고, 현재도 소유가 상속인을 통하는 등의 방법으로 계속될 가능성이 있어도 판별할 가능성이 없는 점에서 무주물과 구별된다. 매장물은 보통 동산이나, 그에 한할 필요는 없다(고건물이 매장되어 있는 경우).

2) 발견하였을 것

- ① 발견이란 매장물의 존재를 구체적·객관적으로 인식하는 것으로서 점유의 취득은 필요로 하지 않는다. 이 점에서 선점·습득과 구별된다. 선점·습득에 있어서는 물건의 점유취득이 중요함에 반하여 매장물에 있어서는 물건의 보호면으로부터 보아 발견 자체가 중요하기 때문이다.
- ② 타인을 사용하여 매장물을 발견한 경우에는, 그 타인의 고용목적이 매장물의 발굴이라면 사용자(고용주)가 발견자이지만, 그 외의 목적으로 고용된 노무자가 공사 중 우연히 발견한 경우에는 노무자가 발견자이다.

3) 공고후 1년이 경과할 것

(4) 효과

1) 소유권의 원시취득

발견자는 당연히 매장물의 소유권을 취득한다(제254조 본문). 포장물(토지·건물 등)이 발견자의 소유물인 때에는 발견자가 매장물의 전부를 취득하나, 포장물이 타인의 소유물인 때에는 소유자와 발견자가 절반하여 소유권을 취득한다(제254조 단서). 즉 공유관계가 성립한다.

2) 보상금청구권

공고한 후 1년 내에 소유자가 권리를 주장하면 발견자, 포장물 소유자는 매장물의 소유권을 취득하지 못하게 된다. 이 경우 발견자는 매장물 소유자에 대하여 보상금을 청구할 수 있다(유실물법 제13조 제1항·제4조).

3) 학술훈 등의 재료

국유로 하고 보상청구권이 인정된다.

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 시효권리자(시효취득자)는 소유명의자에 대하여 “채권적인” 등기청구권을 갖는다.
- ② 시효가 완성됨에 따라 시효권리자에게 등기를 해 줄 의무를 지는 소유명의자는 시효권리자에 대하여 불법점유임을 이유로 건물의 철거 및/또는 대지의 인도를 청구할 수 없다.
- ③ 시효완성 후 그 등기 전에 제3자가 먼저 이전등기를 경료한 경우 완성자는 제3자에 대하여 시효취득을 주장할 수 있다.

- ④ 부동산에 관한 취득시효가 완성된 후에 취득시효를 주장하거나 이로 인한 소유권이전등기를 청구하기 전에는 등기명의자인 부동산소유자로서는 이를 제3자에게 처분하였다고 하더라도 점유자에 대하여 불법행위가 되지 않는다.
 - ⑤ 시효취득을 주장하는 권리자가 취득시효를 주장하거나, 소유권이전등기청구소송을 제기하여 그에 관한 증명까지 마쳤다면 부동산소유자로서는 시효취득의 사실을 알 수 있다 할 것이다.
- ③. 시효완성 후 그 등기 전에 제3자가 먼저 이전등기를 경료한 경우에는 마치 이중매매에서의 법률관계와 유사하게 그 이전등기가 당연무효가 아닌 한 소유자의 이전등기의무는 이행불능으로 되어 완성자는 제3자에 대하여 시효취득을 주장할 수 없다(대판 1986. 8. 19, 85다카 2306).

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 부동산점유자에게 시효취득으로 인한 소유권이전등기청구권이 있다고 하더라도 이로 인하여 부동산소유자와 시효취득자 사이에 계약상의 채권채무관계가 성립하는 것은 아니므로 그 부동산을 처분한 소유자에게 채무불이행책임을 물을 수 없다.
 - ② 부동산의 소유명의자는 그 부동산에 대해 점유취득시효가 완성된 자에게 소유권이전등기를 하여 줄 의무를 부담하지만 그 시효가 완성된 자가 시효완성 후에 어떤 사정에 의하여 그 점유를 잃었다고 해서 그 점유자로부터 점유를 회수하여 다시 이를 시효가 완성된 자에게 돌려줄 의무까지 부담한다고 할 수 없다.
 - ③ 취득시효가 완성된 토지가 수용됨으로써 취득시효완성을 원인으로 하는 소유권이전등기의무가 이행불능으로 된 경우에는 그 소유권이전등기청구권자는 이행불능으로 인하여 입은 손해를 한도로 대상청구권을 행사하여 토지소유자가 그 대가로서 지급받은 수용보상금의 반환을 청구할 수 있다.
 - ④ 부동산을 취득시효기간 만료 당시의 점유자로부터 양수하여 점유를 승계한 현점유자는 자신의 전점유자에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 전점유자의 소유자에 대한 소유권이전등기청구권을 대위행사할 수 있다.
 - ⑤ 위 ④의 경우, 현점유자는 전점유자의 취득시효완성의 효과를 주장하여 직접 자기에게 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
- ⑤. 부동산을 취득시효기간 만료 당시의 점유자로부터 양수하여 점유를 승계한 현점유자는 자신의 전점유자에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 전점유자의 소유자에 대한 소유권이전등기청구권을 대위행사할 수 있을 뿐, 전점유자의 취득시효완성의 효과를 주장하여 직접 자기에게 소유권이전등기를 청구할 수 없다(대판[전합] 1995. 3. 28, 93다47745).

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 무주의 부동산은 국유로 한다.
- ② 유실물은 법률에 정한 바에 의하여 공고한 후 1년 내에 그 소유자가 권리를 주장하지 아니하면 습득자가 그 소유권을 취득한다.
- ③ 매장물은 법률에 정한 바에 의하여 공고한 후 1년내에 그 소유자가 권리를 주장하지 아니하면 발견자가 그 소유권을 취득한다.
- ④ 타인의 토지 기타 물건으로부터 발견한 매장물은 그 토지 기타 물건의 소유자와 발견자가 절반하여 취득한다.

- ⑤ 학술, 기예 또는 고고의 중요한 재료가 되는 물건에 대하여는 무주물, 유실물 및 매장물에 관한 민법의 규정에 의하지 아니하고 국유로 한다.
- ②. 유실물은 법률에 정한 바에 의하여 공고한 후 6개월 내에 그 소유자가 권리를 주장하지 아니하면 습득자가 그 소유권을 취득한다(제253조).

♣ 학습정리

1. 시효취득자는 소유명의자에 대하여 “채권적인” 등기청구권을 갖는다.
2. 시효완성 후 그 등기 전에 제3자가 먼저 이전등기를 경료한 경우 완성자는 제3자에 대하여 시효취득을 주장할 수 없다.
3. 부동산에 관한 취득시효가 완성된 후에 취득시효를 주장하거나 이로 인한 소유권이전등기를 청구하기 전에는 등기명의자인 부동산소유자로서는 이를 제3자에게 처분하였다고 하더라도 점유자에 대하여 불법행위가 되지 않는다.
4. 부동산점유자에게 시효취득으로 인한 소유권이전등기청구권이 있다고 하더라도 이로 인하여 부동산소유자와 시효취득자 사이에 계약상의 채권채무관계가 성립하는 것은 아니므로 그 부동산을 처분한 소유자에게 채무불이행책임을 물을 수 없다.
5. 유실물은 법률에 정한 바에 의하여 공고한 후 6개월 내에 그 소유자가 권리를 주장하지 아니하면 습득자가 그 소유권을 취득한다.

제20강 침부, 물권적 청구권 (1)

♣ 학습목표

침부에 대하여 설명할 수 있다.

물권적 청구권의 기초이론을 정리할 수 있다.

♣ 학습내용

- 침부의 의의, 인정근거
- 부합
- 혼화
- 가공
- 소유자의 물권적 청구권

♣ 사전 테스트

1. 시효권리자(시효취득자)는 소유명의자에 대하여 “물권적인” 등기청구권을 갖는다.
⇒ × : 시효권리자(시효취득자)는 소유명의자에 대하여 “채권적인” 등기청구권을 갖는다.
2. 부동산을 취득시효기간 만료 당시의 점유자로부터 양수하여 점유를 승계한 현점유자는 전점유자의 취득시효완성의 효과를 주장하여 직접 자기에게 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
⇒ × : 부동산을 취득시효기간 만료 당시의 점유자로부터 양수하여 점유를 승계한 현점유자는 자신의 전점유자에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 전점유자의 소유자에 대한 소유권이전등기청구권을 대위행사할 수 있을 뿐, 전점유자의 취득시효완성의 효과를 주장하여 직접 자기에게 소유권이전등기를 청구할 수 없다(대판[전합] 1995. 3. 28, 93다47745).
3. 유실물은 법률에 정한 바에 의하여 공고한 후 1년 내에 그 소유자가 권리를 주장하지 아니하면 습득자가 그 소유권을 취득한다.
⇒ × : 유실물은 법률에 정한 바에 의하여 공고한 후 6개월 내에 그 소유자가 권리를 주장하지 아니하면 습득자가 그 소유권을 취득한다(제253조).

♣ 강의교안

VI. 침부(부합·혼화·가공)

1. 침부의 의미

어떤 물건에 타인의 물건이 결합하거나, 또는 타인의 노력이 가하여지는 것을 침부라고 한다. 침부에는 부합(제256조·제257조)·혼화(제258조)·가공(제259조)이 있다. 이는 제3자의 법률행위에 의하지 않은 소유권취득의 원인이 된다.

- ① 물건 + 타인의 물건 : 1개의 물건으로 함 → 2개 물건으로 복구금지 / 소유자는 누구?
(→ 부합, 혼화)
- ② 물건 + 타인의 노력 : 1개의 물건으로 함 → 2개 물건으로 복구금지 / 소유자는 누구?
(→ 가공)

2. 인정근거

침부가 소유권취득의 원인이 되는 근거는 형식적으로는 물권법상의 일물일권주의를 유지하고 실질적으로는 경제적 단일성을 유지하여 소유권의 효용을 높이려는 데 있다. 즉, 소유자가 다른 수 개의 물건과 그에 가해진 노력이 결합하여 새로운 물건이 생긴 때(가공물)에 이것을 원상으로 돌리는 것이 물리적으로는 가능하더라도 사회경제상 심히 불이익하므로 그 복구를 금지하고 한 개의 물건으로 하여 어느 한 편의 소유에 귀속시키려는 데 있다.

3. 민법의 규정

- ① 침부에 의하여 생긴 물건은 1개의 물건으로 존속하고 복구는 인정하지 않는다. 이것이 침부의 중심적 효과이며 이에 관한 규정은 강행규정이다.
- ② 침부에 의하여 생긴 새 물건에 관하여는 새로이 소유자가 결정된다. 이에 관한 규정은 계약 자유의 원칙상 임의규정이다.
- ③ 침부에 의하여 소멸한 구물건의 소유자는 손실의 보상을 받는다. 즉 침부의 규정에 의하면 손해를 받은 자는 부당이득에 관한 규정(제741조)에 관하여 보상을 청구할 수 있다(제261조).
- ④ 침부의 결과 소멸한 구물건 위에 존재하였던 제3자의 권리는 원칙적으로 소멸하나 일정한 경우에는 예외적으로 보호되는데, 이에 관한 규정은 강행규정이다.

침부에 의하여 동산의 소유권이 소멸한 때에는 그 동산을 목적으로 한 다른 권리는 소멸하나(제260조 제1항), 구 물건의 소유자가 신 물건의 단독소유권을 취득하거나 공유자로 되는 경우 제3자의 권리는 신 물건 또는 공유지분에 존속하고(제260조 제2항), 제3자의 권리가 담보물권인 경우 물상대위의 법리에 따라 보상금 위에 존속하며, 용익물권이라면 부당이득의 법리에 따라 구제된다.

1. 부합

제256조(부동산에의 부합) 부동산의 소유자는 그 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득한다. 그러나 타인의 “권원에 의하여 부속”된 것은 그러하지 아니하다.

제257조(동산간의 부합) 동산과 동산이 부합하여 훼손하지 아니하면 분리할 수 없거나 그 분리에 과다한 비용을 요할 경우에는 그 합성물의 소유권은 주된 동산의 소유자에게 속한다. 부합한 동산의 주종을 구별할 수 없는 때에는 동산의 소유자는 부합당시의 가액의 비율로 합성물을 공유한다.

부합 : 소유자를 각각 달리하는 수 개의 물건이 결합하여 1개의 물건으로 되는 것
「부동산에의 부합(제256조)」과 「동산간의 부합(제257조)」에 관하여 규정

(1) 부동산에의 부합

부동산의 소유자는 그 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득한다(제256조 본문).

1) 요건

① 부합물

부합되는 물건(피부합물)은 부동산이어야 하는데, 토지·건물 어느 것이나 무방하다.

다수설은 제260조에서 전 4조의 규정에 의하여 동산의 소유권이 소멸한 때로 규정하고 있는 점에서 부동산에 부합하는 물건(부합물)은 동산에 한하는 것으로 본다. 그러나 판례는 부동산도 포함되는 것으로 보고 있다(대판 1994. 6. 10, 94다1606).

제260조(첨부의 효과)

- ① 전4조의 규정에 의하여 동산의 소유권이 소멸한 때에는 그 동산을 목적으로 한 다른 권리도 소멸한다.
- ② 동산의 소유자가 합성물, 혼화물 또는 가공물의 단독소유자가 된 때에는 전항의 권리는 합성물, 혼화물 또는 가공물에 존속하고 그 공유자가 된 때에는 그 지분에 존속한다.

예를 들어 화장실과 같은 독립된 부속건물이 주물인 부동산에 부합할 수 있다.

판례는 기존건물에 붙여서 증축된 건물부분이 물리적 구조상이나 용도, 기능 및 거래의 관점에서 사회적, 경제적으로 볼 때 그 자체로서는 구조상 건물로서의 독립성이 없고 종전의 건물과 일체로서만 거래의 대상이 되는 상태에 있으면 부합이 성립한다(대판 1981. 12. 8, 80다2821)고 하여 부동산에 부동산도 부합할 수 있다고 보고 있다.

[판 례]

주건물에 부합된 건물인가 여부의 판단기준의 하나는 과연 부속된 부분이 독립한 건물로서의 가치와 기능을 시인할 수 있는가 아니면 오로지 주건물에 부착되어 분리하여서는 독립된 건물로서의 가치가 없고 주건물의 사용편의에 제공될 뿐인가 하는 것이다. 경매의 목적이 되고 안 되고는 경매절차에서의 평가목적으로 결정되는 것이 아니고 부합되었는가의 여부에 달린 것이다(대판 1991. 4. 12, 90다11967).

▶ 돌발 퀴즈

부동산과 부동산간의 부합은 불가능하다.

⇒ × : 판례는 기존건물에 붙여서 증축된 건물부분이 물리적 구조상이나 용도, 기능 및 거래의 관점에서 사회적, 경제적으로 볼 때 그 자체로서는 구조상 건물로서의 독립성이 없고 종전의 건물과 일체로서만 거래의 대상이 되는 상태에 있으면 부합이 성립한다(대판 1981. 12. 8, 80다2821)고 하여 부동산에 부동산도 부합할 수 있다고 보고 있다.

② 부합의 정도

(a) 부합으로 인하여 소유권의 변동이 있기 위해서는 부합·합체가 일정한 정도에 이르러야 한다. 부합의 정도는 거래관념에 의하여 부합한 동산이 독립성을 상실하고 부동산에 흡수되었을 것을 요한다. 통설적 견해는 부동산의 경우에도 “훼손하지 아니하면 분리할 수 없거나 그 분리에 과다한 비용을 요할 경우”라고 규정한 동산 간의 부합에 관한 제257조를 그 부합의 정도로 해석한다. 판례도 같은 입장을 취하고 있다(대판 1995. 6. 29, 94다 6345).

(b) 부합은 附屬과 구별되는데(다만 판례가 “권원에 의한 부합”이라는 표현을 하는 것으로 보아 부합과 부속을 구별하지 않는 듯하다), 부속은 본질적 구성부분으로 되지 않을 정도로 결합되고, 권원에 의한 경우를 말한다(즉 권원에 의하고 약한 부합).

부동산에 부합된 물건이 사실상 분리복구가 불가능하여 거래상 독립한 권리의 객체성을 상실하고 그 부동산과 일체를 이루는 부동산의 구성부분이 된 경우에는 타인이 권원에 의하여 이를 부합시켰더라도 그 물건의 소유권은 부동산의 소유자에게 귀속된다(대판 2008. 5 .8, 2007다 36933·36940).

(정리)

부합 : 1개의 물건으로 됨(분리 불가능할 것)/ 권원여부 불문 <- - 일물일권주의사상
부속 : 권원에 의할 것 + 분리가능할 것(즉 구성부분이 되지 않고 독립성을 가질 것)

(참고)

제100조(주물, 종물)

- ① 물건의 소유자가 그 물건의 상용에 공하기 위하여 자기소유인 다른 물건을 이에 부속하게 한 때에는 그 부속물은 종물이다.
- ② 종물은 주물의 처분에 따른다.

제256조(부동산에의 부합) 부동산의 소유자는 그 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득한다. 그러나 타인의 권원에 의하여 부속된 것은 그러하지 아니하다.

제316조(원상회복의무, 매수청구권)

- ① 전세권이 그 존속기간의 만료로 인하여 소멸한 때에는 전세권자는 그 목적물을 원상에 회복하여야 하며 그 목적물에 부속시킨 물건은 수거할 수 있다. 그러나 전세권설정자가 그 부속물건의 매수를 청구한 때에는 전세권자는 정당한 이유없이 거절하지 못한다.
- ② 전항의 경우에 그 부속물건이 전세권설정자의 동의를 얻어 부속시킨 것인 때에는 전세권자는 전세권설정자에 대하여 그 부속물건의 매수를 청구할 수 있다. 그 부속물건이 전세권설정자로부터 매수한 것인 때에도 같다.

제615조(차주의 원상회복의무와 철거권)

차주가 차용물을 반환하는 때에는 이를 원상에 회복하여야 한다. 이에 부속시킨 물건은 철거할 수 있다.

제646조(임차인의 부속물매수청구권)

- ① 건물 기타 공작물의 임차인이 그 사용의 편익을 위하여 임대인의 동의를 얻어 이에 부속한 물건이 있는 때에는 임대차의 종료시에 임대인에 대하여 그 부속물의 매수를 청구할 수 있다.
- ② 임대인으로부터 매수한 부속물에 대하여도 전항과 같다.

(c) 부합에 관한 판례의 예

(i) 주유소의 지하에 매설된 유류저장탱크를 토지로부터 분리하는데 과다한 비용이 들고 이를 분리하여 발굴하는 경우 그 경제적 가치가 현저히 감소할 것이 분명한 경우, 그 유류저장탱크는 토지에 부합된다(대판 1995. 6. 29, 94다6345).

(ii) 건물내부의 벽에 은파석을 붙이거나 내부천정에 합판을 부착하는 경우(대판 1985. 4. 23, 84도1549)에는 이들은 당연히 건물의 일부로 된다. 그러나 공장건물 내에 설치된 건조로는 이에 부합되었다고 할 수 없다(대판 1985. 12. 24, 84다카2428).

(iii) 가스공급업자가 아파트에 설치한 가스공급시설은 대지에 부합한다(대판 2007. 7. 27, 2006다39270·39278).

[판 례]

토지의 지상에 별개의 부동산인 건축물이 건축된 경우, 토지의 지하에 시공된 시설이 토지에 부합되었는지 아니면 지상 건축물의 기초 등을 구성하여 건축물의 일부분이 되었는지 여부는, 그 시설과 토지 및 건축물 사이의 각 결합 정도나 그 물리적 구조 뿐만 아니라 당해 시설의 객관적, 사회경제적인 기능과 용도, 일반 거래관념, 토지의 당초 조성상태, 건축물의 종류와 규모 등 제반 사정을 종합하여 합리적으로 판단하여야 한다.

그 부지와는 별개의 부동산인 지상 싸이로(silo)시설을 지지하기 위하여 지하에 항타·매립된 콘크리트 파일은 토지 외에 싸이로시설과도 상당한 수준으로 결합되어 있고 싸이로시설의 가치를 증대시키는 데에 기여하고 있어 토지에 부합된 것이 아니라 싸이로시설의 기초를 구성하는 시설로서 싸이로시설의 일부가 되었으므로, 싸이로시설을 국가에 귀속되지 않는 항만시설로 규정하고 있는 구 항만법 시행령(2005. 12. 9. 대통령령 제19174호로 개정되기 전의 것) 제17조 제1항 제2호에 따라 싸이로시설과 마찬가지로 국가에 귀속되지 않는다(대판 2009. 8. 20, 2008두8727).

③ 부합의 원인

인공적이든 자연적이든 이를 묻지 않는다(대판 1962. 1. 31, 4294민상445).

다만 부합하게 하는 행위가 불법행위를 구성하면 이로 인한 손해배상의무가 발생한다(대판 1966. 10. 25, 66다1503).

2) 효과

① 원칙

부동산의 소유자는 그 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득한다(제256조). 물건의 가격이 부동산의 가격을 초과하더라도 동산소유자는 부동산소유권을 취득하지 못한다(대판 1957. 2. 8, 4289민상117). 부합이 되면 부합물은 기존물건의 일부가 되므로 기존물건의 소유권이 이전되면 함께 소유권이 이전된다.

② 예외(제256조 단서)

부동산에 물건이 부합하더라도 그것이 타인의 권원에 의하여 부속된 것인 때에는 부합은 성립하지 않고 그 타인의 소유로 남는다(제256조 단서). 여기서 권원이란 지상권·전세권·임차권 등과 같이 타인의 부동산에 자기의 물건을 부속시켜서 그 부동산을 이용할 수 있는 권리를 말한다(통설, 대판 1989. 7. 11, 88다카 9067).

그러나 권원이 존재하는 외에 부동산에 부속한 물건이 그 부동산과 일체를 이루는 부동산의 구성부분으로 되지 않고 독립성을 가져야 한다. 따라서 부속물이 부동산의 구성부분이 된 경우에는 타인의 권원에 의한 것이라도 부합이 되므로 부동산소유자가 소유권을 갖는다(대판 2008. 5. 8, 2007다36933·36940; 대판 1985. 12. 24, 84다카2428).

부합물을 취득한 부동산소유자는 부합물의 소유자였던 자에게 부당이득에 관한 규정에 의하여 보상할 의무가 있다(제261조).

제261조(첨부로 인한 구상권)

전5조의 경우에 손해를 받은 자는 부당이득에 관한 규정에 의하여 보상을 청구할 수 있다.

→ 제261조 요건을 물론 부당이득법리에 따른 요건도 충족해야 함(판례)

3) 특수문제

① 건물의 부합

(a) 토지와 건물은 별개의 부동산이므로 건물이 토지에 부합하는 일은 없다. 건물의 증·개축 부분은 부합의 법리에 의하여 원칙적으로 기존 건물의 소유자에게 귀속한다(제256조 본문).

건물을 증축한 경우에 그 증축부분이 기존 건물에 부합하는지 여부는 기존 건물에 이미 지당권이 설정된 경우에 특히 문제된다. 지당권의 효력은 지당부동산에 부합된 물건에도 미치기 때문에 그 부합여부에 따라 경매신청의 대상과 경락인의 소유권취득범위가 달라지기 때문이다. 판

례는 어떠한 동산이 민법 제256조에 의하여 부동산에 부합된 것으로 인정되기 위해서는 그 동산을 훼손하거나 과다한 비용을 지출하지 않고서는 분리할 수 없을 정도로 부착·합체되었는지 여부 및 그 물리적 구조, 용도와 기능면에서 기존 부동산과는 독립한 경제적 효용을 가지고 거래상 별개의 소유권의 객체가 될 수 있는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 하고, 이러한 부동산에의 부합에 관한 법리는 건물의 증축의 경우는 물론 건물의 신축의 경우에도 그대로 적용될 수 있다(대판 2009. 9. 24, 2009다15602; 대판 2002. 10. 25, 2000다63110 등)고 한다.

(b) 건물의 임차인이 건물 소유자의 승낙을 얻어서 증·개축한 때 → 제256조의 단서 권원에 의하여 부속된 것인 때에 해당 → 그 부분은 임차인의 소유

(권원에 기하여 증축된 부분이 구조상·이용상으로 기존건물과 구분되는 독립성이 있는 경우에는 임대인과 임차인은 그 건물의 구분소유관계가 성립)

(반면에 권원에 기하여 증·개축된 부분이 경제적으로 보아 독립성이 없는 경우 → 증축된 부분에 별개의 소유권이 성립할 수 없고(대판 2008. 5. 8, 2007다36933·36940; 대판 1981. 12. 8, 80다2821) 비용상환청구권만 문제된다)

② 수목의 부합 수목이 토지에 부합하는 경우에도 건물의 부합의 경우와 같이 처리된다. 판례는 권한 없이 타인의 토지에 수목을 심은 경우에는 그 수목은 임야소유자에게 귀속하고(대판 1989. 7. 11, 88다카9067), 권원에 기하여 수목을 심은 경우에는 수목을 심은 자에게 그 소유권이 있다고 한다(대판 1991. 4. 12, 90다20220).

③ 농작물의 부합

Q : 농작물이 토지에 부합하는가?

① 부합설(다수설)

농작물 등이 타인소유의 토지에 부합하면, 제256조의 본문에 의하여 원칙적으로 토지소유자의 소유가 되며, 다만 예외적으로 임차권 등의 권원에 의하여 부속케 한 때는 제256조의 단서에 의하여 임차인 등이 그 식재한 것의 소유권을 보유하게 된다. 이 견해에 의하면 타인의 토지에 권한 없이 농작물 등을 식재한 자는 그 농작물 등에 대한 소유권을 가지지 못한다.

② 독립설(판례)

부합의 법리를 그대로 인정하면 유휴농지의 소유자 내지 부재지주만을 보호하는 결과가 되어 부당하고, 耕者有田의 원칙에 반한다고 하여 농작물은 경작지에 부합하지 않는다고 한다.

③ 절충설

경작자가 무권원으로 경작한 경우에 선의이면 경작자에게 농작물의 수거권을, 악의여서 부합되는 경우에는 보상청구권을 선택적으로 행사하는 것이 당사자의 이익형평에 타당하다고 한다.

④ 판례

농작물에 관하여서 만은 아무런 권원 없이 타인의 토지 위에서 경작·재배한 농작물의 소유권은 언제나, 심지어는 그 경작자가 위법하게 토지 소유자나 점유자를 배제하여 경작한 경우에도

그 경작자에게 있다(대판 1968. 6. 4, 68다613, 614)고 하여 농작물은 언제나 토지에 부합하지 않고 경작자에게 그 소유권이 있다고 한다(독립설).

검토 : 농작물의 부합에 관한 판례의 태도는 민법 제256조의 규정에 맞지 않는다. 따라서 농작물의 소유권은 농지의 소유자에게 귀속되고, 농작물을 식재한 자는 그에 대한 보상청구권을 가지는 것으로 해석함이 타당하다고 할 것이다.

(2) 동산의 부합

1) 의의

동산과 동산이 부합하여 성립된 합성물에 대해서는 주된 동산의 소유자가 그 합성물의 소유권을 취득하고, 주종을 구별할 수 없는 때에는 동산의 소유자는 부합당시에 가액의 비율로 합성물을 공유하게 된다(제257조).

2) 요건

소유자를 달리하는 수 개의 동산이 부합하여 훼손 없이 분리할 수 없거나 분리에 과다한 비용을 요함(제257조 전단).

선박에 부착된 엔진 : 종물(대판 1965. 3. 5, 64다1793)(부합아님)

3) 효과

① 부합한 동산 간에 주종의 구별이 가능 → 주된 동산의 소유자가 합성물의 소유권을 취득
주종의 구별이 불가능한 때 → 각 소유자는 부합당시의 가격의 비율로 合成物을 공유.

② 부합에 의하여 손실을 받은 자는 소유자에 대하여 제748조 이하의 규정에 의하여 보상을 청구(제261조).

2. 혼화

(1) 의의

混和라고 함은 동산에 동산이 섞이는 것으로 곡물·금전 등과 같은 固形物의 混和
술·간장·기름과 같은 流動物의 混和의 두 종류가 있다.

혼화의 본질은 일종의 동산의 부합 → 혼화에는 동산의 부합에 관한 규정이 준용된다(제258조).

(2) 요건

동산과 동산이 서로 섞여 원물을 식별할 수 없거나 원물의 분리에 과다한 비용이 들어야 한다.

(3) 효과

혼화의 효과는 동산 간의 부합과 동일하다(제258조).

3. 가공

(1) 의의

타인의 동산 + 노동력을 가하여 새로운 물건을 제작하는 것(즉 물건과 노동이 합체)

민법상의 가공은 동산에 한한다(제259조). 그러나 부동산에도 이 규정을 유추적용하자는 판례가 있다(대판 1962. 3. 29, 62다23).

(2) 요건

1) 타인의 재료를 쓰거나 또는 타인의 물건에 변경을 가하는 공작이어야 한다. 그러나 재료의 전부나 타인 소유일 것을 요하지 않고 재료의 일부를 제공하여도 무방하다.

2) 가공의 결과 원재료와는 다른 새로운 물건이 생겨야 한다. 새로운 물건인가의 여부는 사회경제상의 관념에 의하여 결정하여야 할 것이다.

대수선이 가공인가?

① 부정설

② 긍정설

검토 : 대수선은 원재료에 수선을 가하는 것이므로 수선물을 원재료와 전혀 다른 새로운 물건으로 볼 수 없을 것이다(부정설).

3) 가공자의 선의·악의는 묻지 않는다. 다만 타인의 물건임을 알면서 가공한 때에는 별도로 불법행위 책임을 진다.

(3) 효과

1) 가공물의 소유권은 원칙적으로 원재료의 소유자에게 귀속한다(제259조 제1항 본문). 그러나 예외적으로 가공으로 인한 가액의 증가가 원재료의 가격보다 현저히 다액일 때는 가공자의 소유로 한다(제259조 제1항 단서). 이 경우에 가공자가 재료의 일부를 제공한 때에는 그 재료의 가액은 증가액에 가산하여 소유권의 귀속을 결정하여야 한다(제259조 제2항).

2) 제259조 제1항의 가공물의 귀속에 관한 규정은 임의규정이다. 따라서 당사자의 특약으로 다른 약정을 할 수 있다.

3) 종속적 노동에 의한 생산에는 제259조가 적용 × → 생산물은 사용자 귀속

Ⅶ. 소유자의 물권적 청구권

소유물반환청구권(제213조)·소유물방해제거청구권(제214조)·소유물방해예방청구권(제214조)을 인정하고 이를 각종의 물권에 준용하고 있다.

- 계약상 청구권과의 관계 : 양자의 경합 긍정(다수설)
- 부당이득반환청구권과의 관계 : 양자의 경합 긍정(다수설·판례). 다수설은 타인 소유물의 사용수익으로 인한 부당이득의 반환관계는 제741조 이하가 아니라 제201조 내지 제203조에 따라야 하는 것으로 이해한다.

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 침부에 의하여 생긴 물건은 1개의 물건으로 존속하고 복구는 인정하지 않는다. 이것이 침부의 중심적 효과이며 이에 관한 규정은 강행규정이다.
 - ② 침부에 의하여 생긴 새 물건에 관하여는 새로이 소유자가 결정된다. 이에 관한 규정은 계약 자유의 원칙상 임의규정이다.
 - ③ 침부에 의하여 소멸한 구물건의 소유자는 손실의 보상을 받는다. 즉 침부의 규정에 의하면 손해를 받은 자는 부당이득에 관한 규정에 의하여 보상을 청구할 수 있다.
 - ④ 침부에 의하여 동산의 소유권이 소멸한 때에는 그 동산을 목적으로 한 다른 권리는 소멸한다.
 - ⑤ 부동산의 소유자는 그 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득한다. 타인의 권원에 의하여 부속된 것도 마찬가지이다.
- ⑤. 부동산의 소유자는 그 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득한다. 그러나 타인의 권원에 의하여 부속된 것은 그러하지 아니하다(제256조).

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 동산과 동산이 부합하여 훼손하지 아니하면 분리할 수 없거나 그 분리에 과다한 비용을 요할 경우에는 그 합성물의 소유권은 주된 동산의 소유자에게 속한다.
- ② 위 ①의 경우 부합한 동산의 주종을 구별할 수 없는 때에는 동산의 소유자는 부합당시의 가액의 비율로 합성물을 공유한다.

- ③ 판례는 부동산에 부동산도 부합할 수 있다고 보고 있다.
 - ④ 부동산에 부합된 물건이 사실상 분리복구가 불가능하여 거래상 독립한 권리의 객체성을 상실하고 그 부동산과 일체를 이루는 부동산의 구성부분이 된 경우에도 타인이 권원에 의하여 이를 부합시켰더라면 그 물건의 소유권은 부동산의 소유자에게 귀속되지 않는다.
 - ⑤ 주유소의 지하에 매설된 유류저장탱크를 토지로부터 분리하는데 과도한 비용이 들고 이를 분리하여 발굴하는 경우 그 경제적 가치가 현저히 감소할 것이 분명한 경우, 그 유류저장탱크는 토지에 부합된다.
- ④. 부동산에 부합된 물건이 사실상 분리복구가 불가능하여 거래상 독립한 권리의 객체성을 상실하고 그 부동산과 일체를 이루는 부동산의 구성부분이 된 경우에는 타인이 권원에 의하여 이를 부합시켰더라도 그 물건의 소유권은 부동산의 소유자에게 귀속된다(대판 2008. 5 .8, 2007다36933·36940).

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 가스공급업자가 아파트에 설치한 가스공급시설은 대지에 부합한다.
 - ② 토지의 지상에 별개의 부동산인 건축물이 건축된 경우, 토지의 지하에 시공된 시설이 토지에 부합되었는지 아니면 지상 건축물의 기초 등을 구성하여 건축물의 일부분이 되었는지 여부는, 그 시설과 토지 및 건축물 사이의 각 결합 정도나 그 물리적 구조 뿐만 아니라 당해 시설의 객관적, 사회경제적인 기능과 용도, 일반 거래관념, 토지의 당초 조성상태, 건축물의 종류와 규모 등 제반 사정을 종합하여 합리적으로 판단하여야 한다.
 - ③ 그 부지와는 별개의 부동산인 지상 싸이로(silo)시설을 지지하기 위하여 지하에 향타·매립된 콘크리트 파일은 토지 외에 싸이로시설과도 상당한 수준으로 결합되어 있고 싸이로시설의 가치를 증대시키는 데에 기여하고 있어 토지에 부합된 것이 아니라 싸이로시설의 기초를 구성하는 시설로서 싸이로시설의 일부가 되었으므로, 싸이로시설을 국가에 귀속되지 않는 향만 시설로 규정하고 있는 구 향만법 시행령(2005. 12. 9. 대통령령 제19174호로 개정되기 전의 것) 제17조 제1항 제2호에 따라 싸이로시설과 마찬가지로 국가에 귀속되지 않는다.
 - ④ 부합의 원인은 인공적이든 자연적이든 이를 묻지 않지만, 다만 부합하게 하는 행위가 불법행위를 구성하면 이로 인한 손해배상의무가 발생한다.
 - ⑤ 부동산의 소유자는 그 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득한다. 그러나 물건의 가격이 부동산의 가격을 초과하는 경우 동산소유자가 부동산소유권을 취득한다.
- ⑤. 부동산의 소유자는 그 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득한다(제256조). 물건의 가격이 부동산의 가격을 초과하더라도 동산소유자는 부동산소유권을 취득하지 못한다(대판 1957. 2. 8, 4289민상117).

♣ 학습정리

1. 토지와 건물은 별개의 부동산이므로 건물이 토지에 부합하는 일은 없다. 건물의 증·개축부분은 부합의 법리에 의하여 원칙적으로 기존 건물의 소유자에게 귀속한다.
2. 권한 없이 타인의 토지에 수목을 심은 경우에는 그 수목은 임야소유자에게 귀속하고, 권원에 기하여 수목을 심은 경우에는 수목을 심은 자에게 그 소유권이 있다
3. 아무런 권한 없이 타인의 토지 위에서 경작·재배한 농작물의 소유권은 언제나, 심지어는 그 경작자가 위법하게 토지 소유자나 점유자를 배제하여 경작한 경우에도 그 경작자에게 있다.
4. 동산과 동산이 부합하여 성립된 합성물에 대해서는 주된 동산의 소유자가 그 합성물의 소유권을 취득하고, 주종을 구별할 수 없는 때에는 동산의 소유자는 부합당시에 가액의 비율로 합성물을 공유한다.
5. 가공물의 소유권은 원칙적으로 원재료의 소유자에게 귀속한다. 그러나 예외적으로 가공으로 인한 가액의 증가가 원재료의 가격보다 현저히 다액일 때는 가공자의 소유로 한다.

제21강 물권적 청구권 (2), 공동소유 서설

♣ 학습목표

1. 소유권에 기한 물권적청구권을 정리할 수 있다.
2. 공동소유 제도의 기초이론을 정리할 수 있다.

♣ 학습내용

- 소유물반환청구권
- 소유물방해제거청구권
- 소유물방해예방청구권
- 공동소유의 의의와 유형
- 공유제도 서설

♣ 사전 테스트

1. 부동산의 소유자는 그 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득한다. 타인의 권원에 의하여 부속된 것도 마찬가지이다.
⇒ × : 부동산의 소유자는 그 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득한다. 그러나 타인의 권원에 의하여 부속된 것은 그러하지 아니하다(제256조).
2. 부동산에 부합된 물건이 사실상 분리복구가 불가능하여 거래상 독립한 권리의 객체성을 상실하고 그 부동산과 일체를 이루는 부동산의 구성부분이 된 경우에도 타인이 권원에 의하여 이를 부합시켰더라면 그 물건의 소유권은 부동산의 소유자에게 귀속되지 않는다.
⇒ × : 부동산에 부합된 물건이 사실상 분리복구가 불가능하여 거래상 독립한 권리의 객체성을 상실하고 그 부동산과 일체를 이루는 부동산의 구성부분이 된 경우에는 타인이 권원에 의하여 이를 부합시켰더라도 그 물건의 소유권은 부동산의 소유자에게 귀속된다(대판 2008. 5. 8, 2007다36933·36940).
3. 경작자가 위법하게 토지 소유자나 점유자를 배제하거나 아무런 권원 없이 타인의 토지 위에서 경작·재배한 농작물의 소유권은 토지소유자에게 있다.
⇒ × : 아무런 권원 없이 타인의 토지 위에서 경작·재배한 농작물의 소유권은 언제나, 심지어는 그 경작자가 위법하게 토지 소유자나 점유자를 배제하여 경작한 경우에도 그 경작자에게 있다(대판 1968. 6. 4, 68다613, 614).

♣ 강의교안

Ⅶ- 1. 소유물반환청구권

1. 요건

(1) 청구권자

- 1) 청구권자는 현재의 소유자이다. 이러한 소유자는 사실심변론종결 당시의 소유자이면 족하므로 소유물반환청구의 소제기후 사실심변론종결 전에 소유자로 등기된 자는 소유물반환청구권의 주체로 된다(대판 1991. 7. 12, 90다13161).

여기서 말하는 소유자란 법적인 의미에서의 소유자임

- ① 자동차 지입의 경우 그 소유자는 등록명의를 갖고 있는 소유자이다(대판 1970. 9. 29, 70다1508).
- ② 명의신탁의 경우 수탁자가 물권적 청구권자이며 신탁자는 수탁자를 대위할 뿐이다(대판 1979. 9. 25, 77다1079).
- ③ 도로예정지로 편입되어 사실상 일반공중의 통행로로 사용되어 온 토지의 소유자가 그 독점적이고 배타적인 사용·수익권을 포기한 것으로 볼 경우라도, 그 토지를 불법점유하고 있는 제3자에 대하여 물권적 청구권을 행사하여 토지의 반환 내지 방해의 제거, 예방을 청구할 수 있다(대판 2001. 4. 13, 2001다8493).

[판례] 배타적 사용수익권을 포기한 것으로 인정되는 토지를 불법점유하고 있는 점유자에 대하여, 토지소유자가 방해배제 및 그 점유로 인한 부당이득의 반환을 구할 수 있는지 여부

종전부터 자연발생적으로 또는 도로예정지로 편입되어 사실상 일반공중의 통행로로 사용되어 온 토지의 소유자가 그 독점적이고 배타적인 사용수익권을 포기한 것으로 볼 경우에도, 일반공중의 통행을 방해하지 않는 범위 내에서는 토지소유자로서 그 토지를 처분하거나 사용수익할 권능을 상실하지 않는다고 할 것이므로, 그 토지를 불법점유하고 있는 제3자에 대하여 물권적 청구권을 행사하여 토지의 반환 내지 방해의 제거, 예방을 청구할 수 있다고 할 것이나, 특별한 사정이 없는 한 토지소유자는 그 이후에도 토지를 독점적, 배타적으로 사용수익할 수는 없고, 따라서 제3자가 그 토지를 불법점유하였다 하더라도 이로 인하여 토지소유자에게 어떠한 손실이 생긴다고 할 수 없어 그 점유로 인한 부당이득의 반환을 청구할 수는 없다(대판 2001. 4. 13, 2001다8493).

- 2) 소유물을 여러 사람이 공동소유를 하고 있는 경우에, 공유자 1인은 제3자에 대하여 소유물 전부의 반환을 청구할 수 있다. 이 때 공유자 전원에게 반환할 것을 청구할 필요는 없고, 자기에게 반환할 것을 청구하여도 무방하다. 합유자 1인도 단독으로 보존행위를 할 수 있으므로(제272조 단서) 자기에게 반환을 청구할 수 있다. 공유자 1인 또는 합유자 1인이 자기에게 반환받는 경우에 그 물건은 공유자 전원 및 합유자 전원을 위하여 점유하는 것으로 간주된다.

주 의

- ① 부동산의 양도담보권설정자는 그 부동산의 등기명의가 양도담보권자 앞으로 되어있다 할지라도 가등기담보법에 의해 청산금지급 전까지 소유권이전이 인정되지 않으므로 등기명의에도 불구하고 그 부동산의 불법점유자인 제3자에 대하여는 그 실질적 소유자임을 주장하여 불법점유의 상태의 배제권을 행사할 수 있다(대판 1988. 4. 25, 87다카2696·2697).
- ② 동산양도담보의 경우에는 그 성격을 신탁적 소유권이전으로 보는 입장(대판 1994. 8. 26, 93다44739; 대판 2004. 12. 24. 2004다45943)에서는 외부관계에서 물건의 소유자는 양도담보권자(채권자)가 되므로 양도담보권자가 소유물반환청구권을 행사하고 설정자(채무자)는 이 청구권을 갖지 않는다.

(2) 상대방

- 1) 청구권의 상대방은 「현재」 그 물건을 점유함으로써 소유자의 점유를 방해하고 있는 자이다. 따라서 불법행위자라도 그 물건을 다른 사람에게 인도하여 현실적으로 점유를 하고 있지 않은 이상, 그 불법점유자를 상대로 한 인도 또는 명도청구는 부당하다(대판 1999. 7. 9, 98다9045).

[판례] 등기를 갖추지 아니한 건물 양수인에 대한 대지소유자의 건물철거 청구권

건물철거는 그 소유권의 종국적 처분에 해당하는 사실행위이므로 원칙으로는 그 소유자에게만 그 철거처분권이 있으나 미등기건물을 그 소유권의 원시취득자로부터 양도받아 점유 중에 있는 자는 비록 소유권취득등기를 하지 못하였다고 하더라도 그 권리의 범위 내에서는 점유 중인 건물을 법률상 또는 사실상 처분할 수 있는 지위에 있으므로 그 건물의 존재로 불법점유를 당하고 있는 토지소유자는 위와 같은 건물점유자에게 그 철거를 구할 수 있다(대판 1989. 2. 14, 87다카3073).

→ 사실상 소유자 개념(피고로만 인정)

- 2) 현재의 점유방해인가의 여부에 대한 결정기준시점은 청구권의 존부를 확정하여야 할 때, 즉 사실심의 변론종결시이다.
- 3) 상대방이 점유보조자를 통하여 점유하고 있는 경우에는 상대방에게만 청구할 수 있고, 점유보조자는 반환청구권의 상대방으로 되지 않는다.

[판례] 점유보조자가 퇴거청구의 상대방이 되는지 여부(소극)

소유물반환청구의 상대방은 현재 그 물건을 점유하는 자이고 그 점유보조자에 불과한 자는 이에 해당하지 아니하므로, 주식회사의 직원으로서 회사의 사무실로 사용하고 있는 건물부분에 대한 점유보조자에 불과할 뿐 독립한 점유주체가 아닌 피고들은, 회사를 상대로 한 명도소송의 확정판결에 따른 집행력이 미치는 것은 별론으로 하고, 소유물반환청구의 성질을 가지는 퇴거청구의 독립한 상대방이 될 수는 없는 것이다(대판 2001. 4. 27, 2001다13983).

4) 공유자가 소유자 토지에 무단으로 공유물을 설치한 경우에는 그 공유자는 지분의 범위 내에서 반환을 할 수 있으므로 토지소유자는 반드시 공유자 전원을 상대로 반환청구(시설물의 철거)를 할 필요는 없고 개별적으로 청구를 할 수 있다(대판 1993. 2. 23, 92다49218). 즉 필수적 공동소송이 아니다. 다만 강제집행을 하기 위해서는 공유자 전원에 대한 집행권원이 필요하다.

(3) 점유할 권리의 부존재

상대방에게 점유할 권리가 없어야 한다(제213조 단서). 점유할 권리, 즉 점유를 정당하게 하는 권리에는 지상권·전세권·질권·유치권과 같은 점유를 수반하는 물권뿐만 아니라 임차권과 같은 채권과 동시이행항변권도 포함된다.

[판례] 미등기매수인의 점유할 권리

토지의 매수인이 아직 소유권이전등기를 경료 받지 아니하였다 하여도 매매계약의 이행으로 그 토지를 인도받은 때에는 매매계약의 효력으로서 이를 점유사용할 권리가 생기게 된 것으로 보아야 하고 또 매수인이 그 토지 위에 건축한 건물을 취득한 자는 그 토지에 대한 매수인의 위와 같은 점유사용권까지 아울러 취득한 것으로 봄이 상당하므로 매도인은 매매계약의 이행으로서 인도한 토지 위에 매수인이 건축한 건물을 취득한 자에 대하여 토지소유권에 기한 물권적 청구권을 행사할 수 없다(1988. 4. 25, 87다카1682).

(4) 상대방의 귀책사유

상대방에게 점유취득에 대한 고의·과실 등의 귀책사유가 요구되지 않는다(통설).

2. 효과

(1) 점유의 이전

상대방은 소유자의반환청구권에 따라 소유물의 반환, 즉 점유의 이전을 하여야 한다. 일반적으로 점유의 이전은 동산에 있어서는 인도, 부동산에 있어서는 명도라고 부른다.

건물의 소유자가 그 건물의 소유를 통하여 타인 소유의 토지를 점유하고 있다고 하더라도 그 토지 소유자로서는 그 건물의 철거와 그 대지 부분의 인도를 청구할 수 있을 뿐, 자기 소유의 건물을 점유하고 있는 자에 대하여 그 건물에서 퇴거할 것을 청구할 수는 없다(대판 1999. 7. 9, 98다57457·57464; 비교판례로 방해배제청구권에서의 대판 2010. 8. 19, 2010다43801 참조).

(2) 반환의 방법

점유자는 그 물건을 원상회복하여 반환할 필요는 없다.

점유침탈자인 상대방의 점유 중에 생긴 과실취득, 목적물을 멸실·훼손한 경우의 손해배상책임, 비용을 지출한 경우의 상환청구 등의 문제에 관하여는 우리 민법은 아무 규정을 두고 있지 않다. 이에 관하여 학설은 계약관계가 있었다면 그 계약관계를 지배하는 법조항에 의하고, 그러한 계약관계가 없는 때에는 점유자와 회복자의 관계에 관한 규정(제201조 내지 제203조)을 적

용한다(대판 2003. 7. 25, 2001다64752). 그리고 불법행위(제750조 이하)·부당이득에 관한 규정(제741조 이하)이 적용될 수 있다. 반환비용은 청구의 상대방이 부담함이 원칙이다(제473조).

[판례] 토지의 불법점유로 인한 통상의 손해

타인 소유의 토지를 법률상 권원 없이 점유함으로써 인하여 그 토지소유자가 입은 통상의 손해는 특별한 사정이 없는 한 그 점유토지의 임료 상당액이라 할 것이고, 이 사건에 있어서와 같이 그 불법점유의 태양이 지하철의 설치, 운용 등과 같이 반영구적으로 계속될 것이라고 예상되는 경우라고 하더라도 특별한 사정이 없는 한 그 손해의 일시 배상을 청구하는 것은 허용되지 아니한다(대판 1994. 6. 28, 93다51539).

Ⅶ- 2. 소유물방해제거청구권

1. 의의

소유자는 소유물을 방해하는 자에 대하여 방해제거를 청구할 수 있다(제214조 전단). 이를 소유물방해제거청구권이라고 한다. 이 청구권은 소유권 기타 물권에 관하여만 적용되는 것이 아니라 물권유사의 권리인 명예·신용과 같은 인격권, 어업권, 광업권, 수렵권, 지식재산권 기타 절대적으로 보호되는 재산권에도 적용된다.

2. 요건

(1) 청구권자

- ① 청구권의 주체는 소유권의 내용의 실현이 점유침탈 이외의 방법으로 방해되고 있는 자이다. 현재 소유권을 방해받고 있어야 하므로 방해받고 있는 소유권을 타인에게 양도한 때에는 그 양수인만이 청구권자이다(대판 1980. 9. 9, 80다7). 방해를 당하고 있는가의 여부는 사실심의 변론종결시를 표준으로 하여 결정하게 된다.
- ② 무효인 가등기에 기한 본등기로 인해 소유권등기가 말소된 중간취득자도 청구권자이다(대판 1997. 10. 24, 97다29097).
- ③ 명의신탁자는 대외관계에서는 소유자가 아니므로 제3자에게 직접 물권적 청구권을 행사할 수 없으며 수탁자를 대위하여 수탁자의 물권적 청구권을 행사할 수 있을 뿐이다(대판 1979. 9. 25, 77다1079).

(2) 상대방

- 1) 청구권의 상대방은 「현재」 방해하고 있는 자이다. 즉 현재 방해하는 사정을 지배하는 지위에 있는 자이다(대판 1966. 1. 31, 65다218). 따라서 과거에 방해하였더라도 현재 그 방해 상태를 지배하는 지위에 있지 않은 자는 상대방으로 되지 않는다.

예를 들어 타인의 토지에 불법으로 건물을 지은 뒤 다른 자에게 양도한 경우에는 점유하고 있는 양수인이 상대방으로 된다(대판 1991. 6. 11, 91다11278).

▶ 돌발 퀴즈

타인의 토지에 불법으로 건물을 지은 뒤 다른 자에게 양도한 경우에는 건물을 지은 자를 상대방으로 하여 방해제거를 청구하여야 한다.

⇒ × : 청구권의 상대방은 「현재」 방해하고 있는 자이다. 즉 현재 방해하는 사정을 지배하는 지위에 있는 자이다(대판 1966. 1. 31, 65다218). 따라서 과거에 방해하였더라도 현재 그 방해 상태를 지배하는 지위에 있지 않은 자는 상대방으로 되지 않는다. 예를 들어 타인의 토지에 불법으로 건물을 지은 뒤 다른 자에게 양도한 경우에는 점유하고 있는 양수인이 상대방으로 된다(대판 1991. 6. 11, 91다11278).

[판례] 방해제거청구로서 가등기에 기한 본등기의 말소청구

어떤 부동산에 관하여 채권 담보를 위한 가등기가 경료된 후에 매매에 의하여 그 소유권을 취득한 제3자가 채무원리금을 변제함으로써 피담보채무가 전부 소멸하였음에도 불구하고 등기부상 가등기가 그대로 남아있음을 이용하여 가등기 명의자가 가등기에 기한 소유권이전의 본등기를 경료하고 나아가 타인 명의로 가등기까지 경료하였다 하더라도 피담보채무의 소멸 후의 위 담보가등기는 원인무효이고, 위 가등기에 기하여 경료된 본등기 및 타인 명의의 가등기도 원인무효이며, 나아가 위 가등기에 기한 본등기가 경료됨으로써 등기공무원이 직권으로 한 가등기 후의 위 제3자 명의의 소유권이전등기의 말소등기 역시 원인무효이어서 위 제3자는 여전히 소유권자로서의 지위를 잃지 않으므로, 위 제3자로서는 위 말소등기의 회복 여부에 관계없이 소유권에 기한 방해배제 청구로서 “직접 등기 명의자를 상대”로 원인무효인 위 각 가등기 및 가등기에 기한 본등기의 말소를 청구하여 그 등기가 말소되면 등기공무원이 다시 직권으로 말소된 위 제3자 명의의 소유권이전등기의 회복등기를 할 수 있고, 위 제3자 명의로 경료된 소유권이전등기가 잘못 말소되었다 하여 이미 목적 달성으로 소멸한 전 소유자에 대한 소유권이전등기 청구권이 다시 발생한다고는 할 수 없으므로 위 제3자에게는 전 소유자를 대위하여 위 각 가등기 및 본등기의 말소를 청구할 피보전권리가 없다(대판 1997. 10. 24, 97다29097).

- 2) 타인의 토지 위에 무단으로 건물을 신축하거나 또는 타인의 토지에 불법점유하고 있는 미등기 건물을 양수한 경우와 같이, 건물이 그 존립을 위한 토지사용권을 갖추지 못한 경우 토지소유자는 그 건물소유자를 상대로 건물의 철거와 대지의 인도를 청구할 수는 있지만(제213조), 건물소유자를 그 건물로부터 퇴거할 것을 청구할 수는 없다(대판 1999. 7. 9, 98다57457-57464; 대판 1989. 2. 14, 87다카3073 참조). 그러나 건물소유자가 아닌 다른 사람이 건물을 점유하고 있다면 토지소유자는 그 소유권의 실현을 방해받고 있다 할 것이므로 그 건물점유자를 건물로부터 퇴거할 것을 청구할 수 있다(대판 2010. 8. 19, 2010다43801).

[판례] 토지소유자가 (건물소유자가 아닌)건물점유자에 대하여 퇴거청구를 할 수 있는지 여부

건물이 그 존립을 위한 토지사용권을 갖추지 못하여 토지의 소유자가 건물의 소유자에 대하여 당해 건물의 철거 및 그 대지의 인도를 청구할 수 있는 경우에라도 건물소유자가 아닌 사람이 건물을 점유하고 있다면 토지소유자는 그 건물 점유를 제거하지 아니하는 한 위의 건물 철거 등을 실행할 수 없다. 따라서 그때 토지소유권은 위와 같은 점유에 의하여 그 원만한 실현을 방해당하고 있다고 할 것이므로, 토지소유자는 자신의 소유권에 기한 방해배제로서 건물점유자에 대하여 건물로부터의 퇴출을 청구할 수 있다. 그리고 이는 건물점유자가 건물소유자로부터의 임차인으로서 그 건물임차권이 이른바 대항력을 가진다고 해서 달라지지 아니한다. 건물임차권

의 대항력은 기본적으로 건물에 관한 것이고 토지를 목적으로 하는 것이 아니므로 이로써 토지 소유권을 제약할 수 없고, 토지에 있는 건물에 대하여 대항력 있는 임차권이 존재한다고 하여도 이를 토지소유자에 대하여 대항할 수 있는 토지사용권이라고 할 수는 없다. 바꾸어 말하면, 건물에 관한 임차권이 대항력을 갖춘 후에 그 대지의 소유권을 취득한 사람은 민법 제622조 제1항이나 주택임대차보호법 제3조 제1항 등에서 그 임차권의 대항을 받는 것으로 정하여진 ‘제3자’에 해당한다고 할 수 없다(대판 2010. 8. 19, 2010다43801).

- 3) 근저당권 양도의 부기등기가 경료되었는데 근저당권설정등기가 무효이거나 채무변제 등으로 소멸하여야 할 경우에 근저당권설정등기만 말소하면 되고(주등기 말소에 따라 부기등기는 직권으로 말소 됨), 이 때의 근저당권설정등기말소 청구권의 상대방은 양도인이 아니고 현재의 저당권 명의자인 양수인이다.

근저당권의 양도에 의한 부기등기는 기존의 근저당권설정등기에 의한 권리의 승계를 등기부상 명시하는 것뿐으로, 그 등기에 의하여 새로운 권리가 생기는 것이 아닌 만큼, 근저당권설정등기의 말소등기청구는 양수인만을 상대로 하면 족하고, 양도인은 그 말소등기청구에 있어서 피고적격이 없다. 따라서 부기등기는 별도로 말소를 구하지 않더라도 주등기의 말소에 따라 직권으로 말소된다(대판 1995. 5. 26, 95다7550)고 한다. 다만 저당권이전의 원인인 저당권양도계약만이 무효나 취소 또는 해제된 때에는 저당권양도인인 양수인을 상대로 부기등기의 말소를 구하여야 한다(대판 2003. 4. 11, 2003다5016).

(3) 소유권의 방해

- 1) 상대방이 목적물의 점유침탈이나 불법점거 이외의 방법으로 소유권을 방해하고 있어야 한다(대판 1965. 9. 28, 65다1591·1572). 이 경우에 피방해자인 소유자는 점유를 그대로 보유하고 있어야 하고, 이 점에서 소유물반환청구권과 다르다.

2) 현재 계속되는 방해

방해라 함은 현재에도 지속되고 있는 침해를 의미하고, 법익 침해가 과거에 일어나서 이미 종결된 경우에 해당하는 ‘손해’의 개념과는 다르다 할 것이어서, 소유권에 기한 방해배제청구권은 방해결과의 제거를 내용으로 하는 것이 되어서는 아니 되며(이는 손해배상의 영역에 해당한다 할 것이다) 현재 계속되고 있는 방해의 원인을 제거하는 것을 내용으로 한다(대판 2003. 3. 28, 2003다5917). 따라서 쓰레기 매립으로 조성한 토지에 소유자가 매립에 동의하지 않은 쓰레기가 매립되어 있다 하더라도, 이는 위법한 매립공사로 인하여 생긴 결과로서 소유자가 입은 손해에 해당할 뿐, 방해라고 볼 수는 없다(대판 2003. 3. 28, 2003다5917).

3) 고의·과실불요

소유권의 방해가 상대방의 고의 또는 과실에 기하여야 하는 것은 아니다(예를 들어 임차인에 의한 소음에 대해 이웃에 사는 사람이 임대인에게 방해배제청구를 한 경우). 방해가 자연력(예를 들어 바람에 의해 담장을 넘어간 물건이 이웃토지를 점유하여 물건소유자에게 방해배제청구를 한 경우) 또는 제3자의 행위(토지를 변형시키고 이를 매도하였는데 이웃한 토지에 토사가 흘러내려가 매수인에게 방해배제청구를 한 경우)에 의한 경우에도 소유물방해제거청구권은 인정된다(통설).

3) 위법성 방해는 위법한 것이어야 한다. 따라서 소유권자의 소유권행사가 상린관계규정 (제217조·제240조·제241조·제242조·제243조·제249조) 기타 특별법에 의하여 일정한 제한을 받고 있는 경우에는 그 범위 내에서 방해제거청구권이 부인된다.

4) 방해의 모습

(가) 소극적 침해 및 정신적 침해

자기 소유의 토지를 사용함에 있어서 이웃집 토지의 이익을 침해(예를 들어 자기 소유의 토지에 건물을 신축함으로써 이웃 토지의 채광이나 조망을 방해하는 것)하거나 이웃 토지소유자를 정신적으로 침해(이웃 토지에 영안실이나 윤락업소를 설치함으로써 정신적 피해를 주는 것)하는 경우이다. 이에 대하여도 소유물방해제거청구권이 인정된다.

다만 구체적으로 주위의 여건, 그 침해의 정도 등을 고려하여 수인해야 할 것으로 인정된다면 위법성이 없게 되어 소유물방해제거청구권은 부정될 것이다.

(나) 원인무효등기 →말소등기청구

3. 효과

(1) 청구권자는 상대방에 대하여 방해의 제거를 청구하는 것이다. 방해제거청구권의 내용은 다양하다. 여기서 방해의 제거라 함은 방해 결과의 제거가 아니고 현재 계속되고 있는 방해의 원인을 제거하는 것이다(대판2003. 3. 28, 2003다 3917).

→ 예는 소유자의 토지경계를 유월한 건물의 철거 또는 원인 없는 등기의 말소청구, 건축공사의 중지청구이다.

(2) 소유물반환청구권과 소유물방해제거청구권은 논리적으로는 서로 경합할 수 없는 것이다. 그러나 越境建築의 경우에는 토지소유자는 그 건축물의 철거를 구하고 동시에 토지의 인도를 청구할 수 있으므로 양자는 실제로는 경합할 수 있다.

Ⅶ- 3. 소유물방해예방청구권

소유자는 소유권을 방해할 염려가 있는 행위를 하는 자에 대하여 그 예방이나 손해배상의 담보를 청구할 수 있다(제214조 후단). 이를 소유물방해예방청구권이라고 한다. 이 청구권은 방해 사실이 현존하는 때에 성립하는 반환청구권이나 방해제거청구권과는 달리 방해를 당할 염려가 있는 경우에 그 방해의 위험원인을 제거하고 방해의 발생을 사전에 예방하려는 취지로 인정된 것이다.

Ⅷ. 공동소유

Ⅷ- 1. 총설

1. 의의

한 개의 물건을 2인 이상의 다수인이 공동으로 소유하는 것
공유(제262조 이하), 합유(제271조 이하), 총유(제275조 이하)

2. 유형

	공 유	합 유	총 유
인적결합형태	공동소유자 사이에 아무런 인적 결합관계가 없는 매우 개인주의적인 소유형태 (로마법 기원)	조합체의 소유형태 (게르만의 공동상속인 단체에서 유래)	권리능력 없는 사단의 소유형태 (게르만의 촌락공동체에서 유래)
재산(예)	공동상속 재산	조합재산	종중, 교회 재산
목적(취지)	단순한 재산의 결합 (공동사업목적 없음 : 지분적 조합)	공동사업 목적 (합수적 조합)	단체적 소유·결합
지분(지분권)	공유지분	합유지분	없음
지분의 처분	자유	전원의 동의 필요	.
보존행위	각자 단독으로 가능	각자 단독으로 가능	사원총회의 결의 (판례)
이용·개량행위	지분의 과반수의 동의(판례)	.	사원총회의 결의
목적물변경·처 분	전원의 동의	전원의 동의	사원총회의 결의
목적물사용·수 익	지분의 비율 (공유물 전부)	조합계약 기타 규약 (합유물 전부)	정관 기타 규약
분할청구	자유 ※특약으로 금지 가능(5년 이내)	원칙적 금지 (단, 조합해산시 가능)	없음
등기 방식	공유자 전원의 명의 (지분을 기재)	합유자 전원의 명의 (합유인 뜻을 기재/ 합유지분 등기 불가)	권리능력 없는 사단 자체의 명의로 등기

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 소유물반환청구권의 청구권자는 현재의 소유자이다. 이러한 소유자는 사실심변론종결 당시의 소유자이면 족하므로 소유물반환청구의 소제기후 사실심변론종결 전에 소유자로 등기된 자는 소유물반환청구권의 주체로 된다.
- ② 도로예정지로 편입되어 사실상 일반공중의 통행로로 사용되어 온 토지의 소유자가 그 독점적이고 배타적인 사용·수익권을 포기한 것으로 볼 경우라도, 그 토지를 불법점유하고 있는 제3자에 대하여 물권적 청구권을 행사하여 토지의 반환 내지 방해의 제거, 예방을 청구할 수 있다.
- ③ 위 ②의 경우 특별한 사정이 없는 한 토지소유자는 그 이후에도 토지를 독점적, 배타적으로 사용수익할 수는 없고, 따라서 제3자가 그 토지를 불법점유하였다 하더라도 이로 인하여 토지소유자에게 어떠한 손실이 생긴다고 할 수 없어 그 점유로 인한 부당이득의 반환을 청구할 수는 없다.
- ④ 부동산의 양도담보권설정자는 그 부동산의 등기명의가 양도담보권자 앞으로 되어있다 할지라도 가등기담보법에 의해 청산금지급 전까지 소유권이전이 인정되지 않으므로 등기명의에도 불구하고 그 부동산의 불법점유자인 제3자에 대하여는 그 실질적 소유자임을 주장하여 불법점유의 상태의 배제권을 행사할 수 있다.
- ⑤ 동산양도담보의 경우에는 그 성격을 신탁적 소유권이전으로 보는 입장에서는 양도담보설정자(채무자)가 소유물반환청구권을 행사하고 양도담보권자(채권자)는 이 청구권을 갖지 않는다.
- ⑤. 동산양도담보의 경우에는 그 성격을 신탁적 소유권이전으로 보는 입장(대판 1994. 8. 26, 93다44739; 대판 2004. 12. 24. 2004다45943)에서는 외부관계에서 물건의 소유자는 양도담보권자(채권자)가 되므로 양도담보권자가 소유물반환청구권을 행사하고 설정자(채무자)는 이 청구권을 갖지 않는다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 청구권의 상대방은 「현재」 그 물건을 점유함으로써 소유자의 점유를 방해하고 있는 자이다. 따라서 불법행위자라도 그 물건을 다른 사람에게 인도하여 현실적으로 점유를 하고 있지 않은 이상, 그 불법점유자를 상대로 한 인도 또는 명도청구는 부당하다
- ② 미등기건물을 그 소유권의 원시취득자로부터 양도받아 점유 중에 있는 자는 소유권취득등기를 하지 못하였으므로 그 권리의 범위 내에서는 점유 중인 건물을 법률상 또는 사실상 처분할 수 없는 지위에 있으므로 그 건물의 존재로 불법점유를 당하고 있는 토지소유자는 위와 같은 건물점유자에게는 그 철거를 구할 수 없다.
- ③ 소유물반환청구의 상대방은 현재 그 물건을 점유하는 자이고 그 점유보조자에 불과한 자는 이에 해당하지 아니하므로, 주식회사의 직원으로서 회사의 사무실로 사용하고 있는 건물부분에 대한 점유보조자에 불과할 뿐 독립한 점유주체가 아닌 피고들은, 회사를 상대로 한 명도소송의 확정판결에 따른 집행력이 미치는 것은 별론으로 하고, 소유물반환청구의 성질을 가지는 퇴거청구의 독립한 상대방이 될 수는 없는 것이다.
- ④ 공유자가 소유자 토지에 무단으로 공유물을 설치한 경우에는 그 공유자는 지분의 범위 내에서 반환을 할 수 있으므로 토지소유자는 반드시 공유자 전원을 상대로 반환청구(시설물의 철거)를 할 필요는 없고 개별적으로 청구를 할 수 있다.

⑤ 점유침탈자인 상대방의 점유 중에 생긴 과실취득, 목적물을 멸실·훼손한 경우의 손해배상책임, 비용을 지출한 경우의 상환청구 등의 문제에 관하여는 우리 민법은 아무 규정을 두고 있지 않다. 이에 관하여 학설은 계약관계가 있었다면 그 계약관계를 지배하는 법조항에 의하고, 그러한 계약관계가 없는 때에는 점유자와 회복자의 관계에 관한 규정(제201조 내지 제203조)을 적용한다.

②. 건물철거는 그 소유권의 종국적 처분에 해당하는 사실행위이므로 원칙으로는 그 소유자에게만 그 철거처분권이 있으나 미등기건물을 그 소유권의 원시취득자로부터 양도받아 점유 중에 있는 자는 비록 소유권취득등기를 하지 못하였다고 하더라도 그 권리의 범위 내에서는 점유 중인 건물을 법률상 또는 사실상 처분할 수 있는 지위에 있으므로 그 건물의 존재로 불법점유를 당하고 있는 토지소유자는 위와 같은 건물점유자에게 그 철거를 구할 수 있다(대판 1989. 2. 14, 87다카3073).

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

① 어떤 부동산에 관하여 채권 담보를 위한 가등기가 경료된 후에 매매에 의하여 그 소유권을 취득한 제3자가 채무원리금을 변제함으로써 피담보채무가 전부 소멸하였음에도 불구하고 등기부상 가등기가 그대로 남아있음을 이용하여 가등기 명의자가 가등기에 기한 소유권이전의 본등기를 경료하고 나아가 타인 명의로 가등기까지 경료하였다 하더라도 피담보채무의 소멸 후의 위 담보가등기는 원인무효이고, 위 가등기에 기하여 경료된 본등기 및 타인 명의의 가등기도 원인무효이며, 나아가 위 가등기에 기한 본등기가 경료됨으로써 등기공무원이 직권으로 한 가등기 후의 위 제3자 명의의 소유권이전등기의 말소등기 역시 원인무효이어서 위 제3자는 여전히 소유권자로서의 지위를 잃지 않는다.

② 위 ①의 경우 제3자로서는 위 말소등기의 회복 여부에 관계없이 소유권에 기한 방해배제청구로서 “직접 등기 명의자를 상대”로 원인무효인 위 각 가등기 및 가등기에 기한 본등기의 말소를 청구하여 그 등기가 말소되면 등기공무원이 다시 직권으로 말소된 위 제3자 명의의 소유권이전등기의 회복등기를 할 수 있다.

③ 위 ①의 경우 제3자 명의로 경료된 소유권이전등기가 잘못 말소되었다 하여 이미 목적 달성으로 소멸한 전 소유자에 대한 소유권이전등기청구권이 다시 발생한다고는 할 수 없으므로 위 제3자에게는 전 소유자를 대위하여 위 각 가등기 및 본등기의 말소를 청구할 피보전권리가 없다.

④ 소유물방해제거청구권에서 방해라 함은 현재에도 지속되고 있는 침해를 의미하고, 법익 침해가 과거에 일어나서 이미 종결된 경우에 해당하는 ‘손해’의 개념과는 다르다 할 것이어서, 소유권에 기한 방해배제청구권은 방해결과의 제거를 내용으로 하는 것이 되어서는 아니 되며(이는 손해배상의 영역에 해당한다 할 것이다) 현재 계속되고 있는 방해의 원인을 제거하는 것을 내용으로 한다.

⑤ 쓰레기 매립으로 조성한 토지에 소유자가 매립에 동의하지 않은 쓰레기가 매립되어 있다면, 이는 위법한 매립공사로 인하여 생긴 결과로서 소유자가 입은 손해에 해당하는 것이 아니라, 방해라고 볼 수 있다.

⑤. 방해라 함은 현재에도 지속되고 있는 침해를 의미하고, 법익 침해가 과거에 일어나서 이미 종결된 경우에 해당하는 ‘손해’의 개념과는 다르다 할 것이어서, 소유권에 기한 방해배제청구권은 방해결과의 제거를 내용으로 하는 것이 되어서는 아니 되며(이는 손해배상의 영역에 해당한다 할 것이다) 현재 계속되고 있는 방해의 원인을 제거하는 것을 내용으로 한다. 따라

서 쓰레기 매립으로 조성한 토지에 소유자가 매립에 동의하지 않은 쓰레기가 매립되어 있다 하더라도, 이는 위법한 매립공사로 인하여 생긴 결과로서 소유자가 입은 손해에 해당할 뿐, 방해라고 볼 수는 없다(대판 2003. 3. 28, 2003다5917).

♣ 학습정리

1. 공유물의 분할은 당사자 간에 협의가 이루어지는 경우에는 그 방법을 임의로 선택할 수 있으나 협의가 이루어지지 아니하여 재판에 의하여 공유물을 분할하는 경우에는 법원은 현물로 분할하는 것이 원칙이고, 현물로 분할할 수 없거나 현물로 분할을 하게 되면 현저히 그 가액이 감소될 염려가 있는 때에 비로소 물건의 경매를 명할 수 있다.
2. 물건이 지분에 의하여 수인의 소유로 된 때에는 공유로 한다. 공유자의 지분은 균등한 것으로 추정한다.
3. 등기부상 등기명의자의 공유지분의 분자 합계가 분모를 초과하는 경우에는 등기부의 기재 자체에 의하여 그 등기가 부실함이 명백하므로 그 중 어느 공유지분에 관한 등기가 무효인지를 가려보기 전에는 등기명의자는 등기부상 공유지분의 비율로 공유한다고 추정할 수 없을 뿐만 아니라, 공유지분의 분모를 분자 합계로 수정한 공유지분의 비율로 공유한다고 추정할 수도 없다.
4. 소유권에 기한 방해배제청구권은 방해결과의 제거를 내용으로 하는 것이 되어서는 아니 되며, 현재 계속되고 있는 방해의 원인을 제거하는 것을 내용으로 한다.
5. 도로예정지로 편입되어 사실상 일반공중의 통행로로 사용되어 온 토지의 소유자가 그 독점적이고 배타적인 사용·수익권을 포기한 것으로 볼 경우라도, 그 토지를 불법점유하고 있는 제3자에 대하여 물권적 청구권을 행사하여 토지의 반환 내지 방해의 제거, 예방을 청구할 수 있다.

제23강 공유

♣ 학습목표

1. 공유자 간의 법률관계를 정리할 수 있다.
2. 공유물 분할에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 공유지분의 처분
- 공유자 간의 법률관계
- 공유의 주장
- 공유물 분할

♣ 사전 테스트

1. 공유물의 분할은 당사자 간에 협의가 이루어지는 경우에는 그 방법을 임의로 선택할 수 있으나 협의가 이루어지지 아니하여 재판에 의하여 공유물을 분할하는 경우에는 법원은 자유로운 선택으로 현물로 분할하거나 물건의 경매를 명할 수 있다.
⇒ × : 공유물의 분할은 당사자 간에 협의가 이루어지는 경우에는 그 방법을 임의로 선택할 수 있으나 협의가 이루어지지 아니하여 재판에 의하여 공유물을 분할하는 경우에는 법원은 현물로 분할하는 것이 원칙이고, 현물로 분할할 수 없거나 현물로 분할을 하게 되면 현저히 그 가액이 감소될 염려가 있는 때에 비로소 물건의 경매를 명할 수 있다.
2. 등기부상 등기명의자의 공유지분의 분자 합계가 분모를 초과하는 경우에는 공유지분의 분모를 분자 합계로 수정한 공유지분의 비율로 공유한다고 추정한다.
⇒ × : 등기부상 등기명의자의 공유지분의 분자 합계가 분모를 초과하는 경우에는 등기부의 기재 자체에 의하여 그 등기가 부실함이 명백하므로 그 중 어느 공유지분에 관한 등기가 무효인지를 가려보기 전에는 등기명의자는 등기부상 공유지분의 비율로 공유한다고 추정할 수 없을 뿐만 아니라, 공유지분의 분모를 분자 합계로 수정한 공유지분의 비율로 공유한다고 추정할 수도 없다.
3. 공유물의 관리에 관한 사항은 공유자의 지분의 과반수로써 결정한다. 그러나 보존행위는 각자가 할 수 있다.
⇒ ○

♣ 강의교안

Ⅷ-2. 공유

1. 서설

(1) 공유 및 지분의 법적 성질

양적분할설(통설·판례) : 1개 소유권의 양적 분할 - 일물일권주의에 부합

지분은 공유자가 목적물에 가지는 소유의 비율

다수소유권경합설 : 수인이 각자 소유권을 갖지만 각 소유자는 일정비율에 따라

지분은 1개의 소유권

[판 례] 공유의 법적 성질

공유는 물건에 대한 공동소유의 한 형태로서 물건에 대한 1개의 소유권이 분량적으로 분할되어 여러 사람에게 속하는 것이므로 특별한 사정이 없는 한 각 공유자는 공유물의 분할을 청구하여 기존의 공유관계를 폐지하고 각 공유자간에 공유물을 분배하는 법률관계를 실현하는 일방적인 권리를 가지는 것이며(공유물분할의 자유), 공유물의 분할은 당사자 간에 협의가 이루어지는 경우에는 그 방법을 임의로 선택할 수 있으나 협의가 이루어지지 아니하여 재판에 의하여 공유물을 분할하는 경우에는 법원은 현물로 분할하는 것이 원칙이고, 현물로 분할할 수 없거나 현물로 분할을 하게 되면 현저히 그 가액이 감소될 염려가 있는 때에 비로소 물건의 경매를 명할 수 있다(대판 1991. 11. 12, 91다27228).

지분은 각 공유자가 목적물에 대하여 가지는 소유권의 비율이나, 지분권은 그 지분에 기하여 각 공유자가 공유물에 대하여 가지는 권리이다. 이와 같이 지분과 지분권은 이론상으로는 구별되나, 민법(제266조·제267조)상의 「지분」이란 용어는 이들 두 가지 의미를 모두 포함하고 있어서, 실제로는 엄격하게 이들을 구별하지 않고 있다.

(2) 공유의 성립

1) 법률행위에 의한 성립

공유의 합의(1개의 물건을 수인이 공동소유로 한다는 뜻의 의사의 합치)

동산의 경우에는 공동점유, 부동산의 경우에는 등기(부동산등기법 제67조 제1항)

2) 법률의 규정에 의한 성립

① 수인 공동의 무주물선점(제252조)·유실물습득(제253조)·매장물발견(제254조 본문)·타인의 물건 속에서의 매장물발견(제254조 단서).

② 주종을 구별 못하는 동산의 부합(제257조 후단)·혼화(제258조)

③ 공유물의 과실(제102조)

- ④ 건물 구분소유에서의 공용부분(제215조 제1항)과 경계에 설치된 경계표·담·구거 등(제239조). 이러한 공유에는 분할청구가 인정되지 않는다(제268조 제3항). 따라서 공유지분의 포기도 금지된다(집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제22조).
- ⑤ 귀속불명의 부부재산(제830조 제2항).
- ⑥ 공동상속재산(제1006조)과 공동포괄수증재산(제1078조) : 공유설

[사례] A, B가 공동상속한 부동산을 제3자 C가 자기 소유로 등기한 경우는?

1. 공동상속의 성질 : 공유이다(다수설·판례. 대판 1966. 4. 19, 66다415)
2. C가 매매를 원인으로 등기를 하였다고 주장한 경우 공유자 1인의 청구
→ A는 단독으로 C의 등기 전부의 말소를 청구할 수 있다(판례), 보존행위로서 자기 지분을 넘은 전부에 대해 권리주장이 가능하다. 이는 물권적 청구권의 성질을 지닌다. 따라서 소멸시효의 대상이 되지 않는다.
3. C가 상속인 외관을 갖추고 상속인임을 주장하여 상속등기를 받아간 경우
(주의 : C가 상속인 외관, 즉 참칭상속의 외관이 아닌 단순히 매매, 증여 등을 원인으로 하여 등기하고 있는 경우는 위의 2에 해당한다)
→ C는 참칭상속인이므로 상속권자 A나 B의 C에 대한 반환청구나 등기말소청구는 상속회복청구권의 성질을 갖는다. 따라서 이 경우에는 상속권의 침해로 안 날로부터 3년, 상속권을 침해한 날로부터 10년의 제척기간의 적용을 받는다(제999조)

참고 : 신탁법상 신탁에서 공동신탁 : 공동수탁자의 합유이다(신탁법 제50조).

2. 공유의 지분

(1) 지분의 비율

당사자 약정, 법률의 규정 → 불분명하면 균등 추정(제262조 제2항)

제262조(물건의 공유)

- ① 물건이 지분에 의하여 수인의 소유로 된 때에는 공유로 한다.
- ②공유자의 지분은 균등한 것으로 추정한다.

[판례] 지분에 관한 묵시적 약정 사례

부동산의 1/2 지분 공유자 겸 나머지 1/2 지분의 명의수탁자 갑이 을과 자신의 지분 1/2 중 1/2 지분(전체의 1/4 지분)에 관하여 대물변제의 약정을 하면서 명의신탁자 병의 지분까지 확인하는 내용의 문서를 작성하였다면, 위와 같은 합의의 취지는 단순히 갑이 을에게 지분을 양도하는 것에 그치는 것이 아니라, 나아가 갑, 을, 병 3인의 각 지분의 비율을 확인하고 그들 사이에서는 각자의 지분의 비율에 따라서만 권리를 주장하기로 하는 뜻까지 포함하는 것이라고 봄이 상당하므로 자신의 지분 중 일부를 을에게 이전하여 줄 의무가 있는 갑으로서 을에 대한 관

계에서 단지 1/4 지분에 관하여만 권리를 주장할 수 있다(대판[전합] 1994. 3. 22, 93다9392·93다9408).

[판례] 등기부상 등기명의자의 공유지분의 분자 합계가 분모를 초과하는 경우, 등기명의자가 등기부상 공유지분 비율로 공유한다고 추정되는지 여부(소극)

소유권지분이전등기가 경료되어 있는 경우, 일단 등기명의자는 공유지분 비율에 의한 적법한 공유자로 추정되는 것이나, 등기부상 등기명의자의 공유지분의 분자 합계가 분모를 초과하는 경우에는 등기부의 기재 자체에 의하여 그 등기가 부실함이 명백하므로 그 중 어느 공유지분에 관한 등기가 무효인지를 가려보기 전에는 등기명의자는 등기부상 공유지분의 비율로 공유한다고 추정할 수 없을 뿐만 아니라, 공유지분의 분모를 분자 합계로 수정한 공유지분의 비율로 공유한다고 추정할 수도 없다(대판 1997. 9. 5, 96다33709).

(2) 지분의 처분

제263조(공유지분의 처분과 공유물의 사용, 수익)

공유자는 그 지분을 처분할 수 있고 공유물 전부를 지분의 비율로 사용, 수익할 수 있다.

1) 지분처분의 자유 및 제한

- ① 각 공유자는 그의 지분을 처분할 수 있다(제263조). 다른 공유자의 동의는 필요하지 않다(대판 1972. 5. 23, 71다2760). 다만 구분건물의 소유자는 그가 소유하는 전유부분과 분리하여 공용부분 및 대지사용권에 대한 지분을 처분할 수 없다(집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제20조).
- ② 담보물권은 자기의 지분에 대하여 단독으로 설정 가능하다. 용익물권 및 임차권 등의 설정은 공유자가 공유물의 특정부분을 배타적으로 사용할 수 없으므로 비록 지분의 범위에서 일지라도 용익물권을 설정할 수 없다.

2) 지분양도의 효과

- ① 지분이 양도된 경우에 그 양수인은 양도인이 받고 있었던 것과 같은 제약(사용·수익의 방법에 관한 특약)을 받는 지분을 취득한다.
- ② 부동산에 관한 분할금지특약(불분할의 특약) 및 공유자 상호간에 이미 성립한 개개의 채권채무가 양수인에게 승계되는가? → 등기되지 않은 한 양수인에게 승계되지 않는다.

3) 처분금지특약(지분양도금지의 특약)

지분양도금지의 특약은 유효하나 채권적 효력만을 가질 뿐이다(통설). 부동산등기법상 이 특약을 등기하는 것은 인정되어 있지 않다.

3. 공유자 간의 법률관계

(1) 공유물의 사용·수익

1) 지분비율에 의한 사용·수익

제263조(공유지분의 처분과 공유물의 사용, 수익)

공유자는 그 지분을 처분할 수 있고 공유물 전부를 지분의 비율로 사용, 수익할 수 있다.

① 각 공유자는 공유물의 전부를 지분의 비율로 사용·수익할 수 있다(제263조). 공유물의 사용·수익의 방법은 공유자 상호간의 협정에 의하여 결정한다.

② 공유자 사이에 공유물을 사용·수익할 구체적인 방법을 정하는 것은 공유물의 관리에 관한 사항으로서 공유자의 지분의 과반수로써 결정하여야 할 것이다.

→ 협의 없다면 과반수 지분권자 단독으로 결정 가능(자기가 특정부분 배타적 사용·수익가능. 또는 3자에게 임대가능. 단 관리가 아닌 처분이나 변경 정도에 이르러서는 안됨(건축 X))

(2) 공유물의 관리·보존

제265조(공유물의 관리, 보존)

공유물의 관리에 관한 사항은 공유자의 지분의 과반수로써 결정한다. 그러나 보존행위는 각자가 할 수 있다.

1) 공유물의 관리

① 관리

관리 : 처분이나 변경에 이르지 않는 정도로서 공유물을 보존·이용·개량하는 행위.

관리에 관한 사항 : 공유자 지분의 과반수로 결정(제265조 본문).

보존행위 : 각자가 단독으로 할 수 있다(제265조 단서).

공유자 지분의 과반수의 결정이 필요한 관리행위의 판례의 예

- ① 상가건물 임대차보호법이 적용되는 상가건물의 공유자인 임대인이 같은 법 제10조 제4항에 의하여 (상가건물)임차인에게 갱신거절의 통지를 하는 것(대판 2010. 9. 9, 2010다37905)
- ② 공유토지 중 도로보다 높은 부분을 굴착하여 도로와 같은 높이로 정지하는 공사는 공유토지의 이용가치를 높이는 것(대판 1991. 4. 12, 90다20220).
- ③ 과반수 공유지분권자가 그 공유물의 특정 부분을 배타적으로 사용·수익(예컨대 임대차)할 것을 정하는 것이 공유물의 관리방법으로서 적법하다(대판 2001. 11. 27, 2000다33638·33645; 대판 2002. 5. 14, 2002다9738).

- ① 나대지에 새로이 건물을 건축한다든지 하는 것은 관리의 범위를 넘는 것이다(대판 2001. 11. 27, 2000다33683·33645 참조).

Q : 계약의 해제 또는 해지가 관리행위에 해당하는가가 아니면 처분·변경행위로서 제264조 및 제547조 제1항과 관계되어 전원의 동의를 얻어야 하는가?

판례 : 위토경작계약의 해지는 관리행위라고 할 수 있는 것이므로 특단의 사정이 없는 한 민법 제265조 본문에 의하여 공유자의 과반수의 결의가 필요하다(대판 1964. 9. 22, 64다288).

② 과반수 결의

일부 공유자를 제외하고 서면으로 공유물의 관리방법을 정하였다고 하더라도 참여한 공유자들의 공유지분을 전부 합하면, 과반수를 넘는 경우(예컨대 963분의 780)에도 이러한 결의는 공유자 전원에 대한 관계에 있어서 유효하다(대판 1980. 9. 9, 79다1131·1132; 대판 1966. 2. 28, 65다2348판결 참조).

2) 공유물의 보존

보존행위는 각자가 단독으로 할 수 있다(제265조 단서).

공유물의 보존행위란 공유물의 멸실·훼손을 방지하고 그 현상을 유지하기 위하여 하는 사실적·법률적 행위를 말한다.

보존행위의 예

- ① 공유물에 관한 제3자의 원인무효 등기의 말소를 청구하는 행위(대판 2009. 2. 26, 2006다72802; 대판 1960. 7. 7, 4292민상46; 대판 1966. 7. 19, 66다800)
- ② 공유자 1인(토지 1/2 지분권자)이 나머지 공유자(토지 1/2 지분권자)의 정당한 협의 없이 공유물을 배타적으로 사용하는 경우 나머지 지분권자의 공유물보존행위로서 그 배타적 사용의 배제, 즉 지상 건물의 철거와 토지의 인도를 청구하는 행위(대판 2003. 11. 13, 2002다57935; 대판 1983. 2. 22, 80다1280·1281)
- ③ 공유에 속하는 권리가 제3자에 의하여 방해받는 경우에 각 공유자는 단독으로 그 방해제거를 청구하는 행위(대판 1991. 9. 24, 91다23639)

- ④ 공유부동산의 불법점거자에 대하여 손해배상을 청구하는 것도 보존행위이다(대판 1962. 4. 12, 4294민상1242). 다만 이 경우에는 공유물에 끼친 불법행위를 이유로 하는 손해배상청구권은 특별한 사유가 없는 한 각 공유자가 그 지분에 대응한 비율의 한도에서만 이를 행사할 수 있고 타인의 지분에 대해서는 청구권이 없다(대판 1970. 4. 14, 70다171).

[판례] 과반수 지분을 갖지 못한 공유자가 부동산을 임의로 타에 임대한 경우

가. 부동산의 1/7 지분 소유권자가 타공유자의 동의없이 그 부동산을 타에 임대하여 임대차보증금을 수령하였다면, 이로 인한 수익 중 자신의 지분을 초과하는 부분에 대하여는 법률상 원인없이 취득한 부당이득이 되어 이를 반환할 의무가 있고, 또한 위 무단임대행위는 다른 공유지분권자의 사용, 수익을 침해한 불법행위가 성립되어 그 손해를 배상할 의무가 있다.

나. 위 "가"항의 경우 반환 또는 배상해야 할 범위는 위 부동산의 임대차로 인한 차임 상당액이라 할 것으로서 타공유자는 그 임대보증금 자체에 대한 지분비율 상당액의 반환 또는 배상을 구할 수는 없다.

다. 위 "가"항의 경우 공유물의 보존행위란 공유물의 현상을 유지하기 위하여 이를 침해하는 제3자에게 그 배제를 구하는 행위를 말하므로 그 행위의 전제로서 공유자가 수령한 임대차보증금 중 자신의 지분비율 상당액의 지급을 구할 수 없다(대판 1991. 9. 24, 91다23639).

3) 공유물의 이용·개량

공유물의 이용이라 함은 공유물을 그의 경제적 용도에 따라서 활용하는 것이며, 공유물의 개량이라 함은 사용가치를 증대케 하는 것으로 변경의 정도까지는 이르지 않는 것이다. 공유물의 이용 및 개량에 관한 사항은 공유자의 과반수가 아니고 각 공유자의 지분의 과반수로써 결정한다(제265조 본문). 판례에 의하면 과반수의 동의가 있는 한 일부의 공유자에게 의사를 묻지 않았더라도 그 결의는 유효하며(대판 1980. 9. 9, 79다1132), 또한 과반수의 지분을 가진 공유자는 별도의 결정을 거치지 않더라도 독자적으로 이용·개량행위를 할 수 있다고 한다(대판 1991. 9. 24, 88다카33855). 따라서 과반수의 지분을 가지는 공유자의 임대행위는 적법한 것이다(대판 1966. 10. 25, 66다1388).

(3) 공유물의 처분·변경

제264조(공유물의 처분, 변경)

공유자는 다른 공유자의 동의없이 공유물을 처분하거나 변경하지 못한다.

1) 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 공유물을 처분하거나 변경하지 못한다(제264조).

① 처분

법률상의 처분 또는 사실상의 처분

전세권과 같은 용익물권도 포함

지상권의 설정(대판 1993. 4. 13, 92다55756)

② 변경

건물의 축조·토지의 개간·동산의 가공 등과 같이 목적물이 멸실되지 않는 범위에서 목적물에 대한 사실상의 물리적인 변경을 의미

(4) 공유물에 관한 부담

제266조(공유물의 부담)

- ① 공유자는 그 지분의 비율로 공유물의 관리비용 기타 의무를 부담한다.
- ② 공유자가 1년 이상 전항의 의무이행을 지체한 때에는 다른 공유자는 상당한 가액으로 지분을 매수할 수 있다.

1) 대내적 : 지분비율에 따른 관리비용 부담 / 대외적 : 원칙적 불가분채무

공유자는 그 지분의 비율로 공유물의 관리비용 기타 의무를 부담한다(제266조 제1항). 이 규정은 공유자 상호간의 내부관계에 관한 규정이고 제3자에 대한 대외적 관계에는 적용되지 않는다(대판 2009. 11. 12, 2009다54034·54041; 대판 1991. 4. 12, 90다20220; 대판 1985. 4. 9, 93다카1775). 대외적 관계에서는 비록 그것이 금전채무라 하더라도 각 공유자가 공동 불가분적으로 이익의 대가라는 의미를 가지므로 원칙적으로 불가분채무이고, 따라서 공유자 각자가 전액을 지급할 의무를 진다.

공유자가 부담하는 공유물에 관한 채무가 불가분채무인 경우

- ① 공유자가 타인의 재산을 사용한 경우의 부당이득 반환채무는 특별한 사정이 없는 한 불가분적 이득의 반환으로서 불가분채무이고, 불가분채무는 각 채무자가 채무 전부를 이행할 의무가 있으며, 1인의 채무이행으로 다른 채무자도 그 의무를 면하게 된다(대판 2001. 12. 11, 2000다13948).
- ② 시의 공유재산인 토지를 공유건물의 주차장 용도로 점유 사용한 공유자 중 1인에 대하여 한 변상금 전액부과처분(대판 1992. 9. 22, 92누2202)
- ③ 건물의 공유자가 공동으로 건물을 임대하고 보증금을 수령한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 임대는 각자 공유지분을 임대한 것이 아니고 임대목적물을 다수의 당사자로서 공동으로 임대한 것이고 그 보증금 반환채무(대판 1998. 12. 8, 98다43137)

[판례] 공유물의 관리비용에 관한 공유자의 제3자에 대한 책임(불가분채무)

[1] 공유자가 공유물의 관리에 관하여 제3자와 계약을 체결한 경우에 그 계약에 기하여 제3자가 지출한 관리비용의 상환의무를 누가 어떠한 내용으로 부담하는가는 일차적으로 당해 계약의 해석으로 정하여진다. 공유자들이 공유물의 관리비용을 각 지분의 비율로 부담한다는 내용의 민법 제266조 제1항은 공유자들 사이의 내부적인 부담관계에 관한 규정일 뿐이다. 한편, 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제10조, 제12조, 제17조는 집합건물의 공용부분을 구분소유자의 전유부분 면적비율에 의한 공유로 하고, 공용부분의 관리비용은 규약에 달리 정함이 없는 한 그 지분비율에 따라 부담한다는 내용으로서, 공용부분의 관리비용 부담에 관한 구분소유자들의 내부관계에 관한 규정일 뿐이고, 공유인 전유부분에 대한 관리비용의 부담에 관하여 제3자에 대한 대외적인 책임이 문제된 경우에 적용될 수 있는 규정이 아니다.

[2] 상가건물의 일부에서 숙박업을 하는 공유자들이 건물의 관리를 담당한 단체와 체결한 위 숙박사업장의 관리에 관한 계약은 상법 제57조 제1항에서 규정하는 상행위에 해당하므로, 위 공유자들은 연대하여 관리비 전액의 지급의무를 부담한다(대판 2009. 11. 12, 2009다54034·54041).

2) 의무불이행에 의한 공유자의 지분취득

공유자가 1년 이상 관리비용 기타 부담의 의무를 이행하지 않는 경우에, 다른 공유자는 상당한 가액으로 그 자의 지분을 매수할 수 있다(제266조 제2항). 공유자의 지분매수청구권은 상대방의 동의를 요하지 않는 일종의 형성권으로 의무불이행자를 제외한 모든 공유자에게 인정되며, 의무불이행자를 대신하여 이행한 공유자에게 한정되는 것이 아니다. 이를 행사하기 위해서는 매수대상이 되는 지분 전부에 대한 매매대금을 제공하거나 지급하여야 한다(대판 1992. 10. 9, 92다25656).

▶ 돌발 퀴즈

공유자는 그 지분의 비율로 공유물의 관리비용 기타 의무를 부담한다(제266조 제1항). 이 규정은 공유자 상호간의 내부관계 뿐만 아니라 제3자에 대한 대외적 관계에도 적용된다.

⇒ × : 공유자는 그 지분의 비율로 공유물의 관리비용 기타 의무를 부담한다(제266조 제1항). 이 규정은 공유자 상호간의 내부관계에 관한 규정이고 제3자에 대한 대외적 관계에는 적용되지 않는다(대판 2009. 11. 12, 2009다54034·54041; 대판 1991. 4. 12, 90다20220; 대판 1985. 4. 9, 93다카1775)

4. 공유의 주장

(1) 지분의 대외적 주장

지분은 실질에 있어서 독립한 소유권과 같으므로 각 공유자는 단독으로 다른 공유자 및 제3자에 대하여 그의 지분을 주장할 수 있다.

1) 지분의 확인청구 등

① “자신의” 지분확인 소 단독으로 가능

공유자는 지분의 확인을 구하는 때에는 자기의 지분을 부인하거나 또는 다투는 다른 공유자 또는 제3자를 상대방으로 하여 단독으로 소를 제기할 수 있다. 즉 이 소송은 필수적 공동소송이 아니며(대판 1994. 11. 11, 94다35008), 기판력은 소의 당사자 사이에서만 생긴다.

② “다른 공유자의” 지분에 대해 제3자를 상대로 한 지분확인 불가(<- - 확인의 이익 없음)

공유자가 다른 공유자의 지분권을 대외적으로 주장하는 것은 공유물의 보존행위가 아니므로 각 공유자가 단독으로 행사할 수 없다(대판 2010. 1. 14, 2009다67429).

공유자가 제3자를 상대로 전체로서의 공유관계의 확인(공유물 전체에 대한 소유관계 확인)을 구하는 것은 필수적 공동소송이므로 각 공유자가 단독으로 할 수 없고 전원이 공동으로 하여야 한다(대판 1994. 11. 11, 94다35008).

③ “자신의” 지분등기청구 가능 → 다른 공유자의 지분이전등기청구 단독으로 불가

공유물이 타인(예; 매도인)의 단독명의로 등기되어 있는 경우에는 각 공유자는 “자기 지분”의 이전등기를 청구할 수 있다(대판 1990. 12. 7, 90다카26355).

④ 공유물 전부에 대해 일부 공유자의 단독명의로 등기가 되어 있는 경우

공유부동산이 공유자 중 1인의 명의로 등기된 경우에는 다른 공유자는 그 등기의 전부말소를 청구할 수는 없고, 그 명의인의 지분을 제외한 나머지 지분부분에 관하여만 말소를 청구할 수 있다(대판 2006. 8. 24, 2006다32200; 대판 1988. 8. 23, 87다카961).

⑤ 원인 없이 공유자 아닌 타인 명의로 등기되어 있는 경우

공유자 각자는 단독으로 지분권에 기하여 그 원인무효의 등기 전부의 말소청구를 할 수 있다(대판 1993. 5. 11, 92다52870). 판례는 보존행위임을 이유로 하지만(대판 1968. 9. 17, 68다1142), 학설은 불가분채권 규정을 유추적용한다.

(2) 지분침해에 대한 방해제거청구 등

① 다른 공유자에 대한 청구

㉠ 지분의 과반수에 미달하는 공유자 중 1인이 공유물의 전부를 배타적, 독립적으로 사용하는 경우, 다른 공유자는 단독으로 그 공유자를 상대로 그 전부의 인도를 청구할 수 있다.

[판 례] 대법원 1994.3.22. 선고 93다9392,93다9408 전원합의체 판결

[다수의견] 지분을 소유하고 있는 공유자나 그 지분에 관한 소유권이전등기청구권을 가지고 있는 자라고 할지라도 다른 공유자와의 협의 없이는 공유물을 배타적으로 점유하여 사용 수익할 수 없는 것이므로, 다른 공유권자는 자신이 소유하고 있는 지분이 과반수에 미달되더라도 공유물을 점유하고 있는 자에 대하여 공유물의 보존행위로서 공유물의 인도나 명도를 청구할 수 있다.

㉡ 과반수 지분권을 가진 자가 배타적 사용·수익하는 경우 → 공유물의 관리방법으로 적법(대판 2001. 11. 27, 2000다33638)하므로 다른 공유자는 공유물의 반환청구 불가.

(과반수 지분권자로부터 사용·수익을 허락받은 점유자에게도 마찬가지로 건물철거나 퇴거 등 점유배제요구하지 못함. 대판 2002. 5. 14, 2002다9738. 또한 부당이득반환청구도 못함(정당한 점유권원이 있기 때문) (단 과반수 지분권자에게 사용이익을 초과하는 부분의 부당이득반환청구를 할 수 있다. 대판 2002. 5. 14, 2002다9738).

② 제3자에 대한 물권적 청구

제3자가 공유물을 불법으로 점유하고 있는 경우에 각 공유자는 그의 지분권에 기한 물권적 청구권으로서 제3자에 대하여 반환청구권 내지 방해배제청구권을 행사하여 그 공유물의 전부의 인도를 단독으로 청구할 수 있다(통설·판례).

[근 거]

㉠ 통설 : 불가분채권 규정(제409조) 유추적용

㉡ 판례 : 방해제거 내지 방해배제청구는 보존행위이므로 제265조 단서에 근거.

이 때 시효중단의 효력에 관하여 판례는 공유자의 1인이 공유물의 보존행위로서 제소한 것이라고 하더라도 그로 인한 시효중단의 효력은 재판상의 청구를 한 그 공유자에 한하여 발생하고, 다른 공유자에게는 미치지 아니한다.(대판 1979. 6. 26, 79다639). → 시효취득이 진행되어 그 결과 시효취득이 된 경우 시효중단을 시킨 자와 시효취득자가 공유

4) 부당이득 반환청구

① 다른 공유자에 대한 부당이득 반환청구

공유자 1인이 지분과반수의 합의가 없이 공유물의 전부 또는 일부를 배타적으로 사용하는 경우에 다른 공유자는 자신의 지분에 상응하는 부당이득반환을 청구할 수 있다(대판 2001. 12. 11, 2000다13948; 대판 2006. 11. 24, 2006다49307·49314).

부당이득하고 있는 공유자가 특정부분을 배타적으로 사용하는 부분이 자신의 지분보다 적은 면적이더라도 그 특정부분 자체가 공유이므로 부당이득반환의 의무가 있다(대판 2001. 12. 11, 2000다13948).

② 제3자에 대한 부당이득 반환청구

공유물을 제3자가 무단으로 사용하는 경우 각 공유자는 자신의 지분의 비율 범위 내에서만 부당이득반환을 청구할 수 있다(대판 1979. 1. 30, 78다12088; 1977. 9. 13, 77다1366·1367·1368).

③ 제3자에 대한 불법행위에 기한 손해배상청구

각 공유자는 자기의 지분범위 내에서 단독으로 손해배상을 청구할 수 있다.

5. 공유물의 분할

제268조(공유물의 분할청구)

- ① 공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다.
- ② 전항의 계약을 갱신한 때에는 그 기간은 갱신한 날로부터 5년을 넘지 못한다.
- ③ 전2항의 규정은 제215조, 제239조의 공유물에는 적용하지 아니한다.

제269조(분할의 방법)

- ① 분할의 방법에 관하여 협의가 성립되지 아니한 때에는 공유자는 법원에 그 분할을 청구할 수 있다.
- ② 현물로 분할할 수 없거나 분할로 인하여 현저히 그 가액이 감소될 염려가 있는 때에는 법원은 물건의 경매를 명할 수 있다.

제270조(분할로 인한 담보책임)

공유자는 다른 공유자가 분할로 인하여 취득한 물건에 대하여 그 지분의 비율로 매도인과 동일한 담보책임이 있다.

(1) 공유물분할의 자유와 금지

1) 분할의 자유

공유물의 분할은 원칙적으로 자유이므로 각 공유자는 언제든지 공유물의 분할을 청구할 수 있다(제265조 제1항 본문). → 공동목적 없는 단순결합관계이므로 분할도 자유

2) 분할의 금지

① 법률행위에 의한 분할금지

(a) 분할금지의 특약

분할금지기간 중에도 공유자 전원의 동의가 있으면 분할할 수 있다고 할 것이다

(b) 유언에 의한 분할금지

피상속인은 유언으로 상속개시의 날로부터 5년을 경과하지 아니하는 기간 내에서 상속재산의 분할을 금지할 수 있다(제1012조).

② 법률의 규정에 의한 분할금지

(a) 건물의 구분소유에 있어서의 공용부분(제215조), 경계표, 담과 같은 경계선상의 공유물(제239조)에 관하여는 각 공유자의 일방적인 청구에 의한 분할이 인정되지 않는다(제268조 제3항).

(b) 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률에 따르면 대지 위에 구분소유권의 목적인 건물이 속하는 1동의 건물이 있을 때에는 그 대지의 공유자는 그 건물의 사용에 필요한 범위 내의 대지에 대하여는 분할을 청구하지 못한다(동법 제8조).

③ 판례에 의한 분할금지

(a) 상호명의신탁의 경우 : 공유물분할청구가 인정되지 않는다. 즉 공유물분할청구는 공유자의 일방이 그 공유지분권에 터잡아서 하는 것이므로, 공유지분권을 주장하지 아니하고 목적물의 특정 부분을 소유한다고 주장하는 자는 그 부분에 대하여 신탁적으로 지분등기를 가지고 있는 자를 상대로 하여 그 특정 부분에 대한 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등기절차의 이행을 구하면 되고, 이에 갈음하여 공유물분할청구를 할 수는 없다(대판 1996. 2. 23, 95다8430; 대판 1985. 9. 24, 85다카451·452).

(b) 공유물분할청구는 공유로 한 목적에 반하는 경우에도 허용되지 않는다. 예를 들어 공동명의신탁을 받은 경우 수탁자들이 수탁 받은 부동산에 대하여 공유물분할을 하는 것은 명의신탁의 목적에 반하고 신탁자가 명의신탁을 한 취지에도 어긋나는 것이고, 특히 종중의 재산을 보존하고 함부로 처분하지 못하게 하기 위하여 다수의 종중원에게 공동으로 명의신탁한 경우에는 더욱 그 취지에 반하는 것으로 허용되지 아니한다(대판 1993. 2. 9, 92다37482).

(2) 분할의 방법

공유물의 분할은 우선 협의에 의하여 행하여지고(제268조 제1항) 협의가 이루어지지 않을 때에는 법원에 그 분할을 청구할 수 있다.

1) 분할청구권

각 공유자는 언제든지 공유물의 분할을 청구할 수 있다.

분할청구권은 형성권

공유물분할청구권은 공유관계가 존재하는 한 언제나 행사할 수 있으므로 소멸시효에 걸리지 않는다(대판 1981. 3. 24, 80다1888·1889).

공유물분할청구권의 행사로 공유자는 분할협의를 할 의무를 부담하게 되고 협의가 없으면 법원에 그 분할의 실현을 청구할 수 있다(제269조 제1항).

2) 협의에 의한 분할

협의를 통한 분할방법에 관하여 민법에 아무런 규정을 두고 있지 않다. 그러나 협의에 의하여 분할방법을 임의로 정할 수 있다는 것은 계약자유 원칙상 당연한 것이다. 이 협의는 공유자전원에 의하여 이루어져야 하고 그렇지 않은 협의는 무효이다(대판 1968. 6. 25, 68다647). 일단 협의가 성립한 이상 반드시 지분비율에 따르지 않더라도 무방하다. 협의에 의한 분할을 하는 때에는 그 방법에 제한이 없지만 일반적으로 다음과 같은 3가지가 있다.

원칙 : 현물분할 // 보충적으로 대금분할(매각대금)/가액보상(1인이 단독으로 취득)

3) 재판에 의한 분할

형식적 형성의 소/ 피고는 원고 이외의 공유자 전원(필수적 공동소송)/ 법원의 재량으로 분할함(원칙적으로 현물분할. 경매하여 대금분할할 수 있음)

공유물분할은 협의분할을 원칙으로 하고 협의가 성립되지 아니한 때에는 재판상 분할을 청구할 수 있으므로 공유자 사이에 이미 분할에 관한 협의가 성립된 경우에는 일부 공유자가 분할에 따른 이전등기에 협조하지 않거나 분할에 관하여 다툼이 있더라도 그 분할된 부분에 대한 소유권이전등기를 청구하든가 소유권확인을 구함은 별문제이나 또다시 소로써 그 분할을 청구하거나 이미 제기한 공유물분할의 소를 유지함은 허용되지 않는다고 한다(대판 1995. 1. 12, 94다30348).

[판례] 토지의 현물분할 방법 및 금전으로 경제적 가치의 과부족을 조정하는 분할 방법과 일부 공유자는 공유로 남겨두는 분할 방법의 가부(적극)

[1] 토지를 분할하는 경우에는 원칙적으로는 각 공유자가 취득하는 토지의 면적이 그 공유지분의 비율과 같도록 하여야 하나, 반드시 그런 방법으로만 분할하여야 하는 것은 아니고, 토지의 형상이나 위치, 그 이용 상황이나 경제적 가치가 균등하지 아니할 때에는 이와 같은 제반 사정을 고려하여 경제적 가치가 지분 비율에 상응되도록 분할하는 것도 허용된다.

[2] 토지를 현물분할함에 있어 일정한 요건이 갖추어진 경우에는 공유자 상호간에 금전으로 경제적 가치의 과부족을 조정하게 하여 분할을 하는 것도 현물분할의 한 방법으로 허용되고, 여러 사람이 공유하는 물건을 현물분할하는 경우에는 분할을 원하지 않는 나머지 공유자는 공유로 남겨두는 방법도 허용된다(대판 1997. 9. 9, 97다18219; 대판 2002. 10. 25, 2001다83852 등).

[판례] 공유물을 대금분할하기 위한 요건인 “현물분할로 인하여 현저히 가격이 감소된다”고 함의 의미와 형식적으로는 현물분할이 가능하다 하더라도 대금분할의 방법으로 공유물분할을 하여야 할 경우

재판에 의한 공유물분할은 현물분할의 방법에 의함이 원칙이나 현물분할이 불가능하거나 그것이 형식상 가능하다고 하더라도 그로 인하여 현저히 가격이 감소될 염려가 있을 때에는 공유물의 경매를 명하여 대금을 분할하는 이른바 대금분할의 방법에 의하여야 할 것인바, 여기서 “현물분할로 인하여 현저히 가격이 감소된다”고 함은 공유물 전체의 교환가치가 현물분할로 인하여 현저하게 감소될 경우뿐만 아니라 공유자들에게 공정한 분할이 이루어지지 아니하여 그중의 한 사람이라도 현물분할에 의하여 단독으로 소유하게 될 부분의 가액이 공유물분할 전의 소유지분가액보다 현저하게 감소될 경우도 이에 포함된다고 할 것이므로, 비록 형식적으로는 현물분할이 가능하다고 하더라도 공유물의 위치, 면적과 주변도로상황, 사용가치, 가격, 공유자의 소유지분비율 및 사용수익의 현황 등을 종합하여 볼 때 각 공유자의 소유지분비율에 따른 공평한 분할이 이루어질 수 없는 경우에는 현물분할방법에 의할 것이 아니라 대금분할의 방법으로 공유물을 분할하여야 한다(대판 1993. 1. 19, 92다30603; 대판 2002. 4. 12, 2002다4580 등).

(3) 분할의 효과

제270조(분할로 인한 담보책임)

공유자는 다른 공유자가 분할로 인하여 취득한 물건에 대하여 그 지분의 비율로 매도인과 동일한 담보책임이 있다.

1) 소유권의 변동

협의상의 분할의 경우에는 등기시(법률행위에 의한 물건변동이므로)

재판상의 분할의 경우에는 판결확정시(제187조에 의해 등기를 요하지 않는다)

2) 분할효과의 불소급

공유물분할은 지분의 교환 또는 매매의 실질을 가지므로 분할의 효과가 소급하지 아니한다. 단 상속재산분할은 상속개시시로 소급한다(제1015조).

3) 공유자 사이의 담보책임

공유물의 분할로 각 공유자간에는 지분의 교환 또는 매매가 행하여진 것이 된다. 지분의 비율로 매도인과 동일한 담보책임을 진다(제270조).

손해배상, 감액청구, 해제(여기서는 재분할이지만 재판상 분할의 경우는 재분할 불가)

4) 지분상의 담보물권

Q : 공유자의 지분 위에 성립하고 있는 담보물권이 분할에 의하여 어떠한 영향을 받는가?

(예를 들어 A·B의 공유물인 토지(A 지분 1/3, B 지분 2/3)에 관하여 A의 지분 위에 있는 C가 저당권을 가진 때 공유토지의 분할로 C의 지위는 어떻게 되는가?)

→ 규정 없음

A : 공유물의 분할은 분할한 때로부터 장래를 향하여 그 효력이 발생하기 때문에 공유자의 1인의 지분위에 설정된 담보물권은 그 목적물이 존속하는 한 분할에 의하여 영향을 받지 않는다. (즉 목적물 전체 위에 담보물권은 1/3지분에 해당하는 만큼의 저당권은 존속한다)

[판례] 공유토지의 분할과 지분상의 담보물권의 효력

갑·을 공유인 부동산 중 갑의 지분위에 설정된 근저당권 등 담보물권은 특단의 합의가 없는 한 공유물분할이 된 뒤에도 종전의 지분비율대로 공유물 “전부”의 위에 그대로 존속하고 근저당권설정자인 갑 앞으로 분할된 부분에 당연히 집중되는 것은 아니므로, 갑과 담보권자 사이에 공유물분할로 갑의 단독소유로 된 토지부분 중 원래의 을 지분부분을 근저당권의 목적물에 포함시키기로 합의하였다고 하여도 이런 합의가 을의 단독소유로 된 토지부분 중 갑 지분부분에 대한 피담보채권을 소멸시키기로 하는 합의까지 내포한 것이라고는 할 수 없다(대판 1989. 8. 8, 88다카24868).

5) 공유물상의 용익물권

공유물상의 용익물권은 분할로 영향을 받지 않고 분할된 각 부분 위에 존속하며, 공유물의 일부에만 존재하였던 용익물권은 분할 후에도 그 부분 위에만 존속한다(제293조 제2항).

6) 공유지에 대한 취득시효 중단

A·B 공유의 토지를 C가 점유하여 왔는데 이에 대하여 A만이 C를 상대로 방해배제를 소구하였다면, 시효중단의 효력은 A에게만 발생한다(대판 1967. 6. 26, 79다639).

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 공유자는 그 지분을 처분할 수 있고 공유물 전부를 지분의 비율로 사용, 수익할 수 있다.
- ② 공유물의 관리에 관한 사항은 공유자의 지분의 과반수로써 결정한다. 그러나 보존행위는 각자가 할 수 있다.
- ③ 과반수 공유지분권자가 그 공유물의 특정 부분을 배타적으로 사용·수익(예컨대 임대차)할 것을 정하는 것이 공유물의 관리방법으로서 적법하다.
- ④ 위토경작계약의 해지는 관리행위라고 할 수 있는 것이므로 특단의 사정이 없는 한 민법 제 265조 본문에 의하여 공유자의 과반수의 결의가 필요하다.
- ⑤ 공유부동산의 불법점거자에 대하여 손해배상을 청구하는 것도 보존행위이다. 이 경우 공유물에 끼친 불법행위를 이유로 하는 손해배상청구권은 각 공유자가 그 지분에 대응한 비율의 한도에서 이를 행사할 수도 있고 타인의 지분에 대해서도 청구권할 수 있다.
- ⑤. 공유부동산의 불법점거자에 대하여 손해배상을 청구하는 것도 보존행위이다(대판 1962. 4. 12, 4294민상1242). 다만 이 경우에는 공유물에 끼친 불법행위를 이유로 하는 손해배상청구권은 특별한 사유가 없는 한 각 공유자가 그 지분에 대응한 비율의 한도에서만 이를 행사할 수 있고 타인의 지분에 대해서는 청구권이 없다(대판 1970. 4. 14, 70다171).

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 부동산의 1/7 지분 소유권자가 타공유자의 동의없이 그 부동산을 타에 임대하여 임대차보증금을 수령하였다면, 이로 인한 수익 중 자신의 지분을 초과하는 부분에 대하여는 법률상 원인 없이 취득한 부당이득이 되어 이를 반환할 의무가 있고, 또한 위 무단임대행위는 다른 공유지분권자의 사용, 수익을 침해한 불법행위가 성립되어 그 손해를 배상할 의무가 있다.

② 위 ①의 경우 반환 또는 배상해야 할 범위는 위 부동산의 임대차로 인한 차임 상당액이라 할 것으로서 타공유자는 그 임대보증금 자체에 대한 지분비율 상당액의 반환 또는 배상을 구할 수는 없다.

③ 위 ①의 경우 공유물의 보존행위란 공유물의 현상을 유지하기 위하여 이를 침해하는 제3자에게 그 배제를 구하는 행위를 말하므로 그 행위의 전제로서 공유자가 수령한 임대차보증금 중 자신의 지분비율 상당액의 지급을 구할 수 없다.

④ 공유물의 이용 및 개량에 관한 사항은 공유자의 과반수가 아니고 각 공유자의 지분의 과반수로써 결정한다. 따라서 과반수의 지분을 가진 공유자는 별도의 결정을 거치지 않더라도 독자적으로 이용·개량행위를 할 수 있다.

⑤ 공유자는 그 지분의 비율로 공유물의 관리비용 기타 의무를 부담한다. 이 규정은 제3자에 대한 대외적 관계에도 적용된다.

⑤. 공유자는 그 지분의 비율로 공유물의 관리비용 기타 의무를 부담한다(제266조 제1항). 이 규정은 공유자 상호간의 내부관계에 관한 규정이고 제3자에 대한 대외적 관계에는 적용되지 않는다(대판 2009. 11. 12, 2009다54034·54041; 대판 1991. 4. 12, 90다20220; 대판 1985. 4. 9, 93다카1775). 대외적 관계에서는 비록 그것이 금전채무라 하더라도 각 공유자가 공동 불가분적으로 이익의 대가라는 의미를 가지므로 원칙적으로 불가분채무이고, 따라서 공유자 각자가 전액을 지급할 의무를 진다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

① 공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다.

② 공유물분할청구는 공유자의 일방이 그 공유지분권에 터잡아서 하는 것이므로, 공유지분권을 주장하지 아니하고 목적물의 특정 부분을 소유한다고 주장하는 자는 그 부분에 대하여 신탁적으로 지분등기를 가지고 있는 자를 상대로 하여 그 특정 부분에 대한 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등기절차의 이행을 구하면 되고, 이에 갈음하여 공유물분할청구를 할 수는 없다.

③ 공동명의신탁을 받은 경우 수탁자들이 수탁 받은 부동산에 대하여 공유물분할을 하는 것은 명의신탁의 목적에 반하고 신탁자가 명의신탁을 한 취지에도 어긋나는 것이고, 특히 종중의 재산을 보존하고 함부로 처분하지 못하게 하기 위하여 다수의 종중원에게 공동으로 명의신탁한 경우에는 더욱 그 취지에 반하는 것으로 허용되지 아니한다.

④ 공유물분할청구권은 공유관계가 존재하는 한 언제나 행사할 수 있으므로 소멸시효에 걸리지 않는다.

⑤ 토지를 현물분할함에 있어 공유자 상호간에 금전으로 경제적 가치의 과부족을 조정하게 하여 분할하거나, 분할을 원하지 않는 나머지 공유자의 공유로 남겨 두는 방법은 허용되지 않는다.

⑤. 토지를 현물분할함에 있어 일정한 요건이 갖추어진 경우에는 공유자 상호간에 금전으로 경제적 가치의 과부족을 조정하게 하여 분할을 하는 것도 현물분할의 한 방법으로 허용되고, 여러 사람이 공유하는 물건을 현물분할하는 경우에는 분할을 원하지 않는 나머지 공유자는 공유로 남겨 두는 방법도 허용된다(대판 1997. 9. 9, 97다18219; 대판 2002. 10. 25, 2001다83852 등)

♣ 학습정리

1. 공유자는 다른 공유자가 분할로 인하여 취득한 물건에 대하여 그 지분의 비율로 매도인과 동일한 담보책임이 있다.
2. A·B 공유의 토지를 C가 점유하여 왔는데 이에 대하여 A만이 C를 상대로 방해배제를 소구하였다면, 시효중단의 효력은 A에게만 발생한다.
3. 공유자가 다른 공유자의 지분권을 대외적으로 주장하는 것은 공유물의 보존행위가 아니므로 각 공유자가 단독으로 행사할 수 없다.
4. 공유물이 타인(예; 매도인)의 단독명의로 등기되어 있는 경우에는 각 공유자는 “자기 지분”의 이전등기를 청구할 수 있다.
5. 공유부동산이 공유자 중 1인의 명의로 등기된 경우에는 다른 공유자는 그 등기의 전부말소를 청구할 수는 없고, 그 명의인의 지분을 제외한 나머지 지분부분에 관하여만 말소를 청구할 수 있다.

제24강 합유, 총유, 준공동소유, 명의신탁 (1)

♣ 학습목표

1. 합유의 법률관계를 정리할 수 있다.
2. 총유의 법률관계를 정리할 수 있다.
3. 명의신탁제도의 기초이론을 정리할 수 있다.

♣ 학습내용

- 합유
- 총유
- 준공동소유
- 명의신탁 기초이론

♣ 사전 테스트

1. 과반수 공유지분권자가 그 공유물의 특정 부분을 배타적으로 사용·수익(예컨대 임대차)할 것을 정하는 것은 공유물의 관리방법으로서 부적법하다.
⇒ × : 과반수 공유지분권자가 그 공유물의 특정 부분을 배타적으로 사용·수익(예컨대 임대차)할 것을 정하는 것이 공유물의 관리방법으로서 적법하다.
2. 공유물분할청구권은 공유관계가 존재하는 한 언제나 행사할 수 있지만 소멸시효에 걸리지 않는 것은 아니다.
⇒ × : 공유물분할청구권은 공유관계가 존재하는 한 언제나 행사할 수 있으므로 소멸시효에 걸리지 않는다.
3. 공유물이 타인(예; 매도인)의 단독명의로 등기되어 있는 경우에는 각 공유자는 자기 지분의 이전등기를 청구할 수 있다.
⇒ ○ : 공유물이 타인(예; 매도인)의 단독명의로 등기되어 있는 경우에는 각 공유자는 “자기 지분”의 이전등기를 청구할 수 있다.

♣ 강의교안

VI-3. 합 유

제271조(물건의 합유)

- ① 법률의 규정 또는 계약에 의하여 수인이 조합체로서 물건을 소유하는 때에는 합유로 한다. 합유자의 권리는 합유물 전체에 미친다.
- ② 합유에 관하여는 전항의 규정 또는 계약에 의하는 외에 다음 3조의 규정에 의한다.

1. 합유의 의의 및 법적 성질

(1) 의 의

법률의 규정 또는 계약에 의하여 수인이 조합체로서 물건을 소유하는 공동소유형태이다(제271조 제1항).

조합체가 재산을 소유하면 합유가 성립한다(제217조 제1항; 이는 물권법상의 규정으로서 강행규정이고, 따라서 조합체의 구성원인 조합원들이 공유하는 경우에는 조합체로서 물건을 소유하는 것으로 볼 수 없다. 대판 2002. 6. 14, 2000다30622 참조).

(2) 합유의 법적 성질

- ① 지분 : 공유에서와 같이 지분 있음. 그러나 지분처분의 자유와 분할청구권은 없다.
- ② 합유물에 관한 지분의 처분 : 조합원 전원의 합의나 전원의 이름으로
- ③ 합유의 법적 성질
 - (i) 합유는 공유와 총유의 중간형태라는 견해
 - (ii) 합유는 공유와 총유의 중간형태이지만 공유에 가깝다는 견해
 - (iii) 합유는 주체의 인적 결합형태 및 민법의 규정으로부터 보면 총유에 가깝다는 견해

2. 합유의 성립

합유는 조합원의 출자 등으로 조합체가 취득한 재산에 관하여 성립한다. 조합은 법률의 규정 또는 계약에 의하여 성립한다(제271조 제1항).

(1) 계약에 의한 조합

계약으로 조합이 성립하는 경우로 조합계약(제703조 이하)

1) 동업계약

(가) 사업의 공동경영을 목적으로 하는 동업계약은 민법상 조합이므로, 그 조합이 재산을 취득하게 되면 그 재산은 동업자의 합유로 된다(대판 1956. 3. 3, 4288민상527).

공유수면매립권자들의 공동명의로 된 공유수면매립면허가 유효한 이상 면허권자들은 공동으로 당해 매립지 중 면허권자에게 귀속되는 토지의 소유권을 취득하게 되고, 나아가 공동면허권

자가 공유수면매립법의 규정에 의하여 가지는 권리의무는 그들의 합유에 속한다고 할 것이므로 당해 토지들은 매립권자들이 합유로 취득한 것이 된다(대판 1997. 4. 8, 95다34521).

(나) 민법상 조합계약은 2인 이상이 상호 출자하여 공동으로 사업을 경영할 것을 약정하는 계약으로서, 특정한 사업을 “공동경영하는 약정”에 한하여 이를 조합계약이라 할 수 있고, “공동의 목적 달성”이라는 정도만으로는 조합의 성립요건을 갖추었다고 할 수 없다(대판 2010. 2. 11, 2009다79729; 대판 2004. 4. 9, 2003다60778 등).

Q : 수인이 부동산을 공동으로 매수한 경우, 매수인들 사이의 법률관계는?

- ① 공유관계로서 단순한 공동매수인에 불과할 수도 있고, → 공유(아래 (i)의 경우)
- ② 그 수인을 조합원으로 하는 동업체에서 매수한 것일 수도 있다. → 합유 (아래 (ii)의 경우)

(대판 2002. 6. 14, 2000다30622)

(i) 단순한 공동매수인인 경우 → 단순 공유(단순 공동 목적)

공동매수의 목적이 전매차익의 획득에 있을 경우 그것이 공동사업을 위해 동업체에서 매수한 것이 되려면, 적어도 공동매수인들 사이에서 그 매수한 토지를 공유가 아닌 동업체의 재산으로 귀속시키고 공동매수인 전원의 의사에 기해 전원의 계산으로 처분한 후 그 이익을 분배하기로 하는 명시적 또는 묵시적 의사의 합치가 있어야만 할 것이고, 이와 달리 공동매수 후 매수인별로 토지에 관하여 공유에 기한 지분권을 가지고 각자 자유롭게 그 지분권을 처분하여 대가를 취득할 수 있도록 한 것이라면 이를 동업체에서 매수한 것으로 볼 수는 없다(대판 2007. 6. 14, 2005다5140).

(ii) 동업체에서 매수한 경우 → 조합체 귀속이므로 합유(공동사업 또는 공동경영 약정)

3인이 부동산을 공동으로 매수함에 있어 그 중 1인이 부동산을 물색하여 다른 이들에게 매수 기회를 제공하였고, 3인의 합의에 따라 계약금은 그 중 2인이 부담하고, 나머지 매수대금은 그 부동산을 단기 전매하여 충당하고 그 차익은 먼저 전매한 자가 차지하기로 하였으며, 3인 사이의 공유지분은 정하여지지도 아니하였고 균등하다고도 볼 수 없다고 한다면, 그 3인 사이의 법률관계는 공유관계로서의 단순한 공동매수인에 해당한다고 보기보다는 오히려 매수인들이 상호 출자하여 공동사업을 경영하여 이익을 분배할 것을 목적으로 하는 동업체 관계로 봄이 상당하다(대판 1995. 9. 15, 94다54894).

2) 계

계도 당사자 사이에 특별한 약정이 없으면 조합계약이고 (대판 1962. 7. 26, 62다265), 계를 중심으로 하는 재산은 각 계원의 합유이다. 다만 낙찰계는 조합이 아닌 계주가 자기의 개인사업으로 계를 조직 운영하는 것이다(대판 1994. 10. 1, 93다55456).

[판 례] 계의 재산관계 : 조합(순번계)

모든 형태의 계가 조합관계는 아니지만, 당사자 간에 특정한 약정이 없으면 조합계약이라 추정되며 계를 중심으로 하는 재산은 각 계원의 합유이다(대판 1962. 7. 26, 62다265).

▶ 돌발 퀴즈

민법상 조합계약은 2인 이상이 상호 출자하여 공동으로 사업을 경영할 것을 약정하는 계약으로서, 특정한 사업을 “공동경영하는 약정”을 하거나 또는 “공동의 목적 달성”하는 경우 조합의 성립요건을 갖추었다고 할 수 있다.

⇒ × : 민법상 조합계약은 2인 이상이 상호 출자하여 공동으로 사업을 경영할 것을 약정하는 계약으로서, 특정한 사업을 “공동경영하는 약정”에 한하여 이를 조합계약이라 할 수 있고, “공동의 목적 달성”이라는 정도만으로는 조합의 성립요건을 갖추었다고 할 수 없다(대판 2010. 2. 11, 2009다79729; 대판 2004. 4. 9, 2003다60778 등).

(2) 법률의 규정에 의한 조합

1) 신탁법상의 조합

제50조(공동수탁자)

① 수탁자가 여럿인 경우 신탁재산은 수탁자들의 합유(合有)로 한다.

2) 광업법상 조합

제17조(공동광업출원인)

⑤ 공동광업출원인은 조합계약을 한 것으로 본다.

(3) 합유의 등기

1) 조합이 부동산을 소유하는 때에는 합유등기를 하여야 한다(부등법 제48조 제4항)

제48조(등기사항)

④ 제1항제5호의 권리자가 2인 이상인 경우에는 권리자별 지분을 기록하여야 하고 등기할 권리가 합유(合有)인 때에는 그 뜻을 기록하여야 한다.

2) 합유재산을 합유자 1인의 명의로 등기한 경우

(가) 조합원이 임의로 단독명의등기를 한 경우

합유재산을 합유자 1인이 임의로 자기 명의로 소유권보존등기를 한 것은 실질관계에 부합하지 않는 원인무효의 등기이다(대판 1970. 12. 29, 69다22). 따라서 합유자 전원의 동의없이 한 지분매매는 그 효력이 없으며, 지분매매를 전제로 하여 그 명의자로부터 등기명의를 취득한 자의 등기도 무효이다(대판 1970. 12. 29, 69다22).

(나) 조합원들의 약정에 의해 조합원 1인 명의로 등기한 경우

그러나 조합원들의 약정에 의해 조합원 1인 명의로 등기한 경우 명의신탁관계가 될 수 있다(대판 2006. 4. 13, 2003다25256).

[판례] 조합원 약정에 의한 조합원 1인 명의의 등기

[1] 수인이 부동산을 공동으로 매수한 경우, 매수인들 사이의 법률관계는 공유관계로서 단순한 공동매수인에 불과하여 매도인은 매수인 수인에게 그 지분에 대한 소유권이전등기의무를 부담하는 경우도 있을 수 있고, 그 수인을 조합원으로 하는 조합체에서 매수한 것으로서 매도인이 소유권 전부의 이전의무를 그 조합체에 대하여 부담하는 경우도 있을 수 있다.

[2] 매수인들이 상호 출자하여 공동사업을 경영할 것을 목적으로 하는 조합이 조합재산으로서 부동산의 소유권을 취득하였다면 민법 제271조 제1항의 규정에 의하여 당연히 그 조합체의 합유물이 되고, 다만 그 조합체가 합유등기를 하지 아니하고 그 대신 조합원 1인의 명의로 소유권이전등기를 하였다면 이는 조합체가 그 조합원에게 명의신탁한 것으로 보아야 한다(대판 2006. 4. 13, 2003다25256).

3) 조합체가 합유등기를 하지 아니하고 그 대신 조합원들 명의로 각 지분에 관하여 공유등기를 한 경우

이는 그 조합체가 조합원들에게 각 지분에 관하여 명의신탁한 것이다(대판 2002. 6. 14, 2000다30622).

[판례] 조합체가 합유등기를 하지 아니하고 조합원들 명의로 각 지분에 관하여 공유등기를 한 경우 조합체가 조합원들에게 각 지분에 관하여 명의신탁한 것인지 여부(적극)

[1] 부동산의 소유자가 동업계약(조합계약)에 의하여 부동산의 소유권을 투자하기로 하였으나 아직 그의 소유로 등기가 되어 있고 조합원의 합유로 등기되어 있지 않다면, 그와 조합 사이에 채권적인 권리의무가 발생하여 그로 하여금 조합에 대하여 그 소유권을 이전할 의무 내지 그 사용을 인용할 의무가 있다고 할 수는 있지만, 그 동업계약을 이유로 조합계약 당사자 아닌 사람에 대한 관계에서 그 부동산이 조합원의 합유에 속한다고 할 근거는 없으므로, 조합원이 아닌 제3자에 대하여는 여전히 소유자로서 그 소유권을 행사할 수 있다.

[2] 민법 제271조 제1항은 "법률의 규정 또는 계약에 의하여 수인이 조합체로서 물건을 소유하는 때에는 합유로 한다. 합유자의 권리는 합유물 전체에 미친다."고 규정하고(이는 물권법상의 규정으로서 강행규정이요, 따라서 조합체의 구성원인 조합원들이 공유하는 경우에는 조합체로서 물건을 소유하는 것으로 볼 수 없다.), 민법 제704조는 "조합원의 출자 기타 조합재산은 조합원의 합유로 한다."고 규정하고 있으므로, 동업을 목적으로 한 조합이 조합체로서 또는 조합재산으로서 부동산의 소유권을 취득하였다면, 민법 제271조 제1항의 규정에 의하여 당연히 그 조합체의 합유물이 되고(이는 민법 제187조에 규정된 '법률의 규정에 의한 물권의 취득'과는 아무 관계가 없다. 따라서 조합체가 부동산을 법률행위에 의하여 취득한 경우에는 물론 소유권이전등기를 요한다.), 다만, 그 조합체가 합유등기를 하지 아니하고 그 대신 조합원들 명의로 각 지분에 관하여 공유등기를 하였다면, 이는 그 조합체가 조합원들에게 각 지분에 관하여 명의신탁한 것으로 보아야 한다.

[3] 동업 목적의 조합체가 부동산을 조합재산으로 취득하였으나 합유등기가 아닌 조합원들 명의로 공유등기를 하였다면 그 공유등기는 조합체가 조합원들에게 각 지분에 관하여 명의신탁한 것에 불과하므로 부동산실권리자명의등기에관한법률 제4조 제2항 본문이 적용되어 명의수탁자인 조합원들 명의의 소유권이전등기는 무효이어서 그 부동산 지분은 조합원들의 소유가 아니기 때문에 이를 일반채권자들의 공동담보에 공하여지는 책임재산이라고 볼 수 없고, 따라서 조합원들 중 1인이 조합에서 탈퇴하면서 나머지 조합원들에게 그 지분에 관한 소유권이전등기를 경료하여 주었다 하더라도 그로써 채무자인 그 해당 조합원의 책임재산에 감소를 초래한 것이라고 할 수 없으므로, 이를 들어 일반채권자를 해하는 사해행위라고 볼 수는 없으며, 그에게 사해의 의사가 있다고 볼 수도 없다(대판 2002. 6. 14, 2000다30622).

- 4) 업무집행자가 업무처리 중 자기의 이름으로 취득한 부동산은 조합의 업무집행자로서의 권리 취득이 되어 특약이 없는 한 조합 앞으로 이전하여 줄 의무가 있다(대판 1997. 5. 30, 95다 4957).

[판례] 조합의 업무집행자가 업무처리 중 자기의 이름으로 취득한 부동산에 관하여 조합원 중 1인이 조합원들 명의의 합유등기청구를 할 수 있는지 여부(적극)

2인 이상이 상호출자하여 공동사업을 경영할 것을 약정함으로써 효력이 생기는 조합에 있어서는 조합계약이나 조합원의 3분의 2 이상의 찬성으로써 업무집행자를 정할 수 있고, 조합의 업무를 집행하는 조합원은 조합업무의 처리로 인하여 받은 금전 기타의 물건 및 그 수취한 과실을 조합에 인도하여야 하고, 조합을 위하여 자기의 명의로 취득한 권리는 조합에게 이전하도록 되어 있는바, 갑과 을이 각자 자금을 출자하고 공동으로 공사를 시공하여 그 이익을 반분하기로 하되 갑은 공사시공과 관계되는 일을 맡고 을은 자금관리와 대외적 업무처리를 맡기로 하는 내용의 동업약정을 맺고 위와 같은 동업관계를 유지하면서 건물의 신축공사를 진행한 경우, 을은 적어도 자금관리와 대외적 업무처리에 관한 한 갑, 을로 구성된 조합의 업무집행자라고 할 것이고, 조합의 업무집행자인 을이 조합의 대외적 업무처리를 하면서 자기의 이름으로 건물에 관한 공유지분을 취득하였다면 그것은 조합의 업무집행자로서의 권리취득이 되어 특약이 없는 한 공유지분을 조합 앞으로 이전하여 줄 의무가 있으며, 조합원 중의 1인인 갑으로서도 갑, 을 사이의 조합계약에 기하여 조합의 업무집행자인 을이 취득한 공유지분을 조합 앞으로 이전할 것을 청구할 수 있다(대판 1997. 5. 30, 95다4957).

3. 합유의 법률관계(합유물 처분·보존/ 합유지분 처분)

제271조(물건의 합유)

- ① 법률의 규정 또는 계약에 의하여 수인이 조합체로서 물건을 소유하는 때에는 합유로 한다. 합유자의 권리는 합유물 전부에 미친다.
- ② 합유에 관하여는 전항의 규정 또는 계약에 의하는 외에 다음 3조의 규정에 의한다.

제272조(합유물의 처분, 변경과 보존)

합유물을 처분 또는 변경함에는 합유자 전원의 동의가 있어야 한다. 그러나 보존행위는 각자가 할 수 있다.

제273조(합유지분의 처분과 합유물의 분할금지)

- ① 합유자는 전원의 동의없이 합유물에 대한 지분을 처분하지 못한다.
- ② 합유자는 합유물의 분할을 청구하지 못한다.

제274조(합유의 종료)

- ① 합유는 조합체의 해산 또는 합유물의 양도로 인하여 종료한다.
- ② 전항의 경우에 합유물의 분할에 관하여는 공유물의 분할에 관한 규정을 준용한다.

- ① 합유자의 권리, 즉 지분은 합유물 전부에 미친다(제271조 제1항 후단).→ 합유자가 그 지분에 따라 합유물을 전체로서 사용·수익할 수 있음을 의미한다.
- ② 법률의 규정이나 또는 합유자 사이의 계약에 의하여 정하여짐

- ③ 이에 의하여 정하여지지 않는 경우에는 제272조 내지 제274조에 의하여 규율된다(제271조 제2항).

(1) 합유물의 처분·변경과 보존

1) 처분·변경

(가) 합유물을 처분 또는 변경 → 합유자 전원의 동의가 있어야 한다(제272조 본문).

→ Q : 1인이 단독으로 처분하는 경우(특약으로 1인이 단독으로 처분가능은 당연)

A : 무권리자에 의한 처분행위로서 무효

(거래상대방은 동산인 경우 → 선의취득이 가능)

부동산인 경우 → 소유권을 취득할 수 없다)

합유자에 대한 관계에 있어서도 모두 무효로 된다(대판 1991. 5. 15, 91다186).

합유물을 제3자에게 양도하거나 담보로 제공하는 계약을 체결할 때는 합유자 전원이 계약당사자.

(나) 제706조와 제272조의 관계

제272조(합유물의 처분, 변경과 보존)

합유물을 처분 또는 변경함에는 합유자 전원의 동의가 있어야 한다. 그러나 보존행위는 각자가 할 수 있다.

제706조(사무집행의 방법)

- ① 조합계약으로 업무집행자를 정하지 아니한 경우에는 조합원의 3분의 2 이상의 찬성으로써 이를 선임한다.
- ② 조합의 업무집행은 조합원의 과반수로써 결정한다. 업무집행자 수인인 때에는 그 과반수로써 결정한다.
- ③ 조합의 통상사무는 전항의 규정에 불구하고 각 조합원 또는 각 업무집행자가 진행할 수 있다. 그러나 그 사무의 완료전에 다른 조합원 또는 다른 업무집행자의 이의가 있는 때에는 즉시 중지하여야 한다.

(a) 문제점

제272조에 의하면 합유물에 대한 보존행위는 합유자(조합원) 각자가 단독으로 할 수 있으나(단서), 그의 처분이나 변경에는 조합원 전원의 동의가 있어야 한다(본문). 그런데 조합원의 업무집행방법에 관한 제706조에 의하면, 조합의 통상업무는 각 조합원 또는 업무집행자가 단독으로 할 수 있지만(제3항 본문), 그 외의 경우에는 업무집행자가 없는 때에는 조합업무의 집행은 조합원의 과반수로 결정하고(제706조 제2항 전단), 업무집행자가 여럿인 때에는 그 과반수로 결정할 수 있다(제2항 후단),

Q : 여기서 합유물 또는 합유재산의 처분·변경이 조합의 통상사무가 아니고 특별사무라면 제272조와 제706조 제2항·제3항이 서로 충돌된다(이러한 연유는 민법제정시 제272조를 신설함으로써 기인한 것이다). 이러한 충돌되는 부분을 어떻게 해결할 것인가?

(b) 학 설

① 제706조 우선적용설(판례)

제272조는 합유물 일반에 관한 일반규정이고 제706조는 조합에만 국한된 특별규정
따라서 조합이 업무집행을 일정한 조직을 통하여 수행하고 있거나 조직을 예상하고 있는 경우에는 제706조가 적용되고, 그 이외의 경우에는 제272조가 적용된다.

② 제272조 우선적용설

㉠ 업무집행자가 없는 경우에 제272조와 제706조 제2항의 전단이 충돌하지만 조합재산인 합유물의 처분·변경에 관하여는 제272조가 특별규정이라고 보는 견해 → 전원의 합의

㉡ 업무집행자가 선임되어 있는 경우 → 제706조 제2항의 후단 → 조합원의 과반수로 결정

③ 적용영역구별설

제272조의 (전원의)동의란 합유물처분의 법률행위는 합유자 전원이 제3자에 대하여 행하여야 함을 의미

제706조는 조합업무의 내부적 수임관계 및 대리권의 수여관계를 규율함에 불과하므로 양자는 규율대상이 달라서 일반법·특별법의 관계에 있지 않는 것.

→ 따라서 그 특별사무에 관한 합유물의 처분·변경에 관한 것일 때에는 제272조가 적용되고, 그 밖의 특별사무에 관한 것일 때에는 제706조가 적용된다고 할 것이다.

(c) 판례

조합재산의 처분·변경에 관한행위는 다른 특별한 사정이 없는 한 조합의 특별사무

업무집행자가 없는 경우 : 원칙적으로 조합원의 과반수로써 결정(대판 1998. 3. 13, 95다30345) 업무집행조합원이 수인 있는 경우 : 업무집행조합원의 과반수로써 결정(대판 2000. 10. 10, 2000다28506·28513)

제272조와 제706조와의 관계에 대하여 특별한 사정이 없는 한 제706조 제2항이 우선 적용되는 것으로 판시하였다(대판 2010. 4. 29, 2007다18911).

[판례] 제706조 제2항과 제272조와의 관계

민법 제272조에 따르면 합유물을 처분 또는 변경함에는 합유자 전원의 동의가 있어야 하나, 합유물 가운데서도 조합재산의 경우 그 처분·변경에 관한 행위는 조합의 특별사무에 해당하는 업무집행으로서, 이에 대하여는 특별한 사정이 없는 한 민법 제706조 제2항이 민법 제272조에 우선하여 적용되므로, 조합재산의 처분·변경은 업무집행자가 없는 경우에는 조합원의 과반수로 결정하고, 업무집행자가 수인 있는 경우에는 그 업무집행자의 과반수로써 결정하며, 업무집행자가 1인만 있는 경우에는 그 업무집행자가 단독으로 결정한다(대판 2010. 4. 29, 2007다18911).

2) 보존행위

합유물의 보존행위는 각 합유자가 단독으로 할 수 있다(제272조 단서).

Q : 조합재산이 제3자에 의하여 점유된 경우에 합유자 1인이 단독으로 방해배제를 청구할 수 있는가?

(긍정 : 통설·판례)

(i) 부정설

합유지분은 공유지분과 같이 독립한 권리로서의 성질을 가지지 않는다. 따라서 보존행위는 사실행위만을 의미한다.

(ii) 긍정설(판례)

방해배제의 청구가 보존행위에 해당하는 경우에는 합유자 각자가 단독으로 가능

(iii) 판례

합유물에 관하여 경료된 원인 무효의 소유권이전등기의 말소를 구하는 소송은 합유물에 관한 보존행위로서 합유자 각자가 할 수 있다(대판 1997. 9. 9, 96다16896; 대판 1991. 6. 25, 90누5184; 대판 1972. 5. 23, 72누9; 이 점에서 공유와 같다. 그러나 총유에서는 총유 재산의 보존을 위해서 구성원 개인이 소를 제기할 수 없다. 대판[전합] 2005. 9. 15, 2004 다44971 참조)고 한다.

검토 : 조합원 개인은 지분의 확인, 말소의 등기, 방해제거, 합유물의 반환 청구가 보존행위인 경우에는 단독으로 할 수 있다.

- 3) 합유의 권리를 주장하는 소송은 합유자 전원을 소송당사자로 하는 필수적 공동소송이다. ① 합유로 소유권이전등기가 된 부동산에 관하여 명의신탁해지를 원인으로 한 소유권이전등기 절차의 이행을 구하는 소송(대판 1996. 12. 10, 96다23238) (예 : ABC가 합유자, D가 수탁자인 경우)
- ② 광업권을 공유하는 자들 사이에는 조합계약을 체결한 것으로 보아야 한다는 것을 근거로, 광업권자가 광업권에 관한 소송을 수행하던 중 사망한 경우에는 그 상속인 전원이 공동으로 수계신청을 하여야 한다(대판 1995. 5. 23, 94다23500).
- ③ 수인의 수탁자에 의한 신탁재산에 관한 소송(신탁법 제45조; 대판 1970. 11. 30, 70다1831)

(2) 합유지분의 처분

1) 합유지분

(가) 의 의

조합체의 일원으로서의 지위(공유지분 : 소유권의 수량적 일부).

(나) 지분의 비율

합유지분은 조합계약으로 결정(특별한 약정이 없는 때에는 출자가액에 비례. 제711조 제1항).

(공유지분 : 균등추정. 제262조 제2항)

(다) 지분의 귀속

합유자의 1인이 사망하거나 탈퇴한 경우에 그 지분은 누구에게 귀속하는가? 특별한 약정이 없는 한 사망하거나 탈퇴한 조합원의 지분은 반환하는 것이 원칙이며, 그 반환은 금전으로 할

수 있다고 할 것이다(제719조). 부동산의 합유자 중의 일부가 사망한 경우 합유자 사이에 특별한 약정이 없는 한 상속인이 합유자로서의 지위를 승계하지 못하므로 해당 부동산은 잔존 합유자에게 귀속된다고 한다(대판 1996. 6. 10, 96다23238).

[판례] 합유지분의 상속성

부동산 합유자 중 일부가 사망한 경우, 합유자 사이에 특별한 약정이 없는 한 사망한 합유자 상속인은 합유자로서의 지위를 승계하지 못하므로 해당 부동산은 잔존합유자 2인 이상일 경우에는 잔존 합유자의 합유로 귀속되고, 잔존 합유자가 1인인 경우에는 잔존 합유자의 단독소유로 귀속된다(대판 1996. 12. 10, 96다23238).

(라) 지분의 포기

합유지분은 나머지 잔존 합유지분권자들에게 균분으로 귀속

부동산의 경우 잔존 합유지분권자들에게 합유지분권 이전등기가 이루어지지 아니하는 한 지분을 포기한 지분권자는 제3자에 대하여 여전히 합유지분권자로서의 지위를 가지고 있다(대판 1997. 9. 9, 96다16896).

2) 합유지분의 처분

(가) 합유자는 전원의 동의 없이는 합유물에 대한 지분을 처분하지 못한다(제273조 제1항).

(<- 지분의 양도는 조합원으로서의 지위의 양도를 의미하기 때문)

단, ① 합유자 전원의 동의가 있으면 합유지분의 처분이 가능한 것으로 보고, 전원의 동의가 없이 처분하면 효력이 없다고 한다(대판 1970. 12. 29, 69다22).

② 특약으로 허용 가능

③ 이 때에도 재산 전부에 대한 지분처분을 의미 → 개개의 물건의 지분만 처분은 불가

(3) 합유물의 분할금지

제273조(합유지분의 처분과 합유물의 분할금지)

- ① 합유자는 전원의 동의없이 합유물에 대한 지분을 처분하지 못한다.
- ② 합유자는 합유물의 분할을 청구하지 못한다.

5. 합유의 종료

제274조(합유의 종료)

- ① 합유는 조합체의 해산 또는 합유물의 양도로 인하여 종료한다. (→ 예시적 규정)
- ② 전항의 경우에 합유물의 분할에 관하여는 공유물의 분할에 관한 규정을 준용한다.

(1) 합유의 종료원인

1) 합유물의 전부양도 또는 조합체의 해산(제274조 제1항) → 예시적 규정

2) 조합원의 탈퇴 등

- ① 조합원의 탈퇴로 인하여 조합원이 없게 된 경우(대판 2007. 11. 30, 2005마1130)
- ② 조합계약에서 정한 사유의 발생, 조합원 전원의 합의, 조합의 목적인 사업의 성공 또는 성공 불능, 2인으로 된 조합관계에 있어서 한 사람이 탈퇴하는 경우,
- ③ 부득이한 사유가 있는 때에 각 조합원의 조합체해산 요구(제720조), 해지 등

부득이한 사유라 하면 경제계의 사정변경에 따른 조합 재산상태의 악화나 영업부진 등으로 조합의 목적달성이 매우 곤란하다고 인정되는 객관적인 사정이 있거나 조합 당사자 간의 불화·대립으로 인하여 신뢰관계가 파괴됨으로써 조합업무의 원활한 운영을 기대할 수 없는 경우도 포함된다(대판 1997. 5. 30, 95다4957). → 합유재산 분할절차

2인 조합에서 조합원 1인이 탈퇴하는 경우 조합관계는 종료되지만 특별한 사정이 없는 한 조합이 해산되지 아니하고, 조합원의 합유에 속하였던 재산은 남은 조합원의 단독소유에 속하게 되어 기존의 공동사업은 청산절차를 거치지 않고 잔존자가 계속 유지할 수 있다. 이 경우 조합의 탈퇴자에 대한 채권은 잔존자에게 귀속되므로 잔존자는 이를 자동채권으로 하여 탈퇴자에 대한 지분 상당의 조합재산 반환채무와 상계할 수 있다(대판 2006. 3. 9, 2004다49693·49709).

(2) 조합체의 해산

1) 합유재산의 분할

해산사유의 발생·청산절차의 진행만으로 곧 합유관계가 종료하는 것은 아니고 합유재산의 분할이 실행됨으로써 비로소 종료된다.

2) 합유물의 분할방법

합유물의 분할방법은 조합체를 성립시킨 계약 또는 합유자 전원의 합의로써 결정하고, 그러한 결정이 없는 경우에는 공유물의 분할에 관한 규정이 준용된다(제274조 제2항). 합유재산의 분할 비율은 합유지분의 비율에 의할 것이나, 그 비율이 정하여 지지 않을 때에는 각 조합원의 출자 가액의 비율에 따라야 할 것이다(제724조 제2항 참조). 분할의 효과도 공유분할의 효과에 관한 규정을 준용하여야 할 것이다.

VI-4. 총 유

제275조(물건의 총유)

- ① 법인이 아닌 사단의 사원이 집합체로서 물건을 소유할 때에는 총유로 한다.
- ② 총유에 관하여는 사단의 정관 기타 계약에 의하는 외에 다음 2조의 규정에 의한다.

제276조(총유물의 관리, 처분과 사용, 수익)

- ① 총유물의 관리 및 처분은 사원총회의 결의에 의한다.
- ② 각 사원은 정관 기타의 규약에 좇아 총유물을 사용, 수익할 수 있다.

제277조(총유물에 관한 권리의무의 득상)

총유물에 관한 사원의 권리의무는 사원의 지위를 취득상실함으로써 취득상실된다.

1. 의 의

법인 아닌 사단(사원이 집합체)의 물건을 소유하는 공동소유의 형태(제275조).

(법인 아닌 사단 : 학술연구단체, 종중, 문중, 친목단체, 동창회, 어촌계)

인적 결합체의 존재를 전제/ 단체적 구속

사용·수익 권능 → 각 구성원 / 관리·처분 권능 → 집합체

지분 → 없음

2. 총유의 법률관계

(1) 총유물의 관리·처분 및 사용·수익

1) 관리·처분

제276조(총유물의 관리, 처분과 사용, 수익)

- ① 총유물의 관리 및 처분은 사원총회의 결의에 의한다.
- ② 각 사원은 정관 기타의 규약에 좇아 총유물을 사용, 수익할 수 있다.

(가) 총유에 있어서는 소유권의 내용 중 관리·처분 등의 권능은 집합체에 속한다.

① 정관 기타 규약으로 규율

② ①이 없다면 사원총회의 결의

→ 사단의 정관 기타 규약이 없는 경우, 사원총회 결의없는 관리·처분은 무효이다(대판 2007. 4. 26, 2005다31033; 대판 2001. 5. 29, 2000다10246; 대판 2000. 10. 27, 2000다22881; 대판 1992. 10. 13, 92다27034).

교회 교인들의 총유 또는 준총유에 속하는 토지의 처분에 관하여 교회의 정관이나 규약이 없고 교인들의 처분 결의도 없다면, 비록 그 토지를 전득하여 등기를 마친 자가 선의라 하더라도 교회는 그 처분행위의 무효인 사실을 대항할 수 있다(대판 1989. 2. 14, 88다카3113).

총유물의 관리 및 처분이라 함은 총유물 그 자체에 관한 이용·개량행위나 법률적·사실적 처분 행위를 의미하는 것이므로, 비법인사단이 타인 간의 금전채무를 보증하는 행위는 총유물 그 자체의 관리·처분이 따르지 아니하는 단순한 채무부담행위에 불과하여 이를 총유물의 관리·처분행위라고 볼 수는 없다. 따라서 비법인사단인 재건축조합의 조합장이 채무보증계약을 체결하면서 조합규약에서 정한 조합 임원회의 결의를 거치지 아니하였다거나 조합원총회 결의를 거치지 않았다고 하더라도 그것만으로 바로 그 보증계약이 무효라고 할 수는 없다. 다만, 이와 같은 경우에 조합 임원회의 결의 등을 거치도록 한 조합규약은 조합장의 대표권을 제한하는 규정에 해당하는 것이므로, 거래 상대방이 그와 같은 대표권 제한 및 그 위반 사실을 알았거나 과실로 인하여 이를 알지 못한 때에는 그 거래행위가 무효로 된다고 봄이 상당하며, 이 경우 그 거래 상대방이 대표권 제한 및 그 위반 사실을 알았거나 알지 못한 데에 과실이 있다는 사정은 그 거래의 무효를 주장하는 측이 이를 주장·증명하여야 한다(대판[전합] 2007. 4. 19, 2004다60072·60089).

(나) 총회의 결의 내용이 현저하게 불공정하거나 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 경우에는 무효이다(대판 2010. 9. 9, 2007다42310 2007다42327; 대판 2009. 6. 25, 2006다64559). 예를 들어 재건축의 결의가 각 구분소유자 간의 형평에 현저히 반하는 경우에는 이러한 재건축결의는 특별한 사정이 없는 한 무효이다(대판 2009. 6. 25, 2006다64559).

2) 사용·수익

총유물의 사용·수익은 정관 기타의 규약에 좇아 각 사원이 할 수 있다(제276조 제2항). 총유물의 사용·수익 등의 권능은 각 구성원에게 분속하지만, 그 행사는 정관 기타의 규약에 따라 이를 하여야 한다(제276조 제2항).

3) 보존행위(규정 없음) → 사원총회 결의 또는 전원이 하여야 함 / 소재기도(필수적 공동소송)

→ 구성원 각자는 비록 대표자라거나 사원총회를 거쳤다 하더라도 총유물의 보존을 위한 소재기를 할 수 없다(대판[전합] 2005. 9. 15, 2004다44971).

[판례] 총유물 보존행위의 방법

총유물의 보존에 있어서는 공유물의 보존에 관한 민법 제265조의 규정은 적용될 수 없고, 특별한 사정이 없는 한 그 관리에 관한 민법 제276조 제1항의 규정에 따라 사원총회의 결의를 거쳐야 하는 것인 바, 종중원들이 총회의 결의 없이 보존행위로써 총유물에 관한 타인명의의 소유권이전등기가 원인무효라고 주장하면서 그 말소등기와 종중 소유임의 확인을 구하는 것은 부적합하다(대판 1992. 2. 28, 91다41507).

(2) 총유물에 관한 권리·의무

제277조(총유물에 관한 권리의무의 득상)

총유물에 관한 사원의 권리의무는 사원의 지위를 취득상실함으로써 취득상실된다.

총유물에 관한 사원의 권리·의무는 사원의 지위를 취득·상실함으로써 당연히 취득·상실된다(제277조).

1) 사원의 권리·의무

(가) 총유물에 관한 사원의 주요한 권리에는 총유물의 관리·처분에 참여할 수 있는 것과 총유물을 사용·수익할 수 있는 것이다. 이는 사원권의 한 모습으로서 사원의 지위와 분리하여 존재할 수 없는 것이므로 민법은 사원의 권리를 취득·상실함으로써 그와 운명을 같이 할 것으로 규정한 것이다. 이는 총유의 본질적 내용이다.

(예를 들어 교회의 신도로서의 지위와 함께 교회활동의 목적 범위 내에서 교회재산을 사용·수익할 수 있다.)

(나) 부동산의 총유는 등기하여야 하며, 등기신청은 그 단체의 명의로 그 대표자 또는 관리인이 한다.

2) 가입·탈퇴

사원의 지위는 권리능력 없는 사단의 법리에 따라 정관 기타 계약에서 정한 바에 따라 그 사단에 사원으로 가입·탈퇴함으로써 취득·상실한다.

3) 총유지분

사원의 지위만 있을 뿐이므로 총유지분의 개념은 인정되지 않는다(통설·판례)(총유지분을 인정할 수 있다는 소수설도 있음)

VI-5. 준공동소유

제278조(준공동소유) 본절의 규정은 소유권 이외의 재산권에 준용한다. 그러나 다른 법률에 특별한 규정이 있으면 그에 의한다.

1. 의 의

수인이 공동으로 소유권 이외의 재산권을 소유하는 것을 준공동소유라고 한다. 준공동소유에도 준공유·준총유·준합유의 세 가지가 있다.

2. 준공동소유의 객체

(1) 소유권 이외의 재산권

지상권·지역권·전세권·유치권·질권·저당권

수리권 등 관습상의 물권

특허권·실용신안권·디자인권·상표권·저작권 등의 지식재산권

주식·社債 등의 상법상의 재산권

3. 준용규정

준공통소유에는 공유·합유·총유에 관한 민법의 규정이 준용된다. 그러나 다른 법률에 특별한 규정이 있으면 그에 의한다(제278조).

Ⅶ. 명의신탁

Ⅵ-1. 서설

1. 명의신탁의 의의

(1) 명의신탁이란 당사자의 신탁에 관한 채권계약에 의하여 신탁자가 실질적으로는 그의 소유에 속하는 부동산의 등기명의를 실제적인 거래관계가 없는 수탁자에게 매매 등의 형식으로 이전하여 주는 것(대판 1972. 11. 28, 72다1789).

- 대내적 관계 : 신탁자가 소유권을 보유하여 이를 관리·수익(공부상의 소유명의만을 수탁자 앞)

- 대외적 관계 : 수탁자가 소유권(부동산의 명의수탁자는 대외적인 관계에서는 완전한 소유자이므로 당해 부동산의 처분권을 가지게 된다(판례))

→ 제3자는 선의·악의를 불문하고 소유권 취득(단, 가등기담보법이 적용되는(제한설에 해당 하는) 부동산 양도담보에는 양도담보권자가 임의로 처분한 경우 제3취득자는 선의인 경우에 한하여 보호된다. 동법 제11조 단서)

명의신탁의 연혁

명의신탁은 일본강점기에 종중재산에 대한 등기제도의 미비에서 연유한다. 일본강점기 후 조선총독부의 토지조사령(1912년)과 임야조사령(1918년)에 의해 토지 및 임야 소유자는 그 소유관계를 관할기관에 신고를 하여야 하고 이에 따른査定에 의해 소유권이 창설적 효력으로 부여되었다. 그런데 그 당시 조선부동산등기령에는 종중자체의 명의로 등기할 수 있는 규정이 없어서 부득이 종중 소유의 토지를 종중원 1인 또는 수인의 명의로 사정을 받아 등기할 수밖에 없었고, 이것이 명의신탁의 발단이 되었다. 다만 1930년 조선부동산등기령이 개정되어 종중 기타 법인 아닌 사단 또는 재단을 등기관리자·등기의무자로 등기하는 길이 마련되었으나 여전히 종중은 재산의 보전 또는 보관을 목적으로 그 재산을 종중원 중의 1인 또는 수인의 명의로 소유권보존(또는 이전)등기를 하는 경우가 많았다. 그 종중원은 자신의 명의로 등기되어 있는 것을 기화로 종중재산을 매각처분하여 종중재산을 둘러싸고 분쟁이 빈번하게 야기되었는데, 해방 후 대법원은 이러한 분쟁을 해결하기 위하여 명의신탁이라는 새로운 용어의 법리를 창출하였다.

(2) 현행법상 사용되는 신탁

① 신탁법상의 신탁(명문으로 인정한 제도)

② 민법상 신탁(해석상 인정한 제도) : 이른바 양도담보·추심을 위한 채권의 신탁적 양도 등을 이론적으로 설명하기 위해서 독일 보통법이 로마법의 신탁의 개념을 발전시킨 것이다.

그런데 위의 ②를 우리 대법원은 단순히 소유명의만을 타인의 이름으로 등기·등록하여 두는 명의신탁까지 확대하여 적용(오늘날 확고한 판례법으로 자리매김)

→ 재산의 은닉이나 탈세 등의 편법으로 이용 → 부동산실권리자명의등기에관한법률(1995. 3. 30)에 의하여 원칙적으로 명의신탁이 금지(제4조), 종중이나 배우자 등에서 극히 예외적으로만 인정(제8조).

2. 유효성

명의신탁에 있어서 신탁자와 수탁자 사이에 위임관계 등과 같은 신탁관계가 별도로 존재하지 아니하고 단순히 목적재산의 소유명의만이 수탁자에게 이전되기 때문에 명의신탁계약이 유효한 것으로 다루어질 수 있는가에 관하여 과거에 견해의 대립이 있었다.

(아래 부동산 이외의 자동차 등에는 여전히 의미가 있음)

- ① 부동산 : 부동산실명법의 제정으로 무효설을 성문화하였기 때문에(제4조) 부동산에 관한 이러한 학설대립은 의미를 잃게 됨.
- ② 부동산 이외의 자동차 선박 공장용 기계 등 : 부동산이 아닌 공부에 의하여 권리관계가 공시되는 자동차·항공기·선박·공장용 기계 등은 판례의 명의신탁의 법리가 그대로 적용.

(1) 학 설

1) 무효설(허위표시설) : 다수설

관리신탁 또는 담보신탁에 있어서의 신탁행위와는 달리 명의신탁에 있어서는 소유권양도에 관한 의사표시가 허위표시에 해당하므로 무효(제108조)라고 한다. 명의신탁에 있어서는 당사자 사이에 소유명의를 이전하려고 하는데 합의가 있을 뿐, 소유권을 상대방이 취득하도록 하는 것은 아니라는 데 효과의사가 있으므로, 결국 이는 허위표시로서 무효로 해석할 수밖에 없다.

→ 신탁자와 수탁자 사이의 물권행위는 실질적으로 물권변동을 목적으로 하지 않은 것이므로 무효이고, 이에 의한 등기도 무효.

2) 유효설(신탁행위설) : 판례

- ① 의사의 합치가 있다 : 신탁자가 내부적으로는 소유자가 되고 외부적으로는 수탁자가 소유자로서 표시되도록 하는 내용의 의사표시의 합치로서, 이에 따라 수탁자는 등기부상 소유자이지만 수탁계약에 반하여 소유권을 행사하지 아니할 채권적 의무를 부담할 뿐이다.
- ② 양도담보나 추심을 위한 채권양도와 의사의 합치에 정도의 차이만 있다 : 이러한 당사자 간의 합의는 양도담보나 추심을 위한 채권양도 등 다른 민법상 인정되는 신탁행위와 비교하여 볼 때 정도의 차이만 존재할 뿐 이를 무효로 볼 만한 합리적 근거가 없다.

→ 따라서 명의신탁행위는 유효한 이상 민법 제108조가 적용될 여지가 없고, 수탁자로부터 신탁재산을 양수한 제3자는 악의라 하더라도 유효하게 소유권을 취득한다.

3) 수동신탁설

명의신탁은 영미신탁법상의 수동신탁(passive trust)의 법리에 의하여 재구성 하여야 한다는 견해.

여기서 수동신탁이란 능동신탁에 대립되는 신탁으로서 신탁재산의 권원을 형식상 수탁자에게 이전하지만 단순히 명의만을 수탁자로 하고 신탁재산의 관리·처분은 수익자(신탁자)가 행하는 신탁을 말한다고 한다. 이러한 점에서는 명의신탁과 동일하지만, 명의신탁은 공부상으로는 신탁인지의 여부를 알 수 없는 은닉된 신탁인데 반하여 수동신탁은 공명한 신탁이다. 그러나 명의신탁도 그 실체적 진실은 수동신탁임에 틀림없으므로 실체적 진실 그대로 수동신탁의 법리에 의하여 이론구성할 수 있다고 한다.

4) 표현소유권설

판례법에서 말하는 명의신탁법리를 취하지 않고 표현법리를 취하여 동법하에서 도출될 수 있는 새로운 개념으로서 表見所有權이라는 용어를 명의신탁이라는 개념에 갈음하여 채용하는 견해이다. 표현소유권은 법률상 목적 부동산에 대하여 아무런 처분권한이 없는 명의수탁자의 지위를 의미하게 되므로, 표현소유권은 어떤 새로운 물권을 의미하는 것이 아니며, 따라서 민법 제185조의 물권법정주의에 저촉되는 의미의 물권은 아니라고 한다.

(2) 판례의 태도 : 부동산의 명의신탁에 관하여 명의신탁을 유효한 것으로 봄

신탁자와 수탁자 사이에 있어서 명의신탁 약정이 있어야 한다

- ① 종중의 재산을 종가의 자손 또는 대표자의 소유명으로 등기한 경우
- ② 미분할 토지의 일부를 매수하고 그 전부에 대하여 등기를 한 경우(상호명의신탁) 등

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 조합체가 재산을 소유하면 합유가 성립하므로, 조합체의 구성원인 조합원들이 공유하는 경우에는 조합체로서 물건을 소유하는 것으로 볼 수 없다.
- ② 사업의 공동경영을 목적으로 하는 동업계약은 민법상 조합이므로, 그 조합이 재산을 취득하게 되면 그 재산은 동업자의 합유로 된다.
- ③ 공유수면매립권자들의 공동명으로 된 공유수면매립면허가 유효한 이상 면허권자들은 공동으로 당해 매립지 중 면허권자에게 귀속되는 토지의 소유권을 취득하게 되고, 나아가 공동면허권자가 공유수면매립법의 규정에 의하여 가지는 권리의무는 그들의 합유에 속한다고 할 것이므로 당해 토지들은 매립권자들이 합유로 취득한 것이 된다.
- ④ 합유재산을 합유자 1인이 임의로 자기 명의로 소유권보존등기를 한 것은 실질관계에 부합하지 않는 원인무효의 등기이고, 합유자 전원의 동의없이 한 지분매매는 그 효력이 없으며, 지분매매를 전제로 하여 그 명의자로부터 등기명의를 취득한 자의 등기도 무효이다.
- ⑤ 매수인들이 상호 출자하여 공동사업을 경영할 것을 목적으로 하는 조합이 조합재산으로서 부동산의 소유권을 취득하였다면 민법 제271조 제1항의 규정에 의하여 당연히 그 조합체의 합유물이 되고, 다만 그 조합체가 합유등기를 하지 아니하고 그 대신 조합원 1인의 명의로 소유권이전등기를 하였다면 이는 조합체가 그 조합원에게 명의신탁한 것으로 볼 수는 없다.

- ⑤. 매수인들이 상호 출자하여 공동사업을 경영할 것을 목적으로 하는 조합이 조합재산으로서 부동산의 소유권을 취득하였다면 민법 제271조 제1항의 규정에 의하여 당연히 그 조합체의 합유물이 되고, 다만 그 조합체가 합유등기를 하지 아니하고 그 대신 조합원 1인의 명의로 소유권이전등기를 하였다면 이는 조합체가 그 조합원에게 명의신탁한 것으로 보아야 한다(대판 2006. 4. 13, 2003다25256).

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 민법 제272조에 따르면 합유물을 처분 또는 변경함에는 합유자 전원의 동의가 있어야 하나, 합유물 가운데서도 조합재산의 경우 그 처분·변경에 관한 행위는 조합의 특별사무에 해당하는 업무집행으로서, 이에 대하여는 특별한 사정이 없는 한 민법 제706조 제2항이 민법 제272조에 우선하여 적용되므로, 조합재산의 처분·변경은 업무집행자가 없는 경우에는 조합원의 과반수로 결정하고, 업무집행자가 수인 있는 경우에는 그 업무집행자의 과반수로써 결정하며, 업무집행자가 1인만 있는 경우에는 그 업무집행자가 단독으로 결정한다.
 - ② 합유물에 관하여 경료된 원인 무효의 소유권이전등기의 말소를 구하는 소송은 합유물에 관한 보존행위로서 합유자 각자가 할 수 있다.
 - ③ 광업권을 공유하는 자들 사이에는 조합계약을 체결한 것으로 보아야 하므로, 광업권자가 광업권에 관한 소송을 수행하던 중 사망한 경우에는 그 상속인 전원이 공동으로 수계신청을 하여야 한다.
 - ④ 부동산 합유자 중 일부가 사망한 경우, 합유자 사이에 특별한 약정이 없는 한 사망한 합유자 상속인은 합유자로서의 지위를 승계하지 못하므로 해당 부동산은 잔존합유자 2인 이상일 경우에는 잔존 합유자의 합유로 귀속되고, 잔존 합유자가 1인인 경우에는 잔존 합유자의 단독 소유로 귀속된다.
 - ⑤ 부동산의 경우 잔존 합유지분권자들에게 합유지분권 이전등기가 이루어지지 아니하였더라도 지분을 포기한 지분권자는 제3자에 대하여 합유지분권자로서의 지위를 잃는다.
- ⑤. 부동산의 경우 잔존 합유지분권자들에게 합유지분권 이전등기가 이루어지지 아니하는 한 지분을 포기한 지분권자는 제3자에 대하여 여전히 합유지분권자로서의 지위를 가지고 있다(대판 1997. 9. 9, 96다16896).

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 총유물의 관리 및 처분은 사원총회의 결의에 의하고, 각 사원은 정관 기타의 규약에 좇아 총유물을 사용, 수익할 수 있다.
- ② 교회 교인들의 총유 또는 준총유에 속하는 토지의 처분에 관하여 교회의 정관이나 규약이 없고 교인들의 처분 결의도 없다면, 비록 그 토지를 전득하여 등기를 마친 자가 선의라 하더라도 교회는 그 처분행위의 무효인 사실을 대항할 수 있다.
- ③ 총유물의 관리 및 처분이라 함은 총유물 그 자체에 관한 이용·개량행위나 법률적·사실적 처분행위를 의미하는 것이므로, 비법인사단이 타인 간의 금전채무를 보증하는 행위는 총유물 그 자체의 관리·처분이 따르지 아니하는 단순한 채무부담행위에 불과하여 이를 총유물의 관리·처분 행위라고 볼 수는 없다.
- ④ 따라서 위 ③의 경우 비법인사단인 재건축조합의 조합장이 채무보증계약을 체결하면서 조합규약에서 정한 조합 임원회의 결의를 거치지 아니하였다거나 조합원총회 결의를 거치지 않았다고 하더라도 그것만으로 바로 그 보증계약이 무효라고 할 수는 없다.

⑤ 사단법인의 대표 또는 구성원 각자는 사원총회를 거쳐 총유물의 보존을 위한 소재기를 할 수 있다.

⑤. 구성원 각자는 비록 대표자라거나 사원총회를 거쳤다 하더라도 총유물의 보존을 위한 소재기를 할 수 없다(대판[전합] 2005. 9. 15, 2004다44971).

♣ 학습정리

1. 합유자 전원의 동의가 있으면 합유지분의 처분이 가능하고, 전원의 동의가 없이 처분하면 효력이 없다.
2. 2인 조합에서 조합원 1인이 탈퇴하는 경우 조합관계는 종료되지만 특별한 사정이 없는 한 조합이 해산되지 아니하고, 조합원의 합유에 속하였던 재산은 남은 조합원의 단독소유에 속하게 되어 기존의 공동사업은 청산절차를 거치지 않고 잔존자가 계속 유지할 수 있다. 이 경우 조합의 탈퇴자에 대한 채권은 잔존자에게 귀속되므로 잔존자는 이를 자동채권으로 하여 탈퇴자에 대한 지분 상당의 조합재산 반환채무와 상계할 수 있다.
3. 총유물의 관리 및 처분이라 함은 총유물 그 자체에 관한 이용·개량행위나 법률적·사실적 처분행위를 의미하는 것이므로, 비법인사단이 타인 간의 금전채무를 보증하는 행위는 총유물 그 자체의 관리·처분이 따르지 아니하는 단순한 채무부담행위에 불과하여 이를 총유물의 관리·처분행위라고 볼 수는 없다.
4. 구성원 각자는 비록 대표자라거나 사원총회를 거쳤다 하더라도 총유물의 보존을 위한 소재기를 할 수 없다.
5. 명의신탁이란 당사자의 신탁에 관한 채권계약에 의하여 신탁자가 실질적으로는 그의 소유에 속하는 부동산의 등기명의를 실제적인 거래관계가 없는 수탁자에게 매매 등의 형식으로 이전하여 주는 것이다.

제25강 명의신탁 (2)

♣ 학습목표

1. 명의신탁의 성립요건에 대하여 설명할 수 있다.
2. 명의신탁의 법률관계를 정리할 수 있다.
3. 명의신탁의 해지에 관한 법률관계를 정리할 수 있다.

♣ 학습내용

- 명의신탁의 성립요건
- 명의신탁의 법률관계
- 명의신탁의 해지

♣ 사전 테스트

1. 명의신탁이란 당사자의 신탁에 관한 채권계약에 의하여 신탁자가 실질적으로는 그의 소유에 속하는 부동산의 등기명의를 실제적인 거래관계가 없는 수탁자에게 매매 등의 형식으로 이전하여 주는 것이다.
⇒ ○
2. 명의신탁은 종래 재산의 은닉이나 탈세 등의 편법으로 이용되어 왔다. 부동산실권리자명의등기에관한법률(1995. 3. 30)은 명의신탁을 원칙적으로 금지하고, 종중이나 배우자 등에서 극히 예외적으로만 인정하고 있다.
⇒ ○ : 부동산실명법 제4조, 제8조.
3. 판례에 따르면 명의신탁에 있어서는 소유권양도에 관한 의사표시가 허위표시에 해당하므로 무효(제108조)라고 한다.
⇒ × : 판례의 태도(유효설, 신탁행위설)에 따르면 명의신탁행위는 유효한 이상 민법 제108조가 적용될 여지가 없고, 수탁자로부터 신탁재산을 양수한 제3자는 악의라 하더라도 유효하게 소유권을 취득한다.

♣ 강의교안

VI- 2. 성립요건(판례이론)

1. 명의신탁의 대상

- 1) 명의신탁의 객체는 공부(등기·등록)에 의하여 소유관계가 표시되는 재화에 한한다.

- ① 등기로 공시되는 토지, 건물, 입목법에 의하여 등기된 수목의 집단, 선박 등
- ② 등록에 의하여 공시되는 항공기, 자동차(대판 2007. 1. 25, 2006다61055, 지입차량이 사고로 인하여 차량수리비 등의 손해를 입은 경우, 지입계약에 따라 자동차등록원부에 소유자로 등록된 지입회사가 손해배상청구권을 가진다), 건설기계 등
- ③ 유선방송사업허가명(대판 2002다. 6. 14, 99다61378), 채권(대판 2007. 3. 29, 2006도 9425), 전화가입사용권(대판 1971. 9. 29, 71다1592), 예금주명(대판 2001. 1. 5, 2000다 49091), 가등기상의 지위(대판 2002. 12. 24, 2002다50484; 대판 2000. 12. 12, 2000다 49879; 대판 1980. 9. 9, 79다2072-2073), 주주명(대판 2007. 9. 6, 2007다27755), 토지분양계약체결에 있어서 계약 당사자 사이의 명의신탁(대판 1989. 11. 14, 88다카19033)
- ④ 그러나 동산(자동차 등 제외)은 공부상 그 소유관계가 공시될 수 없기 때문에, 그에 대한 명의신탁이 성립할 여지가 없다(대판 1994. 10. 11, 94다16175).

[판례] 예금주명의신탁

금융실명거래및비밀보장에관한긴급재정명령 시행 이후 예금주 명의를 신탁한 경우, 명의수탁자는 명의신탁자와의 관계에 있어서 상대방과의 계약에 의하여 취득한 권리를 명의신탁자에게 이전하여 줄 의무를 지는 것이고, 위 명령 제3조 제3항은 단속규정일 뿐 효력규정이 아니라는 점에 비추어 볼 때, 출연자와 예금주인 명의인 사이의 명의신탁약정상 명의인은 출연자의 요구가 있을 경우에는 금융기관에 대한 예금반환채권을 출연자에게 양도할 의무가 있다고 보아야 할 것이어서 출연자는 명의신탁을 해지하면서 명의인에 대하여 금융기관에 대한 예금채권의 양도를 청구하고 아울러 금융기관에 대한 양도통지를 할 것을 청구할 수 있다(대판 2001. 1. 5, 2000다49091).

- 2) 명의신탁이 인정될 수 있는 권리로는 소유권은 물론이고 용익물권(대판 1998. 9. 4, 98다 20981) 및 담보물권(대판 2007. 1. 11, 2006다50055; 대판[전합] 2001. 3. 15, 99다 48948; 대판 1995. 9. 26, 94다33583 등)도 가능

2. 명의신탁의 목적

명의신탁의 목적은 불문(등기말소절차의 번거로움을 피하는 등 단순히 편의만을 위한 것도 가능(대판 1966. 7. 5, 66다909; 대판1988. 11. 14, 79다1872)).

명의신탁의 효력

① 무효설(제103조 위반)

부동산실명법의 취지, 부동산등기특별조치법상 처벌규정 등을 고려하면 명의신탁은 제103조 위반이다(부동산실명법 제4조는 제103조를 구체화한 것이다) → 신탁자는 제746조 본문의 불법원인급여에 해당 → 명의수탁자를 상대로 반환청구할 수 없다(다만 실명전환의무를 위반한 동법 시행 전의 명의신탁은 명의수탁자에 대해 부당이득반환청구를 할 수 있다고 한다).

② 유효설(다수설·판례)

⑦ 투기나 탈세 등의 목적으로 행하여졌더라도 그것만으로 명의신탁이 사회질서에 반하여 무효로 되는 것은 아니다.(대판 1991. 9. 23, 91다16334)

㉠ 단 강행법규(예컨대 농지개혁법 제11조; 대판 1995. 12. 26, 95다40366; 대판 1993. 7. 13, 93다494; 대판 1981. 7. 14, 81도1237)나 사회질서(제103조)에 위반되는 경우에는 명의신탁은 무효로 된다.

[판례] 부동산실명법에 위반되어 무효인 명의신탁약정에 기하여 경료된 타인 명의의 등기가 불법원인급여에 해당하는지 여부(소극)

(1) 부동산실권리자명의등기에관한법률이 규정하는 명의신탁약정은 부동산에 관한 물권의 실권리자가 타인과의 사이에서 대내적으로는 실권리자가 부동산에 관한 물권을 보유하거나 보유하기로 하고 그에 관한 등기는 그 타인의 명의로 하기로 하는 약정을 말하는 것일 뿐이므로, 그 자체로 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반하는 경우에 해당한다고 단정할 수 없을 뿐만 아니라, 위 법률은 원칙적으로 명의신탁약정과 그 등기에 기한 물권변동만을 무효로 하고 명의신탁자가 다른 법률관계에 기하여 등기회복 등의 권리행사를 하는 것까지 금지하지는 않는 대신, 명의신탁자에 대하여 행정적 제재나 형벌을 부과함으로써 사적자치 및 재산권보장의 본질을 침해하지 않도록 규정하고 있으므로, 위 법률이 비록 부동산등기제도를 악용한 투기·탈세·탈법행위 등 반사회적 행위를 방지하는 것 등을 목적으로 제정되었다고 하더라도, 무효인 명의신탁약정에 기하여 타인 명의의 등기가 마쳐졌다는 이유만으로 그것이 당연히 불법원인급여에 해당한다고 볼 수 없다(대판 2003. 11. 27, 2003다41722).

(2) 강제집행을 면할 목적으로 부동산의 소유자명의를 신탁하는 것이 위와 같은 불법원인급여에 해당한다고 볼 수는 없다(대판 1994. 4. 15, 93다61307).

[판례] 타인의 명의를 빌려 농지분배를 받게 하는 명의신탁 계약의 효력(무효)

타인의 명의를 빌려 농지분배를 받게 하는 내용의 명의신탁은 농지개혁법상 경자유전의 원칙에 비추어 그 효력을 인정할 수 없고, 당사자 사이에 명의신탁의 약정이 있었다고 하더라도 대외적으로는 물론 대내적으로도 그 소유권은 농지의 수분배자에게 귀속한다(대판 1995. 12. 26, 95다40366).

3. 명의신탁의 약정

(가) 명의신탁의 합의(명시 또는 묵시)가 없이 등기만 된 것은 무효이며 명의신탁이 성립하지 않는다(대판 1972 5. 23, 71다2760; 대판 1981. 12. 8, 80다카367). 이 경우 원인무효등기를 기반으로 한 등기명의자로부터 제3취득자는 권리를 취득할 수 없다.

(나) 명의신탁 목적물을 반드시 신탁자의 자금으로 취득해야만 명의신탁관계가 성립하는 것은 아니다(대판 2008. 2. 14, 2007다69148).

(위 판례의 내용 : 신용불량자인 아버지가 자녀들 명의로 은행대출을 받고 자녀들 명의로 사업과 부동산매입(약 6억, 2억, 4억 상당의 3개의 부동산 매입)을 한 사건으로서 아무런 자금력이 없는 아버지가 하더라도 자녀들과 명의신탁 약정을 한 이상 일단 명의신탁관계가 성립하고, 위 자금을 아버지가 제공한 사실이 인정되지 않는 이상 아버지의 채권자가 아버지를 대위하여 매수대금 상당의 자금을 채권자대위로서 자녀들을 상대로 청구할 수 없다)

[판례] 부동산 경매에서 명의신탁약정과 그 무효 및 부당이득범위

부동산경매절차에서 부동산을 매수하려는 사람이 다른 사람과의 명의신탁약정 아래 그 사람의 명의로 매각허가결정을 받아 자신의 부담으로 매수대금을 완납한 경우, 경매목적 부동산의 소유권은 매수대금의 부담 여부와는 관계없이 그 명의인이 취득하게 되고, 매수대금을 부담한 명의신탁자와 명의를 빌려 준 명의수탁자 사이의 명의신탁약정은 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 제4조 제1항에 의하여 무효이므로, 명의신탁자는 명의수탁자에 대하여 그 부동산 자체의 반환을 구할 수는 없고 명의수탁자에게 제공한 매수대금에 상당하는 금액의 부당이득반환 청구권을 가질 뿐이다(대판 2009. 9. 10, 2006다73102).

(다) 명의신탁관계에 관한 증명책임 : 현재 명의자 소유를 부인하는 상대방측에서 증명책임

(i) 주주명부에 주주로 등재되어 있는 자는 일응 그 회사의 주주로 추정되며 이를 번복하기 위해서는 그 주주권을 부인하는 측에 증명책임이 있으므로(대판 1985. 3. 26, 84다카2082), 주주명부의 주주 명의가 신탁된 것이고 그 명의차용인으로서 실질상의 주주가 따로 있음을 주장하려면 그러한 명의신탁관계를 주장하는 측에서 명의차용사실을 증명하여야 한다(대판 2007. 9. 6, 2007다27755).

(ii) 어떤 토지가 종중의 소유인데 사정 당시 종원 또는 타인 명의로 신탁하여 사정받은 것이라고 인정하기 위하여는 사정 당시 어느 정도의 유기적 조직을 가진 종중이 존재하였을 것과 사정 이전에 그 토지가 종중의 소유로 된 과정이나 내용이 증명되거나 또는 여러 정황에 미루어 사정 이전부터 종중 소유로 인정할 수밖에 없는 많은 간접자료가 있을 때에 한하여 이를 인정할 수 있을 뿐이고, 그와 같은 자료들이 충분히 증명되지 아니하고 오히려 반대되는 사실의 자료가 많을 때에는 이를 인정하여서는 아니 된다. 그리고 종중의 명의신탁에 의한 사정을 인정하기 위한 간접자료가 될 만한 정황으로서는, 사정명의인과 종중과의 관계, 사정명의인이 여러 사람인 경우에는 그들 상호간의 관계, 한 사람인 경우에는 그 한 사람 명의로 사정받게 된 연유, 종중 소유의 다른 토지가 있는 경우에는 그에 대한 사정 또는 등기관계, 사정된 토지의 규모 및 시조를 중심으로 한 종중 분묘의 설치 상태, 분묘수호와 봉제사의 실태, 토지의 관리 상태, 토지에 대한 수익이나 보상금의 수령 및 지출 관계, 제세공과금의 납부 관계, 등기필증의 소지 관계, 그 밖의 모든 사정을 종합적으로 검토하여야 한다(대판 2009. 10. 29, 2008다37247; 대판 1998. 9. 8, 98다13686).

4. 명의신탁의 등기

명의수탁자 명의의 등기(또는 등록) 요함, 가등기라도 무방(대판 1992. 7. 28, 92다10173).

참고 : 3자간 명의신탁 중 (등기명의신탁 또는 중간생략 명의신탁)도 명의신탁을 인정할 수 있는가?

판례 : 명의신탁자가 원시취득한 미등기부동산(신축건물)에 관하여 명의수탁자 앞으로 바로 소유권보존등기를 하는 경우에도 명의신탁관계가 성립한다고 한다(대판 1993. 12. 14, 93다19139)

VI-3. 법률관계

1. 대내관계

(1) 판례이론(이른바 상대적 권리이전설)

대내적으로는 명의신탁자의 소유

대외적으로는 명의수탁자의 소유

① 신탁자는 수탁자에 대하여 언제나 소유권을 주장할 수 있고(대판 1982. 11. 23, 81다372), 자신의 소유권을 다투는 수탁자를 상대로 소유권 확인을 구할 수도 있다(대판 1977. 10. 11, 77다1316).

② 명의신탁 해지를 원인으로 한 신탁자의 수탁자에 대한 등기청구권은 소유권에 기한 물권적 청구권으로 소멸시효에 걸리지 않는다(대판 1976. 6. 22, 75다124).

다만 부동산실명법에 의해 무효가 된 부동산 명의신탁의 경우에 있어서 발생하는 부동산자체에 대한 부당이득반환청구권은 민법 제162조 제1항에 따라 10년의 소멸시효에 걸린다. 왜냐하면 이는 명의신탁자가 그 부동산의 점유 및 사용 등 권리를 행사하고 있다하더라도 부당이득반환청구권 자체의 실질적 행사가 있다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 명의신탁자가 그 부동산을 점유·사용하여 온 경우에 부당이득반환청구권에 기한 등기청구권의 소멸시효가 진행되지 않는다고 본다면 부동산실명법의 취지에도 맞지 않기 때문이다(대판 2009. 7. 9, 2009다23313).

③ 토지에 관한 명의수탁자가 명의신탁 존속 중에 토지위에 건물을 신축한 후 명의신탁관계가 해소되어 토지와 건물에 대한 소유자가 다르게 되었다하더라도 대내적인 관계에서 토지는 신탁자의 소유였으므로 수탁자가 그 건물의 소유를 위한 관습상의 법정지상권을 취득할 수 없다(대판 1987. 11. 10, 85다카1644).

④ 명의수탁자는 타주점유 → 시효취득 불가(대판 1992.4. 14, 91다46533)

수탁자의 상속인·피상속인의 법률상의 지위를 그대로 승계하는 것이므로 상속인이 따로이 소유의 의사로써 점유를 개시하였다고 인정할 수 있는 별개의 사유가 존재하지 않는 한 수탁자의 상속인으로서의 시효의 효과로 인하여 신탁물인 부동산의 소유권을 취득할 수 없다(대판 1987. 11. 10, 85다카1644).

▶ 돌발 퀴즈

부동산실명법에 의해 무효가 된 부동산 명의신탁의 경우에 있어서 발생하는 부동산자체에 대한 부당이득반환청구권은 소멸시효에 걸리지 않는다.

⇒ × : 부동산실명법에 의해 무효가 된 부동산 명의신탁의 경우에 있어서 발생하는 부동산 자체에 대한 부당이득반환청구권은 민법 제162조 제1항에 따라 10년의 소멸시효에 걸린다. 왜냐하면 이는 명의신탁자가 그 부동산의 점유 및 사용 등 권리를 행사하고 있다하더라도 부당이득반환청구권 자체의 실질적 행사가 있다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 명의신탁자가 그 부동산을 점유·사용하여 온 경우에 부당이득반환청구권에 기한 등기청구권의 소멸시효가 진행되지 않는다고 본다면 부동산실명법의 취지에도 맞지 않기 때문이다(대판 2009. 7. 9, 2009다23313).

- (2) 당사자 사이에 특약이 없는 한 위임에 관한 규정이 준용 → 명의수탁자는 선량한 관리자의 주의로 명의신탁재산에 관한 소유명의를 보존하고 명의신탁약정이 해지되면 명의신탁부동산을 반환하여야 할 의무를 지며(제681조), 명의신탁 받은 재산을 임의로 처분하면 횡령죄의 죄책을 진다.

명의신탁받은 재산을 임의로 처분(근저당권설정행위도 포함)하게 되면 배임죄가 아니라 횡령죄를 구성한다(대판 1998. 2. 24, 97도3282; 대판[전합] 1971. 6. 22, 71도740).

- (3) 명의신탁계약의 당사자 일방이 사망하여도 신탁관계는 당연히 소멸하지 않으며, 그 신탁관계는 상속인과의 사이에 존속한다(대판 1965. 2. 16, 64다1576; 대판 1981. 6. 23, 80다2809). 따라서 상호명의신탁의 경우 명의신탁 당사자의 내부관계의 법리는 명의신탁 당사자의 특정승계인에게도 미친다(대판[전합] 1980. 12. 9, 79다634).

2. 대외관계

(1) 명의수탁자의 처분과 제3자의 권리취득

- ① 대외관계(제3자에 대한 관계)에서는 수탁자에게 소유권이 이전·귀속된다. 따라서 대외관계에 있어서 명의수탁자만이 완전한 소유자이므로 수탁자가 신탁자의 승낙 없이 이를 처분한 경우에 양수인은 “선의·악의를 불문”하고 소유권을 취득한다(대판 1987. 3. 10, 85다카2508).
- ② 명의수탁자가 제3자에게 처분하는 때에 신의칙상 명의신탁사실을 고지할 의무가 없다(대판 2007. 1. 11, 2006도4498). 다만 제3자가 수탁자에게 매도나 담보의 제공 등을 적극적으로 권유함으로써 수탁자의 배임행위에 적극 가담한 경우에는, 명의수탁자와 제3자 사이의 계약은 반사회적인 법률행위로서 무효이다(대판 1992. 6. 9, 91다29842).
- ③ 수탁자는 신탁재산에 대한 처분권을 제3자에게 위임할 수도 있고, 자기의 채무를 담보하기 위하여 신탁재산에 저당권을 설정할 수도 있다(대판 1968. 8. 31, 68다895). → 횡령죄성립(근저당권을 설정 후 또 근저당권을 설정(또는 매도)한 경우 → 별도의 횡령죄(불가벌적 사후행위 아님. 대법원 2013.2.21. 선고 2010도10500 전원합의체 판결)

(2) 제3자가 신탁 목적물을 침해한 경우

① 물권적청구권

수탁자(등기명의인)만이 불법점유자에 대해서 방해배제청구권
신탁자는 명의인을 대위하여서만 이를 행사할 수 있다(대판[전합] 1979. 9. 25, 77다1079).

② 신탁자의 제3자에 대한 부당이득반환청구권

대외적으로 소유권자가 아니므로 신탁자는 제3자에게 직접 부당이득반환을 청구 할 수 없으며, 나아가 수탁자도 목적물을 사용·수익할 권능이 없으므로 침해자에 대한 피대위채권으로서의

부당이득반환청구권도 존재하지 않으므로 수탁자를 대위하여 청구할 수도 없다(대판 1991. 10. 22, 91다17207).

상호명의신탁의 경우에도 자신의 지분범위 내에서만 침해자에 대해 주장할 수 있을 뿐 다른 공동소유적 공유자의 지분에 기하여 직접 또는 대위하여 주장할 수 없다(대판 1993. 11. 23, 93다22326). → 대외적으로 공유이므로 공유지분만큼의 부당이득반환청구 가능

③ 명의신탁자의 진정명의회복을 위한 등기청구권

(i) 명의신탁자는 수탁자가 아닌 제3자에 대해서는 진정명의의 회복을 위한 소유권이전등기를 청구할 수 없다. 이 경우 수탁자의 등기청구권을 대위행사할 수 있을 뿐이다(대판 2001. 8. 21, 2000다36484). 그러나 (ii) 부동산실명법 소정의 유예기간 내에 실명등기를 하지 아니하여 명의신탁약정이 무효로 된 경우, 종전에 명의신탁 대상 부동산에 관하여 소유권이전등기를 경료한 적이 있던 명의신탁자는 명의수탁자를 상대로 진정명의회복을 원인으로 한 이전등기를 구할 수 있다(대판 2002. 9. 6, 2002다35157). 반면에 명의신탁자가 이 청구권을 행사하기 위하여는 자신의 명의로 등기가 되었던 적이 있어야 하므로 토지를 매수하여 명의수탁자에게 명의신탁등기를 하여 놓고 명의신탁자 명의로 등기를 마친 바 없는 경우, 그 명의신탁자가 진정 명의 회복을 원인으로 하는 소유권이전등기절차이행을 구할 수는 없다(대판 1998. 10. 23, 98다35266).

④ 보상청구권

명의신탁된 토지가 수용되면 손실보상청구권도 명의수탁자에게 귀속한다(대판 1993. 6. 29, 91누2342).

(3) 시효취득

(i) 명의신탁된 부동산에 대한 점유취득시효 완성 후 그 소유권이전등기가 경료되기 전에 명의신탁이 해지되어 등기명의가 명의신탁자에게 이전된 경우, 그에 대하여 시효취득을 주장할 수 없다(대판 2001. 10. 26, 2000다8861; 대판 1995. 12. 8, 95다38493; 대판 1995. 5. 9, 94다22484). 그러나 (ii) 취득시효 완성 후 등기 경료 전에 그 부동산이 제3자에게 명의신탁된 경우, 종전 등기명의인으로서 언제든지 이를 해지하고 소유권이전등기를 청구할 수 있고, 점유시효 취득자로서는 종전 등기명의인을 대위하여 이러한 권리를 행사할 수 있으므로, 그러한 제3자가 소유자로서의 권리를 행사하는 경우 점유자로서는 취득시효완성을 이유로 이를 저지할 수 있다(대판 1995. 9. 5, 95다24586).

(4) 강제집행 또는 경매

수탁자의 일반채권자는 수탁자명의로 되어 있는 신탁재산에 대하여 강제집행이나 경매를 청구할 수 있고, 신탁자는 신탁을 이유로 그 일반채권자에 대하여 소유권을 주장할 수 없다(대판 1974. 6. 25, 74다423). 그러나 신탁자의 일반채권자들에 의하여 강제집행이 실시된 경우에는 수탁자가 제3자 이의의 소를 제기할 수 있다(대판 1971. 3. 23, 71다225).

(5) 신탁자의 제3자에 대한 지위

(i) 신탁자는 수탁자의 동의 없이 처분이 가능하며, 이는 사실상으로나 법률상으로 처분 할 수 있는 권원에 의해 매도한 것이므로 타인의 물건의 매매라 할 수 없다(대판 1996. 8. 20, 96다18656). 다만 이 경우 등기를 하기 위해서는 신탁계약을 해지하여 신탁자 명의로 이전한 후 매수인에게 이전등기를 하여야 하며, 이때 매수인은 신탁자를 대위하여 이러한 권리를 행사하여

수탁자에게 등기를 청구할 수 있다(대판 1993. 5. 11, 91다31685). (ii) 신탁자가 목적물을 제3자에게 임대차계약을 맺을 수도 있다. 이 때 임차인은 명의수탁자에 대하여 임차권을 주장할 수 있다. 판례도 주택임대차보호법이 적용되는 임대차로서는, 반드시 임차인과 주택의 소유자인 임대인 사이에 임대차계약이 체결된 경우에 한정된다고 할 수는 없고, 나아가 주택의 소유자는 아니지만 주택에 관하여 적법하게 임대차계약을 체결할 수 있는 권한(적법한 임대 권한)을 가진 임대인과 사이에 임대차계약이 체결된 경우도 포함된다(대판 2008. 4. 10, 2007다38908-38915; 대판 1995. 10. 12, 95다22283; 대판 1999. 4. 23, 98다49753 주택의 명의신탁자가 임대차계약을 체결한 후 명의수탁자가 명의신탁자로부터 주택을 임대할 권리를 포함하여 주택에 대한 처분권한을 종국적으로 이전받는 경우에 임차인이 주택의 인도와 주민등록을 마친 이상 명의수탁자는 주택임대차보호법 제3조 제2항의 규정에 의하여 임차인과의 관계에서 그 주택의 양수인으로서 임대인의 지위를 승계하였다고 보아야 한다)고 한다.

VI-4. 명의신탁의 해지

1. 신탁자의 해지권

→ 신탁자의 해지권·수탁자의 해지권

① 명의신탁자 해지권 → 수탁자에게 신탁재산의 반환을 청구(대판[전합] 1980. 2.9, 79다634).
: 신탁자의 채권자 → 해지권을 대위행사

② 명의수탁자 해지권 → 청산의무로서 신탁재산의 반환의무를 부담

[주의]

부동산실명법 제11조·제12조 제1항과·제4조의 규정에 의하면, 같은 법 시행 전에 명의신탁 약정에 의하여 부동산에 관한 물권을 명의수탁자의 명의로 등기하도록 한 명의신탁자는 같은 법 제11조에서 정한 유예기간 이내에 실명등기 등을 하여야 하고, 유예기간이 경과한 날 이후부터 명의신탁약정과 그에 따라 행하여진 등기에 의한 부동산에 관한 물권변동이 무효가 되므로, 명의신탁자는 더 이상 명의신탁 해지를 원인으로 하는 소유권이전등기를 청구할 수 없다(대판 2007. 6. 14, 2005다5140).

2. 해지의 효과

장래에 향해서만 발생(대판 1982. 8. 24, 82다카416).

Q : 명의신탁계약의 해지에 의하여 신탁자로부터 수탁자에게 이전된 소유권은 등기의 복귀 없이도 신탁자에게 회복되는가?

1) 학 설

(가) 채권적 효과설 해지에 의하여 소유권이 당연히 신탁자에게 복귀하지는 않고, 수탁자는 신탁자에 대하여 소유권 반환의무를 부담할 뿐이며, 그 소유권반환에 관하여 물권적 합의와 이전등기가 있는 때에 비로소 신탁자에게 소유권이 이전된다는 견해이다. 즉 해지로 인하여 즉시 소유권의 변동이 생기는 것이 아니고, 반환청구할 수 있는 채권이 발생할 뿐이라고 한다. 따라서 소유명의가 수탁자에게 있는 동안에 수탁자로부터 소유권을 이

전반은 제3자는 적법하게 소유권을 취득한다. 그러나 다른 견해는 대외적으로는 채권적 효과설을 취하면서 대내적으로는 명의신탁계약의 해지와 함께 신탁자는 등기명의의 회복을 기다릴 필요 없이 당연히 보유하였던 소유권을 행사할 수 있는 것이 된다. 이러한 점에서는 내부관계에 있어서 물권적 효과설과 같다. 다만 해지에 의해 새삼스럽게 복귀하는 것이 아니고 당연한 복귀라는 점에서는 물권적 효과설과는 다르다고 한다.

(나) 물권적 효과설 해지에 의하여 소유권은 당연히 신탁자에게 복귀한다는 견해이다 (곽윤직) 이 견해에 의하면 신탁자는 수탁자에 대하여 소유권에 기하여 말소등기를 청구할 수 있고, 가령 명의신탁계약의 해지 후 아직 등기명의가 수탁자에게 있는 동안 그로부터 소유권을 취득한 제3자가 소유권이전등기까지 경료받았다고 하더라도 신탁자는 소유권에 기하여 제3자에 대하여 그 등기명의의 말소를 청구할 수 있게 된다. 다만 소유명의가 수탁자에게 있는 동안에 수탁자로부터 소유권을 이전받은 선의의 제3자는 제548조 제1항의 단서의 유추적용에 의하여 보호된다.

2) 판례

(가) 대내적 효과(수탁자에 대한 관계) 판례는 명의신탁의 해지에 관하여도 대내관계에서는 소유권은 당연히 신탁자에게 귀속하며, 따라서 신탁자는 수탁자에 대하여 명의신탁 해지를 원인으로 한 소유권이전등기를 청구할 수 있는 동시에 말소등기를 청구할 수 있다고 한다. 이 때의 등기청구권은 신탁해지를 원인으로 한 소유권이전등기청구권이나, 그 실질에서는 소유권에 기한 말소등기청구권이므로 소멸시효에 걸리지 않는다(대판 1980. 4. 8, 80다173).

명의신탁자는 명의수탁자에 대하여 신탁해지를 하고 신탁관계의 종료 그 것만을 이유로 하여 소유 명의의 이전등기절차의 이행을 청구할 수 있음은 물론, 신탁해지를 원인으로 하고 소유권에 기해서도 그와 같은 청구를 할 수 있고(이 경우 양 청구는 청구원인을 달리하는 별개의 소송이다), 위와 같은 법리는 위 상호 명의신탁의 지위를 승계한 자와의 관계에 있어서도 마찬가지로 적용된다(대판[전합] 1980. 12. 9, 79다634).

(나) 대외적 효과(제3자에 대한 관계) 대외관계에 있어서는 당연히 소유권이 복귀하지 않고 등기명의를 신탁자 앞으로 이전하기 전까지는 소유권이 수탁자에게 있게 된다(대판[전합] 1980. 12. 9, 79다634). 따라서 명의신탁을 해지만 하고 아직 소유권이전등기 또는 말소등기를 하지 않은 상태에서 수탁자가 이를 제3자에게 양도하고 이전등기를 마친 경우에는 제3자는 유효하게 소유권을 취득한다(대판 1982. 8. 24, 82다카416). 수탁자가 사망한 후 그 상속인이 수탁부동산을 처분한 경우에도 마찬가지로 처분행위는 유효하다. 제3자가 수탁자로부터 신탁재산을 취득하였으나 아직 등기를 이전 받기 전에 명의신탁계약이 해지된 경우에는 먼저 등기를 하는 자가 우선한다고 할 것이다. 따라서 이 경우에 신탁자가 먼저 등기명의를 회복한 때에는 제3자는 소유권을 취득하지 못한다고 할 것이다(대판 1971. 10. 22, 71다1700). 그리고 명의신탁계약 후 수탁자명의의 소유권이전등기가 경료되기 전에 신탁계약이 해제되면 그 후에 수탁자명의의 소유권이전등기가 경료되더라도 이는 원인무효의 등기이므로(대판 1970. 9. 17, 70다1215), 위 수탁자로부터 이를 영수한 제3자는 적법하게 소유권을 취득할 수 없다. 또한 신탁자가 수탁자에게 이전등기를 청구하자 수탁자가 이를 피하기 위해서 가장매매에 기하여 이를 제3자에게 이전등기를 한 경우에는

무효로 되어 신탁자는 그 이전등기의 말소를 청구할 수 있다(대판 1994. 12. 13, 94다 15486).

3) 검 토 명의신탁의 해지는 일반적인 해지와는 달리 물권행위의 독자성 및 무인성만에 의하여 해결할 문제는 아니라고 본다. 왜냐하면 명의신탁은 내부적으로는 목적물의 소유권이 언제나 신탁자에 있고 문제되는 것은 단지 외부적 소유권뿐이고 수탁자가 완전한 외부적 소유권을 취득하고 있기 때문이다. 따라서 제3자는 자신의 선의·악의에 상관없이 신탁자에게 등기명의가 이전되기 전까지는 해지에도 불구하고 수탁자의 명의의 등기가 되어 있는 한 유효하게 소유권을 취득하게 되고, 명의신탁자는 이전등기를 경료한 제3자에 대하여 소유권을 주장할 수 없다. 다만 제3자가 등기를 하지 않아 채권만을 취득한 단계에서는 신탁계약을 해지한 신탁자와 지위가 동일하므로 먼저 등기를 하는 자가 우선한다. 한편 대내관계에서는 신탁자의 소유권이 해지에 의해서 복귀하는 것이 아니라 당연한 소유권의 확인적인 의미만 있으므로 물권적 효과설과 가깝다. 결국 문제되는 점은 외부적 소유권이므로 명의신탁의 해지의 효과에 대하여 채권적 효과설을 취하는 것이 타당할 것이다.

4) 해지와 수탁자 또는 제3자의 등기

(가) 해지 후 신탁자로 이전등기를 하기 전 수탁자의 지위

부동산소유권을 명의신탁한 경우에 비록 그 명의신탁을 해지하더라도 수탁자로부터 신탁자로의 소유권이전등기를 하지 않고 있는 한 그 소유권이 법률상 당연히 신탁자에게 복귀되는 것은 아니고 외부관계에 있어서의 수탁자의 지위에는 아무런 변동도 생기지 아니하는 것이고 같은 이치에서 수탁자가 사망한 경우에도 수탁자의 상속인은 외부관계에 있어서 그 소유권을 적법하게 상속취득하여 이를 제3자에게 유효하게 처분할 수 있다(대판 1982. 11. 23, 81다372).

(나) 해지 후 신탁자로 이전등기하기 전 제3취득자

부동산의 명의수탁자가 명의신탁이 해지된 후 그 명의신탁자 명의로 신탁해지에 따른 등기의 회복이 있기 전에 그 부동산을 제3자에게 매도하여 그에 따른 소유권이전등기가 제3자 명의로 경료된 경우에는 특별한 사정이 없는 한 위의 제3자는 명의신탁자에 앞서 보호되어야 할 것이므로 명의수탁자가 명의신탁자에 대하여 부담하고 있는 소유권이전등기의무는 이행불능상태에 있는 것이라고 보아야 할 것이다(대판 1982. 12. 28, 82다카984).

(다) 해지 후 이루어진 토지대장의 기재를 바탕으로 한 수탁자명의등기에 기한 제3취득자 아직 수탁자가 명의신탁의 효과로 토지대장 등에 소유자로 등재되었을 뿐 아직 등기를 취득하지 아니한 경우에 있어서 신탁자가 명의신탁을 해지하였음에도 불구하고 그 후 수탁자가 토지대장 등의 기재에 바탕하여 수탁자 명의로 소유권보존등기를 경료하였다면 그 등기는 원인무효의 등기이다(대판 1993. 7. 13, 93다531; 대판 1980. 10. 14, 79다232).

[판례] 명의신탁의 당사자의 결정 (세금 → 실질과세 원칙으로 판단/ 명의자로 판단 아님)
부동산을 제3자에게 명의신탁한 경우 명의신탁자가 부동산을 양도하여 그 양도로 인한 소득이 명의신탁자에게 귀속되었다면 국세기본법 제14조 제1항 및 구 소득세법 제7조 제1항

등에서 규정하고 있는 실질과세 원칙상 당해 양도소득세의 납세의무자는 양도의 주체인 명의신탁자이지 명의수탁자가 그 납세의무자가 되는 것은 아니다(대판 1997. 10. 10, 96누 6387).

* 상호명의신탁

- 등기 : 공유

- 사용·수익 : 특정 부분

다만 구분소유의 약정, 구조상·이용상 독립성

* 공동명의신탁

: 수인에 대하여 명의신탁, 수탁자 상호간 공유, 단 분할 불가

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 동산(자동차 등 제외)은 공부상 그 소유관계가 공시될 수 없기 때문에, 그에 대한 명의신탁이 성립할 여지가 없다.
- ② 소유권은 물론이고 용익물권 및 담보물권에 대하여도 명의신탁이 인정될 수 있다.
- ③ 무효인 명의신탁약정에 기하여 타인 명의의 등기가 마쳐졌다는 이유만으로 그것이 당연히 불법원인급여에 해당한다고 볼 수 없다.
- ④ 명의신탁의 합의(명시 또는 묵시)가 없이 등기만 된 것은 무효이며 명의신탁이 성립하지 않는다.
- ⑤ 명의신탁관계가 성립하기 위해서는 명의신탁 목적물을 반드시 신탁자의 자금으로 취득해야 한다.
- ⑤. 명의신탁 목적물을 반드시 신탁자의 자금으로 취득해야만 명의신탁관계가 성립하는 것은 아니다(대판 2008. 2. 14, 2007다69148).

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 주주명부의 주주 명의가 신탁된 것이고 그 명의차용인으로서 실질상의 주주가 따로 있음을 주장하려면 그러한 명의신탁관계를 주장하는 측에서 명의차용사실을 증명하여야 한다.
- ② 부동산실명법에 의해 무효가 된 부동산 명의신탁의 경우에 있어서 발생하는 부동산자체에 대한 부당이득반환청구권은 민법 제162조 제1항에 따라 10년의 소멸시효에 걸린다.
- ③ 명의수탁자가 제3자에게 처분하는 때에 신의칙상 명의신탁사실을 고지할 의무가 없다.
- ④ 명의신탁자는 수탁자가 아닌 제3자에 대해서는 진정명의의 회복을 위한 소유권이전등기를 청구할 수 없다. 이 경우 수탁자의 등기청구권을 대위행사할 수 있을 뿐이다.
- ⑤ 부동산실명법 소정의 유예기간 내에 실명등기를 하지 아니하여 명의신탁약정이 무효로 된 경우, 종전에 명의신탁 대상 부동산에 관하여 소유권이전등기를 경료한 적이 있던 명의신탁자도 명의수탁자를 상대로 진정명의회복을 원인으로 한 이전등기를 구할 수 없다.
- ⑤. 부동산실명법 소정의 유예기간 내에 실명등기를 하지 아니하여 명의신탁약정이 무효로 된 경우, 종전에 명의신탁 대상 부동산에 관하여 소유권이전등기를 경료한 적이 있던 명의신탁자는 명의수탁자를 상대로 진정명의회복을 원인으로 한 이전등기를 구할 수 있다(대판

2002. 9. 6, 2002다35157).

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 명의신탁된 부동산에 대한 점유취득시효 완성 후 그 소유권이전등기가 경료되기 전에 명의 신탁이 해지되어 등기명의가 명의신탁자에게 이전된 경우, 그에 대하여 시효취득을 주장할 수 없다.
 - ② 명의신탁자는 명의수탁자의 동의 없이 처분이 가능하며, 이는 사실상으로나 법률상으로 처분할 수 있는 권원에 의해 매도한 것이므로 타인의 물건의 매매라 할 수 없다.
 - ③ 주택의 명의신탁자가 임대차계약을 체결한 후 명의수탁자가 명의신탁자로부터 주택을 임대할 권리를 포함하여 주택에 대한 처분권한을 종국적으로 이전받는 경우에 임차인이 주택의 인도와 주민등록을 마친 이상 명의수탁자는 주택임대차보호법 제3조 제2항의 규정에 의하여 임차인과의 관계에서 그 주택의 양수인으로서 임대인의 지위를 승계하였다고 보아야 한다.
 - ④ 부동산실명법 제11조·제12조 제1항과·제4조의 규정에 의하면, 같은 법 시행 전에 명의신탁약정에 의하여 부동산에 관한 물권을 명의수탁자의 명의로 등기하도록 한 명의신탁자는 같은 법 제11조에서 정한 유예기간 이내에 실명등기 등을 하여야 하고, 유예기간이 경과한 날 이후부터 명의신탁약정과 그에 따라 행하여진 등기에 의한 부동산에 관한 물권변동이 무효가 되므로, 명의신탁자는 더 이상 명의신탁 해지를 원인으로 하는 소유권이전등기를 청구할 수 없다.
 - ⑤ 부동산경매절차에서 부동산을 매수하려는 사람이 다른 사람과의 명의신탁약정 아래 그 사람의 명의로 매각허가결정을 받아 자신의 부담으로 매수대금을 완납한 경우, 명의신탁자는 명의수탁자에 대하여 그 부동산 자체의 반환을 구할 수 있다.
- ⑤. 부동산경매절차에서 부동산을 매수하려는 사람이 다른 사람과의 명의신탁약정 아래 그 사람의 명의로 매각허가결정을 받아 자신의 부담으로 매수대금을 완납한 경우, 경매목적 부동산의 소유권은 매수대금의 부담 여부와는 관계없이 그 명의인이 취득하게 되고, 매수대금을 부담한 명의신탁자와 명의를 빌려 준 명의수탁자 사이의 명의신탁약정은 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 제4조 제1항에 의하여 무효이므로, 명의신탁자는 명의수탁자에 대하여 그 부동산 자체의 반환을 구할 수는 없고 명의수탁자에게 제공한 매수대금에 상당하는 금액의 부당이득반환청구권을 가질 뿐이다(대판 2009. 9. 10, 2006다73102).

♣ 학습정리

- 1. 명의신탁의 객체는 공부(등기·등록)에 의하여 소유관계가 표시되는 재화에 한한다.
- 2. 명의신탁 목적물을 반드시 신탁자의 자금으로 취득해야만 명의신탁관계가 성립하는 것은 아니다.
- 3. 부동산실명법 소정의 유예기간 내에 실명등기를 하지 아니하여 명의신탁약정이 무효로 된 경우, 종전에 명의신탁 대상 부동산에 관하여 소유권이전등기를 경료한 적이 있던 명의신탁자는 명의수탁자를 상대로 진정명의회복을 원인으로 한 이전등기를 구할 수 있다.
- 4. 명의신탁된 부동산에 대한 점유취득시효 완성 후 그 소유권이전등기가 경료되기 전에 명의 신탁이 해지되어 등기명의가 명의신탁자에게 이전된 경우, 그에 대하여 시효취득을 주장할 수 없다.
- 5. 명의신탁자는 명의수탁자의 동의 없이 처분이 가능하며, 이는 사실상으로나 법률상으로 처분할 수 있는 권원에 의해 매도한 것이므로 타인의 물건의 매매라 할 수 없다.

제26강 명의신탁 (3)

♣ 학습목표

1. 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률을 정리할 수 있다.
2. 현행 명의신탁제도의 법적 규율을 정리할 수 있다.

♣ 학습내용

- 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률의 주요내용
- 명의신탁의 효력
- 2자간(이전형) 등기명의신탁
- 3자간(중간생략형) 등기명의신탁
- 계약명의신탁

♣ 사전 테스트

1. 동산에 대한 명의신탁도 가능하다.
⇒ × : 명의신탁의 객체는 공부(등기·등록)에 의하여 소유관계가 표시되는 재화에 한한다.
2. 부동산실명법 소정의 유예기간 내에 실명등기를 하지 아니하여 명의신탁약정이 무효로 된 경우, 종전에 명의신탁 대상 부동산에 관하여 소유권이전등기를 경료한 적이 있었다라도 명의신탁자는 명의수탁자를 상대로 진정명의회복을 원인으로 한 이전등기를 구할 수 없다.
⇒ × : 부동산실명법 소정의 유예기간 내에 실명등기를 하지 아니하여 명의신탁약정이 무효로 된 경우, 종전에 명의신탁 대상 부동산에 관하여 소유권이전등기를 경료한 적이 있던 명의신탁자는 명의수탁자를 상대로 진정명의회복을 원인으로 한 이전등기를 구할 수 있다.
3. 명의신탁자는 명의수탁자의 동의 없이 처분이 가능하며, 이는 사실상으로나 법률상으로 처분할 수 있는 권원에 의해 매도한 것이므로 타인의 물건의 매매라 할 수 없다.
⇒ ○ : 명의신탁자는 명의수탁자의 동의 없이 처분이 가능하며, 이는 사실상으로나 법률상으로 처분할 수 있는 권원에 의해 매도한 것이므로 타인의 물건의 매매라 할 수 없다.

♣ 강의교안

Ⅷ. 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률

제1조(목적)

이 법은 부동산에 관한 소유권과 그 밖의 물권을 실체적 권리관계와 일치하도록 실권리자명으로 등기하게 함으로써 부동산등기제도를 악용한 투기·탈세·탈법행위 등 반사회적 행위를 방지하고 부동산 거래의 정상화와 부동산 가격의 안정을 도모하여 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "명의신탁약정"(名義信託約定)이란 부동산에 관한 소유권이나 그 밖의 물권(이하 "부동산에 관한 물권"이라 한다)을 보유한 자 또는 사실상 취득하거나 취득하려고 하는 자[이하 "실권리자"(實權利者)라 한다]가 타인과의 사이에서 대내적으로는 실권리자가 부동산에 관한 물권을 보유하거나 보유하기로 하고 그에 관한 등기(가등기를 포함한다. 이하 같다)는 그 타인의 명의로 하기로 하는 약정[위임·위탁매매의 형식에 의하거나 추인(追認)에 의한 경우를 포함한다]을 말한다. 다만, 다음 각 목의 경우는 제외한다.

가. 채무의 변제를 담보하기 위하여 채권자가 부동산에 관한 물권을 이전받거나 가등기하는 경우

나. 부동산의 위치와 면적을 특정하여 2인 이상이 구분소유하기로 하는 약정을 하고 그 구분소유자의 공유로 등기하는 경우

다. 「신탁법」 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁재산인 사실을 등기한 경우

2. "명의신탁자"란 명의신탁약정에 따라 자신의 부동산에 관한 물권을 타인의 명의로 등기하게 하는 실권리자를 말한다.
3. "명의수탁자"란 명의신탁약정에 따라 실권리자의 부동산에 관한 물권을 자신의 명의로 등기하는 자를 말한다.
4. "실명등기"란 법률 제4944호 부동산실권리자명의등기에관한법률 시행 전에 명의신탁약정에 따라 명의수탁자의 명의로 등기된 부동산에 관한 물권을 법률 제4944호 부동산실권리자명의등기에관한법률 시행일 이후 명의신탁자의 명의로 등기하는 것을 말한다.

제3조(실권리자명의 등기의무 등)

- ① 누구든지 부동산에 관한 물권을 명의신탁약정에 따라 명의수탁자의 명의로 등기하여서는 아니 된다.
- ② 채무의 변제를 담보하기 위하여 채권자가 부동산에 관한 물권을 이전받는 경우에는 채무자, 채권금액 및 채무변제를 위한 담보라는 뜻이 적힌 서면을 등기신청서와 함께 등기관에게 제출하여야 한다.

제4조(명의신탁약정의 효력)

- ① 명의신탁약정은 무효로 한다.
- ② 명의신탁약정에 따른 등기로 이루어진 부동산에 관한 물권변동은 무효로 한다. 다만, 부동산에 관한 물권을 취득하기 위한 계약에서 명의수탁자가 어느 한쪽 당사자가 되고 상대방 당사자는 명의신탁약정이 있다는 사실을 알지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 제1항 및 제2항의 무효는 제3자에게 대항하지 못한다.(→ 제3자의 선악 불문)

제8조(종중, 배우자 및 종교단체에 대한 특례) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 조세 포탈, 강제집행의 면탈 또는 법령상 제한의 회피를 목적으로 하지 아니하는 경우에는 제4조부터 제7조까지 및 제12조제1항부터 제3항까지를 적용하지 아니한다.

1. 종중(宗中)이 보유한 부동산에 관한 물권을 종중(종중과 그 대표자를 같이 표시하여 등기한 경우를 포함한다) 외의 자의 명의로 등기한 경우
2. 배우자 명의로 부동산에 관한 물권을 등기한 경우
3. 종교단체의 명의로 그 산하 조직이 보유한 부동산에 관한 물권을 등기한 경우[시행 2013.7.12.] [법률 제11884호, 2013.7.12., 일부개정]

제11조(기존 명의신탁약정에 따른 등기의 실명등기 등)

① 법률 제4944호 부동산실권리자명의등기에관한법률 시행 전에 명의신탁약정에 따라 부동산에 관한 물권을 명의수탁자의 명의로 등기하거나 등기하도록 한 명의신탁자(이하 "기존 명의신탁자"라 한다)는 법률 제4944호 부동산실권리자명의등기에관한법률 시행일부터 1년의 기간(이하 "유예기간"이라 한다) 이내에 실명등기하여야 한다. 다만, 공용징수, 판결, 경매 또는 그 밖에 법률에 따라 명의수탁자로부터 제3자에게 부동산에 관한 물권이 이전된 경우(상속에 의한 이전은 제외한다)와 종교단체, 향교 등이 조세 포탈, 강제집행의 면탈을 목적으로 하지 아니하고 명의신탁한 부동산으로서 대통령령으로 정하는 경우는 그러하지 아니하다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따라 실명등기를 한 것으로 본다.

1. 기존 명의신탁자가 해당 부동산에 관한 물권에 대하여 매매나 그 밖의 처분행위를 하고 유예기간 이내에 그 처분행위로 인한 취득자에게 직접 등기를 이전한 경우
2. 기존 명의신탁자가 유예기간 이내에 다른 법률에 따라 해당 부동산의 소재지를 관할하는 특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장에게 매각을 위탁하거나 대통령령으로 정하는 바에 따라 「금융회사부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」에 따라 설립된 한국자산관리공사에 매각을 의뢰한 경우. 다만, 매각위탁 또는 매각의뢰를 철회한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 실권리자의 귀책사유 없이 다른 법률에 따라 제1항 및 제2항에 따른 실명등기 또는 매각처분 등을 할 수 없는 경우에는 그 사유가 소멸한 때부터 1년 이내에 실명등기 또는 매각처분 등을 하여야 한다.
- ④ 법률 제4944호 부동산실권리자명의등기에관한법률 시행 전 또는 유예기간 중에 부동산 물권에 관한 쟁송이 법원에 제기된 경우에는 그 쟁송에 관한 확정판결(이와 동일한 효력이 있는 경우를 포함한다)이 있은 날부터 1년 이내에 제1항 및 제2항에 따른 실명등기 또는 매각처분 등을 하여야 한다.

제12조(실명등기의무 위반의 효력 등)

- ① 제11조에 규정된 기간 이내에 실명등기 또는 매각처분 등을 하지 아니한 경우 그 기간이 지난 날 이후의 명의신탁약정 등의 효력에 관하여는 제4조를 적용한다.
- ② 제11조를 위반한 자에 대하여는 제3조제1항을 위반한 자에 준하여 제5조 및 제6조를 적용한다.
- ③ 법률 제4944호 부동산실권리자명의등기에관한법률 시행 전에 명의신탁약정에 따른 등기를 한 사실이 없는 자가 제11조에 따른 실명등기를 가장하여 등기한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다.

1. 목 적(제1조)

2. 적용대상

(1) 적용되는 범위(제2조 제1항)

(2) 적용이 배제되는 범위

- ① 동법 제2조 제1항의 단서는 이 법의 적용을 받는 명의신탁에서 제외되는 3가지의 경우를 규정하고 있다. 여기에는 (i) 채무의 변제를 담보하기 위하여 채권자가 부동산에 대한 물권을 이전받거나(양도담보) 및 가등기를 하는 경우(가등기담보), (ii) 부동산의 위치와 면적을 특정하여 2인 이상이 구분소유하기로 하는 약정을 하고 그 구분소유자의 共有로 등기하는 상호명의신탁의 경우, (iii) 신탁법 또는 신탁업법에 의한 신탁재산인 사실을 등기한 경우(신탁법상의 신탁)에는 각기 고유의 경제적 기능을 가지고 있으며, 전형적인 명의신탁과는 달리 등기부상에 실질권리관계가 나타나는 점 등을 고려하여 유효한 법률행위로 인정하므로 동법의 적용이 배제됨을 명확히 하고 있다. 즉 (i)의 경우에는 「가등기담보 등에 관한 법률」이, (ii)의 경우에는 종래의 판례이론(상호명의신탁이론)이, (iii)의 경우에는 신탁법이 적용된다.

② 또한 종종, 배우자, 종교단체의 경우는 명의신탁이 가능(제8조)

3. 실권리자명의등기의무 및 과징금 등(제3조, 제5조, 제6조, 제7조)

4. 명의신탁의 효력

제4조(명의신탁약정의 효력)

- ① 명의신탁약정은 무효로 한다.
- ② 명의신탁약정에 따른 등기로 이루어진 부동산에 관한 물권변동은 무효로 한다. 다만, 부동산에 관한 물권을 취득하기 위한 계약에서 명의수탁자가 어느 한쪽 당사자가 되고 상대방 당사자는 명의신탁약정이 있다는 사실을 알지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 제1항 및 제2항의 무효는 제3자에게 대항하지 못한다.

(1) 명의신탁 「약정」의 무효(제4조 제1항)

- ① 명의신탁약정이 무효가 되면 그에 기한 급부는 부당이득이 됨

Q : 명의신탁자가 수탁자에게 지급한 매매대금(또는 일정한 경우 수탁자가 매수한 부동산 그 자체)가 불법원인급여(제746조 본문)가 되어 부당이득 반환청구를 하지 못하는가?

→ 불법원인급여 부정설(다수설·판례)

(2) 제3자 보호(제4조 제3항)

1) 제3자는 선의·악의를 묻지 않는다. 이는 종래 판례의 태도를 반영한 것이다.

2) 이때의 제3자는 수탁자로부터 이해관계를 맺은 제3자를 의미하며, 신탁자와 이해관계를 맺은 제3자를 의미하는 것이 아니다.

① 오로지 명의신탁자와 부동산에 관한 물권을 취득하기 위한 계약을 맺고 단지 등기명의만을 명의수탁자로부터 경료받은 것 같은 외관을 갖춘 자는 제3자에 해당되지 않고, 이러한 자는 자신의 등기가 실체관계에 부합하여 유효라고 주장하는 것은 별론으로 하더라도 같은 법 제4조 제3항의 규정을 들어 무효인 명의신탁등기에 터 잡아 경료된 자신의 등기의 유효를 주장할 수는 없다(대판 2004. 8. 30, 2002다48771).

② 수탁자가 물권자임을 기초로 그와의 사이에 새로운 이해관계를 맺는 자를 말하고, 여기에는 소유권이나 저당권 등 물권을 취득한 자뿐만 아니라 압류 또는 가압류채권자도 포함된다(대판 2009. 3. 12, 2008다36022).

③ 부동산실명법 제4조 제3항에 정한 제3자가 아닌 자와 사이에서 무효인 등기(예 : 위조에 의한 등기)를 기초로 다시 이해관계를 맺은 데 불과한 자는 위 조항이 규정하는 제3자에 해당하지 않는다(대판 2005. 11. 10, 2005다34677).

↔ 반대설 : 민법 제108조 제2항의 “선의의 제3자”에 가장행위의 당사자가 그 행위에 의하여 취득한 권리를 전득한 자도 포함되는 것(이론 없음)과 균형을 이루어야 하며, 오히려 명의신탁자를 형사처벌(부동산실명법 제5조)까지 하여 제재를 하는 것을 고려한다면 이러한 것이 없는 가장양도인보다 더욱 권리상실의 법적 불이익을 감수하게 할 수 있어야 함을 이유로 하여 전득자도 제3자에 포함시켜야 한다. 이 견해는 민법 제108조 제2항은 부동산등기에 공신력을 인정하지 않는다는 원칙의 예외이므로 부동산실명법 제4조 제3항도 이러한 원칙의 예외가 될 수 있는 것으로 보고 있다.

[판례] 부동산실명법 제4조 제3항에서의 제3자의 의미

(1) 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률(이하 '부동산실명법'이라 한다) 제4조 제3항에서 “제3자”라고 함은 명의신탁 약정의 당사자 및 포괄승계인 이외의 자로서 명의수탁자가 물권자임을 기초로 그와의 사이에 직접 새로운 이해관계를 맺은 사람을 말한다고 할 것이므로, 명의수탁자로부터 명의신탁된 부동산의 소유명의를 이어받은 사람이 위 규정에 정한 제3자에 해당하지 아니한다면 그러한 자로서는 부동산실명법 제4조 제3항의 규정을 들어 무효인 명의신탁등기에 터 잡아 마쳐진 자신의 등기의 유효를 주장할 수 없고, 따라서 그 명의의 등기는 실체관계에 부합하여 유효라고 하는 등의 특별한 사정이 없는 한 무효라고 할 것이고, 등기부상 명의수탁자로부터 소유권이전등기를 이어받은 자의 등기가 무효인 이상, 부동산등기에 관하여 공신력이 인정되지 아니하는 우리 법제 아래서는 그 무효인 등기에 기초하여 새로운 법률원인으로 이해관계를 맺은 자가 다시 등기를 이어받았다면 그 명의의 등기 역시 특별한 사정이 없는 한 무효임을 면할 수 없다고 할 것이므로, 이렇게 명의수탁자와 직접 이해관계를 맺은 것이 아니라 부동산실명법 제4조 제3항에 정한 제3자가 아닌 자와 사이에서 무효인 등기를 기초로 다시 이해관계를 맺은 데 불과한 자는 위 조항이 규정하는 제3자에 해당하지 않는다고 보아야 한다(대판 2005. 11. 10, 2005다34667).

(2) 명의신탁자와 명의수탁자의 명의신탁약정에 기하여 명의수탁자 앞으로 부동산소유권이전등기가 마쳐진 후 명의수탁자가 이를 새로운 이해관계를 가진 제3자에게 처분한 경우에는 그 제3자에 대하여 명의신탁약정의 무효를 이유로 대항하지 못하는바, 명의수탁자가 명의신탁부동산을 재건축조합에게 신탁하고 재건축조합이 이를 바탕으로 재건축사업을 진행한 경우, 재건축조합도 여기서 말하는 새로운 이해관계인인 제3자에 해당하므로, 명의수탁자와 재건축조합 간에 체결된 명의신탁 부동산에 관한 신탁약정이나 명의수탁자가 재건축조합과의 관계에서 취득한 조합원의 지위 등은 특별한 사정이 없는 한 그 명의신탁약정이 명의신탁자에 대한 관계에서 무효라는 사정만으로 영향을 받지 않는다. 따라서 재건축조합이 관리처분계획인가 및 이에 따른 분양처분의 고시 내지 이전고시 등의 절차를 밟지 않고 조합원들로부터 토지 및 건물 등을 신탁받아 재건축사업을 진행하여 신축한 건물과 그 대지권을 조합원인 명의수탁자와의 분양계약을 통하여 명의수탁자에게 분양한 경우, 명의수탁자의 그 신축 건물 등에 대한 소유권 취득은 유효하고 그 신축 건물 등과 당초의 명의신탁 부동산 사이에는 동일성이 유지되고 있다고 볼 수 없으므로, 명의신탁자는 명의신탁 부동산의 처분을 이유로 명의수탁자에게 손해배상 등을 청구할 수 있음은 별론으로 하고, 당초의 명의신탁약정이 명의신탁자에 대한 관계에서 무효라는 사정을 내세워 명의수탁자를 상대로 명의수탁자가 재건축조합으로부터 분양받은 신축 건물 등에 관한 소유권의 이전을 청구할 권리가 있다고 할 수 없다(대판 2009. 6. 23, 2008다1132).

3) 「대항하지 못한다」의 의미는 신탁자는 제3자에 대하여 명의신탁의 무효를 주장하여 등기의 말소 및 물건의 반환을 청구할 수 없다는 것이다. 즉 수탁자명의의 등기는 무효이지만, 제3자에 대한 관계에서는 유효한 것으로 취급되어 제3자는 물권(또는 채권)을 취득할 수 있다는 것을 의미한다.(제3자가 스스로 무효를 주장하지도 못함 ↔ 반대 송덕수)

4) 배임행위에 가담한 제3자도 보호되는 자가 문제된다. 제3자가 수탁자의 배임행위에 적극적으로 가담한 경우에는 수탁자의 처분행위는 무효로 된다(대판1991. 4. 23, 91다6221). 따라서 제3자가 수탁자와 공모하여 부동산의 소유권을 이전한 경우에는 신탁자는 제3자에 대하여 등기의 말소 및 그 부동산의 반환을 청구할 수 있다.

▶ 돌발 퀴즈

명의수탁자와 직접 이해관계를 맺은 것이 아니라 부동산실명법 제4조 제3항에 정한 제3자가 아닌 자와 사이에서 무효인 등기를 기초로 다시 이해관계를 맺은 자도 위 조항이 규정하는 제3자에 해당한다.

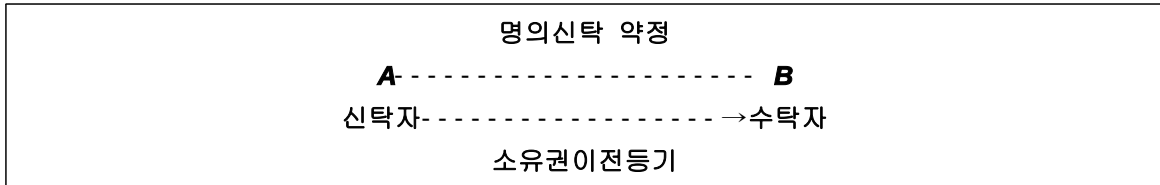
⇒ × : 명의수탁자와 직접 이해관계를 맺은 것이 아니라 부동산실명법 제4조 제3항에 정한 제3자가 아닌 자와 사이에서 무효인 등기를 기초로 다시 이해관계를 맺은 데 불과한 자는 위 조항이 규정하는 제3자에 해당하지 않는다고 보아야 한다(대판 2005. 11. 10, 2005다34667).

명의수탁자와 직접 이해관계를 맺은 것이 아니라 부동산실명법 제4조 제3항에 정한 제3자가 아닌 자와 사이에서 무효인 등기를 기초로 다시 이해관계를 맺은 데 불과한 자는 위 조항이 규정하는 제3자에 해당하지 않는다고 보아야 한다(대판 2005. 11. 10, 2005다34667).

(3) 유형별 명의신탁등기의 효력

명의신탁약정에 의하여 행하여진 등기에 기한 부동산은 무효이다(부동산실명법 제4조 제2항 본문). 따라서 명의수탁자는 명의신탁자에 대한 관계에서는 물론 제3자에 대한 관계에서도 소유권을 주장할 수 없다.

1) 2자간 등기명의신탁(이전형 명의신탁)

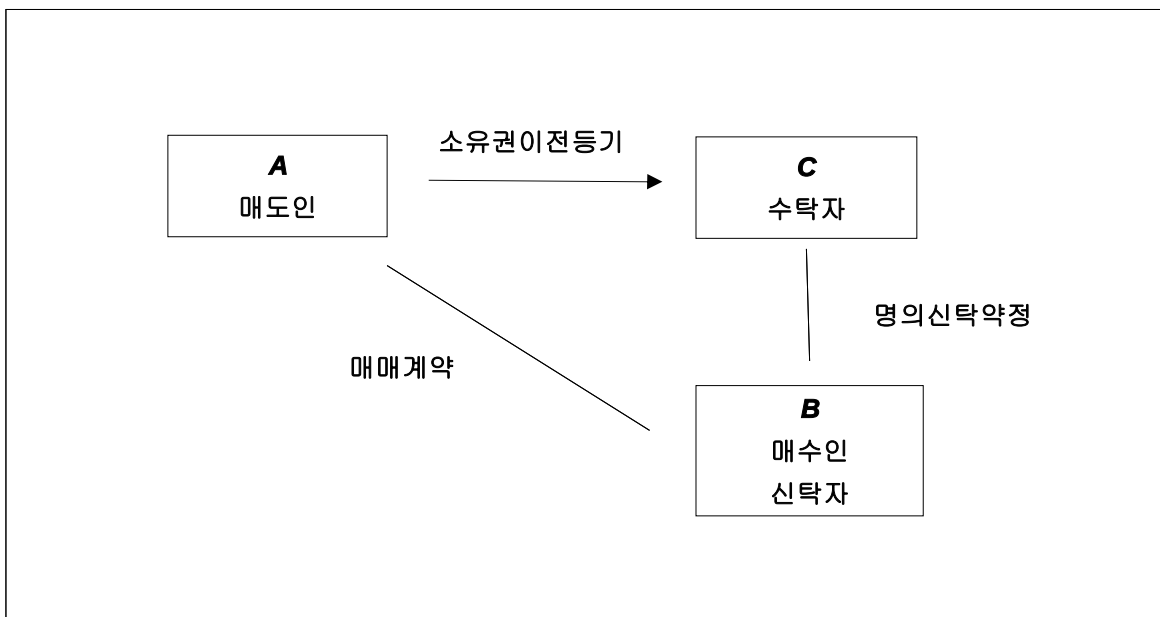


- ① 명의신탁 약정 무효
- ② 등기에 기한 물권변동(소유권이전)도 무효
- ③ 신탁자는 여전히 수탁자에 대한 관계에서 소유자임
- ④ 수탁자는 제3자(선의·악의)에 대한 관계에서 소유자 → 제3자는 유효하게 소유권 취득(제3항)
→ 신탁자는 수탁자에게 불법행위 손해배상청구 또는 부당이득반환청구 가능

Q : 신탁자가 수탁자에 대한 관계에서 여전히 소유자인바 반환받는 방법은?

- ① 명의신탁 해지를 통해서 소유권이전등기 말소등기청구 또는 소유권이전등기청구 불가 (명의신탁계약 자체가 무효이므로)(대판 1999. 1. 26, 98다1027)
- ② 소유권에 기한 방해배제청구권(제214조)을 근거로 소유권이전등기 말소등기청구 가능
- ③ 소유권에 기한 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구 가능(대판 2002. 9. 6, 2002다35157)
- ④ 부당이득반환청구(다수설·판례 : 불법원인급여 아님)

2) 3자간 등기명의신탁(중간생략형 명의신탁)



① 명의신탁약정이 3자간 등기명의신탁인지 아니면 계약명의신탁인지의 구별은 계약당사자가 누구인가를 확정하는 문제로 귀결 : 계약명의자인 명의수탁자가 아니라 명의신탁자에게 계약에 따른 법률효과를 직접 귀속시킬 의도로 계약을 체결한 사정이 인정된다면 명의신탁자가 계약당사자라고 할 것이므로, 이 경우의 명의신탁관계는 3자간 등기명의신탁으로 보아야 한다(대판 2010. 10. 28, 2010다52799).

② ㉠ 명의신탁약정 → 무효

㉡ 소유권이전등기 → 무효(무효등기)

㉢ 매도인이 여전히 소유자

- 소유권에 기하여 명의수탁자 명의 등기의 말소등기(매도인은 수탁자에 대하여)
- 소유권에 기하여 진정명의 회복을 원인으로 하는 소유권이전 등기(매도인은 수탁자에 대하여)
- 만약 수탁자가 자기명의등기를 기화로 제3자(선의·악의 불문)에게 매도 → 제3자는 소유권 취득(제3항), 수탁자는 소유권상실, 수탁자는 매도인에 대하여 횡령죄 성립

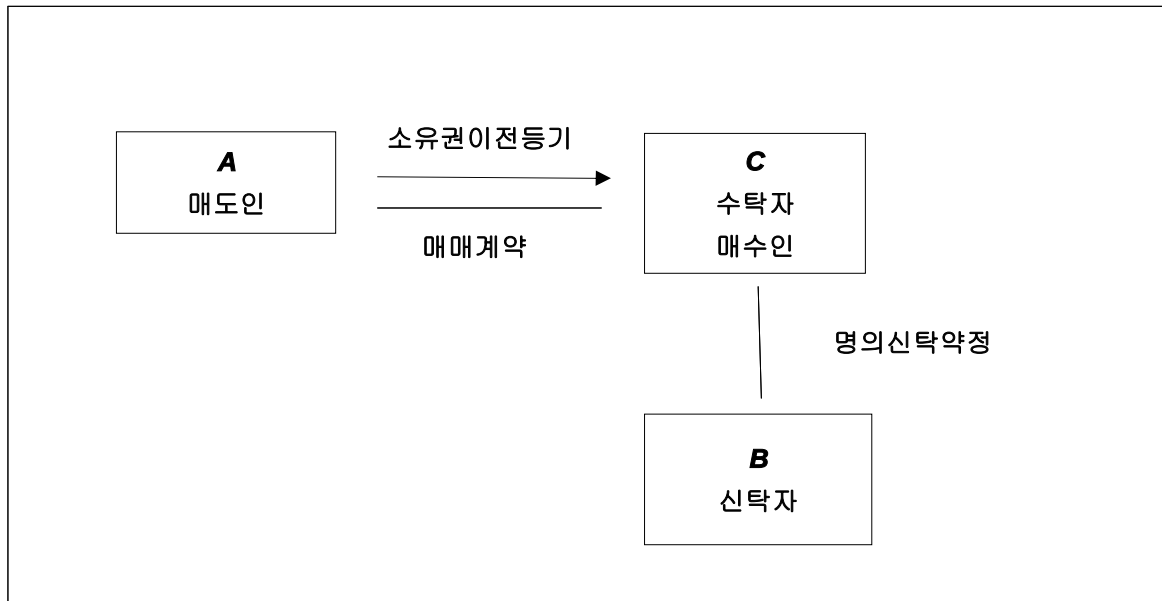
㉣ 매매계약은 여전히 유효한 상태

- 신탁자는 매도인에게 여전히 소유권이전등기청구권 보유(설령 유예기간 경과하였어도 매매는 유효한 상태)
- 명의신탁 부동산의 소유권이 매도인에게 복귀한 마당에 명의신탁자가 무효인 등기의 명의인인 명의수탁자를 상대로 그 이전등기를 구할 수도 없으므로, 결국 3자간 등기명의신탁에 있어서 명의신탁자는 명의수탁자를 상대로 부당이득반환을 원인으로 한 소유권이전등기를 구할 수 없다고 한다(대판 2008. 11. 27, 2008다55290-55306; 대법원 2009. 4. 9, 2008다87723). → 단 제3자가 소유권취득 → 매도인의 소유권이전의무 이행불능 → 신탁자손해/수탁자 이득 → 처분대금·보상금의 부당이득(대판 2011. 9. 8, 2009다49193-49209)
→ 신탁자는 매도인을 대위하여 수탁자로부터 매도인에게로 말소등기청구를 할 수 있음(대판 2002. 3. 15, 2001다61654)
- 수탁자 명의의 등기 말소(대위하여) → 매도인 명의로 등기 → 신탁자에게로 이전등기 : 실제관계에 부합하여 유효(대판 2004. 6. 25, 2004다6764)

[판례] 명의신탁자의 명의수탁자에 대한 등기말소의 방법

부동산실권리자명의 등기에 관한 법률 소정의 유예기간 경과에 의하여 기존 명의신탁 약정과 그에 의한 등기가 무효로 되면 명의신탁 부동산은 매도인 소유로 복귀하므로 매도인은 명의수탁자에게 무효인 명의수탁자 명의의 등기의 말소를 구할 수 있게 되고, 한편 같은 법은 매도인과 명의신탁자 사이의 매매계약의 효력을 부정하는 규정을 두고 있지 아니하여 위 유예기간 경과 후로도 매도인과 명의신탁자 사이의 매매계약은 여전히 유효하므로, 명의신탁자는 위 매매계약에 기한 매도인에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 매도인을 대위하여 명의수탁자에게 무효인 명의수탁자 명의의 등기의 말소를 구할 수 있다(대판 1999. 9. 17, 99다21738).

3) 계약명의신탁(위임형 명의신탁)



1) 매도인이 선의인 경우

- ① 제4조 제2항 단서에 의하여 명의수탁자의 계약상대방인 매도인이 계약명의신탁약정이 있었음을 알지 못한 경우(선의)에는 부동산 물권변동은 유효하고, 이에 따라 명의수탁자 명의등기는 유효하게 된다. 따라서 매도인이 명의신탁약정에 대하여 선의인 경우에는 명의수탁자는 매도인은 물론 명의신탁자에 대한 관계에서도 그 부동산에 관한 유효하고 완전한 소유권을 취득하게 된다(대판 2002. 12. 26, 2000다21123).
- ② 명의신탁약정은 무효이므로 명의신탁자가 수탁자에 대하여 명의신탁해지를 이유로 소유권이전등기청구를 할 수 없다.

Q : 이 경우 신탁자는 수탁자를 상대로 부당이득반환을 청구할 수 있는데, 부당이득이 매수대금인가 아니면 매매목적물자체인가?(판례 참조)

판례 :

- ① 부동산실명법 시행 전에 명의신탁약정이 있는 경우의 부당이득은 취득한 부동산 자체
- ② 부동산실명법 시행 후에 명의신탁약정을 한 경우의 부당이득은 신탁자가 제공한 매매대금뿐(수탁자의 소유권은 법률상 원인이 있기 때문)

2) 매도인이 악의인 경우

- ① 매도인이 악의인 경우 명의신탁약정 및 물권변동은 무효 → 수탁자 명의의 등기도 무효
 - 매도인이 소유자가 됨
 - 매도인은 수탁자를 상대로 소유권이전등기말소청구 또는
 - 매도인은 수탁자를 상대로 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구
 - 매매계약에 대하여는 규정 없음(악의인 경우는 불능계약목적이므로 매매계약도 무효)

② 명의신탁자는 매도인과 사이에 아무런 법률관계가 없음

매도인에 대해 부당이득반환청구를 할 수 없고, 다만 수탁자를 상대로 부당이득반환을 청구하거나 수탁자의 무자력을 요건으로 수탁자가 매도인에 대해 가지는 부당이득반환청구권을 대위행사할 수 있다.

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 명의신탁약정과 그에 따른 물건변동의 무효는 제3자에게 대항하지 못한다.
 - ② 위 ①의 제3자는 선의, 악의를 묻지 않고, 수탁자로부터 이해관계를 맺은 제3자를 의미하며, 신탁자와 이해관계를 맺은 제3자를 의미하는 것이 아니다.
 - ③ 수탁자가 물건자임을 기초로 그와의 사이에 새로운 이해관계를 맺는 자를 말하고, 여기에는 소유권이나 저당권 등 물권을 취득한 자가 포함된다. 그러나 압류 또는 가압류채권자는 이에 해당하지 않는다.
 - ④ 부동산실명법 제4조 제3항에 정한 제3자가 아닌 자와 사이에서 무효인 등기(예 : 위조에 의한 등기)를 기초로 다시 이해관계를 맺은 데 불과한 자는 위 조항이 규정하는 제3자에 해당하지 않는다.
 - ⑤ 오로지 명의신탁자와 부동산에 관한 물권을 취득하기 위한 계약을 맺고 단지 등기명의만을 명의수탁자로부터 경로받은 것 같은 외관을 갖춘 자는 자신의 등기가 실제관계에 부합하여 유효라고 주장하는 것은 별론으로 하더라도 부동산실명법 제4조 제3항의 규정을 들어 무효인 명의신탁등기에 더 잡아 경로된 자신의 등기의 유효를 주장할 수는 없다.
- ③. 수탁자가 물건자임을 기초로 그와의 사이에 새로운 이해관계를 맺는 자를 말하고, 여기에는 소유권이나 저당권 등 물권을 취득한 자뿐만 아니라 압류 또는 가압류채권자도 포함된다(대판 2009. 3. 12, 2008다36022).

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 2자간 명의신탁에 있어서 명의신탁약정과 이에 기한 물건변동은 무효이지만, 신탁자는 여전히 수탁자에 대한 관계에서 소유자이고, 수탁자는 제3자(선악 불문)에 대한 관계에서 소유자이다.
- ② 계약명의자인 명의수탁자가 아니라 명의신탁자에게 계약에 따른 법률효과를 직접 귀속시킬 의도로 계약을 체결한 사정이 인정된다면 명의신탁자가 계약당사자라고 할 것이므로, 이 경우의 명의신탁관계는 3자간 등기명의신탁으로 보아야 한다.
- ③ 3자간 명의신탁에서 매도인이 여전히 소유자이며, 매매계약은 여전히 유효한 상태이므로, 명의신탁자는 매도인에게 여전히 소유권이전등기청구권을 보유한다.
- ④ 3자간 등기명의신탁에 있어서 명의신탁자는 명의수탁자를 상대로 부당이득반환을 원인으로 한 소유권이전등기를 구할 수 있다.
- ⑤ 3자간 등기명의신탁의 경우 명의신탁자는 매도인을 대위하여 수탁자로부터 매도인에게로 말소등기청구를 할 수 있다.

- ④. 명의신탁 부동산의 소유권이 매도인에게 복귀한 마당에 명의신탁자가 무효인 등기의 명의인인 명의수탁자를 상대로 그 이전등기를 구할 수도 없으므로, 결국 3자간 등기명의신탁에 있어서 명의신탁자는 명의수탁자를 상대로 부당이득반환을 원인으로 한 소유권이전등기를 구할 수 없다고 한다(대판 2008. 11. 27, 2008다55290-55306; 대법원 2009. 4. 9, 2008다87723)

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 명의수탁자의 계약상대방인 매도인이 계약명의신탁약정이 있었음을 알지 못한 경우(선의)에는 부동산 물권변동은 유효하고, 이에 따라 명의수탁자 명의등기는 유효하게 된다.
- ② 위 ①의 경우 매도인이 명의신탁약정에 대하여 선의인 경우에는 명의수탁자는 매도인은 물론 명의신탁자에 대한 관계에서도 그 부동산에 관한 유효하고 완전한 소유권을 취득하게 된다.
- ③ 위 ② 경우 명의신탁자는 명의수탁자를 상대로 부당이득반환을 청구할 수 있는데, 부동산 실명법 시행 전에 명의신탁약정이 있는 경우의 부당이득은 취득한 부동산 자체이다.
- ④ 위 ② 경우 명의신탁자는 명의수탁자를 상대로 부당이득반환을 청구할 수 있는데, 부동산 실명법 시행 후에 명의신탁약정을 한 경우의 부당이득은 신탁자가 제공한 매매대금뿐이다.
- ⑤ 위 ②의 경우 명의신탁자는 매도인에 대해 부당이득반환청구를 할 수 있다.
- ⑤. 계약명의신탁자는 매도인과 사이에 아무런 법률관계가 없다. 따라서 매도인에 대해 부당이득반환청구를 할 수 없고, 다만 수탁자를 상대로 부당이득반환을 청구하거나 수탁자의 무자력을 요건으로 수탁자가 매도인에 대해 가지는 부당이득반환청구권을 대위행사할 수 있다.

♣ 학습정리

1. 명의신탁약정과 그에 따른 물권변동의 무효는 제3자에게 대항하지 못한다.
2. 부동산실명법상 대항하지 못하는 제3자는 수탁자가 물권자임을 기초로 그와의 사이에 새로운 이해관계를 맺는 자를 말하고, 여기에는 소유권이나 지당권 등 물권을 취득한 자뿐만 아니라 압류 또는 가압류채권자도 포함된다.
3. 2자간 명의신탁에 있어서 명의신탁약정과 이에 기한 물권변동은 무효이지만, 신탁자는 여전히 수탁자에 대한 관계에서 소유자이고, 수탁자는 제3자(선악 불문)에 대한 관계에서 소유자이다.
4. 명의신탁 부동산의 소유권이 매도인에게 복귀한 마당에 명의신탁자가 무효인 등기의 명의인인 명의수탁자를 상대로 그 이전등기를 구할 수도 없으므로, 결국 3자간 등기명의신탁에 있어서 명의신탁자는 명의수탁자를 상대로 부당이득반환을 원인으로 한 소유권이전등기를 구할 수 없다.
5. 계약명의신탁의 경우 매도인이 명의신탁약정에 대하여 선의인 경우에는 명의수탁자는 매도인은 물론 명의신탁자에 대한 관계에서도 그 부동산에 관한 유효하고 완전한 소유권을 취득하게 된다.

제27강 지상권 (1)

♣ 학습목표

1. 지상권의 의의에 대하여 정리할 수 있다.
2. 지상권의 취득·효력·소멸에 대하여 정리할 수 있다.

♣ 학습내용

- 지상권의 의의,
- 지상권의 취득, 존속기간
- 지상권의 효력
- 지상권의 소멸

♣ 사전 테스트

1. 지상권은 토지의 교환가치를 목적으로 하는 담보물권이다.
⇒ × : 지상권은 토지를 사용하는 것을 내용으로 하는 용역물권이다.
2. 지상권은 법률행위에 의해서만 취득 가능하다.
⇒ × : 법률의 규정에 의하여 성립하는 법정지상권도 존재한다.
3. 지상권자는 특약이 없는 한 지료를 지급할 필요가 없다.
⇒ ○ : 지상권은 다른 합의가 없으면 원칙적으로 무상이다.

♣ 강의교안

제3절 지상권

I. 총설

1. 의의

- 건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위해서 타인의 토지를 사용하는 것을 내용으로 하는 물권(제279조)

2. 성질

- 물권 : 양도성, 상속성
 - 지상권자는 지상권을 유보한 채 지상물 소유권만을 양도할 수도 있고 지상물 소유권을 유보한 채 지상권만을 양도할 수도 있는 것이어서 지상권자와 그 지상물의 소유권자가 반드시 일치하여야 하는 것은 아니며, 또한 지상권설정시에 그 지상권이 미치는 토지의 범위와 그 설정 당시 매매되는 지상물의 범위를 다르게 하는 것도 가능하다(대법원 2006.06.15. 선고 2006다6126 판결).
 - 비록 별채권의 확보를 위하여 지상권을 설정하였다 하더라도 지상권에는 부종성이 인정되지 아니하므로 별채권이 소멸하였다 하더라도 지상권마저 소멸하는 것은 아니고, 지상권은 독립된 물권으로서 다른 권리에 부종함이 없이 그 자체로서 양도될 수 있으며 그 양도성은 민법 제282조, 제289조에 의하여 절대적으로 보장되고 있으므로 소유자의 의사에 반하여도 자유롭게 타인에게 양도할 수 있다(대법원 1991.11.08. 선고 90다15716 판결).
 - 타물권 : 타인 소유의 토지에 관한 권리이므로 소유권과 혼동시 소멸한다.
 - 용익물권 : 타인의 토지를 독점적으로 사용하는 권리로서 토지의 일부에 대해서도 성립 가능함
 - 지료는 지상권의 요소가 아니므로, 지료에 관한 약정이 없으면 무상으로 인정된다(대판 1999.9.3, 99다24847). 그러나 법정지상권의 경우 지료지급의무가 당연히 발생한다.

※ 담보지상권 : 지상권을 담보목적으로 전용

토지에 관하여 저당권을 취득함과 아울러 그 저당권의 담보가치를 확보하기 위하여 지상권을 취득하는 경우, 특별한 사정이 없는 한 당해 지상권은 저당권이 실행될 때까지 제3자가 용익권을 취득하거나 목적 토지의 담보가치를 하락시키는 침해행위를 하는 것을 배제함으로써 저당 부동산의 담보가치를 확보하는 데에 그 목적이 있다고 할 것이므로, 그와 같은 경우 제3자가 비록 토지소유자로부터 신축중인 지상 건물에 관한 건축주 명의를 변경받았다 하더라도, 그 지상권자에게 대항할 수 있는 권원이 없는 한 지상권자로서는 제3자에 대하여 목적 토지 위에 건물을 축조하는 것을 중지하도록 구할 수 있다(대법원 2004.03.29. 자 2003마1753 결정).

3. 기능

- 부합방지(수목), 철거방지(수목, 건물)

※ 임차권과의 비교

II. 분류

1. 일반지상권과 구분지상권

- 일반지상권 : 건물 기타 공작물 및 수목의 소유를 위해 타인의 토지의 상하 사용
- 구분지상권
 - 의의(제289조의 2) : 토지소유권이 미치는 지상, 지하를 층으로 나누어 특정된 층에만 사용권이 부여되는 지상권
 - 설정상의 특수성 : 기존 용역권자의 승낙(제289의2 제2항)
 - 효력 : 지상권의 규정에 따름

2. 법정지상권

- 성문법 : 제305조, 제366조, 가등기담보법 제10조, 임목법 제10조
- 관습법 : 관습법상 법정지상권

III. 지상권의 취득

1. 법률행위

- 물권변동의 일반원칙에 따름 → 설정행위 : 지상권설정합의 + 등기

2. 법률규정

- 등기 불필요(상속·판결·경매·공용징수, 다만 점유취득시효의 경우 등기해야(제245조))
- 법정지상권
 - 제305조, 제366조, 가담법 제10조, 임목법 제10조
 - 토지가 양도된 경우 법정지상권자는 등기 없이도 양수인에게 대항할 수 있다(대판(전) 1965.9.23, 65다1222).
 - 법정지상권을 취득한 건물소유자가 건물을 양도한 경우 별도의 특약이 없는 한 건물소유권 양도의 합의는 법정지상권 양도의 합의를 포함한다.
 - 법정지상권자는 물권으로서의 효력에 의하여 이를 취득할 당시의 대지소유자나 이로부터 소유권을 전득한 제삼자에 대하여도 등기없이 위 지상권을 주장할 수 있는 것이므로, 대지의 전득자에 대하여 지상권설정등기청구권이 있다 할 것이므로, 법정지상권을 양도받기로 한 자는 채권자대위의 법리에 의하여 차례로 토지소유자, 지상권 양도인에 대하여 지상권설정등기 및 이전 등기절차의 이행을 구할 수 있다. 그리고 이와 같이 이 사건 대지에 대한 법정지상권을 취득할 지위에 있는 자에 대하여 토지소유자가 대지소유권에 기하여 건물철거를 구함은, 지상권의 부담을 용인하고 그 설정등기절차를 이행할 의무 있는 자가 그 권리자를 상대로 한 청구라 할 것이어서 신의성실의 원칙상 허용될 수 없다(대법원(전합) 1985.04.09. 선고 84다카1131 판결).
 - 법정지상권자라 할지라도 대지 소유자에게 지료를 지급할 의무는 있는 것이고, 법정지상권이 있는 건물의 양수인으로서 장차 법정지상권을 취득할 지위에 있어 대지 소유자의 건물 철거나 대지 인도 청구를 거부할 수 있다 하더라도 그 대지를 점유·사용함으로써 인하여 얻은 이득은

부당이득으로서 대지 소유자에게 반환할 의무가 있다(대법원 1997.12.26. 선고 96다34665 판결).

3. 관습법

- 분묘기지권, 관습법상 법정지상권

IV. 존속기간

1. 계약으로 기간을 정한 때 : 원칙

- 최단기간(제280조)

- 석조· 석회조· 연와조 이와 비슷한 견고한 건물이나 수목의 소유목적 : 30년
- 그 밖의 건물 소유목적 : 15년
- 건물 이외의 공작물의 소유목적 : 5년
- 계약으로써 이보다 단기의 기간을 정한 경우 그 존속기간은 위의 최단기간으로 연장(제280조 제2항)

- 최장기간

- 영구무한의 지상권 인정 가능한가?

민법상 지상권의 존속기간은 최단기만이 규정되어 있을 뿐 최장기에 관하여는 아무런 제한이 없으며, 존속기간이 영구(영구)인 지상권을 인정할 실체의 필요성도 있고, 이러한 지상권을 인정한다고 하더라도 지상권의 제한이 없는 토지의 소유권을 회복할 방법이 있을 뿐만 아니라, 특히 이 사건에서와 같은 구분지상권의 경우에는 존속기간이 영구라고 할지라도 대지의 소유권을 전면적으로 제한하지 아니한다는 점 등에 비추어 보면, 지상권의 존속기간을 영구로 약정하는 것도 허용된다(대법원 2001.05.29. 선고 99다66410 판결).

2. 계약으로 기간을 정하지 아니한 때

- 지상물의 종류와 구조에 따라 제280조가 정하는 최단존속기간을 그 지상권의 존속기간으로 함(제281조 제2항)
- 지상권설정 당시에 공작물의 종류와 구조를 정하지 아니한 때에는 그 지상권의 존속기간은 15년임(제281조 제2항)

3. 계약의 갱신과 존속기간

(1) 계약에 의한 갱신

- 당사자의 계약으로 가능

(2) 지상권자의 갱신청구권(민법 제283조)

(가) 요건

- 존속기간의 만료 → 다른 사유로 소멸시는 불가
- 건물 기타 공작물 또는 수목의 현존

(나) 성질

- 채권적 청구권(형성권×) → 그러나 상대방의 승낙의무는 없음 ⇒ 승낙거절시 제283조 제2항에 따른 매수청구권 행사 가능

(다) 행사

- 지상권 기간 만료 후 지체 없이 행사해야

(라) 갱신된 존속기간

- 제284조 → 제280조의 최단기간보다 단축할 수 없음

4. 존속기간 규정

- 민법 제289조 : 지상권자에게 불리한 약정 무효, 지상권자에게 유리하면 유효 → 편면적 강행규정

V. 지상권의 효력

1. 토지이용권

- 설정행위에서 정한 목적의 범위 내에서 토지를 사용할 권리 → 지상물의 소유에 필요한 범위 내에서 토지의 상, 하에 미침
- 이용제한 : 공작물, 수목의 종류제한 가능 → 등기해야 양수인에게 대항 가능
- 토지에 영구적 손해를 주는 변경 및 목적 범위 벗어난 이용 금지
- 소유자의 이용 제한 및 (소극적) 인용의무 → 이용적상 유지의무는 원칙적으로 없음
- 상린관계규정의 준용(제290조)

2. 지상권자의 점유권과 물권적 청구권

- 토지를 사용할 물권으로서 토지를 점유할 권리를 포함하고, 지상권은 제256조 단서 소정의 권원에 해당하므로 지상권자가 토지에 부속시킨 공작물이나 수목은 토지에 부합되지 않고 매수청구의 대상이 된다.
- 지상권의 내용의 실현이 방해되는 경우에는 물권적 청구권을 행사할 수 있음 → 반환청구권, 방해제거청구권, 방해예방청구권

3. 지상권의 처분 : 지상권자의 투하자본 회수 방법

▶ 돌발 퀴즈

계약자유 원칙에 따라 당사자들이 지상권의 처분을 금지하는 특약을 맺을 수 있고 이러한 특약은 유효하다.

⇒ × : 지상권의 처분금지특약은 무효이다(제282조, 제289조).

(1) 처분의 자유

- 민법 제282조는 강행규정이므로 처분금지특약은 무효(제289조)
- 토지 임대도 가능(이 경우 등기 불필요)
- 저당권 설정 가능(제371조) : 담보제공 금지특약의 효력 : 채권적 효력설 ↔ 무효설(다수설 ← 투하자본 회수보장)

(2) 지상물 양도와 지상권

- 지상물의 소유 자체는 지상권의 내용이 아님 → 지상물소유와 지상권의 분리 가능 → 지상물만의 양도도 가능(대법원 2001.12.27. 선고 2000다1976 판결)
- 이 경우 지상권에 관한 합의 없이 지상물 양도시 지상권은?
 - 수반이전설 : 양자가 결합되어 경제적 효용 발휘
 - 반대설 : 별개의 권리. 물권변동에 관한 성립요건주의(← 등기 부존재)

4. 지료지급의무

(1) 발생

- 지료합의시 발생 → 합의 없으면 원칙적으로 무상(대법원 1999.9.3. 선고 99다24874 판결)
- 법정지상권 : 청구 있으면 법원이 결정

(2) 지상권 이전과 지료의무

- 지료채무도 이전 → 단 등기 있어야 소유자는 새로운 지상권자에게 지료 대항가능(부등법 제69조 : 대법원 2001.3.13. 선고 99다17142 판결)
- 체납효과 승계 안됨(위 판례)
- 이전등기 있어야 전지상권자의 지료채무 소멸

(3) 토지소유권 이전과 지료청구권

- 지료청구권도 수반 이전
- 증액금지특약 : 등기가 있을 때 신소유자에게 대항 가능

(4) 지료증감청구권 : 민법 제286조

- 성질 : 형성권
- 일방의 결정에 대하여 상대방이 다투는 경우
 - 법원이 결정 → 소급효
 - 결정전까지 종래의 지료(증액청구시) 또는 감액된 지료(감액청구시) 지급해도 연체 아님

VI. 지상권의 소멸

1. 원인

- 물권에 공통된 소멸사유 : 멸실, 혼동, 소멸시효, 포기
- 제한물권에 공통된 소멸사유 : 존속기간 만료, 선순위저당권 실행

(1) 소멸청구(민법 제287조)

- 요건 : 통산 2년분 이상 지료지급 지체 ← 지상권자의 유책사유
- 성질 : 등기를 요하는가 여부와 관련
 - 형성권설 : 형성권특질 강조(등기불요)
 - 채권적 청구권설(등기필요)
- 행사 효과 : 장래를 향한 소멸
- 제288조 : 지상권 또는 건물이 저당권의 목적인 때, 저당권자에게 통지한 후 상당한 기간 경과해야 효력발생 → 저당권자는 이해관계 있는 제3자로서 변제 가능하므로

(2) 제544조(계약해제) 적용

- 지당권자의 토지에 영구적 손해를 가하는 변경을 하거나 기타 토지 사용에 대한 약정위반
→ 최고 후 해지 가능

(3) 지상권 포기

- 타인에게 손해주지 않아야 하고, 지료가 있을 때는 손해배상해야 함
- 제371조 제2항 : 지당권자의 동의

(4) 기타 약정소멸사유

- 제289조 소정의 편면적 강행규정에 위반하지 않아야 하므로, 존속기간, 소멸청구 등에 있어서 지상권자에게 불리한 약정은 효력이 없는 경우가 있을 수 있음

2. 소멸의 효과

(1) 지상권자의 원상회복의무(제285조 제1항)

- 지상물 수거는 권리이자 의무의 성격

(2) 소유자의 매수청구권(제285조 제2항)

- 상당한 가액제공하여 매수청구 가능
- 형성권 : 행사하면 매매 성립
- 정당한 사유 있으면 거절 가능

(3) 지상권자의 매수청구권(제283조)

- 갱신청구 불응시 투자자본회수 수단 ← 갱신의 사실상 강제
- 존속기간 만료 이외의 사유로 인한 종료의 경우 매수청구가 인정되지 않고, 특히 지상권자 귀책사유 시에는 불가(대법원 1993.6.29. 선고 93다10781 판결)

(4) 지상권자의 비용상환청구권

- 필요비 : 지상권자 부담
- 유익비 : 제626조(임차인의 상환청구권) 유추

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 지상권자는 지상권을 유보한 채 지상물 소유권만을 양도할 수 있다.
- ② 지상권은 타물권으로서 소유권과 혼동시 소멸한다.
- ③ 지상권은 용익물권으로서 일물일권주의에 따라 토지의 일부에 대해서는 성립되지 않는다.
- ④ 지료는 지상권의 요소가 아니다.
- ⑤ 지상권을 담보목적으로 전용한 경우에도 물권법정주의에 반하지 않는다.
⇒ ③. 지상권은 토지의 일부에 대하여도 성립할 수 있다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 지상권은 지상 또는 지하의 층을 나누어 특정한 층에만 성립할 수도 있다.
- ② 법정지상권이 성립하면 지료지급의무 역시 당연히 발생한다.
- ③ 지상권의 존속기간에 관하여 민법은 최장기간의 규정을 두고 있다.
- ④ 지상권 설정 당시 공작물의 종류·구조를 정하지 않은 경우 그 존속기간은 15년이다.
- ⑤ 지상권자의 갱신청구권은 존속기간 만료 시 건물 기타 공작물 또는 수목이 현존한 경우에만 인정된다.

⇒ ③. 최단기간의 규정만 두고 있으나, 판례는 구분지상권의 경우 영구무한의 지상권을 인정한다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 지상권에 있어서 지료증감청구권은 형성권이다.
- ② 지상권은 멸실, 혼동, 소멸시효 등으로 소멸한다.
- ③ 지상권자의 귀책사유가 있는 경우에는 지상물매수청구권을 행사할 수 없다.
- ④ 통산 1년분 이상의 지료지급이 지체된 경우 지상권의 소멸청구가 가능하다.
- ⑤ 지상권이 저당권의 목적인 경우 지상권 소멸청구는 저당권자에게 통지한 후 상당한 기간이 경과함으로써 효력이 생긴다.

⇒ ④. 지상권의 소멸청구는 통산 2년분 이상의 지료가 연체된 경우 가능하다.

♣ 학습정리

- 1. 지상권은 공작물이나 수목의 소유를 위하여 타인의 토지를 사용하는 것을 내용으로 하는 용역물권이다.
- 2. 지상권의 취득은 법률행위에 의한 것은 물론이고 법률의 규정에 의해서도 이루어진다.
- 3. 지상권자자에게는 토지사용권, 지상권처분의 자유, 지료지급의무가 인정된다.
- 4. 지상권은 일정한 경우 지상권설정자의 소멸청구에 의하여 소멸한다.

제28강 지상권 (2), 지역권 (1)

♣ 학습목표

1. 특수 지상권에 대하여 설명할 수 있다.
2. 지역권의 법적 성질 및 종류에 대하여 정리할 수 있다.

♣ 학습내용

- 구분지상권
- 분묘기지권
- 관습법상 법정지상권
- 지역권의 법적 성질

♣ 사전 테스트

1. 수목의 소유를 위한 구분지상권은 인정되지 않는다.
⇒ ○ : 구분지상권은 공작물의 소유를 위해서만 인정된다.
2. 토지와 그 지상의 건물이 동일인에게 속하였다가 매매 기타 원인으로 소유자를 달리하게 된 경우 건물소유자에게 법정지상권이 인정된다.
⇒ ○ : 이러한 경우 관습법상의 법정지상권이 성립한다.
3. 지역권은 특정한 사람의 이익을 위하여 다른 사람의 토지를 이용하는 용익물권이다.
⇒ × : 지역권은 특정한 토지의 편익을 위해 다른 사람의 토지를 이용하는 권리이다.

♣ 강의교안

VII. 특수 지상권

1. 구분지상권(제289조의 2)

(1) 의의

- 상하 범위를 정한 지하 또는 지상의 공간을 대상으로 하는 지상권 → 토지이용의 입체화

(2) 설정 : 합의 + 등기

- 객체 : 목적 토지의 어떤 층 → 층을 특정해서 등기해야
- 기존 용역권자의 승낙 : 제289조의 2 제2항
 - 보통의 용역권은 토지의 상하에 미침 ← 구분지상권의 설정은 그 이용에 영향을 미침 → 용역권자 전원의 승낙 필요
 - 대상인 용역권 : 대항력이 있는 권리이어야

(3) 효력

- 원칙 : 지상권에 관한 규정에 따름
- 특칙 : 소유자의 사용제한 특약 가능 → 등기하면 제3자에게 대항 가능
 - 기존의 용역권 방해 금지
 - 지상권자 사이 상린관계 준용
 - 구분지상권자가 부속시킨 공작물은 토지에 부합 안됨
- 지료 : 합의 또는 법원의 결정에 의하여 정해짐

2. 분묘기지권

(1) 의의

- 타인의 토지에 분묘를 설치한 자가 갖는, 관습에 의하여 인정되는 지상권 유사의 토지 이용권 → 분묘를 수호하고 봉제사하는 목적을 달성하는 필요한 범위 내에서 타인의 토지 사용
 - 분묘 → 사체 또는 유골을 매장하는 시설을 말함
- 장사 등에 관한 법률의 시행으로 시효취득할 수 없는 등 많은 제한

(2) 발생

(가) 소유자의 승낙을 얻어(계약 의미) 분묘 설치

- 등기 불요
- 합의 내용이 불확실하거나 정해지지 않은 때 의미 있음

(나) 시효취득

- 20년간 평온·공연하게 분묘를 점유한 경우 ← 시효취득의 한 예
- 장사법 이후의 분묘기지권의 시효취득은 2001년 이후로 불가

(다) 분묘이전 특약 없는 토지소유권 이전

- 자기 토지 위해 분묘 설치 후 토지 매매한 경우

* 등기의 문제 : 관습법상 물권의 하나로 공시방법도 그에 따름 → 제187조의 경우에 해당

(3) 효력 및 존속기간

- 대법원 1994.8.26. 선고 94다28970 판결

· 분묘를 소유하기 위한 이용권 : 분묘수호 및 봉사 목적의 범위 내에서 이용 가능

· 분묘의 소유가 계속되는 동안 존속

3. 관습법상 법정지상권

(1) 법정지상권의 의의

- 동일인 소유의 토지 및 건물의 소유자 변경으로 인하여 건물의 소유를 위한 토지이용권 필요시 → 토지와 건물을 각각 독립한 부동산으로 하고 있는 우리 법제의 특수성에 따라 필요성이 인정

- 성문법으로 규율되는 법정지상권 : 제305조(건물의 전세권과 법정지상권), 제366조(저당권 실행시 법정지상권), 가담법 제10조, 입목법 제6조

(2) 요건

(가) 동일인 소유의 토지와 건물의 존재

- 타인의 토지 위에 지은 건물의 매각 → 건물 매수인의 지상권 취득 불가

- 토지와 미등기 건물의 일괄양도시 매도인의 관습법상 법정지상권 인정 안됨(대법원 2002.6.20. 선고 2002다9660 전원합의체 판결)

[판례] 대법원 2002.06.20. 선고 2002다9660 전원합의체 판결[건물등철거]

[1] 민법 제366조의 법정지상권은 저당권 설정 당시에 동일인의 소유에 속하는 토지와 건물이 저당권의 실행에 의한 경매로 인하여 각기 다른 사람의 소유에 속하게 된 경우에 건물의 소유를 위하여 인정되는 것이므로, 미등기건물을 그 대지와 함께 매수한 사람이 그 대지에 관하여만 소유권이전등기를 넘겨받고 건물에 대하여는 그 등기를 이전 받지 못하고 있다가, 대지에 대하여 저당권을 설정하고 그 저당권의 실행으로 대지가 경매되어 다른 사람의 소유로 된 경우에는, 그 저당권의 설정 당시에 이미 대지와 건물이 각각 다른 사람의 소유에 속하고 있었으므로 법정지상권이 성립될 여지가 없다.

[2] 관습상의 법정지상권은 동일인의 소유이던 토지와 그 지상건물이 매매 기타 원인으로 인하여 각각 소유자를 달리하게 되었으나 그 건물을 철거한다는 등의 특약이 없으면 건물 소유자로 하여금 토지를 계속 사용하게 하려는 것이 당사자의 의사라고 보아 인정되는 것이므로 토지의 점유·사용에 관하여 당사자 사이에 약정이 있는 것으로 볼 수 있거나 토지 소유자가 건물의 처분권까지 함께 취득한 경우에는 관습상의 법정지상권을 인정할 까닭이 없다 할 것이어서, 미등기건물을 그 대지와 함께 매도하였다면 비록 매수인에게 그 대지에 관하여만 소유권이전등기가 경료되고 건물에 관하여는 등기가 경료되지 아니하여 형식적으로 대지와 건물이 그 소유 명의자를 달리하게 되었다 하더라도 매도인에게 관습상의 법정지상권을 인정할 이유가 없다.

- 토지와 건물 중 어느 하나가 '처분될 당시'에 토지와 그 지상건물이 동일인의 소유면 충분하며, 반드시 원시적으로 동일인의 소유였을 필요는 없음(대법원 1995.7.28. 선고 95다 9075,9082 판결)

- 주의 : 건물에 대한 압류 또는 가압류가 있는 경우의 토지와 건물이 동일인 소유 여부에 대한 판단 시점에 대한 최근 전원합의체 판결 : 대법원 2012.10.18. 선고 2010다52140 전합판결

▶ 돌발 퀴즈

강제경매의 목적이 된 토지 또는 그 지상 건물의 소유권이 강제경매로 인하여 그 절차상의 매수인에게 이전된 경우에 건물의 소유를 위한 관습상 법정지상권의 성립에 있어서 토지와 건물이 동일인에게 속하였는지 여부는 매수인이 매각대금을 완납한 때를 기준으로 판단한다.

⇒ × : 압류의 효력이 발생한 때를 기준으로 한다.

[판 례] 대법원 2012.10.18. 선고 2010다52140 전원합의체 판결

“강제경매의 목적이 된 토지 또는 그 지상 건물의 소유권이 강제경매로 인하여 그 절차상의 매수인에게 이전된 경우에 건물의 소유를 위한 관습상 법정지상권이 성립하는가 하는 문제에 있어서는 그 매수인이 소유권을 취득하는 매각대금의 완납시가 아니라 그 압류의 효력이 발생하는 때를 기준으로 하여 토지와 그 지상 건물이 동일인에 속하였는지가 판단되어야 한다.”

⇒ 따라서 건물을 경락받은 자가 법정지상권을 취득하기 위한 요건의 판단시점은 경락시점이 아닌 압류시점 즉 건물 가압류 신청이 있었던 2003.10.이며 이 시점 당시 A는 토지와 건물의 소유권을 취득하지 않았으므로, 건물을 경락받은 자의 법정지상권은 성립하지 않는 것으로 판단함

(이 판결로 인해 건물 매수인이 대금을 완납한 때를 기준으로 판단해야 한다는 기존 판례는 변경)

따라서 판례변경 전에는 강제경매절차에서의 건물 매수인은 (경매에서) 매수 당시에 건물과 토지가 동일인에게 속하였는지만 확인하면 됐는데, 이 판례로 인해 가압류시의 건물과 토지가 동일인 소유인지를 확인하지 않으면 건물을 매수하고도 건물이 철거되는 손해를 입을 수도 있게 됨

(나) 매매 등의 원인에 의한 소유자의 변동

- 토지 또는 건물 매매 여부 불문
- 소유자 변동원인 : 매매, 증여, 국세징수법상의 공매, 민사집행법상의 강제경매에 따른 소유권이전등기가 있을 때

(다) 토지 이용 또는 철거특약이 없을 것

- 그러한 특약이 없을 때에는, 토지와 건물의 소유자가 달라진 후에도 건물소유자로 하여금 그 건물의 소유를 위해 계속 토지를 사용하게 하려는 목시적 합의가 정당화된다고 하여, 철거특약을 소극적으로 해석(판례)

* 이 점에서 2013 법무부 민법개정위원회는 관습상의 법정지상권을 폐지하고, 일정한 제한 하에 법정지상권이나 법정임대차 규정을 마련하기로 입법안 제시함

(라) 등기 불필요

- 토지 소유권 양도시 등기 없이 양수인에게 대항 가능 : 대법원 1988.9.27. 선고 87다카279 판결
- 이 지상권 처분시는 먼저 설정등기 해야(제187조 단서)

(3) 내용

- 보통의 지상권과 같음
- 존속기간 : 약정 없는 경우에 해당
- 범위 : 증축물에도 미침(대법원 1995.7.28. 선고 95다9075,9082 판결)

제4절 지역권

I. 개관

1. 지역권의 의의

- 설정행위에서 정한 일정한 목적을 위하여, 타인의 토지를 자기 토지의 편익에 이용할 수 있는 부동산용익물권(제291조)
- 要役地(편익을 제공받는 토지) ↔ 承役地(편익을 제공하는 토지)

2. 지역권의 특징

- 지역권과 임차권 → 물권과 채권이라는 본질적인 차이
- 지역권과 상린관계
 - 지역권 - 설정행위에 의하여 성립하는 독립한 물권으로서, 넓게 두 개의 토지 사이의 이용의 범위를 포함
 - 상린관계 - 소유권의 내용으로서 법률이 규정하는 바에 따라서, 인접하는 토지 사이의 최소한의 이용을 조달하기 위하여 인정됨

3. 지역권의 법적 성질

(1) 자기 토지의 편익을 위한 타인토지의 이용

- 반드시 두 개의 토지의 존재를 전제
- 요역지에 거주하는 사람의 개인적 이익을 위해서는 지역권 설정 × = 인역권 ×
 - 요역지의 편익에 이용 : 요역지의 사용가치를 증가시키는 것
 - 편익의 종류 : 제한 ×
- 승역지의 소유자 : 그 승역지가 요역지의 편익에 제공되는 범위에서 일정한 의무 부담
 - 지역권자의 적극적인 행위를 인용 → 승역지의 일정한 이용을 하지 않을 의무
 - 지역권은 그 내용으로서 승역지의 소유자에 대하여 일정한 행위를 하여야 할 적극적인 의무를 부담시킬 수도 있음 → 승역지의 소유자로 하여금 지역권의 행사에 필요한 공작물의 설치 또는 수선과 같은 부수적인 행위를 하도록 하는 의무를 지역권의 내용으로 할 수 있으며, 민법은 승역지 소유자가 그러한 의무를 부담하는 경우를 예정(제298조)
- 지역권은 유상이거나 무상이거나 상관없음(통설) → 유상의 약정에 관해서는 등기할 길이 없기 때문에(부동산등기법 70조), 제3자에게 대항할 수 없음

(2) 요역지 용익권자의 지역권 행사

- 요역지 위에 지상권, 전세권, 임차권을 취득한 자는 당연히 지역권을 행사할 수 있음(제292조 제1항 본문)
- 승역지의 지상권자, 전세권자, 임차인 → 지역권에 의하여 그의 권리가 제한됨
 - 지상권자, 전세권자, 임차인이 그들이 이용하는 그 토지 위에 지역권을 설정할 수 있는가 → 긍정적으로 해석함이 다수설
- 토지의 일부를 위해서 또는 토지의 일부 위에 지역권을 설정할 수 있는가?
 - 요역지 : 1필의 토지 → 토지의 일부를 위한 지역권 ×
 - 승역지 : 1필의 토지 일부 위에도 지역권 성립(제293조 제2항 단서)

(3) 지역권의 부종성

- 지역권은 요역지의 소유권의 내용이 아니며 그것으로부터 독립된 권리이지만, 요역지 소유권으로부터 분리되어 존재할 수 없고, 그에 종된 권리로서 결합
 - 지역권은 요역지 소유권에 대하여 수반성을 가짐 → 지역권의 이전만을 목적으로 하는 특별한 의사표시(물권행위) 필요 ×
- 소유권 이외의 이용권을 위하여 지역권을 설정한 경우 : 이용권에 수반
- 지역권은 수반성이 있기 때문에, 요역지 소유권으로부터 분리하여 양도하거나 또는 다른 권리의 목적으로 하지 못함(제292조 제2항)

(4) 지역권의 불가분성

- 토지공유자 1인은 그의 지분에 관하여, 그 토지를 위한 지역권 또는 그 토지가 부담하고 있는 지역권을 소멸하게 하지 못함(제293조 제1항)
- 요역지 또는 승역지가 분할되거나 일부 양도된 경우에는, 지역권은 요역지의 각 부분을 위하여 또는 승역지의 각 부분 위에 존속(제293조 제2항 본문)
 - 지역권의 성질상 토지의 일부분만에 관한 것인 경우에는, 그 일부분에 관해서만 존속(제293조 제2항 단서)
- 공유자의 1인이 지역권을 취득하는 경우 → 다른 공유자도 지역권 취득(제295조 제1항)
- 점유에 의한 지역권의 취득시효의 중단은 지역권을 사실상 행사하고 있는 각 공유자에 대하여 하지 않으면 그 효력이 없음(제295조 제2항)
- 요역지를 공유하고 있는 경우에, 공유자 1인을 위한 소멸시효의 중단 또는 정지가 있는 경우에는, 그 중단 또는 정지의 사유는 다른 공유자를 위해서도 효력이 있음(제296조)

4. 지역권의 존속기간

- 지역권의 존속기간(규정 ×) → 지역권의 설정행위에 의하여 결정할 수 있음
- 지역권의 존속기간을 영구무한으로 약정할 수 있는가? → 영구무한의 존속기간을 약정할 수 있는 것으로 해석(통설)
- 당사자가 지역권의 존속기간을 약정하고, 그것을 등기하면 제3자에게 대항할 수 있음

5. 지역권의 종류

(1) 작위지역권과 부작위지역권(적극지역권과 소극지역권)

- 작위지역권 : 지역권자가 일정한 행위를 할 수 있고, 승역지 이용자가 이를 인용해야 할 의무를 부담하는 내용의 지역권

- 승역지 이용자가 지역권자를 위해서 일정한 작위의무를 이행하여야 하는 지역권
- 통행지역권, 인수지역권
- 부작위지역권 : 승역지이용자가 일정한 이용을 하지 않을 의무를 부담하는 지역권 → 예) 전망지역권

(2) 계속지역권과 불계속지역권

- 계속지역권 : 지역권의 내용의 실현이, 일정한 시설을 설치하는 것을 내용으로 하는 지역권이나, 부작위지역권과 같이 계속되는 지역권
- 불계속지역권 : 지역권의 내용을 실현함에 있어서, 그때그때마다 권리자의 행위를 요하는 지역권
- 구별실익 → 계속지역권만이 취득시효의 대상이 됨(제294조)

(3) 표현지역권과 불표현지역권

- 표현지역권 : 지역권의 내용의 실현이 외부로부터 인식될 수 있는 외형적 사실을 수반하는 경우 → 통행지역권, 노출된 도관에 의한 인수지역권
- 불표현지역권 : 외형적 사실을 수반하지 않는 경우 → 부작위지역권, 지하인수지역권
- 구별실익 : 표현지역권만이 취득시효의 대상이 됨(제294조)

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 구분지상권의 객체를 특정하기 위하여 토지의 상하의 범위를 등기할 것이 요구된다.
- ② 분묘기지권은 분묘를 설치할 때 토지소유자의 승낙을 얻지 못한 경우에도 인정된다.
- ③ 분묘기지권은 이미 설치되어 있는 분묘를 수호하고 봉제사하는 데 필요한 범위 내에서만 인정된다.
- ④ 토지와 지상 건물이 동일인에게 속하였으나 그 소유권 귀속이 원인무효로 이루어졌다가 그 원인무효를 원인무효를 이유로 건물과 토지의 소유자가 달라졌다면 관습법상의 법정지상권이 성립하지 않는다.
- ⑤ 미등기나 무허가의 건물이더라도 그 건물을 원시취득한 경우라면 관습법상의 법정지상권이 성립한다.

⇒ ② 분묘기지권은 분묘 설치 당시 토지소유자의 승낙을 얻은 경우라야 인정된다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 원소유자로부터 대지와 건물이 한 사람에게 매도되었으나 대지에 관한 소유권이전등기만 경료되고 건물의 소유명의가 매도인 앞으로 남아 있어 형식적으로 대지와 건물이 그 소유명의자를 달리하게 된 경우 관습법상의 법정지상권이 성립하지 않는다.
- ② 공유자 중 1인이 지분 과반수의 동의에 의하여 공유지에 건물을 신축한 후 경매를 통하여 공유지가 분할됨에 따라 토지와 건물의 소유자가 달라진 경우 관습법상의 법정지상권이 성립하지 않는다.

- ③ 타인의 토지 위에 토지소유자의 승낙을 얻어 신축한 건물을 매수·취득한 경우 법정지상권이 성립하지 않는다.
- ④ 원래 채권을 담보하기 위하여 나대지상에 가등기가 경료되었고, 그 뒤 대지소유자가 그 지상에 건물을 신축하였는데, 그 후 가등기에 기한 본등기가 경료되어 대지와 건물의 소유자가 달라진 경우 관습법상의 법정지상권이 성립하지 않는다.
- ⑤ 관습법상의 법정지상권의 성립 및 존속에 관한 등기를 요하지 않으므로 이를 양도하는 경우에도 등기를 요하지 않는다.

⇒ ⑤. 제187조에 따라 관습법상의 법정지상권을 양도하는 경우에는 등기를 해야 한다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 편익을 제공받는 토지를 요역지, 편익을 제공하는 토지를 승역지라 한다.
- ② 요역지 위에 지상권, 전세권, 임차권을 취득한 자도 당해 지역권을 행사할 수 있다.
- ③ 요역지의 소유권이 이전되면 지역권도 수반하여 이전한다.
- ④ 점유에 의한 지역권의 취득시효의 중단은 지역권을 사실상 행사하고 있는 공유자 중 일부에게 하여도 그 효력이 있다.
- ⑤ 계속되고 표현된 지역권만이 취득시효의 대상이 된다.

⇒ ④. 점유에 의한 지역권의 취득시효의 중단은 지역권을 사실상 행사하고 있는 각 공유자에게 하여야 그 효력이 있다.

♣ 학습정리

1. 구분지상권이란 건물 기타 공작물을 소유하기 위하여 타인 소유 토지의 지하 또는 지하의 공간을 그 상하의 범위를 정하여 사용하는 지상권을 말한다.
2. 분묘기지권이란 타인의 토지 위에 분묘를 소유하기 위하여 분묘의 기지부분의 토지를 사용할 것을 내용으로 하는 지상권 유사한 관습상 물권이다.
3. 관습법상의 법정지상권이란 토지와 그 지상의 건물이 동일인에게 속하였다가 매매 기타 원인으로 각각 그 소유자를 달리하게 된 경우 건물철거특약이 없는 한 건물소유자에게 인정되는 관습법상의 지상권이다.
4. 지역권이란 설정행위에서 정한 일정한 목적을 위하여 타인의 토지를 자기 토지의 편익에 이용하는 용익물권이다.

제29강 지역권 (2), 전세권 (1)

♣ 학습목표

1. 지역권의 취득과 효력 및 소멸에 대하여 정리할 수 있다.
2. 특수지역권의 의의와 법적 성질을 정리할 수 있다.
3. 전세권의 개념과 법적 성질을 체계적으로 정리할 수 있다.

♣ 학습내용

- 지역권의 취득시효
- 지역권에 기한 물권적 청구권
- 승역지 소유자의 의무
- 특수지역권의 효력
- 전세권의 개념과 법적 성질

♣ 사전 테스트

1. 지역권을 시효로 취득하기 위해서는 그 지역권이 계속되고 표현되어야 한다.
⇒ ○ : 판례는 요역지의 소유자가 타인의 토지를 20년간 통행하였다는 사실만으로는 부족하고, 요역지의 소유자가 승역지에 통로를 개설하여 사용하고 있는 객관적인 상태가 민법 제245조에 규정된 기간 계속한 사실이 있어야 한다고 본다.
2. 지역권은 일정한 범위에서 승역지를 직접 지배하기 때문에 물권적 청구권이 발생할 수 있다.
⇒ ○ : 그러나 지역권에서는 승역지를 점유할 권능이 없으므로 방해제거청구권과 방해예방청구권만이 인정될 뿐이고(제214조), 반환청구권은 인정되지 않는다.
3. 전세금을 지급하지 않는다는 특약은 전세권의 성립에 아무런 영향을 미치지 않는다.
⇒ × : 전세금의 지급은 전세권의 요소이다(제303조1항). 따라서 전세금을 지급하지 않는다는 특약을 하면 전세권은 성립하지 않는다.

♣ 강의교안

II. 지역권의 취득

1. 지역권 취득 일반

- 설정계약 + 등기 ⇒ 가장 일반적
- 시효취득, 유언, 양도, 상속 등
- 민법 제187조 단서 적용 ×
 - 지역권은 부종성을 갖고 있기 때문에, 요역지의 소유권 또는 이용권이 이전되면 그에 수반해서 이전
 - 요역지 소유권 또는 이용권이 계속적으로 이전되어도, 지역권의 이전등기의 필요 없음

2. 지역권의 시효취득

- 계속되고 표현된 것에 한해서 시효취득 가능(제294조) → 제245조 준용
 - 불계속 또는 불표현의 지역권 ⇒ 시효취득 대상 × → 요역지의 소유자가 승역지를 일상적으로 사용하고 있다는 객관적 상태가 제245조에 의하는 기간(20년) 동안 계속된 사실이 있어야 함(대법원 1979.4.10. 선고 78다2482 판결)
- 공유자 중 1인이 지역권을 시효취득하면 → 공유자 전원을 위하여 지역권 취득(제295조 제1항)

III. 지역권의 효력

1. 지역권의 내용(지역권자의 권능)

- 설정행위(제291조)에 따름
 - 시효취득의 경우 ⇒ 시효취득의 기초가 된 점유에 의하여 그 목적의 범위가 결정
- 지역권의 목적을 달성하기 위하여 필요하고, 또 승역지 사용자에게 손해가 가장 적은 범위 → 지역권의 기능은 수개의 토지간의 이용을 조절하는데 있기 때문
 - 용수지역권 - 승역지의 수량이 요역지와 승역지의 수요에 부족한 경우에는, 그 수요의 정도에 따라서, 먼저 家用에 공급하고, 그 나머지를 다른 용도에 공급(제297조 제1항 본문) → 설정행위에 의하여 다른 사용방법을 정할 수 있음(제297조 제1항 단서) ← 등기하여야 제3자에게 대항 가능
 - 승역지 소유자는 지역권의 행사를 방해하지 않는 범위 내에서, 지역권자가 지역권의 행사를 위하여 승역지에 설치한 공작물을 사용할 수 있음(제300조 제1항)
 - 수익의 정도의 비율로 공작물의 설치·보존의 비용을 부담(제300조 제2항)
- 지역권의 배타성
 - 먼저 설정된 지역권이 나중 설정된 지역권에 우선
 - 자의적으로 승역지 위에 수개의 용수지역권이 설정된 경우에는, 후순위의 지역권자는 선순위의 지역권자를 방해하지 못함(제297조 제2항)

2. 지역권에 기한 물건적 청구권

- 지역권도 물건이므로 물건적 청구권 인정
- 반환청구권 ×

- 지역권에는 승역지를 점유할 권능이 없음 → 방해제거청구권, 방해예방청구권만 인정(제301조, 제214조)

3. 승역지 소유자의 의무

(1) 기본적 의무

- 지역권자의 행위 인용 + 일정한 이용을 하지 않아야 할 부작위의무
- 승역지 소유자가 설치한 설비를 이용할 권리를 지역권자가 가지는 경우에는, 승역지 소유자는 이를 함부로 변경해서는 아니할 의무 부담

(2) 부수적 의무

- 계약으로 승역지 소유자가 자기의 비용으로 지역권의 행사를 위하여 공작물의 설치 또는 수선의 의무를 부담하는 경우에는, 승역지 소유자의 특별승계인도 그 의무를 부담(제298조)
 - 특별승계인에 대하여 대항하기 위해서는 등기를 하여야 함
 - 승역지 소유자의 이 의무는 승역지를 이용하는 이익에 비하여 그 정도를 넘어서는 안 됨
- 委棄(위기)에 의한 부담면제
 - 승역지소유자는 지역권에 필요한 부분의 토지소유권을 지역권자에게 위기할 수 있음(제299조)
 - 委棄 - 토지소유권을 지역권자에게 이전한다는 일방적 의사표시
 - ▷ 지역권자에 대하여 하고, 물권적 단독행위이기 때문에 등기하여야 효력 발생
 - ▷ 위기로 인하여 소유권이 지역권자에게 이전하는 경우에는, 지역권은 혼동으로 소멸

IV. 지역권의 소멸

1. 소멸사유 일반

- 요역지 또는 승역지의 멸실, 지역권자의 포기, 혼동, 존속기간의 만료, 약정소멸 사유의 발생, 승역지의 수용(토지수용법 제67조), 승역지의 시효취득, 지역권의 소멸시효 등

2. 승역지의 시효취득에 의한 소멸

- 승역지가 제3자에 의하여 시효취득되는 경우 → 시효취득은 원시취득이므로 원칙적으로 지역권 소멸
- 예외
 - 승역지의 점유자가 지역권의 존재를 인용하면서 점유를 계속한 때
 - 승역지의 점유자의 취득시효가 진행하고 있는 동안에 지역권자가 그의 권리를 행사하면 시효취득의 기초인 점유는 지역권의 제한을 받는 것이므로 승역지가 시효취득되어도 지역권은 소멸하지 않음

3. 지역권의 시효소멸

- 20년간 행사하지 않음으로써 소멸(제162조 제2항)
- 기산점 : 불계속지역권(최후행사시), 계속지역권(그 행사를 방해하는 사실의 발생시)
- 요역지가 공유인 경우 → 소멸시효는 모든 공유자에 관하여 완성한 때에만 효력발생(제296조)

- 지역권자가 내용의 일부만을 행사하는 경우 → 불행사의 부분에 관해서만 지역권 소멸(4미터의 통로를 개설할 수 있는데도 불구하고, 2미터의 통로만을 개설한 경우)

V. 특수지역권

1. 특수지역권의 의의

- 어느 지역의 주민이 집합체의 관계로, 각자가 타인의 토지(주로 산림이나 초원)에서 초목, 야생물 및 토사의 채취, 방목 기타의 수익을 하는 권리(제302조) ← 인역권의 일종
- 일정한 주민이 공동체로서 타인의 토지에 수익할 수 있는 권리 → 총유적 토지수익권

2. 특수지역권의 모습

- 목적토지의 소유권이 수익을 하는 어느 지역의 주민 전체의 총유에 속하는 형태
 - 지역주민의 수익권 → 토지소유권의 수익권능 행사
 - 토지소유권의 총유이므로, 특수지역권으로 논할 성질의 권리가 아님
- 목적토지의 소유권이 수익을 하는 일정지역의 주민의 총유에 속하지 않고, 타인의 소유에 속하는 형태
 - 그 수익권이 타인의 소유토지에 존재하기 때문에 일종의 제한물권의 성질
 - 제302조가 규정하는 특수지역권 → 지역주민이 전체로서 목적토지를 소유하지 않는 경우

3. 특수지역권의 법적 성질

- 토지수익권으로서 제한물권
- 인역권의 일종
 - 편익을 받는 것은 토지가 아니라 일정한 지역주민 → 양도성·상속성 ×
- 토지수익권의 준총유 : 특수지역권의 주체
- 주로 관습에 의해서 성립하는 권리 → 법률행위에 의해서도 성립

4. 특수지역권의 효력

(1) 특수지역권의 적용법리

- 관습 → 총유에 관한 규정 준용, 지역권에 관한 규정 유추적용

(2) 토지수익권

- 지역주민은 공동으로 각자의 편익을 위하여 목적 토지 사용 → 초목, 야생물, 토사의 채취, 방목 등
- 대가 : 지역주민이 총유적으로 부담

(3) 토지수익권의 침해

- 지역주민의 일부가 그 권능의 행사를 넘어서 수익하거나, 그러한 수익으로 인하여 다른 주민의 권리행사를 방해한 경우
 - 주민 전체가 그 단체의 통제규범에 의하여, 불법한 행위의 정지 및 손해배상청구
 - 주민 각자도 그와 같은 청구 가능
- 제3자가 특수지역권을 침해하는 경우 → 주민단체도 침해행위의 배제를 청구할 수 있고, 침해를 받은 주민도 독립하여 같은 청구를 할 수 있음

(4) 특수지역권의 득실

- 취득 : 관습 또는 계약 → 계약에 의한 경우 등기를 하여야 효력발생
- 소멸
 - 목적토지의 멸실
 - 목적토지로부터의 수익불능
 - 지역주민 전체의 의사 또는 목적토지소유자와의 협의에 의하여 소멸
- 주민으로서의 지위의 득실 ⇒ 특수지역권도 당연히 취득 또는 소멸(양도성·상속성 ×)

제5절 전세권

I. 개관

1. 전세권의 의의

- 의의 : 전세금을 지급하고 타인의 부동산을 점유하여, 그 부동산의 용도에 좇아 사용·수익하며, 전세권이 소멸하면 그 부동산의 전부에 대하여 후순위권리자 기타 채권자보다 전세금의 우선변제를 받을 수 있는 특수한 용익물권(제303조 제1항) ⇒ 용익물권 + 담보물권
- 채권적 전세와 물권적 전세권

▶ 돌발 퀴즈

전세권은 일본 민법에서 유래된 것이다?

: ×

- 전세권은 종래 일종의 채권계약으로 관행되어온 「전세」라는 건물임대차를 물권의 일종으로 규정한 것이며, 1984년 민법개정에 의하여 전세금의 우선변제권을 인정하는 내용을 신설하였다. 따라서 전세권은 용익물권이지만, 전세금반환채권을 확보하기 위한 담보물권의 성질도 아울러 가지는 우리 민법상 특유한 제도이다.

2. 전세권의 법적 성질

(1) 전세권의 목적물

- 타인의 부동산에 대한 권리 - 부동산을 목적으로 하는 제한물권
- 농경지 ×
 - 농지법에 의하여 농지의 임대차가 허용되고 있으므로(농지법 제22조 내지 제29조), 민법 제303조 제2항의 해석에 있어서도, 농지에 대한 전세권은 농지의 임대차로서의 법률행위의 전환을 인정하여야 할 것
- 1필의 토지의 일부 또는 1동의 건물의 일부라도 가능 → 부동산의 일부를 전세권의 목적으로 하는 경우에는, 전세권을 등기할 때, 그 도면을 첨부(부동산등기법 제139조 제2항)

(2) 사용·수익권

- 타인의 부동산을 점유하여, 그 부동산의 용도에 좇아 사용·수익하는 권리 → 상린관계의 규정 준용(제319조)
- 토지를 목적으로 하는 토지전세권과 지상권과의 관계 : 건물 기타의 공작물이나 수목의 소유를 위하여, 지상권을 설정하지 않고, 전세권을 설정할 수 있는가? → 긍정설 다수임

(3) 전세금의 지급

(가) 전세권의 요소로 전세금(제303조 제1항)

- 전세금 : 전세권자가 전세권설정자에게 지급하는 금전 → 전세권이 소멸하는 때에는 다시 그 반환을 받음(제317조, 제310조) ← 목적부동산을 원물로 하는 법

정과실이 아님

- 다만 판례는 전세금의 지급은 전세권 성립의 요소가 되지만, 그것이 반드시 현실적으로 수수되어야 하는 것은 아니고 기존의 채권으로 전세금의 지급에 갈음할 수 있다고 함(대법원 1995.2.10. 선고 94다18590 판결)

→ 따라서 예컨대 A가 B에 대하여 1억의 공사대금채무를 부담하고 있는데, 이를 담보하기 위해서 A의 건물에 그 채무 1억을 전세금으로 삼기로 하고 B에게 전세권을 설정해 주기로 한 경우에 B를 위한 전세권 설정은 유효함

- 전세금액 : 등기된 금액에 한하여 제3자에게 대항
- 전세금을 지급하지 않는다는 특약 : 무효 → 전세금은 반드시 지급되어야 함

(나) 전세금의 성질과 기능

a) 부동산의 사용대가

: 차임 또는 지료의 특수한 지급방법으로서 지급되는 것

b) 보증금으로서의 성질

: 전세권자의 채무를 담보하기 위하여 교부되는 금전 - 보증금의 일종

c) 신용수수의 수단

: 부동산질권의 실질

(4) 용익물권

- 타인의 부동산의 사용·수익을 그 본체로 하는 용익물권 → 직접 그 객체인 토지나 건물을 지배하는 권리 → 물권으로서 양도성과 상속성(+)

(5) 담보물권성

- 우선변제권(제303조 제1항) + 경매청구권(제318조)
- 담보물권의 통유성
 - 부종성 : 전세권과 전세금
 - 수반성 : 전세금채권에 수반
 - 불가분성 : 전세금채권 전액에 관하여 목적물 전부 위에 효력을 미침
 - 물상대위성 : 본래의 전세목적물 뿐만 아니라, 그 대체물 위에도 효력

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 도자기공이 도자기를 만들기 위해 타인의 토지를 채취하고자 할 때, 그것을 지역권의 대상으로 할 수 있다.
- ② 민법은 지역권의 대가와 존속기간에 관해 규정을 두고 있지 않다.
- ③ 지역권은 요역지와 분리하여 양도하거나 다른 권리의 목적으로 하지 못한다.
- ④ 공유자의 1인이 지역권을 취득한 때에는 다른 공유자도 이를 취득한다.
- ⑤ 지역권에 있어서 토지의 이용목적에는 아무런 제한이 없다.

- ① 지역권은 토지자체의 편익을 위해서 설정된다(제295조, 제293조 참고).

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 주위토지통행권은 기존 통로가 토지용도에 필요한 통로로서의 기능을 다하지 못하는 경우에도 새로운 통행권이 인정된다.
- ② 건축법상 도로의 폭 등에 관하여 제한규정이 있다면 반사적 이익으로서 포위된 토지소유자에게 이와 일치하는 통행권이 인정된다.
- ③ 기존의 통로보다 더 편리하다는 이유만으로 다른 곳으로 통행할 권리를 갖는 것은 아니다.
- ④ 통행지 소유자는 통행권자의 허락을 얻어 사실상 통행하고 있는 자에게 손해의 보상을 청구할 수 없다.
- ⑤ 분할이나 토지의 일부양도로 포위된 토지의 특정승계인의 경우에는 주위토지통행권에 관한 일반원칙에 따라 그 통행권의 범위를 따로 정하여야 한다.

- ②. 판례는 건축법상 도로의 폭등에 반하여 제한규정이 있더라도 반사적 이익으로서 포위된 토지소유자에게 이와 일치하는 통행권이 인정되는 것은 아니라고 한다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 전세권은 저당권의 목적이 될 수 있다.
- ② 전세권의 존속기간은 10년을 넘지 못한다.
- ③ 전세권에 관하여는 상린관계의 규정이 준용된다.
- ④ 전세권은 타인의 건물에 대해서만 성립한다.
- ⑤ 전세권에 관하여는 우선변제권이 인정된다.
- ④. 전세권이란 전세금을 지불하고 타인의 부동산(토지·건물)을 점유하여 그 부동산의 용도에 좇아 사용·수익한 후 그 부동산을 반환하고 전세금의 반환을 받게 되는 용익물권이다. 이때의 부동산은 1필지의 토지 또는 1동의 건물의 일부라도 무방하다.

♣ 학습정리

1. 지역권은 요역지의 소유권 또는 사용권의 이전에 수반해서 이전된다(부종성).
2. 민법 제294조에서 지역권은 계속되고 표현된 것에 한하여 제245조의 규정을 준용한다고 규정하고 있으므로 요역지의 소유자가 승역지에 통로를 개설하여 그 통로를 사용하는 상태가 제254조에 규정된 기간 계속된 경우에 한하여 통행지역권의 시효취득을 인정할 수 있다(대판 2001.2.27, 2000다28728).
3. 물건적 전세권에는 목적물의 경매권과 우선변제권이 있으나(제318조), 임대차에서는 원칙적으로 이러한 권리가 없다. 다만 주택의 경우에는 주택임대차보호법에 의하여 보증금의 우선변제권(동법 제3조의 2 1항) 및 최우선변제권이 인정된다(동법 제8조).

제30강 전세권 (2)

♣ 학습목표

1. 전세권의 취득과 존속기간을 이해한다.
2. 전세권의 효력을 유형별로 정리한다.
3. 전세권의 소멸을 살펴본다.

♣ 학습내용

- 전세권의 취득과 존속기간
- 전세권자의 효력
- 전세권자의 우선변제권
- 전세권의 소멸사유

♣ 사전 테스트

1. 전세권의 법정갱신은 법률의 규정(제312조 4항)에 의한 부동산에 관한 물권의 변동이나 전세권갱신에 관한 등기를 필요로 한다.
⇒ × : 등기를 필요로 하지 않는다. 특히 전세권자는 그 등기 없이도 전세권설정자나 그 목적물을 취득한 제3자에 대하여 그 권리를 주장할 수 있다.
2. 전세권설정 당시에 이미 소유자가 다른 경우에는 별도로 법정지상권을 설정하여야 한다.
⇒ × : 이러한 경우에는 당사자 사이의 계약에 의하여 건물소유를 위한 대지이용권(지상권·임차권)이 이미 설정되어 있는 것이 보통이므로 법정지상권을 별도로 인정할 필요가 없게 된다.
3. 전세권자는 원칙적으로 제3자에게 그 목적물을 양도하거나 임대할 수 없다.
⇒ × : 전세권자는 설정행위로 금지되어 있지 않는 한 전세권의 존속기간 내에서 轉傳貰 또는 임대할 수 있다(제306조).

♣ 강의교안

II. 전세권의 취득과 존속기간

1. 설정계약에 의한 취득

- 전세권의 성립 = 전세권 설정에 관한 물권적 합의 + 등기 + 전세금의 지급
- 전세권의 객체
 - 부동산
 - 1필의 토지 또는 1동의 건물의 일부 ⇒ 등기신청시 그 도면 첨부(부동산등기법 제139조 제2항)
- 목적부동산의 인도 → 전세권의 성립요건은 아님
- 전세권 성립 후에도 목적부동산의 인도가 없으면, 전세권자는 전세권에 기한 반환청구권을 행사하여 인도 청구
- 전세권자와 전세권설정자 및 제3자 사이에 합의가 있을 때에 전세권자 명의를 그 제3자에게 하는 것도 가능 : 대법원 1998.9.4. 선고 98다20981 판결

2. 전세권의 존속기간

(1) 설정행위로서 정하는 경우

(가) 토지전세권의 존속기간

- 최장기간의 제한 → 10년
- 10년을 넘는 경우 10년으로 단축(제312조 제1항)
- 존속기간 : 등기하여야 제3자에게 대항 → 존속기간의 등기가 없으면 존속기간의 약정이 없는 것으로 다루어짐
- 약정갱신 : 존속기간을 갱신한 날로부터 10년을 넘지 못함(제312조 제3항) → 당사자 사이의 합의

(나) 건물전세권의 존속기간

- 최장기간 : 10년 → 10년을 넘지 못함
- 최단기간 : 1년, 1년 미만으로 정한 때에는 1년으로 함(제312조 제2항)
- 존속기간의 등기 → 등기하지 않으면 존속기간의 약정이 없는 전세권으로 다룸
- 약정갱신 - 10년을 넘지 못함
- 법정갱신 인정(제312조 제4항 후문)

(2) 설정행위로서 정하지 않은 경우

- 소멸통고 : 각 당사자는 언제든지 상대방에 대하여 전세권의 소멸을 통고할 수 있고, 상대방이 이 통고를 받은 날로부터 6개월이 경과하면 전세권 소멸(제313조) → 소멸통고의 성질(물권적 단독행위 ← 통설)
- 법정갱신에 의한 전세권의 존속기간의 연장의 경우 : 전세권의 소멸통고에 관한 제313조의 규정이 그대로 적용

3. 전세권의 법정갱신

(1) 법정갱신의 의의

· 건물의 전세권설정자가 전세기간 만료 전 6월부터 1월 사이에 전세권자에 대하여 갱신거절의 통지 또는 조건을 변경하지 않으면 갱신하지 아니한다는 뜻의 통지를 하지 아니한 경우에는, 그 기간이 만료된 때에 전 전세권과 동일한 조건으로 다시 전세권을 설정한 것으로 본다(제312조 제4항)

- 전세권자의 지위를 강화하여 전세권자의 부동산이용권 강화 → 법정의 제한된 기간 내에, 전세권 설정계약의 갱신거절 또는 조건변경의 통지가 없는 경우에는 법률상 당연히 종전의 전세권이 계속하여 존속하는 것으로 함

(2) 법정갱신의 성립과 효과

- 건물전세권 약정(합의)갱신이 없는 경우 → 전세권설정자가 갱신거절 또는 조건변경에 관한 통지를 전세권의 존속기간의 만료일로부터 소급하여 6월부터 1월 사이에 하지 않을 것 ← 등기
- × · 법률의 규정에 의한 물권변동(전세권의 기간변경)(제187조)
- 전 전세권의 내용과 동일한 전세권이 설정된 것으로 봄(제312조 제4항 전문)
- 전세기간 - 정함이 없는 것으로 다루어짐(제312조 제4항 후문)
- 각 당사자는 언제든지 전세권의 소멸을 통고할 수 있고, 그 통고가 있을 후 6개월이 경과하면 전세권 소멸(제313조)

III. 전세권의 효력

1. 전세권의 효력이 미치는 범위

- 건물 전세권의 효력은 그 토지 위의 지상권 또는 임차권에 미친다고 규정(제304조)
- 전세권의 목적인 건물의 소유자와 그 대지의 소유자가 다르게 되는 경우에, 지상권의 성립을 인정(제305조) : 법정지상권

(1) 건물전세권의 지상권, 토지임차권에 대한 효력

- 타인의 토지 위에 건물을 소유하는 자가 그 건물에 전세권을 설정한 때에는, 그 전세권의 효력은 그 건물의 소유를 목적으로 하는 지상권 또는 토지임차권에도 미침(제304조 제1항)
- 건물전세권설정자는 건물전세권자의 동의 없이, 지상권 또는 임차권을 소멸하게 하는 행위를 하지 못함(제304조 제2항)
- 건물소유권과 대지이용권은 불가분의 관계 → 건물전세권자의 동의가 있는 경우에는 가능

(2) 법정지상권

- 대지와 건물이 동일한 소유자에게 속하는 경우에, 그 중 건물 만에 대하여 전세권을 설정한 때에는, 그 대지소유권의 특별승계인은 전세권설정자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 봄(제305조 제1항 본문)
- 건물사용자의 토지이용을 법적으로 현실화하기 위함 ⇒ 토지만 매매되어 건물과 대지소유자가 각각 다른 사람으로 된 때에는, 대지에 대해 잠재적으로 존재하던 건물전세권자의 대지사용관계를 하나의 권리로서 현실화시킬 필요
- 건물소유자가 지상권 또는 임차권을 취득한 경우에는 전세권의 효력이 이에 미침(제304조 제1항 - 제305조 적용 ×

- 대지소유권에는 변동이 없으나 건물이 경매됨으로써, 토지와 건물의 소유자가 각각 다르게 된 경우 - 법정지상권 성립
 - 법정지상권을 취득하는 자 - 건물소유자
 - 등기 × (제187조)
- 법정지상권의 효과
 - 지료 : 당사자의 합의 → 합의가 성립되지 않는 경우, 당사자의 청구에 의하여 법원이 지료 결정(제305조 제1항 단서)
 - 법정지상권이 성립된 경우에는, 대지소유자는 타인에게 그 대지를 임대하거나, 그 대지를 목적으로 하는 지상권 또는 전세권을 설정하지 못함(제305조 제2항)

2. 상린관계규정의 준용

- 전세권 - 토지이용수반 → 전세권자와 인지전세권자 사이 또는 전세권자와 인지소유자 및 지상권자와의 사이에 준용(제319조)
 - 경계선 상에 설치된 경계표, 담, 구거에 관한 공유추정의 규정(제239조)은 전세권 설정 후에 전세권자가 설치한 것에 관해서만 준용

3. 전세권자의 점유권과 물권적 청구권

- 제319조 → 목적물반환청구권, 방해제거청구권, 방해예방청구권

4. 전세금증감청구권

- 전세권 성립 후 목적부동산에 관한 조세, 공과금 기타 부담의 증감이나 경제사정의 변동으로 전세금이 상당하지 않게 된 때에는, 당사자는 장래에 대하여 그 증감을 청구(제312조의 2 본문) → 사정변경의 원칙을 구체화
- 전세권설정자의 전세금증액청구
 - 전세권설정계약이 있는 날 또는 전세금의 증액이 있는 날로부터 1년 이내에는 증액청구 ×
 - 증액청구의 비율 ⇒ 현재의 전세금의 5%를 초과하지 못함(민법 제312조의 2 단서의 시행에 관한 규정)

5. 전세권자의 사용·수익권과 의무

(1) 전세권자의 목적물사용·수익권

- 전세권자는 목적부동산을 점유하여 그 부동산의 용도에 좇아 사용·수익할 권리가 있음(제303조 제1항) ← 용도에 좇아 → 경제적 효능에 따른다는 뜻
- 전세권자가 설정계약 또는 부동산의 성질에 의하여 정하여진 용도에 따라 사용·수익하지 않는 경우 ⇒ 전세권설정자 소멸청구 가능(제311조 제1항)
 - 형성권으로 이해
 - 말소등기를 하지 않더라도 소멸청구의 의사표시로 전세권 소멸
 - 전세권설정자는 그의 선택에 따라서 원상회복 또는 손해배상청구(제311조 제2항)

▶ 돌발 퀴즈

전세권설정자는 목적물의 현상 유지 및 통상의 관리에 속하는 수선을 할 의무를 부담한다.

: ×. 전세권자가 이러한 의무를 부담하고, 이 점에서 임대차관계와는 다르다.

(2) 전세권자의 현상유지·수선의무

- 전세권자는 목적물의 현상을 유지하고 그 통상의 관리에 속한 수선을 하여야 함(제309조)
- 현상의 유지 - 전세권의 존속 중, 목적물의 사용·수익에 필요한 상태를 유지
- 통상의 관리에 속한 수선 - 목적물의 통상의 유지에 필요한 한도 내에서 하는 수선
- 구체적으로 거래관념과 신의성실에 좇아 판단
- 전세권자가 현상유지의무를 위반하는 경우 ⇒ 목적부동산의 용도에 따르지 않는 사용·수익
- 전세권설정자는 그의 의무위반을 이유로 전세권의 소멸을 청구하고, 원상회복 또는 손해배상청구(제311조)
- 전세권자의 필요비상환청구 × ⇒ 전세권자가 수선의무 부담하므로
- 수선의무위반의 효과 - 수선을 소홀히 한 것만으로는 전세권소멸청구나 손해배상청구의 원인으로 하지 못할 것이나, 수선을 소홀히 함으로써 파손 또는 멸실 등의 사태가 발생한 경우에는 손해배상책임

6. 전세권의 처분

(1) 처분의 자유 및 제한

- 전세권자는 그의 전세권을 양도하거나 담보로 제공할 수 있고, 또한 그 존속기간 내에 그 목적물을 타인에게 전전세 또는 임대할 수 있음(제306조 본문)
- 처분의 자유 인정
- 전세권 = 물권 ⇒ 전세권의 존속기간 중에 전세권자의 경제적 사정으로, 그 투자자본을 회수할 수 있는 방법을 법률상 보장할 필요
- 당사자가 설정행위로서 그 처분을 금지할 수 있음(제306조 단서)
- 등기하여야만 제3자에게 대항

(2) 양도, 담보제공, 임대

(가) 전세권의 양도

- 전세권자는 전세권설정행위에서 금지되어 있지 않는 한, 전세권설정자의 동의없이 전세권을 자유로이 양도할 수 있음(제306조)
- 양도방법 - 양도의 합의 + 등기(제186조)
- 양도의 결과 양수인은 전세권설정자에 대하여, 전세권양도인(원래의 전세권자)과 동일한 권리·의무를 가짐(제307조)

(나) 전세권의 담보제공

- 설정행위에서 금지하고 있지 않는 한, 전세권자는 전세권설정자의 동의없이 전세권을 타인에게 담보로 제공할 수 있음(제306조) → 전세권을 목적으로 하여 저당권설정(제371조)

(다) 전세목적물의 임대

- 전세권자는 전세목적물을 임대할 수 있음(제306조 본문)
- 제한
- 전세권설정행위에서 금지되어 있지 않아야 함
- 임대기간은 전세권의 존속기간 내
- 전세목적물을 임대한 경우에 전세권자의 책임 가중
- 전세권자는 전세목적물을 임대하지 않았더라면, 면할 수 있었을 불가항력으로 인한 손

해에 대해서도, 전세권설정자에게 그 배상책임을 짐(제308조)

(3) 전전세

(가) 의의

- 전세권자가 전세권을 그대로 유지하면서, 그 전세부동산을 목적으로 하는 전세권을 설정하는 것

(나) 요건

- 물권적 합의 + 등기
- 설정행위에 의하여 전전세권의 설정을 금지할 수 있음(제306조 단서)
- 당사자 - 원전세권자(전전세권설정자)와 전전세권자
- 원전세권설정자 ×, 원전세권설정자의 동의 ×
- 전전세권의 존속기간 - 원전세권의 존속기간 내(제306조 본문)
- 전세금의 지급 : 원전세권의 범위 내(다수설)
- 원전세권의 일부를 목적으로 하는 전전세권도 유효

(다) 효과

- 원전세권 - 소멸하지 않음
- 원전세권자는 전전세권에 의하여 제한되는 한도에서, 스스로 목적부동산을 사용·수익하지 못함
- 전전세권자는 원전세권설정자에 대해서는 아무런 권리·의무도 가지지 않음
- 전세권자는 원전세권을 소멸시키는 행위를 하지 못함
- 전전세권을 해하지 않는 범위 안에서 처분행위를 하는 것은 상관없음
- 원전세권 소멸 ⇒ 전전세권 소멸
- 전전세권이 소멸한 경우
- 원전세권자의 전전세금 반환과 전전세권자의 목적부동산의 인도 및 전전세권설정등기의 말소등기에 필요한 서류의 교부 - 동시이행관계(제317조)
- 전전세금의 반환 지체 - 전전세권의 목적부동산의 경매 가능(제318조). 다만 원전세권도 소멸하고 있고, 또한 원전세권설정자가 원전세권자에 대하여, 원전세금의 전세금의 반환을 지체하고 있어야 함
- 전세권자는 전전세권을 설정하지 않았더라면 면할 수 있었던 불가항력으로 인한 손해에 대해서도 그 책임을 부담(제308조)

IV. 전세권자의 우선변제권(제303조)

- 전세권설정자가 전세금반환을 지체한 경우 민사집행법에 의하여 전세권의 목적물을 경매할 수 있음(민법 제318조)

- 후순위권리자 및 그밖의 채권자 보다 전세금을 우선변제 받을 수 있음(제303조 제1항)
- 전세권자는 일반채권자보다 언제나 우선
- 전세권과 지당권이 경합할 때

① 전세권이 먼저 설정되고 그 후 지당권이 설정된 때에는 전세권자가 경매신청하면 두 권리는 모두 소멸하고, 배당순위는 설정등기 선후에 따라 결정(민집 제145조). 그러나 나중에 설정된 지당권자가 경매신청한 때에는 전세권은 존속(민집 제91조 제3항)

② 지당권이 먼저 설정되고 나중에 전세권이 설정된 때에는 경매신청(지당권자, 전세권자 관계없음)이 있으면 두 권리는 모두 소멸하고 배당순위는 설정등기의 선순위에 따름

- 전세권 설정자의 파산 → 전세권자는 별제권을 가짐. 개인회생절차에서는 전세권은 회생담보권으로 취급

V. 전세권의 소멸

1. 전세권의 소멸사유

(1) 개설

- 물권일반에 공통하는 소멸사유 → 목적부동산의 멸실, 존속기간의 만료, 소멸시효, 혼동, 토지수용, 전세권에 우선하는 저당권의 실행으로 인한 경매 등
- 전세권에 특수한 소멸사유 → 전세권설정자의 소멸청구(제311조), 전세권의 소멸통고(제313조), 전세권의 포기(제371조 제2항) 등

(2) 전세권설정자의 소멸청구

- 전세권자가 전세권설정계약 또는 목적물의 성질에 의하여 정하여진 용법으로 사용·수익하지 않는 경우(제311조)
 - 설정행위로서 전세권의 양도, 담보제공, 전전세, 임대 등을 금지하고 있는데도 불구하고, 전세권자가 이에 위반하는 처분을 한 때
 - 전세권자가 전세목적물의 현상유지의무 또는 통상의 관리에 속하는 수선의무(제309조)를 다하지 아니한 때

(3) 전세권의 소멸통고

- 전세권의 존속기간을 약정하지 않은 경우, 각 당사자는 언제든지 상대방에 대하여 전세권의 소멸을 통고할 수 있고, 상대방이 이 통고를 받은 날로부터 6월이 경과하면 전세권 소멸(제313조)

(4) 목적부동산의 멸실

(가) 멸실의 태양

- 목적부동산의 전부멸실의 경우와 일부멸실의 경우
- 불가항력으로 인한 멸실의 경우와 전세권자의 귀책사유로 인한 멸실의 경우

(나) 전부멸실의 경우

- 전세권 소멸 → 손해배상책임에는 차이 있음
- 전세권자에게 책임있는 사유로 멸실한 경우 - 손해배상책임(제315조) → 전세권설정자는 전세금으로 그 손해배상에 충당하고, 나머지가 있으면 반환하여야 하나, 부족하면 그 부족액을 청구할 수 있음(제315조 제2항)
- 목적부동산이 불가항력으로 멸실한 경우 → 손해배상책임 ×, 전세금반환의 문제

(다) 일부멸실의 경우

- 멸실된 부분 - 전세권 존속 ×
- 잔존부분에 관하여 전세권이 존속하는가 또한 존속한다면 전세금은 감액되는가?

a) 잔존부분만으로 목적을 달성할 수 있는 경우

- 전세권자에게 귀책사유가 있는 경우
 - 전세권설정자가 목적부동산의 일부멸실을 초래한 전세권자에게 전세권을 존속시키는 것을 원하지 않는 경우 → 소멸청구 가능, 손해배상청구도 가능

- 전세권설정자가 소멸청구를 하지 않는 경우 - 전세권자가 소멸시킬 수는 없음(전세권설정자는 전세권소멸시기에 이르러야만, 손해배상청구)
- 전세권자에게 귀책사유가 없는 경우
 - 전세금감액 - 당사자간의 합의 → 합의가 성립되지 않는 경우 법원이 결정
- b) 잔존부분만으로 목적을 달성할 수 없는 경우
 - 불가항력의 사유로 인한 경우 - 전세권자는 소멸청구
 - 전세권자에게 귀책사유가 있는 경우 - 전세권자는 소멸청구 ↔ 전세권설정자는 손해배상청구

(5) 전세권의 포기

- 전세권자는 존속기간을 약정하고 있더라도 자유로이 전세권 포기 가능
- 전세권이 제3자의 권리의 목적인 때에는 포기할 수 없음(제371조 제2항)
- 포기의 의사표시와 말소등기를 하여야 소멸의 효력 발생

(6) 약정소멸사유

- 약정된 소멸사유 발생 : 전세권 소멸 → 등기하여야 소멸의 효력 발생

2. 전세권소멸의 효과

(1) 동시이행

- 전세권자 - 목적부동산인도, 전세권등기의 말소등기를 위해 필요한 서류 교부
↑↓ 동시이행의 관계
- 전세권설정자 - 전세금반환

(2) 전세권자의 경매청구권과 우선변제권

(3) 전세권자의 부속물수거권

- 전세권이 소멸하면 전세권자는 그 목적부동산을 원상으로 회복하여야 하고, 그 목적부동산에 부속시킨 물건을 수거할 수 있음(제316조 제1항 본문)
- 전세권설정자의 부속물매수청구권 행사 ⇒ 부속물수거권 ×

(4) 부속물매수청구권

(가) 개설

- 전세권이 소멸하는 때에 목적부동산에 부속시킨 물건 또는 지상물의 수거 → 가치 감소, 전세권자를 위해서나 또는 사회·경제상 불이익한 결과가 될 수도 있음
- 전세권설정자와 전세권자 양자에게 부속물매수청구권 인정

(나) 전세권설정자의 부속물매수청구권

- 전세권이 소멸한 경우 전세권설정자는 언제든지 부속물매수청구권을 행사할 수 있는 것이 원칙(제316조 제1항 단서)

- 부속물매수청구권의 성질 : 형성권

- 이 청구권의 행사 ⇒ 매매계약 성립(통설)

- 예외 : 전세권자에게 정당한 사유가 있는 경우, 전세권자는 전세권설정자의 매수청구권 거절 가능(제316조 제1항 단서)

(다) 전세권자의 부속물매수청구권

- 전세권설정자의 동의를 얻어서 부속시킨 때
- 그 부속물건을 전세권설정자로부터 매수한 것인 때
- 전세권자의 부속물매수청구권 : 형성권

(5) 유익비상환청구권

- 필요비 : 전세권자 부담(원칙) → 전세권자는 목적부동산의 현상을 유지하고, 통상의 관리에 속하는 수선을 하여야 할 의무(제309조)
- 유익비 : 그 가액의 증가가 현존하는 경우에 한하여, 소유자의 선택에 따라서, 그 지출액이나 증가액의 상환을 청구(제310조 제1항)
 - 상환기간의 허여 : 법원은 전세권설정자의 청구에 의하여 상당한 상환기간을 허여할 수 있음(제310조 제2항)

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 목적물의 일부가 불가항력으로 멸실되더라도 전세권에는 변동이 없다.
 - ② 존속기간의 약정이 없는 전세권의 경우에는 각 당사자는 언제든지 상대방에 대하여 그 소멸을 통고할 수 있다.
 - ③ 전세권자는 목적부동산을 점유·사용·수익할 권리가 있으며, 사용·수익방법에는 아무런 제한이 없다.
 - ④ 전세권은 물권이기 때문에 양도행위나 담보제공을 설정행위로써도 금지할 수 없다.
 - ⑤ 전세권에 있어서는 불가분성과 물상대위성은 배제된다.
- ②. 기간의 약정이 없는 전세권의 당사자는 언제라도 소멸을 통고할 수 있고, 소멸통고가 도달된 후 6개월이 경과되면 전세권은 소멸한다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 건물의 전세권자는 필요한 범위에서 대지 및 부근의 토지를 사용할 수 있다.
- ② 전세권자는 목적물을 점유하여 사용·수익할 수 있다.
- ③ 전세권자는 전세권을 양도하거나 담보로 제공할 수 있다.
- ④ 전세권자는 설정자의 동의를 얻지 아니하면 전전세를 할 수 없다.
- ⑤ 전세권자는 전세금감액청구권을 가진다.

- ④. 전세권은 처분의 자유가 인정되므로 양도·임대·전전세할 수 있다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 전세권자와 임차인은 목적물에 지출한 필요비와 유익비의 상환을 청구할 수 있다.
- ② 임차인은 전세권자와 마찬가지로 임대인의 동의를 얻어 부속시킨 부속물에 대하여 임대차 종료 후에 그 매수를 청구할 수 있다.
- ③ 임차인의 파산은 전세권과 달리 임대차 관계의 해지 통고 사유가 된다.
- ④ 전세권은 임차권과 달리 전세권자와 그 양수인 사이의 합의만으로 유효하게 양도될 수 있다.
- ⑤ 전세권과 부동산임차권 모두 최장 기간에 대한 제한을 두고 있다.

- ①. 전세권자는 목적물의 현상유지와 통상의 관리에 속한 수선의무가 있으므로 필요비의 상환청구는 할 수 없다(제309조).

♣ 학습정리

1. 건물의 전세권설정자가 전세기간 만료 전 6월부터 1월 사이에 전세권자에 대하여 갱신거절의 통지 또는 조건을 변경하지 않으면 갱신하지 아니한다는 뜻의 통지를 하지 아니한 경우에는 그 기간이 만료된 때에 전 전세권과 동일한 조건으로 다시 전세권을 설정한 것으로 본다.
2. 대지와 건물이 동일한 소유자에게 속하는 경우에 그 중 건물에 대하여만 전세권을 설정한 때에는 그 대지소유권의 특별승계인은 전세권설정자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다.
3. 전세권은 임차권과 달리 전세권자와 그 양수인 사이의 합의만으로 유효하게 양도될 수 있다.

제31강 담보물권 서설, 유치권 (1)

♣ 학습목표

1. 담보물권의 의의와 유형을 파악한다.
2. 담보물권의 본질 및 특성을 살펴본다.
3. 담보물권의 효력과 순위를 체계적으로 정리한다.
4. 유치권의 개념과 법적 성질을 검토한다.

♣ 학습내용

- 물적 담보제도의 유형
- 담보물권의 특성
- 우선변제적 효력
- 순위확정의 원칙
- 유치권과 동시이행항변권의 비교

♣ 사전 테스트

1. 담보물권은 부종성이 있으므로 타인명의의 저당권설정은 무효가 원칙이다.
⇒ ○ : 근저당권은 채권담보를 위한 것이므로 원칙적으로 채권자와 근저당권자는 동일인이 되어야 한다. 다만 제3자를 근저당권 명의인으로 하는 근저당권을 설정하는 경우 채권자와 채무자, 제3자 사이에 합의 등 특별한 사정이 있는 경우에는 이러한 근저당권설정등기도 유효하다 (대판 1995.9.26, 94다33583).
2. 유치권에도 물상대위성이 인정된다는 것은 담보물권의 성질상 당연하다
⇒ × : 물상대위성은 우선적 효력이 있는 담보물권 중 질권과 저당권에만 인정된다. 즉 유치권은 유치적 기능을 중심으로 하고 우선변제적 효력이 없으므로 물상대위성이 인정되지 않는다.
3. 유치권과 동시이행항변권은 동시에 서로 병존할 수 없다.
⇒ × : 양자 모두가 공평의 원리에 입각한 제도라는 점, 채권과 목적물간 또는 채권과 채무간의 견련관계가 있고 채권이 변제기에 있을 때 법률상 당연히 발생하며 또 당사자의 특약으로 그 발생을 저지시킬 수 있다는 점, 그 기본이 되는 채권이 소멸한 경우에 권리가 소멸한다는 측면에서 양자는 병존할 수 있다.

♣ 강의교안

제4장 담보물권

제1절 총설

I. 담보물권의 의의

채무자의 채무불이행 → 책임재산 보전 필요성 : 채권자대위권, 채권자취소권) → 채권자평등의 원칙 → 먼저 성립한 채권이라도 우선하는 효력이 없다. → 따라서 채권자가 채권실현을 확보할 필요가 있는 경우 담보제도(인적담보, 물적담보)를 활용

- ① 인적담보 : 책임재산의 총액을 확대시켜 그 채무자의 지급불능의 위험이 분산되므로 금전채권의 실현을 더욱 확실하게 한다(보증채무(제428조 내지 제448조), 연대채무(제412조 내지 제427조) → 책임재산의 양적 확대, 담보력은 물적담보보다 불확실, 간편
- ② 물적 담보 : 책임재산 중 어느 특정의 것으로 채권의 담보에 충당하여 다른 채권자보다 우선하여 변제받는 제도이다. 유치권·질권·저당권(민법규율)/가등기담보권·양도담보권(가담법 또는 판례이론에 의한 규율) → 물건 또는 권리의 가치에 의해 담보되어 우선변제로 채권자 지위는 안전, 실행절차 복잡

II. 물적 담보제도의 유형

1. 제한물권의 법리에 의한 것

(1) 법정담보물권

- 1) 유치권 타인의 물건의 점유자가 그 물건에 관하여 생긴 채권을 가진 경우에는 그 채권의 변제를 받을 때까지 그 물건을 유치할 수 있는 담보물권(제320조).

2) 법정질권

(가) 토지임대인의 법정질권

제648조(임차지의 부속물, 과실 등에 대한 법정질권) 토지임대인이 임대차에 관한 채권에 의하여 임차지에 부속 또는 그 사용의 편익에 공용한 **임차인의 소유동산 및 그 토지의 과실을 압류**한 때에는 질권과 동일한 효력이 있다.

(나) 건물 등의 임대인의 법정질권

제650조(임차건물등의 부속물에 대한 법정질권) 건물 기타 공작물의 임대인이 임대차에 관한 채권에 의하여 그 건물 기타 공작물에 부속한 임차인소유의 동산을 압류한 때에는 질권과 동일한 효력이 있다.

3) 법정저당권

제649조(임차지상의 건물에 대한 법정저당권) 토지임대인이 변제기를 경과한 최후 2년의 차임채권에 의하여 그 지상에 있는 임차인소유의 건물을 압류한 때에는 저당권과 동일한 효력이 있다.

4) 우선변제특권

목적물을 유치하지 않더라도 채무자의 재산으로부터 우선변제권이 인정되는 권리가 우선특권이다. 특별법상 우선특권이 인정되는 것으로는

- (i) 근로기준법상 근로자의 임금우선특권(동법 제38조)
- (ii) 주택임대차보호법상 임차인의 보증금우선변제권(동법 제3조의2 제1항·제12조) 및 소액보증금최우선변제권(동법 제8조)
- (iii) 상법상의 사용인의 우선변제권(동법 제468조). 재난구조자의 우선특권(동법 제858조), 선박우선특권(동법 제861조)
- (iv) 신탁계약상의 수익자의 우선특권(신탁업법 제17조)
- (v) 보험계약자 등의 우선특권(보험업법 제32조·제33조) 등이 있다.

(2) 약정담보물권 당사자 사이의 약정에 의하여 성립하는 담보물권

1) 질 권 채권자가 채권의 담보로서 채무자로부터 인도받은 물건을 점유하고 채무불이행시에 그 물건을 환가하여 다른 채권자에 우선하여 채권을 변제받는 담보물권이다(제329조 내지 제355조). 질권에는 동산질권·권리질권/상사질권(상법 제59조) 등이 있다.

2) 저당권 채권자가 채무자 또는 제3자(물상보증인)가 담보로 제공한 부동산을 점유하지 않고 변제가 없을 때에는 다른 채권자에 우선변제 받을 수 있는 담보물권이다(제356조 내지 제372조).

3) 전세권

- ① 본질은 용익물권
- ② 전세기간 종료시 전세금 반환확보하기 위하여 전세권자에게 우선변제권을 인정(제303조 제1항) → 용익권능 소멸하고 담보물권으로 전환

2. 소유권이전의 법리에 의한 것

채권자에게 소유권을 이전하되 채권담보 목적으로 제한된다는 법리.

→ 채무자가 변제하면 소유권을 되찾아 옴.

→ 채무자가 변제하지 않으면 → ① 채권자가 직접 소유권을 취득 또는

② 채권자가 제3자에게 처분

담보권 실행입장에서는 ①과 ②를 질권에서는 유질, 저당권에서는 유저당이라고 함

- ①을 소유권이전형 유질/ 소유권이전형 유저당
- ②를 임의현금화형 유질/ 임의현금화형 유저당

※ 유질계약 금지(<- - 서민보호) / 유저당계약 인정(<- - 채권자 보호)

제339조 (유질계약의 금지) 질권설정자는 채무변제기전의 계약으로 질권자에게 변제에 가
 림하여 질물의 소유권을 취득하게 하거나 법률에 정한 방법에 의하지 아니하고 질물을 처
 분할 것을 약정하지 못한다.

1) 양도담보

채권자에게 목적물을 양도하는 형식에 의하여 담보의 목적을 달성

2) 환매·재매매의 예약(매도담보)

- 채권편에 규정(제590조 내지 제595조).
- 제1매매 후 제2매매를 하거나(환매) 제2매매를 예약(재매매의 예약)함.

3) 대물변제의 예약

- 대물변제(제466조) + 예약(제564조) 두 제도 결합
- 특정재산에 관하여 대물변제의 예약을 하면 금전채권상의 채권을 담보
- 대물변제예약의 목적물가액이 채무액 및 이에 붙인 이자의 합산액을 초과할 수 없도록 규정(제607조), 이에 반하는 대물변제예약은 무효(제608조).

4) 매매의 예약

매매의 예약도 담보작용을 하는 수가 있다. 이때의 매매의 예약은 실질에 있어서는 대물변제
 의 예약과 다름이 없다고 할 것이다.

5) 소유권유보부 매매

신탁적 소유권이전설(다수설·판례)
 담보물권설

3. 전형적 담보제도와 변칙적 담보제도

① 전형적 담보제도(민법) : 유치권·질권·저당권. → 실행방법 복잡, 경매가격 하락의 문제

② 변칙적 담보제도 : 양도담보·가등기담보·대물변제의 예약·환매

→ 변칙담보제도가 거래계에서 담보수단으로서 통용됨에 따라 여러 문제가 발생 →채무자 보
 호 목적 → 1983년에 가등기담보등에관한법률을 제정

III. 담보물권의 본질 및 특성

1. 본질

- (1) 가치권성 → 교환가치를 취득
- (2) 물건성 → 물건 또는 재산권 등의 객체(교환가치)를 직접 지배할 수 있는 권리

2. 특성(통유성) : 담보물권의 공통되는 성질(단 약간의 차이가 있음)

(1) 부종성

1) 부종성의 의의

담보물권이 피담보채권의 존부와 운명을 같이 하는 것(성립, 소멸)

제369조(부종성)

저당권으로 담보한 채권이 시효의 완성 기타 사유로 인하여 소멸한 때에는 저당권도 소멸한다.

2) 부종성의 정도

유치권(법정채권) : 특정채권을 보호목적이므로 → 엄격

질권·저당권(약정채권) : 신용수수(예 : 금전대출)의 매개로 하므로 → 완화

(예 특히 장래의 불특정채권을 담보하기 위한 설정인 근저당(제357조) → 부종성이 크게 완화)

[판례] 부종성의 완화

근저당권은 당사자 사이의 계속적인 거래관계로부터 발생하는 불특정채권을 어느 시기에 계산하여 잔존하는 채무를 일정한 한도액 범위 내에서 담보하는 저당권으로서 보통의 저당권과 달리 발생 및 소멸에 있어 피담보채무에 대한 부종성이 완화되어 있는 관계로 피담보채무가 확정되기 이전이라면 채무의 범위나 또는 채무자를 변경할 수 있는 것이고, 채무의 범위나 채무자가 변경된 경우에는 당연히 변경 후의 범위에 속하는 채권이나 채무자에 대한 채권만이 당해 근저당권에 의하여 담보되고, 변경 전의 범위에 속하는 채권이나 채무자에 대한 채권은 그 근저당권에 의하여 담보되는 채무의 범위에서 제외된다(대판 1999. 5. 14, 97다15777·15784).

3) 성립상의 부종성

(가) 채무자의 불일치 문제

담보물권은 부종성이 있어야 하므로 피담보채권의 채무자와 담보물권 등기상의 채무자가 일치하여야 한다.

① 원칙 → 근저당권 설정계약상의 채무자 아닌 제3자를 채무자로 하여 된 근저당권 설정등기는 채무자를 달리 한 것이므로 근저당권의 부종성에 비추어 원인 없는 무효의 등기가 된다(대판 1981. 9. 8, 80다1468).

② 예외 → 다만 이러한 경우에도 당사자간의 합의가 있으면 유효성이 인정된다.

예 : ① 신탁자가 대출받고 신탁부동산의 수탁자소유명의의 등기부에 수탁자를 채무자로

② 편의상 매수인 대신 등기부상 소유자인 매도인을 채무자로 하여 마친 근저당권설정등기

[판례] 피담보채권의 채무자와 담보물권의 채무자 명의가 다른 경우

① 자기 소유 부동산을 타인에게 명의신탁한 명의신탁자가 자신의 채무를 담보하기 위하여 그 부동산에 근저당권설정등기를 함에 있어 편의상 채무자를 명의수탁자로 등재한 경우에 그 근저당권은 명의신탁자의 채무를 담보한다고 하여 피담보채권의 채무자와 근저당권의 채무자 명의가 다른 경우에도 부종성에 반하지 않는 것으로 보고 있다(대판 1999. 7. 22, 99마 2870).

② 근저당권은 채권담보를 위한 것이므로 원칙적으로 채권자와 근저당권자는 동일인이 되어야 하지만, 제3자를 근저당권 명의인으로 하는 근저당권을 설정하는 경우 그 점에 대하여 ㉠채권자와 채무자 및 제3자 사이에 합의가 있고, 채권양도, 제3자를 위한 계약, 불가분적 채권관계의 형성 등 방법으로 ㉡채권이 그 제3자에게 실질적으로 귀속되었다고 볼 수 있는 특별한 사정이 있는 경우에는 제3자 명의의 근저당권설정등기도 유효하다고 보아야 할 것이고, 한편 부동산을 매수한 자가 소유권이전등기를 마치지 아니한 상태에서 매도인인 소유자의 승낙 아래 매수 부동산을 타에 담보로 제공하면서 당사자 사이의 합의로 편의상 매수인 대신 등기부상 소유자인 매도인을 채무자로 하여 마친 근저당권설정등기는 실제 채무자인 매수인의 근저당권자에 대한 채무를 담보하는 것으로서 유효하다고 볼 것인바, 위 양자의 형태가 결합된 근저당권이라 하여도 그 자체만으로는 부종성의 관점에서 근저당권이 무효라고 보아야 할 어떤 질적인 차이를 가져오는 것은 아니라 할 것이다. 그리고 매매잔대금 채무를 지고 있는 부동산 매수인이 매도인과 사이에 소유권이전등기를 경료하지 아니한 상태에서 그 부동산을 담보로 하여 대출받는 돈으로 매매잔대금을 지급하기로 약정하는 한편, 매매잔대금의 지급을 위하여 당좌수표를 발행·교부하고 이를 담보하기 위하여 그 부동산에 제1순위 근저당권을 설정하되, 그 구체적 방안으로서 채권자인 매도인과 채무자인 매수인 및 매도인이 지정하는 제3자 사이의 합의 아래 근저당권자를 제3자로, 채무자를 매도인으로 하기로 하고, 이를 위하여 매도인이 제3자로부터 매매잔대금 상당액을 차용하는 내용의 차용금증서를 작성·교부하였다면, 매도인이 매매잔대금 채권의 이전 없이 단순히 명의만을 제3자에게 신탁한 것으로 볼 것은 아니고, 채무자인 매수인의 승낙 아래 매매잔대금 채권이 제3자에게 이전되었다고 보는 것이 일련의 과정에 나타난 당사자들의 진정한 의사에 부합하는 해석일 것이므로, 제3자 명의의 근저당권설정등기는 그 피담보채무가 엄연히 존재하고 있어 그 원인이 없거나 부종성에 반하는 무효의 등기라고 볼 수 없다(대판[전합] 2001. 3. 15, 99다 48948).

(나) 채권자의 불일치 문제

① 원칙 : 채권자와 담보물권자는 동일인이어야 함

② 예외 : ㉠ 채권자와 채무자 및 제3자 사이에 합의 +

㉡ 제3자에게 채권이 실질적으로 귀속되었다고 볼 수 있는 특별한 사정

→ 제3자 명의의 근저당권설정등기도 유효하다(대판 2000. 12. 12, 2000다49879; 대판 1995. 9. 26, 94다33583; 대판 1995. 2. 10, 94다18508; 대판 1994. 2. 8, 93다19153-93다 19160; 대판 2009. 11. 26, 2008다64478-64485-64492 등).

[판례] 채권자 아닌 제3자 명의로 설정된 저당권 또는 채권담보 목적의 가등기의 효력(=제한적 유효)

채권담보의 목적으로 채무자 소유의 부동산을 담보로 제공하여 저당권을 설정하는 경우에는 담보물권의 부종성의 법리에 비추어 원칙적으로 채권과 저당권이 그 주체를 달리할 수 없는 것이지만, 채권자 아닌 제3자의 명의로 저당권등기를 하는 데 대하여 채권자와 채무자 및 제3자 사이에 합의가 있었고, 나아가 제3자에게 그 채권이 실질적으로 귀속되었다고 볼 수 있는 특별한 사정이 있거나, 거래경위에 비추어 제3자의 저당권등기가 한낱 명목에 그치는 것이 아니라 그 제3자도 채무자로부터 유효하게 채권을 변제받을 수 있고 채무자도 채권자나 저당권 명의자인 제3자 중 누구에게든 채무를 유효하게 변제할 수 있는 관계 즉 묵시적으로 채권자와 제3자가 불가분적 채권자의 관계에 있다고 볼 수 있는 경우에는, 그 제3자 명의의 저당권등기도 유효하다고 볼 것인바, 이러한 법리는 저당권의 경우뿐 아니라 채권 담보를 목적으로 가등기를 하는 경우에도 마찬가지로 적용된다고 보아야 할 것이고, 이러한 법리가 부동산실권리자명의등기에 관한 법률에 규정된 명의신탁약정의 금지에 위반된다고 할 것은 아니다(대판 2000. 12. 12, 2000다49879).

4) 존속상의 부종성

피담보채권이 없는 근저당권만의 양도는 법률상 효력이 없다(대판 1968. 2. 20, 67다2543). 그리고 피담보채권만 양도하면 저당권은 소멸한다(통설).

5) 소멸상의 부종성

제369조(부종성)

저당권으로 담보한 채권이 시효의 완성 기타 사유로 인하여 소멸한 때에는 저당권도 소멸한다.

피담보채무가 소멸 → 담보권도 당연히 소멸 → 말소등기가 없어도 저당권은 소멸

채무자가 근저당권자에게 확정된 피담보채무액 전부를 변제하고 근저당권설정계약을 해지한 경우에 위 근저당권에 대하여 다시 제3자 앞으로 이전등기가 되어도 이 이전된 근저당권설정등기는 원인무효의 등기가 된다(대판 1972. 7. 25, 72다971).

- ① 경매개시결정 이후에 변제하여 소멸한 경우 : 매각대금 완납시까지 이의신청하지 않으면 → 경락인 소유권취득
- ② 경매개시결정 이전에 변제하여 소멸했다면 경매무효 → 경락인 소유권 취득 못함. 후술)

[판례] 소멸상의 부종성

피담보채권이 소멸하면 저당권은 그 부종성에 의하여 당연히 소멸하게 되므로, 그 말소등기가 경료되기 전에 그 저당권부채권을 가압류하고 압류 및 전부명령을 받아 저당권 이전의 부기등기를 경료한 자라 할지라도, 그 가압류 이전에 그 저당권의 피담보채권이 소멸된 이상, 그 근저당권을 취득할 수 없고, 실체관계에 부합하지 않는 그 근저당권 설정등기를 말소할 의무를 부담한다(대판 2002. 9. 24, 2002다27910).

(2) 수반성

1) 피담보채권이 상속·양도 기타의 이유로 이전 → 담보물권도 그에 따라 이전하는 성질

넓은 의미에서 부종성에 포함된다(부종성과 수반성 모두 담보물권이 피담보채권에 종된 지위에 있다는 데서 나오는 것이므로 구별할 필요가 없다는 견해도 있다).

제361조(저당권의 처분제한)

저당권은 그 담보한 채권과 분리하여 타인에게 양도하거나 다른 채권의 담보로 하지 못한다.

→ 민법 제361조는 간접적으로 이 성질을 표명하고 있다.

2) 저당권이전의 경우에, 이전의 부기등기를 요한다(제348조).

[판례] 피담보채권의 처분에 따르지 않은 담보권의 소멸여부(적극)

담보권의 수반성이란 피담보채권의 처분이 있으면 언제나 담보권도 함께 처분된다는 것이 아니라 채권담보라고 하는 담보권 제도의 존재 목적에 비추어 볼 때 특별한 사정이 없는 한 피담보채권의 처분에는 담보권의 처분도 당연히 포함된다고 보는 것이 합리적이라는 것일 뿐이므로, 피담보채권의 처분이 있음에도 불구하고, 담보권의 처분이 따르지 않는 특별한 사정이 있는 경우에는 채권양수인은 담보권이 없는 무담보의 채권을 양수한 것이 되고 채권의 처분에 따르지 않은 담보권은 소멸한다(대판 2004. 4. 28,고 2003다61542).

(3) 물상대위성

제342조(물상대위)

질권은 질물의 멸실, 훼손 또는 공용징수로 인하여 질권설정자가 받을 금전 기타 물건에 대하여도 이를 행사할 수 있다. 이 경우에는 그 지급 또는 인도전에 압류하여야 한다.

제370조(준용규정) 제214조, 제321조, 제333조, 제340조, 제341조 및 제342조의 규정은 저당권에 준용한다.

1) 담보물권은 그 목적물에 갈음한 금전 기타의 물건에 대해서도 역시 존속하는 성질

→ 보험금지급청구권·손해배상청구권·보상금청구권 등

물상대위성은 우선적 효력이 있는 담보물권(질권·저당권)에만 인정된다.

유치권은 유치적 기능을 중심으로 하고 우선변제적 효력이 없으므로 물상대위성이 인정되지 않는다.

2) 변형물의 지급 또는 인도전에 압류하여야 한다. 다만 그 압류는 담보권자가 아닌 다른 채권자가 하여도 무방하며(대판 2002. 10. 11, 2002다33137; 대판 2010. 10. 28, 2010다46756), 그것이 공탁된 경우에도 공탁금에 대해 물상대위를 할 수 있다(대판 1999. 5. 14, 98다62688).

참고 : 동산·채권담보법은 매매·임대금액에 대하여도 가능

(4) 불가분성

제321조(유치권의 불가분성)

유치권자는 채권전부의 변제를 받을 때까지 유치물전부에 대하여 그 권리를 행사할 수 있다.

제343조(준용규정)

제249조 내지 제251조, 제321조 내지 제325조의 규정은 동산질권에 준용한다.

제370조(준용규정)

제214조, 제321조, 제333조, 제340조, 제341조 및 제342조의 규정은 저당권에 준용한다.

- 1) 담보물권자는 피담보채권의 전부의 변제를 받을 때까지 목적물의 전부에 관하여 그 권리를 행사할 수 있다. 담보물권의 일부가 불가항력 기타 사유로 멸실한 경우에도 그 잔존부분이 전 채권을 담보한다.
- 2) 다만 유치권에서는 다른 담보를 제공하고 유치권의 소멸 청구를 할 수 있다(제327조). 그리고 불가분성의 예외로서 공동저당에서 동시배상의 경우 경매대가에 비례하여 채무를 분담한다(제368조).

IV. 담보물권의 효력

1. 제한물권형 담보물권의 효력

제한물권으로서의 담보물권의 효력은 그 종류에 따라 차이가 있으나, 특히 다음과 같은 효력이 인정된다. 그 밖에 담보물권에도 물권으로서의 일반적효력이 있다.

(1) 우선변제적 효력(담보물권의 본래적인 기능)

피담보채권의 변제를 받지 못한 때 목적물을 환가하여 다른 채권자보다도 먼저 변제받는 것

제329조(동산질권의 내용)

동산질권자는 채권의 담보로 채무자 또는 제삼자가 제공한 동산을 점유하고 그 동산에 대하여 다른 채권자보다 자기채권의 우선변제를 받을 권리가 있다.

제356조(저당권의 내용)

저당권자는 채무자 또는 제삼자가 점유를 이전하지 아니하고 채무의 담보로 제공한 부동산에 대하여 다른 채권자보다 자기채권의 우선변제를 받을 권리가 있다.

유치권 → 사실상 우선변제력

(2) 유치적 효력

담보목적물을 채권자가 변제받을때까지 점유함으로써 심리적 압박을 가하여 채무의 변제를 촉구. 즉 물건이 갖는 사용가치를 채권자가 빼앗는 것

유치권과 질권에 이 효력이 인정된다.

(3) 수익적 효력

채권자가 목적물의 수익으로부터 우선변제를 받는 효력을 수익적 효력이라고 한다. 구민법상의 부동산질권에는 수익적 효력이 인정되었으나, 부동산질권을 인정하지 않는 현행민법에서는 용익물권과 담보물권의 성질을 겸유하고 있는 전세권을 수익적 효력이 있는 담보물권(즉 일종의 부동산질권)으로 볼 수 있을 것이다.

2. 권리이전형 담보물권의 효력

양도담보·매도담보·대물변제예약 등의 이른바 권리이전형의 물적담보 내지 변칙담보에 있어서는 채무의 변제가 없으면 권리가 채권자에게 이전되거나 또는 경매에 의한 우선변제적효력이 인정된다.

V. 담보물권의 순위

▶ 돌발 퀴즈

우리 민법은 수 개의 저당권이 설정된 경우에 순위확정의 원칙을 취하므로 선순위 저당권이 소멸하더라도 후순위 저당권의 순위가 승진하지는 않는다.

: ×. 우리 민법은 저당권의 순위가 등기 선후에 따라 결정된다는 의미에서는 순위확정의 원칙을 따르나, 한번 확정된 순위는 선순위 저당권이 소멸하더라도 승진하지 않는다는 의미에서의 순위확정의 원칙은 따르고 있지 않다.

순위확정의 원칙(등기의 효력 중에서)

- ① 저당권의 경우에는 저당권 설정등기의 선후에 의하여 그 순위가 결정된다.
- ② 그런데 저당권의 경우에 선순위의 담보물권이 소멸하면 후순위의 담보물권의 순위는 승진하게 된다(순위승진의 원칙).

참고로 독일 민법의 경우와 같이 담보물권을 독립된 가치권으로 확립하고 있는 입법례에 있어서는 선순위의 저당권이 소멸하더라도 후순위의 저당권은 순위가 승진하지 못한다(순위확정의 원칙).

전형담보의 비교

종류 내용	유 치 권	질 권	저 당 권
성 립	법률이 정한 일정한 요건을 구비하면 당연 성립 (제320조 제1항) 법정담보물권	설정계약 + 인도(제330조) 또는 양도(제346조) 약정담보물권	설정계약 + 등기(제186조) 약정담보물권
목 적 물	물건(동산·부동산)과 유가증권 (제320조 제1항)	동산(제329조)과 재산권(제345)	부동산 (제356조)
본질적 효력	유치적 효력(제320조 제1항) 점유를 요건으로 함	유치적 효력(제335조) + 우선변제적 효력(제329조) 점유를 요건으로 함	우선변제적 효력(제356조) 점유를 요건으로 하지 않음.
경 매 권	있음 (제322조 제1항)	있음 (제338조 제1항)	있음 (제363조)
간이변제 충당권	법원의 허가를 얻어 할 수 있음 (제322조 제2항)	법원의 허가를 얻어 할 수 있음 (제338조 제2항)	없음
물상대위성	없음	있음 (제342조)	있음 (제370조)

제2절 유치권

I. 서 설

1. 의 의

제320조(유치권의 내용)

- ① 타인의 **물건 또는 유가증권**을 점유한 자는 그 물건이나 유가증권에 관하여 생긴 채권이 변제기에 있는 경우에는 변제를 받을 때까지 그 물건 또는 유가증권을 유치할 권리가 있다.
- ② 전항의 규정은 그 점유가 불법행위로 인한 경우에 적용하지 아니한다.
→ 물건 → 동산 및 부동산이다. 부동산에 관한 유치권의 폐해가 적지 않다. → **부동산유치권을 폐지하자는 주장 및 입법안(2013년 7월 국회 제출)이 있음**/ 물건을 동산으로 변경함.

제321조(유치권의 불가분성)

유치권자는 채권 전부의 변제를 받을 때까지 유치물전부에 대하여 그 권리를 행사할 수 있다.

제322조(경매, 간이변제충당)

- ① 유치권자는 채권의 변제를 받기 위하여 유치물을 경매할 수 있다.
- ② 정당한 이유있는 때에는 유치권자는 감정인의 평가에 의하여 유치물로 직접 변제에 충당할 것을 법원에 청구할 수 있다. 이 경우에는 유치권자는 미리 채무자에게 통지하여야 한다.

제323조(과실수취권)

- ① 유치권자는 유치물의 과실을 수취하여 다른 채권보다 먼저 그 채권의 변제에 충당할 수 있다. 그러나 과실이 금전이 아닌 때에는 경매하여야 한다.
- ② 과실은 먼저 채권의 이자에 충당하고 그 잉여가 있으면 원본에 충당한다.

- ① 목적물을 유치함 → 채무자의 변제를 심리적 압박
- ② 목적물의 교환가치로부터 직접 우선변제 받는 것이 아님(↔ 전세권, 질권, 저당권)
단, 목적물이 다른 채권자나 담보물권자에 의하여 경매 또는 강제집행 되더라도 유치권자는 그 경락인에 대하여도 역시 변제받을 때 까지는 그 목적물의 인도를 거절할 수 있기 때문에 사실상으로는 우선변제를 받을 수 있게 된다.(제321조 참조)
→ 우선변제권 없음. 단지 사실상 우선변제와 같은 효력일 뿐
- ③ 경매권(제322조 제1항)

2. 입법취지

채권자가 변제받기 전에 자기만 물건(유가증권)을 인도하면 불공평(공평의 원칙)

3. 연혁·입법례

로마법상의 약의의 항변권(인적 항변권) : 급부거절권의 성질

프랑스독일은 채권법에서 급부거절권

스위스민법만 일종의 법정질권

일본민법은 프랑스의 학설을 받아들여 우리민법과 더불어 담보물권으로 구성

[참 고]

거래계에서 특히 “부동산” 유치권이 초래하는 폐해가 적지 않다. 즉 (법정)담보물권임에도 피담보채무가 공시되지 않을 뿐만 아니라 경매에서의 매수인이 그 부담을 인수하므로, 매수인에게 불측의 손해를 줄 가능성이 크다. 따라서 경매절차에서 유치권 주장하는 자가 있으면 매수신청을 꺼릴 수밖에 없어서 경매가 유찰되는 경우가 허다하고, 그에 따라 담보물의 가치가 저감되어 특히 담보물의 소유자에게 손해를 끼치게 된다. 이러한 사정 때문에 유치권제도의 개선이 요망된다.

유 치 권	동시이행 항변권
양자 모두 공평의 원칙에 기한 제도이다.	
물권으로서 목적물을 직접 지배하는 것을 내용으로 한다	쌍무계약의 효력으로서 상대방의 청구에 대한 항변을 그 내용으로 한다.
채권담보를 목적으로 한다.	당사자 일방만이 선이행을 강요당하는 것을 방지함을 목적으로 한다.
거절할 수 있는 급부는 목적물의 인도에 한한다.	거절할 수 있는 급부에는 제한이 없다.
다른 담보를 제공하고 소멸을 청구할 수 있다.	다른 담보의 제공으로 소멸시킬 수 없다.
채권과 목적물이 서로 대가적 관계에 있지 않다.	쌍방의 채무가 대가적 관계에 있다.
· 유치권과 동시이행의 항변권은 서로 배척하는 것이 아니라 병존할 수 있다. · 상대방의 목적물인도청구에 대하여는 상환급부판결(원고일부승소판결)을 하게 된다.	

II. 유치권의 법적 성질

1. 물 권

(1) 누구에 대하여도 유치 주장

→ 채무자, 양수인, 경락인(단, 압류등기(경매개시결정등기)후 유치권자는 경락인에 대항 못 함)

(2) 특징

- ① 유치권은 점유를 성립요건 및 존속요건으로 하므로 목적물의 점유를 상실하면 유치권은 소멸(제328조),
- ② 추급력이 없으므로 유치물의 점유를 침탈당하는 경우에는 점유물반환청구(제204조 제1항)에 의하여 그 점유를 회복할 수밖에 없다.
- ③ 유치권은 부동산 위에도 성립하지만 등기를 효력요건으로 하지 않고, 유가증권에 대하여 성립하는 경우에도 배서를 필요로 하지 않는다.

[판례] 유치권의 타물권성

유치권은 타물권인 점에 비추어 볼 때 수급인의 재료와 노력으로 건축되었고 독립한 건물에 해당하는 기성부분은 수급인의 소유라 할 것이므로 수급인은 공사대금을 지급받을 때까지 이에 대하여 유치권을 가질 수 없다(대판 1993. 3. 26, 91다14116).

2. 법정물권

요건으로 당연성립하는 법정 담보물권/ 등기, 배서·교부 불요

3. 담보물권

부종성·수반성·불가분성 : 있음

물상대위성 : 없음 <- - 그 목적물 그 자체의 유치를 본체로 하기 때문

즉 우선변제권이 없으므로 물상대위성이 없다(우 → 물)

다만 사실상 우선변제권을 가진다. 그밖에 간이변제충당(제322조 제2항)·과실수취권(제323조 제1항)·별제권(채무자회생및파산에관한법률 제411조) 등에서도 사실상 우선변제권이 인정된다.

[판례] 유치권의 불가분성

민법 제320조 제1항에서 ‘그 물건에 관하여 생긴 채권’은 유치권 제도 본래의 취지인 공평의 원칙에 특별히 반하지 않는 한 ①채권이 목적물 자체로부터 발생한 경우는 물론이고 ②채권이 목적물의 반환청구권과 동일한 법률관계나 사실관계로부터 발생한 경우도 포함하고, 한편 민법 제321조는 “유치권자는 채권 전부의 변제를 받을 때까지 유치물 전부에 대하여 그 권리를 행사할 수 있다”고 규정하고 있으므로, 유치물은 그 각 부분으로써 피담보채권의 전부를 담보하며, 이와 같은 유치권의 불가분성은 그 목적물이 분할 가능하거나 수개의 물건인 경우에도 적용된다(대판 2007. 9. 7, 2005다16942. 다세대주택이 창호 등의 공사를 완성한 하수급인이 공사대금채권 잔액을 변제받기 위하여 위 다세대주택의 한 세대를 점유하여 유치권을 행사하는 경우 그 유치권은 위 한세대에 대하여 시행한 공사대금만이 아니라 다세대주택 전체에 대하여 시행한 공사대금채권의 전액 전부를 피담보채권으로 하여 성립한다고 본 사례).

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 담보물권은 부종성을 가지므로 타인명의의 저당권설정은 무효가 원칙이다.
- ② 유치권에는 물상대위성이 인정되지 않으나, 수반성은 인정된다.
- ③ 불가분성은 공동저당의 일괄경매에서만 그 예외가 인정된다.
- ④ 유치권은 물상대위성이 인정되지 않는다.
- ⑤ 부종성의 완화는 약정담보물권에서 현저하다.

- ③. 판례는 공동저당의 일괄경매와 전세권의 목적물의 일부 멸실의 경우에는 불가분성의 예외를 인정한다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 유치권에도 물상대위성이 인정되지 않는다.
- ② 피담보채권의 일부를 변제하여도 전액이 변제되지 않는 한 목적물 전부에 효력이 미친다.
- ③ 약정담보물권은 부종성을 완화할 수 있다.
- ④ 저당권에는 불가분성이 있으나 유치권에는 인정되지 않는다.
- ⑤ 민법상의 담보물권은 타물권임을 원칙으로 한다.

- ④. 유치권에도 불가분성은 인정된다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 유치권은 독립의 물권이며, 동시 이행의 항변권은 쌍무 계약에서 발생하는 채무에 따르는 단순한 권능이다.
 - ② 유치권뿐만 아니라 동시 이행의 항변권에도 경매권이 인정된다.
 - ③ 양자는 공평의 원리에 입각하여 채무의 이행을 확보하려고 하는 점에서는 동일하다.
 - ④ 유치권은 상당한 담보를 제공하고 소멸시킬 수 있으나, 동시 이행의 항변권은 그러하지 아니하다.
 - ⑤ 유치권에 의하여 거절되는 것은 물건의 인도이나, 동시 이행의 항변권에 의하여 거절할 수 있는 급부는 제한이 없다.
- ②. 유치권자는 채권의 변제를 받기 위하여 유치물을 경매할 수 있으나, 동시이행의 항변권에는 경매권이 인정되지 않는다.

♣ 학습정리

- 1. 담보물권은 물건 또는 재산권 등의 객체(교환가치)를 직접 지배할 수 있는 권리로서 물권의 성질을 갖는다. 특히 담보물권도 물권으로서의 배타성과 우선적 효력을 갖추고 있으며 공시의 원칙이 적용된다는 점에서 다른 물권과 동일하다.
- 2. 제한물권으로서 담보물권은 물권으로서 일반적 효력 이외에 우선변제적 효력, 유치적 효력, 수익적 효력 등이 있다.
- 3. 유치권은 오로지 유치권자의 채권담보를 목적으로 인정되는 반면에 동시이행의 항변권은 계약의 당사자 일방의 선이행이 강요당하는 것을 피하는 것을 목적으로 인정된다.

제32강 유치권 (2)

♣ 학습목표

1. 유치권의 성립요건을 체계적으로 정리할 수 있다.
2. 유치권의 효력을 유형별로 정리할 수 있다.
3. 유치권의 소멸사유를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 유치권의 성립요건
- 경매권과 우선변제권
- 비용상환청구권
- 선관주의의무
- 유치권의 소멸사유

♣ 사전 테스트

1. 임차인이 약정에 기한 권리금반환청구권을 가지고 임차물에 대해 유치권을 행사할 수 있다.
⇒ × : 임대인과 임차인 사이에 건물명도시 권리금을 반환하기로 한 약정이 있었다 하더라도 그와 같은 권리금반환청구권은 건물에 관하여 생긴 채권이라 할 수 없으므로 그와 같은 채권을 가지고 건물에 대한 유치권을 행사할 수 없다(대판 1994. 10. 14, 93다62119).
2. 채권의 변제기가 도래하지 않더라도 유치권은 성립할 수 있다.
⇒ × : 채권의 변제기가 도래하지 않는 동안에는 유치권은 성립하지 않는다(제320조 제1항).
3. 유치권자는 채무자의 승낙 없이는 유치물의 보존에 필요한 사용을 할 수 없다.
⇒ × : 유치권자는 선량한 관리자의 주의로 유치물을 점유하여야 하고, 유치물의 보존에 필요한 사용이 아닌 한 채무자의 승낙 없이 유치물을 사용하지 못한다.

♣ 강의교안

III. 유치권의 성립

제320조(유치권의 내용)

- ① 타인의 물건 또는 유가증권을 점유한 자는 그 물건이나 유가증권에 관하여 생긴 채권이 변제기에 있는 경우에는 변제를 받을 때까지 그 물건 또는 유가증권을 유치할 권리가 있다.
- ② 전항의 규정은 그 점유가 불법행위로 인한 경우에 적용하지 아니한다.

1. 타인의 물건의 점유

(1) 타인의 소유(타물권)

유치권자 자신의 소유가가 아니라 채무자 또는 제3자의 소유물일 것(통설. 대판 1972. 1. 31, 71다2414). 다만 상사유치권은 채무자 소유의 물건만을 객체로 한다(상법 제58조, 대신에 견련성을 요하지 않는다).

[판례] 도급계약에서 수급인이 신축 건물에 대하여 유치권을 가지는 경우

주택건물의 신축공사를 한 수급인이 그 건물을 점유하고 있고 또 그 건물에 관하여 생긴 공사금 채권이 있다면, 수급인은 그 채권을 변제받을 때까지 건물을 유치할 권리가 있다고 할 것이고, 이러한 유치권은 수급인이 점유를 상실하거나 피담보채무가 변제되는 등 특단의 사정이 없는 한 소멸되지 않는다(대판 1995. 9. 15, 95다16202·95다16219, 이 사안은 완성된 건물의 소유권은 도급인에 귀속한다고 보고 수급인의 유치권을 인정한 것).

(2) 물건 또는 유가증권

- 구민법(제295조) → 물건
- 현행 민법 → 물건 + 유가증권
- 민법 개정안 → 부동산 제외 논의 중.

(3) 점유

1) 목적물의 점유

(가) 목적물의 점유 : 유치권의 성립요건 + 존속요건이다.

→ 유치권자가 목적물의 점유를 잃게 되면 유치권은 당연히 소멸(제328조).

유치권자의 점유는 직접점유이든 간접점유이든 불문한다(통설·대판 2002. 11. 27, 2000마3516). 단 채무자가 직접점유자이고 채권자가 간접점유자인 경우는 유치권 X

(즉 “채무자의 직접점유를 매개”로 한 간접점유는 점유를 뺏어 변제의 심리적 압박이 없다)

[판례] 채무자를 직접점유자로 하여 채권자가 간접점유하는 경우에도 유치권이 성립하는지 여부(소극)

유치권의 성립요건이자 존속요건인 유치권자의 점유는 직접점유이든 간접점유이든 관계가 없으나, 다만 유치권은 목적물을 유치함으로써 채무자의 변제를 간접적으로 강제하는 것을 본체적 효력으로 하는 권리인 점 등에 비추어, 그 직접점유자가 채무자인 경우에는 유치권의 요건으로서의 점유에 해당하지 않는다고 할 것이다(대판 2008. 4. 11, 2007다27236).

(나) 점유가 침탈된 경우 → 점유보호청구권(제204조)의 행사로 점유를 회복한 경우에는 그 점유는 계속된 것으로 추정되고(제198조), 이 경우 유치권은 소멸하지 않는다.

2) 적법한 점유

(가) 채권자의 점유가 불법행위에 의하여 개시되지 않아야 한다(제320조 제2항).

→ 타인의 물건을 절도(또는 횡령, 사기·강박)한 자의 수선비채권에 관해서는 유치권 불성립 (보호필요성 X)

적법한 유치권성립 후 유치도중에 지출한 비용 → 당연히 유치권 인정하여야 할 것

Q : 처음에는 적법하게 점유를 취득하였으나 그 후에 근원이 소멸한 경우(예를 들어 점유개시시에는 점유권원이 있었으나 해제나 취소의 소급효 때문에 비용지출시에 권원이 없었던 것으로 되는 경우)에 유치권을 인정할 것인가가 문제된다.

① 부정설

단순한 이행거절권이 아니고 물권으로서의 유치권의 성립은 엄격한 요건 하에 인정하는 것이 바람직하므로 언제나 유치권이 성립하지 않는다.

② 선의·무과실설

비용지출시(채권성립시)에 소멸을 알았거나 과실로 알지 못하는 경우에는 유치권의 성립을 부정한다.

③ 선의·무중과실설

소멸에 관하여 악의이거나 중과실이 있는 경우에는 부정한다.

(나) 점유가 불법행위로 인하여 개시되었다는 점에 대한 증명책임 : 반환청구자(통설·판례)

2. 채권과 목적물 사이의 견련관계

(1) 「관하여 생긴 것」

“목적물에 관하여 생긴 채권”의 의미?

(가) 이원적 기준설(판례·다수설).

채권이 목적물 자체로부터 발생한 경우(예 : 목적물에 지출한 비용의 상환청구권)와

채권이 목적물의 반환청구권(인도의무)과 동일한 법률관계 또는 사실관계로부터 발생한 경우(예 : 미성년을 이유로 매매계약을 취소한 결과 생긴 대금반환청구권과 목적물의 반환의무, 우연히 서로 바꾸어간 물건의 반환의 경우)

(나) 일원적 기준설

자신은 불이행하고 목적물을 반환하는 것이 사회관념상 부당한 경우

채권의 성립과 목적물의 존재 사이에 상당인과관계가 있는 경우

(다) 협의설

채권이 목적물 자체로부터 발생한 경우 + 형평의 원칙상 이에 준하는 경우

(라) 물적 관련성 한정설

물적 관련성 → 유치권

목적물과 채권 사이의 관련성이 계약관계를 매개로 이루어지는 법적 관련성 → 동시이행의 항변권

[관련성의 정도 : ① (강함) → ⑦ (약함)]

① 시계 수리비(채권이 목적물 자체로부터 발생)

② 우산 바꿔감(채권이 목적물 반환청구권과 동일한 사실관계로부터 발생)

③ 미성년자의 법률행위 취소(채권이 목적물 반환청구권과 동일한 법률관계로부터 발생)

④ 공사대금채권 → 건물유치 (O)

⑤ 임차보증금채권 → 임대목적물유치(X)

⑥ 건물자재대금채권(시멘트·모래) → 건물유치(X) (단순 매매대금채권일 뿐임)

⑦ 건축수급인의 독립한 건물로 볼수 없는 정착물에 불과한 경우의 공사대금채권 → 토지
유치(X)

(2) 채권과 목적물의 “점유”와의 관련관계 요부

채권은 목적물의 점유 중에 생긴 것이어야 하는지가 문제 → 점유 중 발생 불요(통설·판례)

목적물의 점유 전에 채권이 발생하고 그 후 목적물의 점유를 취득한 경우에도 유치권은 성립한다(대판 1965. 3. 30, 64다1977). 따라서 물건에 관련한 채권을 가진 자가 후에 그 물건을 점유하기에 이른 경우 또는 유치권자가 일시 물건의 점유를 상실하였다가 후에 다시 동일 물건을 점유하게 된 경우에는 각각 그 채권을 위하여 유치권을 취득할 수 있다(대판 1955. 12. 15, 4288민상136).

3. 채권의 변제기의 도래

(1) 채권의 변제기가 도래하지 않는 동안에는 유치권은 성립하지 않는다(제320조 제1항, 대판 2007. 9. 21, 2005다41740). → 유치권 성립요건
(질권·저당권에서의 변제기 도래 : 담보권 실행요건)

(2) 유치권이 성립하였더라도 법원이 채권에 관하여 상환기간을 허락한 경우(제203조 제3항·제310조 제2항·626조 제2항 제2문 등)에는 유치권이 소멸한다.

제325조(유치권자의 상환청구권)

① 유치권자가 유치물에 관하여 필요비를 지출한 때에는 소유자에게 그 상환을 청구할 수 있다.

② 유치권자가 유치물에 관하여 유익비를 지출한 때에는 그 가액의 증가가 현존한 경우에 한하여 소유자의 선택에 좇아 그 지출한 금액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다. 그러나 법원은 소유자의 청구에 의하여 상당한 상환기간을 허여할 수 있다.

(3) 기간을 정하지 아니한 채권에 관하여는 채권발생과 동시에 유치권이 성립한다.

4. 유치권을 배제하는 특약의 부존재

[판례] 원상복구 특약이 있는 경우 유익비 등 유치권 주장의 당부

건물의 임차인이 임대차관계 종료시에는 건물을 원상으로 복구하여 임대인에게 명도하기로 약정한 것은 건물에 지출된 각종 유익비 또는 필요비의 상환청구권을 미리 포기하기로 한 취지의 특약이라고 볼 수 있어 임차인은 유치권 주장을 할 수 없다(대판1975. 4. 22, 73다2010; 대판 1996. 8. 20, 94다44705).

IV. 유치권의 효력

1. 유치권자의 권리(인도거절권/경매권/간의변제충당/과실수취권)

(1) 목적물의 유치(인도거절권)

1) 유치의 의미·방법

목적물의 점유를 계속하고, 그 인도를 거절하는 것

→ 불법행위를 구성하지 아니하고 이행지체에 빠지지 않는다.

참고 : 부동산 임대차에서 임차인이 필요비·유익비를 지출하여 그 임차부동산을 유치하고 있는 경우 종전의 점유상태(즉 사용상태)를 계속할 수 있다(이설 없음).
(주의 임차보증금반환청구권을 위한 유치권은 성립되지 않음)

근거 : ① 유치방법(다수설)

② 보존에 필요한 사용(판례)

검토 : 유치권자의 건물 등의 사용을 그 가치를 유지하기 위한 보존행위로 볼 수 없다.

단 부당이득 성립 : 유치권의 사용으로 인한 이익은 부당이득으로 반환하여야 하는 것으로 해석한다(통설·판례).

2) 유치권의 대세적 효력

(가) 유치권의 존속 중에 유치물이 제3자의 소유가 된 때

① 채권에 대한 변제청구의 상대방 : 본래 채무자뿐

② 유치권의 행사 : 누구에게나(제3자에게도 인도거절) 매수인에게도.

→ 즉 인도거절권능이지 변제청구권 아님

★민사집행법★

[결론]

원칙 : 유치권은 무조건 불소멸의 인수주의

제한 : 판례해석상 “압류의 처분금지효”적용하여 압류등기(경매개시결정등기)후에 유치권성립하는 경우는 그 유치권자는 경락인에게 대항 못함

제91조(인수주의와 잉여주의의 선택 등)

- ① 압류채권자의 채권에 우선하는 채권에 관한 부동산의 부담을 매수인에게 인수하게 하거나, 매각대금으로 그 부담을 변제하는 데 부족하지 아니하다는 것이 인정된 경우가 아니면 그 부동산을 매각하지 못한다.
- ② 매각부동산 위의 모든 저당권은 매각으로 소멸된다. → 소제주의(또는 소멸주의)
- ③ 지상권·지역권·전세권 및 등기된 임차권은 저당권·압류채권·가압류채권에 대항할 수 없는 경우에는 매각으로 소멸된다. → 소제주의(또는 소멸주의)
- ④ 제3항의 경우 외의 지상권·지역권·전세권 및 등기된 임차권은 매수인이 인수한다. 다만, 그중 전세권의 경우에는 전세권자가 제88조에 따라 배당요구를 하면 매각으로 소멸된다. → 인수주의
- ⑤ 매수인은 유치권자에게 그 유치권으로 담보하는 채권을 “변제할 책임이 있다”.
→ 채무까지 인수한다는 의미가 아니라 변제있을 때까지 인도를 거절할 수 있다는 의미 (판례)

제92조(제3자와 압류의 효력)

- ① 제3자는 권리를 취득할 때에 경매신청 또는 압류가 있다는 것을 알았을 경우에는 압류에 대항하지 못한다. → 압류의 처분금지효

제83조(경매개시결정 등)

- ① 경매절차를 개시하는 결정에는 동시에 그 부동산의 압류를 명하여야 한다.
- ② 압류는 부동산에 대한 채무자의 관리·이용에 영향을 미치지 아니한다.
- ③ 경매절차를 개시하는 결정을 한 뒤에는 법원은 직권으로 또는 이해관계인의 신청에 따라 부동산에 대한 침해행위를 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 수 있다.
- ④ 압류는 채무자에게 그 결정이 송달된 때 또는 제94조의 규정에 따른 등기가 된 때에 효력이 생긴다.
- ⑤ 강제경매신청을 기각하거나 각하하는 재판에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다.

1. 제3항의 대항할 수 없는 경우(소멸) 또는 있는 경우(인수)의 판단기준

→ 말수기준권리(말소기준등기) 또는 최선순위의 저당권기준

2. 반면에 유치권은 저당권설정등기가 (가)압류등기(경매개시결정등기) 전·후를 불문하고

매각에 의하여 소멸되지 않는다(제5항)(무조건 불소멸의 인수주의) → 즉 경매개시결정 후에도 필요비·유익비를 지출하여 유치권행사가능

(임차인이 경락을 방해하기 위해 경매개시결정 후에 필요비를 지출하여 유치권행사 → 유찰 유도 현실)

3. 이와 같은 유치권을 주장하는 자의 존재로 인하여 매수인이 예기치 않은 불이익을 입을 가능성 발생

→ 매수인(경락인)보호 노력이 나타나는 판례가 보임

① 대법원 2005.08.19. 선고 2005다22688 판결[건물명도등]

채무자 소유의 건물 등 부동산에 “강제경매개시결정의 기입등기가 경료되어 압류의 효력이 발생한 이후에” 채무자가 위 부동산에 관한 공사대금 채권자에게 그 점유를 이전함으로써 그로 하여금 유치권을 취득하게 한 경우, 그와 같은 점유의 이전은 목적물의 교환가치를 감소시킬 우려가 있는 처분행위에 해당하여 민사집행법 제92조 제1항, 제83조 제4항에 따른 압류의 처분금지효에 저촉되므로 점유자로서는 위 유치권을 내세워 그 부동산에 관한 경매절차의 매수인에게 대항할 수 없다.

② 위 경우 유치권을 주장하는 자가 경매개시결정의 기입등기 경료에 대한 선의·무과실이 어도 매수인(경락인)에게 대항하지 못함(대판 2006. 8. 25, 2006다22050).

③ 대법원 2011.10.13. 선고 2011다55214 판결[유치권부존재확인]도 마찬가지 임.

유치권은 목적물에 관하여 생긴 채권이 변제기에 있는 경우에 비로소 성립하고(민법 제320조), 한편 채무자 소유의 부동산에 경매개시결정의 기입등기가 마쳐져 압류의 효력이 발생한 후에 유치권을 취득한 경우에는 그로써 부동산에 관한 경매절차의 매수인에게 대항할 수 없는데, 채무자 소유의 건물에 관하여 증·개축 등 공사를 도급받은 수급인이 경매개시결정의 기입등기가 마쳐지기 전에 채무자에게서 건물의 점유를 이전받았다 하더라도 경매개시결정의 기입등기가 마쳐져 압류의 효력이 발생한 후에 공사를 완공하여 공사대금채권을 취득함으로써 그때 비로소 유치권이 성립한 경우에는, 수급인은 유치권을 내세워 경매절차의 매수인에게 대항할 수 없다.

보충판례

[판례] 근저당권설정 후 경매로 인한 압류의 효력 발생 전에 취득한 유치권으로 경매절차의 매수인에게 대항할 수 있는지 여부(적극)

부동산 경매절차에서의 매수인은 민사집행법 제91조 제5항에 따라 유치권자에게 그 유치권으로 담보하는 채권을 변제할 책임이 있는 것이 원칙이나, 채무자 소유의 건물 등 부동산에 경매개시결정의 기입등기가 경료되어 압류의 효력이 발생한 후에 채무자가 위 부동산에 관한 공사대금 채권자에게 그 점유를 이전함으로써 그로 하여금 유치권을 취득하게 한 경우, 그와 같은 점유의 이전은 목적물의 교환가치를 감소시킬 우려가 있는 처분행위에 해당하여 민사집행법 제92조 제1항, 제83조 제4항에 따른 압류의 처분금지효에 저촉되므로 점유자로서는 위 유치권을 내세워 그 부동산에 관한 경매절차의 매수인에게 대항할 수 없다. 그러나 이러한 법리는 경매로 인한 압류의 효력이 발생하기 전에 유치권을 취득한 경우에는 적용되지 아니하고, 유치권 취득시기가 근저당권설정 후라거나 유치권 취득 전에 설정된 근저당권에 기하여 경매절차가 개시되었다고 하여 달리 볼 것은 아니다(대판 2009. 1. 15, 2008다70763).

【판시사항】

채납처분압류가 되어 있는 부동산에 대하여 경매절차가 개시되기 전에 민사유치권을 취득한 유치권자가 경매절차의 매수인에게 유치권을 행사할 수 있는지 여부(적극) : 채납처분압류 후에는 유치권으로 경매 매수인에게 대항 가능

【판결요지】

[다수의견] 부동산에 관한 민사집행절차에서는 경매개시결정과 함께 압류를 명하므로 압류가 행하여짐과 동시에 매각절차인 경매절차가 개시되는 반면, 국세징수법에 의한 채납처분절차에서는 그와 달리 채납처분에 의한 압류(이하 ‘채납처분압류’라고 한다)와 동시에 매각절차인 공매절차가 개시되는 것이 아닐 뿐만 아니라, 채납처분압류가 반드시 공매절차로 이어지는 것도 아니다. 또한 채납처분절차와 민사집행절차는 서로 별개의 절차로서 공매절차와 경매절차가 별도로 진행되는 것이므로, 부동산에 관하여 채납처분압류가 되어 있다고 하여 경매절차에서 이를 그 부동산에 관하여 경매개시결정에 따른 압류가 행하여진 경우와 마찬가지로 볼 수는 없다.

따라서 채납처분압류가 되어 있는 부동산이라고 하더라도 그러한 사정만으로 경매절차가 개시되어 경매개시결정등기가 되기 전에 부동산에 관하여 민사유치권을 취득한 유치권자가 경매절차의 매수인에게 유치권을 행사할 수 없다고 볼 것은 아니다.

(대법원 2014. 3. 20. 선고 2009다60336 전원합의체 판결).

【판례】 유치권자가 경락인에 대하여 피담보채권의 변제를 청구할 수 있는지 여부(소극)

민사소송법 제608조 제3항(현 민사집행법 제91조 제5항)에서 경락인은 유치권자에게 그 유치권으로 담보하는 채권을 변제할 책임이 있다는 규정은 경락인이 부동산상의 부담을 승계한다는 취지로서 인적 채무까지 인수한다는 취지는 아니다. 유치권자는 경락인에 대하여 그 피담보채권의 변제가 있을 때까지 유치목적물인 부동산상의 인도를 거절할 수 있을 뿐이고, 그 피담보채권의 변제를 청구할 수는 없다(대판 1996. 8. 23, 95다8713).

3) 유치권행사의 효과

소송경제와 당사자의 공평을 도모하기 위해서는 채권의 변제와 상환으로 목적물을 인도하여야 한다는 뜻의 상환급부판결(원고의 일부승소판결)(통설·판례)

(2) 경매권(있음)과 우선변제권(없음/사실상 우선변제효)

민법

제322조(경매, 간이변제충당)

① 유치권자는 채권의 변제를 받기 위하여 유치물을 경매할 수 있다.

② 정당한 이유있는 때에는 유치권자는 감정인의 평가에 의하여 유치물로 직접 변제에 충당할 것을 법원에 청구할 수 있다. 이 경우에는 유치권자는 미리 채무자에게 통지하여야 한다.

제323조(과실수취권)

- ① 유치권자는 유치물의 과실을 수취하여 다른 채권보다 먼저 그 채권의 변제에 충당할 수 있다. 그러나 과실이 금전이 아닌 때에는 경매하여야 한다.
- ② 과실은 먼저 채권의 이자에 충당하고 그 잉여가 있으면 원본에 충당한다.

민사집행법

제274조(유치권 등에 의한 경매)

- ① **유치권에 의한 경매**와 민법·상법, 그 밖의 법률이 규정하는 바에 따른 경매(이하 "유치권 등에 의한 경매"라 한다)는 **담보권 실행을 위한 경매의 예에 따라 실시한다.**
- ② 유치권 등에 의한 경매절차는 목적물에 대하여 강제경매 또는 담보권 실행을 위한 경매절차가 개시된 경우에는 이를 정지하고, 채권자 또는 담보권자를 위하여 그 절차를 계속하여 진행한다.
- ③ 제2항의 경우에 강제경매 또는 담보권 실행을 위한 경매가 취소되면 유치권 등에 의한 경매절차를 계속하여 진행하여야 한다.

1) 경매권

참고 : 대법원 2011.06.15. 자 2010마1059 결정

민사집행법 제91조 제2항, 제3항, 제268조는 경매의 대부분을 차지하는 강제경매와 담보권 실행을 위한 경매에서 소멸주의를 원칙으로 하고 있을 뿐만 아니라 이를 전제로 하여 배당요구의 종기결정이나 채권신고의 최고, 배당요구, 배당절차 등에 관하여 상세히 규정하고 있는 점, 민법 제322조 제1항에 “유치권자는 채권의 변제를 받기 위하여 유치물을 경매할 수 있다.”고 규정하고 있는데, 유치권에 의한 경매에도 채권자와 채무자의 존재를 전제로 하고 채권의 실현·만족을 위한 경매를 상정하고 있는 점, 반면에 인수주의를 취할 경우 필요하다고 보이는 목적부동산 위의 부담의 존부 및 내용을 조사·확정하는 절차에 대하여 아무런 규정이 없고 인수되는 부담의 범위를 제한하는 규정도 두지 않아, 유치권에 의한 경매를 인수주의를 원칙으로 진행하면 매수인의 법적 지위가 매우 불안정한 상태에 놓이게 되는 점, 인수되는 부담의 범위를 어떻게 설정하느냐에 따라 인수주의를 취하는 것이 오히려 유치권자에게 불리해질 수 있는 점 등을 함께 고려하면, 유치권에 의한 경매도 강제경매나 담보권 실행을 위한 경매와 마찬가지로 목적부동산 위의 부담을 소멸시키는 것을 법정매각조건으로 하여 실시되고 우선채권자뿐만 아니라 일반채권자의 배당요구도 허용되며, 유치권자는 일반채권자와 동일한 순위로 배당을 받을 수 있다고 보아야 한다. 다만 집행법원은 부동산 위의 이해관계를 살펴 위와 같은 법정매각조건과는 달리 매각조건 변경결정을 통하여 목적부동산 위의 부담을 소멸시키지 않고 매수인으로 하여금 인수하도록 정할 수 있다.

2) 우선변제권 : 없음

▶ 돌발 퀴즈

유치권이 우선변제권이 없다면, 질권과 저당권에 비하여 불리한 것이 아닌가?

: x

- 유치권자는 다른 담보물권자와 달리 우선변제권을 가지지 않는다. 다만 채무자나 제3자가 목적물을 인도받으려면 유치권자에게 변제하여야 한다. 또한 목적물이 유치권자 또는 제3자에 의하여 경매되는 경우에도 채권의 변제가 없는 한 유치권은 소멸하지 않기 때문에

채권담보의 측면에서는 목적물에 대하여 다른 채권보다 먼저 변제받을 수 있게 되므로 사실상 우선변제를 받는 것과 같은 결과가 된다.

※ 예외적으로 우선변제권이 인정되는 경우가 '간이변제충당'이다.

3) 간이변제충당(제322조 제2항) → 유치권자가 유치물 소유권 취득

경매 → 절차복잡. 경매가 하락 → 감정인의 평가에 의하여 유치물로 직접 변제에 충당.

간이변제충당 요건 (i) 정당한 이유를 가지고, (ii) 법원에 청구하여야 하며, (iii) 감정인의 평가에 의하여 유치물의 가치를 산정하여야 한다. 이 때 정당한 이유의 유무는 법원이 판단하여야 한다. 그리고 (iv) 간이변제충당을 하기 위해서는 법원에 신청하기 전에 채무자에게 그 뜻을 통지하여야 한다(제322조 제2항). 법원이 간이변제충당을 허가하는 결정을 하면 유치권자는 유치물의 소유권을 취득한다. 이에 의한 소유권의 취득은 법률의 규정에 의한 것이므로 등기를 요하지 아니한다(제187조). 그리고 평가액이 피담보채권액을 초과한 때에는 유치권자는 그 초과액을 채무자에게 반환하여야 하며, 그 반대의 경우에는 채무자가 부족액을 채권자에게 변제하여야 한다.

[판례] 유치물의 간이변제충당의 요건인 정당한 이유의 존부에 관한 판단 기준

유치물의 처분에 관하여 이해관계를 달리하는 다수의 권리자가 존재하거나 유치물의 공정한 가격을 쉽게 알 수 없는 등의 경우에는 민법 제322조 제2항에 의하여 유치권자에게 유치물의 간이변제충당을 허가할 정당한 이유가 있다고 할 수 없다(대결 2000. 10. 30, 2000마4002).

4) 과실수취권(제323조 제1항 본문)

천연과실·법정과실·사용이익

과실로 채권변제충당/ 과실가격은 합의 → 유치권자가 직접평가도 가능

5) 별제권

채무자가 파산한 때 : 유치권자는 별제권을 가진다(채무자회생및파산절차에관한법률 제411조).

(3) 유치물사용권

제324조(유치권자의 선관의무)

① 유치권자는 선량한 관리자의 주의로 유치물을 점유하여야 한다.

② 유치권자는 채무자의 승낙없이 유치물의 사용, 대여 또는 담보제공을 하지 못한다. 그러나 유치물의 보존에 필요한 사용은 그러하지 아니하다.

③ 유치권자가 전2항의 규정에 위반한 때에는 채무자는 유치권의 소멸을 청구할 수 있다.

원칙 : 유치권자는 사용·수익하지 못함

예외 :

1) 승낙에 의한 사용권 → 변제에 충당

2) 보존에 필요한 사용권

보존에 필요한 사용에 의하여 생긴 이익 → 그 얻은 이익 → 부당이득설(다수설·판례)

건물 또는 토지의 임차인이 그의 비용상환청구권에 관한 유치권도 마찬가지(다수설·판례)

[판 례] 유치물인 주택에 거주하며 사용하는 것이 유치물의 보존에 필요한 사용에 해당하는지 여부(적극) 및 이 경우 차임 상당 이득을 소유자에게 반환할 의무가 있는지 여부(적극)

민법 제324조에 의하면, 유치권자는 선량한 관리자의 주의로 유치물을 점유하여야 하고, 소유자의 승낙 없이 유치물을 보존에 필요한 범위를 넘어 사용하거나 대여 또는 담보제공을 할 수 없으며, 소유자는 유치권자가 위 의무를 위반한 때에는 유치권의 소멸을 청구할 수 있다고 할 것인바, 공사대금채권에 기하여 유치권을 행사하는 자가 스스로 유치물인 주택에 거주하며 사용하는 것은 특별한 사정이 없는 한 유치물인 주택의 보존에 도움이 되는 행위로서 유치물의 보존에 필요한 사용에 해당한다고 할 것이다. 그리고 유치권자가 유치물의 보존에 필요한 사용을 한 경우에도 특별한 사정이 없는 한 차임에 상당한 이득을 소유자에게 반환할 의무가 있다(대판 2009. 9. 24, 2009다40684).

(6) 비용상환청구권

제325조(유치권자의 상환청구권)

- ① 유치권자가 유치물에 관하여 필요비를 지출한 때에는 소유자에게 그 상환을 청구할 수 있다.
- ② 유치권자가 유치물에 관하여 유익비를 지출한 때에는 그 가액의 증가가 현존한 경우에 한하여 소유자의 선택에 좇아 그 지출한 금액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다. 그러나 법원은 소유자의 청구에 의하여 상당한 상환기간을 허여할 수 있다.

1) 의의

유치권자는 유치물에 관하여 지출한 비용의 상환청구권

2) 상환청구권자

비용상환청구권자는 유치권자에 한한다.

유치권이 소멸한 후에 비용을 지출한 경우

→ 제325조에 의해서가 아니라 제203조에 의하여 상환청구권을 취득할 수 있을 뿐.

3) 청구의 상대방

청구의 상대방은 유치물의 소유자

4) 필요비·유익비

5) 비용상환청구권에 의하여 유치권자는 다시 유치물 위에 유치권을 취득한다(통설)

2. 유치권자의 의무

제324조(유치권자의 선관의무)

- ① 유치권자는 선량한 관리자의 주의로 유치물을 점유하여야 한다.
- ② 유치권자는 채무자의 승낙없이 유치물의 사용, 대여 또는 담보제공을 하지 못한다. 그러나 유치물의 보존에 필요한 사용은 그러하지 아니하다.
- ③ 유치권자가 전2항의 규정에 위반한 때에는 채무자는 유치권의 소멸을 청구할 수 있다.

(1) 선관주의의무

위반 → 채무불이행으로 인한 손해배상책임을 부담한다(제390조).

(2) 사용·대여·담보제공 금지(제324조 제2항 본문).

(3) 의무위반의 효과

위의 의무를 위반한 때 → 유치권의 소멸을 청구 → 소멸청구권은 일종의 형성권(이설 없음)으로서 채무자의 일방적 의사표시에 의하여 유치권은 소멸

→ 다만 유치권이 소멸해도 그 자체로부터 목적물반환의무가 생기지는 않으며 채무자의 반환 청구에 의하여 비로소 유치권자는 채무자에게 반환의무를 부담하게 된다.

V. 유치권의 소멸

제326조(피담보채권의 소멸시효)

유치권의 행사는 채권의 소멸시효의 진행에 영향을 미치지 아니한다.

제327조(타담보제공과 유치권소멸)

채무자는 상당한 담보를 제공하고 유치권의 소멸을 청구할 수 있다.

제328조(점유상실과 유치권소멸) 유치권은 점유의 상실로 인하여 소멸한다.

1. 일반적 소멸사유

(1) 물권으로서의 소멸사유

유치권은 목적물의 멸실·공용수용·혼동·포기 등에 의하여 소멸한다. 그러나 유치권자가 유치물의 점유를 상실하면 유치권은 곧 소멸하므로(제328조), 소멸시효로 소멸하거나 취득시효의 반사적 효과로서 소멸하는 일은 없다.

(2) 담보물권으로서의 소멸사유

유치권은 담보물권의 일반적인 소멸사유인 피담보채권의 소멸로 소멸한다.

유치권만은 채권과 독립하여 소멸시효에 걸리는 일은 없다.

2. 유치권의 특유한 소멸사유

(1) 채무자의 소멸청구 유치권자가 선관주의의무 또는 유치물의 사용·대여·담보제공금지에 위반한 때에는 채무자는 유치권의 소멸을 청구할 수 있다(제324조 제3항). 채무자를 목적물의 위험으로부터 보호하려는 취지이다.

(2) 다른 담보의 제공

1) 채무자는 상당한 담보를 제공하고 유치권의 소멸을 청구할 수 있다(제327조).

채무자 + 유치물의 소유자도 청구가능

2) 담보 : 물적담보는 물론 인적담보도 가능

상당한 담보에서 상당성 판단 : 유치물 가액(5억)에 비교하지 않고 채권액(1억)에 상당하면 됨 → 따라서 1억 상당의 타담보 제공 가능

소멸청구를 하기 위하여 제공하여야 하는 담보는 유치물의 가격이 채권액에 비하여 과다한 경우에는 채권액 상당의 가치가 있는 것이면 충분하다고 할 것이다(대판 2001. 12. 11, 2001다 59866).

3) 유치권의 소멸청구 : 채무자의 일방적 의사표시

(3) 점유의 상실

유치권은 점유의 상실로 인하여 소멸한다(제328조).

점유물반환청구권에 의하여 회복한 때에는 점유는 상실되지 않은 것이 되므로(제192조 제2항 단서) 유치권도 처음부터 소멸하지 않았던 것이 된다. 그 결과 유치권자는 그 점유상실 중에 유치물로부터 분리한 과실에 관하여도 유치권을 취득할 수 있다(제323조).

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 채무자 소유가 아닌 타인의 물건에 관해서도 유치권은 성립할 수 있다.
 - ② 채권이 목적물의 반환의무와 동일한 사실관계로부터 발생한 경우에도 유치권은 성립한다.
 - ③ 유치권자에게 우선변제권은 없으나 채무자가 파산한 경우에는 별제권을 갖는다.
 - ④ 유치권은 법정담보물권이므로 유치권의 발생을 배제하는 특약은 그 효력이 없다.
 - ⑤ 유치권이 성립하려면 피담보채권은 변제기에 있어야 한다.
- ④. 유치권은 법정담보물권이며, 당사자간의 유치권의 발생을 배제하는 특약이 없어야 한다. 그러나 당사자가 미리 유치권의 발생을 막는 특약을 하면 그 특약은 유효하다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 유치권자는 채권 전부의 변제를 받을 때까지 유치물 전부에 대하여 그 권리를 행사할 수 있다.
 - ② 유치권자는 유치물의 과실을 수취하여 다른 채권보다 먼저 그 채권의 변제에 충당할 수 있다.
 - ③ 유치권자는 선량한 관리자의 주의로 유치물을 점유하여야 한다.
 - ④ 유치권자에게는 경매의 권리가 없다.
 - ⑤ 정당한 이유가 있는 때에는 유치권자는 감정인의 평가에 의하여 유치물로 직접 변제에 충당할 것을 법원에 청구할 수 있다.
- ④. 유치권자에게는 경매권은 인정되나 우선변제권은 인정되지 않는다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 유치권은 독립의 물권이며, 동시 이행의 항변권은 쌍무 계약에서 발생하는 채무에 따르는 단순한 권능이다.
 - ② 유치권뿐만 아니라 동시 이행의 항변권에도 경매권이 인정된다.
 - ③ 양자는 공평의 원리에 입각하여 채무의 이행을 확보하려고 하는 점에서는 동일하다.
 - ④ 유치권은 상당한 담보를 제공하고 소멸시킬 수 있으나, 동시 이행의 항변권은 그러하지 아니하다.
 - ⑤ 유치권에 의하여 거절되는 것은 물건의 인도이나, 동시 이행의 항변권에 의하여 거절할 수 있는 급부는 제한이 없다.
- ②. 유치권자는 채권의 변제를 받기 위하여 유치물을 경매할 수 있으나, 동시이행의 항변권에는 경매권이 인정되지 않는다.

♣ 학습정리

1. 유치권은 당사자의 약정이 없더라도 일정한 요건이 갖추어지면 법률의 규정에 의하여 당연히 성립하는 담보물권으로서 유치권자는 채권 전부의 변제를 받을 때까지 유치물 전부에 대하여 그 권리를 행사할 수 있고, 유치권자에게는 경매권이 인정되나, 우선변제권은 인정되지 않는다. 즉 물상대위성은 우선적 효력이 있는 담보물권에 인정되는데, 유치권은 유치적 기능을 중심으로 하고 우선변제적 효력이 없으므로 물상대위성이 인정되지 않는다.
2. 유치권과 동시이행항변권은 공평의 원리에 입각한 제도이고, 채권과 목적물간 또는 채권과 채무간의 견련관계가 있으며 채권이 변제기에 있을 때 법률상 당연히 발생하고, 또한 당사자의 특약으로 그 발생을 저지시킬 수 있다는 점에서 공통된다. 하지만 유치권은 오로지 유치권자의 채권담보를 목적으로 인정되는 반면에 동시이행의 항변권은 당사자 일방의 선이행이 강요당하는 것을 피하는 것을 목적으로 인정되며, 유치권은 독립한 법정담보물권으로 불가분성이 있으나 동시이행의 항변권은 독립한 권리가 아니며 권리의 가분성이 있다.
3. 유치권자는 선량한 관리자의 주의로 유치물을 점유하여야 하고, 이러한 선관주의의무에 위반하여 채무자 또는 소유자에게 손해를 입힌 경우에는 채무불이행으로 인한 손해배상책임을 부담한다.

제33강 질권 (1)

♣ 학습목표

1. 질권의 의의와 법적 성질을 이해한다.
2. 동산질권의 성립요건을 유형별로 검토한다.
3. 동산질권의 효력을 체계적으로 살펴본다.

♣ 학습내용

- 질권의 의의와 종류, 법적 성질
- 동산질권의 성립요건
- 동산질권의 효력
- 동산질권자의 전질권
- 동산질권의 소멸사유

♣ 사전 테스트

1. 질권은 당사자의 약정이 없더라도 일정한 요건이 갖추어지면 법률의 규정에 의하여 당연히 성립하는 법정담보물권이다.
⇒ × : 질권은 원칙적으로 당사자 사이의 설정계약에 의하여 성립하는 약정담보물권이다.
2. 질권자의 유치적 효력은 자기보다 우선권이 있는 채권자에 대하여 대항할 수 있다.
⇒ × : 질권자의 유치적 효력은 우선권이 있는 채권자에 대하여 대항할 수 없다(제335조 단서). 따라서 질물에 우선권을 가지는 채권자의 청구로 질물이 경매에 붙여진 경우에는 질권자는 그 배당에 가입하여 자기의 순위에 따른 금액을 받을 수 있을 뿐이고, 유치권자와 같이 자기의 채권 전부에 대한 변제가 없다는 이유로 질물의 인도를 거절하지 못한다.
3. 책임전질은 원질권과는 별개의 독립된 존재로서 원질권이 소멸하더라도 전질권자는 계속 질물을 점유 및 유치할 수 있다.
⇒ × : 이는 승낙전질에 관한 내용이다. 책임전질은 전질권의 피담보채권 및 존속기간은 원질권의 범위 내이어야 한다(제336조).

♣ 강의교안

제3절 질 권

제1항 총 설

I. 의 의

제1절 동산질권

제329조(동산질권의 내용)

동산질권자는 채권의 담보로 채무자 또는 제3자가 제공한 동산을 점유하고 그 동산에 대하여 다른 채권자보다 자기채권의 우선변제를 받을 권리가 있다.

제2절 권리질권

제345조(권리질권의 목적) 질권은 재산권을 그 목적으로 할 수 있다. 그러나 부동산의 사용, 수익을 목적으로 하는 권리는 그러하지 아니하다.

질권은 채권자가 그의 채권의 담보로서 채무자 또는 제3자(물상보증인)가 제공한 동산 또는 재산권을 채무의 변제가 있을 때까지 유치함으로써 채무의 변제를 간접적으로 강제하는 동시에 변제가 없으면 그 목적물로부터 우선변제를 받을 수 있는 담보물권이다(제329조·제345조).

질권에는 유치적 효력과 우선변제적 효력이 모두 인정

▶ 돌발 퀴즈

질권은 유치권과 우선변제적 효력이 모두 인정되기 때문에 서민금융수단의 기능으로 가장 일반적인가?

: x

- 질권은 채권의 담보로서 채무자 또는 제3자로부터 받은 물건을 점유하는 권리이다. 질권자는 피담보채권의 변제가 있을 때까지 목적물을 유치할 수 있다. 이러한 유치적 효력을 통하여 채무자에게 심리적 압박을 가하여 간접적으로 채무의 변제를 강제하는 작용을 한다. 그러나 바로 이점이 질권의 기능을 확대하는데 장애가 된다. 특히 오늘날에는 신용대출이 확대됨으로써 서민금융수단의 기능은 저하되었다.

II. 질권의 법적 성질

1. 물 권

(1) 교환가치의 지배

(2) 약정담보물권 ↔ 유치권, 법정질권(제648조·제650조), 법정저당권(제649조)

(3) 점유질주의

→ 우리민법은 점유질주의를 취하여 질권의 성립요건으로 점유의 이전을 요구한다(제330조). 따라서 점유개정에 의한 질권은 성립될 수 없다.

제330조(설정계약의 요물성)

질권의 설정은 질권자에게 목적물을 인도함으로써 그 효력이 생긴다.

제332조(설정자에 의한 대리점유의 금지) → 점유개정에 의한 질권성립 부정

질권자는 설정자로 하여금 질물의 점유를 하게 하지 못한다.

2. 유치적 효력과 우선변제적 효력

(1) 유치적 효력

- ① 동산질권 : 피담보채권의 변제가 있을 때까지 목적물을 유치 → 심리적 압박 → 변제유도
- ② 권리질권 : 유치적 효력이 사실상 문제되지 않는다.

(2) 우선변제적 효력

① 경매 → 우선변제를 받을 수 있다/ 간이변제충당

제338조(경매, 간이변제충당)

- ① 질권자는 채권의 변제를 받기 위하여 질물을 경매할 수 있다.
- ② 정당한 이유있는 때에는 질권자는 감정인의 평가에 의하여 질물로 직접 변제에 충당할 것을 법원에 청구할 수 있다. 이 경우에는 질권자는 미리 채무자 및 질권설정자에게 통지하여야 한다.

② 유질금지(제339조) → 목적물로 바로 변제에 충당 → 소유권이전형 유질/ 임의환가형 유질

제339조(유질계약의 금지)

질권설정자는 채무변제기전의 계약으로 질권자에게 변제에 갈음하여 질물의 소유권을 취득하게 하거나 법률에 정한 방법에 의하지 아니하고 질물을 처분할 것을 약정하지 못한다.

③ 채권질 : 직접 채권을 추심하여 변제에 충당(제353조)

제353조(질권의 목적이 된 채권의 실행방법)

- ① 질권자는 질권의 목적이 된 채권을 직접 청구할 수 있다.
- ② 채권의 목적물이 금전인 때에는 질권자는 자기채권의 한도에서 직접 청구할 수 있다.
- ③ 전항의 채권의 변제기가 질권자의 채권의 변제기보다 먼저 도래한 때에는 질권자는 제삼채무자에 대하여 그 변제금액의 공탁을 청구할 수 있다. 이 경우에 질권은 그 공탁금에 존재한다.
- ④ 채권의 목적물이 금전 이외의 물건인 때에는 질권자는 그 변제를 받은 물건에 대하여 질권을 행사할 수 있다.

3. 담보물권으로서의 통유성

질권은 담보물권으로서 다음과 같은 담보물권의 일반적인 성질을 가진다.

- (1) 부종성이 있다
- (2) 수반성
- (3) 불가분성이 있다
- (4) 물상대위성이 있다

제342조(물상대위)

질권은 질물의 멸실, 훼손 또는 공용징수로 인하여 질권설정자가 받을 금전 기타 물건에 대하여도 이를 행사할 수 있다. 이 경우에는 그 지급 또는 인도전에 압류하여야 한다.

제355조(준용규정) 권리질권에는 본질의 규정외에 동산질권에 관한 규정을 준용한다.

제370조(준용규정) 제214조, 제321조, 제333조, 제340조, 제341조 및 제342조의 규정은 저당권에 준용한다.

제2항 동산질권

1. 동산질권의 성립

질권설정계약 + 목적물인 동산의 인도

(단 법정질권, 질권의 선의취득도 법률의 규정에 의한 취득. 대판 1981. 12. 22, 80다2910)

[판례] 동산질권 선의취득 요건으로서의 '선의·무과실'의 증명책임

동산질권을 선의취득하기 위하여는 질권자가 평온, 공연하게 선의이며 과실없이 질권의 목적 동산을 취득하여야 하고, 그 취득자의 선의, 무과실은 동산질권자가 증명하여야 한다(대판 1981. 12. 22, 80다2910).

1. 질권설정계약

(1) 당사자

1) 질권자와 질권설정자 제3자도 무방 → 제3자를 물상보증인이라고 한다.

2) 물상보증인

제341조(물상보증인의 구상권)

타인의 채무를 담보하기 위한 질권설정자가 그 채무를 변제하거나 질권의 실행으로 인하여 질물의 “소유권을 잃은 때에는” 보증채무에 관한 규정에 의하여 채무자에 대한 구상권이 있다.

물상보증인은 자신이 피담보채권의 채무를 부담하지 않는다.

→ (즉 채무자가 아니다. 채무자인 보증인과 다르다)

[판례] 물상보증인의 구상권의 법적 성질

물상보증인은 채무자 아닌 사람이 채무자를 위하여 담보물권을 설정하는 행위이고 채무자를 대신해서 채무를 이행하는 사무의 처리를 위탁받는 것이 아니므로, 물상보증인이 변제 등에 의하여 채무자를 면책시키는 것은 위임사무의 처리가 아니고 법적 의미에서는 의무 없이 채무자를 위하여 사무를 관리한 것에 유사하다. 따라서 물상보증인의 채무자에 대한 구상권은 그들 사이의 물상보증 위탁계약의 법적 성질과 관계없이 민법에 의하여 인정된 별개의 독립한 권리이고, 그 소멸시효에 있어서는 민법상 일반채권에 관한 규정이 적용된다(대판 2001. 4. 24, 2001다6237).

[판례] 물상보증인이 사전구상권을 행사할 수 있는지 여부(원칙적 소극)

민법 제370조에 의하여 민법 제341조가 저장권에 준용되는데, 민법 제341조는 타인의 채무를 담보하기 위한 저장권설정자가 그 채무를 변제하거나 저장권의 실행으로 인하여 저장물의 “소유권을 잃은 때”에 채무자에 대하여 구상권을 취득한다고 규정하여 물상보증인의 구상권 발생 요건을 보증인의 경우와 달리 규정하고 있는 점, 물상보증은 채무자 아닌 사람이 채무자를 위하여 담보물권을 설정하는 행위이고 채무자를 대신해서 채무를 이행하는 사무의 처리를 위탁받는 것이 아니므로 물상보증인은 담보물로서 물적 유한책임만을 부담할 뿐 채권자에 대하여 채무를 부담하는 것이 아닌 점, 물상보증인이 채무자에게 구상할 구상권의 범위는 특별한 사정이 없는 한 채무를 변제하거나 담보권의 실행으로 담보물의 소유권을 상실하게 된 시점에 확정된다는 점 등을 종합하면, 원칙적으로 수탁보증인의 사전구상권에 관한 민법 제442조는 물상보증인에게 적용되지 아니하고 물상보증인은 사전구상권을 행사할 수 없다(대판 2009.07.23., 2009다19802).

(→즉 물상보증인은 소유권을 상실하고 난 후라야 채무자에게 구상할 수 있다는 의미)

(2) 질권설정계약의 성질 채권계약과 물권적 합의가 결합된 법률행위

(예 : ①금전소비대차계약 + ②질권설정계약 + ③물권적 합의 + ④동산인도)

②③ : 은 하나로 합체하여 이루어짐(②속에 ③이 포함되어 있음)

·원인행위(채권행위) : ②이다(물론 주된 계약인 ①의 영향을 받는다)
·물권행위 : ③이다.

2. 목적동산의 인도

(1) 제330조의 해석상 문제점

제188조(동산물권양도의 효력, 간이인도)

① 동산에 관한 물권의 양도는 그 동산을 인도하여야 효력이 생긴다.

제330조(설정계약의 요물성)

질권의 설정은 질권자에게 목적물을 인도함으로써 그 효력이 생긴다.

제188조 이외에 추가로 제330조를 규정한 의도가 무엇인가?

① 요물계약부정설(제330조 불요설 : 다수설)

성립요건주의에 따른 인도는 당연한 규정이고(제330조는 아무런 의미없다), 제330조는 구민법(일본민법) 그대로이다. → 폐지되어야 한다.

② 요물계약설

의사의 합치 외에 인도를 성립요건으로 하는 요물계약이다

③ 요물성설(제330조 필요설)

조문 제목이 요물계약을 전제함은 입법자의 의사이다. 다만 점유개정을 금지하고 있으므로 점유개정을 제외하는 인도이므로 요물을 요구한다.

즉 제188조 제1항은 「동산물권에 관한 양도」라고만 하였고 「양도 및 설정」이라고 하지 않았으므로 제330조는 동산질권설정에 필요한 규정이다. 또는 제188조 제1항은 동산물권의 양도에 관하여 규정할 뿐 제한물권의 설정에 관하여는 언급하지 않고 있기 때문에 제330조는 질권설정에 관하여도 형식주의가 관철됨을 규정할 필요가 있다.

④ 제2요건설 : 즉 별개의 요건이다.

질권설정계약은 당사자의 합의만으로 성립하고 제330조에 의하여 요구되는 목적물의 인도는 이러한 계약과는 별도로 요구되는 질권성립의 제2의 요건이다.

(2) 점유개정의 금지

제332조(설정자에 의한 대리점유의 금지)

질권자는 설정자로 하여금 질물의 점유를 하게 하지 못한다.

- ① 취지 : 유치적 효력을 확보(채무자가 사용·수익 못함)→ 변제압박의 목적을 달성하려는 것
- ② 그런데 점유개정의 방법에 의한 양도담보(관습법상 물권)로 위 조문의 의미는 거의 상실함

(3) 질물반환과 질권의 효력 : 질권소멸설(통설)

3. 동산질권의 목적물(질물)

제331조(질권의 목적물) 질권은 양도할 수 없는 물건을 목적으로 하지 못한다.

- (1) 동산 질권의 목적물 : 양도성 있는 동산이어야 하며, 원칙적으로 질권설정자(채무자·제3자)의 소유물이어야 한다.
- (2) 국가정책상 부인되는 것으로는 등기된 선박·자동차·항공기·건설기계 등이 있다(단, 저당권은 가능). 또한 입목에 관한 법률에 의한 입목은 저당권의 목적이 될 뿐 질권의 목적이 되지 않는다. 명인방법을 갖춘 立稻·桑葉·염연초·미분리과실도 부동산으로 취급되므로 질권의 목적이 될 수 없다고 본다.

4. 동산질권의 피담보채권

- ① 원피담보채권 → 아무 채권 가능(불법행위 손해배상채권도)
- ② 장래의 채권 또는 조건부채권을 위하여 이들 담보물권을 설정할 수 있음을 규정
- ③ 근질 인정여부

일정한 계속적인 거래(예 : 은행과 고객사이의 당좌대월계약)에서 발생하는 장래의 불특정채권을 담보하기 위하여 설정되는 담보권을 근담보(근질·근저당·근보증 등)라고 한다.

근저당(제357조), 「근질」은 규정 없지만 인정(통설)

5. 법정질권

- 임대인의 법정질권
- 토지, 건물 기타 공작물에 대하여
- 임대차에 관한 채권에 기하여 임차인 소유의 동산·과실을 대상으로

II. 동산질권의 효력

1. 동산질권의 효력이 미치는 범위

(1) 목적물의 범위

- ① 질물 : 인도된 물건전부에 그 효력이 미친다
- ② 종물 : 미친다(당연히 인도됨을 조건으로)
- ③ 천연과실 : 천연과실을 수취하여 다른 채권보다 먼저 그의 채권의 변제에 충당할 수 있다(제343조, 제323조)
- ④ 법정과실 : 질권자는 소유자의 승낙이 있으면 사용 또는 임대할 수 있다. 사용이익 또는 차임을 변제에 충당가능(제343조, 제323조)
- ⑤ 물상대위의 목적물(제342조)

제323조(과실수취권)

- ① 유치권자는 유치물의 과실을 수취하여 다른 채권보다 먼저 그 채권의 변제에 충당할 수 있다. 그러나 과실이 금전이 아닌 때에는 경매하여야 한다.
- ② 과실은 먼저 채권의 이자에 충당하고 그 잉여가 있으면 원본에 충당한다.

제324조(유치권자의 선관의무)

- ① 유치권자는 선량한 관리자의 주의로 유치물을 점유하여야 한다.
- ② 유치권자는 채무자의 승낙없이 유치물의 사용, 대여 또는 담보제공을 하지 못한다. 그러나 유치물의 보존에 필요한 사용은 그러하지 아니하다.
- ③ 유치권자가 전2항의 규정에 위반한 때에는 채무자는 유치권의 소멸을 청구할 수 있다.

제342조(물상대위) 질권은 질물의 멸실, 훼손 또는 공용징수로 인하여 질권설정자가 받을 금전 기타 물건에 대하여도 이를 행사할 수 있다. 이 경우에는 그 지급 또는 인도전에 압류하여야 한다.

물상대위

1. 의 의 질권은 목적물이 가지는 교환가치를 취득하는 것을 목적으로 하는 권리이므로 그 목적물이 멸실·훼손·공용징수로 인하여 질권이 소멸되더라도 그 교환가치를 대표하는 것이 존재하는 때에는 질권은 그 대표물 위에 존속하게 되는데, 이를 물상대위라고 한다. 민법은 질권에 관하여 이를 규정하고(제342조), 이를 다시 저당권에 준용하고 있다(제370조).

2. 목적물 물상대위의 목적물은 질물의 멸실·훼손 또는 공용징수로 인하여 「질권설정자가 받을 금전 기타의 물건(제342조)」이다. 예를 들어 질물이 보험에 들어 있는 경우의 보험금청구권(대판 2004. 12. 24, 2004다52798), 제3자의 불법행위로 질물이 멸

실·훼손된 경우의 손해배상청구권 또는 질물의 공용징수에 의한 보상금청구권 등이 그것이다.

3. 청구권발생의 원인

(a) 청구권의 발생원인은 멸실·훼손 또는 공용징수이며, 멸실·훼손이란 물리적인 멸실·훼손뿐만 아니라 법률상의 의미의 멸실·훼손(예 : 목적물의 부합·혼화·가공 등으로 질물소유자가 보상금청구권을 갖게 된 경우)도 포함된다. 그리고 멸실·훼손의 원인은 사건이든 인위적인 것이든 불문하나, 질권자의 과실에 기하지 않은 것이어야 한다.

(b) 물상대위의 목적물은 멸실·훼손·공용징수에 한하므로 그 외의 원인에 의한 경우, 예를 들어 목적물을 매각 또는 임대한 경우의 질권설정자가 받을 매각대금·차임 등의 청구는 질권자가 직접 질물에 추급할 수 있기 때문에 물상대위의 목적물이 되지 않는다.

4. 물상대위의 행사요건

- ① 인도받기 전에 압류(제342조 단서) → 일단 지급 또는 인도되어 질권설정자의 일반재산에 混入된 후에도 질권자의 추급을 허용하면 그 특정성을 상실할 뿐만 아니라 다른 채권자의 이익을 해치기 때문이다.
- ② 제3채권자가 이미 압류한 경우에도 특정성 보존의 목적은 달성
- ③ 또한 압류가 아니더라도 공탁을 통하여 특정성이 유지된다면 물상대위를 할 수 있다(대판 2000. 6. 23, 98다31899).

(2) 피담보채권의 범위

제334조(피담보채권의 범위)

질권은 원본, 이자, 위약금, 질권실행의 비용, 질물보존의 비용 및 채무불이행 또는 질물의 하자로 인한 손해배상의 채권을 담보한다. 그러나 다른 약정이 있는 때에는 그 약정에 의한다.

제321조(유치권의 불가분성) 유치권자는 채권전부의 변제를 받을 때까지 유치물전부에 대하여 그 권리를 행사할 수 있다.

[비교] 저당권의 피담보채권의 범위

제360조(피담보채권의 범위) 저당권은 원본, 이자, 위약금, 채무불이행으로 인한 손해배상 및 저당권의 실행비용을 담보한다. 그러나 지연배상에 대하여는 원본의 이행기일을 경과한 후의 1년분에 한하여 저당권을 행사할 수 있다.

1) 질권에 의하여 담보되는 채권

질물을 유치하고 있어서 동일 목적물 위에 질권이 경합하는 경우가 비교적 적기 때문에 다른 채권자를 해 할 염려가 적다. → 저당권보다 담보되는 채권의 범위가 더 넓다.(즉 저당권은 후순위 저당권자가 많이 있기 때문에 지연배상을 1년으로 제한함)

2) 불가분성

이자의 일부만이 존재하는 경우에도 목적물 전부를 유치하고, 또 그 전부를 경매할 수 있다.

2. 유치적 효력

제335조(유치적 효력)

질권자는 전조의 채권의 변제를 받을 때까지 질물을 유치할 수 있다. 그러나 자기보다 우선권이 있는 채권자에게 대항하지 못한다.

유치권의 유치와 질권의 유치적 효력 차이

- 유치권 : 유치권 성립시기 보다 앞서는 저당권 질권이 있어도 유치가능 → 사실상 우선변제 효(단 경매개시결정등기 이후 유치권성립으로 대항하지 못함. 판례)
- 질권 : 유치권과는 달리 우선변제적 효력도 가지고 있기 때문에 질권의 유치적 효력은 유치권의 효력처럼 강할 필요가 없다. → 제335조 단서(즉 순위에 따라 우선변제적).

3. 우선변제적 효력

(1) 질권자의 순위

우선변제적 효력(제329조) / 설정 순위에 따른 순위

제329조(동산질권의 내용) 동산질권자는 채권의 담보로 채무자 또는 제삼자가 제공한 동산을 점유하고 그 동산에 대하여 다른 채권자보다 자기채권의 우선변제를 받을 권리가 있다.

제333조(동산질권의 순위) 수개의 채권을 담보하기 위하여 동일한 동산에 수개의 질권을 설정한 때에는 그 순위는 설정의 선후에 의한다.

→ 질권은 점유를 요건으로 하지만 이러한 점유에는 간접점유도 포함되므로 동일한 동산에 수개의 질권이 성립될 수 있다. 예를 들어 소유자 A는 B가 보관하고 있는 자기의 시계를 먼저 C를 위하여 질권을 설정하면서 목적물반환청구권의 양도에 의한 인도를 하고(제190조), D를 위하여 다시 질권을 설정하면서 마찬가지로 목적물반환청구권의 양도에 의한 인도를 한 경우에는 동일한 시계에 C와 D의 질권이 설정되는 것이다.

B(임차인) -- A(임대인, 소유자) ----- → C(제1질권자) 목적물반환청구권에 의한 인도 받음
----- → D(제2질권자) 목적물반환청구권에 의한 인도 받음

(2) 우선변제권의 행사

1) 요건

변제가 도래 후 변제가 없을 것

2) 행사 방법

제338조(경매, 간이변제총당)

- ① 질권자는 채권의 변제를 받기 위하여 질물을 경매할 수 있다.
- ② 정당한 이유있는 때에는 질권자는 감정인의 평가에 의하여 질물로 직접 변제에 총당할 것을 법원에 청구할 수 있다. 이 경우에는 질권자는 미리 채무자 및 질권설정자에게 통지하여야 한다.

(3) 일반재산으로부터의 변제

제340조(질물 이외의 재산으로부터의 변제)

- ① 질권자는 질물에 의하여 변제를 받지 못한 부분의 채권에 한하여 채무자의 다른 재산으로부터 변제를 받을 수 있다.
- ② 전항의 규정은 질물보다 먼저 다른 재산에 관한 배당을 실시하는 경우에는 적용하지 아니한다. 그러나 다른 채권자는 질권자에게 그 배당금액의 공탁을 청구할 수 있다.

Q : 질물에 대하여 질권을 실행하지 않고 처음부터 채무자의 일반재산에 대하여 집행할 수 있는가?(있다. 다만 일반채권자는 이의를 제기할 수 있다. 채무자는 이의제기 못함 : 다수설)

- ① **부정설** : 민법 제340조의 규정이 일반채권자의 보호만을 목적으로 하는 것이 아니라 채무자도 함께 보호할 것을 목적으로 하고 있기 때문에 채무자도 이를 근거로 이의를 제기할 수 있다. 그리고 질권설정시에 질물에 대한 질권실행을 우선할 것이 묵시적으로 합의되었다고 해석되므로 특별한 사정이 없는 한 담보물로부터 변제받는 것이 타당하다.
- ② **긍정설(다수설)** : 민법 제340조 제1항은 단지 일반채권자를 보호하기 위한 규정이므로 질권자가 질권을 실행하지 않고 채무자의 일반재산에 대하여 먼저 집행하더라도 채무자는 아무런 이의를 제기할 수 없는 것으로 본다. 다만 일반채권자만이 이의를 할 수 있다.

(3) 유질계약의 금지

1) 의의 및 기능

- ① 질권설정자가 질권설정계약과 동시에 또는 변제기 전의 계약으로써 질권자에게 변제에 갈음하여 질물의 소유권을 취득시키거나 법률에 정한 방법에 의하지 아니하고 질물을 처분할 것을 약정할 수 없다(제339조). 이를 流質契約의 禁止라고 한다. → 폭리행위방지
- ② 서민금융을 압박 → 이미 동산양도담보나 환매약관부 매매가 유효한 것으로 인정 → 실질적으로 유질계약금지의 실효성은 상실, 상사질에서는 유질계약이 허용(상법 제59조) 실제거래에서 유질계약이 광범위하게 허용되고 있는 실정임. → 폐지하자는 주장의 이유

2) 요건

- ① 유질계약이 변제기 전에 체결
- ② 질권자가 질물의 소유권 취득
- ③ 법률에 정한 방법(경매·간이변제총당)에 의하지 아니하고 질물을 처분할 것을 약정

3. 효 과

- ① 유질계약은 당연히무효이다. 다만 질권설정계약 자체가 무효로 되는 것이 아니다(통설).
- ② 통설에 의하면 질권설정계약 자체가 무효로 되는 것이 아니므로 질권은 본래의 채권을 담보하고 또한 법률이 정한 방법에 따라 질물을 처분하여야 한다.
- ③ 질물의 가격과 채권액이 별 차이가 없는 경우 : 계약유효설(다수설 ↔ 반대 이영준)

4. 동산질권자의 전질권

책임전질

제336조(전질권)

질권자는 그 권리의 범위내에서 자기의 책임으로 질물을 전질할 수 있다. 이 경우에는 전질을 하지 아니하였으면 면할 수 있는 불가항력으로 인한 손해에 대하여도 책임을 부담한다.

제337조(전질의 대항요건)

- ① 전조의 경우에 질권자가 채무자에게 전질의 사실을 통지하거나 채무자가 이를 승낙함이 아니면 전질로써 채무자, 보증인, 질권설정자 및 그 승계인에게 대항하지 못한다.
- ② 채무자가 전항의 통지를 받거나 승낙을 한 때에는 전질권자의 동의없이 질권자에게 채무를 변제하여도 이로써 전질권자에게 대항하지 못한다.

승낙전질

제343조(준용규정)

제249조 내지 제251조, 제321조 내지 제325조의 규정은 동산질권에 준용한다.

제324조(유치권자의 선관의무)

- ① 유치권자는 선량한 관리자의 주의로 유치물을 점유하여야 한다.
- ② 유치권자는 채무자의 승낙없이 유치물의 사용, 대여 또는 담보제공을 하지 못한다. 그러나 유치물의 보존에 필요한 사용은 그러하지 아니하다.
- ③ 유치권자가 전2항의 규정에 위반한 때에는 채무자는 유치권의 소멸을 청구할 수 있다.

[참 고] 승낙전질을 부정하는 견해

민법이 인정하는 전질권은 책임전질뿐이고 승낙전질을 인정하지 않는 견해가 있다. 그 이유로 ① 승낙전질은 채무자 및 물상보증인의 이익을 부당하게 침해하고, ② 채무자의 ‘전질에 대한 승낙’은 책임전질의 대항요건으로서의 의의를 가지며 승낙전질을 발생시키는 요건이 되지 아니하며, ③ 복수질권의 설정은 채무자 또는 그의 물상보증인이 할 수 있을 뿐이며, ④ 전질로 인하여 발생한 손해는 원질권자가 배상하는 것이 타당하다는 것을 들고 있다.

(1) 책임전질

- 1) 성 질 책임전질은 질권자가 질권설정자의 승낙 없이 자기의 책임아래 질물 위에 다시 질권을 설정하는 것인데, 그 성질에 관하여 학설이 나뉜다.

(가) 질물재입질설 전질은 원질권자가 자기의 채무를 담보하기 위하여 질물 위에 다시 질권을 설정하는 것으로서 「질물의 전질」이라고 규정한 제336조의 문언에도 합치된다고 한다.

(나) 채권·질권공동입질설(통설) 질권의 부종성을 주요한 이유로 하며, 현행 민법은 구 민법과는 달리 민법 제337조에서 질권뿐 아니라 채권도 함께 입질된다고 하는 것을 전제로 하여 규정하고 있다는 점에서 피담보채권과 함께 질권이 전질권의 목적이 된다는 견해로서 독일의 통설이며 우리나라의 현재의 통설이다.

2) 성립요건(채권·질권공동입질설)

(가) 입질에 관한 물권적 합의 + 질물의 인도

(나) 전질권의 피담보채권액·존속기간은 원질권의 범위 내이어야 한다(제336조).

(다) 전질대항요건(제337조 제1항).

3) 효 과

(가) 전질권설정자의 의무와 책임

(a) 전질권설정자의 책임가중(제336조 후단). 예를 들어 전질권자가 질물인 TV를 보관하고 있는 주택이 태풍에 의하여 붕괴되고 그 질물도 함께 파손 되었으나 원질권자의 주택은 붕괴되지 않은 경우에도 원질권자는 배상책임을 진다.

(b) 원질권자에 대한 구속 : 원질권자는 전질권자의 이익을 해하는 행위를 하지 못한다(제352조 참조). → 질권포기 X, 채무면제 X

(c) 원질권설정자에 대한 구속 : 통지 승낙한 경우 채무자(원질권설정자)가 원질권자에게 채무를 변제하더라도 전질권자에 대하여 질물의 반환을 청구하지 못한다(제337조 제2항).

(나) 전질권자의 권리

(a) 전질권자의 인도거절권

(b) 전질권자의 변제수령 → 원질권자에게 반환

그리고 전질권자는 채권질권자와 같은 지위에서 원질권자의 피담보채권을 질권설정자에게 직접 청구하고 급부목적물을 수령할 수 있다(제353조 제1항·제2항).

제353조(질권의 목적이 된 채권의 실행방법)

① 질권자는 질권의 목적이 된 채권을 직접 청구할 수 있다.

② 채권의 목적물이 금전인 때에는 질권자는 자기채권의 한도에서 직접 청구할 수 있다.

(c) 경매권 및 간이변제충당권 단, 전질권자가 질권을 행사하려면 자기채권 외에 원질권자의 채권도 변제기가 도래하여야 한다.

(d) 환가우선변제권

(2) 승낙전질

1) 성 질 승낙전질은 질권자가 질권설정자의 승낙을 얻어 자기의 채무를 위하여 그 질물위에 다시 질권을 설정하는 것이다(제343조·제324조 제2항). 승낙전질은 책임전질과는 달리 질권설정자(질물소유자)의 처분의 승낙을 얻어서 전질하는 것이므로 원질권과는 별개의 독립

된 존재이며 그 요건·효과는 승낙전질의 내용에 의하여 결정된다. 따라서 승낙전질의 법적 성질은 질물의 재입질이라고 할 것이다(이설없음).

2) 성립요건

(가) 질물소유자의 승낙을 얻어야 한다. 승낙 없이 재입질하면 원질권설정자는 제324조 제2항에 의하여 전질의 소멸을 청구할 수 있다(제343조).

(나) 승낙전질은 원질권의 범위에 의하여 제한을 받지 않는다. 따라서 초과전질도 유효하며, 또한 존속기간도 원질권과 무관하게 정할 수 있다.

(다) 민법 제337조의 적용이 없으므로 원질권자는 채무자에게 전질의 사실을 통지할 필요가 없다.

3) 효 과

(가) 책임전질과 같은 질물에 관한 질권자의 가중된 책임은 없다. 즉 불가항력에 의한 손해배상 의무를 부담하지 않는다.

(나) 원질권설정자는 자기의 채무를 원질권자에게 변제하여 질권을 소멸시킬 수 있다. 그러나 원질권자의 질권이 소멸하여도 전질권자의 질권에는 영향이 없다. 따라서 원질권이 소멸해도 전질권자는 계속 질물을 점유·유치할 수 있다.

(다) 원질권설정자가 원질권자에게 채무를 변제하는 데 전질권자가 동의한 경우에는 그 변제로 원질권설정자는 전질권자에게 대항할 수 있다(제337조 제2항). 따라서 그 변제로 원질권이 소멸하면 질물소유자는 질물의 반환을 청구할 수 있다(통설).

5. 동산질권의 침해에 대한 효력

① 물권적청구권 → 제213조 제214조 유추적용(통설)

② 채무자가 멸실·훼손시 기한의 이익상실 → 질권자는 피담보채권의 즉시이행 청구, 손해배상 청구

③ 제3자가 질물훼손 → 제3자를 상대로 손해배상청구권

6. 동산질권자의 의무

(1) 질물보관의무

선량한 관리자의 주의를 가지고 질물을 점유(제343조·제324조 제1항)

(2) 질물반환의무

질물이 제3자의 소유인 경우에도 질권자는 언제나 이를 질권설정자에게 반환(통설)

III. 증권에 의하여 표상되는 동산의 입질과 화환

1. 증권에 의한 동산질

질권설정계약(합의) + 증권의 배서·교부

(1) 운송증권에 의한 입질 : 화물상환증과 선하증권을 통틀어서 「운송증권」이라고 한다.

(2) 창고증권에 의한 입질

(3) 증권에 의한 질권의 실행방법 : 증권의 처분 또는 상품의 인도 및 처분으로 우선변제받음

2. 환환(환어음 + 운송증권)

- ① 환환이란 격지자간의 송부매매에서 매도인이 대금채권을 가지고 금용을 얻거나 대금의 추심을 위임하기 위하여, 매수인 또는 그가 지정하는 은행을 지급인으로 하여 환어음을 발생하고, 이 환어음에 담보로서 매매목적물을 표상하는 운송증권을 첨부한 것을 말한다.
- ② 매도인이 위의 운송증권을 담보로 은행으로부터 대금의 융통(어음의 할인)을 받으면, 그 증권에 의하여 표상되는 목적물 위에 은행을 위한 질권이 성립한다. 이 질권은 권리질이 아니라 동산질이다.

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 원질권자와 전질권자 사이에 물권적 합의와 질물의 인도가 있어야 성립한다.
- ② 전질권의 피담보채권액은 원질권의 피담보채권액을 넘지 못한다.
- ③ 전질권설정자는 전질을 하지 않았더라면 생기지 않았을 불가항력에 의한 손해를 배상할 책임이 있다.
- ④ 책임전질권은 원질권과의 관계에서 독립성을 가지므로 전질권자는 원질권자의 채권의 변제기와는 관계없이 전질권을 실행할 수 있다.
- ⑤ 질권자가 채무자에게 전질의 사실을 통지하지 않으면 전질로써 채무자·보증인·질권설정자 및 그 승계인에게 대항하지 못한다.

정답 ④. 전질권의 피담보채권액 및 존속기간은 원질권의 범위 내이어야 한다(제336조). 전질권의 피담보채권의 변제기간은 원질권의 채권의 변제기보다 늦어서는 안 된다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 질권은 유치적 효력이 인정된다는 점에서 유치권과 같고, 우선변제적 효력이 인정된다는 점에서 저당권과 같다.
- ② 물상보증인은 채무자의 의사에 반한 변제를 할 수 있다.
- ③ 동산질권에 있어서 질물을 반환한 경우에 다수설은 질권이 소멸한다고 한다.
- ④ 책임전질에 있어서 전질권은 피담보채권 및 존속기간에 있어서 원질권을 초과하는 경우 그 효력이 없다.
- ⑤ 책임전질과는 달리, 승낙전질의 법적 성질은 질물의 재입질이라고 하여야 한다.

정답 ④. 전질권의 피담보채권액은 원질권의 채권액을 초과할 수 없다. 만일 원질권의 채권액을 초과할 때에는 그 초과액은 전질권의 피담보채권이 되지 못한다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 질권자는 그의 채권의 전액을 변제받을 때까지 목적물의 점유를 계속하고 그 반환을 거부할 수 있으며, 자기보다 우선권이 있는 채권자에 대해서도 대항할 수 있으므로 그러한 우선권이 있는 채권자에 의하여 목적물이 경매되는 때에 질권자는 자신의 채무가 변제되지 않았음을 이유로 하여 목적물의 인도를 거부할 수 있다.
- ② 채무자의 승낙 없이 그 목적물을 사용, 대여 또는 담보제공을 하지 못하나, 그 목적물의 보존에 필요한 사용은 할 수 있다.

- ③ 그 목적물로부터 다른 채권자보다 자기 채권의 우선변제를 받을 수 있으나, 당해 질권자에 우선하는 질권자에 대해서는 우선변제의 권능이 제한된다.
- ④ 질권자는 그 목적물의 과실을 수취하여 우선적으로 채권변제에 충당할 수 있다.
- ⑤ 질권설정자나 제3자가 질권자의 점유를 침해할 때에는 질권자는 점유권에 기하여 점유보호 청구권을 행사할 수 있다.

정답 ①. 질권자는 채권의 변제를 받을 때까지 질물을 유치할 수 있다. 그러나 자기보다 우선권이 있는 채권자에게 대항하지 못한다(민법 제 335조).

♣ 학습정리

1. 질권은 유치적 효력이 인정된다는 점에서 유치권과 유사하며, 우선변제적 효력이 인정된다는 점에서 저당권과 같다. 특히 질권은 당사자 사이의 설정계약에 의하여 성립하는 약정담보물 권으로 질물에 대한 유치권과 우선변제권을 가지고 있으므로 우선변제권만 있는 저당권과 구별된다.
2. 동산질권은 원칙적으로 당사자 사이의 질권설정계약과 목적물인 동산의 인도에 의하여 성립하고, 법정질권은 예외적인 경우(부동산임대인의 채권)에 한하여 우선변제를 확보할 수 있도록 한다.
3. 전질이란 질권자가 채권담보로서 인도받아 유치하는 질물을 이용하여 다시 자신의 제3자에 대한 채무를 담보하기 위하여 질권을 설정하는 것을 말한다. 특히 책임전질은 질권자가 질권 설정자의 승낙 없이 자기의 책임아래 질물에 다시 질권을 설정하는 것이기 때문에 전질권의 피담보채권액 등은 원질권의 채권액을 초과할 수 없지만, 승낙전질은 원질권과는 별개의 독립된 존재이며 그 요건과 효과는 승낙전질의 내용에 의하여 결정되기 때문에 원질권자의 질권이 소멸하더라도 전질권자의 질권은 소멸하지 않는다.

제34강 질권 (2), 저당권 (1)

♣ 학습목표

1. 권리질권의 개념과 종류를 유형별로 이해한다.
2. 채권질권의 설정 및 효력을 살펴본다.
3. 저당권의 의의와 성립요건을 체계적으로 검토한다.

♣ 학습내용

- 권리질권의 개념과 종류
- 채권질권의 설정 및 효력
- 저당권의 의의와 법적 성질
- 저당권의 성립요건

♣ 사전 테스트

1. 채권질권은 동산질권과 달리 당사자 사이의 질권설정의 합의와 공시방법에 의하지 않는다.
⇒ × : 권질권은 동산질권과 마찬가지로 당사자 사이의 질권설정의 합의와 공시방법에 의하여 성립한다. 권리질권의 설정은 법률에 다른 규정이 없으면 그 권리의 양도에 관한 방법에 의하여야 한다.
2. 채권질권의 효력은 피담보채권액의 입질채권액보다 적은 경우에는 무효가 된다.
⇒ × : 채권질권의 효력은 입질된 원본채권 및 이자에 미치며(제100조2항), 피담보채권액의 입질채권액보다 적은 때에도 질권의 효력은 입질채권의 전부에 미친다.
3. 저당권은 피담보채권이 무효로 되거나 취소되더라도 그 효력에는 영향을 미치지 않는다.
⇒ × : 저당권은 부종성을 지니고 있기 때문에 피담보채권이 무효로 되거나 취소되는 경우에는 그 저당권도 무효로 되거나 효력을 잃는다(제361조).

♣ 강의교안

제3항 권리질권

I. 총 설

1. 권리질권의 의의(채권질권/ 주식질권(상법규율)/ 지식재산권질권(해당법규율))

제345조(권리질권의 목적)

질권은 재산을 그 목적으로 할 수 있다. 그러나 부동산의 사용, 수익을 목적으로 하는 권리는 그러하지 아니하다. → (예 : 지상권·전세권·부동산임차권의 질권 불가)

2. 권리질권의 설정방법

제346조(권리질권의 설정방법)

권리질권의 설정은 법률에 다른 규정이 없으면 그 권리의 양도에 관한 방법에 의하여야 한다.

- ① 지명채권 : 질권설정계약 + 통지승낙은 대항요건(단 채권증서 있으면 교부한다 제347조)
- ② 지시채권(예 : 어음·수표) : 질권설정계약 + 배서·교부
- ③ 무기명채권(예 : 상품권) : 질권설정계약 + 교부
- ④ 지식재산권 : 질권설정계약 + 등록원부에 등록(성립요건주의. 저작권의 경우 대항요건주의)

II. 채권질권

1. 채권질권의 설정

(1) 채권질권의 목적

1) 질권의 목적으로 될 수 있는 채권

- ① 양도성 : 매수인에 대한 매매대금채권, 도급인에 대한 공사대금채권, 금전의 차주에 대한 대금채권, 은행에 대한 예금채권(제355조·제331조).
- ② 채권은 질권자 자신에 대한 것 : 예를 들어 은행이 정기예금 위에 질권을 취득하고 예금자에게 금용을 주거나, 보험회사가 보험금 위에 질권을 취득하고 보험가입자에게 금용을 주는 경우 → 이러한 경우의 질권의 실행은 일반적으로 상계(제492조 참조)의 방법으로 행함

2) 질권의 목적으로 될 수 없는 채권

(가) 법률상 담보의 제공이 금지된 채권

공무원 또는 군인의 연금청구권(공무원연금법 제12조·군인연금법 제7조)

(나) 양도성이 없는 채권

(a) 법률상 양도가 금지된 채권

부양청구권(제979조)·연금청구권·근로자의 재해보상청구권

(b) 성질상 양도성이 없는 채권

그림그리는 것, 강의하는 것

(c) 양도금지 특약이 있는 채권(제449조 제2항 단서).

단, 이 특약은 선의의 제3자에게 대항할 수 없으므로(제449조 제2항 단서), 질권자가 선의이면 질권은 유효하게 성립한다.

※ 저당권부 채권

제348조(저당채권에 대한 질권과 부기등기)

저당권으로 담보한 채권을 질권의 목적으로 한 때에는 그 저당권등기에 질권의 부기등기를 하여야 그 효력이 저당권에 미친다.

→ 附記登記가 없으면 채권자는 無擔保債權에 관하여만 질권을 취득하는 것이 된다(통설)

2. 채권질권의 효력

(1) 효력의 범위

채권질권이 담보하는 채권의 범위는 동산질권의 경우와 같다(제355조·제334조). 불가분성이 있다는 것도 동산질권의 경우와 같다(제355조·제343조·제321조).

(2) 유치적 효력

1) 채권증서의 유치

채권질권자 교부받은 채권증서를 점유하고, 피담보채권의 전부의 변제를 받을 때까지 이를 유치할 수 있다(제335조·제355조). 그러나 채권이라는 것은 교환가치를 가지고 있을 뿐 사용가치는 적기 때문에 채권질권은 질권보다도 저당권에 가까운 작용을 하는 것이다.

2) 질권설정자 및 제3채무자에 대한 구속력

제352조(질권설정자의 권리처분제한)

질권설정자는 질권자의 동의없이 질권의 목적된 권리를 소멸하게 하거나 질권자의 이익을 해하는 변경을 할 수 없다.

채권질권자는 채권의 추심권능과 환가권능을 가지므로(제355조·제335조), 채권질권의 설정자 및 제3채무자는 이 권능을 해하는 행위를 하지 못한다. 이는 채권질권의 유치적 효력과 관련하여 채권질권자를 보호하는데 그 목적이 있다. 따라서 질권설정자는 질권자의 동의 없이 질권의 목적이 된 권리를 소멸(예 : 채권의 추심·면제·상계·변제의 수령 등)하게 하거나 질권자의 이익을 해하는 변경(예 : 경개·변제의 연장·이율의 감소 등)을 할 수 없다(제352조). 결국 채권질권의 설정에 의하여 입질채권은 질권자의 채권만족을 위하여 질권설정시와 같은 상태로 존재하게 된다.

(3) 우선변제적 효력

1) 입질채권의 실행방법

제353조(질권의 목적이 된 채권의 실행방법)

- ① 질권자는 질권의 목적이 된 채권을 직접 청구할 수 있다.
- ② 채권의 목적물이 금전인 때에는 질권자는 자기채권의 한도에서 직접 청구할 수 있다.
- ③ 전항의 채권의 변제기가 질권자의 채권의 변제기보다 먼저 도래한 때에는 질권자는 제삼채무자에 대하여 그 변제금액의 공탁을 청구할 수 있다. 이 경우에 질권은 그 공탁금에 존재한다.
- ④ 채권의 목적물이 금전 이외의 물건인 때에는 질권자는 그 변제를 받은 물건에 대하여 질권을 행사할 수 있다.

제354조(동전)

질권자는 전조의 규정에 의하는 외에 민사집행법에 정한 집행방법에 의하여 질권을 실행할 수 있다.

(가) 채권질권자는 입질채권의 이자를 수취하여 이를 우선변제에 충당할 수 있다(제355조·제343조·제323조). 그러나 채권질권자가 우선변제를 받는 주된 방법은 입질채권자체로부터 우선변제를 받는 것이다.

(나) 채권질권의 두 가지의 실행방법

- ① 채권을 직접청구는 방법(제353조)
- ② 민사집행법이 정하는 집행방법(제354조·민사집행법 제273조)

2) 채권의 직접청구

(가) 질권자가 ‘자기의 이름으로’ 청구(통설). (대위 X)

효과는 그 채권의 채권자에게 귀속하는 것이지만 당연히 질권자의 채권에 충당되는 것이 아니다. 따라서 제3채무자에 의한 변제는 피담보채권에 대한 변제가 아니고 질권설정자에 대한 채무이행의 의미를 가진다고 할 것이다.

(나) 입질채권이 금전채권인 경우

질권자는 자기의 채권액의 한도에서 직접 청구하고, 변제에 충당할 수 있다(제353조 제2항).

(다) 입질채권이 「금전 이외의 물건」(예 : 채권이 동산인도청구권인 경우)인 경우

추심한 물건으로 직접변제에 충당할 수 없으므로, 질권자는 그 변제받은 물건에 대하여 질권을 행사할 수 있다(제353조 제4항). 따라서 이때부터는 채권질권은 동산질권으로 변하여 존속하므로, 동산질권의 실행방법에 의하여 우선변제를 받아야 한다.

[판례] 채권질권의 효력 범위 및 그 실행 방법

질권의 목적이 된 채권이 금전채권인 때에는 질권자는 자기채권의 한도에서 질권의 목적이 된 채권을 직접 청구할 수 있고, 채권질권의 효력은 질권의 목적이 된 채권의 지연손해금 등과

같은 부대채권에도 미치므로 채권질권자는 질권의 목적이 된 채권과 그에 대한 지연손해금채권을 피담보채권의 범위에 속하는 자기채권액에 대한 부분에 한하여 직접 추심하여 자기채권의 변제에 충당할 수 있다(대판 2005. 2. 25, 2003다40668).

3) 민사집행법에 의한 집행방법

질권자는 채권의 직접청구에 의하여 않고 「민사집행법」에 의해서도 질권을 실행할 수 있다(제354조). 집행방법은 채권의 추심·전부 및 현금화의 세 방법이 있다(민사집행법 제273조·제223조 이하). 집행권원은 필요하지 않고, 질권의 존재를 증명하는 서류의 제출만으로 실행된다(민사집행법 제273조 제1항).

3) 유 질

채권질권에 관하여서도 유질계약금지에 관한 제339조가 준용된다(제355조).
단, 금전채권의 입질은 직접청구, 변제충당(통설)

III. 기타의 권리질권

1. 주식 위의 질권 → 상법

2. 지적재산권 위의 질권 → 성립요건주의/대항요건주의(저작권)

제4절 저당권

제1항 총 설

I. 의의 및 사회적작용

1. 저당권의 의의

제356조 (저당권의 내용) 저당권자는 채무자 또는 제삼자가 점유를 이전하지 아니하고 채무의 담보로 제공한 부동산에 대하여 다른 채권자보다 자기채권의 우선변제를 받을 권리가 있다.

/ 기타 특별법상 저당

2. 사회적 작용

(1) 금융수단으로서의 작용

담보물을 유치하지 않아 질권보다 활용도가 큼

(2) 투자의 매개작용

특정채권의 변제를 담보하는 보전저당권 → 투자의 수단 내지 투자의 대상으로 이용되는 투자저당권

II. 근대적 저당권과 우리의 저당제도

1. 공시의 원칙

공시함으로써 저당권의 존재를 알려 일반채권자가 입을 수 있는 불측의 손해 방지

예외 : 법정저당권, 저당권보다 우선하는 국세 및 공과금(우리민법 원칙 채택)

2. 특정의 원칙

저당목적물의 현존특정 -> 피담보채권액, 저당목적물 특정

↔ 채무자의 전재산에 설정하는 일반저당권 부정

예외 법정저당권, 조세우선평권(우리민법 원칙 채택)

3. 순위확정의 원칙

① 동일 목적물 위에 설정된 저당권은 설정된 순위에 결정된다(우리민법 채택)

② 한번 주어진 순위는 선순위 저당권이 소멸하더라도 그 순위가 올라가지 않는다.

(우리민법 채택 X, 즉 순위승진의 원칙)

→ 순위확정의 원칙을 인정하기 위해서는

첫째, 채권이 없음에도 불구하고 저당권 존재를 인정(부종성완화)

둘째, 소유자 스스로 자기의 소유물 위에 저당권 가지는 것을 인정(소유자저당권인정)

결국 순위가 확정되면 근대저당권의 성질인 투자저당권의 이론적 기초가 된다.

4. 독립의 원칙

① 피담보채권과 독립

저당권을 피담보채권의 종된 권리가 아닌, 피담보채권과 분리하여 가치권으로서 금융거래에서 독립된 지위를 보장하는 원칙

(즉 피담보채권에 독립하여 저당권을 투자의 대상 또는 독자의 상품으로 유통) → 이를 위해서는 부종성(피담보채권의 성립·존속·소멸)이 부인되어 완전히 추상적으로 존재하여야 한다 (추상화의 원칙)

(예 : 독일의 토지채무)

(우리민법 채택 X, 361조 피담보채권과 분리양도, 분리담보금지/369조 피담보채권소멸 시 저당권도 당연히 소멸 → 부종성을 본질로 함/ 단 근저당권은 부종성 완화)

② 후순위저당권실행과 독립

후순위저당권의 실행으로 말미암아 변제를 강요당하지 아니한다

(특정채권담보목적이 아닌 유통저당권목적인 경우 → 독일민법채택 따라서 후순위저당권이 실행되더라도 선순위저당권은 매수인에게 인수되는 것으로 본다(인수주의))

(우리민법 채택 X, 즉 후순위저당권에 의한 경매는 물론 전세권 등에 의한 경매가 있는 경우 선순위저당권도 소멸한다(소제주의))

③ 채권자의 일반재산으로부터 독립

저당권자는 자기가 파악한 교환가치만을 추구하고 채무자의 일반재산에 대하여 집행하는 것은 일반채권자의 지위에 위협이 된다 → 독일민법의 채권적 기초 없는 저당권(토지채무)

(우리민법 부분적 채택 : 340조 제1항, 제370조 담보목적물에 의하여 변제를 받지 못한 부분의 채권에 한하여 채무자의 일반 재산으로부터 변제를 받을 수 있다.

④ 저당목적물을 이용하는 자로부터 독립

저당권의 목적인 부동산을 양수한 자는 스스로 저당권자에게 변제하여 저당권을 소멸시킬 수 있는 권리인 척제제도(구민법 제378조)는 인정되지 않는다.

(독일, 우리민법 채택)

5. 유통성의 확보

저당권 자체를 담보가치로 파악하여 이를 금융거래시장에 하는 작용

(공신의 원칙과 저당권의 증권화제도 이용함)

① 저당권의 공신의 원칙 : 등기부의 기재를 믿고 저당권을 취득한 자는 피담보채권의 하자에 불이익 받지 않는다

(우리민법 채택 X)

② 저당권의 증권화 : 저당권을 증권화하여 등기부로부터 독립시켜 그 거래의 안전을 유가증권 이론에 의하여 확보(독일의 저당증권, 저당채권 등)

(우리민법 채택 X, 단 자산유동화에 관한 법률, 주택저당채권유동화회사법에서 인정)

▶ 돌발 퀴즈

우리나라의 저당권은 근대적 저당권 원칙과 내용이 동일하다.

: x

- 우리 민법상 저당제도에서는 근대적 저당권의 원칙과는 상당히 다르다. 그 이유는 우리의 저당제도는 특정채권의 담보를 위한 것에 국한되어 있기 때문이다. 그래서 금융기관의 대출도 외국의 경우 신용대출이 중요하지만, 우리의 경우 담보대출이 중요하다고 볼 수 있다. 특히 우리 민법은 순위승진의 원칙을 채택하고 있으며, 저당권은 피담보채권과 그 운명을 같이하는 부종성을 인정하고 있고, 등기를 통하여 성립하며, 증권화하지 않는 점이 그러한 예이다.

III. 저당권의 법적 성질

1. 제한물권

우선변제적효력에 의하여 목적물의 교환가치를 직접배타적으로 지배하는 제한물권이다.

2. 담보물권

(1) 약정담보물권

법정저당권은 예외적으로만 인정(제649조).

제649조(임차지상의 건물에 대한 법정저당권)

토지임대인이 변제기를 경과한 최후 2년의 차임채권에 의하여 그 지상에 있는 임차인소유의 건물을 압류한 때에는 저당권과 동일한 효력이 있다.

(2) 담보물권으로서의 통유성

1) 타물권이다

우리민법에서는 근대적저당권의 특질의 하나인 소유자저당권은 인정되지 않는다.

2) 부종성

3) 수반성

그러나 물상보증인이 설정한 저당권은 그의 동의가 없으면 수반하지 않는다. 또한 수반성으로 말미암아 저당권은 피담보채권으로부터 분리하여 처분할 수 없다(제361조).

제361조(저당권의 처분제한)

저당권은 그 담보한 채권과 분리하여 타인에게 양도하거나 다른 채권의 담보로 하지 못한다.

4) 불가분성(제370조·제321조)

5) 물상대위성

제2항 저당권의 성립

I. 서 설

① 채권성립(금전소비대차계약) + ② 저당권설정계약(원인행위) + ③ 물건적 합의(물권행위) + ④ 등기 → 저당권설정계약은 보통 피담보채권을 발생케 하는 계약(예 : 금전소비대차계약) 속에 포함되어서 행하여짐.

→ 물건행위는 저당권설정계약 속에 포함되어 행하여짐

→ 결국 ①②③이 함께 행하여짐

II. 저당권설정계약

1. 계약의 성질

저당권설정계약은 저당권의 설정을 약정하는 채권계약과 저당권설정 그 자체를 목적으로 하는 순수한 물권계약의 두 성격을 갖는 것으로 특별한 사정이 없으면 양자가 합체되어서 행하여지고 많은 경우에 저당권설정계약은 보통 피담보채권을 발생케 하는 계약(예 : 금전소비대차계약 등)속에 포함되어서 행하여진다고 볼 것이다.

2. 계약의 당사자

(1) 저당권자

① 원칙 : 피담보채권의 채권자(우리민법은 소유자저당은 인정하지 않음)

② 예외 : 타인명의의 저당권 등기도 유효

(㉠채권자·채무자·제3자 사이의 합의가 있고 또 ㉡그 채권이 그 제3자에게 실질적으로 귀속되었다고 볼 수 있는 특별한 사정이 있거나, 거래경위에 비추어 제3자의 저당권등기가 한낱 명목에 그치는 것이 아니라 제3자도 채무자로부터 유효하게 채권을 변제받을 수 있는 관계가 있는 경우 : 판례) → 부동산실명법상 명의신탁약정금지에 위반 아님(판례)

[판 례] 채권자 아닌 제3자 명의로 설정된 저당권 또는 채권담보 목적의 가등기의 효력 (=제한적 유효)

채권담보의 목적으로 채무자 소유의 부동산을 담보로 제공하여 저당권을 설정하는 경우에는 담보물권의 부종성의 법리에 비추어 원칙적으로 채권과 저당권이 그 주체를 달리할 수 없는 것이지만, 채권자 아닌 제3자의 명의로 저당권등기를 하는 데 대하여 ①채권자와 채무자 및 제3자 사이에 합의가 있었고, 나아가 ②제3자에게 그 채권이 실질적으로 귀속되었다고 볼 수 있는 특별한 사정이 있거나, 거래경위에 비추어 제3자의 저당권등기가 한낱 명목에 그치는 것이 아니라 그 제3자도 채무자로부터 유효하게 채권을 변제받을 수 있고 채무자도 채권자나 저당권 명의자인 제3자 중 누구에게든 채무를 유효하게 변제할 수 있는 관계 즉 묵시적으로 채권자와 제3자가 불가분적 채권자의 관계에 있다고 볼 수 있는 경우에는, 그 제3자 명의의 저당권등기도 유효하다고 볼 것인바, 이러한 법리는 저당권의 경우뿐 아니라 채권 담보를 목적으로 가등기를 하는 경우에도 마찬가지로 적용된다고 보아야 할 것이고, 이러한 법리가 부동산실권리자명의등기에관한법률에 규정된 명의신탁약정의 금지에 위반된다고 할 것은 아니다(대판 2002. 12. 24, 2002다50484; 동지 대판 2009. 11. 26, 2008다64478-64485-64492).

[판 례] 명의신탁적 근저당권 설정등기의 유효성

[다수의견] 근저당권은 채권담보를 위한 것이므로 원칙적으로 채권자와 근저당권자는 동일인이 되어야 하지만, 제3자를 근저당권 명의인으로 하는 근저당권을 설정하는 경우 그 점에 대하여 채권자와 채무자 및 제3자 사이에 합의가 있고, 채권양도, 제3자를 위한 계약, 불가분적 채권관계의 형성 등 방법으로 채권이 그 제3자에게 실질적으로 귀속되었다고 볼 수 있는 특별한 사정이 있는 경우에는 제3자 명의의 근저당권설정등기도 유효하다고 보아야 할 것이고, 한편 부동산을 매수한 자가 소유권이전등기를 마치지 아니한 상태에서 매도인인 소유자의 승낙 아래 매수 부동산을 타에 담보로 제공하면서 당사자 사이의 합의로 편의상 매수인 대신 등기부상 소유자인 매도인을 채무자로 하여 마친 근저당권설정등기는 실제 채무자인 매수인의 근저당권자에 대한 채무를 담보하는 것으로서 유효하다고 볼 것인바, 위 양자의 형태가 결합된 근저당권이라 하여도 그 자체만으로는 부종성의 관점에서 근저당권이 무효라고 보아야 할 어떤 질적인 차이를 가져오는 것은 아니라 할 것이다. 그리고 매매잔대금 채무를 지고 있는 부동산 매수인이 매도인과 사이에 소유권이전등기를 경료하지 아니한 상태에서 그 부동산을 담보로 하여 대출받

는 돈으로 매매잔대금을 지급하기로 약정하는 한편, 매매잔대금의 지급을 위하여 당좌수표를 발행·교부하고 이를 담보하기 위하여 그 부동산에 제1 순위 근저당권을 설정하되, 그 구체적 방안으로서 채권자인 매도인과 채무자인 매수인 및 매도인이 지정하는 제3자 사이의 합의 아래 근저당권자를 제3자로, 채무자를 매도인으로 하기로 하고, 이를 위하여 매도인이 제3자로부터 매매잔대금 상당액을 차용하는 내용의 차용금증서를 작성·교부하였다면, 매도인이 매매잔대금 채권의 이전 없이 단순히 명의만을 제3자에게 신탁한 것으로 볼 것은 아니고, 채무자인 매수인의 승낙 아래 매매잔대금 채권이 제3자에게 이전되었다고 보는 것이 일련의 과정에 나타난 당사자들의 진정한 의사에 부합하는 해석일 것이므로, 제3자 명의의 근저당권설정등기는 그 피담보채무가 엄연히 존재하고 있어 그 원인이 없거나 부종성에 반하는 무효의 등기라고 볼 수 없다.

(대판[전합] 2001. 3. 15, 99다48948).

(2) 저당권설정자

① 원칙적 : 채무자 또는 제3자(물상보증인) (제356조)

② 등기부상의 채무자는 피담보채권의 채무자이어야 함

→ 부종성에 따라 채무자 아닌 다른 자를 채무자로 등기한 경우 그 등기는 무효, 다만 ㉠ 당사자간 합의와 ㉡ 저당권설정등기가 실제 채무자의 채무를 담보하는 경우에는 그 등기는 유효하다.

III. 저당권의 설정등기

1. 등기사항

채권자·채무자·채권액·변제기·이자·이자의발생기 또는 지급시기 원본 또는 이자의 지급장소 · 저당권의 효력범위에 관한 약정이 있는 경우 약정(제358조) 등

근저당권은 이자 관련사항은 등기 없다. 왜냐하면 채권최고액으로 모두 포함하기 때문

2. 불법말소된 등기의 효력

저당권등기가 불법말소 되더라도 등기는 물권의 효력발생요건이고 효력존속요건이 아니므로 저당권의 효력에는 아무런 영향을 미치지 않는다.

피담보채권의 변제 등으로 저당권이 소멸하였으나 말소등기를 하지 않는 동안에 그 무효등기를 다른 저당권을 위한 등기로 유용할 수 있는가

: 제한적 유효설(통/판)/ 등기의 유용합의 전까지 등기상 이해관계가 있게 된 제3자(예를 들어 후순위저당권자, 제3취득자)에 대하여는 무효이지만, 등기의 유용합의 후에 이해관계가 있게 된 제3자에 대하여는 유효하다.

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 부동산의 사용·수익을 목적으로 하는 권리도 질권의 목적이 될 수 있다.
- ② 채권을 질권의 목적으로 하는 경우에 채권증서가 있는 때에는 질권의 설정은 그 증서를 질권자에게 교부함으로써 효력이 생긴다.
- ③ 저당권으로 담보한 채권을 질권의 목적으로 한 때에는 그 저당권등기에 질권의 부기등기를 하여야 그 효력이 저당권에 미친다.
- ④ 질권설정자는 질권자의 동의 없이 질권의 목적이 된 권리를 소멸하게 하거나 질권자의 이익을 해하는 변경을 할 수 없다.
- ⑤ 질권자는 질권의 목적이 된 채권을 직접 청구할 수 있다.

- ①. 부동산의 사용·수익을 목적으로 하는 권리(예 : 지상권·전세권·부동산임차권)는 권리질권의 목적이 될 수 없다(제345조 단서).

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 채권을 질권의 목적으로 하는 경우에 채권증서가 있는 때에는 질권의 설정은 그 증서를 질권자에게 교부함으로써 그 효력이 생긴다.
- ② 지명채권에 대한 질권설정에 있어서 채무자가 이의를 보류하지 않은 승낙을 한 경우 채무자는 질권설정자에게 대항할 수 있는 사유로서 질권자에게 대항할 수 있다.
- ③ 질권자는 질권의 목적이 된 채권을 직접 청구할 수 있다.
- ④ 질권설정자와 제3채무자가 질권자의 동의 없이 질권의 목적된 권리를 소멸하게 하는 행위를 하였다고 하더라도 이는 질권자에 대한 관계에 있어 무효일 뿐이어서 특별한 사정이 없는 한 질권자 아닌 제3자가 그 무효의 주장을 할 수는 없다.
- ⑤ 채권질권자는 입질채권의 이자를 수취하여 이를 우선변제에 충당할 수 있으나, 채권질권자가 우선변제를 받는 주된 방법은 입질채권자채로부터 우선변제를 받는 것이다.

- ②. 채권양도나 채권에 대한 질권 설정에 있어서 채무자가 이의를 보류하지 않은 승낙을 한 경우 채무자는 질권설정자에게 대항할 수 있는 사유로서 질권자에게 대항할 수 없고, 이 경우 대항할 수 없는 사유는 협의의 항변권에 한하지 아니하고, 넓게 채권의 성립, 존속, 행사를 저지하거나 배척하는 사유를 포함한다(대판 2002. 3. 29, 2000다13887).

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 저당권이 설정된 후에 용익권을 취득한 제3자는 경락인에게 권리를 주장할 수 없다.
- ② 저당권이 설정될 당시에 건물이 없었던 경우에는 나중에 건물이 축조되더라도 법정지상권은 인정되지 않는다.
- ③ 저당권 설정 당시에 대항력 있는 임차권자는 경락인에 대하여 임차권을 주장할 수 있다.
- ④ 법정지상권이 성립하기 위해서는 저당권 설정시에 반드시 건물의 보존등기가 되어 있어야 한다.
- ④. 저당권 설정당시 건물이 존재하면 되고, 보존등기가 되어 있지 않아도 법정지상권을 취득할 수 있다.
- ⑤ 판례는 법정지상권이 있는 건물의 양수인은 양도인의 대지의 소유자에 대한 지상권 설정등기 청구권을 대위행사를 할 수 있다고 한다.

♣ 학습정리

1. 채권자가 지정되어 있는 일반적인 채권인 지명채권은 채권증서를 질권자에게 교부함으로써 효력이 생기고, 지명채권의 입질을 가지고 제3채무자 기타 제3자에 대항하기 위해서는 제3채무자에게 질권설정을 통지하거나 제3채무자가 이를 승낙하여야 하며, 제3채무자 이외의 제3자에게 대항하기 위해서는 이 통지나 승낙은 확정일자 있는 증서로 하여야 하는데, 이는 질권양도의 대항요건과 같다.
2. 저당권은 비점유담보이기 때문에 일반채권자가 불측의 손해를 입지 않도록 하기 위하여 저당권의 존재는 반드시 등기 및 등록 등에 의하여 공시되어야 한다. 저당권의 공시는 우리 민법에서 엄격하게 지키고 있는 원칙이며, 다만 제한된 경우에 법정저당권이 인정될 뿐이다. 또한 우리 민법은 동일한 목적물 위에 설정된 저당권은 각각 확정된 순위를 가지고 있어서 서로 침범하지 못한다는 순위확정의 원칙을 마련하고 있다.
3. 채권자 아닌 제3자 명의로 설정된 저당권 또는 채권담보 목적의 가등기의 효력은 담보물권의 부종성의 법리에 비추어 원칙적으로 무효이나, 제3자 명의로 저당권등기를 하는 데에 대하여 채권자의 채무자 및 제3자 사이에 합의가 있고, 제3자에게 그 채권이 실질적으로 귀속되었다고 볼 수 있는 특별한 사정이 있는 경우에는 제3명의로 저당권등기도 유효하다.

제35강 저당권 (2)

♣ 학습목표

1. 저당권의 객체와 피담보채권을 정리할 수 있다.
2. 저당권의 효력을 유형별로 정리할 수 있다.

♣ 학습내용

- 저당권의 객체
- 피담보채권
- 저당권 효력의 범위
- 우선변제적 효력

♣ 사전 테스트

1. 피담보채권이 금전채권인 경우에는 그 채권의 평가액을 등기하여야 한다.
⇒ × : 저당권에 의하여 담보되는 채권, 즉 피담보채권이 금전채권이 아닌 경우에는 그 채권의 평가액을 등기하여야 한다(부동산등기법 제140조, 제143조).
2. 토지와 건물은 각각 별개의 부동산이지만, 저당권은 건물에 효력을 미친다.
⇒ × : 토지와 건물은 개별 부동산이기 때문에 토지의 저당권은 건물에 그 효력이 미치지 않는다. 그러나 저당권설정 후 그 설정자가 해당지상에 건물을 건축한 때에는 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여 경매를 청구할 수 있다.
3. 저당권의 본체적인 효력은 목적물로부터 우선변제를 받는 것이다.
⇒ ○ : 저당채무자가 피담보채권의 변제기가 도래하였음에도 불구하고 이를 변제하지 않은 경우에는 저당채권자는 저당권의 목적물을 일정한 절차에 따라 매각 및 환가하여 그 대금으로부터 다른 채권자에 우선하여 변제를 받을 수 있다.

♣ 강의교안

IV. 저당권의 객체

1. 민법이 인정하는 저당권의 객체

- ① 민법이 인정하는 저당권의 객체는 부동산(토지·건물)과 부동산물권(지상권·전세권)이다(제356조)

▶ 돌발 퀴즈

지상권과 전세권을 객체로 저당권을 설정하는 경우가 많은가?

: ×

- 전세권에 대하여 저당권이 설정된 경우 그 저당권의 목적물은 물권인 전세권 자체이지 전세금반환채권은 그 목적물이 아니고, 전세권의 존속기간이 만료되면 전세권은 소멸한다. 이 때 전세권설정자는 전세금반환채권에 대한 제3자의 압류 등이 없는 한 전세권자에 대하여만 전세금반환의무를 부담한다고 보아야 한다. 그런데 저당권의 객체로서 지상권 및 전세권을 설정하는 경우는 많지 않다.

- ② 부동산(토지·건물) : 1필의 토지, 여러 필의 토지 집합 위에 1개 저당권 불가
(단 공동저당은 여러 개의 저당권임/ 공장재단저당은 집합 위의 1개의 저당권임)

[판례] 저당권의 객체로서의 전세권과 그 법률관계

- (1) 전세권이 기간만료로 종료된 경우 전세권은 전세권설정등기의 말소등기 없이도 당연히 소멸하고, 저당권의 목적물인 전세권이 소멸하면 저당권도 당연히 소멸하는 것이므로 전세권을 목적으로 한 저당권자는 전세권의 목적물인 부동산의 소유자에게 더 이상 저당권을 주장할 수 없다.
- (2) 전세권에 대하여 저당권이 설정된 경우 그 저당권의 목적물은 물권인 전세권 자체이지 전세금반환채권은 그 목적물이 아니고, 전세권의 존속기간이 만료되면 전세권은 소멸하므로 더 이상 전세권 자체에 대하여 저당권을 실행할 수 없게 되고, 이러한 경우에는 민법 제370조, 제342조 및 민사소송법 제733조에 의하여 저당권의 목적물인 전세권에 갈음하여 존속하는 것으로 볼 수 있는 전세금반환채권에 대하여 압류 및 추심명령 또는 전부명령을 받거나 제3자가 전세금반환채권에 대하여 실시한 강제집행절차에서 배당요구를 하는 등의 방법으로 자신의 권리를 행사하여 비로소 전세권설정자에 대해 전세금의 지급을 구할 수 있게 된다는 점, 원래 동시이행항변권은 공평의 관념과 신의칙에 입각하여 각 당사자가 부담하는 채무가 서로 대가적 의미를 가지고 관련되어 있을 때 그 이행에 있어서 견련관계를 인정하여 당사자 일방은 상대방이 채무를 이행하거나 이행의 제공을 하지 아니한 채 당사자 일방의 채무의 이행을 청구할 때에는 자기의 채무이행을 거절할 수 있도록 하는 제도인 점, 전세권을 목적으로 하는 저당권의 설정은 전세권의 목적물 소유자의 의사와는 상관없이 전세권자의 동의만 있으면 가능한 것이고, 원래 전세권에 있어 전세권설정자가 부담하는 전세금반환의무는 전세금반환채권에 대한 제3자의 압류 등이 없는 한 전세권자에 대해 전세금을 지급함으로써 그 의무이행을 다할 뿐이라는 점에 비추어 볼 때, 전세권저당권이 설정된 경우에도 전세권이 기간만료로 소멸되면 전세권설정자는 전세금반환채권에 대한 제3자의 압류 등이 없는 한 전

세권자에 대하여만 전세금반환의무를 부담한다고 보아야 한다(대판 1999. 9. 17. 98다 31301).

→ 전세권설정자는 전세권자에게만 전세금반환의무를 부담한다.(제3자의 압류가 없는 한)
(즉 전세권자가 전세권을 저당권설정하는 것은 전세권설정자와는 별개다)

2. 민법 이외의 법률이 인정하는 객체

- (1) 상법상 등기된 선박(상법 제871조)
- (2) 입목등기한 수목의 집단(입목등기에 관한 법률 제3조·제4조)은 그 지반인 토지와는 별개의 부동산이므로 독립하여 저당권의 객체가 된다.
- (3) 광업권(광업법 제11조), 어업권(수산업법 제16조·제22조·제26조)
- (4) 공장및광업재단저당법상의 공장재단·광업재단은 물건 및 권리의 집합체로서 하나의 부동산으로 다루어져 저당권의 목적이 된다.
- (5) 자동차등특정동산저당법상의 건설기계·자동차·항공기·선박등기법이 적용되지 아니하는 선박(소형선박) 등 등록에 의하여 공시되는 특수한 동산도 저당권의 목적이 된다.

V. 피담보채권

1. 보통은 금전채권이지만 금전채권이 아니더라도 저당권의 실행시기에 금전채권으로 되어 있으면 족하다. 다만 피담보채권이 금전채권이 아닌 경우에는 그 채권의 평가액을 등기하여야 한다.
2. 법정저당권 : 토지임대인이 변제기를 경과한 최후 2년의 차임채권
(이 경우 지상에 있는 임차인 소유의 건물을 압류한 때에 → 법정저당권이 성립한다 : 제649조/ 압류등기시 성립)
3. 부동산공사의 수급인의 그 보수에 관한 채권 : 부동산공사수급인의 저당권설정청구권
→ 약정저당권(제666조/ 등기설정시 성립)

제3항 저당권의 효력

I. 저당권의 효력이 미치는 범위

1. 피담보채권의 범위

제360조(피담보채권의 범위) 저당권은 원본, 이자, 위약금, 채무불이행으로 인한 손해배상 및 저당권의 실행비용을 담보한다. 그러나 **지연배상에 대하여는 원본의 이행기일을 경과한 후의 1년분에 한하여 저당권을 행사할 수 있다.**

원칙적으로 저당권설정계약에서 정함 단 약정이 없는 경우 원본·이자·지연배상·위약금·채무불이행상의 손해배상 및 실행비용(실행비용은 등기하지 않아도 당연히 저당권에 의하여 담보→근저당권의 채권최고액은 당사자 사이의 계속적 거래관계에서 생긴 채권 가운데 담보할 한도액

을 말하는 것이므로, 근저당권의 실행비용은 채권최고액에 포함되지 아니한다고 봄이 타당하다(대판 2001. 11. 27, 2001다47986))

(단 지연배상은 원본의 이행기일을 경과한 후의 1년분에 한하여 저당권을 행사할 수 있음)

→ 채권자에 대하여는 1년 이후 지연배상전액을 변제하여야 하지만(불가분성) 후순위저당권자 및 다른 채권자를 보호하기 위해 1년분만 담보됨(360조 단서) → 양도담보도 마찬가지(대판 1992. 5. 12, 90다8855)

[판례] 평가액이 저당권의 피담보채권으로 등기된 때 저당채무범위

저당권으로 담보할 채권에 대하여는 법률상 제한이 없으므로 특정물의 지급 또는 종류물의 일정수량의 지급을 목적으로 하는 채권을 위하여 저당권을 설정할 수 있으나 이와 같은 경우에는 부동산등기법 제143조에 의하여 미리 그 채권을 금전으로 평가하여 그 평가액을 등기하도록 하였던 바, 이는 피담보채권이 금전채권 이외의 경우라 하더라도 그 채권이 이행불능의 경우에는 금전적 손해배상 채권으로 되어 그 목적물의 매각대금으로서 받게 될 뿐 아니라 그 부동산으로서 담보된 담보가치의 수액을 미리 공시함으로써 그 부동산에 대한 후순위 저당권자 또는 제3취득자와 같은 이해관계인의 이익을 보호하고 부동산에 관한 거래의 안전을 기하하는데 그 목적이 있으므로 채권자는 제3자에 대한 관계에 있어서는 그 등기된 평가액의 한도에서만 저당권의 효력을 주장할 수 있다(대판 1980. 9. 18, 80마75).

[판례] 제360조 단서의 적용범위 → 양도담보에도 적용

저당권의 피담보채무의 범위에 관하여 민법 제360조가 지연배상에 대하여는 원본의 이행기일을 경과한 후의 1년분에 한하여 저당권을 행사할 수 있다고 규정하고 있는 것은 저당권자의 제3자에 대한 관계에서의 제한이며 채무자나 저당권설정자가 저당권자에 대하여 대항할 수 있는 것이 아니고, 민법 제360조가 양도담보의 경우에 준용된다고 하여도 마찬가지로 해석하여야 할 것인 만큼, 양도담보의 채무자가 양도담보권자에 대하여 민법 제360조에 따른 피담보채권의 제한을 주장할 수는 없는 것이다(대판 1992. 5. 12, 90다8855).

2. 목적물의 범위

(1) 목적물

제358조(저당권의 효력의 범위)

저당권의 효력은 저당부동산에 부합된 물건과 종물에 미친다. 그러나 법률에 특별한 규정 또는 설정행위에 다른 약정이 있으면 그러하지 아니하다.

제359조(과실에 대한 효력)

저당권의 효력은 저당부동산에 대한 압류가 있는 후에 저당권설정자가 그 부동산으로부터 수취한 과실 또는 수취할 수 있는 과실에 미친다. 그러나 저당권자가 그 부동산에 대한 소유권, 지상권 또는 전세권을 취득한 제삼자에 대하여는 압류한 사실을 통지한 후가 아니면 이로써 대항하지 못한다.

1) 소유권 : 보통은 소유권의 범위와 일치 (단 제358조, 제359조의 특칙)

2) 부합물(제358조) :

- ① 거래관념상 저당권부동산의 일부분이 되었다고 인정되면 저당권의 효력이 미친다(제358조)
(예 : 지상의 수목이나 건물의 부속물 내지 증축건물/ 그러나 성숙한 농작물은 토지에 부합하지 않음) → 부합물의 소유자가 누구인가를 불문하고 경매로 매수한 사람이 소유권을 취득함
- ② 부합시기는 저당권설정 이후에 부합된 것도 포함한다.
- ③ 토지와 건물은 각각 별개의 부동산이므로 토지의 저당권은 건물에 그 효력이 미치지 않는다. 그러나 저당권설정 후 그 설정자가 해당지상에 건물을 건축한 때에는 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여도 경매를 청구할 수 있다. 다만 그 건물의 경매대가에 대하여는 우선변제를 받을 권리가 없다(제365조 : 일괄경매청구권)
- ④ 저당목적 건물 위에 부합된 증축부분이 기존건물에 대한 경매절차에서 경매목적물로 평가되지 아니한 경우라도 매수인은 증축부분의 소유권을 취득한다.(판례)
- ⑤ 부합물·종물이 아닌 독립성 있는 물건을 부합물로 보고 경매진행 → 경매무효(판례) → 따라서 경매의 매수인은 그 부합물의 소유권을 취득하지 못함(동산선의취득은 가능).
- ⑥ 법률에 특별규정이 있는 경우, 설정행위에서 다른 약정을 한 경우에는 그렇지 않음

[판례] 당사자간 채권적 합의에 의한 제한의 효력

신축 상가건물에 대한 공사대금채권의 담보를 위하여 상가건물에 근저당권을 설정하면서 근저당권설정자와 근저당권자 사이에 분양계약자가 분양대금을 완납하는 경우 그 분양계약자가 분양 받은 지분에 관한 근저당권을 말소하여 주기로 하는 약정이 있었다 하더라도, 근저당권자는 근저당권설정자 또는 분양계약자에 대하여 그 약정에 따라 분양계약자의 분양 지분에 관한 근저당권을 말소하여 줄 채권적 의무가 발생할 뿐이지 물권인 근저당권자의 근저당권 자체가 등기에 의하여 공시된 바와 달리 위 약정에 의하여 제한되는 것은 아니고, 그 근저당권의 인수인이 당연히 위 약정에 따른 근저당권자의 채무를 인수하는 것도 아니다(대판 2001. 3. 23. 2000다49015).

- ⑦ 저당부동산에서 분리반출된 부합물·종물에 대한 저당권의 효력(예 : 저당권 설정산림의 벌채 또는 목재 반출/ 붕괴된 건물의 목재반출)
→ 공시원칙설(통), 사회관념적일체설, 물상대위설

3) 종물(제358조) 및 종된 권리(통설, 판례)

- ① 종물은 동산, 부동산을 불문(예 : 공장토지에 설치된 폐수처리시설, 주유소건물의 주유기)
- ② 종물로 된 시기는 저당권설정 이후에 된 것도 포함한다.

4) 과실(제359조)

- ① 원칙적으로 목적부동산에서 생기는 천연과실에 저당권의 효력이 미치지 않는다.
- ② 예외적으로 저당권의 실행에 착수하여 부동산을 압류한 후에는 저당권설정자가 그 부동산으로부터 수취한 과실 또는 수취할 수 있는 과실에 대해서는 저당권의 효력이 미침(제359조)
→ 즉 경매 매수인이 천연과실의 소유권 취득(다만 그 부동산에 대한 소유권·지상권·전세권을 취득한 제3자에 대해서는 저당권자가 압류한 사실을 통지하여야만 대항할 수 있다. 제359조 단서)

③ 법정과실도 인정(통설)

(2) 물상대위

- ① 멸실·훼손·공용징수로 저당권설정자가 받을 금전 기타의 물건에 저당권자가 추급
→ 보험금청구권, 손해배상금청구권, 수용보상금청구권(저당물의 매각대금, 차임 등에는 X)
- ② 물상대위권을 행사하려면 금전 기타의 물건을 지급 또는 인도받기 전에 이 청구권을 압류(저당권자 아닌 다른 제3채권자가 압류하여도 특정성이 유지됨(판례))
- ③ 물상대위권의 행사는 늦어도 민사집행법상 배당요구의 종기까지 하여야 함(판례)

[판례] 저당권자의 물상대위권의 행사방법과 그 시한 및 이를 제한하는 취지

- (1) 저당권자의 물상대위권은 어디까지나 그 권리실행의사를 저당권자 스스로 법원에 명확하게 표시하는 방법으로 저당권자 자신에 의하여 행사되어야 하는 것이지, 저당권자 아닌 다른 채권자나 제3채무자의 태도나 인식만으로 저당권자의 권리행사를 의제할 수는 없으므로, 저당권자 아닌 다른 채권자나 제3채무자가 저당권의 존재와 피담보채무액을 인정하고 있고, 나아가 제3채무자가 채무액을 공탁하고 공탁사유를 신고하면서 저당권자를 피공탁자로 기재하는 한편 저당권의 존재를 증명하는 서류까지 제출하고 있다 하더라도 그것을 저당권자 자신의 권리행사와 같이 보아 저당권자가 그 배당절차에서 다른 채권자들에 우선하여 배당받을 수 있는 것으로 볼 수 없으며, 저당권자로서는 제3채무자가 공탁사유신고를 하기 이전에 스스로 담보권의 존재를 증명하는 서류를 제출하여 물상대위권의 목적채권을 압류하거나 법원에 배당요구를 한 경우에 한하여 공탁금으로부터 우선배당을 받을 수 있을 뿐이다(대판 1999. 5. 14, 98다62688).
- (2) 민법 제370조, 제342조 단서가 저당권자는 물상대위권을 행사하기 위하여 저당권설정자가 받을 금전 기타 물건의 지급 또는 인도전에 압류하여야 한다고 규정한 것은 물상대위의 목적인 채권의 특정성을 유지하여 그 효력을 보전함과 동시에 제3자에게 불측의 손해를 입히지 않으려는 데 있는 것이므로, 저당목적물의 변형물인 금전 기타 물건에 대하여 이미 제3자가 압류하여 그 금전 또는 물건이 특정된 이상 저당권자가 스스로 이를 압류하지 않고서도 물상대위권을 행사하여 일반 채권자보다 우선변제를 받을 수 있으나, 그 행사방법으로서는 민사집행법 제273조(구 민사소송법 제733조)에 의하여 담보권의 존재를 증명하는 서류를 집행법원에 제출하여 채권압류 및 전부명령을 신청하는 것이나 민사집행법 제247조 제1항(구 민사소송법 제580조 제1항)에 의하여 배당요구를 하는 것이므로, 이러한 물상대위권의 행사

에 나아가지 아니한 채 단지 수용대상토지에 대하여 담보물권의 등기가 된 것만으로는 그 보상금으로부터 우선변제를 받을 수 없고(대판 1998. 9. 22, 98다12812 참조), 저당권자가 물상대위권의 행사에 나아가지 아니하여 우선변제권을 상실한 이상 다른 채권자가 그 보상금 또는 이에 관한 변제공탁금으로부터 이득을 얻었다고 하더라도 저당권자는 이를 부당이득으로서 반환청구할 수 없다(대판 2002. 10. 11, 2002다33137; 대판 2010. 10. 28, 2010다46756; 대판 1998. 9. 22, 98다12812; 대판 1994. 11. 22, 94다25728).

II. 우선변제적 효력

- 우선변제받는 방법- (저당권으로서 우선변제 / 일반채권자로서 변제)

- ① 저당권으로서 우선변제 : 직접 저당권실행으로 변제 단 일반채권자, 전세권자, 후순위저당권자의 경매신청에 의하여 순위에 따라 변제받을 수 있다. 단 이러한 자는 선순위 저당권자가 저당채권을 완전히 변제 받을 수 있는 경우가 아니면 강제집행 또는 저당권을 실행 또는 전세권의 경매신청은 인정되지 않음(잉여주의 민사집행법 제91조 제1항. 통설) → 투자저당권으로 미흡
- ② 일반채권자로서 변제 : 저당부동산의 매각대금으로 배당을 받았지만 완전변제가 아닌 경우에는 저당권자의 나머지 채권은 무담보의 채권이 됨. → 그 나머지 채권은 채무자의 일반재산에 대하여 강제집행을 하거나 또는 타인이 집행하는 경우에 배당에 참가 가능
- ③ 다른 채권자가 다른 재산에 대한 배당을 실시하는 경우 저당권자는 그의 채권 전액을 가지고 배당에 참가할 수 있다. 단 다른 채권자는 저당권자에게 배당금액의 공탁청구.

▶ 돌발 퀴즈

저당권자가 저당권의 실행 없이 먼저 채무자의 일반재산에 대하여 일반채권자로서도 집행할 수 있는가?

: ○

- 저당권자는 질권과 마찬가지로 저당권을 실행하지 않고 먼저 채무자의 일반재산에 대하여 일반채권자로서 집행할 수 있다. 그러나 저당권자는 저당부동산에 의하여 변제받지 못한 부분의 채권에 관하여서만 일반채권에 대하여 집행할 수 있으며, 이를 위반한 때에는 일반채권자는 이의를 제기할 수 있지만, 채무자는 이의를 제기할 수 없다.

- 배당 순위 -

- ① 제1순위 : 경매집행비용 / 유치권(필요비·유익비)
- ② 제2순위 : 최종 3개월분의 임금·퇴직금(3년분)·재해보상금 / 주택·상가건물임대차보증금의 일정액
- ③ 제3순위 : 질권·저당권에 우선하는 국세 및 지방세와 그 가산금(당해세)
- ④ 제4순위 : 당해세 이외의 법정기일이 도래된 국세 및 지방세와 그 가산금 / 질권·저당권에 의하여 담보된 채권 / 대항력 있는 임대차보증금(주택·상가건물)
- ⑤ 제5순위 : 임금·퇴직금(제2순위의 것 제외)
- ⑥ 제6순위 : 저당권보다 후순위인 일반적인 국세·지방세
- ⑦ 제7순위 : 각종 공과금(건강보험·국민연금·산재보험)
- ⑧ 제8순위 : 일반채권

- 임금우선허권은 배당요구채권이다(민사집행법 제268조, 제88조 참조). 배당요구의 종기(동법 제84조에 따라 첫 매각기일 이전)까지 배당요구를 하여야 한다.(동법 제148조 제3호에 따라 경매개시 전 사용자 소유의 부동산을 가압류한 경우에도 같다(판례))
- 임금 등에 대한 지연손해금채권에 대하여는 최우선변제권이 인정되지 않는다(판례)
- 당해세란 목적 부동산에 당연히 부과되는 세금(증여세, 상속세, 재산세, 종합부동산세)을 말한다. 단 상속재산임이 등기부에 기재되지 않아 공시되어 있지 않은 부동산의 경우에 담보물권자가 당해 부동산에 상속세가 부과된다는 점을 예측할 수 없었다는 이유로 등기되어 있지 않은 상속세는 제3순위의 당해세에 해당 없음(대판 2003. 1. 10, 2001다44376).

주의 : 유치권자에 대한 관계

‘우선변제“권”이 없는 유치권’과 저당권은 이론상 경합하거나 우열의 문제가 생길 여지가 없다. 그리고 저당권과 유치권의 성립 선후로 정하여지지 않음 → 유치권은 사실상 우선변제 효력.

[판례] 가압류등기 후에 경료된 근저당권설정등기의 효력 및 배당순위

가. 부동산에 대하여 가압류등기가 먼저 되고 나서 근저당권설정등기가 마쳐진 경우에 그 근저당권등기는 가압류에 의한 처분금지의 효력 때문에 그 집행보전의 목적을 달성하는 데 필요한 범위 안에서 가압류채권자에 대한 관계에서만 상대적으로 무효이다.

나. ‘가’항의 경우 가압류채권자와 근저당권자 및 근저당권설정등기 후 강제경매신청을 한 압류채권자 사이의 배당관계에 있어서, 근저당권자는 선순위 가압류채권자에 대하여는 우선변제권을 주장할 수 없으므로 1차로 채권액에 따른 안분비례에 의하여 평등배당을 받은 다음, 후순위 경매신청압류채권자에 대하여는 우선변제권이 인정되므로 경매신청압류채권자가 받을 배당액으로부터 자기의 채권액을 만족시킬 때까지 이를 흡수하여 배당받을 수 있다(대결 1994. 11. 29, 94마417).

[판례] 대지에 관한 저당권 설정 후 지상에 건물이 신축된 경우, 건물의 소액임차인에게 그 저당권 실행에 따른 환가대금에 대한 우선변제권이 있는지 여부(소극)

임차주택의 환가대금 및 주택가액에 건물뿐만 아니라 대지의 환가대금 및 가액도 포함된다고 규정하고 있는 주택임대차보호법(1999. 1. 21. 법률 제5641호로 개정되기 전의 것) 제3조의2 제1항 및 제8조 제3항의 각 규정과 같은 법의 입법 취지 및 통상적으로 건물의 임대차에는 당

연히 그 부지 부분의 이용을 수반하는 것인 점 등을 종합하여 보면, 대지에 관한 저당권의 실행으로 경매가 진행된 경우에도 그 지상 건물의 소액임차인은 대지의 환가대금 중에서 소액보증금을 우선변제받을 수 있다고 할 것이나, 이와 같은 법리는 대지에 관한 저당권 설정 당시에 이미 그 지상 건물이 존재하는 경우에만 적용될 수 있는 것이고, 저당권 설정 후에 비로소 건물이 신축된 경우에만까지 공시방법이 불완전한 소액임차인에게 우선변제권을 인정한다면 저당권자가 예측할 수 없는 손해를 입게 되는 범위가 지나치게 확대되어 부당하므로, 이러한 경우에는 소액임차인은 대지의 환가대금에 대하여 우선변제를 받을 수 없다고 보아야 한다(대판 1999. 7. 23, 99다25532).

[참 고] 배당요구와 부당이득과의 관계

1. 배당요구채권자

민사집행법 제88조 제1항은 “집행력 있는 정본을 가진 채권자, 경매개시결정이 등기된 뒤에 가압류를 한 채권자, 민법·상법, 그 밖의 법률에 의하여 우선변제청구권이 있는 채권자는 배당요구를 할 수 있다”고 규정하고 있고, 제148조는 부동산의 강제경매에서 배당받을 채권자로 “1. 배당요구의 종기까지 경매신청을 한 압류채권자 2. 배당요구의 종기까지 배당요구를 한 채권자 3. 첫 경매개시결정등기전에 등기된 가압류채권자 4. 저당권·전세권, 그 밖의 우선변제청구권으로서 첫 경매개시결정등기전에 등기되었고 매각으로 소멸하는 것을 가진 채권자”를 들고 있다. **제148조 제2호의 배당요구채권자는 소액보증금우선변제권이 나 임차보증금우선변제권이 있는 임차인(상가건물임차인 포함)과 근로기준법상 우선변제권이 있는 임금채권자, 경매개시등기후의 가압류권자를 말한다. 그러나 압류의 효력발생 전에 등기한 가압류채권자, 경락에 의하여 소멸하는 저당권자 및 압류의 효력발생 전에 등기한 전세권자 등은 배당요구채권자에 해당하지 않는다. 또한 저당권이 불법말소된 상태에서 저당목적부동산이 경락된 경우의 저당권자도 배당요구채권자가 아니다**(대판 1998. 10. 2, 98다27197).

2. 우선변제권자가 배당요구를 하지 않은 경우와 부당이득

① 권리도 없는 자가 배당받은 경우에 부당이득이 성립하는 것은 당연하다. 이 때 손실자에 관하여 판례는 배당절차에서 권리 없는 자가 배당을 받아갔다면 이는 법률상 원인 없이 부당이득을 한 것이라고 할 것이나 이로 인하여 **손해를 입은 사람은 그 배당이 잘못되지 않았더라면 배당을 받을 수 있었던 사람(즉, 채권자)이지 이것이 다음 순위의 배당을 받을 수 있는 사람이 있는 경우에도 채무자에게 귀속된다고 할 수 없다고 하였다**(대판 2000. 10. 10, 99다53230).

② 우선변제권자가 배당요구를 하지 않은 경우, 배당받은 자에 대한 부당이득반환청구를 할 수 있는 가에 대하여 **배당요구채권자가 아닌 우선채권자는 배당을 받은 자에 대하여 부당이득반환청구권이 있다.**

확정된 배당표에 의하여 배당을 실시하는 것은 실체법상의 권리를 확정하는 것이 아니므로 배당을 받아야 할 자가 배당을 받지 못하고 배당을 받지 못할 자가 배당을 받은 경우에는

배당에 관하여 이의를 한 여부 또는 형식상 배당절차가 확정되었는지 여부에 관계없이 배당을 받지 못한 채권자는 배당받은 자에 대하여 부당이득반환을 청구할 수 있다(대판 2004. 4. 9, 2003다32681; 동지 대판 2000. 10. 10, 99다53230; 대판 2008. 6. 26, 2008다19966; 대판 2007. 2. 9, 2006다39546 등).

③ 그러나 실체법상 우선변제권자라도 **배당요구채권자라면 배당요구를 하지 않는 한 배당받은 후순위권리자에 대하여 부당이득반환을 청구하지 못한다.**

(i) 민사소송법 제728조에 의하여 준용되는 제605조 제1항에서 규정하는 배당요구 채권자는 경락기일까지 배당요구를 한 경우에 한하여 비로소 배당을 받을 수 있고, 적법한 배당요구를 하지 아니한 경우에는 임금채권과 같이 실체법상 우선변제청구권이 있는 채권자라 하더라도 그 매수대금으로부터 배당을 받을 수는 없을 것이므로, 이러한 배당요구 채권자가 적법한 배당요구를 하지 아니하여 그를 배당에서 제외하는 것으로 배당표가 작성·확정되고 그 확정된 배당표에 따라 배당이 실시되었다면, 집행목적물의 교환가치에 대하여서만 우선변제권을 가지고 있는 법정당보물권자의 경우와는 달리 그가 적법한 배당요구를 한 경우에 배당받을 수 있었던 금액 상당의 금원이 후순위 채권자에게 배당되었다 하여 이를 법률상 원인이 없는 것이라고 할 수 없다(대판 1996. 12. 20, 95다28304; 다만 2003. 1. 24, 2002다64254는 채납처분절차를 주관하는 기관은 임금채권자에게 배분할 금액을 직권으로 확정하여 배분계산서를 작성하여야 하는 이유로 배분요구를 하지 아니한 경우라도 임금채권자는 후순위권리자를 상대로 부당이득의 반환을 청구할 수 있다고 하여 예외를 인정하고 있다).

(ii) 주택임대차보호법에 의하여 우선변제청구권이 인정되는 임대차보증금반환채권은 현행법상 배당요구가 필요한 배당요구채권에 해당하고, 이러한 배당요구채권자가 적법한 배당요구를 하지 아니하여 그를 배당에서 제외하는 것으로 배당표가 작성·확정되고 그 확정된 배당표에 따라 배당이 실시되었다면 그가 적법한 배당요구를 한 경우에 배당받을 수 있었던 금액 상당의 금원이 후순위채권자에게 배당되었다고 하여 이를 법률상 원인이 없는 것이라고 할 수 없다고 하여 임차인의 부당이득의 반환청구를 부정하고 있다(대판 1998. 10. 13, 98다12379). 소액보증금반환채권도 마찬가지이다(대판 2002. 1. 22, 2001다70702).

[판례] 주택임대차보호법상 임차인으로서의 지위와 전세권자로서의 지위를 함께 가지고 있는 자가 임차인으로서의 지위에 기하여 경매법원에 배당요구를 한 경우, 전세권에 관하여도 배당요구가 있는 것으로 볼 수 있는지 여부(소극)

(1) 민사집행법 제91조 제3항은 “전세권은 저당권·압류채권·가압류채권에 대항할 수 없는 경우에는 매각으로 소멸된다”라고 규정하고, 같은 조 제4항은 “ 제3항의 경우 외의 전세권은 매수인이 인수한다. 다만, 전세권자가 배당요구를 하면 매각으로 소멸된다”라고 규정하고 있고, 이는 저당권 등에 대항할 수 없는 전세권과 달리 최선순위의 전세권은 오로지 전세권자의 배당요구에 의하여만 소멸되고, 전세권자가 배당요구를 하지 않는 한 매수인에게 인수되며, 반대로 배당요구를 하면 존속기간에 상관없이 소멸한다는 취지라고 할 것인 점, 주택임차인이 그 지위를 강화하고자 별도로 전세권설정등기를 마치더라도 주택임대차보호법상 임차인으로서 우선변제를 받을 수 있는 권리와 전세권자로서 우선변제를 받을 수 있는 권리는 근거규정 및 성립요건을 달리하는 별개의 권리라고 할 것인 점 등에 비추어 보면, 주택임대차보호법상 임차인으로서의 지위와 전세권자로서의 지위를 함께 가지고 있는 자가 그 중 임

차인으로서의 지위에 기하여 경매법원에 배당요구를 하였다면 배당요구를 하지 아니한 전세권에 관하여는 배당요구가 있는 것으로 볼 수 없다(대판 2010. 6. 24, 2009다40790).

- (2) 주택임차인으로서의 우선변제를 받을 수 있는 권리와 전세권자로서 우선변제를 받을 수 있는 권리는 근거규정 및 성립요건을 달리하는 별개의 것이므로, 주택임대차보호법상 대항력을 갖춘 임차인이 임차주택에 관하여 전세권설정등기를 경료하였다거나 전세권자로서 배당절차에 참가하여 전세금의 일부에 대하여 우선변제를 받은 사유만으로는 변제받지 못한 나머지 보증금에 기한 대항력 행사에 어떤 장애가 있다고 볼 수 없다(대판 1993.12.24. 선고 93다39676).

[판례] 저당권에 우선하는 국세의 범위

국세기본법 제35조 제1항 제3호는 공시를 수반하는 담보물권과 관련하여 거래의 안전을 보장하려는 사법적 요청과 조세채권의 실현을 확보하려는 공익적 요청을 적절하게 조화시키려는 데 그 입법의 취지가 있으므로, 당해세가 담보물권에 의하여 담보되는 채권에 우선한다고 하더라도 이로써 담보물권의 본질적 내용까지 침해되어서는 아니 되고, 따라서 같은 법 제35조 제1항 제3호 단서에서 말하는 '그 재산에 대하여 부과된 국세'라 함은 담보물권을 취득하는 사람이 장래 그 재산에 대하여 부과될 것을 상당한 정도로 예측할 수 있는 것으로서 오로지 당해 재산을 소유하고 있는 것 자체에 담세력을 인정하여 부과되는 국세만을 의미하는 것으로 보아야 한다(대판[전합] 1999. 3. 18, 96다23814).

→ (재산자체의 세금 임 / 사업자의 부가가치세, 관세, 사업소득세, 자동차세 등은 제외된다)

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 우리 민법에는 소유자저당권이 인정되고 있다.
- ② 목적물의 종물에는 저당권의 효력이 미치지 않는다.
- ③ 저당권의 효력이 미치는 이자의 범위는 만기가 된 후의 2년분에 한한다.
- ④ 장래에 발생할 채권을 위하여 저당권을 설정할 수 없다.
- ⑤ 채권자가 각각 다른 수 개의 채권을 1개의 저당권으로 담보할 수 있다.

- ⑤. 저당권의 준공유로서 타당하다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 목적토지 위의 건물에는 저당권의 효력이 미치지 않는다.
- ② 지연이자에 대하여는 원본의 이행기 도과 후 1년분에 한하여 저당권의 효력이 미친다.
- ③ 저당권은 저당권의 목적으로 등기된 종물에만 미친다.
- ④ 저당권을 피담보채권과 분리하여 양도할 수 없다.
- ⑤ 전세권도 저당권의 목적이 될 수 있다.

- ③. 등기 여부와 상관없이 종물은 저당권의 목적이 된다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 설정등기의 경로와 임차인의 임차주택 입주, 주민등록전입신고, 임대차계약서상 확정일자 구비가 모두 같은 날에 이루어졌다면 저당권자가 임차보증금(7,000만원)에 우선하여 변제받을 수 있다.
 - ② 주택임대차보호법 제8조상의 소액임차인은 임차보증금 중 일정액에 관하여 다른 담보권자의 경매신청등기 전에 주택임대차보호법 소정의 대항요건을 갖춘 경우에는 1순위 저당권자에 우선하여 변제받을 권리가 있다.
 - ③ 동일한 부동산 위에 수 개의 저당권이 경합하는 경우에 각 저당권의 순위는 설정등기의 전후에 의하는바, 그 등기의 전후는 순위번호에 의한다.
 - ④ 저당목적물에 대하여 부과되는 국세(이른바 당해세)와 그 가산금은 국세기본법 제35조 소정의 법정기일과 저당권설정등기일의 선후에 의하여 저당권과의 우열이 정해진다.
 - ⑤ 근로자의 최종 3월분의 임금은 사용자의 총 재산에 대하여 저당권에 의하여 담보된 채권에 우선하여 변제되어야 한다.
- ④. 국세 및 지방세와 저당권의 순위는 조세채권의 납부기한과 저당권의 설정등기의 선후에 의하지만, 저당목적물 차체에 부과된 국세(상속세, 증여세 등 국세기본법 시행령 제18조 1항)와 가산금은 그 법정기일 이전에 설정된 저당권에 대해서도 언제나 우선한다(대판 1989. 9. 26, 89다카2515).

♣ 학습정리

- 1. 저당권에 의하여 담보되는 채권인 피담보채권은 금전소비대차에 의한 채권과 같은 금전채권인 경우가 보통이나, 금전채권이 아닌 그 밖의 채권이라 하더라도 저당권 실행시기에 금전채권으로 되어 있으면 충분하다. 또한 저당권의 효력이 미치는 피담보채권의 범위는 저당권에 의하여 우선변제를 받을 수 있는 채권액을 의미한다. 저당권에 의하여 담보되는 피담보채권의 범위는 원칙적으로 저당권설정계약에 의하여 정하여진다.
- 2. 저당권은 채무자가 채무를 변제하지 않는 경우에 궁극적으로 저당목적물을 처분하여 우선변제를 받는 것을 내용으로 하는 권리이므로, 그 효력이 미치는 목적물의 범위는 대체로 소유권이 미치는 범위와 일치한다. 다만 법률에 특별규정이 있는 경우와 설정행위에서 다른 약정을 한 경우 등에 대하여 예외를 두고 있다.
- 3. 저당권의 본래적인 효력은 목적물로부터 우선변제를 받는 것이다. 저당채무자가 피담보채권의 변제기가 도래하였음에도 불구하고 이를 변제하지 않은 경우에는 저당채권자는 저당권의 목적물을 일정한 절차에 따라 매각, 환가하여 그 대금으로부터 다른 채권자에 우선하여 변제를 받을 수 있다. 또한 저당권자가 저당권과 관계없이 하나의 채권자로서 채무자의 일반재산으로부터 변제를 받을 수도 있다.

제36강 저당권 (3)

♣ 학습목표

1. 저당권의 실행을 체계적으로 이해한다.
2. 담보권실행경매의 의의와 절차를 살펴본다.
3. 유저당의 개념과 종류를 검토한다.

♣ 학습내용

- 저당권 실행의 의의
- 담보권실행경매의 요건과 절차
- 민사집행법상 경매개시절차
- 유저당의 개념과 종류

♣ 사전 테스트

1. 전세권 등을 대상으로 하는 저당권은 일반적인 담보권실행경매절차에 의해야 한다.
⇒ × : 지상권이나 전세권을 대상으로 하는 저당권의 경우에는 일반적인 담보권실행경매절차에 의하지 않을 수 있다.
2. 이행기가 도래하기 전에 저당권자가 경매를 신청한 경우 매각허가결정이 확정되기까지 이행기가 도래해도 여전히 위법한 경매가 된다.
⇒ × : 이행기가 도래하기 전에 저당권자가 경매를 신청한 경우에도 매각허가결정이 확정되기까지 이행기가 도래하면 위법신청이라는 하자는 치유되고 적법한 경매로 된다.
3. 체납처분압류된 부동산 후 경매개시결정 전 유치권 취득자는 경매절차의 매수인에게 유치권을 행사할 수 없다.
⇒ × : 체납처분압류가 되어 있는 부동산이라고 하더라도 그러한 사정만으로 경매절차가 개시되어 경매개시결정등기가 되기 전에 부동산에 관하여 민사유치권을 취득한 유치권자가 경매절차의 매수인에게 유치권을 행사할 수 없다고 볼 것은 아니다.

♣ 강의교안

III. 저당권의 실행

1. 서 설

실행 : 채무자의 임의이행이 없는 경우에 담보물을 환가 → 변제받음

- ① 일반적으로 “담보권의 실행경매”(민사집행법 규율)
- ② “流抵當(유저당)”계약에 의한 사적 실행도 포함

<경매규율 법률>

종 래	현 재	
임의경매 (경매법)	담보권실행경매 (민사집행법 제3편)	· 민법(전세권, 유치권, 질권, 저당권), 가담법, 동산채권담보법, 임목법, 국세징수법 등
강제경매 (민사소송법)	강제경매 (민사집행법 제2편)	· 일반채권자에 의한 집행방법 · 주임법상 임차보증금반환청구는 판결을 받아(즉 집행 권원 필요) 경매할 수 있음(제3조의2 제1항)(상가건물 임대차보호법 제5조도 마찬가지)

관련법에 명문으로 경매권규정이 있는 것에 의한 경매를 담보권실행경매라고 한다.

→ 집행권원(판결문에 집행할 수 있음의 도장 받는 것)을 요하지 않는다. 그 권리 자체에 명문으로 경매권을 인정하고 있기 때문(단 경매신청시 저당권 존재 증명서류 제출).

지상권이나 전세권에 저당권을 설정하여 이를 실행하는 경우

지상권이나 전세권을 대상으로 하는 저당권의 경우에는 일반적인 담보권실행경매절차에 의하지 않을 수 있다.

대결 1995. 8. 14, 95마684는 전세권에 대하여 설정된 저당권은 민사집행법 제264조 소정의 부동산 경매절차에 의하여 실행하는 것이나, 전세권의 존속기간이 만료되면 전세권의 용익물권적 권능이 소멸하기 때문에 더 이상 전세권 자체에 대하여 저당권을 실행할 수 없게 되고, 이러한 경우는 민법 제370조, 제342조 및 민사집행법 제273조에 의하여 저당권의 목적물인 전세권에 갈음하여 존속하는 것으로 볼 수 있는 전세금반환채권에 대하여 ① 추심명령 또는 ②전부명령을 받거나(이 경우 저당권의 존재를 증명하는 등기사항증명서를 집행법원에 제출하면 되고 별도의 채무명의를 필요한 것은 아니다), ③제3자가 전세금 반환채권에 대하여 실시한 강제집행절차에서 배당요구를 하는 등의 방법으로 자신의 권리를 행사할 수 있을 뿐이다(지원림).

2. 담보권실행경매

(1) 의 의

담보권 실행으로 인한 경매 ↔ 강제경매

(2) 저당권실행의 요건

(가) 저당권의 존재

민사집행법

제264조(부동산에 대한 경매신청)

① 부동산을 목적으로 하는 담보권을 실행하기 위한 경매신청을 함에는 담보권이 있다는 것을 증명하는 서류를 내야 한다. → 등기부등본 등

②담보권을 승계한 경우에는 승계를 증명하는 서류를 내야 한다.

(나) 이행지체 변제기 미도래 경우 → 그 신청은 부적합한 것으로 각하(대판 1968. 4. 24, 68마300). 다만 이행기가 도래하기 전에 저당권자가 경매를 신청한 경우에도 매각허가결정이 확정되기까지 이행기가 도래하면 위법신청이라는 하자는 치유되고 적법한 경매로 된다(통설).

(3) 경매의 절차

1) 경매의 신청 경매신청서를 부동산 소재지의 지방법원에 제출(민사집행법 제268조, 제78조 제1항). 저당권자는 경매신청을 취하할 수 있으나, 매수신고가 있는 후 신청을 취하하려면 최고가 매수신고인과 차순위 매수신고인의 동의가 있어야 한다(민사집행법 제268조·제93조).

2) 경매개시결정 적법한 경매의 신청이 있으면 관할법원은 경매개시결정을 하고 동시에 그 저당부동산의 압류를 명한다(민사집행법 제268조·제83조 제1항). 경매개시결정에 대한 이해관계인의 이의사유로서는 저당권의 부존재 또는 소멸만이 인정된다(민사집행법 제265조). 법원은 경매개시결정과 동시에 관할등기소에 경매신청의 기입등기를 촉탁한다(민사집행법 제94조). 경매개시결정이 채권자에게 송달된 때 또는 개시결정이 등기된 때 목적물에 대한 압류의 효력이 생긴다(민사집행법 제268조·제83조 제4항). 법원은 경매개시결정을 한 후 지체 없이 집행관에게 집행관에게 부동산의 현상, 점유관계, 차임 또는 보증금의 액수 그 밖의 현황에 관하여 조사할 것을 명하여야 한다(민사집행법 제268조·제85조 제1항).

3) 매각 집행법원은 경매 및 매각결정기일을 정하여 공고하고 아울러 이를 이해관계인에게 통지한다(민사집행법 제104조 제1항·제2항). 저당물의 소유권을 취득한 제3자도 경매인이 될 수 있다(민법 제363조 제2항). 그리고 민사집행법은 잉여주의를 취하고 있으므로(제91조 제1항) 법원은 최저매각가격으로 압류채권자의 채권에 우선하는 부동산의 모든 부담과 절차비용을 변제하고도 남음이 있다고 인정되는 등의 사유가 있는 때에는 직권으로 매각기일과 매각결정기일을 정하여 공고하고, 이를 이해관계인에게 통지하여야 한다(민사집행법 제104조 제1항·제2항·제268조). 만약 남을 것이 없다면 민사집행법 제268조·제102조 규정에 따라 경매절차취소의 절차를 거쳐야 한다. 매각기일에 상당한 매수가격의 신고인이 없을 때에는 최저매각가격을 상당히 저감하고 새매각기일을 정하여 매각하여야 한다(민사집행법 제110조). 매각가격기일은 매각기일로부터 7일 이내로 정하고, 매각가격결정절차는 법원 안에서 하여야 한다(민사집행법 제109조).

4) 매각허가결정 최고가 매수인이 정하여지면 법원은 매각기일을 열어 매각허가결정을 한다(민사집행법 제120조 제1항·제128조). 매각허가결정이 확정된 때에는 매수인은 법원이 정하는 대금지급기일에 매각대금을 법원에 완납하여야 하고(민사집행법 제142조), 매각대금을 완납한 때에 매수인은 경매부동산의 소유권을 취득한다(민사집행법 제135조). 매수인이 대금을 완납한 때에는 법원은 매수인의 소유권 등기를 관할등기소에 촉탁한다(민사집행법 제144조).

5) 매각대금의 배당 매수인이 매수대금을 지급하면 법원은 배당기일을 정하여 이해관계인과 배당을 요구한 채권자를 소환·심문하여 배당표를 확정하고 배당을 실시한다(민사집행법 제149조).

- 6) 재매각 매수인이 대금지급기일에 그의 의무를 완전히 이행하지 아니하고 차순위 매수신고인이 없는 때에는 법원은 직권으로 부동산의 재경매를 명하여야 한다(민사집행법 제138조).

→ 담보권실행경매에서 (근)저당권자가 배당요구를 하지 않았다 하여도 배당에서 제외하여서는 안 되고, 만약 배제하고 배당하였다면 이미 배당받은 자에 대해 부당이득반환청구할 수 있음 (배당요구채권자와 구별)

(4) 매각의 효과

- 1) 매수인의 권리취득 매각의 효과로서 매수인은 경매의 목적이었던 권리를 취득한다. 저당부동산의 소유자로부터 매수인에게 소유권이 이전되는 시기는 매각대금을 완납한 때이다(민사집행법 제135조). 이 경우의 물권변동은 제187조에 의하여 등기 없이 그 효력이 발생한다(제187조).

2) 매각목적물 위의 다른 권리

▶ 돌발 퀴즈

저당권이 실행되면 다른 저당권, 용익물권, 등기된 임차권은 소멸한다.

: ×. 저당권에 대항할 수 있는 용익물권 및 등기된 임차권은 소멸되지 않는다.

★민사집행법★

제91조(인수주의와 잉여주의의 선택 등)

- ① 압류채권자의 채권에 우선하는 채권에 관한 부동산의 부담을 매수인에게 인수하게 하거나, 매각대금으로 그 부담을 변제하는 데 부족하지 아니하다는 것이 인정된 경우가 아니면 그 부동산을 매각하지 못한다. → **잉여주의**
- ② 매각부동산 위의 모든 저당권은 매각으로 소멸된다. → **소제주의(또는 소멸주의)**
- ③ 지상권·지역권·전세권 및 등기된 임차권은 저당권·압류채권·가압류채권에 대항할 수 없는 경우에는 매각으로 소멸된다. → **소제주의(또는 소멸주의)**
- ④ 제3항의 경우 외의 지상권·지역권·전세권 및 등기된 임차권은 매수인이 인수한다. 다만, 그중 전세권의 경우에는 전세권자가 제88조에 따라 배당요구를 하면 매각으로 소멸된다. → **인수주의**
- ⑤ 매수인은 유치권자)에게 그 유치권으로 담보하는 채권을 “**변제할 책임이 있다**”.
→ 채무까지 인수한다는 의미가 아니라 변제있을 때까지 인도를 거절할 수 있다는 의미 (판례)

제92조(제3자와 압류의 효력)

- ① 제3자는 권리를 취득할 때에 경매신청 또는 압류가 있다는 것을 알았을 경우에는 압류에 대항하지 못한다. → **압류의 처분금지효**

제83조(경매개시결정 등)

- ① 경매절차를 개시하는 결정에는 동시에 그 부동산의 압류를 명하여야 한다.
- ② 압류는 부동산에 대한 채무자의 관리·이용에 영향을 미치지 아니한다.
- ③ 경매절차를 개시하는 결정을 한 뒤에는 법원은 직권으로 또는 이해관계인의 신청에 따라 부동산에 대한 침해행위를 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 수 있다.
- ④ 압류는 채무자에게 그 결정이 송달된 때 또는 제94조의 규정에 따른 등기가 된 때에 효력이 생긴다.
- ⑤ 강제경매신청을 기각하거나 각하하는 재판에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다.

< 제3항의 대항할 수 없는 경우(소멸) 또는 있는 경우(인수)의 판단기준 >
→ 말수기준권리(말소기준등기) 또는 최선순위의 저당권기준

1. 저당부동산 위에 존재하던 다른 저당권은 순위에 관계없이 모두 소멸한다(소제주의 제2항)

2. 저당목적물 위에 존재하던 용익권(용익물권과 대항력 있는 임차권)의 운명은 “최선순위”의(소제주의를 상기하라) 저당권과의 우선순위에 따라 결정된다. 즉 그보다 선행순위의 용익권은 존속하지만(매수인이 이를 인수한 것으로 된다), 후순위의 용익권은 소멸한다. 다만 전세권이 선행순위이더라도 전세권자가 배당요구를 하면 매각으로 소멸된다(제4항)

3-1. 반면에 유치권은 저당권설정등기가 (가)압류등기(경매개시결정등기) 전·후를 불문하고 매각에 의하여 소멸되지 않는다(제5항)(무조건 불소멸의 인수주의) → 즉 경매개시결정 후에도 필요비·유익비를 지출하여 유치권행사가 가능 (임차인이 경락을 방해하기 위해 경매개시결정 후에 필요비를 지출하여 유치권행사 → 유찰 유도 현실)

3-2. 이와 같은 유치권을 주장하는 자의 존재로 인하여 매수인이 예기치 않은 불이익을 입을 가능성 발생

→ 매수인(매수인)보호 노력이 나타나는 판례가 보임 → **대법원 2014. 3. 20. 선고 2009다 60336 전합판**

① 대법원 2005.08.19. 선고 2005다22688 판결[건물명도등]

채무자 소유의 건물 등 부동산에 “**강제경매개시결정의 기입등기가 경료되어 압류의 효력이 발생한 이후에**” 채무자가 위 부동산에 관한 **공사대금 채권자에게 그 점유를 이전함**으로써 그로 하여금 유치권을 취득하게 한 경우, 그와 같은 점유의 이전은 목적물의 교환가치를 감소시킬 우려가 있는 처분행위에 해당하여 민사집행법 제92조 제1항, 제83조 제4항에 따른 압류의 처분금지효에 저촉되므로 점유자로서는 위 유치권을 내세워 그 부동산에 관한 경매절차의 매수인에게 대항할 수 없다.

② 위 경우 유치권을 주장하는 자가 경매개시결정의 기입등기 경료에 대한 선의·무과실이어도 매수인(매수인)에게 대항하지 못함(대판 2006. 8. 25, 2006다22050).

③ 대법원 2011.10.13. 선고 2011다55214 판결[유치권부존재확인]도 마찬가지 임.

유치권은 목적물에 관하여 생긴 채권이 변제기에 있는 경우에 비로소 성립하고(민법 제 320조), 한편 채무자 소유의 부동산에 경매개시결정의 기입등기가 마쳐져 압류의 효력이 발생한 후에 유치권을 취득한 경우에는 그로써 부동산에 관한 경매절차의 매수인에게 대항할 수 없는데, 채무자 소유의 건물에 관하여 증·개축 등 공사를 도급받은 수급인이 경매개시결정의 기입등기가 마쳐지기 전에 채무자에게서 건물의 점유를 이전받았다 하더라도 경매개시결정의 기입등기가 마쳐져 압류의 효력이 발생한 후에 공사를 완공하여 공사대금채권을 취득함으로써 그때 비로소 유치권이 성립한 경우에는, 수급인은 유치권을 내세워 경매절차의 매수인에게 대항할 수 없다.

보충판례

[판례] 근저당권설정 후 경매로 인한 압류의 효력 발생 전에 취득한 유치권으로 경매절차의 매수인에게 대항할 수 있는지 여부(적극)

부동산 경매절차에서의 매수인은 민사집행법 제91조 제5항에 따라 유치권자에게 그 유치권으로 담보하는 채권을 변제할 책임이 있는 것이 원칙이나, 채무자 소유의 건물 등 부동산에 경매개시결정의 기입등기가 경료되어 압류의 효력이 발생한 후에 채무자가 위 부동산에 관한 공사대금 채권자에게 그 점유를 이전함으로써 그로 하여금 유치권을 취득하게 한 경우, 그와 같은 점유의 이전은 목적물의 교환가치를 감소시킬 우려가 있는 처분행위에 해당하여 민사집행법 제92조 제1항, 제83조 제4항에 따른 압류의 처분금지효에 저촉되므로 점유자로서는 위 유치권을 내세워 그 부동산에 관한 경매절차의 매수인에게 대항할 수 없다. 그러나 이러한 법리는 경매로 인한 압류의 효력이 발생하기 전에 유치권을 취득한 경우에는 적용되지 아니하고, 유치권 취득시기가 근저당권설정 후라거나 유치권 취득 전에 설정된 근저당권에 기하여 경매절차가 개시되었다고 하여 달리 볼 것은 아니다(대판 2009. 1. 15, 2008다70763).

[판례] 유치권자가 매수인에 대하여 피담보채권의 변제를 청구할 수 있는지 여부(소극)

민사소송법 제608조 제3항(**현 민사집행법 제91조 제5항**)에서 매수인은 유치권자에게 그 유치권으로 담보하는 채권을 변제할 책임이 있다는 규정은 매수인이 부동산상의 부담을 승계한다는 취지로서 인적 채무까지 인수한다는 취지는 아니다. 유치권자는 매수인에 대하여 그 피담보채권의 변제가 있을 때까지 유치목적물인 부동산상의 인도를 거절할 수 있을 뿐이고, 그 피담보채권의 변제를 청구할 수는 없다(대판 1996. 8. 23, 95다8713).

[결론]

원칙 : 유치권은 무조건 불소멸의 인수주의

제한 : 판례해석상 “압류의 처분금지효”적용하여 압류등기(**경매개시결정등기**)후에 유치권성립하는 경우는 그 유치권자는 매수인에게 대항 못함

※ 주의 : 가압류와 압류와 차이가 있는 점

“압류”후 유치권이 성립한 경우 그 유치권자는 매수인에게 대항 못함.

“가압류” 후 유치권이 성립한 경우 그 유치권자는 매수인에게 대항 가능.

[판례] 부동산에 가압류등기가 경료된 후에 채무자의 점유이전으로 제3자가 유
치권을 취득하는 경우, 가압류의 처분금지효에 저촉되는지 여부(소극)(대판
2011.11.24., 2009다19246 판결[건물명도등])

부동산에 가압류등기가 경료되면 채무자가 당해 부동산에 관한 처분행위를 하
더라도 이로써 가압류채권자에게 대항할 수 없게 되는데, 여기서 처분행위란 당
해 부동산을 양도하거나 이에 대해 용익물권, 담보물권 등을 설정하는 행위를
말하고 특별한 사정이 없는 한 점유의 이전과 같은 사실행위는 이에 해당하지
않는다. 다만 부동산에 경매개시결정의 기입등기가 경료되어 압류의 효력이 발
생한 후에 채무자가 제3자에게 당해 부동산의 점유를 이전함으로써 그로 하여
금 유치권을 취득하게 하는 경우 그와 같은 점유의 이전은 처분행위에 해당한
다는 것이 당원의 판례이나, 이는 어디까지나 경매개시결정의 기입등기가 경료
되어 압류의 효력이 발생한 후에 채무자가 당해 부동산의 점유를 이전함으로써
제3자가 취득한 유치권으로 압류채권자에게 대항할 수 있다고 한다면 경매절차
에서의 매수인이 매수가격 결정의 기초로 삼은 현황조사보고서나 매각물건명세
서 등에서 드러나지 않는 유치권의 부담을 그대로 인수하게 되어 경매절차의
공정성과 신뢰를 현저히 훼손하게 될 뿐만 아니라, 유치권신고 등을 통해 매수
신청인이 위와 같은 유치권의 존재를 알게 되는 경우에는 매수가격의 즉각적인
하락이 초래되어 책임채산을 신속하고 적정하게 환가하여 채권자의 만족을 얻
게 하려는 민사집행제도의 운영에 심각한 지장을 줄 수 있으므로, 위와 같은 상
황하에서는 채무자의 제3자에 대한 점유이전을 압류의 처분금지효에 저촉되는
처분행위로 봄이 타당하다는 취지이다. 따라서 이와 달리 부동산에 가압류등기
가 경료되어 있을 뿐 **“현실적인 매각절차가 이루어지지 않고 있는 상황”** 하
에서는 채무자의 점유이전으로 인하여 제3자가 유치권을 취득하게 된다고 하더
라도 이를 처분행위로 볼 수는 없다.

- ④ 위의 경우처럼 “부동산 경매개시결정과 동시에 압류등기” 후의 유치권이 성립하는 경우
는 경매 매수인에게 대항하지 못한다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2009다60336 전원합의
체 판결). 그런데 체납처분압류등기가 되어 있는 부동산(이하 체납처분압류 통상 공매개
시결정은 하지 않고 있다. 그리고 체납처분압류가 있어도 동시에 공매절차가 개시되는
것이 아니다.)도 “경매개시결정 및 압류등기”와 동일하게 해석하는가?

→ 체납처분압류된 부동산 후 경매개시결정 전 유치권 취득자는 경매절차의 매수인에게 유
치권을 행사할 수 있다(위 2014년 전합체 다수의견).

대법원 2014. 3. 20. 선고 2009다60336 전원합의체 판결

【판시사항】

체납처분압류가 되어 있는 부동산에 대하여 경매절차가 개시되기 전에 민사유치권
을 취득한 유치권자가 경매절차의 매수인에게 유치권을 행사할 수 있는지 여부(적
극)

【판결요지】

[다수의견] 부동산에 관한 민사집행절차에서는 경매개시결정과 함께 압류를 명하므로 압류가 행하여짐과 동시에 매각절차인 경매절차가 개시되는 반면, 국세징수법에 의한 체납처분절차에서는 그와 달리 체납처분에 의한 압류(이하 ‘체납처분압류’라고 한다)와 동시에 매각절차인 공매절차가 개시되는 것이 아닐 뿐만 아니라, 체납처분압류가 반드시 공매절차로 이어지는 것도 아니다. 또한 체납처분절차와 민사집행절차는 서로 별개의 절차로서 공매절차와 경매절차가 별도로 진행되는 것이므로, 부동산에 관하여 체납처분압류가 되어 있다고 하여 경매절차에서 이를 그 부동산에 관하여 경매개시결정에 따른 압류가 행하여진 경우와 마찬가지로 볼 수는 없다.

따라서 체납처분압류가 되어 있는 부동산이라고 하더라도 그러한 사정만으로 경매절차가 개시되어 경매개시결정등기가 되기 전에 부동산에 관하여 민사유치권을 취득한 유치권자가 경매절차의 매수인에게 유치권을 행사할 수 없다고 볼 것은 아니다.

[대법관 신영철, 대법관 민일영, 대법관 박보영의 반대의견] 국세징수법에 의한 체납처분절차는 압류로써 개시되고, 체납처분에 의한 부동산 압류의 효력은 민사집행절차에서 경매개시결정의 기입등기로 인한 부동산 압류의 효력과 같으므로, 조세채납자 소유의 부동산에 체납처분압류등기가 마쳐져 압류의 효력이 발생한 후에 조세채납자가 제3자에게 그 부동산의 점유를 이전하여 유치권을 취득하게 하는 행위는 체납처분압류권자가 체납처분압류에 의하여 파악한 목적물의 교환가치를 감소시킬 우려가 있는 처분행위에 해당하여 체납처분압류의 처분금지효에 저촉되므로 유치권으로써 공매절차의 매수인에게 대항할 수 없다.

나아가 체납처분에 의한 부동산 압류 후 그 부동산에 관하여 개시된 경매절차에서 부동산이 매각되는 경우에 마치 공매절차에서 부동산이 매각된 것과 같이 매수인이 체납처분압류의 부담을 인수하지 아니하고 체납처분압류등기가 말소되는바, 선행하는 체납처분압류에 의하여 체납처분압류권자가 파악한 목적물의 교환가치는 그 후 개시된 경매절차에서도 실현되어야 하므로, 체납처분압류의 효력이 발생한 후에 채무자로부터 점유를 이전받아 유치권을 취득한 사람은 유치권으로써 경매절차의 매수인에게 대항할 수 없다고 보아야 한다.

4. 담보가등기는 순위에 관계없이 모두 말소되지만(가담법 제12조 제1항 후문에 따라 담보가등기는 저당권으로 간주되므로 소제주의의 적용을 받는다), **보전가등기**는 최선순위의 저당권에 앞선 것이라면 말소되지 않는다.

4) 경매의 하자

공신력의 문제와 경매의 하자 구별

(요약)

1. 공신력의 문제 →(동산의 선의취득/ 부동산 선의취득 불가하여 담보책임)문제
(아래 그림에서 ①의 단계에 문제가 있는 경우 : 즉 **A → B** 단계)

: 동산에는 공신력이 있으므로 경매 매수인은 선의취득한다
 부동산에는 공신력이 없어 경매 매수인은 소유권을 상실하고 채무자 상대로 담보책임

2. 경매의 하자 문제(경매신청자의 채권에 하자가 있는 경우)

(아래 그림에서 ②의 단계에 문제가 있는 경우 : 즉 **B <- - C** 단계)

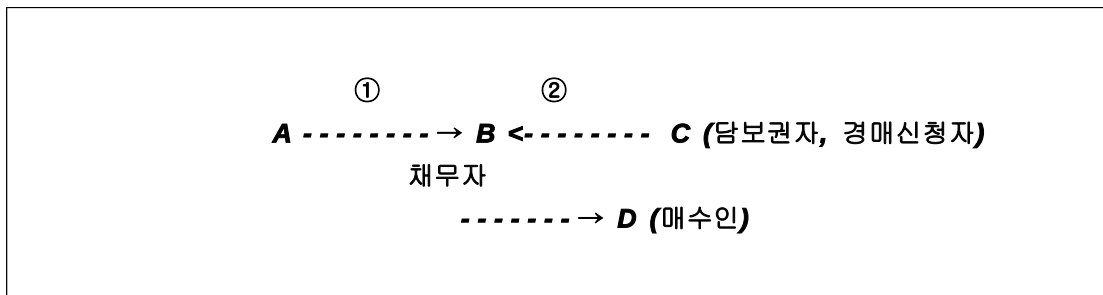
① 경매가 무효가 되는 경우(경락허가결정 이전에 처음부터 피담보채권이 없거나 위조문서)

→ 매수인은 소유권을 상실하고 배당채권자를 상대로 부당이득반환청구

(이 때 매수인은 채무자를 상대로 담보책임을 물을 수 없다. 판례)

② 경매가 유효인 경우(경락허가결정 이후에 변제 등으로 피담보채권이 소멸한 경우)

→ 매수인은 소유권 취득(매수대금 완납시)



(설명)

1. 선의취득(공신력)의 문제 또는 담보책임의 문제 -> 위의 ①의 단계에서 하자가 있는 경우

위의 ①에서 하자가 있다면 B는 무권리자가 됨

(하자 : 원인무효(위조문서/제103조)·미성년자 취소·제3자에게 대항가능한 취소)

(B에게 취소권 행사전 선의의 제3자 C가 저당권설정한 경우는 C의 저당권 유효)

이 때 무권리자로부터 경락받은 D의 소유권은?

: 동산인 경우 → 선의취득

부동산인 경우 → 선의취득불가 (→ 부동산소유권을 상실한 D는 B를 상대로 담보책임)

2. 경매의 하자 -> 위의 ②의 단계에서 하자(실체법적 하자)가 있는 경우

① 처음부터(경매개시결정 이전부터) 피담보채권이 없거나(부존재), 위조 문서(무효)에 의한 저당권인 경우(즉 저당권이 부존재 또는 무효인 경우)

→ 경매자체가 무효로 됨 → 매수인은 소유권 취득 못함 → 채무자는 매수인에게 소유권 이전등기말소청구(이 때 매수인은 매수대금반환을 이유로 동시이행항변권 행사 못함)

(대판 2006.9.22., 2006다24049), 매수인은 배당채권자에게 부당이득반환청구할 수 있음.

[판례] 대판 1991.10.11., 91다21640.

가. 민법 제578조 제1항, 제2항은 매매의 일종인 경매에 있어서 그 목적물의 하자로 인하여 매수인이 경락의 목적인 재산권을 완전히 취득할 수 없을 때에 매매의 경우에 준하여 매도인의 위치에 있는 경매의 채무자나 채권자에게 담보책임을 부담시켜 매수인을 보호하기 위한 규정으로서, 그 담보책임은 매매의 경우와 마찬가지로 경매절차는 유효하게 이루어졌으나 경매의 목적이 된 권리의 전부 또는 일부가 타인에게 속하는 등의 하자로 매수인이 완전한 소유권을 취득할 수 없거나 이를 잃게 되는 경우에 인정되는 것이고, 경매절차 자체가 무효인 경우에는 경매의 채무자나 채권자의 담보책임은 인정될 여지가 없다.

나. 매수인이 강제경매절차를 통하여 부동산을 경락받아 대금을 납부하고 그 앞으로 소유권이전등기까지 마쳤으나, 그 후 위 강제집행의 채무명의로 된 약속어음공정증서가 위조된 것이어서 무효라는 이유로 그 소유권이전등기의 말소를 명하는 판결이 확정됨으로써 경매 부동산에 대한 소유권을 취득하지 못하게 된 경우 매수인은 경매 채권자에게 경매 대금 중 그가 배당받은 금액에 대하여 일반 부당이득의 법리에 따라 반환을 청구할 수 있을 뿐, 민법 제578조 제2항에 의한 담보책임을 물을 수는 없다.

② 저당권이 유효하게 성립하였으나 경매개시결정 이후 피담보채권이 소멸하여 저당권이 소멸한 경우(즉 저당권이 소멸한 경우) → 절차 정지 또는 취소해야 → 계속 진행하여 매수인이 매각대금 완납한 경우 → 매수인은 소유권 취득함(채무자는 다투지 못함)

2. 담보권실행경매에 의하지 않는 저당권실행(저당권의 사적실행 : 유저당)

(1) 유저당계약

① 저당권설정계약에서 동시에 유저당계약/ 별도로 피담보채권의 변제기 도래 전의 특약 (변제기 후에 채권자가 소유권을 취득하기로 계약하는 것은 대물변제계약(요물계약)이 되어 당연히 인정된다)

② 유저당금지규정 없음(인정. 통설·판례)

↔ 유질계약금지규정 있음(제339조. 폐지 주장하는 견해 있음)

③ 방법(모습)

㉠ 대물변제예약형 유저당 : 저당권자가 소유권취득

㉡ 임의환가의 약정형 유저당 : 저당물을 매각해서 변제에 충당

(2) 유저당의 모습

1) 대물변제예약형 유저당(소유권 이전형 유저당)

① 저당채무의 불이행시 목적물의 소유권을 저당권자가 취득하기로 하는 경우

(대물변제형 유저당).

→ 단 피담보채권이 소비대차계약에 기한 것이라면 제607조, 제608조가 적용되며, 가등기(소유권이전등기)와 결부되면 가담법이 적용된다. 따라서 소유권이전형 유저당은 가담법의 적용이 없는 대물변제 예약에 한정할 것이다.

② 유저당 인정여부 : 유질계약금지(제399조, 물론 입법론으로 폐지 견해)에 비해 저당권은 유저당금지규정이 없고, 경매에 의한 실행은 번잡하고, 유저당이 저당권자 저당권설정자에게 모두 유리할 수도 있으므로 유저당인정.

③ 종전 판례 : 원리금의 합산액 보다 저당목적물의 가액이 초과인 경우

→ 제607조, 제608조 위반→ 대물변제예약 무효(62년 판례)

변경 판례 : “대물반환예약의 효력은 인정될 수 없다 하여도 양도담보의 효력은 인정되어야 할 것이며 그 채무담보를 근저당권설정등기가 되어 있다 하여도 아무런 영향을 줄 바 못 된다”고 하여 이른바 “약한 의미의 양도담보”로서의 효력을 인정(대판 1968. 6. 28, 68다762,763)

약한 의미의 양도담보	가등기 담보법
●채권발생원인 제한 없다 (단 가담법이 적용될 경우에는 가담법이 적용)	●소비대차계약에 제한 (소수설/판례) (607조,608조의 특별법이므로)
●채권자가 정산 전에는 <u>언제든지</u> 변제하고 가 등기 또는 본등기 말소를 구할 수 있음 (따라서 가등기 및 소유권이전등기말소청구권은 소멸시효 걸리지 않음. 87다카62)	●제11조 단서 변제기 <u>10년</u> 경과 또는 선의의 제3자가 소유권을 취득한 경우에는 가 등기 또는 본등기 말소를 구할 수 없음
●양도담보권자의 부동산 처분의 경우 ① 신탁적소유권이전설 ->권리자의 처분->상대방 <u>선악불문</u> 소유권이전 ② 담보물권설 ->무권리자의 처분->상대방 <u>선악불문</u> <u>소유권이전하지 않음</u>	●양도담보권자의 부동산 처분의 경우 ① 신탁적소유권설 (다만 가담법 적용되는 양도 담보는 제11조에 의해 악의자는 배제됨) ② 담보물권설 (다만 가담법 적용되는 양도담보는 제11조에 의해 선의자는 보호됨)
●정산기간 없음	●정산기간 있음(제3조 : 2개월)
●귀속청산(담보권자의 소유권 취득) 처분청산(<u>환가처분, 즉 경매아닌 임의현금화형</u>)	●제4조 귀속청산(즉 소유권 취득)과 제12조 처분청산(<u>경매</u>)이 있음

※ 넓은 의미의 양도담보 :

약한 의미의 양도담보(협의의 양도담보) + 가담법 적용되는 양도담보

④ 위 판례의 약한 의미의 양도담보(학설도 지지) 이론 구성 :

- (i) 일부무효법리(부당이득반환청구권)
- (ii) 무효행위의 전환법리(계약상 청구권)

2) 임의환가의 약정형

- ① 임의현금화의 약정 즉, 담보권실행경매가 아닌 제3자에게 매각하여 청산하기로 하는 약정(구 체적으로는 저당권자 명의로 소유권을 이전한 후 제3자에게 매각하는 방법 또는 채무자명의 인채로 제3자에게 매각하는 방법)
- ② 처분대금에서 정산하고 잔여금액을 저당권설정자에게 반환함
- ③ 제3자 명의로 소유권이전등기 된 때 확정적으로 피담보채권 소멸함(다수설)
(↔ 정산금을 지급받은 때 소멸한다는 견해 있음)
따라서 그때까지 저당권설정자는 피담보채무를 변제하고 저당목적물을 되찾아 올 수 있다.

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 저당권은 목적물로부터 다른 채권자 보다 우선변제를 받을 수 있는 약정 담보물권이다.
 - ② 저당권은 목적물의 점유를 설정자에게 남겨 둔다.
 - ③ 저당권은 일종의 타물권이다.
 - ④ 저당권은 불가분성을 가진다.
 - ⑤ 저당권은 물상대위성을 가지지 않는다.
- ⑤. 물상대위성이란 담보물이 멸실하면 가치변형된 다른 권리 위로 옮겨가서 권리를 행사하는 것으로서 저당권자에도 물상대위성이 인정된다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 목적토지 위의 건물에는 저당권의 효력이 미치지 않는다.
 - ② 지연이자에 대하여는 원본의 이행기 도과 후 1 년분에 한하여 저당권의 효력이 미친다.
 - ③ 저당권은 저당권의 목적으로 등기된 종물에만 미친다.
 - ④ 저당권을 피담보채권과 분리하여 양도할 수 없다.
 - ⑤ 전세권도 저당권의 목적이 될 수 있다.
- ③ 등기 여부와 상관없이 종물은 저당권의 목적이 된다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 저당권보다 먼저 설정된 지상권은 저당권자의 경매신청에 따른 매각으로 매수인에게 인수되지만, 저당권보다 나중에 설정된 지상권은 매각으로 소멸한다.

- ② 가압류등기가 먼저 된 후 저당권이 설정된 경우, 물권자인 저당권자는 가압류채권자에 우선하여 변제받는다.
 - ③ 저당권보다 먼저 설정된 전세권이 있는 경우, 저당권자가 신청한 경매절차에서 전세권자가 배당요구를 하였다면 그 전세권은 매각으로 소멸한다.
 - ④ 경매신청등기 이전에 대항요건을 구비한 주택임대차보호법 제8조의 보증금 중 일정액은 저당권자에게 우선하여 변제된다.
 - ⑤ 최종 3개월분의 임금이나 최종 3년간의 퇴직금은 저당권에 의해 담보된 채권보다 우선하여 변제된다.
- ②. 가압류등기가 먼저 된 후 저당권이 설정된 경우, 저당권자와 가압류채권자는 동순위로서 각 채권액에 비례하여 평등배당을 받게 된다.

♣ 학습정리

1. 저당권의 실행이란 채무자의 임의이행이 없는 경우에 저당권자가 저당물을 환가하고, 그것으로 부터 자신의 채권을 변제받는 것을 말한다. 저당권의 실행은 일반적으로 민사집행법이 정하는 담보권의 실행경매에 의하지만, 넓은 의미에서는 기타의 실행수단도 포함한다.
2. 경매절차의 하자에는 절차상의 하자와 실체법상의 하자로 나뉘는데, 절차상의 하자는 경락허가결정이 확정되면 그때까지 이의신청 등의 대상이 될 수 있었던 경매절차상의 하자는 치유되어 이를 가지고 다룰 수 없다. 따라서 채권의 변제기 전에 저당권을 실행하였다 하더라도 경매의 효과는 확정된다. 이와 달리 피담보채권이나 저당권의 소멸·무효·부존재 등과 같은 경매의 기초가 되는 실체법상의 하자는 경락허가결정이 확정되어 경락인이 대금을 완납하면 치유되고, 그 후 채무자는 경락인의 소유권취득을 다투지 못한다. 다만 목적물의 소유자가 채무자 또는 물상보증인이 아닌 경우에는 하자는 치유되지 않는다.
3. 경매절차는 유효하게 이루어졌으나 경매의 목적이 된 권리의 전부 또는 일부가 타인에게 속하는 등의 하자로 매수인이 완전한 소유권을 취득할 수 없거나 이를 잃게 되는 경우에 인정되는 것이고, 경매절차 자체가 무효인 경우에는 경매의 채무자나 채권자의 담보책임은 인정될 여지가 없다.

제37강 저당권 (4)

♣ 학습목표

1. 저당권과 용익권과의 관계를 이해한다.
2. 법정지상권의 의의와 성립요건을 체계적으로 정리한다.
3. 일괄경매청구권의 개념과 효력을 살펴본다.

♣ 학습내용

- 저당권과 용익관계
- 법정지상권의 의의와 성립요건
- 법정지상권과 관습법상 법정지상권의 비교
- 일괄경매청구권의 개념과 효력

♣ 사전 테스트

1. 저당권이 실행되면 제3자의 대항력 있는 용익권은 용익권과 저당권 설정의 선후에 따라 결정된다.
⇒ ○ : 저당권이 실행되면 제3자의 대항력 있는 용익권(예 : 지상권, 전세권, 대항력 있는 임차권)은 용익권과 저당권 설정의 선후에 따라 결정된다(다만 경매를 신청한 저당권의 순위가 아니라 최선순위의 저당권을 기준으로 함에 주의해야 한다).
2. 토지에 저당권설정 당시 건물이 없었으나, 그 후 건물신축시에 토지저당권자가 건축에 관한 동의를 한 경우에 법정지상권은 성립한다.
⇒ × : 토지에 저당권설정 당시 건물이 없었다면 그 후 건물신축시에 토지저당권자가 건축에 관한 동의를 한 경우에도 법정지상권은 성립하지 않는다(대판 2003. 9. 5, 2003다26051).
3. 토지의 저당권자는 토지만에 대하여 경매를 신청한 후에는 토지에 관한 경매기일 공고시까지 일괄경매의 추가신청을 할 수 없다.
⇒ × : 토지의 저당권자는 토지만에 대하여 경매를 신청한 후에도 그 토지상의 건물에 대하여 토지에 관한 경매기일 공고시까지는 일괄경매의 추가신청을 할 수 있다(대결 2001. 6. 13, 2001마1632).

♣ 강의교안

IV. 저당권과 용익관계

1. 저당권과 용익관계일반

인수주의 및 소제주의(소멸주의) 참조
특히 중간임차인은 소제주의 적용되어 소멸됨.

저당권이 실행되면 제3자의 대항력 있는 용익권(예 : 지상권, 전세권, 대항력 있는 임차권)은 용익권과 저당권 설정의 선후에 따라 결정된다(다만 경매를 신청한 저당권의 순위가 아니라 최선순위의 저당권을 기준으로 함에 주의).

2. 법정지상권(제366조)

제366조(법정지상권)

저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상건물이 다른 소유자에 속한 경우에는 토지소유자는 건물소유자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다. 그러나 지료는 당사자의 청구에 의하여 법원이 이를 정한다.

제305조(건물의 전세권과 법정지상권)

- ① 대지와 건물이 동일한 소유자에 속한 경우에 건물에 전세권을 설정한 때에는 그 대지소유권의 특별승계인은 전세권설정자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다. 그러나 지료는 당사자의 청구에 의하여 법원이 이를 정한다.
- ② 전항의 경우에 대지소유자는 타인에게 그 대지를 임대하거나 이를 목적으로 한 지상권 또는 전세권을 설정하지 못한다.

가등기담보 등에 관한 법률

제10조(법정지상권)

토지와 그 위의 건물이 동일한 소유자에게 속하는 경우 그 토지나 건물에 대하여 제4조 제2항에 따른 소유권을 취득하거나 담보가등기에 따른 본등기가 행하여진 경우에는 그 건물의 소유를 목적으로 그 토지 위에 지상권(地上權)이 설정된 것으로 본다. 이 경우 그 존속기간과 지료(地料)는 당사자의 청구에 의하여 법원이 정한다.

입목에 관한 법률

제6조(법정지상권)

- ① 입목의 경매나 그 밖의 사유로 토지와 그 입목이 각각 다른 소유자에게 속하게 되는 경우에는 토지소유자는 입목소유자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다.
- ② 제1항의 경우에 지료(地料)에 관하여는 당사자의 약정에 따른다.

구 별 : 관습법상 법정지상권

(1) 서 설

1) 의 의

법정지상권이라 함은 토지와 그 지상의 건물이 동일인에게 속하고 있었으나, 어떤 사정으로 인하여 이들 토지와 그 지상건물이 각각 소유자를 달리하게 된 때에 건물소유자에게 그 건물 소유를 위하여 법률상 당연히 인정되는 지상권을 말한다.

어떤 사정 : 제한설(소수설·판례) ↔ 다수설

① 저당물 경매(담보권실행경매) → 저당권에 있어서 법정지상권(제366조)

② 전세건물소유자의 그 건물대지의 양도·증여·경매(강제경매·담보권실행경매)·공매 등으로 특별승계

→ 건물전세권과 법정지상권(제305조)

③ 가등기 등에 따른 본등기 또는 경매 → 가담법상 법정지상권(제10조)

④ 입목의양도·증여·경매·공매 등으로 특별승계 → 입목과 법정지상권(제6조)

⑤ 매매·증여·강제경매·채납처분에 의한 공매 등 → 관습법상 법정지상권

따라서 제366조의 경매는 담보권실행경매만을 의미하고 강제경매(일반채권자의 집행권원에 기한 경매)·채납처분에 의한 공매·담보가등기에 기한 본등기는 제외된다(판례 ↔ 다수설)

→ 강제경매는 관습법상 법정지상권

2) 제도의 취지 (공익)

건물소유자는 대지이용권이 없다는 이유로 토지소유자의 건물철거청구 → 사회·경제적 손실

3) 제366조의 강행규정성

법정지상권을 배제하는 특약 무효(통설. 대판 1988. 10. 25, 87다카1564)

(2) 성립요건

1) 저당권“설정 당시”의 건물의 존재

(가) 나대지에 저당권설정 후에 신축건물에도 법정지상권을 인정한다면 저당권자가 불측의 손해

(나) 건물은 실제로 존재하면 됨(보존등기 불요), 독립된 건물의 실체 요구됨(건축 중인 경우)

Q : 저당권이 설정될 당시 존재하던 건물이 그 후 증·개축된 경우 또는 건물이 멸실되거나 철거된 뒤 재건축한 경우에도 법정지상권이 성립하는지가 문제된다.

1. 인정여부 → 인정

① 증개축의 경우 동일성기준설

원래의 건물과 증·개축된 건물사이에 동일성이 있어야 법정지상권이 성립할 수 있다는 견해(건물에만 저당권이 설정된 후 기존건물이 철거되고 새로운 건물이 신축되었다면 저당목

적물의 멸실로 그 지당권은 소멸한다고 한다 → 법정지상권 성립 불가) ↔ 판례는 동일성을 요구하지 않음

② 법정지상권 존속설

건물을 철거하고 신축한 경우에도 비록 신구건물간의 동일성은 유지되지 않지만, 건물존재의 계속성은 인정할 수 있으므로 법정지상권은 성립한다는 견해

2. 법정지상권의 범위(내용) → 원칙 : 구건물기준

(a) 구건물 기준설(판례·다수설)

(b) 신건물 기준설

(c) 판례 : 구건물 기준설(동일성 불요)

건물을 개축 또는 증축하는 경우는 물론 건물이 멸실되거나 철거된 후에 신축하는 경우에도 법정지상권은 성립하며(대판 1997. 1. 21, 96다40080), 이 경우 신건물과 구건물사이에 동일성이 있거나 소유자가 동일할 것을 요하지는 않으며, 그 법정지상권의 내용인 존속기간·범위 등은 구건물을 기준으로 한다(대판 2001. 3. 13, 2000다48517·48524·48531).

(d) 최근의 판례에서는

「토지와 지상건물에 공동저당권이 설정된 경우」에 한하여 입장을 바꾸어 동일인의 소유에 속하는 토지 및 그 지상건물에 관하여 공동저당이 설정된 후 그 지상건물이 철거되고 새로 건물이 신축된 경우에는, 토지의 저당권자에게 신축건물에 관하여 토지의 저당권과 동일한 순위의 공동저당권을 설정해 주는 등 특별한 사정이 없는 한, 그 신축건물을 위한 법정지상권이 성립하지 않는다고 하였다(대판[전합] 2003. 12. 18, 98다43601). 그 이유는 담보권자의 이익과 건물소유자의 이익을 형량할 때 그렇게 새기지 않으면 공동저당권자에게 불측의 손해가 생기기 때문이라고 한다.

[판 례] 민법 제366조의 법정지상권 성립의 요건

민법 제366조 소정의 법정지상권이 성립하려면 저당권 설정 당시 저당권의 목적이 되는 토지 위에 건물이 존재하여야 하는데, 저당권 설정 당시의 건물을 그 후 개축·증축한 경우는 물론이고 그 건물이 멸실되거나 철거된 후 재건축·신축한 경우에도 법정지상권이 성립하며, 이 경우 신 건물과 구 건물 사이에 동일성이 있거나 소유자가 동일할 것을 요하는 것은 아니라 할 것이지만, 그 법정지상권의 내용인 존속기간·범위 등은 구건물을 기준으로 하여야 할 것이다(대판 2001. 3. 13. 2000다48517·48524·48531).

[판 례] 건물의 증·개축과 법정지상권

- 토지에 대해서만 저당권을 설정한 경우

민법 제366조 소정의 법정지상권이 성립하려면 저당권의 설정 당시 저당권의 목적이 되는 토지 위에 건물이 존재하여야 하고, 저당권 설정 당시 건물이 존재한 이상 그 이후 건물을 개축, 증축하는 경우는 물론이고 건물이 멸실되거나 철거된 후

재축, 신축하는 경우에도 법정지상권이 성립하며, 이 경우의 법정지상권의 내용인 존속기간, 범위 등은 구 건물을 기준으로 하여 그 이용에 일반적으로 필요한 범위 내로 제한된다(대판 1991. 4. 26, 90다19985).

· 토지와 그 지상건물에 공동저당권이 설정된 경우

동일인의 소유에 속하는 토지 및 그 지상건물에 관하여 공동저당권이 설정된 후 그 지상건물이 철거되고 새로 건물이 신축된 경우에는 그 신축건물의 소유자가 토지의 소유자와 동일하고 토지의 저당권자에게 신축건물에 관하여 토지의 저당권과 동일한 순위의 공동저당권을 설정해 주는 등 특별한 사정이 없는 한 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 신축건물이 다른 소유자에 속하게 되더라도 그 신축건물을 위한 법정지상권은 성립하지 않는다고 해석하여야 하는바, 그 이유는 동일인의 소유에 속하는 토지 및 그 지상건물에 관하여 공동저당권이 설정된 경우에는, 처음부터 지상건물로 인하여 토지의 이용이 제한받는 것을 용인하고 토지에 대하여만 저당권을 설정하여 법정지상권의 가치만큼 감소된 토지의 교환가치를 담보로 취득한 경우와는 달리, 공동저당권자는 토지 및 건물 각각의 교환가치 전부를 담보로 취득한 것으로서, 저당권의 목적이 된 건물이 그대로 존속하는 이상은 건물을 위한 법정지상권이 성립해도 그로 인하여 토지의 교환가치에서 제외된 법정지상권의 가액 상당 가치는 법정지상권이 성립하는 건물의 교환가치에서 되찾을 수 있어 궁극적으로 토지에 관하여 아무런 제한이 없는 “나대지”로서의 교환가치 전체를 실현시킬 수 있다고 기대하지만, 건물이 철거된 후 신축된 건물에 토지와 동순위의 공동저당권이 설정되지 아니 하였는데도 그 신축건물을 위한 법정지상권이 성립한다고 해석하게 되면, 공동저당권자가 법정지상권이 성립하는 신축건물의 교환가치를 취득할 수 없게 되는 결과 법정지상권의 가액 상당 가치를 되찾을 길이 막혀 위와 같이 당초 나대지로서의 토지의 교환가치 전체를 기대하여 담보를 취득한 공동저당권자에게 불측의 손해를 입게 하기 때문이다(대판[전합] 2003. 12. 18, 98다43601).

→ 법정지상권이 성립할 수 있는 토지만을 저당권설정할 때 그 저당권가치는 적을 것이지만 토지와 건물 모두를 공동저당한 경우는 마치 나대지를 저당 잡은 것과 같다.

(마) 토지에 저당권설정 당시 건물이 없었다면 그 후 건물신축시에 토지저당권자가 건축에 관한 동의를 한 경우에도 법정지상권은 성립하지 않는다(대판 2003. 9. 5, 2003다26051).

<- - 법적 안정성

[판 례] 저당권자의 동의 아래 신축된 건물과 법정지상권

민법 제366조의 법정지상권은 저당권설정 당시부터 저당권의 목적되는 토지 위에 건물이 존재할 경우에 한하여 인정되며, 토지에 관하여 저당권이 설정될 당시 그 지상에 토지소유자에 의

한 건물의 건축이 개시되기 이전이었다면, 건물이 없는 토지에 관하여 저당권이 설정될 당시 근저당권자가 토지소유자에 의한 건물의 건축에 동의하였다고 하더라도 그러한 사정은 주관적 사항이고 공시할 수도 없는 것이어서 토지를 낙찰 받는 제3자로서는 알 수 없는 것이므로 그와 같은 사정을 들어 법정지상권의 성립을 인정한다면 토지소유권을 취득하려는 제3자의 법적 안정성을 해하는 등 법률관계가 매우 불명확하게 되므로 법정지상권이 성립되지 않는다(대판 2003. 9. 5, 2003다26051).

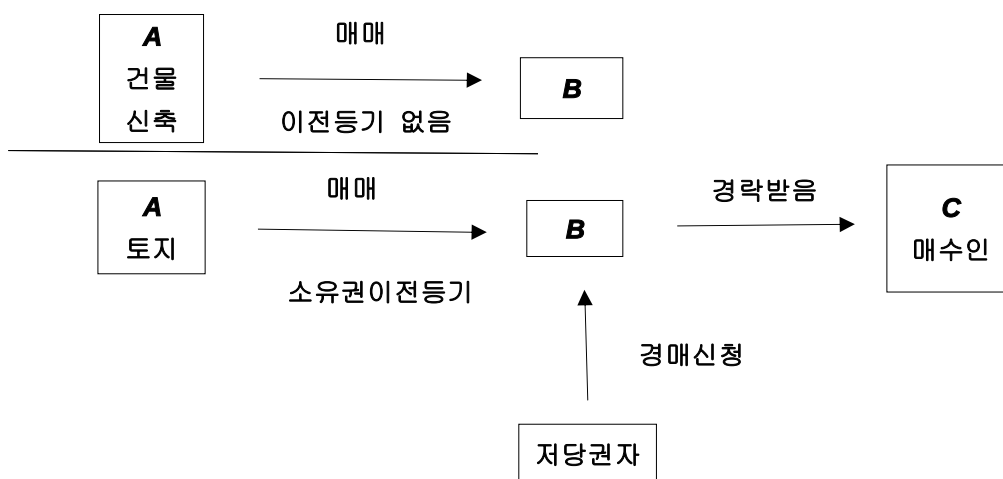
2) 저당권설정 당시에 토지와 건물이 동일 소유자에 속할 것

(가) 이미 토지위에 건물이 있고 그 건물에 토지의 용역권(지상권, 전세권, 임차권)이 있다면 토지저당권을 취득하려는 자는 이를 고려하여 저당권을 취득

(나) 무허가의 미등기건물을 위해서도 법정지상권이 인정(통설; 대판 1964. 9. 22, 63아62).

그러나 대지와 미등기건물을 함께 매수하여 매수인이 대지에 관하여만 소유권이전등기를 경료받고, 건물에 대해서는 그 등기를 이전받지 못하고 있다가 대지에 저당권을 설정하고 그 저당권의 실행으로 대지가 경매되어 다른 사람의 소유로 된 경우에 그 저당권의 설정당시에 이미 대지와 건물이 각각 다른 사람의 소유에 속하고 있었으므로 법정지상권이 성립될 여지가 없다(대판[전합] 2002. 6. 20, 2002다9660).

→ 법정지상권[1]과 관습법상 법정지상권[2] 검토



- ① A가 건축하였으므로 B가 건물을 매수하였다 하더라도 등기가 없는 한 건물은 A소유가 됨
- ② 따라서 저당권 설정당시 건물은 A소유, 토지는 B 소유가 됨 → 동일소유자 아님
- ③ B는 A에 대하여 관습법상 법정지상권?(부정) → 아래 [2] 참조

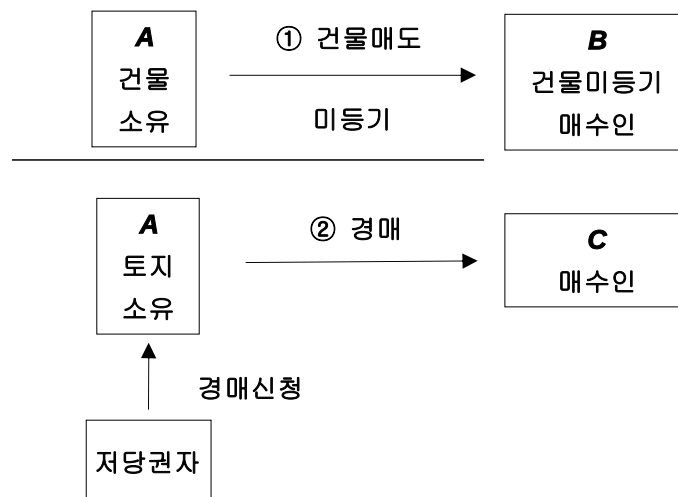
[판례] [1] 미등기건물을 대지와 함께 매수하였으나 대지에 관하여만 소유권이전등기를 넘겨받고 대지에 대하여 저당권을 설정한 후 저당권이 실행된 경우, 민법 제366

조 소정의 법정지상권이 성립하는지 여부(소극)/ **[2]** 미등기건물을 대지와 함께 매도하였으나 대지에 관하여만 매수인 앞으로 소유권이전등기가 경료된 경우, 관습상의 법정지상권이 성립하는지 여부(소극)

[1] 민법 제366조의 법정지상권은 저당권 설정 당시에 동일인의 소유에 속하는 토지와 건물이 저당권의 실행에 의한 경매로 인하여 각기 다른 사람의 소유에 속하게 된 경우에 건물의 소유를 위하여 인정되는 것이므로, 미등기건물을 그 대지와 함께 매수한 사람이 그 대지에 관하여만 소유권이전등기를 넘겨받고 건물에 대하여는 그 등기를 이전 받지 못하고 있다가, 대지에 대하여 저당권을 설정하고 그 저당권의 실행으로 대지가 경매되어 다른 사람의 소유로 된 경우에는, 그 저당권의 설정 당시에 이미 대지와 건물이 각각 다른 사람의 소유에 속하고 있었으므로 법정지상권이 성립될 여지가 없다.

[2] 관습상의 법정지상권은 동일인의 소유이던 토지와 그 지상건물이 매매 기타 원인으로 인하여 각각 소유자를 달리하게 되었으나 그 건물을 철거한다는 등의 특약이 없으면 건물 소유자로 하여금 토지를 계속 사용하게 하려는 것이 당사자의 의사라고 보아 인정되는 것이므로 토지의 점유·사용에 관하여 당사자 사이에 약정이 있는 것으로 볼 수 있거나 토지 소유자가 건물의 처분권까지 함께 취득한 경우에는 관습상의 법정지상권을 인정할 까닭이 없다 할 것이어서, 미등기건물을 그 대지와 함께 매도하였다면 비록 매수인에게 그 대지에 관하여만 소유권이전등기가 경료되고 건물에 관하여는 등기가 경료되지 아니하여 형식적으로 대지와 건물이 그 소유 명의자를 달리하게 되었다 하더라도 매수인에게 관습상의 법정지상권을 인정할 이유가 없다(대판[전합] 2002. 6. 20, 2002다9660).

동일인 소유의 토지와 지상건물 중 건물양수인이 미등기건물인 관계로 소유권이전등기를 경료하지 못한 사이에 토지에 설정된 저당권이 실행되어 토지와 건물의 소유자가 달라진 경우 양도인이 건물의 소유를 위한 법정지상권을 취득한다(대판 1991. 5. 28, 91다6658).



→ 저당권자가 저당권 설정당시에 비록 B가 건물을 매수하였다고 하더라도 건물과 토지의 소유자는 A로서 동일인이다. 따라서 C가 매수한 경우 양도인(A)이 건물의 소유를 위한 법정지상권을 취득(B가 취득한 것이 아님).

<관습법상 법정지상권>

성립요건 :

- ① 처분 당시 토지와 건물의 소유권이 동일인에게 속하여야 할 것
- ② 매매 기타의 적법한 원인으로 소유자가 달라져야 할 것
- ③ 당사자 사이에 건물을 철거한다는 특약이 없을 것

A(건물소유자) -- → B(건물양수인) - → C(건물 양수인)

A(토지소유자)

예1) 만약 B가 등기를 갖추고 매수한 경우 B는 A에 대한 관습법상 법정지상권 취득.

예2) 토지와 건물 소유자인 A가 토지는 등기하여 B에게 매도하고 건물은 미등기인채로 B에게 매도한 경우 매매로 토지와 건물의 소유자가 달라지는 경우로 보아(?) A가 건물을 위해 관습법상 법정지상권을 취득하는가?**(부정)**

A(건물소유자/미등기) --- → B(건물 미등기인채 양수인)

A(토지소유자/ 등기) --- → B(토지 등기 양수인)

→ 대판[전합] **2002. 6. 20, 2002다9660**

“관습법상 법정지상권은 동일인의 소유이던 토지와 그 지상건물이 매매 기타 원인으로 인하여 각각 소유자를 달리하게 되었으나 그 건물을 철거한다는 등의 특약이 없으면 건물 소유자로 하여금 토지를 계속 사용하게 하려는 것이 당사자의 의사라고 보아 인정되는 것이므로 ①토지의 점유·사용에 관하여 당사자 사이에 약정이 있는 것으로 볼 수 있거나 ②토지 소유자가 건물의 처분권까지 함께 취득한 경우에는 관습법상 법정지상권을 인정할 까닭이 없다.”

→ 풀이 : 형식적으로는 토지 소유자와 건물 소유자가 다른 경우다.

실질적으로는 토지 소유자와 건물 소유자가 같다(즉 건물처분권까지 취득한 것)

결국 소유자가 달라질 것에 해당하지 않는다.

- - 성립요건 ①에 관한 아래의 예 -

- 1. **처분당시(매도 당시)** 건물소유자는 A, 토지소유자도 A이므로, 동일 소유자인 상태에서 매매 등으로 소유자가 다른 경우에 의한 경우이므로 →B는 건물을 위한 관습법상 법정지상권 취득(배제 특약이 없을 경우)

※ **소유자 동일성 판단 기준시점**

- ① 원칙 : 관습법상 법정지상권이 성립되기 위하여는 토지와 건물 중 어느 하나가 **“처분될 당시”**에 토지와 그 지상건물이 동일인의 소유에 속하였으면 족하고 원시적으로 동일인의 소유였을 필요는 없다(대판 1995. 7. 28, 95다9075·9082)
- ② 예외 : **“가압류 효력이 발생하는 때” 또는 “압류의 효력이 발생하는 때”**
(강제경매로 토지와 건물의 소유자가 달라진 경우)

대법원 2012.10.18. 선고 2010다52140 전원합의체 판결[토지인도등]

[판례] 강제경매의 목적이 된 토지 또는 그 지상 건물의 소유권이 강제경매로 인하여 그 절차상 매수인에게 이전된 경우, 건물 소유를 위한 관습상 법정지상권의 성립 요건인 ‘토지와 그 지상 건물이 동일인 소유에 속하였는지’를 판단하는 기준 시기(=압류 또는 가압류의 효력 발생 시)

참고 : 부동산강제경매절차에서 목적물을 매수한 사람의 법적지위는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 절차상 “압류의 효력이 발생하는 때”를 기준으로 하여 정하여진다.

강제경매의 목적이 된 토지 또는 그 지상 건물의 소유권이 강제경매로 인하여 그 절차상의 매수인에게 이전된 경우에 건물의 소유를 위한 관습상 법정지상권이 성립하는가 하는 문제에 있어서는 그 매수인이 소유권을 취득하는 “매각대금의 완납시가 아니라 그 압류의 효력이 발생하는 때를 기준”으로 하여 토지와 그 지상건물이 동일인에 속하였는지가 판단되어야 한다. 강제경매개시결정의 기입등기가 이루어져 압류의 효력이 발생한 후에 경매목적물의 소유권을 취득한 이른바 제3취득자는 그의 권리를 경매절차상 매수인에게 대항하지 못하고, 나아가 그 명의로 경료된 소유권이전등기는 매수인이 인수하지 아니하는 부동산의 부담에 관한 기입에 해당하므로(민사집행법 제144조 제1항 제2호 참조) 매각대금이 완납되면 직권으로 그 말소가 촉탁되어야 하는 것이어서, 결국 매각대금 완납 당시 소유자가 누구인지는 이 문제맥락에서 별다른 의미를 가질 수 없다는 점 등을 고려하여 보면 더욱 그러하다. 한편 강제경매개시결정 이전에 가압류가 있는 경우에는, 그 가압류가 강제경매개시결정으로 인하여 본압류로 이행되어 가압류집행이 본집행에 포섭됨으로써 당초부터 본집행이 있었던 것과 같은 효력이 있다. 따라서 경매의 목적이 된 부동산에 대하여 가압류가 있고 그것이 본압류로 이행되어 경매절차가 진행된 경우에는, 애초 가압류가 효력을 발생하는 때를 기준으로 토지와 그 지상건물이 동일인에 속하였는지를 판단하여야 한다.

예1 :

- ㉠ 건물에 대한 “가압류 당시” 건물소유자는 A, 토지소유자는 B이었다.
㉡ 그 후 건물과 토지의 소유권이 모두 C에게 이전된 상태에서 강제경매가 이루어짐
㉢ 강제경매에서 건물의 소유권이 D에게 이전된 경우 D는 관습법상 법정지상권?(부정)

예2 :

- ㉠ 건물에 대한 “가압류 당시” 건물 소유자는 A, 토지소유자는 B이었다.
- ㉡ 그 후 토지소유권이 A에게 이전됨(즉 A가 건물·토지 소유자가 됨)
- ㉢ 그 상태에서 A 건물 강제경매로 건물을 C가 취득한 경우 C의 관습법상 법정지상권?(부정)

예3 :

- ㉠ 건물에 대한 가압류 당시 건물과 토지의 소유자는 모두 A
- ㉡ 이후 토지 소유권이 B에게 이전
- ㉢ 건물강제경매에서 건물 소유권이 C에게 이전
- ㉣ “A에게” 관습법상 법정지상권 인정? (A에게 인정)

→ 가압류 당시 소유자가 동일 건물소유자 A의 관습법상 법정지상권 인정
 → 매각시점을 기준으로 하여도 토지소유권 이전 당시 토지건물 소유자는 A이므로
 토지 소유권이 B에게 이전될 때 A에게 건물을 위한 관습법상 법정지상권 있음.
 따라서 건물 매수인 C는 건물 소유권의 종된 권리인 관습법상 법정지상권에도 가압
 류효력, 압류(경매)의 효력이 미쳐 관습법상 법정지상권까지 승계취득한다.

2. A와 B 사이에 건물소유권 양도의 합의는 법정지상권 양도의 합의도 포함. 다만, 제187조 단서에 따라 187조 단서에 따라 처분하려면 등기하여야 하므로 C가 법정지상권을 취득하려면 **B가 법정지상권을 등기하고 C에게 이전하여야 C는 법정지상권도 취득**(다수설)

3. 건물양수인 C는 법정지상권 등기 없더라도 토지 소유자의 건물철거청구에 대항가능
 (대판[전합] 1985. 4. 9, 84다카1131·1132)

건물양수인(C)은 토지소유자(A)에 대한 건물양도인(B)의 지상권설정등기청구권을 대위행사하여 건물양도인(B) 명의로 등기한 다음 다시 자기에게 이전등기를 할 수 있으며, 건물양수인(C)이 지상권설정등기를 **대위행사**할 수 있는 한 지상권의 부담을 용인하고 설정등기절차를 이행할 의무 있는 토지소유자는 신의칙상 건물양수인(C)에 대하여 건물의 철거를 청구할 수 없다.

3) 토지와 건물의 한쪽 또는 양쪽에 저당권이 설정될 것
 (저당권 이외 → 관습법상법정지상권)

4) “경매”로 토지와 건물의 소유자가 달라질 것

- ① 다수설(곽윤직) : 강제경매나 공매도 포함
- ② 소수설은 제336조의 조문의 규정에 충실 : 담보권실행경매로 한정
- ③ 판례(소수설)

제366조의 경매는 담보권실행에 의한 경매(담보권실행경매)만을 의미하고, 통상의 강제경매의 경우에는 관습법상의 법정지상권을 인정하고 있다(대판 1970. 9. 29, 70다1454). 나아가 국제

징수법에 의한 공매의 경우에도 판례는 관습법상 법정지상권을 인정한다(대판 1967. 11. 28, 67다1831).

5) 특약의 배제 불가

제366조는 가치권과 이용권의 조절을 위한 강행규정으로 저당권설정 당사자의 특약으로 배제하지 못한다.(관습법상 법정지상권은 배제특약할 수 있다)

(3) 성립시기와 등기

1) 매수인이 매각대금을 완납한 때에 법정지상권이 성립한다(민사집행법 제135조·제268조).

2) 법정지상권은 법률의 규정(제366조)에 의한 물권의 취득 → 등기 없이 지상권취득(제187조).

(4) 내 용

1) 법정지상권의 범위

그 건물을 이용하는데 필요한 한도에서는 대지 이외의 부분에도 미친다(대판 1977. 7. 26, 77다921).

2) 법정지상권자

건물의 소유자. 건물소유자는 사실상의 소유자가 아닌 법률상의 소유자를 의미한다.

3) 지 료

(가) 협의 → 협의 불성립하면 → 당사자 청구 → 법원(제366조 단서)

법정지상권에 관한 지료가 결정된 바 없다면 법정지상권자가 지료로 지급하지 않았다고 하더라도 지료지급을 지체한 것으로 볼 수 없으므로, 토지소유자는 법정지상권자가 2년 이상의 지료를 지급하지 않았음을 이유로 지상권 소멸청구를 할 수 없다(대판 2001. 3. 13, 99다17142). 지료가 결정되기 전에는 2년의 지료연체를 이유로 지상권소멸을 청구할 수 없다(대판 1994. 12. 2, 93다52297).

4) 존속기간

당사자 사이의 합의에 의하는 것이 원칙이지만, 합의가 없는 경우에는 존속기간에 관해 민법 제280조 제1항의 「존속기간을 약정하지 않는 때」와 같이 다루어서 최단존속기간으로 보아야 한다는 견해(통설·판례) → 그 존속기간은 건물의 종류에 따라 30년 또는 15년으로 된다.

제280조(존속기간을 약정한 지상권)

① 계약으로 지상권의 존속기간을 정하는 경우에는 그 기간은 다음 연한보다 단축하지 못한다.

1. 석조, 석회조, 연와조 또는 이와 유사한 견고한 **건물**이나 수목의 소유를 목적으로 하는 때에는 30년
2. 전호이외의 **건물**의 소유를 목적으로 하는 때에는 15년
3. 건물 이외의 공작물의 소유를 목적으로 하는 때에는 5년

② 전항의 기간보다 단축한 기간을 정한 때에는 전항의 기간까지 연장한다.

제281조(존속기간을 약정하지 아니한 지상권)

① 계약으로 지상권의 존속기간을 정하지 아니한 때에는 그 기간은 전조의 최단존속기간으로 한다.

② 지상권설정당시에 공작물의 종류와 구조를 정하지 아니한 때에는 지상권은 전조제2호의 건물의 소유를 목적으로 한 것으로 본다.

(5) 법정지상권의 처분

1) 법정지상권은 건물의 소유에 부속되는 종속적인 권리가 아니고 하나의 독립된 법률상의 물건이므로 건물의 소유자가 건물과 법정지상권 중 어느 하나만을 처분하는 것도 가능하다(대판 2001. 12. 27, 2000다1976). 다만 주된 권리인 건물소유권의 이전에 법정지상권도 종된 권리로 포함되어 양도된 것으로 본다(판례)

2) 법정지상권의 취득자는 등기 없이 토지소유자 또는 그 전득자에게 대항할 수 있으나, 그 법정지상권을 제3자에게 처분하려면 원칙적으로 제187조 단서에 의하여 등기를 하여야 한다(판례·통설).

→ 따라서 전득자는 「법정지상권을 가진 전 건물소유자로부터 건물을 양수한 자는 전 건물소유자에 대한 법정지상권의 이전등기청구권에 터잡아 토지소유자에게 법정지상권의 설정등기청구권을 대위행사 할 수 있으므로 그 설정등기의무를 부담하고 있는 토지소유자가 건물양수인에게 건물철거를 구하는 것은 신의성실의 원칙에 반한다」(대판[전합] 1985. 4. 9, 84다카1131·1132)고 하여 건물의 전득자가 법정지상권의 이전등기를 하지 않아도 토지소유자에게 대항할 수 있는 것으로 본다.

(6) 법정지상권의 소멸

법정지상권은 토지소유자의 소멸청구(제287조), 지상권자에 의한 포기 및 당사자 사이의 계약에 의하여 소멸한다.

3. 저당토지 위의 건물에 대한 일괄경매

제365조(저당지상의 건물에 대한 경매청구권)

토지를 목적으로 저당권을 설정한 후 그 설정자가 그 토지에 건물을 축조한 때에는 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여도 경매를 청구할 수 있다. 그러나 그 건물의 경매대가에 대하여는 우선변제를 받을 권리가 없다.

(1) 의 의

1) 의의

토지를 목적으로 저당권을 설정한 후 그 설정자가 그 토지에 건물을 축조한 때에는 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여도 경매를 청구할 수 있다. 그러나 그 건물의 경매대가에 대하여는 우선변제를 받을 권리가 없다.

2) 인정 이유

① 주된 취지 : 저당권자의 토지에 대한 교환가치 확보(토지저당권자의 경매 용이)

- ② 부수적 취지 : 저당권 설정 후 건물축조의 경우 법정지상권이 성립되지 않아 건물이 철거될 소지의 방지(사회경제적 이익)

[판례] 민법 제365조에 기한 일괄경매청구권

민법 제365조가 토지를 목적으로 한 저당권을 설정한 후 그 저당권설정자가 그 토지에 건물을 축조한 때에는 저당권자가 토지와 건물을 일괄하여 경매를 청구할 수 있도록 규정한 취지는, 저당권은 담보물의 교환가치의 취득을 목적으로 할 뿐 담보물의 이용을 제한하지 아니하여 ② 저당권설정자로서는 저당권설정 후에도 그 지상에 건물을 신축할 수 있는데, 후에 그 저당권의 실행으로 토지가 제3자에게 경락될 경우에 건물을 철거하여야 한다면 사회경제적으로 현저한 불이익이 생기게 되어 이를 방지할 필요가 있으므로 이러한 이해관계를 조절하고, ①저당권자에게도 저당 토지상의 건물의 존재로 인하여 생기게 되는 경매의 어려움을 해소하여 저당권의 실행을 쉽게 할 수 있도록 한 데에 있다고 풀이되며, 그러한 규정취지에 비추어 보면 민법 제365조에 기한 일괄경매청구권은 “저당권설정자가 건물을 축조하여 소유”하고 있는 경우에 한한다고 봄이 상당하다(대판 1999. 4. 20, 99마146).

(2) 요건

- 1) 일괄경매권은 토지에 저당권이 설정된 후에 건물이 축조된 경우에만 인정된다.

▶ 돌발 퀴즈

일괄경매청구가 가능하기 위해서는 저당권설정자가 건물을 직접 축조하고 소유하고 있어야 하는가?

: ×

- ① 민법 제365조의 조문은 “저당권설정자가 건물을 축조한 경우”라고 규정하고 있다.
 ② 과거의 판례(대결 1999. 4. 20, 99마146)는 “규정 취지에 비추어 보아 민법 제365조에 기한 일괄경매청구권은 저당권설정자가 건물을 축조하여 소유하고 있는 경우에 한한다고 봄이 상당하다”고 하여 저당권설정자가 건물을 원시취득을 하여야 일괄경매가 가능하다고 하였다.
 ③ 현재의 판례는 적용범위를 확대하여 저당권설정 후에 토지소유자로부터 용익권을 설정 받은 자가 건물을 축조한 후 토지소유자가 그 건물을 매수한 때에도 일괄경매권을 인정하였다(대판 2003. 4. 11, 2003다3850). 즉 현재의 판례는 토지의 저당권설정자가 원시취득한 건물일 것을 요하지 않는다.

→ 결국 경매개시결정 당시에 저당권설정자가 건물을 소유하고 있으면 일괄경매권이 인정되고 저당권설정자가 건물을 축조한 후 제3자에게 양도하면 일괄경매권은 인정되지 않는다.

- 2) 제365조는 강행규정이 아님 → 일괄경매청구의 권리이고 의무가 아님 → 저당권자가 토지와 건물을 일괄경매하든, 또는 저당부동산인 토지만을 경매하든, 그것은 저당권자의 자유로운 선택
- 3) 토지경매로 변제에 충분하여도 일괄경매가능. 즉 민사집행법 제124조의 과잉경매금지규정은 적용되지 않는다(대결 1967. 12. 22, 67마1162; 대결 1968. 9. 30, 68마890).

- 4) 토지의 저당권자는 토지만에 대하여 경매를 신청한 후에도 그 토지상의 건물에 대하여 토지에 관한 경매기일 공고시까지는 일괄경매의 추가신청을 할 수 있다(대결 2001. 6. 13, 2001마1632).

(3) 효 력

- 1) 저당권의 효력은 토지에만 미치므로 저당권자가 토지와 건물을 일괄경매하더라도, 그 건물의 경매대가로부터는 우선변제를 받지 못한다(제365조 단서). 다만 다른 저당권자나 일반채권자가 없는 경우에는 건물의 경매대금으로부터 변제를 받을 수 있다.
- 2) 토지와 건물을 동일인에게 경락시켜 건물을 유지하려는 것이 일괄경매를 인정한 취지를 고려하여 경매법원은 토지와 건물을 동일인에게 경락하여야 할 것이다.

4. 저당목적물의 제3취득자의 지위

제363조(저당권자의 경매청구권, 경매인)

- ① 저당권자는 그 채권의 변제를 받기 위하여 저당물의 경매를 청구할 수 있다.
- ② 저당물의 소유권을 취득한 제삼자도 경매인이 될 수 있다. → 이런 규정없어도 누구든지 경매에서 매수인 될 수 있음(제2항은 주의적인 규정일 뿐임)

제364조(제삼취득자의 변제)

저당부동산에 대하여 소유권, 지상권 또는 전세권을 취득한 제삼자는 저당권자에게 그 부동산으로 담보된 채권을 변제하고 저당권의 소멸을 청구할 수 있다.

제367조(제삼취득자의 비용상환청구권)

저당물의 제삼취득자가 그 부동산의 보존, 개량을 위하여 필요비 또는 유익비를 지출한 때에는 제203조제1항, 제2항의 규정에 의하여 저당물의 경매대가에서 우선상환을 받을 수 있다.

(1) 서 설

저당목적부동산의 소유권을 저당권설정 후에 양도받은 양수인 또는 그 저당부동산 위에 지상권이나 전세권을 취득한 자, 즉 저당부동산의 제3취득자라고 한다. 채무자의 변제 없이 저당권이 실행되면 제3취득자는 자신의 권리를 상실하게 된다.

이러한 제3취득자의 불안정한 지위를 보호 → 제363조, 제364조, 제367조

(2) 경매의 매수인

제363조 제2항의 규정은 주의적인 것

(3) 제3취득자의 변제

- 1) 변제할 수 있는 제3취득자는 경매신청 전 또는 경매개시결정 전에 소유권·지상권·전세권을 취득한 자에 한하지 않으며, 경매개시 후에 소유권 등을 취득한 자도 포함된다(대판 1974. 10. 24, 74마440).

- 2) 그러나 근저당부동산에 대하여 후순위근저당권을 취득한 자는 민법 제364조에서 정한 권리를 행사할 수 있는 제3취득자에 해당하지 아니하므로 이러한 후순위근저당권자가 선순위근저당권의 피담보채무가 확정된 이후에 그 확정된 피담보채무를 변제한 것은 민법 제469조의 규정에 의한 이해관계 있는 제3자의 변제로서 유효한 것인지 따져볼 수는 있을지언정 민법 제364조의 규정에 따라 선순위근저당권의 소멸을 청구할 수 있는 사유로는 삼을 수 없다(대판 2006. 1. 26, 2005다17341).

저당부동산 매수의 거래계의 현실

거래의 실제 : 저당부동산을 매수한 제3자는 매도인에게는 피담보채무를 공제하고 나머지만을 부동산 매매대금으로 지급한다. → 원칙 : 이행인수(판례)

- ① 즉 은행대출계약상의 채무는 여전히 매도인이고(따라서 매도인이 채무자이다), 매수인은 단지 매도인과의 계약으로 은행에 대하여 채무“이행”만을 약속한 것이다

(그리고 이 때 특약으로 매도인은 매수인에게 매수인이 은행에 변제하지 않으면 저당권을 실행당하게 되고 이는 매수인 책임이므로 당연히 매수인은 매도인에게 담보책임을 물을 수 없다고 특약한다).

- ② (물론 매수인이 매도인의 채무를 인수하는 채무인수(병존적 채무인수, 면책적 채무인수)를 하거나 계약을 인수할 수 있다)

- ③ 결국 제3취득자가 물상보증인의 재산을 양수한 경우에는 제3취득자는 불안한 지위 → 보호위해 민법의 특칙을 둔 것이다.

【판례】 저당부동산 매매에서 피담보채무액을 매매대금에서 공제하는 경우

저당부동산의 제3취득자가 피담보채무를 인수한 경우에는 그 때부터는 제3취득자는 채권자에 대한 관계에서 채무자의 지위로 변경되므로 민법 제364조의 규정은 적용될 여지가 없을 것이다. 다만, 민법 제364조를 둔 취지가, 저당권설정자가 제3취득자로부터 매매목적물의 대가 전액을 받고서도 저당권자에 대한 피담보채무를 변제하지 않는 경우에 저당권의 실행으로 말미암아 제3취득자의 권리가 상실될 위험이 있으므로, 제3취득자로 하여금 대가 전액을 저당권설정자에 대하여 지급하고 다시 저당권설정자가 그 피담보채무를 변제하게 할 것이 아니라 저당권자에게 직접 담보된 채권을 변제하도록 하게 함으로써 제3취득자의 보호를 도모하고자 한 것이라는 점을 감안해 볼 때, 저당부동산에 관한 매매계약을 체결하는 당사자 사이에 매매대금에서 피담보채무 또는 채권최고액을 공제한 잔액만을 현실로 수수하였다는 사정만을 가지고 언제나 매수인이 매도인의 저당채권자에 대한 피담보채무를 인수한 것으로 보아 제3취득자는 채권자에 대한 관계에서 제3취득자가 아니라 채무자와 동일한 지위에 놓이게 됨으로써 저당부동산의 제3취득자가 원래 행사할 수 있었던 저당권소멸청구권을 상실한다고 볼 수는 없고, 오히려 이러한 매매대금 지급방법상의 약정은 다른 특별한 사정이 없는 한 매매당사자 사이에서는 매수인이 피담보채무 또는 채권최고액에 해당하는 매매대금부분을 매도인에게 지급하는 것이 아니라 채권자에게 직접 지급하기로 하여 그 매매목적 부동산에 관한 저당권의 말소를 보다 확실

하게 보장하겠다고 하는 취지로 그런 약정을 하게 된 것이라고 볼 것이다(대판 2002. 5. 24, 2002다7176).

→ 즉 채무인수가 아니라 이행인수다.(채무인수로 보면 제3취득자가 아닌 직접 채무자로 되어 버린다. 이는 제3취득자의 변제범위에도 영향을 준다)

- 4) 저당부동산에 소유권·지상권·전세권을 취득한 제3자는 저당권자에게 그 부동산으로 담보된 채권을 변제하고 저당권의 소멸을 청구할 수 있다(제364조). 원래 채권은 제3자도 변제할 수 있고(제469조), 특히 저당부동산의 제3취득자는 이해관계가 있는 제3자이므로 채무자의 의사에 반해서 변제할 수 있다(제469조 제2항). 그럼에도 불구하고 특별히 제364조를 두고 있는 이유가 무엇인지가 검토되어야만 한다.

1) 변제할 채무범위의 제한여부

- ① 채무자인 경우 : 모든 채무를 변제하여야 저당권소멸청구가능
② 제3취득자의 경우 : 제360조가 정하는 범위의 금액만을 변제하면 되므로 자연이자는 원본의 이행기일을 경과한 후의 1년분만 변제하면 된다(통설, 대결 1974. 10. 26, 74마440).

2) 변제기 도래 전의 변제가능 여부(부정설 : 다수설·판례)

제468조에 따른 변제기 전의 변제는 채무자만이 할 수 있다고 보아야 하므로 부정설이 타당하다.

제468조(변제기전의 변제) 당사자의 특별한 의사표시가 없으면 변제기전이라도 채무자는 변제할 수 있다. 그러나 상대방의 손해는 배상하여야 한다.

[판 례] 제3취득자의 변제기 도래 전의 변제가능 여부

- (1) 소외인이 원고 소유이던 부동산에 관하여 가등기 및 소유권이전등기를 경료하고 이어 피고 공사 앞으로 근저당권설정등기를 하였는데, 그 후 원고와 위 소외인 간의 전시 가등기 및 본등기에 관한 말소청구소송에서 위 소외인은 원고로부터 일정한 금원을 수령함과 상환으로 그 명의의 전시 가등기와 본등기를 말소하되 동 소외인은 피고 공사 앞으로 된 근저당권설정등기의 말소등기절차가 이행되도록 조치하며 원고가 만일 위 금원지급을 이행치 않을 때에는 본건 부동산은 위 소외인의 소유로 확정되고 원고가 이를 인도한다는 내용의 재판상의 화해를 하였고 그 후 위 근저당권설정등기는 그대로 존속한 채 소외인 명의의 가등기와 본등기만이 위 법정화해가 원인이 되어 말소된 경우 원고는 결국 피고 공사와의 관계에 있어서는 담보목적 부동산의 제3취득자와 같은 지위에 있다.
- (2) 원고가 이러한 제3취득자와 같은 지위에 있는 것이라면 원고는 피고 공사에 대하여 민법 제364조에 따라 결산기에 이르러 확정되는 그 부동산의 피담보채권을 변제하고 근저당권설정등기의 말소를 구할 수는 있다고 하겠지만, 원고 스스로 또는 근저당권설정자를 위하여 계속적 거래관계에 기인한 이 사건 근저당권설정계약의 종료 전에 이를 일방적으로 폐기하고 그 당시까지의 채무액만을 변제하는 조건으로 근저당권설정등기의 말소를 소구할 수는 없다(대판 1979. 8. 21, 79다783).

3) 제3취득자의 변제의 효과

(가) 제3취득자와 저당권자 사이의 법률관계

- ① 통설 : 부종성에 의하여 말소등기 없이 당연히 소멸 → 민법 제364조가 「저당권의 소멸을 청구할 수 있다」고 한 규정은 무의미하다
- ② 소수설 : 제3취득자의 변제는 전액변제가 아닐 수 있으므로 말소등기가 된 때 소멸한다.

(나) 제3취득자와 저당채무자 사이의 법률관계

제3취득자는 변제하는데 정당한 이익을 가지는 자이므로 변제로 인하여 당연히 채권자를 대위하게 된다(제481조). 즉 제3취득자가 변제한 경우에는 저당권은 제3취득자에게 이전하게 되며(제482조 제1항), 채무자에 대하여 구상권을 가진다.

판례는 저당부동산의 제3취득자가 채무를 변제한 경우에 물상보증인의 구상권에 관한 규정(제370조·제341조)을 유추적용하여 보증채무에 관한 규정에 의하여 채무자에 대한 구상권이 있다(대판 1977. 7. 25, 77다8403)고 한다.

[참 고] 제3취득자의 변제와 구상권

1. 제3취득자는 피담보채권을 변제하고 저당권소멸청구를 하여 저당권을 소멸시킨 때에는 채무자에 대하여 구상권을 갖는다. 여기에서 제3취득자의 변제는 민법 제469조의 이른바 제3자의 변제는 아니지만, 법정대위(제481조)의 규정을 준용하여 제3취득자의 구상권을 인정하는 것이 타당하기 때문이다. 제3취득자가 소유자로서 변제한 경우에는 저당권은 소멸하지만, 지상권자 또는 전세권자가 변제한 경우에는 대위에 의하여 저당권은 그 지상권자 또는 전세권자가 갖는다.
2. 물상보증인이 제공한 저당부동산을 제3자가 취득하고 변제한 경우에는 무상보증인과 제3취득자 사이에 이행인수를 하였느냐에 따라 채무자에게 구상할 수 있는 자가 결정된다. 따라서 ① 제3취득자가 피담보채무를 인수하지 않기로 한 경우에는 “제3취득자”가 채무자에게 구상권을 행사한다. 즉 타인의 채무를 담보하기 위하여 저당권을 설정한 부동산의 소유자(물상보증인)로부터 소유권을 양수한 제3자는 채권자에 의하여 저당권이 실행되게 되면 저당부동산에 대한 소유권을 상실한다는 점에서 물상보증인과 유사한 지위에 있다고 할 것이므로, 물상보증의 목적물인 저당부동산의 제3취득자가 채무를 변제하거나 저당권의 실행으로 저당물의 소유권을 잃은 때에는 물상보증인의 구상권에 관한 민법 제370조, 제341조의 규정을 유추적용하여 보증채무에 관한 규정에 의하여 채무자에 대한 구상권이 있다(대판 1997. 7. 25, 97다8403). 그러나 ② 제3취득자가 피담보채무를 이행인수하기로 한 경우에는 그 이행인수는 매매당사자 사이의 내부적인 계약에 불과하여 이로써 물상보증인의 책임이 소멸하지 않는 것이고, 따라서 담보부동산에 대한 담보권이 실행된 경우에도 제3취득자가 아닌 원래의 “물상보증인”이 채무자에 대한 구상권을 취득한다(대판 1997. 5. 30, 97다1556).

(4) 제3취득자의 비용상환청구권

저당물의 제3취득자가 그 부동산의 보존·개량을 위하여 필요비 또는 유익비를 지출한 때에는 점유자의 비용상환청구권의 규정(제203조 제1항·제2항)에 따라 저당목적물의 매각대금에서 우선상환을 받을 수 있다(제367조). 이때의 제3취득자에는 소유권자·지상권자·전세권자 뿐만 아니라

등기된 임차권도 포함된다. 그러나 물상보증인은 비용상환청구권이 없다(대판 1959. 5. 14, 4191민상302).

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 저당권 설정 당시 토지 위에 건물이 반드시 존재하고 있었어야 한다.
- ② 저당권 설정 당시 토지와 건물이 동일인의 소유에 속하고 있지 않았어도 무방하다.
- ③ 토지와 건물 중 어느 한쪽에 저당권이 설정된 경우에만 법정지상권이 성립한다.
- ④ 저당권자와 저당권설정자 간의 특약으로 법정지상권의 성립을 배제할 수 있다.
- ⑤ 법정지상권은 성립했으나 그 등기가 이루어지지 않은 건물의 양수인에 대해서는 토지소유자가 건물철거청구를 할 수 있다고 봄이 판례의 태도이다.

- ①. 저당권 설정 당시 토지 위에 건물이 반드시 존재하고 있었어야 한다(대판 1990. 7. 10, 90다카6399).

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 저당권으로 담보한 채권이 시효완성 기타 사유로 소멸한 때에는 저당권도 소멸한다.
 - ② 저당권의 효력은 저당부동산의 종물에도 미친다.
 - ③ 저당부동산의 제3취득자는 저당권자에게 그 부동산으로 담보된 채권을 변제하고 저당권의 소멸을 청구할 수 있다.
 - ④ 법정지상권이 성립하기 위하여는 저당권설정 당시 토지 위에 건물이 있어야 하고 토지와 건물의 소유자가 동일인이어야 한다.
 - ⑤ 토지가 저당권의 목적이 된 후 건물을 축조한 경우 저당권자는 토지와 건물의 경매를 청구할 수 있고 건물의 대가에서 우선변제를 받을 수 있다.
- ⑤. 이러한 경우 토지와 함께 건물의 경매를 청구할 수 있으나, 건물의 경락대금에 대해서는 우선변제를 받을 수 없다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 판례는 저당권이 설정될 당시 존재하던 건물이 그 후 증·개축된 경우에도 민법 제366조 소정의 법정지상권의 성립을 인정하면서 그 내용은 구 건물을 기준으로 한다고 한다.
 - ② 토지저당권자가 지상건물을 일괄경매하는 경우에 그가 우선변제를 받는 범위는 토지의 매각 대가에 한정된다.
 - ③ 저당부동산의 제3취득자는 경매인이 될 수 없다.
 - ④ 저당부동산의 제3취득자는 저당권자에게 그 부동산으로 담보된 채권만을 변제하고, 저당권의 소멸을 청구할 수 있다.
 - ⑤ 저당권자는 저당권이 침해된 경우에 물권적 반환청구권을 가지지 않는다.
- ③. 저당부동산의 제3취득자는 경매인이 될 수 있다(제363조 2항).

♣ 학습정리

1. 용익권이 저당권의 실행에 의하여 소멸하는지의 여부는 경매를 신청한 저당권자의 저당권과 용익권설정의 시기의 선후에 의하여 결정되지 아니하고, 그 부동산 위의 최선순위의 저당권과 용익권설정의 우열에 의하여 결정된다.
2. 법정지상권은 토지와 그 지상의 건물이 동일인에게 속하고 있었으나, 어떠한 사정으로 인하여 이들 토지와 그 지상건물이 각각 소유자를 달리하게 된 때에 건물소유자에게 그 건물 소유를 위하여 법률상 당연히 인정되는 지상권을 말한다.
3. 토지 위에 저당권을 설정한 후에 그 토지에 건물을 지었으나, 경매의 결과 토지소유자와 건물소유자가 다르게 되더라도 건물소유자에게는 법정지상권이 인정되지 않는다. 따라서 토지를 목적으로 저당권을 설정한 후 그 설정자가 그 토지에 건물을 축조한 때에는 저당권자는 그 토지와 건물을 일괄경매할 수 있다.

제38강 저당권 (5)

♣ 학습목표

1. 저당권의 침해에 대한 구제방법을 설명할 수 있다.
2. 저당권의 처분 및 소멸에 대하여 정리할 수 있다.
3. 공동저당의 의의와 성립요건을 정리할 수 있다.

♣ 학습내용

- 저당권 침해의 유형
- 침해에 대한 물권적·채권적 효과
- 저당권의 처분 및 소멸
- 공동저당의 개념과 성립

♣ 사전 테스트

1. 저당부동산에 대한 점유가 저당부동산의 본래의 용법에 따른 사용·수익의 범위를 초과하여 교환가치를 감소시키거나 점유자에게 저당권 실현을 방해하기 위해 점유를 개시하였다면 저당권의 침해가 인정된다.
⇒ ○ : 이러한 저당권의 실현이 곤란하게 될 사정이 있는 경우에는 저당권의 침해가 인정될 수 있다(대판 2005. 04. 29, 2005다3243).
2. 저당권설정자의 책임 있는 사유로 인하여 저당물의 가격이 현저히 감소한 때에도 추가적인 담보제공이 필요하지 않다.
⇒ × : 저당권설정자의 책임 있는 사유로 인하여 저당물의 가격이 현저히 감소한 때에는 저당권자는 설정자에 대하여 원상회복 또는 상당한 다른 담보제공을 청구할 수 있다(제362조).
3. 공동저당권의 경우 당사자간의 저당권설정의 합의만으로도 성립된다.
⇒ × : 동일한 채권의 담보로써 수 개의 부동산 위에 저당권이 설정되면 공동저당권이 성립하고, 이러한 저당권이 설정되기 위하여는 저당권설정의 합의와 등기가 필요하다.

♣ 강의교안

V. 저당권의 침해에 대한 구제

1. 저당권의 침해유형과 특수성

(1) 침해에 대한 효과

물권적 효과 : 물권적 청구권(제214조·제370조), 원상회복청구권, 저당물보충청구권(제362조)

채권적 효과 : 손해배상청구권(제390조·제750조), 즉시변제청구권(제388조)

(2) 침해의 성부(침해의 특수성)

1) 목적물이 통상의 경제적 용도에 따라 사용되고 있는 한 저당권의 침해가 아니다.

예를 들어 자동차에 대하여 저당권이 설정되는 경우 자동차의 교환가치는 그 저당권에 포섭되고, 저당권설정자가 자동차를 매도하여 그 소유자가 달라지더라도 저당권에는 영향이 없으므로, 특별한 사정이 없는 한 저당권설정자가 단순히 그 저당권의 목적인 자동차를 다른 사람에게 매도한 것만으로는 배임죄가 성립하지 아니한다(대판 2008. 8. 21, 2008도3651).

2) 저당부동산에 대한 점유가 저당부동산의 본래의 용법에 따른 사용·수익의 범위를 초과하여 그 교환가치를 감소시키거나, 점유자에게 저당권의 실현을 방해하기 위하여 점유를 개시하였다는 점이 인정되는 등, 그 점유로 인하여 정상적인 점유가 있는 경우의 경락가격과 비교하여 그 가격이 하락하거나 경매절차가 진행되지 않는 등 저당권의 실현이 곤란하게 될 사정이 있는 경우에는 저당권의 침해가 인정될 수 있다(대판 2005. 04. 29, 2005다3243).

2. 침해에 대한 구제방법

(1) 물권적 청구권

→ 침해행위의 제거·예방의 청구 (반환청구는 불가)

[판례] 저당권에 기한 물권적 청구권

저당권자는 물권에 기하여 그 침해가 있는 때에는 그 제거나 예방을 청구할 수 있다고 할 것인바, 공장저당권의 목적 동산이 저당권자의 동의를 얻지 아니하고 설치된 공장으로부터 반출된 경우에는 저당권자는 점유권이 없기 때문에 설정자로부터 일탈한 저당목적물을 저당권자 자신에게 반환할 것을 청구할 수는 없지만, 저당목적물이 제3자에게 선의취득되지 아니하는 한 원래의 설치 장소에 원상회복할 것을 청구함은 저당권의 성질에 반하지 아니함은 물론 저당권자가 가지는 방해배제권의 당연한 행사에 해당한다(대판 1996. 3. 22, 95다55184).

(2) 손해배상청구권

1) 저당목적물의 가격이 감소하더라도 채권의 완전한 만족을 얻을 수 있다면 손해 없다.

2) 손해배상청구를 할 수 있는 시기는 저당권실행 전이라도 불법행위가 있는 후에 즉시 손해배상을 청구할 수 있다.

3) 제3자가 불법행위를 한 경우에는 저당권자는 저당권침해에 대하여 선택적으로 제3자에게 손해배상을 청구하거나 소유자의 제3자에 대한 손해배상청구권에 물상대위할 수 있다(제342조·제370조).

[판례] 물상보증인의 저당권 침해

물상보증인이 저당권의 목적인 토지 위에 포장도로 개설공사·옹벽축조 공사를 시행하여 일반 공중이 사용하는 도로로 제공함으로써 그 교환가치를 감소시킨 경우, 공사시공자와 함께 저당권자에 대한 공동불법행위책임을 부담한다(대판 2008. 1. 17, 2006다586).

4) 근저당권의 소멸로 인하여 근저당권자가 입게 되는 손해는 근저당 목적물인 부동산의 가액범위 내에서 채권최고액을 한도로 하는 피담보채권액이다(대판 1997. 11. 25, 97다35771).

[참 고] 저당권등기의 불법말소와 손해배상청구 및 부당이득반환청구

1. 저당권등기의 불법말소와 회복등기 등기가 원인 없이 말소된 경우라도 등기는 물권의 효력 발생요건이고 존속요건은 아니므로 그 물권의 효력에는 아무런 영향이 없고, 그 회복등기가 마쳐지기 전이라도 말소된 등기의 등기명의인은 적법한 권리자로 추정된다. 따라서 저당권자는 처음부터 그러한 말소가 없었던 것과 같은 효력을 보유하게 할 목적으로 부동산등기법의 절차에 따라서 불법말소된 저당권등기의 회복등기를 할 수 있다(대판 1997. 9. 30, 95다39526).

2. 저당권등기의 불법말소와 손해배상청구 ① 채무자(또는 그의 이행보조자)에 의하여 저당권등기가 불법말소되었다면 채무자는 기한의 이익을 상실하므로(제388조 제1호), 회복등기에 의하여 회복된 저당권을 즉시 실행할 수 있어서 저당권의 실행 외에 별도의 손해를 인정할 실익이 크지 않을 것이다. 반면에 ② 제3자나 물상보증인에 의하여 저당권등기가 불법말소되었다면, 제3자 또는 물상보증인에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다. 즉 저당권이 경매등으로 저당권회복등기가 불가능하게 된 경우에는 저당권자는 불법행위자인 제3자 또는 물상보증인에게 손해배상을 청구할 수 있다(대판 1997. 11. 25, 97다35771). 그런데 위에서 살펴본 바와 같이 저당권등기가 회복될 수 있다면 저당권등기의 회복등기에 소요되는 비용 외에 다른 어떠한 손해가 발생하였는지에 대하여는 의문이 있을 수 있다. ③ 다만 위의 97다35771 판례에서는 타인의 불법행위로 인하여 근저당권이 소멸되는 경우에 있어 근저당권자로서는 근저당권이 소멸하지 아니하였더라면 그 실행으로 피담보채무의 변제를 받았을 것임에도 불구하고 근저당권의 소멸로 말미암아 이러한 변제를 받게 되는 권능을 상실하게 되는 것이므로, 근저당권의 소멸로 인하여 근저당권자가 입게 되는 손해는 근저당 목적물인 부동산의 가액범위 내에서 채권최고액을 한도로 하는 피담보채권액이라고 한다(대판 1997. 11. 25, 97다35771).

2. 저당권등기의 불법말소와 부당이득 ① 부동산에 관하여 근저당권설정등기가 경료되었다가 그 등기가 위조된 등기서류에 의하여 아무런 원인 없이 말소되었다는 사정만으로는 곧바로 근저당권이 소멸하는 것은 아니라고 할 것이지만, 부동산이 경매절차에서 경락되면 그 부동산에 존재하였던 근저당권은 당연히 소멸하는 것이므로, 근저당권설정등기가 원인 없이 말소된 이후에 그 근저당 목적물인 부동산에 관하여 다른 근저당권자 등 권리자의 경매신청에 따라 경매절차가 진행되어 경락허가결정이 확정되고 매수인이 매수대금을 완납하였다면,

원인 없이 말소된 근저당권은 이에 의하여 소멸한다(대판 1998. 10. 2, 98다27197). 따라서 담보채권액에 해당하는 금액을 배당받지 못한 근저당권자는 배당기일에 출석하지 않음으로써 배당표가 확정되었다고 하더라도, 확정된 배당표에 의하여 배당을 실시하는 것은 실체법상의 권리를 확정하는 것이 아니기 때문에 위 경매절차에서 실제로 배당받은 자에 대하여 부당이득반환 청구로서 그 배당금의 한도 내에서 그 근저당권설정등기가 말소되지 아니하였더라면 배당받았을 금액의 지급을 구할 수 있다(대판 2002. 10. 22. 선고 2000다59678).

- ② 그 밖에 위 저당권자는 배당기일에 출석하여 이의를 하고 배당이의의 소를 제기하여 구제를 받을 수 있다(대판 2002. 10. 22. 선고 2000다59678). 그러나 매수인이 매수대금을 완납하여서 근저당권이 소멸하였다면, 이미 소멸한 근저당권에 관한 말소등기의 회복등기를 위하여 현소유자를 상대로 그 승낙의 의사표시를 구할 수는 없다(대판 1998. 10. 2, 98다27197).

(3) 채무자에 대한 특별효과

1) 담보물보충청구권

(가) 저당권설정자의 책임 있는 사유로 인하여 저당물의 가격이 현저히 감소한 때에는 저당권자는 설정자에 대하여 원상회복 또는 상당한 다른 담보제공을 청구할 수 있다(제362조).

(채무자일 것/ 물상보증인 아님)

(나) 여기서 「저당물의 가격이 현저히 감소」하였다는 것이 무엇을 의미

- ① 교환가치의 감소로 인하여 피담보채권을 완전히 변제하지 못할 염려가 있는 상태라는 견해
 ② 저당물의 가액의 감소가 크면 되고 나머지를 가지고 피담보채권을 완전히 변제할 수 있더라도 저당물보충청구권이 생긴다는 견해
 → 타당 : 저당권자가 이러한 불안의 위험을 부담할 이유가 없다. 경매가격 하락예상

▶ 돌발 퀴즈

저당권설정자에 대하여 담보물보충청구권을 행사하는 경우 이외에 손해배상청구나 기한의 이익의 상실로 인한 즉시변제청구를 할 수 있는가?

: ×

- 저당권설정자의 책임있는 사유로 인하여 저당물의 가격이 현저히 감소한 때에는 저당권자는 저당권설정자에 대하여 원상회복 또는 상당한 다른 담보제공을 청구할 수 있다. 다만, 이 청구권을 행사하는 경우에는 손해배상청구권이나 기한의 이익 상실로 인한 즉시변제청구권을 행사할 수 없다.

2) 즉시변제청구권(기한의 이익의 상실)

채무자가 저당물을 손상·감소 또는 멸실하게 한 때는 기한의 이익을 잃게 되어(제388조 제1항), 채권자는 즉시 변제청구를 할 수 있으며 저당권을 실행할 수 있다.

(4) 구제방법의 관계

채무자인 저당권설정자가 고의·과실로 침해행위를 하여 담보력의 부족을 야기한 경우에는

- ① 손해배상청구권은 담보물보충청구권과는 선택적으로 행사할 수 있으나 기한의 이익 상실에 의한 즉시변제청구권과는 함께 행사할 수 있다.

- ② 즉시변제청구권은 손해배상청구권과 함께 행사할 수 있으나 담보물보충청구권과는 선택적으로 행사할 수 있을 뿐이다.

VI. 저당권의 처분

피담보채권의 변제기 전에 투하자본을 회수하기 위해 저당권을 처분할 수 있다.

→ (i) 저당권부 채권의 양도, (ii) 저당권부 채권의 입질

1. 저당권부 채권의 양도

① 수반성 :

(i) 저당권은 그 담보한 채권과 분리하여 타인에게 양도하거나 다른 채권의 담보로 하지 못한다(제361조).

(ii) 종된 권리 : 피담보채권 양도시 종된 권리인 저당권도 양도된 것으로 추정(100조 2항 유추).

② 양도의 요건

(i) 저당권부 채권양도 : 제449조 이하 적용

→ 통지·승낙(제450조 제1항 : 채무자 기타 제3자에게 대항 못함)

확정일자 증서(450조 2항 : 채무자이외의 제3자에게 대항 못함)

(ii) 저당권 양도 : 물권적 합의(저당권자와 양수인사이) + 등기(부기등기) /
채무자나 물상보증인의 합의는 불요

(iii) 통상 채권양도의 시기와 저당권이전등기의 시기가 상이하게 되는데 당사자 의사는 저당권 이전의 등기가 경료된 때에 채권양도의 효력이 발생하게 하는 것으로 볼 수 있다. 이 때 시간적 간격에 따라 저당권이 소멸한다고 볼 수는 없다.

(iv) 만약 피담보채권이 부존재하거나 소멸하였는데 채무자가 이의 없이 승낙한 경우에는 채무자는 양수인에게 채권이 없음을 주장하지 못한다. 그러나 저당권은 부종성에 의해 소멸하였으므로 다시 부활하지 않는다. 결국 양수인은 저당권 없는 채권을 취득하게 된다.(다수설)

(v) 피담보채권의 일부가 양도된 경우에는 양 채권자는 그 채권액의 비율로 저당권을 준공유한다. 이 경우 양도액 또는 변제액을 등기하여야 한다(부동산등기법 제79조).

2. 저당권부 채권의 입질

(i) 저당권은 그 담보한 채권과 분리하여 타인에게 양도하거나 다른 채권의 담보로 하지 못한다(제361조).

(ii) 제348조 (저당채권에 대한 질권과 부기등기) 저당권으로 담보한 채권을 질권의 목적으로 한 때에는 그 저당권등기에 질권의 부기등기를 하여야 그 효력이 저당권에 미친다.

(iii) 제353조 (질권의 목적이 된 채권의 실행방법)

①질권자는 질권의 목적이 된 채권을 직접 청구할 수 있다.

Ⅶ. 저당권의 소멸 : 저당권은 피담보채권과 독립하여 소멸시효에 걸리지 않지만, 피담보채권이 시효의 완성으로 소멸하면 저당권도 소멸한다(부종성).

제5항 특수저당권

특수저당권으로 민법이 규정하는 것으로는 공동저당(제368조)과 근저당(제357조)이 있고, 특별법에서 규정하는 것으로 농지저당·임목저당·재단저당·동산저당 등이 있다.

1. 공동저당

1. 의 의

동일한 채권을 담보하기 위하여 수개의 부동산 위에 설정된 저당권을 공동저당이라고 한다(제368조). 예를 들어 A가 B에 대하여 5천만원의 채권을 가지고 있는데, 그 담보를 위하여 B소유의 토지(5천만원 상당)와 건물(6천만원 상당)위에 각각 저당권을 설정하는 것이다. 공동저당은 목적물의 수만큼 저당권이 성립한다. 이러한 공동저당은 개개의 부동산으로는 채권자의 채권담보로서 충분하지 않은 경우에 수개의 부동산을 모아서 담보가치를 증대시키고, 또한 장래에 발생할 수 있는 저당부동산의 멸실·훼손 등에 의한 담보가치의 저하를 예방하는 수단으로 기능을 한다. 그리고 모든 저당권은 동일한 채권의 담보라는 단일목적하에 불가분적으로 결합하여 각 부동산이 등기된 채권액의 전부가 변제될 때까지 책임을 진다. 이 불가분성으로 인하여 공동저당권자·채무자인 저당권설정자·물상보증인·선순위 및 후순위의 저당권자 등 많은 사람의 이해관계가 교착하여, 특수한 취급을 받게 한다. 그 외에는 공동저당도 일반저당권의 성질과 동일하다.

2. 공동저당의 성립

(1) 설정계약 동일한 채권의 담보로써 수 개의 부동산 위에 저당권이 설정되면 공동저당권이 성립한다. 저당권이 설정되기 위하여는 저당권설정의 합의와 등기가 필요하다. 수개의 저당권이 동시에 공동저당으로서 설정되어야 하는 것은 아니며, 추가담보로서 소유자를 달리하여 설정될 수도 있다(부등법 제147조 참조). 공동저당의 목적물은 부동산뿐만 아니라 지상권·전세권 외에 임목법에 의한 임목, 1개의 부동산으로 보는 공장재단·광업재단 등도 될 수 있다. 그리고 목적물의 전부나 일부가 제3자(물상보증인)의 소유이더라도 상관없으며 또한 각 목적물에 있어서의 공동저당권의 순위도 반드시 같아야 하는 것은 아니다. 그리고 저당권 등의 피담보채권은 동일한 채권이나, 그것이 반드시 1개의 채권이어야 하는 것은 아니다.

(2) 등 기 공동저당에 의하여 각 부동산 위에 저당권이 성립하므로 각 부동산에 관하여 등기를 요한다. 이 경우 공동저당관계에 있는 다른 부동산과 함께 1개의 채권의 공동담보로 되어 있다는 것을 기재하여야 한다(부등법 제145조·제149조). 그리고 목적 부동산의 수가 5개 이상인 때에는 절차의 번거러움을 피하기 위하여 등기신청시에 공동담보목록을 첨부하

고 거기에 공동담보의 목적이 된 모든 부동산의 권리관계를 기재한다(부등법 제146조·제150조). 이 공동담보목록은 등기의 일부로 본다(부등법 제151조).

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 저당권에는 유치적 효력이 없다.
 - ② 저당권자도 채무자의 일반재산에 대하여 강제 집행할 수 있다.
 - ③ 저당권이 침탈된 때에는 저당물 반환을 청구할 수 있다.
 - ④ 저당권은 타인의 전원에 의하여 부속시킨 것에는 효력이 미치지 않는다.
 - ⑤ 저당권 설정 이전에 저당물에 관한 제3자의 용익물권은 저당권실행 이후에는 아무런 영향이 없다.
- ③. 저당권이 침탈된 때에는 저당권자는 점유권이 없기 때문에 설정자로부터 일탈한 저당물을 저당권자에게 반환을 청구할 수 없다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 침해가 있더라도 목적물의 잔존가치가 피담보채권을 충분히 만족시킬 수 있는 경우에는 저당권자의 침해자에 대한 손해배상청구권이 성립하지 않는다.
 - ② 저당목적물에 대한 침해가 저당권설정자의 책임 있는 사유로 이루어진 경우에만 저당권자는 저당권설정자에 대하여 담보물보충청구권을 가진다.
 - ③ 저당목적물에 대한 침해가 채무자에 의해 이루어진 경우에는 저당권자는 채무자에 대해 즉시 변제를 청구할 수 있다.
 - ④ 저당권자가 채무자에 대해 즉시 변제를 청구한 경우에는 담보물보충청구권을 행사할 수 없다.
 - ⑤ 저당권자가 채무자에 대해 즉시 변제를 청구함과 동시에 손해배상을 청구할 수는 없다.
- ⑤. 즉시변제청구권은 손해배상청구권과 함께 행사할 수 있다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 수 개의 동일한 채권을 담보하기 위한 공동저당도 가능하다.
- ② 공동저당권자가 일부만을 실행하는 경우에도 그 매각대금으로부터 피담보채권의 전액을 변제받을 수 있다.
- ③ 공동저당의 목적인 부동산 전부를 동시에 배당하는 경우에 각 부동산의 매각대금에 비례하여 피담보채권의 부담이 나누어진다.
- ④ 공동저당의 일부 부동산만의 매각대금을 먼저 배당하는 경우에, 경매된 부동산의 후순위저당권자는 공동저당부동산을 동시에 배당하였더라면 공동저당권자가 다른 부동산으로부터 변제받을 수 있었던 금액의 한도 내에서 공동저당권자를 대위하여 그 저당권을 행사할 수 있지만, 다른 부동산이 물상보증인의 소유에 속하는 경우에는 대위하지 못한다.
- ⑤ 동일 채권의 담보를 위하여 부동산과 선박에 저당권이 설정된 경우에도 ④의 법리가 적용 내지 유추적용된다.

- ⑤. 동일한 채권의 담보로 부동산과 선박에 대하여 저당권이 설정된 경우에는 민법 제368조 제2항 후문의 규정이 적용 또는 유추적용되지 아니한다. 따라서 부동산과 선박에 대한 담보권 실행절차가 함께 진행되어 동시에 배당을 하였더라면 받을 수 있었던 금액보다 적은 금액만을 배당받게 되었다고 하더라도 선박에 대한 후순위 저당권자는 민법 제368조 제2항 후문의 규정에 따라 부동산에 대한 선순위 저당권자의 저당권을 대위할 수 없다(대판 2002. 7. 12, 2001다53264).

♣ 학습정리

1. 저당권자는 저당권의 침해에 대하여 물권적 청구권으로서 방해제거 또는 방해예방을 청구할 수 있고, 불법행위에 기한 손해배상을 청구할 수 있다. 저당권은 목적물의 점유를 수반하지 않는 권리이기 때문에 반환청구권은 인정되지 않는다. 따라서 부합물이나 종물이 부당하게 분리된 경우에 이의 반출을 금지할 수 있을 뿐이고, 그것이 이미 반출된 경우에는 이의 반환을 청구할 수 없다.
2. 채무자인 저당권설정자가 고의·과실로 침해행위를 하여 담보력의 부족을 야기한 경우에는 ① 손해배상청구권은 담보물보충청구권과는 선택적으로 행사할 수 있으나, 기한의 이익 상실에 의한 즉시변제청구권과는 함께 행사할 수 있다. ② 즉시변제청구권은 손해배상청구권과 함께 행사할 수 있으나, 담보물보충청구권과는 선택적으로 행사할 수 있다.
3. 공동저당은 개개의 부동산으로는 채권자의 채권담보로서 충분하지 않은 경우 수개의 부동산을 모아서 담보가치를 증대시키고, 또한 장애에 발생할 수 있는 저당부동산의 멸실, 훼손 등에 의한 담보가치의 저하를 예방하는 수단으로 기능을 한다.

제39강 저당권 (6)

♣ 학습목표

1. 후순위저당권자에 대한 관계를 이해한다.
2. 근저당권의 의의와 성립요건 및 효력을 살펴본다.
3. 포괄근저당과 공동근저당을 유형별로 정리한다.

♣ 학습내용

- 후순위저당권자에 대한 관계
- 근저당권의 의의와 설정
- 근저당권의 효력 및 변경
- 포괄근저당의 개념과 유형
- 공동근저당의 의의

♣ 사전 테스트

1. 공동저당권자가 배당에 의하여 일부변제를 받는 경우에 후순위저당권자의 대위권은 발생하지 않는다.
⇒ × : 공동저당권자가 배당에 의하여 채권의 일부변제를 받는 경우라도 통설은 일부변제로도 후순위저당권자의 대위권이 발생한다고 한다. 이러한 경우에 부동산의 후순위저당권자는 담보권을 상실하는 반면, 다른 부동산의 후순위저당권자는 대위없는 배당을 받게 되어 유리하게 되는 불균형이 생기기 때문이다.
2. 공동저당의 목적물의 전부가 채무자 이외의 자의 소유에 속하는 경우에 공동저당권은 영향을 받는다.
⇒ × : 공동저당의 목적물의 전부 또는 일부가 채무자 이외의 자(물상보증인, 제3취득자)의 소유에 속하는 경우에도 공동저당권은 아무런 영향을 받지 않는다.
3. 근저당권도 제한물권으로서 피담보채권의 소멸에 관하여 영향을 받는다.
⇒ × : 근저당권은 피담보채권의 소멸에 관한 부종성의 예외로서 피담보채권액이 일시 감소하거나 전무하게 되더라도 저당권의 존속 자체에는 아무런 영향이 없다.

♣ 강의교안

3. 후순위저당권자에 대한 관계

공동저당권자는 수개의 목적부동산 중에서 임의로 선택하여 채권의 전부나 일부의 우선변제를 받을 수 있다. 그러나 공동저당에서 후순위저당권이 존재하는 경우에도 이러한 원칙을 관철한다면 후순위저당권자의 지위는 전적으로 공동저당권자의 의사에 따라 결정된다. 이렇게 되면 후순위저당권자 사이에도 불공평한 결과를 가져올 뿐만 아니라 부동산의 담보가치를 부당하게 고정시키는 결과가 된다. 여기서 민법은 저당권자의 자유선택을 인정하면서 아울러 각 부동산의 소유자·후순위저당권자를 보호하기 위하여 다음과 같은 규정을 두고 있다.

(1) 동시배당의 경우

공동저당의 목적물 전부를 경매하여 그 대가를 동시에 배당하는 때에는 각 부동산의 경매대가에 비례해서 피담보채권의 부담을 안분하고 각 부동산에 관하여 그 비례안분액을 넘는 부분을 후순위저당권자의 변제에 총당한다(제368조 1항). 예를 들어 A·B·C 부동산이 각각 1500만원, 1000만원, 500만원이고, 이 부동산에 대하여 甲이 1500만원의 채권으로 1번의 공동저당권을 가지고 있고, 乙이 A에 대하여 750만원, 丙이 B에 관하여 500만원 丁이 C에 대하여 250만원의 채권으로 2번 저당권을 가지는 경우에 A·B·C 부동산을 동시에 경매한다면 甲의 1500만원의 채권에 대하여 A가 750만원, B가 500만원, C가 250만원을 각각 분담하게 된다. 그리고 2번 저당권자인 乙·丙·丁도 A·B·C의 경매대가의 잔액으로부터 각각 750만원, 500만원, 250만원을 변제받을 수 있다. 이 규정은 후순위저당권자 외의 자(예 : 가압류채권자 등)도 공동저당권자를 해하지 않는 범위 내에서 보호하는 것이 타당하므로, 후순위저당권자가 존재하지 않는 경우에도 적용된다.

(2) 이시배당의 경우

1) 후순위저당권자의 대위

공동저당의 부동산 중 어느 일부 부동산이 경매되어 그 대가를 먼저 배당하는 경우에는 공동저당권자는 그 대가로부터 채권전액의 변제를 받을 수 있다. 그 결과 후순위저당권자의 지위가 불안하게 된다. 이에 민법은 이시배당의 경우에 그 경매된 부동산 위의 후순위저당권자는 선순위저당권자가 동시에 배당하였었다면 다른 부동산의 경매대가에서 변제를 받을 수 있는 금액의 한도에서 선순위저당권자를 대위하여 저당권을 행사할 수 있다(제368조 2항 후단). 위 예에서 A부동산이 경매된 경우에 甲은 그 채권전부(1500만원)를 변제받을 수 있지만, 그 결과 乙은 A부동산으로부터 변제를 받을 수 없게 된다. 여기서 후순위저당권자 乙은 제368조 2항에 의하여 甲을 대위하여 B와 C에 대하여 각각 500만원과 250만원의 한도에서 저당권을 행사할 수 있다. 민법은 공동저당권자를 대위하는 자를 「차순위 저당권자」라고 규정하나, 그것은 바로 다음 순위의 저당권자만을 가리키는 것이 아니라 후순위 저당권자 전부를 포함하는 것으로 새겨야 한다.

2) 일부변제와 대위범위

공동저당권자가 배당에 의하여 채권의 일부변제를 받는 경우라도 통설은 일부변제로도 후순위저당권자의 대위권이 발생한다고 한다. 이와 같이 해석하지 않으면 공동저당권자가 어느 부동산의 경매대가 전부로부터 채권의 일부를 변제 받은 때에는, 그 부동산의 후순위 저당권자는

담보권을 상실하는 결과로 되는 반면에 다른 부동산의 후순위 저당권자는 대위없는 배당을 받게 되어 유리하게 되는 불균형이 생기기 때문이다. 후순위 저당권자의 대위권은 공동저당권자의 채권이 완제되는 때에 발생하는데, 이 경우 후순위 저당권자는 선순위의 공동저당권자가 장차 다른 저당부동산의 대가로부터 채권잔액을 완제받아 그 공동저당권이 소멸하는 때에 그 저당권을 대위하게 된다.

3) 대위의 효과

대위의 결과 공동저당권자가 가지고 있던 저당권이 후순위저당권자에게 이전한다. 이 저당권의 이전은 법률의 규정에 의한 이전이므로 등기 없이도 효력이 생긴다. 그런데 대위할 저당권등기가 말소되고 그 후에 제3자를 위하여 저당권이 설정된 경우에도 대위자가 등기없이 대위로 주장할 수 있는지가 문제된다. 이에 관하여 학설은 (i) 대위의 등기를 하여야만 새로운 저당권자에게 대항할 수 있다는 견해, (ii) 대위의 등기 없이도 대위를 주장할 수 있다는 견해, (iii) 저당권등기가 말소되면 대위할 저당권이 존재하지 않으므로 대위가 불가능하다는 견해로 나뉘고 있다. 생각컨대 대위될 저당권등기가 말소되고 그 후에 제3자를 위하여 저당권이 설정된 경우에 신저당권자에 대해서는 등기가 있어야 대항할 수 있다고 할 것이다. 대위권이 공시되어 있지 않은 경우에는 신저당권자는 불측의 불이익을 받게 되며, 또한 거래의 안전을 해할 수 있기 때문이다. 이 경우에 대위는 저당권의 이전이고, 저당권의 이전은 부기등기에 의하므로(부등법 제153조) 대위등기도 부기등기에 의하여야 할 것이다.

(3) 선순위저당권자와의 관계

공동저당의 부동산 중의 하나 또는 수 개의 부동산 위에 선순위저당권자가 존재하는 경우에 공동저당권자는 모든 부동산을 일괄경매할 수 없고 선순위저당권이 존재하는 부동산만을 별도로 경매하여야 한다. 일괄경매를 함으로써 선순위저당권자에게 불이익이 미칠 염려가 있기 때문이다.

4. 물상보증인 또는 제3취득자에 대한 관계

공동저당의 목적물의 전부 또는 일부가 채무자 이외의 자(물상보증인·제3취득자)의 소유에 속하는 경우에도 공동저당권은 아무런 영향을 받지 않는다. 다만 물상보증인 또는 제3취득자의 소유물에 관하여 경매가 행하여진 때에는 이들은 변제자대위의 규정(제481조·제482조)에 의하여 채무자 또는 다른 자의 소유부동산 위의 공동저당권에 대위한다. 그런데 제3자에 의하여 대위되는 저당목적물에 후순위저당권자가 있는 경우에는 제3자의 대위권(제481조)과 후순위저당권자의 대위권(제368조 2항)이 충돌하게 된다. 예를 들어 甲의 乙에 대한 300만원의 채권의 담보로서 A부동산(시가 300만원)과 B부동산(시가 300만원)위에 1번 저당권이 설정되었는데, A부동산은 채무자 乙의 소유이나 B부동산은 물상보증인 丙의 소유에 속하면 그 후 A부동산 위에 丁의 채권(150만원)을 위하여 2번 저당권이 설정되었다고 하자. 이 경우에 甲이 B부동산으로부터 변제를 받고 물상보증인 丙은 제481조에 의하여 300만원에 관하여 A부동산에 대위하면 丁은 배당을 받지 못한다. 반면에 물상보증인 丙의 대위권을 제368조 제2항에 의하여 150만원으로 제한하면 丁은 보호되지만 丙은 구상권을 행사할 수 없게 된다.

(1) 학 설

1) 물상보증인 우선설(변제자대위 우선설)

후순위저당권자의 대위는 공동저당의 목적물이 모두 채무자 소유에 속하는 경우에만 인정되고, 물상보증인 소유의 부동산이 공동저당의 목적물에 포함되는 경우에는 제368조 2항 후문의

적용이 없고, 물상보증인의 변제자대위만이 인정된다고 한다. 그 논거로는 ① 물상보증인은 변제자의 대위에 관한 규정에 의하여 최종적인 책임을 채무자에게 귀속시킬 수 있는 권리를 기대하고 담보를 제공하므로 그 기대이익을 박탈할 수는 없다는 점, ② 채무자 소유의 부동산이 후순위저당권이 설정된 후에 물상보증인 소유의 부동산이 추가로 공동저당의 목적으로 된 경우에는 채무자 소유의 부동산에 설정된 후순위저당권은 원래 민법 제368조 2항의 규정에 대한 보호를 기대하지 아니하고 설정된 것이므로 새삼스럽게 이 규정에 의해 보호할 필요는 없다는 점을 들고 있다.

2) 후순위저당권자 우선설

민법 제368조 2항은 공동저당목적물의 일부가 물상보증인의 소유에 속하는 경우에도 적용되어 물상보증인의 변제자대위는 후순위자대위에 의하여 제한을 받게 되며, 후순위자의 대위와 변제자대위가 충돌, 경합하는 경우에 후순위자의 대위가 우선하고 변제자대위는 그 잔액에 대해서만 인정된다고 한다. 그 논거로서는 ① 타인의 채무를 담보하기 위하여 물상보증인이 된 자나 공동저당의 목적인 부동산을 취득한 제3자는 적어도 각 담보물의 가액에 비례한 범위에서는 책임질 것을 각오한 자이므로, 민법 제368조 2항의 규정을 무시하여 가면서까지 보호할 필요가 없으며, ② 각 부동산의 담보가치를 최대한 활용시키고자 하는 민법 제368조의 취지를 살리기 위하여는 후순위저당권자를 우선시켜야 함을 들고 있다.

3) 선순위등기 우선설

물상보증인의 저당권설정등기·제3취득자의 소유권이전등기와 후순위저당권자의 저당권등기 가운데 어느 것이 먼저 행하여졌는가에 따라 선등기자의 대위를 우선시킬 것이라고 한다.

(2) 판례

판례는 「공동저당의 목적인 채무자 소유의 부동산(A)과 물상보증인 소유의 부동산(B)에 각각 채권자를 달리하는 후순위저당권이 설정되어 있는 사례에서 물상보증인 소유의 부동산(B)에 대하여 먼저 경매가 이루어져 그 경매대금의 교부에 의하여 1번 저당권자가 변제를 받은 경우에 물상보증인(丙)은 채무자에 대하여 구상권을 취득함과 동시에 민법 제481조·제482조의 규정에 의한 변제자대위에 의하여 채무자 소유의 부동산(A)에 대한 1번 저당권을 취득한다」(대판 1994. 5. 10, 93다25417)고 하여 물상보증인을 우선시키고 있다. 다만 위 학설 중 선순위등기 우선설에서 논하고 있는 경우에 관한 판례는 없다.

(3) 검토 후순위저당권자 우선설에 의하면 후순위저당권자를 우선시켜야 저당권자 상호간의 공평을 도모할 수 있으며 그것이 제368조의 입법취지라고 하나 물상보증인 소유부동산과 채무자 소유부동산간에 동일한 지위가 인정될 수 있는지는 의문이며, 담보가치의 효율적인 이용면에서 보면 어느 견해에 따르더라도 본질적인 차이점이 발견되지 않는다는 점에서 후순위저당권자 우선설은 그 논거가 빈약하다고 하지 않을 수 없다. 따라서 물상보증인은 채무자의 담보력을 신뢰하고 제481조는 이러한 신뢰를 보호하려는 것이고, 제368조 2항은 채무자 소유의 부동산 위에 있는 경우에 적용되므로 물상보증인의 대위권을 우선시키는 것이 타당하다고 할 것이다.

[판례] 공동저당에 있어서 후순위저당권자의 대위권이 물상보증인 소유의 부동산에까지 미치는지 여부

공동저당의 목적인 채무자 소유의 부동산과 물상보증인 소유의 부동산 중 채무자 소유의 부동산에 대하여 먼저 경매가 이루어져 그 경매대금의 교부에 의하여 1번 공동저당권자가 변제를 받더라도 채무자 소유의 부동산에 대한 후순위저당권자는 민법 제368조1항 후단에 의하여 1번 공동저당권자를 대위하여 물상보증인 소유의 부동산에 대하여 저당권을 행사할 수 없다(대판 1995. 6. 13, 95마500).

[판례] 공동저당에 있어서 변제자대위와 후순위저당권자대위의 충돌(대판 1994. 5. 10, 93다25417)

- (1) 공동저당의 목적인 채무자 소유의 부동산과 물상보증인 소유의 부동산에 각각 채권자를 달리하는 후순위저당권이 설정되어 있는 경우, 물상보증인 소유의 부동산에 대하여 먼저 경매가 이루어져 그 경매대금의 교부에 의하여 1번저당권자가 변제를 받은 때에는 물상보증인은 채무자에 대하여 구상권을 취득함과 동시에, 민법 제481조, 제482조의 규정에 의한 변제자대위에 의하여 채무자 소유의 부동산에 대한 1번저당권을 취득하고, 이러한 경우 물상보증인 소유의 부동산에 대한 후순위저당권자는 물상보증인에게 이전한 1번저당권으로부터 우선하여 변제를 받을 수 있으며, 물상보증인이 수인인 경우에도 마찬가지라 할 것이므로(이 경우 물상보증인들 사이의 변제자대위의 관계는 민법 제482조 제2항 제4호, 제3호에 의하여 규율될 것이다), 자기 소유의 부동산이 먼저 경매되어 1번저당권자에게 대위변제를 한 물상보증인은 1번저당권을 대위취득하고, 그 물상보증인 소유의 부동산의 후순위저당권자는 1번저당권에 대하여 물상대위를 할 수 있다.
- (2) 물상보증인이 대위취득한 선순위저당권설정등기에 대하여는 말소등기가 경료될 것이 아니라 물상보증인 앞으로 대위에 의한 저당권이전의 부기등기가 경료되어야 할 성질의 것이며, 따라서 아직 경매되지 아니한 공동저당물의 소유자로서는 1번저당권자에 대한 피담보채무가 소멸하였다는 사정만으로는 말소등기를 청구할 수 없다.

II. 근저당

1. 의의

근저당이란 계속적 거래관계로부터 생기는 불특정다수의 채권을 장래의 결산기에 있어서 일정한 한도액까지 담보할 목적으로 설정된 저당권을 말한다(제357조). 예를 들어 은행과 상인 사이의 계속적인 신용수수나 상사와 소매상 사이의 계속적 물품공급 등의 경우처럼, 계속적으로 거래하고 있는 당사자 사이에는 여러 채권이 발생·변제되고 다시 채권이 발생하고 변제되는 과정이 반복되며, 또한 그 액도 일정하지 않다. 이러한 채권을 담보하려면 저당권의 설정·말소를 연속적으로 행하여야 한다. 여기서 장래의 불특정한 채권을 담보할 수 있을 뿐만 아니라 저당권의 소멸에 있어서의 부종성을 완화하여 저당권과 채권의 결합관계가 요구되지 않는 저당권이 필요하게 되는데, 이러한 제도를 인정된 것이 근저당이다.

2. 特 質

- 1) 근저당권은 장래의 증감·변동하는 불특정·다수의 채권을 담보한다. 이 증감·변동하는 채권은 근저당계약의 기초가 된 당좌대월계약·어음할인·대부계약·상인간의 계속적 상품공급계약 등의 계속적 계약관계로부터 생긴다.
- 2) 근저당권은 피담보채권의 소멸에 관한 부종성의 예외로서 피담보채권액이 일시 감소하거나 전무하게 되더라도 저당권의 존속 자체에는 아무 영향이 없다. 이러한 점에서 피담보채권이 존재하지 않으면 저당권도 소멸한다는 저당권의 부종성에 대한 예외가 되는 것이다.

3. 근저당권의 설정

근저당권도 보통저당권과 마찬가지로 근저당권설정의 물권적 합의와 등기에 의하여 성립한다(제186조).

- (1) 설정계약 근저당권설정계약의 당사자는 근저당권자(채권자)와 근저당설정자(채무자·물상보증인)이다. 근저당권이 성립하기 위해서는 계속적 계약관계(예 : 당좌대월계약·어음할인계

약·물품공급계약 등)의 성질을 가진 기본계약이 체결되어야 한다. 그리고 설정계약에서는 담보할 채권의 최고액과 피담보채권의 범위를 결정하는 기준이 정하여져야 한다. 근저당권의 존속기간 내지 결산기의 약정여부는 자유이다(대판1959. 5. 14, 4291민상564).

(2) 등 기

1) 등기원인 근저당권의 등기에서는 그것이 근저당이라는 것을 반드시 등기하여야 하는데, 이는 등기원인으로서 기본계약을 기재할 것이지만 실재로는 「근저당권설정계약」이라고 기재한다(부동산등기법 제140조 2항). 이를 기재하지 않으면 보통의 저당권이 설정된 것으로 본다.

2) 최고액 담보할 채권의 최고액을 반드시 등기하여야 한다(부등법 제140조 2항). 최고액은 보통의 저당권에 있어서 채권액에 상당하는 것이므로 이를 등기로 공시하지 않으면 제3자에게 불측의 손해를 입힐 수 있기 때문이다. 최고액으로서 등기되는 것은 채권원본의 한도액이 아니라 이자를 포함하는 원리금의 한도액이므로(제357조 2항) 이자의 등기를 별도로 할 필요는 없다.

3) 근저당권의 존속기간·결산기의 등기 근저당권의 존속기간 또는 기본계약에 의한 거래관계의 결산기에 관한 약정은 반드시 등기할 필요는 없지만(임의적 기재사항), 이를 등기한 때에는 그 시기 이후에 발생한 채권을 피담보채권에 포함시키지 못하고, 당사자의 합의로 이를 연기하여도 그것을 가지고 후순위저당권자에게 대항하지 못한다(대판 1961. 12. 14, 4293민상893).

4. 근저당권의 효력

▶ 돌발 퀴즈

실제 대출금액과 다른 근저당권에서 최고액의 실질적인 의미는 무엇인가?

- 원래 저당권은 원본, 이자, 위약금, 채무불이행으로 인한 손해배상 및 저당권의 실행비용을 담보하는 것이며, 채권최고액의 정함이 있는 근저당권에 있어서 이러한 채권의 총액이 그 채권최고액을 초과하는 경우, 적어도 근저당권자와 채무자 겸 근저당권설정자와의 관계에 있어서는 위 채권 전액의 변제가 있을 때까지 근저당권의 효력은 채권최고액과는 관계없이 잔존채무에 여전히 미친다. 금융기관에서는 관례적으로 대출금액의 120%를 기준으로 최고액을 산정한다.

(1) 피담보채권의 범위

1) 담보되는 채권 근저당권으로 담보하는 피담보채권은 설정계약에 의하여 정하여진다. 당사자는 약정에 의하여 설정계약 전의 기존채무도 담보의 목적에 포함시킬 수 있다(대판 1958. 6. 12, 4290민상875). 그리고 설정계약 전에 발생한 채무가 설정계약에서 정한 것과 같은 거래방법에 의하여 발생한 때에는 특별한 사정이 없는 한 당사자 사이의 근저당권에 의하여 담보하기로 합의 한 것으로 보아야 한다(대판1970. 4. 28). 그러나 설정계약에서 채무자를 지정한 경우에는 지정된 채무자가 아닌 자의 채무는 담보되지 않는다(대판1987. 12. 8, 87다카2008).

그런데 결산기에 확정된 채권액이 최고액을 넘는 경우에 채무자가 최고액만을 변제하고 근저당권등기의 말소를 청구할 수 있는지가 문제된다. 이에 관하여 판례는 근저당권에 있어서 채권의 총액이 최고액을 초과하는 경우, 적어도 근저당권자와 채무자 겸 근저당권설정자와의 관계에서는 위 채권 전액의 변제가 있을 때까지 근저당권의 효력은 채권최고액과는 관계없이 잔존채무에 여전히 미친다고 하면서, 채무자겸 근저당권설정자는 채무의 일부인 채권최고액과 지연손해금·집행비용만의 변제공탁으로는 근저당권설정등기의 말소를 청구할 수 없다고

한다(대판1981. 11. 10, 80다2712). 한편 판례는 물상보증인이나 근저당부동산의 제3취득자는 채권최고액과 경매비용을 변제공탁하면 근저당권의 소멸을 청구할 수 있다고 한다(대판 1974. 12. 10, 74다998).

2) 최고액 근저당권설정계약에서 정한 최고액은 목적물로부터 우선변제를 받을 수 있는 최고한도액을 말하며, 근저당권을 실행할 수 있는 피담보채권은 결산기에 확정된다. 결산기에 피담보채권이 최고액을 넘은 때에는 그 한도액까지, 그 반대로 피담보채권액이 최고액에 미달하면 그 때의 구체적인 확정액에 한하여 근저당권자는 우선변제를 받을 수 있다(대판 1971. 4. 6, 71다 26). 근저당권에 의하여 담보되는 채권은 설정계약에서 정하여진 최고액을 한도로, 결산기에 현실로 존재하는 채권액의 전부에 미치며 저당권의 효력이 미치는 목적물의 범위는 보통저당권의 경우와 같다.

3) 최고액과 민법 제360조 저당권의 피담보채권의 범위에 관한 민법 제360조는 근저당에도 적용된다고 본다. 따라서 원본·이자·위약금·채무불이행으로 인한 손해배상·저당권의 실행비용 등이 모두 채권최고액의 범위 내에서 담보된다(제360조 본문). 이 경우 채무의 이자는 최고액 중에 산입한 것으로 본다(제357조 2항). 그리고 여기서의 이자는 1년 이후의 지연이자를 포함한 모든 지연이자 내지 지연배상도 최고액에 포함되는 것으로 해석한다. 즉 제360조 단서는 근저당에는 적용이 없다고 본다. 그밖에 근저당권의 실행비용이 최고액에 포함되는가에 관하여는 긍정설과 부정설이 대립된다. 생각건대 제360조의 해석에 있어서도 직접적인 경매비용인 저당권의 실행비용은 최고액에 산입되지 않는다고 할 것이다. 판례도 경매비용은 저당권의 실행비용에 포함되지 않는 것으로 해석하여 부정설을 취하고 있다(대판 1971. 4. 6, 71다26).

3) 담보되는 채권의 확정 피담보채권은 (i) 근저당권의 설정계약 내지 기본계약에서 규정되고 있는 결산기가 도래하거나, (ii) 근저당권의 존속기간이 있는 경우에는 그 기간이 만료되거나, (iii) 기본계약 또는 근저당권설정계약이 해지 또는 해제되는 때에 확정된다. 근저당권의 존속기간을 정하지 아니한 때에는 다른 특약이 없는 한 당사자는 기본계약 또는 설정계약을 해지할 수 있다(대판 1962. 3. 22, 4294민상1149). 또한 근저당부동산의 제3취득자가 설정계약을 해지 할 수도 있다(대판2002. 5. 24, 2002다7176 ; 대판2001. 11. 9, 2001다47528). 뿐만 아니라 존속기간이나 결산기가 정하여져 있다고 하더라도 근저당권에 의하여 담보되는 채권이 모두 소멸하고 채무자가 거래를 계속 할 의사가 없는 경우에는 근저당권설정자는 계약을 해지할 수 있다(대판2002. 2. 26, 2000다48265). 또한 물상보증인은 피담보채무가 현존하든 없든 새로운 채무의 발생이 없고, 앞으로도 계속적인 거래관계를 유지할 수 없는 사정이 있는 경우에는 근저당권의 소멸을 청구할 수 있다(대판1990. 6. 26, 89다카26915). 위와 같이 피담보채권이 확정되면 그 후에 발생하는 채권은 그 근저당권에 의하여 담보되지 못한다(대판 1988. 10. 11, 87다카545). 그리고 피담보채권이 확정된 때로부터 근저당권은 불특정 채권의 담보라는 성격을 상실하고 보통저당권으로 전환된다(대판 1963. 2. 7, 62다796). 경매를 신청하는 경우에는 경매신청시에 피담보채권액이 확정되고 피담보채권이 확정되면 근저당권은 보통저당권과 동일하게 된다고 할 것이므로(대판 1997. 12. 29, 97다25521), 그 후에 발생하는 채권은 그 근저당권에 의하여 담보되지 아니하고 무담보채권으로 된다고 할 것이다(대판1991. 9. 10, 91다17979).

(2) 근저당권의 실행

근저당권자는 담보되는 채권이 확정되고, 그 채권의 변제기가 도래하면(즉, 채권이 확정된 때) 근저당권을 실행하여 최고액까지 피담보채권의 우선변제를 받을 수 있다. 근저당에 있어서 피담보채권이 확정되면 보통의 저당권으로 전환되므로, 근저당권의 실행은 일반저당권의 실행과 동

일한 절차에 의한다. 다른 채권자가 근저당권의 목적물에 관하여 경매를 신청하면 근저당권은 경매개시결정이 있는 때를 기준으로 하여 그 때까지 생긴 채권에 대하여 최고액의 한도에서 우선변제받을 수 있다. 판례는 후순위 근저당권자가 경매를 신청한 경우에 선순위 근저당권의 피담보채권은 매수인이 매수대금을 완납한 때 확정된다고(대판 1999. 9. 21, 99다26085)하고 실제로 경매신청을 한 것이 아니라 경매신청을 하려는 태도를 보이는 것만으로는 근저당채무가 확정되었다고 볼 수 없다고 한다(대판 1993. 3. 12, 92다48567).

5. 근저당권의 변경

(1) 최고액·존속기간의 변경

당사자는 계약에 의하여 근저당권설정계약으로 정한 최고액·존속기간을 변경할 수 있다. 다만 후순위저당권자 등의 등기상 이해관계를 가지는 제3자가 있는 경우에는 그의 승낙서를 첨부하여 부기등기를 할 수 있다(부등법 제63조).

(2) 기본계약의 追加·변경

피담보채권이 확정되기 전에는 기본계약을 변경하거나 다른 기본계약을 추가할 수 있다. 최고액의 한도에서 변경·추가하는 것이므로 근저당권의 동일성을 변경하는 것이 아니기 때문이다. 따라서 부기등기에 후순위저당권자의 승낙서를 첨부할 필요는 없다.

(3) 채권자·채무자 지위의 변경

설정계약에서 정한 채권자·채무자는 상속 또는 합병에 의하여 변경될 수 있다. 이 때에도 근저당권의 이전에 등기가 필요하지 않다. 기본계약상의 채권자의 지위나 채무자의 지위는 계약에 의하여 타인에게 이전될 수 있는데, 특정승계도 인정되며, 이는 계약인수에 의하여 이루어지므로 기본계약의 당사자와 인수인의 3면계약을 요한다. 이러한 지위의 이전이 있으면 근저당권도 새로운 채권자에게 이전된다. 이 경우에는 근저당권의 이전등기를 하여야 한다.

(4) 근저당권의 양도

근저당권에 의하여 담보되어 있는 어떤 개별적인 채권이 양도된 경우에 그 채권은 담보되는 채권의 범위에서 제외되며, 근저당권의 기초가 되는 계약관계상 당사자의 지위가 이전되면 이에 수반하여 근저당권도 이전된다. 다만 피담보채권과 분리하여 근저당권만 양도할 수는 없으며, 피담보채권이 없는 근저당권의 양도는 무효이다(대판 1968. 2. 20 67다2543). 따라서 근저당을 양도하는 경우에는 근저당설정자·양수인·채무자의 3면계약에 의하여야 하며, 근저당이전의 등기를 하여야 효력이 생긴다.

피담보채권의 일부가 양도된 때에 근저당권도 이전하는가?

- 피담보채권이 확정된 후에 일부의 채권이 양도되고 근저당권에 관하여 준공유등기를 하면, 근저당권은 채권자들에 의하여 준공유하게 된다. 물상보증인이나 근저당부동산의 제3취득자가 일부변제를 한 경우에는 등기 없이도 근저당권을 준공유한다(대판2002. 7. 26, 2001다53929).
- 피담보채권이 확정되기 전에 일부의 채권이 양도 또는 이전된 때에도 근저당권이 이전되는가에 관하여 학설은 부정설과 긍정설로 나뉜다. 판례는 부정설을 취하고 있다(대판2002. 7. 26, 2001다53929).

6. 근저당권의 소멸

- (2) 근저당권의 소멸 피담보채권이 확정되기 전에는 일단 발생한 채권을 채무자가 변제하더라도 근저당권은 소멸하지 않는다(대판 1965. 4. 20, 64다1698). 그러나 피담보채권이 확정되기 전이라도 근저당설정계약에 존속기간의 정함이 없는 때에는, 이미 발생한 채무가 변제 등으로 전부 소멸하고 있으면, 기본계약과 설정계약을 해지하여 근저당권을 소멸시킬 수 있다(대판 1965. 12. 7, 65다1617). 한편 근저당권의 존속기간이나 결산기를 정하고 있는

때에는 발생한 채권이 소멸하고 있고, 또한 채무자가 거래의 계속을 원하지 않으면 설정자는 계약을 해지하고 설정등기의 말소를 청구할 수 있다(대판 1966. 3. 22, 66다68).

확정된 피담보채권이 최고액을 초과한 경우에는 채권전액을 변제하여야만 소멸을 청구할 수 있는가, 아니면 최고액만 변제하여도 소멸을 청구할 수 있는지가 문제된다. 이에 관하여 판례는 채무자겸 근저당권설정자(대판 1981. 11. 10, 80다2712)나 연대보증인겸 근저당권설정자(대판 1972. 5. 23, 72다485등)에 대해서는 피담보채권액 전액을 변제하여야만 근저당권의 소멸을 청구할 수 있다는 입장을 취하고 있다. 그러나 경매부동산의 제3취득자, 후순위담보권자 및 단순한 물상보증인의 경우는 그 부동산으로 담보하는 채권최고액과 경매비용을 변제공탁하면 그 저당권의 소멸을 청구할 수 있다고 한다(대결 1971. 5. 15, 71마 251 ; 대판 1974. 12. 10, 74다998).

7. 포괄근저당

(1) 의의

포괄근저당이란 채권발생의 기초가 되는 계속적 거래계약(기본계약)에 의하여 발생하는 채권뿐만 아니라 당사자 사이에 발생하는 현재 및 장래의 일체의 채권을 일정한도액까지 담보하기 위하여 설정된 근저당이다. 예를 들어 A가 B은행에 당좌대월계약을 맺고 B은행이 그 채권을 담보하기 위하여 근저당권을 설정하였는데 A가 은행과 맺은 당좌대월계약외의 다른 금융거래(예 : 어음대출·어음할인·증서대출 등)를 맺고자 할 때에는 그 거래별로 따로 근저당권을 설정하여야 하는 번거로움이 따른다. 여기서 이들을 포괄하여 하나의 근저당권으로 일괄하여 담보하는 것이 필요한데, 이를 포괄근저당이라고 한다.

(2) 유 형

- 1) 순수한 포괄근저당 채권자와 채무자 사이에 현재 및 장래에 발생할 일체의 채권·채무를 담보한다는 유형을 말하는 데 실제에 있어서는 매우 드물다.
- 2) 부가적 포괄근저당 당좌대월계약·어음할인계약·상호계산계약 등과 같이 유형적인 기본계약을 열거하고 「...등의 계약에서 생기는 채무 기타 일체의 채무를 담보한다」는 형식으로 설정하는 것으로 은행거래에서 주로 이용되고 있다.

(3) 유 효 성

- 1) 학 설 포괄근저당의 유효성에 관하여는 (i) 근저당에 관한 제357조에서 부종성이 완화되고, 계약자유 원칙에 비추어 제한적 유효설은 제한의 경우 및 한계가 문제가 되고, 채권의 특정성이 없어도 한도액의 약정 내지 등기로 제3자에게 손해를 주지 않으며, 담보가치의 독점적 지배의 폐단은 무지공박의 이용 여부에 의하면 된다는 등을 근거로 제한 없이 유효하다는 단순유효설과 (ii) 「당사자 사이의 일체의 채권을 담보한다」고 하는 순수한 포괄근저당권은 부종성을 갖추지 못하므로 무효이나 당좌대월계약, 계속적 어음할인계약 등에서 생기는 채권 기타 일체의 채권을 담보하는 것과 같은 제한적 포괄근저당은 유효하다는 한정적 유효설, (iii) 기본계약이 있어야 한다는 점은 한정적 유효설과 동일하나 그 기본계약이 채권채무를 발생하는 계약에 국한하지 않고 담보계약으로도 충분하다고 하고 포괄근저당의 유효·무효문제를 피담보채권의 범위문제로 보는 확대한정적 유효설이 대립한다. 포괄근저당은 금융거래에 있어서 근저당권자에게는 편리한 제도이지만 이를 남용하게 되면 근저당권설정자에게 피해가 발생할 수도 있다. 따라서 포괄근저당의 유효성을 인정하되 구체적인 경우에 당사자 사이의 의사표시의 해석에 의하여 피담보채권의 범위를 한정하거나, 장래에 확정될 수 있는 피담보채권에 한하여 한정적으로 그 유효성을 인정함이 타당하다고 본다.
- 2) 판 례 판례는 포괄근저당의 유효성에 대하여 정면으로 판단하지 않고 있으며, 다만 그 유효성을 전제로 피담보채권의 범위를 판단하고 있다. 종래의 판례에서는 원고가 피고에

대하여 현재 또는 장래 부담하게 될 보증채무를 포함한 모든 채무를 담보하기 위하여 근저당이 설정될 수 있다는 약관을 유효한 것으로 보았다(대판 1982. 12. 14, 82다카413). 나아가 판례는 소비대차계약에 기하여 부담하게 될 일체의 채무와 그 불이행으로 인한 손해배상채무를 담보하기 위하여 근저당설정계약을 체결한 경우에는 이 근저당권은 소비대차계약이 무효로 됨으로써 발생하는 부당이득반환채권을 담보하는 것으로 보았다(대판 1968. 1. 11, 67마576). 그러나 약관규제법의 시행을 계기로 판례는 포괄약관부 근저당권으로 담보되는 피담보채권의 범위를 축소하고 있다. 따라서 최근 판례는 금융기관 등에서 일반거래약관의 형태로 사용하는 근저당설정계약서에 장래에 부담하게 될 다른 원인에 의한 모든 채무도 포함하는 것으로 기재되었다고 하여도 그 피담보채무에 대한 포괄적 기재는 부동산으로 인쇄된 일반약관의 예문에 불과한 것으로 보아 그 구속력을 배제하는 것이 타당하다(대판 1990. 7. 10, 89다카12152; 대판 1997. 5. 28, 96다9508)고 하여 채무자의 특정한 채무만을 담보하는 것으로 해석하고 있다.

8. 공동근저당

피담보채권을 공동으로 하는 근저당권을 수개의 부동산 위에 설정한 경우가 공동근저당이다. 공동근저당에 대해서도 민법 제368조가 적용된다. 따라서 확정채권액이 최고액보다 적으면 확정채권액을 기준으로 하고 많을 때에는 최고액을 기준으로 하여, 동시배당에 대하여는 제368조 1항을, 이시배당에 대하여는 제368조 2항을 적용하여야 한다.

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 순차배당에서 일부 변제받은 경우에는 대위권이 인정되지 않는다.
- ② 일부목적물에 설정된 저당권이 무효이면 나머지 물건에 대한 저당권도 무효이다.
- ③ 어떤 부동산의 매득금만으로 채무액 전액을 변제할 수 있는 경우에도 동시배당을 하여야 한다.
- ④ 공동저당의 목적물 중 일부가 물상보증인에게 속하고 채무자소유의 목적부동산 위에 후순위저당권자가 있을 때 판례는 후순위저당권자를 우선시킨다.
- ⑤ 동시배당에 관한 민법규정은 후순위저당권자가 없는 경우에도 적용된다.
- ⑤. 동시배당에 관한 민법 제368조는 후순위저당권자의 존재여부와 상관없이 적용된다. 공동저당목적부동산의 경매대가에 대한 배당참가는 저당권자 이외에도 존재할 수 있는데(예컨대, 집행권원을 가지는 배당요구자, 가압류채권자 등), 이러한 배당권자도 고려해야하기 때문이다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 근저당에서 담보할 채권의 최고액이란 목적물로부터 우선변제를 받을 수 있는 한도액을 의미하는 것이 아니고 책임의 한도액을 의미한다.
- ② 채권의 최고액에는 피담보채권의 이자가 포함된 것으로 본다.
- ③ 채권액이 확정되면 그 이후 발생하는 채권은 더 이상 근저당권에 의하여 담보되지 않는다.
- ④ 후순위권리자가 없는 한, 당사자는 피담보채권액이 확정될 때까지는 최고액 또는 존속기간을 합의로 변경할 수 있고, 이를 변경등기하여야 한다.

⑤ 피담보채권의 양도 없는 근저당권만의 양도는 무효이다.

①. 근저당에서 담보할 채권의 최고액이란 우선변제를 받을 수 있는 한도액을 의미한다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 근저당권설정 후 저당목적물의 소유권이 제3자에게 이전된 경우 현재의 소유자는 피담보채무가 소멸된 경우라도 근저당권의 말소를 청구할 수 없다.
- ② 근저당권설정시 채권최고액은 필요적 등기사항이다.
- ③ 근저당권자가 경매를 신청한 경우 그 근저당권의 원본채권액은 경매신청시에 확정된다.
- ④ 결산기의 정함이 없는 경우 근저당권설정자는 언제든지 근저당권자를 상대로 해지의 의사표시를 함으로써 피담보채무를 확정시킬 수 있다.
- ⑤ 실제 발생한 채권액이 채권최고액을 초과하는 경우 채무자는 실제 채권액 전액을 변제하여야 근저당권의 말소를 청구할 수 있다.

①. 현재의 소유자는 소유권에 기한 물권적 청구권으로서 피담보채권의 소멸을 원인으로 근저당권설정등기의 말소를 청구할 수 있다.

♣ 학습정리

- 1. 동시배당에 관한 민법 제368조는 후순위저당권자의 존재여부와 상관없이 적용되나, 이시배당의 경우 후순위저당권자의 지위가 불안하기 때문에 후순위저당권자는 선순위저당권자가 동시배당을 하였더라면 다른 부동산의 경매대가에서 변제를 받을 수 있는 금액의 한도에서 선순위저당권자를 대위하여 저당권을 행사할 수 있다.
- 2. 근저당권은 장래의 증감 및 변동하는 불특정 다수의 채권을 담보하고, 피담보채권의 소멸에 관한 부종성의 예외로서 피담보채권액이 일시 감소하거나 전무하게 되더라도 저당권의 존속 자체에는 아무 영향이 없다. 이러한 점에서 피담보채권이 존재하지 않으면 저당권도 소멸한다는 저당권의 부종성에 대한 예외가 되는 것이다.
- 3. 근저당권에 의하여 담보된 채권이 양도된 경우에 그 채권은 담보되는 채권의 범위에서 제외되며, 근저당권의 기초가 되는 계약관계상 당사자의 지위가 이전되면 이에 수반하여 근저당권도 이전된다. 다만 피담보채권과 분리하여 근저당권만 양도할 수는 없고, 피담보채권이 없는 근저당권의 양도는 무효이다. 따라서 근저당설정자, 양수인, 채무자의 3면계약에 의하여야 하며, 근저당이전의 등기를 하여야 효력이 발생한다.

제40강 저당권 (7), 가등기담보 (1)

♣ 학습목표

1. 특별법에 의한 저당권을 살펴본다.
2. 비전형담보의 의의 및 작용을 이해한다.
3. 가등기담보의 개념, 법적 성질 및 효력을 정리한다.

♣ 학습내용

- 특별법에 의한 저당권의 종류
- 비전형담보의 의의와 유형
- 가등기담보의 개념과 성질
- 가등기담보의 설정 및 이전
- 가등기담보의 효력

♣ 사전 테스트

1. 임목은 법정지상권의 대상이 아니다.
⇒ × : 토지와 그 지상의 임목이 동일소유자에 속하였다가 어느 한 쪽이 저당권의 목적이 되어 경매되고, 양자의 소유자가 다르게 된 때 토지소유자는 임목소유자에게 지상권을 설정한 것으로 의제한다(임목법 제6조 1항).
2. 가등기담보는 양도담보와 달리 소유권이전형 담보형식에 의한 물적담보방식을 말한다.
⇒ ○ : 가등기담보는 미리 소유권이전청구권을 보전하기 위한 가등기를 하는 담보형식인 소유권이전형 담보형식에 의한 물적담보방식이며, 처음부터 권리의 이전이 없다는 점에서 일단 권리를 이전했다가 변제가 있으면 다시 권리를 반환받는 양도담보와 다르다.
3. 가등기담보권은 피담보채권과 함께 양도할 수 있을 뿐 아니라, 피담보채권을 분리하여 양도할 수 있다.
⇒ × : 가등기담보권도 일반적인 재산권과 같이 양도성 내지 이전성을 가지며 피담보채권과 더불어 양도할 수 있다. 다만 가등기담보권은 담보권의 부종성으로 인하여 피담보채권과 함께 양도할 수 있을 뿐이고, 피담보채권과 분리하여 양도할 수 없다.

♣ 강의교안

III. 특별법에 의한 저당권

저당권에 관한 민법의 규정은 민법 이외의 법률에 의하여 설정되는 저당권에 대해서도 준용된다(제372조). 예를 들어 입목저당(입목법 제3조)·선박저당(상법 제871조)·재단저당(공장저당법·광업재단저당법)·동산저당(자동차 등 특정동산 저당법)·광업권의 저당(광업법 제13조)·어업권의 저당(수산업법 제29조) 등에 준용된다.

1. 입목저당

(1) 의 의

입목에 관한 법률이 제정되어 일필의 토지 또는 일필의 토지의 일부에 성립하는 소정의 종류 범위에 속하는 수목의 집단(입목법시행령 제1조)은 소유권보존등기를 할 수 있다. 이 등기를 거친 수목의 집단은 입목법상 입목이라고 불리고(입목법 제2조), 토지와 독립한 하나의 부동산으로 보게 되며(동법 제3조 1항), 토지와 분리해서 양도 및 저당의 목적이 될 수 있다(동법 제3조 2항). 이러한 입목을 목적으로 하여 설정된 저당권을 입목저당이라고 한다.

(2) 입목저당권의 설정

입목저당은 저당권자(채권자)와 저당권설정자(채무자·제3자) 사이의 입목저당권설정의 합의와 등기에 의하여 설정된다. 그리고 입목을 저당권의 목적으로 하려면 그 입목을 보험에 가입시켜야 한다(입목법 제22조).

(3) 입목저당권의 효력

- 1) 입목의 벌채 입목에 관하여 저당권을 설정하면 입목소유자는 당사자 사이에 약정한 방법에 따라 그 입목을 조성·육림하여야 한다(동법 제5조 1항). 저당된 입목은 저당권자의 동의가 있는 때에는 행정기관의 허가를 얻어 벌채를 할 수 있으며(동법시행령 제2조), 이 경우에 저당권의 효력은 벌채되어 토지로부터 분리된 입목에 대해서도 미친다(입목법 제4조 1항). 저당권자는 그의 피담보채권의 기한이 도래하기 전이라도 벌채된 수목을 경매할 수 있다.
- 2) 법정지상권 토지와 그 지상의 입목이 동일소유자에 속하는 경우에는, 그 어느 한 쪽이 저당권의 목적이 되어 경매되고, 양자의 소유자가 다르게 된 때, 토지소유자는 입목소유자에게 지상권을 설정한 것으로 간주된다(입목법 제6조 1항). 즉 민법 제366조와 같은 법정지상권의 제도를 인정한 것이다. 그리고 지상권자 또는 토지임차인이 그 소유의 입목을 저당한 경우에는 저당권자의 승낙 없이 자기의 지상권이나 임차권을 포기하지 못하고, 또한 토지소유자와의 사이에서 합의해지를 하지 못한다(입목법 제7조).

2. 재단저당

재단저당제도는 기업경영을 위한 토지 건물·기계·기구·기타의 물적 설비나 공업소유권 등을 한 데 묶어 하나의 재단을 구성하고, 그 위에 저당권을 설정하는 것을 인정하는 제도이다. 여기에는 공장저당법에 의한 공장재단저당과, 광업재단저당법에 의한 광업재단저당이 있다.

(1) 공장저당

공장저당법은 공장재단저당과 협의의 공장저당 두 가지를 규정하고 있다.

- 1) 공장재단저당 1개 또는 수개의 공장에 관하여 설정되고(공장저당법 제11조) 공장에 속하는 토지·공작물·기계·기구·전주·전선·기타의 부속물이나 지상권·전세권·임차권·공업소유권으로 구성된다(공장저당법 제15조). 이 저당권은 재단을 구성하는 개개의 물건 또는 권리를 표시한 공장재단목록을 작성하여(공장저당법 제39조) 이를 공장재단등기부에 소유권보존등기를 함으로써 설정된다(공장저당법 제32조 이하).

2) 협의의 공장저당 공장소유자는 공장재단저당을 설정하지 않고 협의의 공장저당을 설정할 수도 있다(공장저당법 제4조 내지 제10조). 협의의 공장저당은 공장에 속하는 토지·건물·권리 등에 대하여 각각 개별적으로 저당권을 설정하는 것이며 전체로서의 공장을 담보에 제공하는 것이 아니라는 점에서 공장재단저당과 다르다. 다만 공장에 속하는 토지에 설정한 저당권의 효력은 원칙적으로 그 토지의 부가물과 공용물에도 미친다는 점에서 민법상의 저당권과 차이가 있다(공장저당법 제4조). 부가물에 관하여는 별도의 규정이 없으나 공용물에 관하여는 저당권설정등기를 신청한 때 그에 관한 목록을 제출하여야 하며, 그 목록은 등기부의 일부로서 다루어진다(공장저당법 제7조 2항). 따라서 공용물은 위 기계·기구목록에 기재되어야만 공장저당의 효력이 미치게 된다(대판 1988. 2. 9, 89다카1514).

(2) 광업재단저당

광업재단저당은 광업재단저당법에 의하여 설정된다. 광업재단은 광업권·토지와 공작물·지상권과 기타 토지사용권·임차권·기계·기구·차량·선박 기타 부속물으로써 광업에 관하여 동일한 광업권자에게 귀속하는 것의 일부 또는 전부로서 구성된다(광업재단저당법 제4조). 광업재단에 관하여는 공장저당법 중 공장재단에 관한 규정이 준용된다(동법 제5조).

3. 동산저당

민법상 동산은 질권의 목적이 될 뿐 저당권의 목적이 되지는 못한다. 이를 담보화하는 방법으로는 양도담보와 등기·등록의 제도를 두어 저당권을 공시하는 방법이 있다. 후자가 이른바 동산저당제도로 특별법에서 인정되고 있는 것으로는 자동차·항공기·건설기계 등의 저당권(자동차 등 특정동산저당법)·상법상 선박저당권(상법 제871조·874조)이 있으며, 이들에 대해서는 질권설정이 금지되고 있다.

제5절 비전형담보

제1항 총설

1. 비전형담보의 의의 및 작용

1. 의의

민법이 예정하지 않았던 새로운 담보방법으로 실제 거래계에서 신용수수에 대한 담보권적인 기능을 수행하고 있는 모든 제도를 변칙담보 또는 비전형담보라고 한다. 민법은 법정담보물권으로 유치권, 약정담보물권으로 질권과 저당권을 규정하고 있다. 그러나 이러한 담보물권만으로는 거래계의 요청에 충분히 대처할 수 없다. 즉 담보권설정자가 동산을 담보로 제공하여 질권을 설정한 경우에는 그 동산을 인도하여야 하기 때문에 직접 점유·이용 할 수 없게 된다. 따라서 담보권설정자가 자기의 동산을 점유·이용하면서 담보로 제공할 수 있는 민법상의 담보제도 외에 새로운 유형의 변칙담보제도가 필요하게 된 것이다.

2. 작용

비전형담보는 ① 동산저당의 결과를 가져오기 위하여 거래계에서 이용하게 되었으며, ② 목적물의 가액이 피담보채권액을 초과하는 경우에 그러한 초과분의 취득을 가능하게 하는 방법으로

나타난 것으로, ③ 저당권의 실행방법인 담보권실행경매의 번거로운 절차를 회피하기 위하여 개발·이용하게 된 것이다.

II. 비전형담보의 유형

1. 매매에 의한 방식(매도담보 ; 넓은 의미의 양도담보)

환매와 재매매의 예약과 같은 매매의 방법에 의하여 필요한 자금을 융통하는 경우인데, 이를 일반적으로 매도담보라고 한다. 예를 들어 5000만원이 필요한 A가 부동산을 5000만원에 B에게 매각하여 자금을 융통하고 후에 5000만원을 변제함으로써 그 부동산을 다시 반환받는 방법이다.

2. 소비대차에 의한 방식

필요한 자금을 금전소비대차의 형식으로 얻고 그것을 담보하기 위하여 소유권을 이전하거나 또는 장차 소유권을 이전하기로 하는 방식이다. 소비대차에 의한 방식은 다시 계약체결과 동시에 목적물의 소유권을 채권자에게 이전하는 형식을 취하는 좁은 의미의 양도담보와 채무불이행이 있는 때에 목적물의 소유권을 채권자에게 이전하는 형식을 취하는 가등기담보가 있다.

(1) 좁은 의미의 양도담보 예를 들어 5000만원이 필요한 A가 소비대차계약에 의하여 B로부터 5000만원을 차용하고, 이 채무를 담보하기 위하여 A소유의 물건의 소유권을 B에게 이전하는 것이 좁은 의미의 양도담보이다. 좁은 의미의 양도담보는 다시 채권자가 변제기에 그 목적물의 환가대금에서 채권의 원리금을 변제받고 나머지가 있으면 이를 채무자에게 반환하기로 하는 정산형의 약한 의미의 양도담보와 목적물의 환가대금 중 잔여가 있더라도 반환하지 않아도 되는 유담보형인 강한 의미의 양도담보가 있다.

(2) 가등기담보 예를 들어 5000만원이 필요한 A가 금전소비대차계약에 의하여 B로부터 5000만원을 차용하면서 A가 변제기에 5000만원을 갚지 못할 때에는 시가 8000만원 상당의 A소유의 건물을 대신 주기로 미리 약속하고(대물변제의 예약), 그 예약에 따른 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 A소유의 건물 위에 B명으로 가등기를 하는 방법이 가등기담보이다. 이러한 가등기담보는 담보로써의 효용도를 갖추어 있고 또한 그 절차 등이 간편하다는 점에서 비전형담보 중에서 가장 많이 이용된다. 이러한 가등기담보는 다시 청산절차없이 소유권이 귀속되는 대물변제에 의한 소유권이전등기와 청산절차를 거쳐 담보권실행을 위한 수단으로써 소유권의 귀속되는 소유권이전등기의 경우로 나눌 수 있다.

III. 비전형담보에 대한 규제

구법 시대에도 이미 비전형담보가 이용되었으나 그 중에서 양도담보가 가장 많이 이용되었으며, 가등기담보는 저당권과 병용하는 것이 보통이었다. 그러나 이를 규율할 구민법의 규정이나 특별법이 없었으며, 학설과 판례에서는 목적물의 가치와 채권액과의 사이에 부당히 큰 불균형이 있는 때에 이를 폭리행위라고 하여 무효로 하였을 뿐이었다. 그리하여 현행민법에서는 제607조·608조를 신설하여 소비대차의 당사자가 차용액 및 이에 붙인 이자의 합산액을 넘는 물건에 관하여 담보의 목적으로 대물변제예약을 한 경우에는 그 예약은 무효라고 규정하게 되었다. 한편 판례는 이 경우의 대물변제 계약은 무효일지라도 당사자 사이에 정산절차를 밟아야 하는 「약한의미의 양도담보계약」을 맺은 취지로 보았다. 그런데 초기의 판례에서는 제607조·608조가 양도담보에는 적용되지 않는다고 하였지만(대판1962. 2. 22, 61다943), 후에는 이를 양도담보에는 적용하여 정산의무를 인정하였다(대판1965. 12. 21, 65다2027). 따라서 모든 비전형담보에 있어서 정산이 필요하게 되었다. 이와 같이 비전형담보에 정산이 요구됨으로써 채권자가 폭리를 취할 수 없게 되자 가등기담보를 하면서 미리 제소전 화해(민소법 제385조이하)조서를 작성하

여 두고 변제기가 되면 채권자가 이를 이용하여 즉시 가등기에 기한 본등기를 하는 새로운 폭리수단이 등장하였다. 이에 따라 가등기담보를 규제하는 특별법이 필요하게 되었으며, 드디어 「가등기담보 등에 관한 법률」(1983. 12. 30, 법률제3681호)이 제정·시행되었다. 이 법률은 가등기담보뿐만 아니라 양도담보·매도담보에도 적용되는 것으로 하고 있다. 즉 등기·등록에 의하여 공시되는 물건이나 재산을 목적으로 하는 비전형담보는 동법에 의하여 규율하게 되었다.

가등기담보법은 채무자를 보호하기 위하여 변제기가 경과하더라도 채권자는 곧바로 담보를 실행할 수 없고 변제기 후 일정한 청산기간(2월)이 경과한 후에 비로소 담보를 실행할 수 있게 하고 있다(동법 제3조 이하). 가등기담보법은 까다롭고 복잡한 청산절차를 가등기담보권자에게 부과하고 있으며, 또한 후순위권리자의 보호를 겨냥한 경매청구권, 청산금지금금지 등 다수의 제한·금지규정을 두고 있기 때문에 그 이용이 기피되고 있는 실정이다.

또한 이 법률은 소비대차에 기하지 않은 채권을 담보하기 위하여 재산을 이전하는 경우에는 적용되지 않을 뿐만 아니라, 소비대차에 기한 채권을 담보하기 위한 것일지라도 재산권의 가액이 채권액(차용액 및 이자의 합산액)에 미달하는 때에는 적용되지 않고, 재산권의 가액이 채권액을 초과할 지라도 재산권이 등기·등록에 의하여 공시되지 않는 때에는 적용되지 않으며, 재산권이 등기 등에 의하여 공시되는 것이더라도 가등기 또는 소유권이전등기가 되어 있지 않는 때에는 적용되지 않도록 되어 있다는 비판을 면치 못하고 있다.

제2항 가등기담보

1. 서 설

1. 의 의

가등기담보란 채권 특히 금전채권을 담보할 목적으로 채권자와 채무자(또는 제3자) 사이에서 채무자(또는 제3자) 소유의 부동산을 목적물로 하는 대물변제예약이나 매매예약 등을 하고, 동시에 장차 채무자가 채무를 이행하지 않는 경우에는 채권자가 그의 예약완결권을 행사하여 그 목적물의 소유권을 취득할 수 있도록, 미리 소유권이전청구권을 보전하기 위한 가등기를 하는 담보형식, 즉 소유권이전형 담보형식에 의한 물적 담보수단을 말한다(통설). 처음부터 권리의 이전이 없다는 점에서 일단 권리를 이전했다가 변제가 있으면 다시 권리를 반환받는 양도담보와 다르다.

2. 사회적 작용

가등기담보는 등록세 등의 설정비용이 저렴하고, 저당권에서의 요건의 엄격성, 실행절차의 번잡 등을 피할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 사채업자의 폭리행위에 악용되어 채무자가 부당한 손해를 입을 위험이 많으므로 가등기담보 등에 관한 법률을 제정하여 이를 규제하고 있다.

3. 가등기담보의 유형

- (1) 대물변제예약과 가등기 소비대차에 의하여 금전을 차용할 때 채무자가 채무불이행시에는 채무자(또는 제3자) 소유의 부동산소유권을 채권자에게 이전할 것을 예약하고, 이 예약에 기하여 채권자가 가지게 되는 장래의 소유권이전청구권을 보전하기 위하여 가등기를 하는 경우이다. 예를 들어 A가 소비대차에 의하여 B로부터 5000만원을 년리 2할 5푼으로 1년간 차용하면서 변제기에 원리금 6250만원을 변제하지 않은 때에는 A소유의 시가 1억원의 부동산 소유권을 B에게 이전할 것을 예약하고 이 예약에 기하여 채권자 B가 가지게 되는 장래의 소유권이전청구권을 보전하기 위하여 가등기를 하면 B의 채권이 담보된다.

- (2) 매매의 예약과 가등기 위의 예에서 A가 B로부터 금전을 차용 할때 A소유의 부동산을 채권자 B에게 매각하는 매매예약을 하고, B는 매매예약으로 가지게 되는 장래의 소유권이전 청구권을 보전하기 위하여 가등기를 하는 경우이다. A가 채무를 이행하지 못하면 B는 예약완결권을 행사하여 그 부동산에 관한 매매를 성립시켜 목적물의 소유권을 취득하고 대금반환채권과 A의 매매대금채권을 상계한다.
- (3) 매매와 가등기 매매계약을 하여도 위 2)와 같은 결과를 이룰 수 있다. 이 경우에 B는 매수인으로서 가지는 소유권이전청구권을 보전하기 위하여 가등기를 하게 된다.

II. 가등기담보의 성질

1. 담보물권성

가등기담보는 가담법에 의하여 인정되는 특수한 담보형태로서 제한물권형이 아니라 소유권이전형의 담보물권에 속한다. 그런데 가등기담보법은 가등기담보의 물권성에 관하여 명시하고 있지 않기 때문에 이를 담보물권으로 볼 것인가의 여부를 둘러싸고 견해가 대립한다.

- (1) 담보물권설(통설) 가등기담보권자의 경매청구권이나 우선변제권·별제권 등이 모두 담보물권 특유의 권리이고, 이러한 권리의 행사에 관하여 가등기담보권을 저당권으로 보고 있으며, 채권자의 청산의무도 담보물권의 가액취득권 내지 우선변제권이라는 점에서 가등기담보권은 특수저당권인 일종의 담보물권이라고 한다. 채권자가 가등기에 기한 본등기를 하면 그의 가등기담보권은 양도담보권에 흡수되는 것이 아니라 완전한 소유권으로 전환되므로 가등기담보는 일종의 담보물권이라고 함이 타당하다고 할 것이다.
- (2) 신탁적 소유권이전설 가등기담보도 양도담보에서와 같이 소유권의 신탁적 이전이 그 본질이며, 다만 양도담보와는 달리 그 소유권의 신탁적 양도가 정지조건의 성취 또는 예약완결권의 행사라고 하는 조건부로 행하여지는 것에 불과하다고 한다.
- (3) 검 토 신탁적소유권이전설은 양도담보의 경우에 적어도 대외적으로는 소유권이 채권자에게 이전되어 있다는 것을 전제로 한다. 그러나 가담법이 제정·시행된 현재에는 양도담보의 경우에 채권자에게 소유권이 이전되지 않는다(가등법 제4조2항). 가등기담보의 경우에 채권자는 담보권을 실행하여 우선변제를 받을 수 있다. 이러한 점에서 가등기담보권은 일종의 특수한 담보물권으로 보아야 할 것이다.

2. 담보물권의 통유성

가등기담보권은 일종의 담보물권이므로 담보물권 일반의 통유성을 가진다. 즉 가등기담보권에도 부종성·수반성·불가분성·물상대위성의 여러 성질이 있다.

III. 가등기담보의 설정 및 이전

1. 가등기담보권의 설정

가등기담보권은 가등기담보권 설정에 관한 물권적 합의와 가등기에 의하여 성립한다. 그리고 가등기담보권 설정에 관한 물권적 합의는 가등기담보계약에 포함되어 행하여지며 가등기담보계약은 일반적으로 담보목적의 대물변제예약 또는 매매예약과 함께 행하여진다(가담법 제2조 1호 참조).

(1) 가등기담보계약

- 1) 당 사 자 가등기담보권은 일반적으로 채권자(담보권자)와 채무자(담보설정자) 또는 제3자(물상보증인)사이에 낙성·불요식의 계약에 의하여 설정된다.

▶ 돌발 퀴즈

채무자가 아닌 제3자 명의의 담보가등기의 설정이 가능한가?

: ×

- 채권담보를 목적으로 가등기를 한 경우에는 원칙적으로 채권자와 가등기명의자가 동일인이 되어야 하지만, 채권자 아닌 제3자의 명의로 가등기를 한데 대하여 채권자와 채무자 및 제3자 사이에 합의가 있고, 제3자에게 그 채권이 실질적으로 귀속되었다고 볼 수 있는 특별한 사정이 있거나, 거래경위에 비추어 제3자의 가등기가 한낱 명목에 그치는 것이 아니라 그 제3자도 채무자로부터 유효하게 채권을 변제받을 수 있고 채무자도 채권자나 가등기명의자인 제3자 중 누구에게든 채무를 유효하게 변제할 수 있는 관계 즉, 채권자와 제3자가 불가분적 채권자의 관계에 있다고 볼 수 있는 경우에는 그 제3자 명의의 가등기도 유효하다고 볼 것이다.

2) 계약의 요건

(가) 채권을 담보하는 것일 것 피담보채권은 금전채권이 보통이지만, 금전채권 이외의 채권도 담보권실행시 금전채권으로 될 수 있으면 피담보채권이 될 수 있다. 그런데 가등기담보권에 의하여 담보되는 채권이 소비대차에 기한 것에 한정되는지가 문제된다. 이에 관하여 가담법이 이를 명시하고 있다는 점(동법 제1조·제2조1호), 나머지의 경우 중에는 채권자를 보호해야 할 때도 있다는 점(불법행위의 경우)등을 이유로 소비대차에 의한 채권만이 피담보채권으로 될 수 있다는 견해가 있다. 그러나 이와는 반대로 이를 긍정하면 그 외의 경우는 가담법이 제정되기 전처럼 해결하여야 되는 점에서 부당하고 또한 탈법행위를 할 위험이 있다는 것을 이유로 소비대차에 의하지 않는 채권도 피담보채권으로 될 수 있다는 견해가 통설이다. 한편 판례는 매매대금채권(대판2002. 12. 24, 2002다50484), 도급의 공사대금채권(대판1992. 4. 10, 91다45356), 불하대금채권(대판1995. 4. 21, 94다26080), 매매계약해제에 의한 대금반환채권(대판1996. 11. 29, 다31895)을 담보하기 위하여 가등기를 한때에는 가담법이 적용되지 않는다고 한다. 또한 일정범위에 속하는 불특정채권의 최고액이 정하여져 있으면 근가등기담보설정도 가능하다.

(나) 담보의 목적으로 체결되었을 것 가담법은 담보의 목적으로 대물변제예약이 체결되었을 것을 요구한다(동법 제1조·제2조1호). 그러나 담보의 목적으로 체결되었으면 충분하고 반드시 대물변제예약에 한정할 필요는 없다. 따라서 매매예약도 담보의 목적으로 체결된 때에는 가등기담보를 성립시킬 수 있다.

(다) 채무불이행이 일정한 권리를 이전할 것을 내용으로 하는 계약일 것 가등기담보계약은 채권담보를 위하여 소유권 기타의 권리를 설정 내지 이전할 것을 내용으로 하는 것이어야 한다. 이러한 계약은 그 명목내지 명칭여하를 묻지 않으므로 대물변제의 예약에 한하지 않으며 정지조건부 대물변제·매매예약은 물론, 경우에 따라서는 증여계약이나 증여예약도 가등기담보계약이 될 수 있을 것이다.

(라) 채권자의 계약상의 권리에 관하여 가등기(가등록)가 가능할 것 부동산등기법 제2조의 부동산에 관한 권리중 소유권·지상권·지역권·임차권 등만이 가등기담보의 목적으로 될 수 있다. 그밖에 임목·자동차·항공기·건설기계·선박의 소유권·공장재단·특허권 등 가등기·가등록할 수 있는 것은 부동산소유권 이외의 권리도 그 목적물이 될 수 있다. 다만 권리질권·저당권 및 전세권은 제외된다(가등기담보법 제18조).

(2) 가등기 (가등록) 가등기담보권도 공시방법으로써 가등기(또는 가등록)를 갖추어야 한다. 이 가등기를 가담법은 담보가등기라고 한다(동법제2조3호). 이 담보가등기는 소유권이전청구권을 보전하기 위한 가등기의 형태로 한다. 그런데 현행 부동산등기법상 가등기는 채권자만이 표시되고, 저당권설정등기와는 달리 피담보채권액·이자·변제기 등이 공시되지 않

아 보통의 가등기와 구별이 어려워 공시방법으로 매우 불완전하다. 가등기담보권자는 가등기인 채로 그 가등기의 순위를 가지고 우선변제권을 행사할 수 있으므로(가담법 제13조) 그 범위에서 가등기담보는 실체적 효력이 인정된다. 따라서 이 경우에는 담보가등기는 가등기이지만 마치 본등기와 같은 기능과 효력을 가진다.

2. 가등기담보권의 이전

가등기담보권도 일반적인 재산권과 같이 양도성 내지 이전성을 가지며 피담보채권과 더불어 양도할 수 있다(통설). 다만 가등기담보권은 담보권의 부종성으로 인하여 피담보채권과 함께 양도할 수 있을 뿐이고, 피담보채권과 분리하여 양도할 수 없다(통설). 가등기담보권의 양도에는 양도인과 양수인 사이의 물권적 합의와 등기가 있어야 하며(제186조) 등기는 기존의 등기에 권리이전의 부기등기의 형식을 취하게 된다. 피담보채권의 양도는 채권양도에 관한 규정이 적용된다(제449조~제452조). 따라서 채무자 기타 제3자에 대항하기 위해서는 양도인의 채무자에게 통지하거나 채무자가 승낙하여야 하고(제450조 1항), 이러한 통지나 승낙은 확정일자가 있는 증서에 의하지 않으면 채무자 이외의 제3자에게 대항하지 못한다(제450조 2항).

IV. 가등기담보권의 효력

1. 일반적 효력

(1) 효력이 미치는 범위

1) 피담보채권의 범위 가등기담보권의 피담보채권의 범위에 관하여는 저당권의 피담보채권의 범위에 관한 규정이 적용된다(가등기담보법 제3조·제13조). 따라서 귀속정산의 경우에는 채무자 등예의 통지 당시, 경매의 경우에는 경매개시시의 원본·이자·위약금·채무불이행으로 인한 손해배상·담보권의 실행비용 등이 피담보채권에 포함된다. 판례는 「가등기의 원인 증서인 매매예약서상의 매매대금은 가등기절차의 편의상 기재하는 것에 불과하고 가등기의 피담보채권이 그 한도로 제한되는 것이 아니며 피담보채권의 범위는 당사자의 약정내용에 따라 결정된다」고 한다(대판 1996. 12. 23, 96다 39387·39394). 또한 판례는 가등기담보채권자가 가등기담보권을 실행하기 이전에 그의 계약상의 권리를 보전하기 위하여 가등기담보채무자의 제3자에 대한 선순위 가등기담보채무를 대위변제하여 구상권이 발생하였다면 특별한 사정이 없는 한 이 구상권도 가등기담보계약에 의하여 담보된다고 보는 것이 상당하다고 한다(대판 2002. 6. 11, 99다41657).

2) 목적물의 범위 가등기담보권의 효력에 미치는 목적물의 범위는 설정계약으로 정하여지나 부합물·종물·과실 등에도 그 효력이 미치며(제358조·제359조), 그에 관한 이론이 유추 적용된다.

3) 물상대위 가등기담보권도 일종의 담보물권이므로 저당권에 있어서와 마찬가지로 물상대위성을 가진다고 할 것이다(제370조·제342조).

(2) 대내적 효력 가등기담보권이 설정되어도 목적물의 소유권은 그 가등기담보권이 실행될 때 까지는 가등기담보권설정자에게 귀속한다. 따라서 가등기담보권설정자는 목적물을 자유로이 점유·이용할 수 있으며, 제3자를 위하여 용익물권을 설정할 수 있다. 설정자가 목적물의 담보가치를 감소시킨 때에는 가등기 담보권자는 피담보채권을 한도로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 당사자 사이에 대물변제를 예약하고 소유권이전청구권을 보전하기 위하여 등기가 활용된다.
- ② 가등기담보는 담보권의 일종이다.
- ③ 가등기담보에는 저당권의 물상대위에 관한 규정이 유추적용된다.
- ④ 가등기담보권자가 담보권을 실행하여 목적부동산의 소유권을 취득하기 위해서는 청산금을 지급하여야 한다.
- ⑤ 가등기담보권자는 담보물에 대한 소유권을 취득할 수 는 있으나 경매를 청구할 수는 없다.
- ⑤ 가등기담보권자는 그 선택에 따라 소유권취득형식의 담보권실행을 하거나, 목적부동산의 경매를 청구할 수 있다. 이러한 경우에 경매에 관하여는 담보가등기권리를 저당권으로 본다.

2. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 가등기담보 설정계약 당시에 피담보채권은 금전채권으로 존재하여야 한다.
- ② 가등기담보권은 변제기 도래 이전에 피담보채권과 분리하여 양도·이전할 수 있다.
- ③ 가등기담보권설정자는 담보권의 실행 전까지는 담보목적물의 점유·사용뿐만 아니라, 제3자를 위한 용익권을 설정할 수도 있다.
- ④ 담보가등기에 있어서는 피담보채권액·이자·변제기 등이 공개되므로 공시방법으로 충분한 기능을 수행할 수 있다.
- ⑤ 담보가등기의 설정 이후에 대항력 있는 임차권을 취득한 자는 보증금반환을 이유로 동시이행항변권을 행사할 수 없다.
- ③. 가등기담보권도 일반 담보권과 동일한 성질을 가진다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 근가등기담보의 설정은 가능하다.
- ② 대물변제의 예약뿐만 아니라 채권담보를 목적으로 하는 매매의 예약에 의해서도 가등기담보의 설정이 가능하다.
- ③ 가등기담보권은 특수한 저당권으로서의 효력이 인정되며, 담보물권의 특성인 부종성·수반성·불가분성·물상대위성이 인정된다.
- ④ 담보가등기가 경료된 부동산에 대하여 경매 등이 행하여진 때에는 담보가등기권리는 그 부동산의 매각에 의하여 소멸한다.
- ⑤ 금전소비대차계약의 체결과 동시에 가등기를 하여야 이 법이 적용된다.
- ⑤. 금전소비대차계약과 동시에 가등기를 하여야 하는 것은 아니다.

♣ 학습정리

1. 민법은 법정담보물권으로 유치권, 약정담보물권으로 질권과 저당권을 규정하고 있으나, 이러한 담보물권만으로는 거래계의 요청에 충분히 대처할 수 없다. 따라서 담보권설정자가 자기의 동산을 점유·이용하면서 담보로 제공할 수 있는 새로운 유형의 변칙담보제도인 비전형 담보가 마련되었다.
2. 가등기담보는 채권 특히 금전채권을 담보할 목적으로 미리 소유권이전청구권을 보전하기 위한 가등기를 하는 담보형식, 즉 소유권이전형 담보형식에 의한 물적담보수단을 말한다. 이러한 가등기담보는 등록세 등의 설정비용이 저렴하고, 저당권에서의 요건의 엄격성, 실행절차의 번잡 등을 피할 수 있다는 이점이 있고, 처음부터 권리의 이전이 없다는 점에서 일단 권리를 이전했다가 변제가 있으면 다시 권리를 반환받는 양도담보와는 상이하다.
3. 가등기담보권의 피담보채권의 범위에 관하여는 저당권의 피담보채권의 범위에 관한 규정이 적용된다. 따라서 귀속정산의 경우에는 채무자 등예의 통지시 및 경매의 경우에는 경매개시시의 원본·이자·위약금·채무불이행으로 인한 손해배상·담보권의 실행비용 등이 피담보채권에 포함된다.

제41강 가등기담보 (2), 동산·채권담보법

♣ 학습목표

1. 가등기담보권의 실행과 배당참가에 대하여 정리할 수 있다.
2. 가등기담보권의 소멸에 대하여 설명할 수 있다.
3. 동산·채권 등의 담보에 관한 법률의 주요 내용을 정리할 수 있다.

♣ 학습내용

- 가등기담보권의 실행
- 경매에 있어서 가등기담보권자의 배당참가
- 가등기담보권의 소멸
- 동산·채권 등의 담보에 관한 법률의 주요 내용

♣ 사전 테스트

1. 가등기담보권의 실행의 통지는 피담보채권의 변제기 이전에도 가능하다.
⇒ × : 가등기담보권의 실행의 통지는 피담보채권의 변제기 이후에는 언제라도 가능하다(가등기담보법 제3조 1항).
2. 가등기담보권자가 실행통지를 하고 청산기간이 경과한 후 청산금을 지급하면 소유권을 취득한다.
⇒ × : 가등기담보권자가 실행통지를 하고 청산기간이 경과하여 청산금을 지급한 후 담보가등기에 기하여 본등기를 함으로써 목적부동산에 대한 소유권을 취득하게 된다. 이 때 청산금의 지급과 소유권의 이전등기 및 목적물의 인도는 동시이행의 관계에 있다.
3. 양도담보권자가 담보물을 점유하면서 그 인도를 거부하는 제3자에 대하여 손해배상을 구할 수 없다.
⇒ ○ : 판례는 양도담보권자가 담보권의 실행을 위하여 담보채무자가 아닌 제3자에 대하여도 담보물의 인도를 구할 수 있고, 인도를 거부하는 경우에는 담보권실행이 방해된 것을 이유로 하는 손해배상을 구할 수는 있다. 하지만 그러한 경우에도 양도담보권자에게는 목적부동산에 대한 사용·수익권이 없으므로 임대료 상당의 손해배상을 구할 수는 없다고 한다.

♣ 강의교안

2. 가등기담보권의 실행

가등기담보법은 가등기담보권자가 가등기담보권을 실행하여 우선변제를 받는 방법으로 (i) 가등기담보권자가 목적부동산의 소유권을 취득하는 방법(권리취득에의한실행)과 (ii) 가등기담보권자가 경매를 신청하여 그 대가로부터 변제를 받는 방법(경매에의한 실행)을 인정하고 있다.

(1) 권리취득에 의한 실행

채권자가 가등기담보권에 기하여 소유권을 취득함으로써 우선변제를 받는 방법을 권리취득에 의한 실행이라고 한다. 판례는 가등기담보권의 사적 실행에 있어서 채권자가 청산금의 지급 이전에 본등기와 담보목적물의 인도를 받을 수 있다거나 청산기간이나 동시이행관계를 인정하지 아니하는 '처분청산형'의 담보권 실행은 가등기담보등에관한법률상 허용되지 아니한다고 한다(대판 2002. 12. 10, 2002다42001). 이러한 실행은 청산절차에 의한다. 즉 평가액을 통지하고 청산기간을 거쳐서 청산금을 지급하고 소유권을 취득하는 단계를 거치게 된다.

1) 실행의 통지

가) 통지사항은 청산금의 평가액이다(가등기담보법제3조1항1문). 채무자가 변제기에 변제를 하지 않는 경우에는 가등기담보권자는 그 당시의 목적부동산의 평가액 및 민법 제360조에 규정된 채권액을 통지하여야 한다(가등기담보법 제3조 2항 전단). 이 경우 목적부동산이 2 이상인 때에는 각 부동산의 소유권이전에 의하여 소멸시키려고 하는 채권과 그 비용을 명시하여야 한다(가등기담보법 제3조2항2문). 목적부동산의 평가액이 채권액에 미달하여 청산금이 없다고 인정되는 때에는 그 뜻을 통지하여야 한다(가등기담보법제3조1항2문). 다만 예약 당시의 부동산의 가액이 채권액에 미달하면 가등기담보법이 적용되지 않으므로 청산의 통지를 할 필요가 없다.

나) 통지의 상대방은 채무자·물상보증인 및 가등기담보의 소유권을 취득한 제3자이다(가등기담보법 제2조 2항). 통지는 이들 모두에 대하여 하여야 하며, 그 전부 또는 일부에 대하여 통지를 하지 않으면 청산기간이 진행할 수 없게 되고, 따라서 가등기담보권자는 그 후 청산금을 지급하였더라도 가등기에 기한 본등기를 청구할 수 없으며, 설령 편법으로 본등기를 마쳤다고 하더라도 소유권을 취득할 수 없다(대판2002. 4. 23, 2001다81856).

다) 통지의 시기는 피담보채권의 변제기 이후이면 언제라도 상관없다(가등기담보법 제3조 1항).

라) 통지의 방법에는 제한이 없다. 이러한 통지가 채무자등에게 도달한 때에는 채권자는 지체 없이 후순위권리자 또는 담보가등기 후에 등기한 제3자에게 그 통지의 사실, 내용 및 도달일 또는 채권액을 통지하여야 한다(가등기담보법 제6조1·2항).

담보부동산의 평가액이 피담보채권액에 미달하는 경우에는 청산금이 있을 수 없으므로 귀속정산의 통지방법으로 부동산의 평가액 및 채권액을 구체적으로 언급할 필요 없이 그 미달을 이유로 채무자에 대하여 담보권의 실행으로 그 부동산을 확정적으로 채권자의 소유로 귀속시킨다는 뜻을 알리는 것으로 족하다(대판 2001. 8. 24, 2000다15661).

2) 청산기간의 경과 위 실행통지가 채무자 등에게 도달한 날로부터 2개월이 경과하여도 채무자의 변제가 없는 경우에는 가등기담보권자는 청산에 들어가게 된다(가등기담보법 제3조 1항).

3) 청 산

가) 청산의무 목적부동산의 가액이 채권액을 넘는 경우에는 가등기담보권자는 그 차액을 청산금으로서 채무자에게 지급하여야한다(가등기담보법제4조1항1문). 청산의무에 관한 가등기담보법 제4조 제1항에 위반하는 특약으로서 채무자 등에 불리한 것은 무효이다(가등기담보법 제4조 4항 본문). 예컨대 청산금을 지급하지 않기로 한 특약은 무효이다. 그러나 청산기간이 경

과한 후에 행하여진 특약으로서 제3자의 권리를 해하지 않는 것은 예외이다(가등기담보법 제4조 4항 단서). 청산의무의 발생시기는 청산기간이 만료한 때이다(가등기담보법 제3조 1항 1문).

나) 청산방법 가등기담보법이 있기 전에는 담보권자가 목적물의 소유권을 취득하면서 청산금을 지급하는 귀속청산과 목적물을 제3자에게 처분하여 그 대금으로부터 변제를 받고 나머지를 청산금으로 지급하는 처분청산의 두 청산방법이 있었다. 그런데 현재에도 이 두 청산방법이 인정되는가에 관하여 학설은 (i) 가등기담보법상 처분청산은 부정되고 귀속청산만 인정된다는 견해와 (ii) 귀속청산이 원칙이나 처분청산의 약정은 유효하다는 견해로 나뉘고 있다. 판례는 처음에는 양 청산방법 중 선택적으로 행사할 수 있다고 하였으나(대판1988. 12. 20, 87다카2685), 그 후에는 처분청산방법은 가등기 담보법상 허용될 수 없다고 한다(대판2002. 12. 10, 2002다42001). 채권자는 청산금의 지급과 상환으로 본등기 및 담보부동산의 명도를 청구할 수 있으므로(동법 제4조 3항) 처분청산방법은 허용되지 않는다고 할 것이다.

다) 청산금 청산금은 실행통지 당시의 목적부동산의 가액에서 그 채권액을 공제한 금액이다. 청산금은 채무자·물상보증인 및 제3취득자에게 지급하여야 한다(가등기담보법 제4조1항 전문). 채권자는 실행통지에서 명시한 청산금의 가액에 관하여 다툴 수 없다(가등기담보법 제9조). 그리고 담보부동산 위에 선순위담보권 등의 권리가 있을 때에는 그 채권액을 계산함에 있어서 그 담보된 채권액을 포함한다(가등기담보법 제4조 1항 후문).

라) 청산금청구권자 설정자 또는 제3취득자와 후순위권리자가 청산금 청구권자이다(가등기담보법 제4조 1항·제5조 1항). 그 밖에 담보가등기 후에 성립한 대항력있는 임차권자도 청산금의 범위내에서 보증금의 반환을 청구할 수 있다(가등기담보법 제5조 5항).

마) 청산금의 지급시기 청산금은 청산기간이 만료된 때에 지급된다. 따라서 청산기간이 경과하기 전에 채권자가 채무자에게 청산금을 지급하거나 채무자가 청산금에 관한 권리를 제3자에게 양도 기타의 처분을 한 때에는 이로써 후순위권리자에게 대항하지 못한다(가등기담보법 제7조).

바) 청산금의 공탁 청산금채권이 압류 또는 가압류된 경우에 채권자는 청산기간이 경과한 후 이에 해당하는 청산금을 채무이행지를 관할하는 지방법원 또는 지원에 공탁하여 그 범위에서 채무를 면할 수 있다(가등기담보법 제8조 1항). 이러한 공탁이 있는 경우에는 채무자 등의 공탁금출급청구권이 압류 또는 가압류된 것으로 본다(가등기담보법 제8조 2항). 채권자가 청산금을 공탁한 경우에는 채무자 등과 압류채권자 또는 가압류채권자에게 지체없이 공탁의 통지를 하여야 한다(가등기담보법 제8조 4항).

4) 소유권의 취득 가등기담보권자가 채권자는 실행통지를 하고 청산기간이 경과한 후 청산금을 지급한 후 담보가등기에 기하여 본등기를 함으로써 목적부동산에 대한 소유권을 취득하게 된다. 이 때 청산금의 지급과 소유권의 이전등기 및 목적물의 인도는 동시이행의 관계에 있다(가등기담보법 제4조3항). 그러나 담보물의 가액이 채권액을 초과하고 있지 않아서 청산금이 없는 때에는 가등기담보권자는 청산기간이 경과한 후 곧바로 가등기에 기한 본등기를 실행할 수 있다(가등기담보법 제4조 2항). 가등기권리자가 청산금을 지급하지 않고 소유권이전의 본등기를 한 경우에 가등기권리자의 소유권취득 여부에 관하여 학설이 대립된다. 즉 (i) 신탁적 소유권이전설에 의하면 본등기에 의해 소유권은 채무자로부터 채권자에게 이전되어 채권자는 완전한 소유권을 취득하지만 대내적으로는 청산의무를 지게 된다. 그리고 (ii) 담보물권설에 의하면 청산기간이 경과한 후 청산금을 지급하지 않으면 비록 본등기를 하였더라도 그 본등기는 무효임이 원칙이며, 대외적으로 선의의 제3자에게 전매하여 이전등기를 경료한 경우에 등기의 공신력을 부분적으로 인정하는 가등기담보법 제11조 단서에 의하여 그 제3자는 소유권을 취득하게 된다. (iii) 판례는 가등기담보법의 제정 후에도 「제소전화해에 따라 가등기에 기한 본등기를 마친 경우라면 그 소유권이전등기는 정산절차를 예정하고 있는 약한 의미의 양도담보로 보아야 할 것」(대판 1992. 5. 26, 91다28528)이라고 하여 종래와 같이 신탁적 소유권이전설을 취하였으나, 최근 판례는 가등기담보등에 관한 법률

제3조·제4조에 위반하여 이루어진 본등기는 무효라고 하여 무효설의 입장을 취하고 있다(대판 2002. 12. 10, 2002다4001). 다만 가등기담보법 제3조·제4조가 정한 절차에 따라 청산금의 평가액을 채무자들에게 통지한 후 채무자에게 정당한 청산금을 지급하거나, 지급할 청산금이 없는 경우에는 채무자가 통지를 받은 날로부터 2월의 청산기간이 경과하면 무효였던 본등기는 실제적 법률관계에 부활하는 유효한 등기가 될 수 있다고 한다(2002. 6. 11, 99다41657).

5) 법정지상권 토지 및 그 지상의 건물이 동일한 소유자에게 속하는 경우에 그 토지 또는 건물 중 어느 하나를 목적으로 한 가등기담보권이 설정되어 그것이 실행된 때에는 건물을 위하여 지상권이 설정된 것으로 본다. 이 경우에 그 존속기간 및 지료는 당사자의 청구에 의하여 법원이 정한다(가등기담보법 제10조).

6) 채무자 등의 가등기말소청구권 가등기담보법은 제11조에서 양도담보의 경우에 채무자 등이 일정시기까지 채무를 변제하고 소유권이전등기의 말소를 청구할 수 있다고 규정한다. 그러나 가등기담보에 관하여는 규정하지 않고 있어서 그 해석이 문제되고 있다. 양도담보에 관한 가등기담보법 제11조는 원칙적으로 가등기담보에 유추적용되어야 할 것이다. 따라서 가등기담보계약의 당사자인 채무자나 물상보증인 또는 이들로부터 담보가등기 후에 소유권을 취득한 제3취득자는 채권자로부터 청산금을 지급 받을 때까지는 채권액에 상당하는 금액을 채권자에게 지급하고 그 채권담보의 목적으로 경료된 가등기의 말소를 청구할 수 있다고 하여야 한다(가등기담보법 제11조 본문의 유추적용). 판례는 채권자가 채권담보의 목적으로 부동산에 가등기를 경료하였다가 그 후 변제기까지 변제를 받지 못하게 되어 위 가등기에 기한 소유권이전의 본등기를 경료한 경우에도 당사자들이 달리 특약을 하지 않는 한 그 본등기도 채권담보의 목적으로 경료된 것으로서 당사자 사이의 청산절차를 예정하고 있는 이른바 「약한 의미의 양도담보」가 된 것으로 보아야 할 것이며, 이러한 경우에 채무자의 변제기가 도과된 후라고 하더라도 채권자가 담보권을 실행하여 청산절차를 마치기 전에는 채무자는 언제든지 채무를 변제하고 채권자에게 가등기 및 가등기에 기한 본등기의 말소를 청구할 수 있다고 한다(대판 1993. 6. 23, 93다7334). 그러나 채무의 변제기로부터 10년이 경과한 때, 선의의 제3자가 소유권을 취득한 때에는 채무자가 아직 청산금을 받지 못하고 있더라도 가등기의 말소를 청구할 수 없다는(가등기담보법 제11조) 단서도 유추적용할 수 있는지가 문제된다.

이에 관하여 학설은 (i) 그 단서 전부의 유추적용을 인정하는 견해와 (ii) 변제기가 경과한 때로부터 10년이 경과한 경우에 대하여는 유추적용을 부인하고 선의의 제3자가 소유권을 취득한 때에 관한 것만 유추적용하자는 견해로 나뉜다. 생각컨대 가등기담보법 제11조 단서는 양도담보에 관한 것으로 가등기담보에는 적절하지 않으나, 양도담보와의 균형상 그리고 거래의 안전을 보호하기 위해서는 이 경우에도 가등기담보법 제11조 단서를 유추적용하여야 할 것이다.

(2) 경매에 의한 실행

가등기담보권자는 권리취득에 의한 실행을 하지 아니하고 목적부동산의 경매를 청구하여 그의 권리를 실행할 수도 있다(가등기담보법 제12조 1항 전단). 이 경우에 경매에 관하여는 가등기담보권을 저당권으로 본다(가등기담보법 제12조 1항 후단). 경매가 개시되면 가등기담보권자는 가등기인 채로 그 가등기의 순위를 가지고 우선변제권을 행사할 수 있다. 즉 가등기담보권자는 그 순위에 관하여 그 담보가등기가 경료한 때에 저당권이 설정된 것으로 보아 그 순위에 따라 다른 채권액보다 우선변제를 받는다(가등기담보법 제12조·제15조).

3. 경매에 있어서 가등기담보권자의 배당참가

(1) 배당참가 가등기담보의 목적물에 대하여 제3자에 의한 경매가 진행되는 경우에 가등기담보권자는 그 배당에 참가하여 우선변제를 받을 수 있다(가등기담보법 제13조 전단).

이 경우에 그 순위에 관하여는 그 담보가등기 권리를 저당권으로 보고, 그 담보가등기를 한 때에는 그 저당권의 설정등기가 행하여진 것으로 본다(가등기담보법 제13조 후단). 가등기담보권자는 그 가등기의 담보가 등기인 사실과 채권액(이자 기타 부수적 채권포함)을 신고하여야 한다.

- (2) 후순위담보권자의 경매와 가등기담보권자의 지위 후순위담보권자가 경매를 청구한 경우에(가등기담보법 제12조 2항 참조) 그 전에 이미 착수된 가등기담보권자에 의한 「권리취득에 의한 실행」과의 관계에 있어서 어느 것을 우선시키느냐가 문제된다. 후순위권리자에 의한 경매신청이 가등기담보권자가 청산금을 지급하기 전에 행하여진 때에는 가등기담보권자는 그 가등기에 기한 본등기를 청구할 수 없다(가등기담보법 제14조). 따라서 가등기담보권자는 그 후순위권리자의 신청으로 개시된 경매절차에서 우선변제를 받을 수 있을 뿐이다.
- (3) 일반채권자로서 변제받는 효력 가등기담보권자가 위의 방법으로 담보권을 실행하였으나, 피담보채권을 완제받지 못한 경우에는 그 잔여채권으로 다시 채무자의 일반재산에 대하여 단순한 채권자로서 스스로 강제집행하거나 타인의 집행에 참가할 수 있다.

(4) 용익권과의 관계

가등기 전에 제3자가 취득한 대항력 있는 용익권은 가등기담보의 실행으로 아무런 영향도 받지 않는다. 그러나 가등기 후에 취득한 제3자의 용익권이나 소유권의 용익권은 가등기담보의 실행으로 모두 소멸한다. 제3취득자를 보호하기 위하여 가등기담보권의 실행의 통지를 받을 권리(가등기담보법 제3조 1항), 채권자에게 그 채무액을 지급하고 담보가등기의 말소를 청구할 수 있는 권리(가등기담보법 제11조), 경매인이 될 수 있는 권리(가등기담보법 제12조 1항 후단, 민법 제363조 1항), 경락대금으로부터 지출비용의 우선상환을 받을 권리(가등기담보법 제12조1항 후단, 민법 제367조), 매도인에게 하자담보책임을 물을 수 있는 권리(민법 제576조) 등이 인정된다.

(5) 가등기담보권자의 물권적 청구권

가등기담보권자에게도 담보부동산에 대한 방해를 배제할 수 있는 물권적 청구권이 그 담보권의 성질상 필요한 범위에서 인정되어야 한다. 저당권자의 방해배제청구권에 관한 민법규정이 가등기담보권에 유추적용되어야 할 것이다. 판례는 가등기담보권자의 물권적 청구권을 부분적으로 인정하고 있다.

▶ 돌발 퀴즈

양도담보권자가 담보물을 점유하면서 그 인도를 거부하는 제3자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있는가?

: ×

- 양도담보권자는 담보권의 실행을 위하여 담보채무자가 아닌 제3자에 대하여도 담보물의 인도를 구할 수 있고, 인도를 거부하는 경우에는 담보권실행이 방해된 것을 이유로 하는 손해배상을 구할 수는 있으나, 그러한 경우에도 양도담보권자에게는 목적부동산에 대한 사용·수익권이 없으므로 임료 상당의 손해배상을 구할 수는 없다

V. 가등기담보권의 소멸

(1) 채무변제에 의한 소멸

가등기담보권은 채권의 담보를 위한 것이므로 피담보채권이 변제되면 당연히 소멸하여 담보권설정자는 담보의 목적으로 경료된 가등기의 말소를 청구할 수 있다(대판 1997. 10. 24, 97다29097).

(2) 본등기에 의한 소멸

가등기담보권의 실행에 의하여 담보권자가 채무자 등에게 청산금을 지급하고 가등기에 기하여 본등기를 하게되면 가등기담보권은 당연히 소멸한다. 가등기에 기한 본등기의 비용은 담보권자가 부담하여야 한다(대판 1987. 6. 9, 86다카2435).

(3) 경매에 의한 소멸 담보가등기가 경료된 부동산에 대하여 경매가 행하여진 경우에는, 그 부동산의 매각으로 가등기담보권은 소멸한다(가등기담보법 제15조). 따라서 경락인이 경락대금을 모두 지급함으로써 소유권을 취득하였다면 담보가등기권리는 소멸된 것으로 본다.

(4) 목적물의 멸실 등

가등기담보권은 물건에 대한 권리이므로 담보의 목적물이 멸실되면 원칙적으로 소멸한다. 또한 가등기담보권은 채권을 위한 권리이므로 단독으로 소멸시효에 걸리지 않으나 피담보채권과 운명을 같이하기 때문에 피담보채권의 소멸시효에 의하여 가등기담보는 소멸한다.

(5) 담보계약의 해제

피담보채무가 존속하더라도 가등기담보권자가 당해 부동산에 대한 담보계약을 해제하고 가등기를 말소하면 가등기담보권은 소멸한다.

(6) 소유권이전등기가 된 뒤 10년이 경과하거나 선의의 제3자가 부동산의 소유권을 취득한 때(가등기담보법 제11조단서의 유추적용)에도 가등기담보권은 소멸한다.

※ 동산·채권 등의 담보에 관한 법률

1. 목 적

「동산·채권 등의 담보에 관한 법률」(2010. 6. 10. 제정 법률 제10366호)은 동산·채권·지적재산권을 목적으로 하는 담보권과 그 등기 또는 등록에 관한 사항을 규정하여 자금조달을 원활하게 하고 거래의 안전을 도모하며 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 하고 있다(동법 제1조).

2. 특 징

- (1) 동법은 동산이나 채권에 관한 새로운 담보제도를 도입하면서 기존에 동산담보로 이용되고 있는 양도담보나 소유권유보부매매와 달리 그 법적 성질을 담보권으로 구성하였고,
- (2) 양도담보 등 그 명칭을 불문하고 담보약정을 한 경우에는 이 법에 따른 등기를 할 수 있고, 담보등기부는 동산담보등기부와 채권담보등기부로 구분되어 있으며,
- (3) 동산 및 채권에 관한 새로운 담보제도를 도입하면서 기존의 담보제도인 질권, 양도담보, 소유권유보부매매 등의 제도를 폐지하지 않음으로써 양 제도를 병존시키고 있고,
- (4) 지적재산권은 개별 법률에서 지적재산권을 담보로 제공하는 제도를 갖고 있으므로 등기대신 기존처럼 지적재산권에 대한 담보권은 해당 등록원부에 등록을 하도록 하고, 개별 법률에 없는 복수의 지적재산권을 공동담보로 제공하거나 근담보로 설정할 수 있는 특례를 도입하며,

- (5) 동산이나 채권에 관한 담보등기부는 부동산등기와 달리 물적편성주의가 아닌 인적편성주의를 채택하고, 담보등기제도의 공시효과를 보강하고 담보등기를 신뢰한 담보권자를 보호하기 위하여 담보권설정자에게 담보목적물에 대한 명시적무를 부여하고 있고,
- (6) 등기의 효력은 동산의 경우는 성립요건으로, 채권의 경우는 대항요건으로 하였다.

3. 주요내용

제3조(동산담보권의 목적물)

- ① 법인 또는 「상업등기법」에 따라 상호등기를 한 사람(이하 "법인 등"이라 한다)이 담보약정에 따라 동산을 담보로 제공하는 경우에는 담보등기를 할 수 있다.
- ② 여러 개의 동산(장래에 취득할 동산을 포함한다)이더라도 목적물의 종류, 보관장소, 수량을 정하거나 그 밖에 이와 유사한 방법으로 특정할 수 있는 경우에는 이를 목적으로 담보등기를 할 수 있다.
- ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 목적으로 하여 담보등기를 할 수 없다.
1. 「선박등기법」에 따라 등기된 선박, 「자동차 등 특정동산 저당법」에 따라 등록된 건설기계·자동차·항공기·소형선박, 「공장 및 광업재단 저당법」에 따라 등기된 기업재산, 그 밖에 다른 법률에 따라 등기되거나 등록된 동산
 2. 화물상환증, 선하증권, 창고증권이 작성된 동산
 3. 무기명채권증서 등 대통령령으로 정하는 증권

- (4) 동산 및 채권담보권을 이용할 수 있는 자는 법인 또는 「상업등기법」에 따라 상호등기를 한 사람으로 한정하고(동법 제3조 제1항),
- (2) 여러 개의 동산(장래에 취득할 동산을 포함)이라도 이를 특정할 수 있으면 담보등기를 할 수 있도록 하며(동법 제3조 제2항),
- (3) 「선박등기법」에 따라 등기된 선박, 「자동차 등 특정동산 저당법」에 따라 등록된 건설기계·자동차·항공기 등 다른 법률에 따라 등기되거나 등록된 동산, 화물상환증, 선하증권, 창고증권이 작성된 동산, 무기명채권증서 등 대통령령으로 정하는 증권은 담보등기를 할 수 없고(동법 제3조 제3항),

제14조(물상대위)

동산담보권은 담보목적물의 매각, 임대, 멸실, 훼손 또는 공용징수 등으로 인하여 담보권설정자가 받을 금전이나 그 밖의 물건에 대하여도 행사할 수 있다. 이 경우 그 지급 또는 인도 전에 압류하여야 한다.

- (4) 동산담보권에 대해서는 민법상 질권의 물상대위와 달리 매각, 임대 등의 경우에도 물상대위권을 인정하고 있으며(동법 제14조),

제21조(동산담보권의 실행방법)

- ① 담보권자는 자기의 채권을 변제받기 위하여 담보목적물의 경매를 청구할 수 있다.
- ② 정당한 이유가 있는 경우 담보권자는 담보목적물으로써 직접 변제에 충당하거나 담보목적물을 매각하여 그 대금을 변제에 충당할 수 있다. 다만, 선순위권리자(담보등기부에 등기되어 있거나 담보권자가 알고 있는 경우로 한정한다)가 있는 경우에는 그의 동의를 받아야 한다.

제22조(담보권 실행을 위한 경매절차)

- ① 제21조제1항에 따른 경매절차는 「민사집행법」 제264조, 제271조 및 제272조를 준용한다.

- (5) 동산담보권의 실행방법으로 경매 외에 사적실행의 방법으로 담보권자가 담보목적물을 직접 변제에 충당하는 귀속정산과 이를 매각하여 그 대금을 변제에 충당하는 처분정산을 인정하고 있고(동법 제21조),
- (6) 공동담보의 매각대금을 동시에 배당하는 경우에는 각 담보목적물의 매각대금에 비례하여 그 채권의 분담을 정하도록 하고 있으며(동법 제29조),
- (7) 이해관계인은 담보권자가 위법하게 동산담보권을 실행하는 경우에 법원에 이의를 신청할 수 있도록 하고(동법 제30조),

제31조(동산담보권 실행에 관한 약정)

- ① 담보권자와 담보권설정자는 이 법에서 정한 실행절차와 다른 내용의 약정을 할 수 있다. 다만, 제23조제1항에 따른 통지가 없거나 통지 후 1개월이 지나지 아니한 경우에도 통지 없이 담보권자가 담보목적물을 처분하거나 직접 변제에 충당하기로 하는 약정은 효력이 없다.
- ② 제1항 본문의 약정에 의하여 이해관계인의 권리를 침해하지 못한다.

- (8) 민법 제339조는 유질계약을 금지하고 있으나 동법에서는 담보권자와 담보권설정자는 이 법에 정한 실행절차와 다른 내용의 약정을 할 수 있도록 하고 있어 사실상 유질계약을 할 수 있으며(동법 제31조),

제32조(담보목적물의 선의취득) 이 법에 따라 동산담보권이 설정된 담보목적물의 소유권·질권을 취득하는 경우에는 「민법」 제249조부터 제251조까지의 규정을 준용한다.

- (9) 동산담보권이 설정된 담보목적물에 대해서도 선의취득을 인정하고 있고(동법 제32조),

제3장 채권담보권

제34조(채권담보권의 목적)

- ① 법인 등이 담보약정에 따라 금전의 지급을 목적으로 하는 지명채권을 담보로 제공하는 경우에는 담보등기를 할 수 있다.
- ② 여러 개의 채권(채무자가 특정되었는지 여부를 묻지 아니하고 장래에 발생할 채권을 포함한다)이더라도 채권의 종류, 발생 원인, 발생 연월일을 정하거나 그 밖에 이와 유사한 방법으로 특정할 수 있는 경우에는 이를 목적으로 하여 담보등기를 할 수 있다.

제35조(담보등기의 효력)

- ① 약정에 따른 채권담보권의 득실변경은 담보등기부에 등기한 때에 지명채권의 채무자(이하 "제3채무자"라 한다) 외의 제3자에게 대항할 수 있다.
- ② 담보권자 또는 담보권설정자(채권담보권 양도의 경우에는 그 양도인 또는 양수인을 말한다)는 제3채무자에게 제52조의 등기사항증명서를 건네주는 방법으로 그 사실을 통지하거나 제3채무자가 이를 승낙하지 아니하면 제3채무자에게 대항하지 못한다.

- ③ 동일한 채권에 관하여 담보등기부의 등기와 「민법」 제349조 또는 제450조제2항에 따른 통지 또는 승낙이 있는 경우에 담보권자 또는 담보의 목적인 채권의 양수인은 법률에 다른 규정이 없으면 제3채무자 외의 제3자에게 등기와 그 통지의 도달 또는 승낙의 선후에 따라 그 권리를 주장할 수 있다.
- ④ 제2항의 통지, 승낙에 관하여는 「민법」 제451조 및 제452조를 준용한다.

- (10) 이 법에 따라 담보로 제공할 수 있는 채권을 금전지급을 목적으로 하는 지명채권으로 한정하고 있으며^(동법 제34조 제1항),
- (11) 여러 개의 채권(채무자가 특정되었는지 여부를 묻지 아니하고 장래에 발생할 채권을 포함)이더라도 특정할 수 있으면 담보등기를 할 수 있도록 하고^(동법 제34조 제2항),
- (12) 약정에 의한 채권담보권의 득실변경은 담보등기한 때에 지명채권의 채무자(제3채무자) 이외의 제3자에게 대항할 수 있도록 하고, 제3채무자에 대한 대항요건은 민법과 마찬가지로 제3채무자에 대한 통지나 제3채무자의 승낙을 요건으로 하며^(동법 제35조),
- (13) 등기의 사무처리는 접수번호의 순서에 따라 전산정보처리조직에 의하여 담보등기부에 등기사항을 기록하는 방식으로 하도록 하고^(동법 제40조),

제49조(담보권의 존속기간 및 연장등기)

- ① 이 법에 따른 담보권의 존속기간은 5년을 초과할 수 없다. 다만, 5년을 초과하지 않는 기간으로 이를 갱신할 수 있다.
- ② 담보권설정자와 담보권자는 제1항의 존속기간을 갱신하려면 그 만료 전에 연장등기를 신청하여야 한다.
- ③ 제2항의 연장등기를 위하여 담보등기부에 다음 사항을 기록하여야 한다.
1. 존속기간을 연장하는 취지
 2. 연장 후의 존속기간
 3. 접수번호
 4. 접수연월일

- (14) 담보등기의 존속기간은 5년으로 하고, 몇 번이라도 연장이 가능하되, 연장등기의 존속기간도 5년을 초과할 수 없도록 하였으며^(동법 제49조),

제52조(담보등기부의 열람 및 증명서의 발급)

- ① 누구든지 수수료를 내고 등기사항을 열람하거나 그 전부 또는 일부를 증명하는 서면의 발급을 청구할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 등기부의 열람 또는 발급의 범위 및 방식, 수수료에 관하여는 대법원규칙으로 정한다.

동산·채권의 담보등기 등에 관한 규칙

제25조(열람의 방법)

- ① 등기기록의 열람은 등기기록에 기록된 등기사항을 전자적 방법으로 그 내용을 보게 하거나 그 내용을 기록한 서면을 교부하는 방법으로 한다. 다만, 서면을 교부하는 경우에는 등기사항증명서 양식이 아닌 다른 양식으로 교부할 수 있다.
- ② 신청서나 그 밖의 부속서류의 열람은 등기관이 보는 앞에서 하여야 한다. 다만, 신청서나 그 밖의 부속서류가 전자문서로 작성된 경우에는 제1항 본문의 방법에 따른다.

③ 제23조제1항제1호부터 제3호의 증명사항에 해당하는 등기기록 또는 신청서나 그 밖의 부속서류에 대해서는 제23조제2항 각 호에서 정한 사람에 한하여 직접 이해관계가 있는 범위 내에서 열람을 신청할 수 있다.

- (15) 담보등기의 등기사항에 관한 서면의 발급 또는 열람을 누구든지 청구할 수 있도록 하되, 개인정보보호를 위해 열람의 범위, 방식 등에 대하여는 대법원규칙으로 정하도록 하고(동법 제52조),
- (16) 동법은 공포 후 2년이 경과한 날부터 시행하되, 동법 시행 후 체결한 담보약정부터 적용하도록 함(동법부칙 제1조 및 제2조).

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 당사자 사이에 대물변제를 예약하고 소유권이전청구권을 보전하기 위하여 등기가 활용된다.
- ② 가등기담보는 담보권의 일종이다.
- ③ 가등기담보에는 저당권의 물상대위에 관한 규정이 유추적용된다.
- ④ 가등기담보권자가 담보권을 실행하여 목적부동산의 소유권을 취득하기 위해서는 청산금을 지급하여야 한다.
- ⑤ 가등기담보권자는 담보물에 대한 소유권을 취득할 수 는 있으나 경매를 청구할 수는 없다.
- ⑤. 가등기담보권자는 그 선택에 따라 소유권취득형식의 담보권실행을 하거나, 목적부동산의 경매를 청구할 수 있다. 이러한 경우에 경매에 관하여는 담보가등기권리를 저당권으로 본다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 채권자가 채무권자에게 지급할 청산금을 계산함에 있어서는 선순위 권리자의 채권액을 고려하여야 한다.
- ② 청산금채권이 압류 또는 가압류된 경우에 채권자는 청산기간이 경과한 후 이에 해당하는 청산금을 채무이행지를 관할하는 지방법원 또는 지원에 공탁할 수 있다.
- ③ 가등기담보등에 관한 법률에 의한 가등기담보권의 실행방법은 저당권의 경우와 동일하다.
- ④ 채권자가 담보권을 실행하여 그 담보목적물의 소유권을 취득하려면 청산금의 평가액을 통지하여야 한다.
- ⑤ 담보가등기 후에 대항력 있는 임차권을 취득한 자는 청산금의 범위 안에서 임차물의 반환과 상환으로 보증금의 반환을 청구할 수 있다.
- ③. 가등기담보권의 실행방법에는 귀속청산과 경매실행을 선택할 수 있다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 채권자가 담보권을 실행하여 그 담보목적물의 소유권을 취득하려면 청산금의 평가액을 통지하여야 한다.
- ② 채권자가 그 담보목적물의 소유권을 취득하려면 채무자에게 청산금을 지급하여야 한다.
- ③ 채권자의 청산금지급채무와 부동산소유권이전등기 및 인도채무는 동시이행의 관계에 있다.

- ④ 채권자가 채무자에게 지급할 청산금을 계산함에 있어서는 후순위권리자의 채권액도 고려하여야 한다.
 - ⑤ 경매 등이 개시된 경우에 담보가등기권리자는 다른 채권자보다 자기채권의 우선변제를 받을 권리가 있다.
- ④. 청산금을 평가함에 있어서는 선순위권리자의 채권액도 고려하여야 한다.

♣ 학습정리

1. 목적부동산의 가액이 채권액을 넘는 경우에는 가등기담보권자는 그 차액을 청산금으로서 채무자에게 지급하여야 하고, 청산의무에 관한 가등기담보법에 위반하는 특약으로서 채무자 등에 불리한 것은 무효이다. 또한 가등기담보법이 있기 전에는 담보권자가 목적물의 소유권을 취득하면서 청산금을 지급하는 귀속청산과 목적물을 제3자에게 처분하여 그 대금으로부터 변제를 받고 나머지를 청산금으로 지급하는 처분청산의 방법이 있다.
2. 가등기담보권자가 채권자는 실행통지를 하고 청산기간이 경과한 후 청산금을 지급한 후 담보가등기에 기하여 본등기를 함으로써 목적부동산에 대한 소유권을 취득하게 된다. 이 때 청산금의 지급과 소유권의 이전등기 및 목적물의 인도는 동시이행의 관계에 있다. 그러나 담보물의 가액이 채권액을 초과하고 있지 않아서 청산금이 없는 때에는 가등기담보권자는 청산기간이 경과한 후 곧바로 가등기에 기한 본등기를 실행할 수 있다.
3. 가등기담보의 목적물에 대하여 제3자에 의한 경매가 진행되는 경우에 가등기담보권자는 그 배당에 참가하여 우선변제를 받을 수 있다. 이 경우에 그 순위에 관하여는 그 담보가등기 권리를 저당권으로 보고, 그 담보가등기를 한 때에는 그 저당권의 설정등기가 행하여진 것으로 본다.

제42강 양도담보 (1)

♣ 학습목표

1. 양도담보의 의의와 유효성을 이해한다.
2. 양도담보의 법률구성과 설정을 체계적으로 정리한다.
3. 유치권의 효력을 유형별로 살펴본다.

♣ 학습내용

- 양도담보의 의의와 유형
- 양도담보의 유효성
- 양도담보의 법률구성
- 양도담보의 설정
- 양도담보의 효력

♣ 사전 테스트

1. 채권자명의로 신축건물의 보존등기를 경료한 경우에도 원소유자에게 소유권이전등기는 가능하다.
⇒ × : 판례는 건축업자로부터 건물을 분양받고 소유권이전등기를 경료 받지 못한 자는 그보다 앞서 건물에 관하여 담보목적으로 소유권보존등기를 경료한 대지소유자에 대하여 분양을 이유로 한 소유권이전등기를 구할 수 없다고 한다.
2. 부동산의 양도담보의 경우 양도담보권설정자는 목적부동산에 대한 사용수익권을 가진다.
⇒ ○ : 부동산의 양도담보의 경우에는 특별한 사정이 없는 한 목적부동산에 대한 사용수익권은 채무자인 양도담보권설정자에게 있다.
3. 양식장의 어류 등은 유동집합동산으로서 양도담보를 설정할 수 없다.
⇒ × : 특정 양어장 내의 어류 전부에 대한 양도담보계약은 유효하게 성립한다. 그 후 개개의 물건을 반입하더라도 그 때마다 별도의 양도담보권설정계약을 맺거나 점유개정의 표시를 하여야 하는 것은 아니다.

♣ 강의교안

제3항 양도담보

I. 서 설

1. 의 의

양도담보란 채권담보를 위하여 채권자에게 물건의 소유권 또는 기타의 재산권을 이전하고 채무자가 이행하면 목적물을 그 소유자에게 반환하고, 채무자가 이행하지 않는 경우에는 청산절차에 의하여 그 목적물로부터 우선변제를 받는 소유권이전형의 변칙담보이다.

[판례] 채권자명의로 신축건물의 보존등기를 경료한 경우

대지소유자가 건축업자에게 대지를 매도하고 건축업자는 대지소유자 명의로 건축허가를 받았다면 이는 완성될 건물을 대지 매매대금의 담보로 제공키로 하는 합의로서 법률행위에 의한 담보물권의 설정에 다름 아니어서, 완성된 건물의 소유권은 일단 이를 건축한 채무자가 원시적으로 취득한 후 대지소유자 명의로 소유권보존등기를 마침으로써 담보목적의 범위 내에서 대지소유자에게 그 소유권이 이전된다고 할 것이므로, 그 경우 건축업자가 건물을 타에 분양하였다 할지라도 그 후 대지소유자 명의로 건물에 대한 소유권보존등기가 경료된 경우에는, 건축업자가 담보물인 위 건물을 타에 분양하고 그 분양대금 중 일부로 매매대금을 대지소유자에게 지급하기로 약정하는 등 건축업자가 건물을 타에 분양하는 것을 대지소유자가 허용한 경우가 아닌 한, 건축업자의 분양 등 처분행위는 대지소유자의 담보권에 반한다 할 것이고, 따라서 건축업자로부터 건물을 분양받고 소유권이전등기를 경료받지 못한 자는 그보다 앞서 건물에 관하여 담보목적으로 소유권보존등기를 경료한 대지소유자에 대하여 분양을 이유로 한 소유권이전등기를 구할 수 없다(대판 2002. 7. 12, 2002다19254).

2. 유 형

- (1) 매도담보 신용의 수수를 소비대차가 아닌 매매의 형식에 의하고 후에 채무자(매도인)가 그 대금을 채권자(매수인)에게 반환함으로써 목적물을 다시 찾는 방법이다. 예를 들어 B가 A로부터 5000만원을 차용할 때 B소유 부동산을 A에게 매각하고 그 대금으로 A가 B에게 5000만원을 지급하는 방법을 취하는 것이다. 민법상 환매(제590조)와 재매매의 예약에 의한 담보형태를 총칭하여 매도담보라 한다.
- (2) 협의의 양도담보 당사자 사이에 소비대차계약을 맺고 채무의 담보로서 물건의 소유권을 이전하는 형식이며, 신용의 수수를 채권·채무의 형식으로 남겨 두는 것이다. 예를 들어 A가 B에 대하여 5000만원의 금전채권을 가지고 있을 때 그 채권을 담보하기 위하여 B소유의 부동산의 소유권을 A에게 이전하는 형식을 취하는 방법이다.

▶ 돌발 퀴즈

소유권이전형의 변칙담보인 양도담보를 인정하는 것이 타당한가?

: ○

- 양도담보는 동산양도저당권의 실현, 형성과정에 있는 재산권(예 : 골프회원권, 전화가입권 등)의 담보화, 우선변제절차의 간이화 등 민법상 담보물권제도가 가지는 不備點을 보충하는 작용을 한다. 다만 양도담보는 소유권을 이전하는 형식을 취하는 것이기 때문에 채권자의 불성실이나 배신 등으로 목적물을 잃게 될 염려가 있고, 채권자의 폭리수단으로 악용될 가능성도 있다.

II. 양도담보의 유효성

1. 허위표시와의 관계

양도담보는 담보목적의 범위를 넘어서 소유권의 이전을 가장하는 것이기 때문에 허위표시(제108조)라고 볼 수도 있다. 그러나 양도담보에 있어서의 소유권이전은 채권담보의 목적으로써만 행사해야 된다는 구속을 받는 소유권이전 내지 새로운 형태의 담보권의 설정으로 볼 수 있으므로 이를 허위표시라고 할 수 없다는 견해가 지배적인 것으로 되었다. 판례도 양도담보는 허위표시가 아니라고 한다(대판 1964. 6. 16, 64다138).

2. 탈법행위와의 관계

점유이전 없는 동산의 유담보화는 점유개정에 의한 질권설정의 부인(제332조), 유질계약의 금지(제339조)에 반하는 탈법행위라는 견해가 있었다. 그러나 제332조의 질권설정자에 의한 대리점유의 금지는 질권의 유치적 작용에 착안한 것이므로 질권의 형식을 취하는 경우에만 허용되지 않는 것이고, 동산저당의 실질을 가지는 양도담보에서는 이를 강제할 수 없다. 또한 종래의 판례는 동산의 양도담보뿐만 아니라 부동산의 양도담보에 있어서도 민법 제607조·제608조를 근거로 유질 내지 유저당을 인정하지 않기 때문에 양도담보가 유질계약을 금지하는 제339조에 의하여 탈법행위에 해당된다는 것은 문제될 것이 없다.

3. 물권법정주의와의 관계

양도담보를 일종의 담보물권으로 파악하면 양도담보는 민법이 상정하지 않은 담보제도이기 때문에 물권법정주의(제185조)에 위배여부가 문제될 수 있으나, 이를 관습법상의 물권으로 보면 민법은 관습법에 의한 물권의 창설을 인정하고 있으므로(제185조) 아무런 문제가 없다. 또한 가등기담보법의 제정으로 부동산에 관한 양도담보는 특별법에 의한 담보물권으로 인정되어 있는 것으로 볼 수 있다.

III. 양도담보의 법률구성

양도담보의 법률구성에 관하여 종래 학설이 대립되었으나 가등기담보법이 제정되어 양도담보도 규제하게 됨으로써 그 법적 구성이 새롭게 되고 있다.

1. 가등기담보법 제정 전의 이론

(1) 학 설

- 1) 신탁적 소유권이전설 채권자는 목적물의 완전한 소유권을 취득하며, 다만 채무자에 대한 관계에서 담보목적은 넘어서 그 소유권을 행사하지 아니할 채무를 부담한다는 견해이다. 이 견해는 담보라는 실질보다는 소유권이전이라는 형식을 중시한 것으로 채무자보호에 충실치 못하다는 비판이 있다.
- 2) 해제조건부 소유권이전설 채권자는 피담보채권의 변제를 해제조건으로 하여 목적물에 대한 소유권을 취득한다. 따라서 양도담보의 목적물이 부동산인 경우에 채무자의 변제가 있으면 소유권은 당연히 등기 없이도 채무자에게 복귀한다고 한다는 견해이다. 그러나 가등기담보법 제정 후에는 동법에 의하여 이 설은 더 이상 타당할 수 없다고 하여 일종의 담보권설로 개설되었다.
- 3) 담보물권설 소유권은 여전히 채무자가 보유하고 있고, 채권자는 다만 양도담보권이라는 독특한 담보물권을 취득한다고 한다는 견해이다. 이 견해는 소유권이전이라는 형식보다는 담보라고 하는 실질을 중시한 것으로, 채무자의 보호에는 충실하나 적절한 공시방법이 없어 거래의 안전을 해칠 우려가 있다.

(2) 판 례

가등기담보법이 시행되기 전의 판례는 「법률상 양도담보의 경우 당사자의 약정에 의하여 담보의 목적인 권리가 대외적 관계에 있어서만 이전되는 경우와 대외적 관계뿐만 아니라 당사자간의 관계에 있어서도 인정되는 경우가 있으나 어느 경우를 막론하고 양도담보인 이상 대외적 관계에 있어서는 그 권리는 채권자에게 이전된 것이라고 하여 (대판 1962. 12. 27, 62다724) 대외적 이전형과 대내외적 이전형이 있다고 하고 어느 경우나 소유권은 채권자에게 이전된다고 하여 신탁적 소유권이전설의 입장을 취하였다. 대외적 이전형을 정산형인 약한 의미의 양도담보, 대내외적 이전형을 유담보형인 강한의미의 양도담보라고 칭하였다. 또한 판례는 초기부터 채권담보를 위하여 채무자가 그 소유 부동산을 채권자명의로 이전하였다면 별단의 특약이 없는 한 약한 의미의 양도담보라고 추정할 것이다(대판 1960. 10. 13, 4293민상222)고 하여 양도담보의 형태를 약한 양도담보로 보고 있다. 즉 채무자가 채무를 변제하지 않은 경우에는 목적물을 매각하여 채무의 원리금의 변제에 충당하고, 나머지가 있는 경우에는 이를 채무자에게 반환하고 부족이 있으면 다시 채무자에게 청구할 수 있는 것으로 보았다. 그리고 양도담보의 법률구성에 있어서는 대다수의 판례가 이른바 신탁적 소유권설을 취하고 있었다(대판 1969. 10. 23, 69다 1338; 대판 1991.5.24, 71다 699). 그러나 담보물권설에 접근하여, 부동산양도담보설정자가 그 부동산의 불법점유자인 제3자에 대하여 실질적 소유자임을 주장하여 불법점유상태의 배제권을 행사할 수 있다는 판례(대판 1976. 2. 24, 75다1608), 실제로 양도담보의 본질이 담보권이라고 표현한 판례(대판 1962. 5. 31, 61다153) 등도 발견할 수 있다.

2. 가등기담보법 제정 후의 이론

(1) 부동산양도담보

1) 학 설

가등기담보법은 담보계약이 민법 제607조·제608조에 위반하는 경우에 「이에 따른 담보계약과 그 담보의 목적으로 경료된 가등기 또는 소유권이전등기의 효력을 정함을 목적으로 한다」고 규정한다(가등기담보법 제1조). 이 규정은 담보를 목적으로 재산을 이전하는 담보계약을 하고 소유권이전등기를 한 경우, 즉 양도담보·매도담보도 아울러 규제하는 것이 가등기담보법의 목적임을 밝히려 한 것으로 보인다. 그리고 동법 제4조 2항은 「채권자는 담보부동산에 관하여 이미 소유권이전등기가 경료된 경우에는 청산기간 경과 후 청산금을 채무자 등에게 지급한 때에 목적부동산의 소유권을 취득한다」고 규정하고 있다. 이 규정은 비록 소유권이전등기가 경료되었더라도 그 소유권은 여전히 채무자에게 남아 있다는

점을 명백히 하고 있다. 따라서 채권자가 취득하는 것은 단지 제한물권이며 그 중에서도 목적물의 가치를 지배하는 담보물권의 일종이라고 할 것이다. 가등기담보법 시행 이후 현재 우리 나라의 학설은 양도담보를 담보물권으로 보는데 대체로 견해가 일치되고 있다. 그러나 이와는 달리 가등기담보법은 판례에서 파악한 담보목적의 신탁적 소유권이전의 이론을 입법화하여 부동산양도담보 중 이전등기담보로 흡수한 것이므로 담보권설이 그 논거로 내세우는 가등기담보법 제4조 2항 전단 및 제1조 단서 등은 신탁적 소유권이전설에 의하여 설명함이 타당하다는 견해가 있다(이영준). 생각건대 양도담보의 법률구성에 관하여 채권담보라는 목적을 중시하여야 할 것이므로 담보물권설이 타당한 것으로 본다.

2) 판례 가등기담보법이 시행된 후에도 판례는 「이른바 양도담보의 경우에는 채권담보를 위하여 신탁적으로 양도담보권자에게 건물의 소유권이 이전될 뿐 확정적·종국적으로 이전되는 것이 아니다(대판 1995. 7. 25, 94다46428)」고 하여 여전히 신탁적 소유권이전설의 입장을 취하고 있다. 그러나 판례 중에는 담보권설의 입장을 취하고 있는 판례도 있다. 즉 판례는 「양도담보권자가 양도담보의 실행으로 양도담보의 목적물을 제3자에게 처분한 경우에 그 담보권자에게 어떤 양도소득이 있다고 할 수 없으므로 양도담보권자에게 목적물의 처분을 원인으로 하여 양도소득세 등이 부과되었다면 이는 위법한 처분이고, 그로 인한 양도소득세의 본래의 납세의무자는 양도담보설정자라고 보아야 한다(대판 1994. 8. 26, 99다15267)」고 판시하고 있다. 이 판례는 양도담보의 성질에 관하여 명확한 입장을 표명하고 있지 않으나 「양도담보가 설정된 물건의 실질적 소유자는 설정자」라는 것을 밝히고 있어 결론적으로 담보물권설을 취하고 있는 것으로 보인다. 지금까지의 판례의 태도에 비추어 볼 때 양도담보의 법률구성은 소유권적 구성으로부터 담보적 구성으로 이행하는 과도기에 있다고 할 것이다.

(2) 동산양도담보

1) 학 설 동산양도담보권자가 양도담보 목적물에 관하여 소유권을 갖는지 아니면 담보권을 갖는지가 문제된다. 이는 가등기담보법 제정 후에도 문제되는 것으로서 동법은 부동산의 양도담보에만 적용될 뿐 동산의 양도담보에는 적용되지 않기 때문이다. 즉 가등기담보법 제3조 내지 17조는 부동산 소유권의 취득을 목적으로 하는 담보계약을 예정하고 있으며, 제18조는 등기 또는 등록이 가능한 부동산 소유권 이외의 물권의 취득을 목적으로 하는 담보계약에 관하여 동법 제13조 내지 17조의 규정을 준용한다고 하고 있기 때문에 그 적용이 명문에 의해 배제되고 있다고 해석할 수 있다. 따라서 이처럼 가등기담보법의 적용을 받지 않는 양도담보의 법적 성질을 어떻게 이해해야 하는가는 해석상의 문제로 귀결될 수밖에 없다. 이에 대하여는 같은 양도담보이면서도 목적물에 따라 그 이론구성과 규제가 각각 다르다고 하는 것은 도저히 합리적이라 볼 수 없으므로 동산양도담보에 관하여도 가등기담보법이 적용되는 부동산 양도담보에 있어서와 동일한 이론구성을 하고, 그에 준해서 규제하는 것이 타당하다고 설명하는 이른바 일원적 규제설이 주장되고 있다. 그러나 당사자들은 제3자의 공취의 배제, 채권만족의 방법, 시기의 자유로운 선택의 필요 등 그럴만한 합리적인 이유에 기인하여 신탁적 양도를 의도한 것이며, 이러한 당사자들의 의사는 법률의 규정이 없는 한 함부로 그 효력이 부정되어서는 안 된다는 점과 가등기담보법은 명문의 규정상 그 대상을 부동산에 한정하고 있는 한 동산이나 채권 등의 양도담보에는 유추적용될 성질의 것이 아니므로 동산의 양도담보의 경우에는 종래의 신탁적 양도설이 타당하다고 한다.

2) 판 례 판례는 동산양도담보권자가 양도담보의 목적물을 점유하고 있는 제3자에 대하여 목적물의 인도를 청구한 사안에서 「이 사건 동산에 관하여 양도담보계약이 이루어졌다면 원고 은행은 대외적으로 그 소유권을 행사할 수 있다 할 것이므로 원심이 이를 바탕으로 제3자인 피고들에게 이 사건 동산의 인도를 명한 것은 적법하다」고 판시한바 있으며(대판 1986. 8. 19, 86다카315), 양도담보목적물을 설정자의 일반채권자가 압류하자 양도담보권자가 제3자이의의 소를 제기한 사안에서 「이 사건 동산에 관하여 양도담보권계약이 이루어지

고 원고가 점유개정의 방법으로 인도를 받았다면 그 청산절차를 마치기 전이라 하더라도 담보목적물에 대한 사용·수익권은 없지만 제3자에 대한 관계에 있어서는 그 물건의 소유자임을 주장하고 그 권리를 행사할 수 있다 할 것이다. 따라서 이 사건 강제집행의 목적물에 관한 양도담보권자인 원고는 강제집행을 한 피고에 대하여 그 소유권을 주장하여 제3자이익의 소를 제기함으로써 그 강제집행의 배제를 구할 수 있다」고 판시하여(대판 1994. 8. 26, 93다44739), 가등기담보법이 시행된 이후에도 동산양도담보에 대하여는 일관하여 신탁적 양도설에 따라 법률구성을 하고 있는 것으로 해석된다.

IV. 양도담보의 설정

양도담보권은 양도담보권설정에 관한 양도담보계약과 그 목적물의 권리의 이전에 필요한 공시방법을 갖어야 성립한다.

1. 양도담보계약

양도담보계약은 채권담보를 목적으로 채무자 또는 제3자(물상보증인)의 특정의 재산권을 채권자에게 양도하고 채무자의 채무불이행이 있는 때에는 그 재산권으로부터 채권을 변제받기로 하는 내용의 계약이다.

- (1) 계약의 성질 양도담보계약은 채권계약과 물권계약의 두가지 성질을 가지며, 피담보채권의 발생원인인 채권계약(소비대차계약)과 합체 또는 분리되어 행하여질 수도 있다. 양도담보설정계약은 채권자와 채무자 또는 물상보증인과 같은 제3자 사이에도 성립되는 낙성·불요식계약이다.
- (2) 당사자 양도담보계약의 당사자는 담보권설정자와 양도담보권을 취득하는 담보권자이다. 담보권설정자는 채무자에 한하지 않고 제3자도 상관없다. 그러나 담보권자는 채권자에 한한다.
- (3) 피담보채권 양도담보는 피담보채권의 존재를 필요로 한다. 피담보채권은 금전채권이 보통이지만 반드시 금전채권일 필요는 없다. 피담보채권은 특정채권이든 장래에 증감·변동하는 불확정채권이든 상관없다. 소비대차에 의한 채권뿐만 아니라 외상거래로 생긴 상품대금채권·불법행위채권·부당이득반환청구권 등도 포함될 수 있을 것이다.
- (4) 목적물 양도할 수 있는 재산권은 모두 목적물이 될 수 있다. 동산·부동산·채권뿐 아니라, 다른 담보물권의 목적이 될 수 없는 재산적 이익(예 : 상호권·영업권·기업권·아파트 입주권 등)이나 강제집행상 압류가 금지된 물권(민집법 제195조)도 양도담보의 목적이 될 수 있다. 일정한 점포내의 상품과 같이 증감·변동하는 상품일체도 이른바 「집합물에 의한 양도담보권」으로서 특정할 수 있다면 담보설정이 가능하다(대판1999. 9. 7, 98다47283). 미등기부동산도 양도담보의 목적물이 될 수 있다. 사찰 또는 불교단체 소유의 부동산과 농지도 담보목적물로 될 수 있다. 그리고 등기·등록할 수 있는 부동산소유권 이외의 권리(질권·저당권·전세권 제외)도 양도담보의 목적이 될 수 있다.

[판례] 이른바 증감·변동하는 집합물에 의한 양도담보

- (1) 일반적으로 일단의 증감 변동하는 동산을 하나의 물건으로 보아 이를 채권담보의 목적으로 삼으려는 이른바 집합물에 대한 양도담보설정계약 체결도 가능하며 이 경우 그 목적 동산이 담보설정자의 다른 물건과 구별될 수 있도록 그 종류, 장소 또는 수량지정 등의 방법에 의하여 특정되어 있으면 그 전부를 하나의 재산권으로 보아 이에 유효한 담보권의 설정이 된 것으로 볼 수 있다.
- (2) 양도담보계약서 중 양도물건목록에 소재지, 보관창고명과 목적물이 양만장 내 뱀장어, 수량 약 백만 마리라고 기재되어 있을 뿐이고 특별히 위 양만장 내의 뱀장어 중 1,000,000마리로

그 수량을 지정하여 담보의 범위를 제한한 사실이 인정되지 않는다면 위 양도담보계약서에 기재된 수량은 단순히 위 계약 당시 위 양만장 내에 보관하고 있던 뱀장어 등의 수를 개략적으로 표시한 것에 불과하고 당사자는 위 양만장 내의 뱀장어 등 어류전부를 그 목적으로 하였다고 봄이 당사자의 의사에 합치된다고 할 것이다.

- (3) 성장을 계속하는 어류일지라도 특정 양만장 내의 뱀장어 등 어류전부에 대한 양도담보계약은 그 담보목적물이 특정되었으므로 유효하게 성립하였다고 할 것이다.

라. 집합물에 대한 양도담보권설정계약이 이루어지면 그 집합물을 구성하는 개개의 물건이 변동되거나 변형되더라도 한 개의 물건으로서 동일성을 잃지 아니 하므로 양도담보권의 효력은 항상 현재의 집합물 위에 미치는 것이고, 따라서 양도담보권자가 담보권설정계약 당시 존재하는 집합물을 점유개정의 방법으로 그 점유를 취득하면 그 후 양도담보설정자가 그 집합물을 이루는 개개의 물건을 반입하였다 하더라도 그때마다 별도의 양도담보권설정계약을 맺거나 점유개정의 표시를 하여야 하는 것은 아니다(대판 1990. 12. 26, 88다카20224).

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 양도담보는 소유권의 이전을 가장하는 허위표시라고 한다.
 - ② 양도담보는 동산양도저당권의 실현, 형성과정에 있는 재산권의 담보화 등의 역할을 한다.
 - ③ 부동산의 양도담보에 있어서 유질 내지 유저당을 인정하지 않고 있다.
 - ④ 양도담보가 소유권을 이전하는 형식을 취하기 때문에 채권자의 폭리수단으로 악용될 수 있다.
 - ⑤ 가등기담보법의 제정으로 부동산에 관한 양도담보는 특별법에 의한 담보물권으로 인정될 수 있다.
- ①. 그러나 양도담보에 있어서의 소유권 이전은 채권담보의 목적으로써만 행사해야 된다는 구속을 받는 소유권이전 내지 새로운 형태의 담보권의 설정으로 볼 수 있으므로 이를 허위표시라고 할 수 없다는 견해가 지배적이다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 증감 변동하는 동산의 집합물이라 하더라도 대상물을 특정할 수 있고, 그렇게 목적물이 특정된다면 그에 대한 양도담보설정계약은 유효하다.
- ② 집합물에 대한 양도담보권설정계약이 이루어지면 그 집합물을 구성하는 개개의 물건이 변동되거나 변형되더라도 한 개의 물건으로서 동일성을 잃지 않는 것으로 보아야 한다.
- ③ 양도담보권의 효력은 현재의 집합물 위에 미치는 것으로 볼 수 있다.
- ④ 양도담보권자가 담보권설정계약 당시 존재하는 집합물을 점유개정의 방법으로 그 점유를 취득하게 되면 그 후 양도담보설정자가 그 집합물을 이루는 개개의 물건을 반입하였다 하더라도 그때마다 별도의 양도담보권설정계약을 맺거나 점유개정의 표시를 하여야 하는 것은 아니다.
- ⑤ 동산양도담보에 관한 법리구성에 관한 판례의 입장은 가등기담보등에 관한 법률의 제정을 계기로 하여 큰 변화를 보이고 있다.

- ⑤. 판례는 가등기담보법이 시행된 이후에도 동산양도에 대하여는 일관하여 신탁적 양도설에 따라 법리를 구성하고 있다.

3. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 동산의 양도담보권설정자가 점유중인 양도담보 목적물을 선의의 제3자에게 처분한 경우에 그 제3자는 양도담보권의 부담 없는 소유권을 취득한다.
 - ② 성장을 계속하는 어류일지라도 특정 양어장 내의 어류 전부에 대한 양도담보계약은 유효하게 성립한다.
 - ③ 부동산양도담보의 경우 특별한 사정이 없는 한 목적부동산에 대한 사용수익권은 채무자인 양도담보권 설정자에게 있다.
 - ④ 양도담보권자는 담보권의 실행을 위하여 담보채무자가 아닌 제3자에 대하여도 담보물의 인도를 구할 수 있고, 인도를 거부하는 경우에는 임료 상당의 손해배상을 구할 수 있다.
 - ⑤ 양도담보권자가 담보부동산 위에 건물을 신축한다거나 담보부동산에 관하여 제3자에게 근저당권을 설정해 주는 것은 담보권 실행으로서의 환가처분으로 볼 수 없다.
- ④. 판례는 양도담보권자가 담보권의 실행을 위하여 담보채무자가 아닌 제3자에 대하여도 담보물의 인도를 구할 수 있으나, 인도를 거부하는 경우에는 임료 상당의 손해배상을 구할 수 없다고 한다.

♣ 학습정리

1. 양도담보란 채권담보를 위하여 채권자에게 물건의 소유권 또는 기타의 재산권을 이전하고 채무자가 이행하면 목적물을 그 소유자에게 반환하고, 채무자가 이행하지 않는 경우에는 청산절차에 의하여 그 목적물로부터 우선변제를 받는 소유권이전형의 변칙담보이다. 이는 동산양도저당권의 실현, 형성과정에 있는 재산권의 담보화 등의 역할을 하지만, 소유권을 이전하는 형식을 취하기 때문에 채권자의 폭리수단으로 악용될 수 있다.
2. 증감 및 변동하는 동산의 집합물이라 하더라도 대상물을 특정할 수 있고, 그렇게 목적물이 특정된다면 그에 대한 양도담보설정계약은 유효하다. 즉 집합물에 대하여 양도담보권설정계약이 이루어진 이상 그 집합물을 구성하는 개개의 물건이 변동되고, 양도담보권자가 그 때마다 양도담보권설정자와 별도의 양도담보권설정계약을 맺거나 점유개정의 표시를 하지 아니하였더라도 집합물은 한 개의 물건으로서의 동일성을 잃지 아니하여 양도담보권의 효력은 항상 현재의 집합물에 미친다.
3. 부동산의 양도담보의 경우 특별한 사정이 없는 한 목적부동산에 대한 사용·수익권은 채무자인 양도담보설정자에게 있기 때문에 양도담보권자는 사용·수익할 수 있는 정당한 권한이 있는 채무자나 채무자로부터 그 사용·수익할 수 있는 권한을 승계한 자에 대하여는 사용·수익을 하지 못하는 것을 이유로 임료 상당의 손해배상이나 부당이득반환청구를 할 수 없다.

제43강 양도담보 (2)

♣ 학습목표

1. 양도담보의 대외적 효력을 이해한다.
2. 양도담보권의 실행방법 및 소멸사유를 살펴본다.
3. 매도담보의 의의와 법률구성을 정리한다.

♣ 학습내용

- 양도담보의 대외적 효력
- 양도담보권의 실행방법
- 양도담보의 소멸사유
- 유동집합동산의 양도담보
- 매도담보의 의의와 법률구성

♣ 사전 테스트

1. 동산의 양도담보권설정자가 점유중인 양도담보 목적물을 선의의 제3자에게 처분하더라도 당해 거래는 무효이다.
⇒ × : 동산의 양도담보권설정자가 점유중인 양도담보 목적물을 선의의 제3자에게 처분한 경우에 그 제3자는 양도담보권의 부담 없는 소유권을 취득한다.

2. 양도담보권의 피담보채권의 범위에 관해서는 저당권의 피담보채권의 범위에 관한 제360조가 준용된다(가등기담보법 제3조 2항).

⇒ ○ : 따라서 원본·이자·위약금·채무불이행에 의한 손해배상·실행비용이 피담보채권에 포함된다. 지연배상은 원본의 이행기를 경과한 1년분에 한한다.

3. 신탁적 소유권이전설에 의하면 양도담보설정자는 목적물의 처분권한이 없으므로 제3자도 선의취득에 의해서만 권리를 취득할 수 있다.

⇒ ○ : 그러나 담보물권설에 의하면 설정자가 목적물을 점유하는 동산양도담보에서는 그 설정자는 목적물을 제3자에게 처분할 수 있다. 이 경우 제3자는 양도담보권의 부담이 있는 소유권을 취득할 뿐이고, 양도담보권자는 제3자에 대하여 추급력을 행사할 수 있을 것이다. 다만 설정자가 목적물위에 양도담보권이 설정되어 있음을 숨기고 이를 양도한 경우에는 선의취득의 요건을 갖춘 제3자는 양도담보의 부담 없는 소유권을 취득한다.

♣ 강의교안

2. 공시방법

- (1) 동산의 경우 목적물이 동산인 때에는 인도가 있어야 한다(제188조·제200조). 양도담보는 소유권이전의 형식을 이용하는 것이므로 동산질권과는 달리 점유개정에 의한 인도도 할 수 있다. 판례는 동산에 대하여 점유개정의 방법으로 양도담보를 설정한 후에는 양도담보권자나 설정자가 그 동산에 대한 점유를 상실하였다고 하더라도 그 양도담보의 효력에는 아무런 영향이 없다고 한다(대판2000. 6. 23, 99다65066).
- (2) 부동산의 경우 목적물이 부동산인 때에는 매매를 원인으로 하는 소유권이전등기를 하는 것이 보통이다. 그러나 등기실무상으로는 「양도담보」를 등기원인으로 기재하는 것을 인정하고 있다.
- (3) 채권의 경우 양도담보의 목적물이 채권 기타 재산권인 경우에는 그 권리의 이전에 필요한 공시방법을 갖추어야 한다. 지명채권의 경우에는 양도인으로부터의 통지 또는 채무자의 승낙이 그 대항요건이다(제450조·제451조).

V. 양도담보의 효력

1. 대내적 효력

(1) 효력이 미치는 범위

- 1) 피담보채권의 범위 양도담보권의 피담보채권의 범위에 관해서는 저당권의 피담보채권의 범위에 관한 제360조가 준용된다(가등기담보법 제3조 2항). 따라서 원본·이자·위약금·채무불이행에 의한 손해배상·실행비용이 피담보채권에 포함된다. 지연배상은 원본의 이행기를 경과한 1년분에 한한다.
- 2) 물상대위 양도담보도 일종의 담보물권이므로 물상대위성을 가진다(제370조·제342조). 다만 양도담보권에서는 형식상 소유권이 양도담보권자에게 귀속하고 있기 때문에 물상대위에 관한 제342조의 단서는 적용되지 않는다.

(2) 담보목적물의 이용관계

- 1) 목적물의 점유와 이용 목적물을 점유·이용하는 권리를 담보권자가 갖느냐 또는 설정자가 갖느냐는 당사자 사이의 합의에 의하나, 전자는 질권에 의하여 달성되므로 양도담보에서는 후자의 형태를 취하는 경우가 많다. 판례도 「부동산을 채권담보의 목적으로 양도한 경우 특별한 사정이 없는 한 목적부동산에 대한 사용·수익권은 채무자인 양도담보설정자에게 있는 것이므로 양도담보권자는 사용·수익할 수 있는 정당한 권한이 있는 채무자나 채무자로부터 그 사용·수익할 수 있는 권한을 승계한 자에 대하여는 사용·수익을 하지 못하는 것을 이유로 임료상당의 손해배상이나 부당이득반환청구를 할 수 없다」고 하여 양도담보설정자의 목적물에 대한 사용·수익권을 인정하고 있다(대판 2001. 12. 11, 2001다40213).
- 2) 이용관계의 법률적 구성 양도담보권설정자가 목적물을 계속하여 이용하는 경우에 이용권한의 법률관계를 어떻게 구성하느냐가 문제된다. 이에 관하여 양도담보설정자의 구체적 이용관계는 특약이 없는 한, 대체로 임대차(원본이 이자부인 경우) 또는 사용대차(원본이 무이자부인 경우)에 준하여 생각하면 된다는 것이 종래의 통설적 견해였다. 그러나 최근에는 양도담보권의 실질을 담보물권으로 파악하여 양도담보설정자는 양도담보권자에 대한 관계, 즉 내부관계에 있어서는 소유권이전등기가 담보권자에게 경료된 후에도 여전히 소유자이므로 임대차·사용대차에 의하지 아니하고도 당연히 담보목적물을 점유·이용할 수 있는 것으로 보는

견해가 주장되고 있다. 즉 설정자가 사용·수익 할 수 있는 것은 그 자신의 소유권에 의한 것이지 채권자와의 임대차계약 등에 의한 것이 아닌 것으로 본다.

생각건대 가등기담보법이 적용되는 양도담보에 있어서는 양도담보권자는 담보권만 취득하고 소유권은 여전히 설정자에게 있는 것으로 된다. 따라서 양도담보설정자는 소유자로서 이용하는 것으로 해석하여야 할 것이다. 그러나 가등기담보법이 적용되지 않는 양도담보의 경우에는 이를 임대차 또는 사용대차에 준하는 것으로 해석할 수 있다.

(3) 당사자의 의무

- 1) 양도담보권자의 의무 양도담보권자는 그가 취득한 권리를 담보목적을 넘어 행사하지 않을 부작위의무를 부담한다(가등기담보법 제4조). 양도담보권자가 피담보채권의 변제기 전에 목적물을 처분하는 것과 같이 의무위반행위를 하면 손해배상책임을 진다(대판 [전원합의체] 1985. 11. 26, 85도1493). 담보권자가 손해배상책임을 지는 경우에는 손해배상액은 결국 채권액과 상계하게 될 것이다.
- 2) 양도담보설정자의 의무 양도담보설정자도 목적물을 점유·이용하는 경우에는 양도담보권자의 담보목적에 해하지 않도록 보관·이용할 의무가 있다. 양도담보설정자가 양도담보계약을 위반하여 목적물을 부당하게 처분·훼손하면 채무불이행에 의한 손해배상 책임을 진다(제390조).

2. 대외적 효력

(1) 변제기 도래 전의 처분의 효력

1) 양도담보권자에 의한 처분의 효력

가) 가등기담보법이 적용되는 부동산 양도담보에 있어서 양도담보권자는 양도담보권이라는 일종의 담보권만 가지므로 피담보채권과 함께 양도담보권을 처분할 수 있다. 이 경우에는 양도담보권의 양도를 위한 물권적 합의와 이전등기를 하여야 하고, 또한 채권양도에 관한 규정(제449조 내지 제452조 참조)에 따라 피담보채권을 양도하여야 한다. 가등기담보법이 적용되지 않는 양도담보의 경우에는 양도담보권자가 담보권이 아닌 소유권 등의 권리 자체를 가지기 때문에 담보권의 양도는 문제될 수 없다.

나) 양도담보는 형식상 소유권이전의 방식을 취하기 때문에 양도담보권자가 목적물을 실제로 자기의 소유재산으로서 처분한 경우에 양수인이 그 목적물에 대한 소유권을 취득할 수 있느냐가 문제된다. 이에 관하여 종래에는 선의의 제3자는 목적물이 동산인 때는 선의취득의 법리에 의하여, 부동산인 때는 가등기담보법 제11조 단서에 의하여 소유권을 취득할 수 있었다. 다만 양수인이 악의인 때에는 채무자 등은 양도담보권자의 처분행위의 무효를 주장하여 양수인명의 소유권이전등기 말소를 청구하거나 양도담보권 이전의 효과만을 인정하여 채권액을 제공하고 직접 양수인으로 부터 목적부동산을 회수할 수 있었다. 그러나 현재에는 부동산실권리자명의 등기에 관한 법률에 의하여 양도담보권자로부터 양수받은 제3자는 언제나 악의인 것으로 되어 말소등기를 청구할 수 있다.

2) 양도담보설정자에 의한 처분의 효력

(가) 부동산의 경우 신탁적 소유권이전설에 의하면 양도담보설정자는 목적물에 대한 처분권한이 없으므로 목적물을 제3자에게 처분할 수 없다. 그러나 담보물권설에 의하면 목적물의 소유권은 여전히 양도담보설정자에게 남아 있으므로 원칙적으로 처분할 수 있으나 등기부상의 소유명의가 양도담보권자로 되어 있어서 그 처분은 불가능하다.

(나) 동산의 경우 신탁적 소유권이전설에 의하면 양도담보설정자는 목적물의 처분권한이 없으므로 제3자도 선의취득에 의해서만 권리를 취득할 수 있다. 그러나 담보물권설에 의하면 설정자가 목적물을 점유하는 동산양도담보에서는 그 설정자는 목적물을 제3자에게 처분할 수 있다. 이 경우 제3자는 양도담보권의 부담이 있는 소유권을 취득할 뿐이고, 양도담보권자는 제3자에 대하여 추급력을 행사할 수 있을 것이다. 다만 설정자가 목적물위에 양도담보권이 설정되어 있음을 숨기고 이를 양도한 경우에는 선의취득의 요건을 갖춘 제3자는 양도담보의 부담 없는 소유권을 취득한다.

(2) 일반채권자와의 관계

1) 강제집행의 경우

양도담보권자의 일반채권자가 담보목적물에 강제집행을 하여 압류하는 경우에, 신탁적 소유권이전설의 입장에 의하면 담보제공자는 제3자이의의 소를 제기할 수 없으나, 담보권설에 의하면 소유자인 담보제공자가 제3장이의의 소를 제기할 수 있다고 볼 것이다. 양도담보권자의 일반채권자의 신청에 의한 동산의 경매절차가 종료되어 매수인이 이를 선의취득한 경우, 신탁적 소유권이전설의 입장에 의하면 매수인이 담보목적물의 소유권을 취득하고 담보제공자는 양도담보권자에 대하여 채무불이행에 기한 손해배상을 청구할 수 있을 것이다. 담보권설에 의하면, 담보제공자는 배당절차에서 제3자이의의 소에 의하여 경매대가의 반환을 구할 수 있고 배당절차도 종료되었다면 배당받은 채권자에 대하여 부당이득으로 배당받은 금액 전부의 반환을 청구할 수 있을 것이다.

담보제공자의 일반채권자가 담보목적물을 압류하는 경우에, 신탁적 소유권이전설에 의하면 담보권자는 제3자이의의 소를 제기할 수 있으나, 담보권설에 의하면 양도담보권자가 제3자이의의 소를 제기할 수는 없다. 담보제공자의 일반채권자의 신청에 의한 경매절차가 종료되어 매수인이 담보목적물인 동산의 소유권을 취득한 경우, 신탁적 소유권이전설에 의하면 매수인이 담보목적물을 선의취득할 수 있고 양도담보권자는 배당절차에서 제3자이의의 소에 의하여 경매대가의 반환을 구할 수 있으며 배당절차도 종료되었다면 배당받은 채권자에 대하여 부당이득으로 배당받은 금액 전부의 반환을 청구할 수 있을 것이다. 담보권설에 의한다면, 양도담보권자는 배당절차에서 우선변제권을 주장할 수 있고 배당절차가 종료되었다면 배당받은 후순위자에 대하여 부당이득의 반환을 구할 수 있을 것이다.

2) 파산 등의 경우

양도담보권자가 파산한 경우, 신탁적 소유권이전설에 의하면 소유자가 아닌 담보제공자로서는 환취권을 가지지 않는다고 할 것이나, 담보권설에 의한다면 담보제공자는 소유자로서 피담보채권을 변제하고 목적물을 환취할 수 있다고 해야 한다.

담보제공자가 파산한 경우, 신탁적 소유권이전설에 의하면 파산절차 또는 회생절차에서 양도담보권자에게 환취권이 인정되어야 하지만, 채무자회생 및 파산에 관한 법률은 양도담보권을 담보권으로 취급하므로 별제권만 인정된다. 담보권설에 의한다면, 양도담보권자는 환취권을 가지지 않고 별제권을 가질 뿐이고 담보제공자에 대한 회생절차가 개시된 경우에 양도담보권자에게 환추권이 인정되지 않는다고 할 것이다.

(3) 제3자에 의한 침해

제3자가 담보목적물을 침탈한 경우, 신탁적 소유권이전설에 의하면 양도담보권자는 소유권에 기한 물권적 청구권을 가지는 반면 담보제공자는 점유권에 기한 물권적 청구권만 가지는 것으로 보아야 할 것이지만, 판례는 부동산의 등기명의를 양도담보권자 앞으로 되어 있더라도 양

도담보권설정자는 불법점유자인 제3자에 대하여 그 실질적 소유자임을 주장하여 불법점유 상태에 대한 배제청구를 할 수 있는 것으로 본다. 담보권설에 의하면 양도담보권자는 물권으로서 양도담보권에 기하여, 담보제공자는 소유권에 기하여 각각 물권적 청구권을 행사하여 반환 및 방해제거를 청구할 수 있을 것이다.

제3자가 담보목적물을 멸실·훼손한 경우, 신탁적 소유권이전설에 의하면 양도담보권자는 소유자로서 손해배상청구권을 갖지만 담보제공자에 대해서는 기대권 내지 채권의 침해만 문제된다. 담보권설에 의하면, 양도담보권자는 저당권자에 준하여, 담보제공자는 소유자로서 모두 손해배상청구권을 가진다.

VI. 양도담보권의 실행·우선변제권

양도담보권의 실행방법에는 (i) 담보권의 실행시까지 외형적으로 취득하고 있던 목적부동산의 소유권을 실질적으로 취득하고 피담보채권에 충당하는 방법(귀속정산), (ii) 당사자의 약정에 따라 환가처분하는 실행방법(처분정산)이 있다. 가등기담보법은 부동산양도담보권의 실행방법에 관하여는 귀속정산의 실행방법을 원칙으로 하고 있다.

1. 권리취득에 의한 실행(귀속정산)

- (1) 실행통지 피담보채권의 변제기가 도래한 후에 양도담보권자는 통지 당시의 목적부동산의 평가액과 민법 제360조의 규정에 의한 채권액을 채무자 등에게 통지하여야 한다(가등기담보법 제3조 1항 전단). 만일 평가액이 피담보채권액에 미달하는 때에는 청산금이 없다는 뜻을 통지하여야 한다(동법 제3조 2항 후단).
- (2) 청 산 위 실행통지가 채무자 등에게 도달한 날부터 2개월의 청산기간이 경과한 후 목적부동산의 가액에서 채권액을 공제한 차액을 청산금으로서 채무자등에게 지급하여야 한다(가등기담보법 제4조 1항).
- (3) 소유권의 취득 양도담보권자의 실행통지가 상대방에게 도달한 날로부터 2개월의 청산기간이 경과한 후 청산금이 채무자 등에게 지급된 때에 양도담보권자는 목적부동산의 소유권을 취득할 수 있다(가등기담보법 제4조 2항·3항).
- (4) 채무자 등의 소유권이전등기말소청구권 채무자 등은 양도담보권자로부터 청산금채권을 변제받을 때까지 그 채무액을 지급함으로써 채권담보의 목적으로 경료된 소유권이전등기의 말소를 청구할 수 있다(가등기담보법 제11조 본문). 그러나 채권의 변제기가 도래한 때로부터 10년이 경과한 때에는 채무자 등은 말소등기를 청구하지 못하고, 또한 선의의 제3자가 그 소유권을 취득한 때에도 말소등기를 청구하지 못한다(가등기담보법 제11조 단서). 그리고 목적물이 동산인 경우에는 설정자가 목적물을 점유·이용중이면 피담보채권의 소멸로 목적물의 소유권은 당연히 설정자에게 복귀한 것으로 본다. 이 경우에 청산금이 있는 때에는 청산기간의 경과후 청산금이 지급될 때까지, 그리고 청산금이 없으면 청산기간 내에 변제하면 된다.
- (5) 법정지상권 이 경우에도 일정한 요건 하에 법정지상권이 성립한다(가등기담보법 제10조).

2. 환가처분에 의한 실행(처분정산)

가등기담보법은 귀속정산을 원칙으로 하고 있지만 당사자의 합의에 의하여 처분정산의 방법으로 실행할 것을 합의한 경우에는 그 합의에 따라 환가처분에 의한 실행이 가능한 것으로 본다.

Ⅶ. 양도담보의 소멸

1. 피담보채권의 소멸

- (1) 채무의 변제 채무가 변제되면 피담보채무는 소멸하고, 양도담보권도 소멸한다. 목적물이 동산인 경우에는 소유권은 당연히 복귀한다. 그리고 부동산인 경우에 채무자 등은 담보목적으로 경료된 소유권 이전등기의 말소를 청구할 수 있다(가등기담보법 제11조 본문). 또한 양도담보권자가 채무자에게 청산금을 지급함으로써 소유권을 취득하는 때(가등기담보법 제4조 2항)에는 청산금의 지급으로써 당연히 양도담보는 소멸한다.
- (2) 소멸시효의 완성 소멸시효로 인하여도 피담보채무는 소멸한다. 따라서 피담보채권이 시효로 소멸하면 양도담보권도 당연히 소멸한다.
- (3) 변제자의 대위 보증인이나 양도담보의 제3취득자가 대위변제를 하게 되면 양도담보권도 소멸한다.

2. 목적물의 멸실·훼손

목적물이 멸실·훼손되는 때에는 그 한도에서는 양도담보권도 소멸한다. 그러나 피담보채권은 소멸하지 않고 존속하게 된다. 그리고 멸실·훼손된 목적물에 갈음하는 대표물이 있을 때에는 양도담보권은 그 위에 물상대위 한다.

[참고] 유동집합동산의 양도담보

1. 의 의

유동집합동산이란 일반적으로 일단의 증감변동하는 다수의 물건의 집합으로 그 동산이 독자의 개성을 유지하면서 계속 경제적으로 결합되어 하나의 물건으로 취급하기 때문에 이를 채권담보의 목적으로 할 수 있다. 이를 유동집합동산의 양도담보라고 한다.

2. 유효성의 문제

물권의 직접적 배타적인 지배권이라는 특성으로 인한 일물일권주의의 원칙상 개개의 물건만을 목적으로 하여야 하기 때문에 비록 경제적으로 단일성이 있다고 하더라도 유동집합동산의 효력을 인정하지 말아야 하는 것처럼 보일지도 모른다. 그러나 동산양도저당의 실현으로 목적물을 사용·수익하는 상태로 담보화 하는 것이 사회경제적인 요청에 부합한다고 본다.

3. 사회적 작용

일단의 증감 변동하는 동산의 경우 이에 상응하는 적절한 공시방법이 없는 집합물의 경우, 예를 들어 어떤 창고 또는 공장 내의 상품 전부 등은 양도담보가 아니고서는 담보화가 곤란하므로 이에 관하여 양도담보가 이용되고 있는 실정이다.

4. 요 건

대법원은 “집합물에 대한 양도담보설정계약이 가능하기 위해서는 그 목적 동산이 담보설정자의 다른 물건과 구별될 수 있도록 그 종류, 장소 또는 수량지정 등의 방법에 의하여 특정되어 있어야 한다”고 보았다(대판 1990. 12. 26, 88다카20224). 이 판례는 양어장 내에 양식중인 뱀장어를 양도담보권의 객체로 하는 사건에 관한 것으로 “성장을 계속하는 어류일지라도 특정 양어장 내의 뱀장어 등 어류 전부에 대한 양도담보계약은 그 담보목적물이 특정되었으므로 유효하게 성립한다고” 판시하고 있다.

5. 효 력

위의 판례는 “집합물에 대한 양도담보권 설정계약이 이루어지면 그 집합물을 구성하는 개개의 물건이 변동되거나 변형되더라도 한 개의 물건으로서 동일성을 잃지 아니하므로 양도담보권의 효력은 항상 현재의 집합물 위에 미치는 것이고, 따라서 양도담보권자가 담보권설정계약 당시 존재하는 집합물을 점유개정의 방법으로 그 점유를 취득하면 그 후 양도담보설정자가 그 집합물을 이루는 개개의 물건을 반입하였다 하더라도 그 때마다 별도의 양도담보권설정계약을 맺거나 점유개정의 표시를 하여야 하는 것은 아니다”라고 한다.

[판례] 유동집합동산의 양도담보

제강회사가 제품생산에 필요하여 반입하는 原資材를 일정기간 계속하여 채권담보의 목적으로 삼으려는 소위 집합물양도담보설정계약에 있어서는 목적동산의 종류와 수량의 범위가 지정되고 그 소재 장소가 특정되어 있으면 그 전부를 하나의 재산권으로 보아 담보권 설정이 가능하다고 보아야 할 것이고 그러한 경우 양도담보권자는 담보권설정계약 당시 존재하는 원자재를 점유개정에 의하여 그 점유를 취득하면 제3자에 대하여 그 동산의 소유권을 주장할 수 있는 것이고 그 후 새로이 반입되는 개개의 물건에 대하여 그 때마다 점유개정의 표시가 있어야 하는 것은 아니라고 할 것이다(대판 1988. 10. 25, 85누941).

▶ 돌발 퀴즈

양도담보계약에서 담보목적물인 돼지가 출산한 새끼돼지는 누구의 소유인가?

- 채무자가 담보목적물인 돼지를 점유개정의 방법으로 점유하는 동안 이를 무상으로 사용 수익하기로 약정하였다면 원물인 돼지가 출산한 새끼돼지는 천연과실로서 수취권은 원물의 사용수익권을 갖는 양도담보설정자인 채무자에게 귀속하는 것이므로 새끼돼지에 대하여는 양도담보의 효력이 미치지 아니한다.

제4항 매도담보

1. 의 의

넓은 의미의 양도담보 가운데서 특히 신용의 수수를 매매의 형식으로 행하는 것, 즉 환매권보류부 매매(환매특약부 매매)와 재매매예약부 매매를 통틀어서 매도담보라 한다. 이러한 매도담보에 있어서는 환매와 재매매의 예약이 각각 채권담보의 수단이 되고 담보의 기능을 한다.

환매는 매도인이 매매계약과 동시에 특약으로 「환매할 권리」 즉 환매권을 보류한 경우에 그 환매권을 일정한 기간 내에 행사함으로써 매매의 목적물을 다시 취득하는 것이다(제590조 참조). 재매매의 예약은 어떤 물건 또는 권리를 타인에게 매각하여 대금을 받는 반면에 그 매매목적물의 소유권이나 기타의 권리를 매수인에게 이전하면서 미리 장차 매수인으로 하여금 그 매매의 목적물을 다시 한번 매도인에게 매각·반환케 하는 두 번째의 매매의 예약이다.

2. 기 능

환매특약부 매매나 재매매특약부 매매를 실질적으로 본다면 매도인 A는 매매목적물을 담보로 하여 B로부터 3000만원의 금융을 얻고 그 이자는 B의 목적물로부터의 수익으로써 충당되며, 변제기에 변제하지 않으면 목적물으로써 원본의 변제에 충당하는 유담보계약을 한 것과 같은 결과가 되므로 실제로는 채권담보를 하는 것이 된다. 이러한 환매나 재매매의 예약은 채권자가 담보물권을 설정하는 복잡한 절차없이 확실하게 채권을 담보할 수 있으며, 한편 채무자는 목적물의 소유권을 이전하므로 비교적 많은 금액을 융자할 수 있을 뿐만 아니라 부동산은 등기에 의하여 제3자에 대해서도 목적물반환을 주장할 수 있는 이익이 있기 때문에 금융수단으로 이용되고 있다.

3. 매도담보의 법률구성

환매특약부 매매나 재매매특약부 매매자는 매도담보계약을 하게 되면, 목적물의 권리를 채권자에게 이전하는 형식을 취하게 되지만 채권자의 목적은 어디까지나 채권담보에 있는 것이고, 또한 채권액의 범위 내에서 목적물의 가치를 지배하고 목적물의 잔여가치는 여전히 채무자에게 귀속하고 있다고 본다. 따라서 비록 외형적으로는 권리이전의 형식을 취하고 있지만 채권자는 매도담보권이라는 일종의 담보권을 가질 뿐 채무자에게는 소유권에서 매도담보권을 제외한 권리가 잔존·귀속하는 것으로 본다. 즉 매도담보계약과 소유권이전등기를 함으로써 매도담보권이라는 담보권이 설정되는 효과가 발생하는 것으로 볼 수 있다. 그리고 매도담보에 있어서 피담보채권의 발생원인은 양도담보에서의 소비대차의 실질을 갖는 매매이다. 요컨대 매도담보에 있어서는 매매에 의하여 피담보채권이 성립되고, 매매에 의하여 당사자가 취하게 되는 권리이전의 형식은 위와 같이 하여 성립한 채권을 담보하기 위한 것이다. 그리고 부동산매도담보에 있어서 환매등기나 재매매의 예약에 의한 가등기는 채무를 변제할 때에 발생하게 될 채무자의 소유권이전등기말소청구권을 물권적으로 확보하기 위한 것이다.

4. 환매권의 실행

(1) 환매권의 실행방법

- 1) 행사기간 환매는 환매기간 내에 하여야 한다(제594조 1항).
- 2) 환매의 의사표시 환매권자가 환매의무자에 대하여 환매의 의사표시를 하여야 한다. 환매권이 양도된 때에는 양수인이 환매권을 행사하여 목적재산권의 이전을 청구하게 된다. 매매의 목적물이 부동산인 경우에 환매계약과 동시에 환매권의 보류를 등기한 때에는 제3자에 대하여 효력이 있다(제592조). 즉 환매권자는 목적물의 전득자에 대해서도 환매권을 행사할 수 있다.
- 3) 환매대금의 지급 환매권자는 환매대금을 상대방에게 제공하여야 한다(제594조 1항).
- (2) 환매권의 대위행사 환매권은 양도성이 있고 일신전속권이 아니므로 환매권자(매도인)의 채권자는 이를 대위행사할 수 있다(제404조). 매수인은 법원이 선정한 감정인의 평가액에서 매도인이 반환할 금액(환매대금)을 공제한 나머지 금액을 매도인을 위하여 그의 채권자에게 변제하고 나머지가 있으면 그것을 매도인에게 지급하여 환매권을 소멸시킬 수 있다(제593조).
- (3) 공유지분의 환매 각 공유자는 자기의 지분권을 단독으로 처분하는 것이 인정되므로(제263조 참조), 그의 지분을 환매권을 보류하고서 매도할 수 있다. 그런데 공유물이 환매의 특약 후 그 환매권을 행사하기 전에 분할되는 수가 있다. 민법은 이러한 경우에 대처하기 위하여 하나의 특칙을 두고 있다. 즉 공유물의 분할에는 협의상의 분할과 재판상의 분할이 있으며 재판상의 분할은 현물분할을 원칙으로 하나 그것이 불가능하거나 또는 분할로 현저하게 값을 손상할 염려가 있는 때에는 경매를 해서 그 대금으로 분할하게 된다(제269조 참조). 이때에는 현물분할의 경우에는 환매의무자가 그 분할로 받은 부분에 대하여, 그리고 경매에 의한 매각대금을 분할하는 경우에는 환매의무자가 받을 대금, 즉 배당금에 대하여 환매권을 행사할 수 있다(제595조 본문). 분할이나 경매는 환매권자에게 통지하여야 하며, 이를 게을리한 때에는 분할이나 경매로써 매도인(환매권자)에게 대항하지 못한다.

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 가등기담보법이 적용되는 부동산 양도담보에 있어서 양도담보권자는 양도담보권이라는 일종의 담보권만 가지므로 피담보채권과 함께 양도담보권을 처분할 수 있다.
 - ② 가등기담보법이 적용되지 않는 양도담보의 경우에는 양도담보권자가 담보권이 아닌 소유권 등의 권리 자체를 가지기 때문에 담보권의 양도는 문제될 수 없다.
 - ③ 부동산실권리자명의등기에 관한 법률에 의하여 양도담보권자로부터 양수받은 제3자는 언제나 악의인 것으로 되어 말소등기를 청구할 수 없다.
 - ④ 신탁적 소유권이전설에 의하면 양도담보설정자는 목적물에 대한 처분권한이 없으므로 목적물을 제3자에게 처분할 수 없다.
 - ⑤ 담보물권설에 의하면 목적물의 소유권은 여전히 양도담보설정자에게 남아 있으므로 원칙적으로 처분할 수 있으나 등기부상의 소유명의가 양도담보권자로 되어 있어서 그 처분은 불가능하다.
- ③. 현재는 부동산실권리자명의등기에 관한 법률에 의하여 양도담보권자로부터 양수받은 제3자는 언제나 악의인 것으로 되어 말소등기를 청구할 수 있다.

2. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 양도담보권자는 설정자로부터 적법하게 담보목적물의 점유를 취득한 제3자에 대하여 소유권에 기하여 직접 그 인도를 구할 수 없다.
- ② 피담보채무가 이행지체에 빠진 경우 양도담보권자는 담보권의 실행으로 채무자나 그 점유를 이전받은 제3자에게 담보목적물의 인도를 청구할 수 있다.
- ③ 민법 제607조, 제608조에 위반한 대물변제의 약정은 대물변제의 예약으로서 무효이나 약한 의미의 양도담보를 설정하기로 하는 약정으로는 유효하다.
- ④ 별도의 특약이 없으면 양도담보권자는 담보목적물을 제3자에게 임대할 권한이 있다.
- ⑤ 유동집합물에 대한 양도담보에서 담보목적물이 양도된 경우 양수인이 별도의 자금을 투입하여 취득한 물건에 대하여는 담보의 효력이 미치지 않는다.

- ④. 부동산의 경우 양도담보권자는 담보목적물을 제3자에게 임대할 권한이 없다.

3. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 동산양도담보는 점유개정의 방식으로 설정될 수 있는바, 채무자가 채권자 甲에게 자신 소유의 동산을 점유개정 방식으로 양도담보로 제공한 후, 다시 그 동산을 다른 채권자인 乙에게 점유개정 방식으로 양도담보로 제공한 경우, 乙은 후순위의 양도담보권을 취득한다.
 - ② 준소비대차에 기한 차용금반환채무와 매매대금채무를 동시에 담보할 목적으로 마쳐진 소유권이전등기라도 그 후 후자의 채무가 변제로 소멸하고 전자의 채무만이 남게 된 경우 그 양도담보에 가등기담보등에 관한 법률이 적용되지 않는다.
 - ③ 돈사에서 대량으로 사육되는 돼지를 집합물에 대한 양도담보의 목적물로 삼은 경우, 제3자가 선의취득의 요건을 갖추지 못한 채 양도담보의 목적물인 돼지를 양수하였다면, 그 양도담보권의 효력은 양도담보의 목적물인 돼지가 낳은 새끼돼지뿐만 아니라 그 제3자가 별도의 자금을 투입하여 새로 반입한 돼지에도 미친다.
 - ④ 부동산을 채권담보의 목적으로 양도한 경우, 목적부동산에 대한 사용·수익권은 양도담보설정자에게 있으므로, 설정자와 양도담보권자 사이에 양도담보권자가 목적물을 사용·수익하기로 하는 약정이 있더라도 목적부동산을 임대할 권한은 여전히 양도담보설정자에게 있다.
 - ⑤ 성장을 계속하는 어류일지라도 특정 양어장 내의 어류 전부에 대한 양도담보계약은 유효하게 성립한다.
-
- ⑤. 판례는 양도담보권자가 담보권설정계약 당시 존재하는 집합물을 점유개정의 방법으로 그 점유를 취득하고, 그 후 양도담보설정자가 그 집합물을 이루는 개개의 물건을 반입하였다 하더라도 그때마다 별도의 양도담보권설정계약을 맺거나 점유개정의 표시를 하여야 하는 것은 아니라고 한다.

♣ 학습정리

1. 가등기담보법이 적용되는 부동산 양도담보에서 양도담보권자는 양도담보권이라는 담보권을 가지므로 피담보채권과 함께 양도담보권을 처분할 수 있다. 현재는 부동산실권리자명의등기에 관한 법률에 의하여 양도담보권자로부터 양수받은 제3자는 언제나 악의인 것으로 되어 말소등기를 청구할 수 있다.
2. 제3자가 담보목적물을 침탈한 경우 ① 신탁적 소유권이전설에 의하면, 양도담보권자는 소유권에 기한 물권적 청구권을 가지는 반면 담보제공자는 점유권에 기한 물권적 청구권만 가진다고 한다. ② 담보권설에 의하면, 양도담보권자는 물권으로서 양도담보권에 기하고, 담보제공자는 소유권에 기하여 각각 물권적 청구권을 행사하여 반환 및 방해제거를 청구할 수 있다. ③ 판례는 부동산 등기명의가 양도담보권자에게 되어 있더라도 양도담보권설정자는 불법점유자인 제3자에 대하여 그 실질적 소유자임을 주장하여 불법점유상태에 대한 배제청구를 할 수 있다고 한다.
3. 양도담보권자는 담보권설정계약 당시 존재하는 집합물을 점유개정의 방법으로 그 점유를 취득하면 그 후 양도담보설정자가 그 집합물을 이루는 개개의 물건을 반입하였다 하더라도 그 때마다 별도의 양도담보권설정계약을 맺거나 점유개정의 표시를 하여야 하는 것은 아니다.